

법의 개념

제3판

H. L. A. HART

2026 SUMMER 강의용 한국어판

강좌 외의 사용을 불허함

THE CONCEPT OF LAW

Third Edition

H. L. A. Hart

1961년 제1판의 하트의 머리말 (PREFACE)

이 책에서 나의 목적은 법(law), 강제(coercion), 도덕(morality)을 서로 다르지만 관련된 사회적 현상들로서 이해하는 일을 증진하는 것이었다. 이 책은 주로 법리학(jurisprudence) 학생을 위해 고안되었지만, 주된 관심이 법보다는 도덕철학(moral philosophy)이나 정치철학(political philosophy), 또는 사회학(sociology)에 있는 이들에게도 유익하기를 바란다. 법률가는 이 책을 분석법리학(analytical jurisprudence)의 한 에세이로 볼 것이다. 왜냐하면 이 책은 법이나 법정책(legal policy)에 대한 비판보다는 법적 사고의 일반적 틀을 명료화하는 일에 관심을 두기 때문이다. 더구나 나는 여러 지점에서 단어들의 의미에 관한 것이라고 해도 좋을 물음들을 제기해 왔다. 이를테면 나는 ‘하지 않을 수 없는 상태(being obliged)’가 ‘의무를 가진 상태(having an obligation)’와 어떻게 다른지, 어떤 규칙이 유효한 법규칙(valid rule of law)이라는 진술이 공무담당자들의 행태에 대한 예측과 어떻게 다른지, 한 사회집단이 어떤 규칙을 준수한다(observes a rule)는 단언(assertion)이 무엇을 뜻하는지, 그리고 그것이 그 구성원들이 습관적으로 어떤 일들을 한다는 단언과 어떻게 다르고 또 닮았는지를 고찰하였다. 기실 이 책의 중심 주제들 가운데 하나는, 법도 그리고 다른 어떤 형태의 사회구조도, 내가 ‘내부 진술(internal statement)’ 및 ‘외부 진술(external statement)’이라고 부른 두 가지 서로 다른 종류의 진술 사이의 몇몇 핵심적 구별들(crucial distinctions)을 이해하지 않고는 이해될 수 없다는 것이다. 이 두 종류의 진술은 사회적 규칙들이 준수되는 경우에는 언제나 둘 다 이루어질 수 있다.

분석에 대한 관심에도 불구하고 이 책은 또한 기술적 사회학(descriptive sociology)의 한 에세이로 간주될 수 있다. 단어들의 의미에 대한 탐구는 단지 단어들에만 빛을 던질 뿐이라는 주장은 거짓이기 때문이다. 사회적 상황이나 관계의 유형들 사이에 있는, 곧바로 분명하지는 않은 많은 중요한 구별들은, 관련 표현들의 표준적 용법들과 그러한 용법들이 사회적 맥락에 의존하는 방식, 그 자체도 종종 명시되지 않은 채 남는 그 방식을 검토함으로써 가장 잘 드러날 수 있다. 이 연구 분야에서는 J. L. 오스틴 교수의 말처럼 “단어들에 대한 예리한 생각으로 현상들에 대한 우리의 지각을 예리하게 하는” 일이 특히 참이다.

나는 다른 저자들에게 무겁고도 명백하게 빚지고 있다. 기실 이 책의 많은 부분은 오스틴(Austin)의 명법 이론(imperative theory)의 노선에 따라 구성된 단순한 법체계 모델의 결합들을 다룬다. 그러나 본문에서 독자는 다른 저자들에게 대한 참조나 주석을 거의 발견하지 못할 것이다. 그 대신 책의 끝에서 각 장을 읽은 뒤 읽도록 고안된 광범위한 주석들을 발견할 것이다. 거기에서 본문에 표현된 견해들은 나의 선행자들과 동시대인들의 견해들과 관련지어지며, 그들의 저작들 안에서 논변이 어떻게 더 추구될 수 있는지에 관한 제안들이 제시된다. 내가 이 방식을 취한 것은 부분적으로 이 책의 논변이 하나의 연속적 논변이고, 다른 이론들과의 비교가 그것을 끊어 놓을 것이기 때문이다. 그러나 나는 또한 교육적 목적도 가지고 있었다. 나는 이러한 배열이, 법이론에 관한 책은 일차적으로 다른 책들에 무엇이 들어 있는지를 배우는 책이라는 믿음을 약화시키기를 바란다. 이 믿음이 쓰는 이들에게 유지되는 한 그 분야에서는 거의 진전이 이루어지지 않을 것이며, 읽는 이들에게 유지되는 한 그 분야의 교육적 가치는 매우 작게 남을 수밖에 없다.

나는 너무 오랫동안 너무 많은 친구들에게 빚을 져 왔기에 이제 내가 진 모든 빚들(obligations)을 식별할 수는 없다. 그러나 A. M. 오노레(A. M. Honoré) 씨에게는 밝혀야 할 특별한 빚이 있다. 그의 상세한 비판은 사유의 많은 혼란들과 문제상의 부적절함들을 드러냈다. 나는 이것들을 제거하려고 노력했지만, 그가 못마땅해할 것이 많이 남아 있을까 두렵다. 이 책의 정치철학과 자연법(natural law)의 재해석에서 가치 있는 것은 무엇이든 G. A. 폴(G. A. Paul) 씨와의 대화 덕분이며, 교정쇄를 읽어 준 데 대해서도 그에게 감사해야 한다. 또한 나는 본문을 읽어 준 루퍼트 크로스 박사(Dr Rupert Cross)와 P. F. 스트로슨(P. F. Strawson) 씨에게도 그들의 유익한 조언과 비판에 대해 깊이 감사한다.

H. L. A. 하트 (H. L. A. HART)

1994년 제2판의 Bulloch와 Raz의 편집자 주 (Editors' Note)

(제2판을 위해 작성됨)

*The Concept of Law*는 출간된 지 불과 몇 년 만에 영어권 세계와 그 너머에서 법리학(jurisprudence)이 이해되고 연구되는 방식을 변모시켰다. 이 책의 막대한 영향은 이 책과 그 교설들(doctrines)을 논의하는 수많은 출판물들로 이어졌으며, 그것은 법이론(legal theory)의 맥락에서뿐 아니라 정치철학(political philosophy)과 도덕철학(moral philosophy)에서도 그러했다.

하트(Hart)는 여러 해 동안 *The Concept of Law*에 한 장(chapter)을 추가할 생각을 염두에 두고 있었다. 그는 그토록 큰 영향을 미친 본문을 자잘하게 손대기를 원하지 않았고, 그의 뜻에 따라 본문은 사소한 정정들(minor corrections)을 제외하고는 변경 없이 여기 출판된다. 그러나 그는 이 책에 관한 많은 논의들에 응답하기를 원했다. 그는 자신의 입장을 잘못 이해한 이들에 맞서 그 입장을 방어하고, 근거 없는 비판을 논박하며, 그가 보기에 동등하게 중요하게는 정당한 비판의 힘(force)을 인정하고, 그러한 지점들에 대응하기 위해 책의 교설들(doctrines)을 조정하는 방식들을 제안하고자 했다. 새로운 장은 처음에는 머리말(preface)로 생각되었으나 최종적으로는 후기(postscript)로 생각되었고, 그가 사망할 당시 미완성이었다. 이는 부분적으로만 그의 꿈꿨던 완벽주의(perfectionism) 때문이었다. 그것은 또한 이 기획의 현명함에 관한 지속적인 의문들, 그리고 원래 구상된 책의 테제들(theses)이 가진 생동력과 통찰을 자신이 충분히 살려낼 수 있을지에 관한 끈질긴 불확실성 때문이기도 했다. 그럼에도 그는 많은 중단에도 불구하고 후기 작업을 계속했고, 사망 당시 의도된 두 절들 가운데 첫째 절은 거의 완성되어 있었다.

제니퍼 하트(Jennifer Hart)가 우리에게 초고들을 살펴보고 그 안에 출판 가능한 것이 있는지 결정해 달라고 요청했을 때, 우리의 가장 우선적인 생각은 하트가 만족하지 않았을 어떤 것도 출판되도록 해서는 안 된다는 것이었다. 그러므로 우리는 후기의 첫째 절 대부분이 이처럼 완성된 상태에 있음을 발견

하고 기뻐다. 우리는 둘째 절을 위한 손글씨 주석들만 발견했는데, 그것들은 출판 가능하기에는 너무 단편적이고 미정형(inchoate)이었다. 대조적으로 첫째 절은 여러 판본들(versions)로 존재했고, 타자되고, 수정되고, 다시 타자되고, 다시 수정되어 있었다. 가장 최근의 판본조차도 그가 최종 상태로 생각한 것은 분명 아니었다. 연필과 바이로펜(Biro)으로 된 수많은 변경사항들(alterations)이 있다. 더욱이 하트는 더 이른 판본들을 버리지 않았고, 손 가까이에 있던 어느 판본에든 계속 작업한 것으로 보인다. 이것이 편집 작업을 더 어렵게 만들었지만, 지난 2년 동안 도입된 변경들은 대부분 문체적 뉘앙스의 변경들이었고, 그 사실 자체가 그가 본문을 있는 그대로 본질적으로 만족스러워했다는 점을 나타냈다.

우리의 과제는 대안적 판본들(alternative versions)을 비교하고, 그것들이 일치하지 않을 때에는 그중 하나에만 나타나는 본문 조각들(segments of text)이 다른 판본들에서 빠져 있는 이유가 그가 그것들을 버렸기 때문인지, 아니면 모든 수정사항들(emendations)을 편입한 하나의 판본을 그가 한 번도 갖지 못했기 때문인지를 확정하는 것이었다. 출판된 텍스트는 하트가 버리지 않았고 그가 계속 수정한 텍스트 판본들에 나타나는 모든 수정사항들을 포함한다. 때때로 텍스트 자체는 비정합적이었다. 종종 이것은 타자 담당자가 원고를 잘못 읽은 결과였음이 틀림없고, 하트는 그 오류들을 언제나 알아차리지 못했다. 다른 때에는 그것이 틀림없이, 그가 끝내 살아서 하지 못한 최종 원고 작성 단계에서 정리되었을 법한, 작성 과정에서 문장들이 자연스럽게 꼬이는 방식 때문이었다. 이런 경우 우리는 원래 텍스트를 복원하거나 최소한의 개입으로 하트의 생각(thought)을 되살리려 했다. 제6절(재량(discretion)에 관하여)은 하나의 특별한 문제를 제기했다. 우리는 그 첫 단락의 두 판본을 발견했는데, 하나는 그 지점에서 끝나는 사본 안에 있었고, 다른 하나는 그 절의 나머지를 포함하는 사본 안에 있었다. 잘린 판본(truncated version)은 그의 가장 최근 수정들 중 많은 것을 편입한 사본 안에 있었고, 그가 결코 버린 적이 없었으며, 후기의 일반적 논의와도 부합했으므로, 우리는 두 판본 모두 출판되도록 허용하기로 결정했다. 이어지지 않은 판본은 미주(endnote)에 나타난다.

하트는 주석들을, 대부분 참조들(references)인 그 주석들을, 타자하도록 한

적이 결코 없었다. 그는 손글씨 주석 판본을 가지고 있었고, 그 단서들(cues)은 본문 가장 이른 타자 사본에서 가장 쉽게 추적되었다. 나중에 그는 가끔 여백 논평에 참조들을 덧붙였지만, 대체로 이것들은 불완전했고, 때로는 그 참조를 추적할 필요만을 표시했다. 티머시 엔디컷(Timothy Endicott)은 모든 참조들을 확인했고, 불완전한 것들을 모두 추적했으며, 하트가 원천(source)을 지목하지 않고 드워킨(Dworkin)을 인용하거나 그를 가깝게 풀어쓴 곳에는 참조들을 추가했다. 엔디컷은 또한 인용문들이 부정확했던 곳에서 본문을 바로잡았다. 폭넓은 조사와 수완(resourcefulness)을 수반한 이 작업 과정에서, 그는 위에서 제시된 편집 지침들에 부합하는 본문에 대한 몇 가지 정정사항들도 제안했고, 우리는 이를 감사히 편입하였다.

우리 마음속에는, 기회가 주어졌다면 하트가 출판 전에 텍스트를 더 다듬고 개선했을 것이라는 데 아무 의심도 없다. 그러나 우리는 출판된 후기(postscript)가 드워킨의 많은 논변들(arguments)에 대한 그의 숙고된 응답을 담고 있다고 믿는다.

페넬로페 A. 불로흐 (Penelope A. Bulloch) 조셉 라즈 (Joseph Raz)

1994

2012년 제3판의 Leslie Green의 머리말

(PREFACE TO THE THIRD EDITION)

*The Concept of Law*는 허버트 하트(Herbert Hart)가 옥스퍼드 대학교(University of Oxford)에서 법학도들을 대상으로 진행한 법리학(jurisprudence) 입문 강의들에 기반을 두고 있다. 이 책은 1961년 초판이 출간된 뒤, 영어로 쓰인 법철학(legal philosophy) 책 가운데 가장 영향력 있는 책으로 빠르게 자리 잡았다. 법학, 철학, 정치이론의 학자들은 오늘날까지도 이 책의 논변들(arguments)을 발전시키고, 그 위에 구축하며, 비판하고 있다. 동시에 이 책은 여전히 그 주제에 대한 널리 사용되는 입문서로 남아 있으며, 원어로든 그 많은 번역본들 가운데 하나로든 세계 곳곳의 학생들에게 읽히고 있다.

초판 출간 50주년이 가까워졌을 무렵, 옥스퍼드 대학출판부(Oxford University Press)는 새로운 판을 준비할 가능성에 관해 내게 제안해 왔다. 1994년에 페넬로페 불로흐(Penelope Bulloch)와 조셉 라즈(Joseph Raz)의 편집 아래 출판된 사후 제2판(posthumous second edition)은 하트가 생전에 발표하지 않았던 로널드 드워킨(Ronald Dworkin)에 대한 응답들을 바탕으로 한 후기(Postscript)를 포함하고 있었다. 그 판은 하트의 이론들 및 법리학 일반(jurisprudence in general)에 관한 새로운 논쟁의 물결을 촉발했다. 이후 몇 차례 더 재쇄가 이루어진 뒤, 본문에 남아 있는 몇 가지 오류를 바로잡고 책을 새로 디자인할 때가 되었다. 이는 몇몇 새 자료를 포함할 가능성의 문을 열었다.

*The Concept of Law*는 변호(apology)가 필요 없는 저작이지만, 반세기가 지난 지금 더 이상 서론(introduction)이 필요 없다고 할 수는 없다. 이어지는 서론에서 나는 이 책의 몇몇 주요 주제들을 부각하고, 몇 가지 비판을 간략히 그려 보이며, 가장 중요한 것으로서 이 책의 기획에 대한 몇몇 오해를 미연에 막으려 한다. 하트는 참조들(references)을 제공하고, 논점들을 상세히 풀며, 추가 읽을거리들을 제안하는 주석들(notes)을 덧붙였다. 이것들은 그대로 보존되었다. 그러나 그 읽을거리들 가운데 많은 것은 이후 문헌으로 대체되었고, 뒤이어 나온 많은 책들과 논문들이 그의 논변들을 이어 논의하고 있다. 그러므로

학생들을 몇몇 핵심 논쟁들의 방향으로 이끌기 위해 새로운 주석 묶음이 추가되었다. 마지막으로, 더 이른 저작들은 초판의 쪽수(pagination)를 기준으로 인용을 제시하지만, 그 판의 사본들은 이제 점점 더 적게 유통되고 있다. 그리고 그 쪽수에 익숙한 사람들도 점점 더 적게 유통되고 있다. 따라서 나는 제2판의 쪽수를 따르기로 결정했다.

서론(Introduction)은 내가 이전에 발표한 논문 「The Concept of Law Revisited」(1997년 제94권 *Michigan Law Review* 1687쪽)의 자료를 끌어온다. 이 기획을 처음 제안하고 여러 지점에서 귀중한 조언을 준 옥스퍼드 대학출판부의 알렉스 플래치(Alex Flach)에게 깊이 감사드린다. 내 동료 존 피니스(John Finnis)는 하트의 본문에 대한 정정들(corrections)을 도왔고, 톰 애덤스(Tom Adams)는 주석들(Notes)을 위한 조사 작업을 도왔다. 두 사람 모두에게 따뜻한 감사를 전한다. 그리고 서론을 읽고 논평해 준 드니즈 레옴(Denise Réaume)에게 특히 감사드린다.

레슬리 그린(Leslie Green)

옥스퍼드, 베일리얼 칼리지(Balliol College)

2012년 트리니티(Trinity 2012)

2012년 제3판의 Leslie Green의 서론

(INTRODUCTION)

1. 하트의 메시지 (HART'S MESSAGE)

법(law)은 사회적 구성물(social construction)이다. 그것은 역사적으로 우연히 특정 사회들에 나타난 특징이며, 그 출현은 제도들에 의해 운영되는 체계적인 사회적 통제(social control) 형식의 등장으로 표시된다. 어떤 면에서 법은 관습(custom)을 대체하지만, 또 다른 면에서는 관습에 기초해 있다. 법은 인간의 행위를 지시하고 평가하는 일차적 규칙(primary rules)들과, 이러한 일차적 규칙들을 식별하고(identify), 시행하며(enforce), 변경하는 방법에 관한 이차적 사회규칙들(secondary social rules)로 이루어진 하나의 체계다. 이러한 구성은 특정한 맥락에서 유익할 수 있지만, 오직 일부 맥락에서만 그렇고 언제나 일정한 대가를 치른다. 왜냐하면 그것은 부정의(injustice)의 특별한 위험들과, 그 수범자들(subjects)을 그들의 삶을 지배하는 가장 중요한 규범들 일부로부터 소외시키는 위험들을 제기하기 때문이다. 따라서 법에 대해 우리가 취해야 할 적절한 태도는 찬양(celebration)보다 경계(caution)다. 더욱이 법은 때로 자신에게 없는 객관성(objectivity)을 가장하기도 한다. 왜냐하면 판사들이 무엇이라고 말하든 실제로는 그들이 법을 창출하는 중대한 권력(power)을 행사하기 때문이다. 따라서 법과 재판(adjudication)은 정치적이다(political). 그리고 다른 방식으로, 법이론(legal theory) 역시 정치적이다. ‘순수한 법이론(pure theory of law)’은 있을 수 없다. 법 자체에서 끌어온 개념들만으로 세워진 법리학(jurisprudence)은 법의 본성을 이해하기에 충분하지 않다. 그것은 사회이론(social theory)과 철학적 탐구(philosophic inquiry)의 자원들에서 도움을 받아야 한다. 그러므로 법리학은 법률가들이나 법학 교수들의 전유물도 아니며, 심지어 그들의 자연스러운 서식지도 아니다. 그것은 더 일반적인 정치이론(political theory)의 한 부분일 뿐이다. 그 가치는 의뢰인들에게 조언하거나 사건들을 결정하도록 돕는데 있는 것이 아니라, 우리의 문화와 제도들을 이해하고 그것들에 대한 어떤

도덕적 평가(moral assessment)를 뒷받침하는 데 있다. 그러한 평가는 법의 본성뿐 아니라 도덕(morality)의 본성에도 민감해야 한다. 도덕은 복수적이고 상충하는 가치들로 이루어져 있기 때문이다.

이상은 현대 법철학에서 가장 영향력 있는 저작들 가운데 하나인 H. L. A. 하트의 법의 개념(The Concept of Law)의 가장 중요한 관념들이다. 그러나 다른 중요한 책들과 마찬가지로, 하트의 책도 실제 독해만큼이나 풍문(rumour)으로 알려져 있다. 그 책에 대해 알고는 있지만 실제로는 그 책을 알지 못하는 이들에게는, 방금 제시한 압축적 요약이 낯설게 들릴지도 모른다. 그들이 들은 바는 그들로 하여금 이렇게 의아하게 만든다. 하트는 법이 규칙들의 폐쇄적 논리 체계라고 생각하지 않는가? 그는 법이 좋은 것, 곧 사회질서의 다른 형태들 안의 결함들을 치유하는 사회적 성취라고 생각하지 않는가? 그는 법들은 대체로 명확하며 법원들에 의해 도덕적 가치들과 무관하게 적용되어야 한다고 생각하지 않는가? 그는 법과 도덕이 개념적으로 분리되어 있으며 서로 분리해 두어야 한다고 생각하지 않는가? 그리고 그는 법리학이 가치중립적이며, 그 진리들이 ‘법(law)’ 같은 단어들의 참된 의미에 주의를 기울임으로써 확립될 수 있다고 생각하지 않는가?

짧은 답은 ‘아니다’ 이다. 하트는 그 어느 것도 생각하지 않는다. 하트의 메시지에 관한 이 왜곡된 판본들은 세 가지 원천을 가진다. 첫째는 철학 전반에 익숙한 어려움이다. 그가 다루는 문제들은 복잡하며, 참과 거짓 사이의 간격은 종종 미묘하거나 쉽게 간과되는 구별이다. (예컨대 법과 도덕이 분리 가능하다고 주장하는 것은 그것들이 분리되어 있다고 주장하는 것이 아니다.) 둘째는 역사적 요인이다. 반세기가 지난 뒤에는 이 책의 언어와 사례들이 사회적으로, 때로는 철학적으로도 멀게 느껴진다. 오늘날 우리 중 많은 이는 관습적 사회질서들을 여전히 ‘원시적(primitive)’ 이라고 지칭하거나, 어떤 것의 본성에 관한 설명을 그것의 개념에 대한 ‘해명(elucidation)’ 이라고 부르지는 않을 것이다. 셋째는 독자의 기대와 관련된다. 모든 책에는, 말하자면 ‘암시된 독자(implied reader)’ 가 있다. 하트의 경우 그것은 우리의 주요 정치 제도들 가운데 하나의 본성과 그것이 도덕 및 강제력(coercive force)과 맺는 관계들에 관해 철학적으로 호기심을 가진 사람이다. 그러나 그의 실제 독자가 언제나 그런 것은 아니다.

어떤 이들은 실천적 도움을 찾아 법리학으로 향한다. 예컨대 그들은 우리가 현법들을 어떻게 해석해야 하는지, 또는 어떤 종류의 사람들을 판사들로 선택해야 하는지를 알고 싶어 한다. 그들은 법이론에 관한 책이 법에 대해 가지는 관계가, 급식 이론에 관한 책이 급식에 대해 가지는 관계와 같을 것이라고 상상한다. 곧 다양한 상이한 경우들에 적용 가능한 일반적인 ‘방법(how-to)’ 일 것이라고 상상하는 것이다.

하트의 책은 요약이 필요 없을 만큼 충분히 명료하지만, 그 주제들 일부를 탐색하는 일은 그러한 오해들을 막는 데 도움이 될 수 있다. 나는 법과 사회적 규칙들(social rules), 강제(coercion), 도덕(morality)에 관한 그의 견해들을 검토한 뒤 몇 가지 방법론적 논점들을 간단히 훑어볼 것이다. 나는 중립으로 남으려 노력하지 않는다. 하트의 법이론은 부분적으로 옳바르고, 부분적으로 잘못되었으며, 여기저기서 약간 모호하다. 그러나 이어지는 것은 평가(assessment)가 아니다. 나는 사람들이 빗나가거나 빗나가게 되는 영역들을 부각하고 몇몇 지점들에 관해 비판적 논평을 하겠지만, 평정(appraisal)은 독자의 몫이다.

2. 사회적 구성물로서의 법 (LAW AS A SOCIAL CONSTRUCTION)

법들(laws)과 법체계들(legal systems)은 자연(nature)의 사항들이 아니라 인위적 산물(artifice)의 사항들이다. 우리는 그것들이 사회적 구성물들(social constructions)이라고 말할 수도 있다. 이것이 언급할 가치가 있는 어떤 대비를 표시하는가? 어떤 이들은 모든 것이 그렇다고 생각하기 때문에 법이 사회적 구성물이라고 생각한다. 데리다(Derrida)는 “*il n’y a pas de hors-texte*” (텍스트 바깥은 없다)라고 곧잘 짓궂게 말했다. 그것이 이해 가능하더라도 그것은 무관할 것이다. 누군가가 “인종(race)은 사회적 구성물이다” 라고 말하고 나서, “경찰봉들(truncheons)과 감옥들(prisons)처럼 말이다” 라고 해명한다고 상상해 보라. 그것은 누군가가 신(God)은 존재하지 않는다고 말했는데, 알고 보니 그 대화 상대자는 개들(dogs)의 존재도 믿지 않는다는 사실을 알게 되는 것과 같은 것이다. 내가 법이 사회적 구성물이라고 말할 때, 내 뜻은 그것이 어떤 것들은 그렇지 않은 방식으로 사회적 구성물이라는 것이다. 법은 명령들(orders)과 규칙

들(rules) 같은 제도적 사실들(institutional facts)로 이루어져 있으며, 그것들은 사람들이 사고하고 행위함으로써 만들어진다.¹ 그러나 법은 사회적으로 구성되지 않은 물리적 우주 안에 존재하며, 또한 사회적으로 구성되지 않은 사람들에게 의해 그리고 그 사람들을 위해 창출된다. 아마도 이것은 진부한 말일 수 있다. 유행에 맞는 척하기 위해 ‘예절의 사회적 구성(social construction of etiquette)’에 관해 말할 수도 있겠지만, 거기에는 별 의미가 없다. 예절들(manners)이 관행적(conventional)이라는 것은 모두가 이미 알고 있기 때문이다.² 그것들은 공통 실천(common practice)에 의존하고, 역사를 가지며, 장소에 따라 달라진다. 법도 그와 같다는 것은 눈이 부실 만큼 명백하지 않은가? 그렇지만 스토아적 ‘자연법(natural law)’ 견해에 관한 다음의 유명한 요약을 보라.

진정한 법은 자연(Nature)과 일치하는 올바른 이성(right reason)이다. 그것은 보편적으로 적용되며, 변하지 않고 영원하다... 로마와 아테네에서 다른 법이 있을 수 없고, 현재와 미래에 서로 다른 법이 존재할 수 없으며, 오직 하나의 영원하고 불변하는 법만이 모든 민족과 모든 시대에 타당할 것이다...³

이 영원하고 보편적인 법은 누군가가 만들어낸 것이 아니며, 우리는 그것을 아무도 바꿀 수 없다고 듣는다. 자연법(natural law)은 의지(will)의 문제가 아니라 이성(reason)의 문제다. 이 모든 것을 여전히 믿는 법이론가들을 찾기는 어렵지만,⁴ 그 일부를 믿는 이들은 많다. 예컨대 로널드 드워킨(Ronald Dworkin)은 우리의 법이 조약들(treaties), 관습들(customs), 헌법들(constitutions), 제정법들(statutes), 판례들(cases)에서 발견되는 규범들뿐 아니라, 그곳에서 발견되는 규범들에 대한 최선의 정당화(best justification)를 제공하는 도덕 원칙들(moral

¹예컨대 John Searle, *The Construction of Social Reality* (Allen Lane, 1995); Neil MacCormick, *Institutions of Law: An Essay in Legal Theory* (Oxford University Press, 2007) 참조.

²Ian Hacking, *The Social Construction of What?* (Harvard University Press, 1999) 비교 참조.

³Cicero, *De Re Republica* III. xii. 33, tr. C. W. Keyes (Harvard University Press, Loeb Classical Library, 1943) 211.

⁴아마 John Finnis의 *Natural Law and Natural Rights* (2nd edn., Oxford University Press, 2011)가 이에 가장 가까울 것이다.

principles)도 포함한다고 논변한다.⁵ 그의 설명에 따르면, 도덕 원칙들에 의해 정당화되는 것들(things justified)은 사회적으로 구성되지만, 정당화들 자체는 그렇지 않다. 정당화(justification)는 사건(event)이 아니라는 점을 명심하는 것이 중요하다. 그것은 논증(argument)이다. 정당화를 믿거나(believing), 수용하거나(accepting), 단언하는(asserting) 것은 사건들이다. 그러나 드워킨은 법이 구성된 물건들에 사람들이 그것의 정당화라고 믿었거나, 그것의 정당화로 수용했거나, 그것의 정당화라고 단언한 것들을 더한 것으로 이루어진다고 말하지 않는다. 그는 법이 구성된 물건들에 그것에 대해 실제로 정당화들이 도덕 원칙들을 더한 것으로 이루어진다고 말한다. 어떤 것이 법이기에 충분한 조건이, 그것이 이미 법인 다른 어떤 것에 대한 최선의 도덕적 정당화이거나 그 정당화로부터 따라 나온다는 데 있다고 믿는다면, 당신은 키케로(Cicero)와 꼭 마찬가지로, ‘올바른 이성(right reason)’의 요구사항이라는 사실에 그 지위를 빚지고 있는 법이 있다고 믿는 것이다. 우리가 하는 어떤 일도 건전한 정당화(sound justification)를 건전하지 않은 것으로 바꿀 수 없으므로, 당신은 또한 우리가 바꿀 수 없는 법의 존재를 받아들여야 한다. 그리고 어떤 도덕 원칙이 어떤 배열을 정당화하는지는 누가 그것이 그렇다는 점을 알거나 믿는지에 의존하지 않으므로, 누구도 들어본 적 없는 법, 곧 많은 법이 있을 수 있다. 도덕적 지식의 전망에 따라서는, 알 수조차 없는 법도 있을 수 있다.

하트(Hart)의 접근은 그 모든 것을 거부한다. 법 안에 있는 것은 무엇이든 어떤 개인이나 집단이 의도적으로든 우연히든 그것을 거기에 두었기 때문에 거기에 있다. 그것은 모두 역사를 가진다. 그것은 모두 바뀔 수 있다. 그것은 모두 알려져 있거나 알려질 수 있다. 우리의 법들 중 일부는 좋은 정당화들(good justifications)을 가지지만, 일부는 그렇지 않으며, 어쨌든 정당화들은 법을 만들기에 충분하지 않다. 그렇게 하려면 실제 인간의 개입(actual human intervention)이 필요하다. 명령들(orders)이 내려져야 하고, 규칙들이 적용되어야 하며, 결정들이 내려져야 하고, 관습들이 출현해야 하며, 또는 정당화들이 지지되거나 단언되어야 한다.

⁵Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Harvard University Press, 1978), chap. 4; Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Harvard University Press, 1986), chaps. 2–3.

법철학자들은 그러한 인간 개입들(human interventions)에 의해 설정된 것들을 포괄하기 위해 고풍스러운 용어를 자주 사용한다. 그들은 그것들이 ‘정립되었다(posited)’고 말한다. 모든 법이 정립되어 있다고 생각하는 사람은 법실증주의자(legal positivist)이며, 사회구성주의자들(social constructivists)은 그 한 종류다. 그러나 모든 실증주의자가 사회구성주의자인 것은 아니다. 한스 켈젠(Hans Kelsen)은 그렇지 않았다. 그는 모든 법들(laws)이 정립된다고 생각했지만, 모든 법체계에는 정립된 것이 아니라 오직 ‘전제된(presupposed)’ 규범(norm)이 적어도 하나 포함된다고도 생각했다.⁶ 켈젠에 따르면, 법규범(legal norm)은 그것이 유효한(valid) 경우에만 존재하며, 여기서 ‘유효한(valid)’이란 그 수범자들(subjects)이 그것에 부합해야 한다(ought to conform)는 뜻이다. 그는 흄(Hume)과 칸트(Kant)를 따라 ‘있다(is)’ 만으로부터는 ‘마땅하다(ought)’가 나올 수 없다고 보았다. 그러므로 어떤 사회적 구성물(social construction)도, 또는 그것들의 묶음도, 결코 하나의 규범으로 합쳐질 수 없다. 그것들이 규범들을 산출하려면, 한 사회의 근본적 법제정 과정들(fundamental law-making processes)은 유효한 것으로 전제되어야 한다. 원초적 헌법(original constitution)이 진정한 권위를 가질 필요가 있다. 그렇지 않으면 그 아래의 어떤 것도 그렇지 않다. 따라서 우리가 그 기초 규칙들(ground rules) 아래에서 창출된 자료들을 법으로 간주하려면, 원초적 헌법이 구속력 있다고 전제할 필요가 있다. 이제 전제(presupposition)는 정당화(justification)와 마찬가지로 사건(event)이 아니다. 켈젠은 법이 무엇을 요구하는지 알고 싶다면 사람들이 실제로 무엇을 정립했는지를 알아야 한다는 점을 부정하지 않았다. 그러나 그는 그들의 활동들의 산물을 법으로서(as law) 알고 싶다면, 사회적이거나 역사적이지 않은 무언가를 덧붙일 필요가 있다고 논변했다. 그러므로 켈젠은 법실증주의자이지만 사회구성주의자는 아니다. 그가 사회적으로 구성된 규범들을 우리가 연구하는 방식들, 곧 사회학적, 심리학적, 역사적 탐구를 법리학(jurisprudence) 안의 ‘이질적 요소들(alien elements)’로 여기는 이유가 여기에 있다.⁷

⁶Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Max Knight tr., 2nd edn., University of California Press, 1967) 193–205.

⁷Ibid. 1.

하트(Hart)는 켈젠의 견해 역시 거부한다.⁸ 법의 궁극적 기초는 정당화도 전제도 아니라, 사람들이 특정한 것들을 사고하고 행함으로써 생겨나는 사회적 구성물이다. 법리학(jurisprudence)은 이 구성물이 무엇인지, 그리고 그것이 더 일상적인 사회적 사실들로부터 어떻게 구축되는지를 설명한다. 하트는 이 설명을 ‘기술적 사회학에 관한 하나의 에세이(an essay in descriptive sociology)’라고 부르기까지 한다(vi).⁹ 그것은 아마도 너무 멀리 나아간 말이다. 그것은 분석적 법철학(analytic legal philosophy)의 한 에세이지만, 이론적으로 예리한 법사회학이 유익하게 사용할 수 있을 개념들에 의존하는 에세이다. 그중 가장 중요한 것은 사회적 규칙(social rule)이라는 개념이다.

(i) 법, 규칙, 관행 (Law, Rules, and Conventions)

하트는 홉스(Hobbes), 벤담(Bentham), 오스틴(Austin)에게서 발견되는 더 이른 실증주의 설명을 거부한 뒤, 규칙들(rules)이 법의 가장 중요한 구성 단위들(building blocks)이라고 생각하게 되었다. 그들은 법이 사령들(commands), 위협들(threats), 복종(obedience)으로 구성된다고 생각했다. 주권자(sov​er​eign)는 대부분의 다른 사람들로부터 습관적 복종(habitual obedience)을 향유하지만 스스로는 다른 누구에게도 습관적으로 복종하지 않는 개인이나 집단이다. 법은 힘(force)의 위협에 의해 뒷받침된 주권자의 일반적 사령(general command)이다.

1977년에 미셸 푸코(Michel Foucault)는 이렇게 말했다. “우리에게 필요한 것은 ... 주권의 문제를 중심으로 세워지지 않는 정치철학이다... 우리는 왕의 목을 잘라야 한다. 정치이론에서는 그것이 아직 이루어져야 한다.”¹⁰ 이 국왕 살해(regicide)의 소식은 영국해협을 건너지 못했음이 틀림없다. 하트는 이미 오래전에 그 일을 끝냈기 때문이다. 제III장과 제IV장에서 그는 모든 법들이

⁸아래 292-3쪽 및 H. L. A. Hart, *Essays in Jurisprudence and Philosophy* (Oxford University Press, 1983)에 수록된 하트의 논문 「Kelsen Visited」와 「Kelsen's Doctrine of the Unity of Law」 참조.

⁹괄호 안의 쪽수 참조는 모두 이 책을 가리킨다.

¹⁰Michel Foucault, 'Truth and Power' in his *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977* (Colin Gordon ed., Vintage, 1980) 121.

사령들(commands)인 것은 아니라는 점, 법체계가 주권자의 속성들을 지닌 어떤 개인이나 집단을 가질 필요는 없다는 점, 법은 그 창출자들이 사라진 뒤에도 계속된다는 점, 그리고 위협들은 사람들에게 어떤 일들을 하지 않을 수 없게 만들 수는 있지만 그것들을 할 의무들을 창출할 수는 없다는 점을 보여준다. 근처에서 주권 설명에 빠져 있는 것은 사회적 규칙이라는 개념이다. 규칙들을 이해하고 나면, 우리는 그것들이 주권, 권한들(powers), 관할(jurisdiction), 유효성(validity), 권위(authority), 법원들(courts), 법들(laws), 법체계들(legal systems), 그리고 하트가 논변하듯 심지어 정의의 한 종류까지 포함하여 법 안의 많은 현상들을 설명하는 열쇠임을 알게 될 것이다. 법 자체는 사회적 규칙들의 결합(union)이다. 곧 사람들에게 책무들(duties)을 부과하거나 권한들(powers)을 부여함으로써 행위를 안내하는 일차 규칙들(primary rules)과, 그 일차 규칙들의 식별, 변경, 집행을 마련하는 이차 규칙들(secondary rules)의 결합이다. 이차 규칙들 가운데 궁극적 승인 규칙(rule of recognition)은 특별한 중요성을 가진다. 일차 규칙들을 적용하는 역할을 맡은 이들의 관습적 실천(customary practice)인 승인 규칙은 어떤 행위들이 법을 창출하는지를 정함으로써 법적 유효성의 기준들(criteria of legal validity)을 제공한다. 따라서 한 법체계의 근본 헌법(fundamental constitution)은 도덕적 정당화들(moral justifications)이나 논리적 전제들(logical presuppositions)에 기초해 있는 것이 아니라, ‘법원들(courts), 공무담당자들(officials), 사적 개인들(private persons)의 복합적인 … 실천(complex … practice)’에 의해 창출된 이 관습적 사회규칙(customary social rule)에 기초해 있다(107쪽). 하트는 영국의 승인 규칙이 “여왕과 의회가 제정하는 것은 무엇이든 법이다(Whatever the Queen in Parliament enacts is law)”와 같은 것이라고 제안한다. 그렇다면 의회 제정물들(Parliamentary enactments)은 그 도덕적 자격 근거들(moral credentials) 때문에도, 어떤 논리적 전제 때문에도 법인 것이 아니라, 실제로 실천되는 관습적 규칙이 그것들을 그러한 것으로 인정하기 때문에 법이다.

따라서 법은 사회적 규칙들(social rules)로 구성된다. 그러면 규칙들 자체는 어떤가? 그것들 역시 사회적 구성물들이며, 하트는 그것들이 실천(practice)으로 이루어진다고 말한다. (이것은 흔히 ‘규칙의 실천 이론(practice theory of

rules)’ 이라고 불린다.) 관습적 규칙들(customary rules)은 행태적 반복적 일양성 (behavioural regularity) 안에 ‘외부 측면(external aspect)’ 을 가진다. 사람들은 공통된 방식으로 행위한다. (규칙에 따라, 이것은 그 규칙이 요구하는 것에 부합하는 일이나 그것을 타인들에게 적용하는 일을 포함할 수 있다.) 규칙들은 또한 하트가 ‘수용(acceptance)’ 이라고 부르는 복합적 태도를 포함하는 ‘내부 측면(internal aspect)’ 을 가진다. 수용이란, 그 반복적 일양성을 행위를 안내하고 평가하는 기준(standard)으로 사용하려는 의향이며, 특히 부합(conformity)을 칭찬하고 위반들(breaches)을 비판하며, 그러한 칭찬과 비판을 적절한 것으로 대우하려는 의향이다. 수용은 찬동(approval)을 요구하지 않는다. 그것은 사람들이 그 규칙에 대해 어떻게 느끼는가의 문제가 아니라, 그것을 사용하려는 그들의 의향의 문제다. 사람들은 하트의 의미에서 규칙들을 수용할 수 있다. 그 규칙들이 좋은 규칙들이라고 생각해서, 또는 다른 사람들을 기쁘게 하려고, 또는 두려움이나 동조주의(conformism) 때문에 그렇게 할 수 있다(56-7, 115, 257쪽). 밀턴(Milton)을 믿어도 된다면, 사탄(Satan)조차도 그것이 나쁜 규칙이라는 근거에서 하나의 규칙을 수용할 수 있다. “악이여, 나의 선이 되어라 (Evil be thou my good).” 중요한 전부는 사람들이 어떤 기준에 수렴하고, 그것을 행위의 지침으로 사용하며, 그렇게 함으로써 그것을 규범적인 것(normative)으로 대우한다는 점이다.

규칙의 실천 이론(practice theory of rules)은 논쟁적이다. 몇 가지 난점들을 주목한 다음, 일정한 반론들을 빚겨 가려는 하트의 시도로 넘어가자. 하트는 규칙의 존재에 대한 하나의 검사 기준(test)을 원한다. 그 검사 기준은 규칙 따르기와 우연적이거나 순전히 습관적인 행태상의 패턴들(patterns in behaviour)을 구별하고, 관습적 규칙이 의무적이거나 구속력 있는(obligatory or binding) 것이 된다는 것이 무엇인지를 설명해야 한다. 그러나 실천 이론은 이를 제공하지 못한다.¹¹ 사회적 실천들이 아닌 규칙들이 있다(예컨대 개인의 규칙들). 규칙들이 아닌 수용된 사회적 실천들도 있다(예컨대 저항하기보다 강도에게

¹¹Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (rev. edn., Harvard University Press, 1978) 48-58쪽; Joseph Raz, *Practical Reason and Norms* (2nd edn., Oxford University Press, 1999) 49-58쪽 참조.

지갑을 넘겨주는 공통적이고 수용된 실천). 그리고 규칙을 인용하는 것은 자기 행위에 대한 정당화로서 제시될 수 있지, 단지 그것에 대한 어떤 정당화가 있다고 생각한다는 징후(sign)에 그치는 것은 아니다. 이 모든 것은 실천 이론과 맞지 않는다. 더구나 의무라는 관념(the idea of obligation)을 이해하기 위해 사회적 규칙이라는 개념이 필요한지도 명확하지 않다. 어떤 사람은 항공 여행에 대해 탄소 상쇄(carbon offsets)를 구매할 의무가 있다고 믿으면서도, 그것을 하는 공통 실천이 있다고 상정하지 않을 수 있다.

이 책의 후기(Postscript)에서 하트는 자신의 설명을 한정함으로써 그러한 비판들에 대응하려 한다. 이제 그는 모든 규칙들이 실천 규칙들(practice rules)은 아니라고 인정한다. 그러나 관행적 규칙들(conventional rules)은 그러하며, 그것들이 법의 기초를 이룬다. 어떤 규칙은 “한 집단의 그것들에 대한 일반적 부합(general conformity)이 그 개별 구성원들이 수용할 이유들의 일부인 경우 …” 관행적이다(255쪽). 우측 통행 규칙은 관행이다. 대부분의 다른 사람들이 따르지 않는다면 사람들도 그것을 따르지 않을 것이기 때문이다. 졸릴 때 운전해서는 안 된다는 규칙은 관련된 의미에서 관행이 아니다. 졸린 운전자들이 많은 도로에서는 깨어 있을 이유가 더 많지, 더 적지 않기 때문이다. 하트는 궁극적 승인 규칙(rule of recognition)이 관행이라고 본다. “[분명히] 영국 판사가 의회의 입법을 다른 원천들에 대해 최고성을 갖는 법의 원천(a source of law having supremacy over other sources)으로 대우하는 이유(또는 미국 판사가 헌법을 그렇게 대우하는 이유)는, 그의 사법 동료들이 그들의 선임자들이 그래왔듯이 이에 의견을 같이한다는 사실을 포함한다”(267쪽). 법은 “판사들과 법률가들이 수용한 단지 하나의 관행적 승인 규칙(a mere conventional rule of recognition)”에 기초해 있다(267쪽). 두 번째 정식화에서는 ‘단지(mere)’라는 말을 삭제해야 한다. 공무담당자들(officials)이 승인 규칙(또는 다른 근본 규칙들)에 부합하는 유일한 이유가 다른 이들이 그렇게 하기 때문이라고 생각하는 것은 그럴듯하지 않다. 승인 규칙들은 전적으로 자의적인 것으로 믿어지는 경우가 드물다(설령 주변부에서는 자의적인 것으로 믿어지더라도 그렇다). 예컨대 영국에서 법의 원천으로서 의회 제정법들(parliamentary statutes)의 최고성은, 그것들을 최고적인 것으로 대우하는 공통 실천에만 기초해 있는 것이 아니라, 이

실천이 민주적이거나 우리 문화의 중심에 있다는 믿음에도 기초해 있을 수 있다. 미국에서 헌법의 최고성은 공통 실천에만 기초해 있는 것이 아니라, 그것이 정의로운 정부 형태를 수립한다는 믿음이나, 신의를 지키는 것이 중요한 지혜로운 사람들이 그것을 정했다는 믿음에도 기초해 있을 수 있다. 그러한 믿음들은 올바른 필요가 없고, 균일하게 공유될 필요도 없다. 그러나 그러한 믿음들 중 일부는 보통 공통 실천에 근거한 이유들과 함께 존재한다. 하트의 의미에서 승인 규칙이 관행적이기 위해 필요한 것은, 공무담당자들이 그것을 적용할 다른 어떤 이유들을 가지고 있든, 그러한 취지의 공유된 공통 실천(shared common practice to that effect)도 없었다면 그들이 그렇게 하지 않았을 것이라는 점이다.

이러한 수정을 감안하더라도, 맞서야 할 또 다른 문제가 있다.¹² 승인 규칙(rule of recognition)은 의무- 또는 책무부과 규칙(obligation- or duty-imposing rule)이다. 그것은 법의 원천들(sources of law)을 식별할 뿐 아니라, 판사들과 다른 이들에게 그렇게 식별된 법을 적용하라고 지시한다. 실천 이론에 따르면, 사회적 규칙이 책무(duty)를 부과하는 것은 다음의 경우 그리고 오직 그 경우이다. (a) 그 규칙이 사회적으로 필요하다고 믿어지고, (b) 강한 사회적 압력(social pressure)에 의해 강화되며, (c) 그것이 규범-수범자(norm-subject)의 당면한 자기이익(self-interest)과 충돌할 수 있는 경우이다(86-8쪽). 이러한 조건들이 여기서 충족되는가? 그 조건들은 사실적(factual)이므로, 어느 주어진 사례에서든 우리는 조사할 필요가 있을 것이다. 법원들과 다른 이들이 법에 대한 확정된 검사 기준들(settled tests for law)을 가지는 것이 필요하다고 생각할 개연성이 있고, 그것들로부터의 중대한 이탈은 부합하라는 강한 압력에 의해 강화될 것임은 그럴듯해 보인다. (예컨대 미국 지방법원이 대법원의 모든 판결들을 단순히 무시하거나, 샤리아법(Sharia)을 구속력 있는 법의 원천으로 적용하기 시작한다면 어떤 반응이 나타날지 상상해 보라.) 그러나 관행적 규칙의 경우, 조건 (c)가 왜 충족되는지를 보기는 더 어렵다. 어떤 관행적 기준(conventional standard)이 중요하다고 믿어질수록, 그것이 관행적임이 알려져

¹²이 논점에 관한 하트 논증의 다른 의문점들에 대해서는 Leslie Green, 「Positivism and Conventionalism」 (1999) 12 *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 35; Julie Dickson, 「Is the Rule of Recognition Really a Conventional Rule?」 (2007) 27 *Oxford Journal of Legal Studies* 373 참조.

있다고 가정할 때 비부합(non-conformity)에 대한 유혹은 더 적어진다. 우리는 모두 좌측으로 운전할 수도 있고 우측으로 운전할 수도 있지만, 공통 실천이 있을 때에는 대열을 이탈하여 잘못된 쪽으로 운전할 유혹이 별로 없다. 이탈하려는 유혹은 다른 종류의 규칙들, 특히 무임승차에 노출되는 공공재(public goods)를 지탱하는 규칙들의 특징이다. 그러나 규칙이 관행적일 때에는 책무와 욕망이 같은 방향으로 끌어당긴다. ‘의무 또는 책무와 이익 사이의 지속적 충돌 가능성 (the standing possibility of conflict between obligation or duty and interest)’은 존재하지 않는다(87쪽). 위에서 말했듯이, 판사들은 승인 규칙들 사이에서 선호들(preferences)을 가질 수 있으며, 그 선호들은 정당성(legitimacy) 등에 관한 견해들을 반영할 수 있다. 그러나 각자의 지배적 태도가 군중과 함께 가고자 하는 욕망이라면, 우리가 의무들(obligations)에서 발견하는 익숙한 규범적 밀고 당김(normative push and pull)의 감각은 이례적일 것이다. 이 지점에서 하트는 처음 설명에서 진실에 더 가까이 갔다. 대열 이탈은 판사들에게조차 유혹적일 수 있지만, 그것은 또한 비판과 부합하라는 강한 압력의 계기이다. 아쉽게도 그것은 규칙이 전혀 없고 일반적으로 적용되는 하나의 이유(reason of general application)만 있는 경우에도 마찬가지다. 따라서 사회적 규칙들(social rules)의 정확한 성격 규정에 관한 논쟁은 계속되고 있으며, 넓게 하트적인 법 설명 안에 들어맞을 수 있는 다른 선택지들도 있다.¹³ 그러나 단순한 실천 이론도, 그것에 대한 하트의 관행주의적 수정도, 그 자체만으로는 작동하지 않을 것이다.

(ii) 규칙들의 도달 범위 (The Reach of Rules)

법에 대한 규칙 기반 이론(rule-based theory of law)에 관한 독립적인 의문의 원천은 그 범위(scope)와 관련된다. 사회적 규칙들(social rules)이 법적 현상들(legal phenomena)을 이해하는 데 필요하다는 점이 입증된다고 가정하더라도,

¹³예컨대 Joseph Raz, *Practical Reason and Norms*; Frederick F. Schauer, *Playing by the Rules: A Philosophical Examination of Rule-based Decision-making in Law and in Life* (Oxford University Press, 1993); Andrei Marmor, *Social Conventions: From Language to Law* (Princeton University Press, 2009); Scott J. Shapiro, *Legality* (Harvard University Press, 2011) 참조. 규칙(rules)과 기준(standards)의 구별은 Henry M. Hart and Albert Sacks, *The Legal Process: Basic Problems in the Making and Application of Law* (W. N. Eskridge, Jr. and P. P. Frickey eds., Foundation Press, 1994) 139-41쪽에서 제시된다.

그것들은 충분한가? 여러 이유에서 그렇지 않다.

첫 번째 이유는 하트(Hart) 자신이 강조한다. 일차 규칙들과 이차 규칙들의 모든 체계가 법체계인 것은 아니다. 북미 하키 리그(National Hockey League)는 하나의 규칙 체계를 가지고 있다. 곧 선수들, 심판들(officials), 커미셔너의 행위를 지시하는 일차 규칙들과, 공식 규칙들(official rules)에 작용하는 승인, 변경, 판정의 이차 규칙들을 가지고 있다. 그렇지만 하키 규칙들은 법체계가 아니다. (물론 그것들이 법체계와 많이 닮아 있다는 점은 누구도 부정하지 않는다.) 무엇이 빠져 있는가? 하키 규칙들은 특수 목적적(special-purpose)이다. 그것들은 하나의 게임을 규율하지만, 법은 삶의 많은 부분을 규율할 수 있다. 그리고 법체계는 하키 규칙들을 포함하여 하키를 규율하지만, 하키 규칙들은 법을 규율하지 않는다. 하트는 더 나아가, 법은 포괄적으로 규율할 수 있을 뿐 아니라, 규칙들의 체계가 실제로 재산(property), 약정들(agreements), 힘의 사용(use of force)을 포함한 넓은 범위의 것들을 규율하지 않는 한 법체계가 아니라고 논변한다(193-200쪽). 하트는 이것을 법체계의 ‘최소한의 내용(minimum content)’ 이라고 부르며, 그 내용을 규율하는 일이 인간 생존(human survival)을 증진하고 인간 생존은 (그의 가정에 따르면) 도덕적으로 좋은 것이므로, 모든 법체계들은 어떤 종류의 선(good)을 지향한다고 생각한다. 따라서 법체계들에 관해 ‘형식적(formal)’ 검사 기준을 가진다는 문제는 성립하지 않는다. 이것이 내가 서두에서 말했듯이, 하트의 이론이 법체계들을 논리학이나 수학의 어떤 형식 체계(formal system)와 같은 것으로 표상한다고 생각하는 것이 잘못된 이유들 중 하나다. 그리고 이 지점은 훨씬 더 큰 타격력을 가진다. 어떤 것도 어떤 법체계에 속하지 않는다면 하나의 법(a law)이 아니기 때문에, 법에 대해서도 순수하게 형식적인 검사 기준은 있을 수 없다. 법들(laws)은 특정한 종류(kind)의 규범 체계 안에서 하나의 역할을 수행하는 규칙들이며, 그 체계는 부분적으로 그 내용에 의해 구별된다.

두 번째 지점은 하나의 명확화로 이어진다. 어떤 저자들은 법체계 안의 모든 것이 규칙은 아니기 때문에 하트의 설명이 부정확하거나 불완전하다고 생각한다. 예컨대 ‘기준들(standards)’ 이나 ‘원칙들(principles)’ 같은 다른 종류의

규범들도 발견된다고 말해진다.¹⁴ 위에서 보았듯이(xviii쪽), 이것들이 법들에 대한 도덕적 정당화들(moral justifications for laws)을 지목하려는 것이라면, 하트의 설명에서 그것들은 어떤 식으로든 공무담당 방식으로 채택되거나 지지되지 않는 한 법의 일부가 아니다. 그러나 ‘기준들’과 ‘원칙들’은 유연하거나 반박 가능한(defeasible) 일반적 법 규범들을 지목하기 위해서도 흔히 쓰인다. 이런 방식으로 이해되면, 그것들은 하트의 이론에 쉽게 들어맞는다. 어떤 쟁점에 대한 법의 관련성(bearing)을 알기 위해서는, 서로 교차하고 충돌할 수 있는 많은 상이한 규칙들의 순효과(net effect)를 알아야 하며, 그 충돌을 해소하는 허용 가능한 방식이 하나보다 많을 수 있다. 이것이 반박가능성(defeasibility)의 한 원천이다. 또 다른 원천은, 하트가 제VII장에서 설명하듯이, 모든 규칙이 어느 정도 모호하고 개방적 직조를 지닌(open-textured)다는 사실에서 나온다. 규칙이 명확히 적용되는 사례들과 명확히 적용되지 않는 사례들이 있지만, 또한 그것이 적용된다고 논변 가능하고(arguably applies), 많은 작업, 특히 항소심 법원들(appellate courts)에서의 작업이 논변 가능하지만 법적으로 불확실한 사건들을 포함하는 사례들도 있다. 한 의미에서 법적 불확정성(legal indeterminacy)은 규칙의 주변부(margins)에서 발생하지만, 그것은 주변적 현상이 아니다. 그것은 모든 법체계와 그 체계 안의 모든 규칙의 특징이며, 그 결과 “크고 중요한 영역이 법원들과 다른 공무담당자들의 재량(discretion)을 위해 열려 남아 있다”(136쪽). 법원들은 법의 권위 있는 적용들을 하는 특별한 과업을 가지지만, 또한 입법기관들과 공유하는 또 다른 과업, 곧 새로운 법을 창출하는 과업을 가진다. 이 법창출 권한(law-creating power)을 언제 어떻게 사용할지를 아는 것은 대체로 어떤 종류의 규칙들을 적용하는 일에 관한 것이 아니다. 그것은 실천적 판단(practical judgement)을 요구한다. 불확정성을 해소하는 법원들의 역할은, 항소심 법원들의 작업만을, 또는 주로 그 작업을, 기실 어떤 법원들의 작업만을 바라보면서 법의 일반 이론을 발전시키는 일이 오도적일 것임을 뜻한다. ‘선택 효과(selection effect)’ 때문에 법적 불확실성을 과도하게 강조하게 될 것이기 때문이다. 규칙이라는 관념 자체가 법의 유동적이고 논쟁적인 성격을 포착하기

¹⁴규칙(rules)과 원리(principles)의 구별은 Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* 22-8쪽에서 제시된다.

에는 너무 말끔히 재단된 것(cut-and-dried)이라고 보는 많은 이들이 이 함정에 빠진다. 그들은 법원들 자체를 구성하는 꽤 확립된 규칙들이나, 사람들이 법원들 근처에도 가지 않고 무엇을 할지를 결정하는 데 사용하는 일상적 법규칙들을 알아차리지 못한다. 운전자들은 도로 표지판의 “정지(Stop)”가 “눈 깜박임을 멈추라”가 아니라 “차를 멈추라”를 뜻한다는 것을 알고 있다. 그 지점에 관해 사법적 판정은 필요하지 않으며, 이것은 작동 중인 법(law in action)의 전형적 사례다.

세 번째 지점은 법적 규칙들의 체계 안의 모든 것이 어떤 종류의 규칙인 것도 아니라는 점을 상기시킨다. 예컨대 『1998년 영국 인권법(UK Human Rights Act)』 제6조는 다음과 같이 말한다. “이 조에서 ‘공공기관(public authority)’은 다음을 포함한다: (a) 법원 또는 재판소, 그리고 (b) 그 기능들 중 일정한 것이 공적 성격의 기능인 사람...” 이는 규칙인가? 그것은 정의(definition)이다. 하지만 정의가 단어들을 사용하기 위한 규칙이라고 본다면 어떨까? 그렇다면 이는 어떤 행위도 요구하거나 권한을 부여하거나 허용하지 않기 때문에, 규범(norm)은 아닌 규칙(rule)일 것이다. 정의들의 법적 역할은, 그것들이 이 법 제1조(Section 1)에 있는 규범, 곧 “공공기관이 협약상 권리(Convention right)와 양립할 수 없는 방식으로 행위하는 것은 불법(unlawful)이다”라는 규범과, 다른 곳에서 제공되는 불법 행위에 대한 구제들과 함께(along with) 어떻게 작동하는지를 보여줌으로써 설명된다. 이것은 실제로 사람들에게 무언가를 하라고 말한다. 다만 암묵적으로 그렇게 한다. 이런 문맥에서 ‘불법’이 무엇을 의미하는지 알아야 하기 때문이다. 그리고 이것은 법 안의 자료들 중 규범이기는 하지만 규칙은 아닌 것들에 접근해야 하는 방식이기도 하다. 예컨대 사법적 결정은 종종 특정한 명령(order)으로 끝난다. 곧 어떤 사람 또는 다른 사람에게 무언가를 하거나, 무언가를 지급하거나, 무언가를 감수하라고 말하는 지시(directive)다. 이러한 일회적 명령(one-off order)은 규칙이 아니라 개별 규범(individual norm)이다. 개별 규범들만을 사용해 통치하는 것은 실천적으로 불가능하지만, 그것들 없이 통치하는 것은 논리적으로 불가능하다. 법원들이 사람들의 법적 지위들을 권위 있게 결정할 수 있으려면, 특정한 사람들을 구속하는 판정들(rulings)을 내려야 한다. 따라서 규칙들은 법들(laws)과 법체계들(legal

systems)을 이해하는 데 필요하지만, 충분하지는 않다. 우리는 또한 규칙들이 무엇에 관한 것인지, 그리고 무엇을 하도록 기대되는지를 알아야 한다. 우리는 규칙들과 맞물리는 다른 자료들에 대해서도 알아야 하며, 규칙에 의해 지배되지 않는 법적 의사결정에 대해서도 알아야 한다. 하트는 이러한 주제들 가운데 일부에 다른 것보다 더 많은 시간을 할애하지만, 그것들 모두는 그 이론 안에 수용될 수 있다. 널리 퍼진 오해와 달리, 하트는 법이 단순히 규칙의 문제라고 말한 적이 없으며, 규칙들이 모든 법적 현상들을 설명한다고 말한 적도 없다. 기실 그는 그러한 오류를 경계한다. “일차 규칙들과 이차 규칙들의 결합은 법의 많은 측면들을 설명하기 때문에 그 결합에 부여된 중심적 지위를 가질 만하지만, 이것만으로 모든 문제를 밝힐 수는 없다. … [그것은] 법체계의 중심에 있지만, 전체는 아니다…” (99쪽) 관심을 가질 만한 다른 것들이 많이 있으며, 법리학(jurisprudence)은 그것들을 고려해야 한다.

3. 법과 권력 (LAW AND POWER)

이제 우리는 다음을 얻었다. 법(law)은 사회적 규칙들(social rules)의 구성물이며, 그 규칙들 자체도 실천(practice)으로부터 구성된다. 이는 결국 사회적 통제(social control)의 수단인 제도를 다소 안이하게 바라보는 견해처럼 들릴 수 있다. 그렇다면 갈등(conflict), 강제(coercion), 권력(power)은 어떻게 되는가?

(i) 법에서의 분업 (The Division of Labour in Law)

하트(Hart)는 법을 위협(threats)으로 뒷받침된 주권자(sov​er​eign)의 명령들(orders)로 보는 오스틴(Austin)의 하향식 피라미드적 관점(top-down, pyramidal view)에 반대한다. 그 관점이 조잡했다는 점은 널리 인정되지만, 어떤 이들은 그것이 유익한 경계 효과를 가졌고, 하트가 법실증주의(legal positivism)를 더 섬세하게 만들면서도 그 타격력(punch)의 일부를 잃었다고 느낄 수 있다. 법은 합의(consensus)와 일치(agreement)에 관한 것일 뿐 아니라, 갈등(conflict)과

불일치(disagreement)에 관한 것이기도 하다.¹⁵ 물론 이것이 항소심 법원들(appellate courts)에서의 많은 활동이 고도로 정치화되어 있으며, 확립된 법(settled law)을 적용하는 것이 아니라 논변 가능한 사건들을 처리하는(settling arguable cases) 데 있다고 하는 익숙한 주장이라면, 이에 반대할 이유는 없다. 방금 전 우리는 이것이 하트의 이론에 어떻게 들어맞는지를 보았다. 그러나 하트는 사태가 출발하기 위해서는 다른 지점들에서 어느 정도의 합의를 요구한다. 적어도 승인 규칙(rule of recognition)은 어떤 활동들이 법을 만드는지에 관한 합의에 기초해 있어야 한다. 그러나 누구의 합의인가? 다음은 드워킨(Dworkin)이 하트의 이론을 재현한 방식이다.

법의 참된 근거들(grounds of law)은 공동체 전체에 의한 하나의 근본적 지배 규칙(master rule)의 수용(acceptance)에 놓여 있다. 그는 이것을 ‘승인 규칙(rule of recognition)’ 이라고 부른다…. 오스틴에게 캘리포니아의 제한 속도가 55마일이라는 명제가 참인 이유는 단지 그 규칙을 제정한 입법자들이 우연히 그곳을 지배하고 있기 때문이다. 하트에게 그것이 참인 이유는 캘리포니아 사람들이 주 및 연방 헌법 안의 권위 체계(scheme of authority)를 수용해 왔고, 계속 수용하고 있기 때문이다.¹⁶

이것이 법의 ‘근거들(grounds)’ 에 대한 설명으로서 잘못된 점은 충분히 분명하다. 캘리포니아의 많은 사람들은 ‘주 및 연방 헌법 안의 권위 체계’가 무엇을 의미하는지 전혀 알지 못하며, 어떤 이들은 주 헌법(state constitution)이 존재한다는 사실조차 모른다. 또한 그것은 하트의 이론에 대한 해석으로서도 잘못된 점이 있다. 법 이전의(pre-legal) 사회에서 사회 규범들(social norms)은 광범위한 지지가 있어야만 존재할 수 있다. “보다 단순한 구조[법의 출현 이전]에서는, 공무담당자들(officials)이 없기 때문에, 규칙들은 집단의 행태에 대한 비판 기준들을 설정하는 것으로서 널리 수용되어야 한다. 그곳에서는 내부 관점(internal point of view)이 널리 퍼져 있지 않다면 논리적으로 어떤

¹⁵이 주제의 다른 측면에 대해서는 Jeremy Waldron, *Law and Disagreement* (Oxford University Press, 1999) 참조.

¹⁶Ronald Dworkin, *Law's Empire* 34.

규칙들도 존재할 수 없다”(117쪽). 관습적 규칙들(customary rules)은 일반적 동의(general buy-in)를 필요로 한다. 그러나 “...일차 규칙들과 이차 규칙들의 결합이 있는 곳에서는... 규칙들을 집단의 공통 기준들(common standards)로 수용하는 일이, 통상적 개인이 그 자신 몫으로 규칙들에 복종함으로써 규칙들에 묵종(acquiescing)하는 비교적 수동적인 문제로부터 분리될 수 있다. 극단적인 경우에는, ‘이것은 유효한 규칙이다’ 라는 특징적 규범적 언어 사용을 수반하는 내부 관점이 공무담당자 세계에 한정될 수도 있다. 이러한 더 복잡한 체계에서는 공무담당자들만이 체계의 유효성 기준들(criteria of validity)을 수용하고 사용할 수도 있다. 그렇게 된 사회는 개탄스러울 만큼 순종적일 수 있고, 결국 도살장으로 끌려갈 수도 있다. 그러나 그것이 존재할 수 없다고 생각하거나 그것에 법체계라는 명칭을 부정할 이유는 거의 없다”(117쪽).

내가 이 구절을 길게 인용한 것은, 그것이 법의 본성(nature of law)을 이해하는 데 중대한 지점을 제시하며, 또한 법이 그러한 본성을 가진다는 사실의 정치적 의미도 보여주기 때문이다. 하트가 지적하듯이, 관습(custom)과 사회적 도덕(social morality)은 의도적 변경에 대해 면역을 가지며, 오직 점진적으로만 진화한다. 작고 안정된 공동체에서는 그것들이 사태를 운영하는 꽤 좋은 방식이다. 사생활의 많은 영역에서 우리가 통상 사태를 운영하는 방식도 바로 그것이다. 그러나 크고 복잡한 사회들은 관습들과 다른 규범들이 공적으로 확인되고, 통치자들의 말 한마디로든 다수결 투표로든 그 밖의 어떤 방식으로든 즉시 변경될 수 있게 하는, 의도적인 사회 통제 메커니즘들도 필요로 한다.

이는 제도화(institutionalization), 곧 규칙들을 식별하고, 변경하고, 집행할 권한을 가진 전문화된 기관들(specialized organs)의 출현에 의해 가능해진다. 그 결과 생겨나는 규범적 분업(division of normative labour)은 득실이 섞인 것으로서, 이득과 비용을 모두 가져온다. “그 이득은 변화에 대한 적응성, 확실성(certainty), 효율성(eficiency)이다 ... 그 비용은, 중앙집중적으로 조직된 권력이, 그 지지를 필요로 하지 않을 수 있는 다수자들(numbers)을 보다 단순한 일차 규칙 체제가 할 수 없었던 방식으로 억압(oppression)하는 데 사용될 위험이다”(202쪽). 그러므로 법은 보편적으로 좋은 것도 아니고, 무조건적으로 좋은 것도 아니다. 법의 제도적 성격(institutional character)은 일정한 이득들을 가능하게

하지만, 또한 일정한 비용들도 가능하게 한다. 법 없는 사회라면 부담할 가능성이 낮은 비용들이다. 하트가 위에서 논한 한계 사례에까지 이르지 않더라도, 법 아래의 전형적 사회는 광범위한 사회적 합의보다 좁은 공무원당자 합의(official consensus)에 더 의존한다.¹⁷ 법의 존재가 일반 인구에게 요구하는 것은 체계의 의무부과적 규범들(mandatory norms)에 대한 묵종(acquiescence) 이상은 거의 없다.

그렇다면 법이 기초해 있는 합의에는 아늑하거나 공동체적인 것이 전혀 없다. 그것은 가치들에 관한 합의(agreement on values)를 전제하지 않으며, 법의 작동 속에서의 중대한 반대(dissent)를 배제하지도 않는다. 그리고 이것은 왜 모든 법체계가 필연적으로 그 공동체의 가치들을 표현한다는 낭만적 믿음이 잘못된지를 보여준다. 정의롭고 가치 있는 법체계조차도 난해하고, 기술적이며, 그것이 통치하는 사람들의 삶으로부터 멀어질 수 있다. 규범적 분업 때문에 법은 한마디로 법률주의적(legalistic)이 될 상존하는 위험을 안고 있다. 모든 법이론가(legal theorist)는 법이 도덕적으로 오류 가능하다는 점을 인정한다. 여기서 하트의 특별한 기여는, 법이 실패할 수 있는 방식들 중 일부가 사회 제도(social institution)로서의 법의 본성과 긴밀히 연결되어 있음을 보여주는 데 있다.

(ii) 강제와 권력 (Coercion and Power)

법이 본질적으로 강제적 장치(coercive apparatus)라는 관념은 일반인의 견해와 공명하며, 법리학(jurisprudence)에서도 인기를 누려 왔다. 하트(Hart)는 그것이 잘못이라고 생각한다. 모든 법체계(legal system)는 강제적으로 집행되지 않는 규범들(norms)을 일부 포함하며, 법체계가 전적으로 그러한 규범들로 구성될 수도 있다고 상상할 수 있다(199-200쪽). 제재 없는 법(sanction-free law)의 요점은 무엇일까? 제재가 있는 법의 요점과 같다. 사람들에게 어떻게 행위할지를

¹⁷이는 구체적으로 어떤 공무원당자들(officials)이 중요한지, 그리고 ‘공무담당자(official)’의 역할이 어떻게 성격 규정되어야 하는지를 정확히 다루지 않는다. 일반적으로 말해, 하트(Hart)는 적어도 판사들(judges)과 입법자들(legislators)을 포함하려는 뜻을 지니며, 이때 ‘공무담당자(official)’는 법적 정의가 아니라 사회정치적(socio-political) 정의를 따른다.

지시하는 것이다. 제재들은 법의 플랜 B다. 플랜 A는 그 수범자들(subjects)이 추가 감독 없이 법에 부합하는 것이다. 지시의 필요는 있지만 강화 동기(reinforcing motivation)의 필요는 없는 곳에서는, 제재 없는 법들을 발견하는 일이 그리 드물지 않다. 예컨대 미국 연방법전(United States Code)은 사람들에게 국기에 대한 존중을 어떻게 표시할지를 말하는 규범들을 포함한다. “국기는 어떤 것을 받거나, 보관하거나, 운반하거나, 전달하기 위한 용기로 사용되어서는 결코 안 된다.”¹⁸ 그러나 그것은 이러한 규범들의 위반에 대한 벌칙들을 제공하지 않는다. 인간 본성이 현재와 달랐다면, 모든 법규범들이 그와 같을 수 있었을 것이다.

인간 본성이 현재와 같더라도, 많은 법규범들은 제재에 의해 강화되지 않는다. 한 가지 중요한 부류는 권한부여 규범들(power-conferring norms)이다. 이는 법적 규범들과 지위들을 변경할 능력을 창출하는 법규칙들, 예컨대 사람들에게 입법하고, 법인을 설립하고, 계약하고, 혼인할 권한을 부여하는 규칙들이다. 문제되는 권한들이 자발적인 경우에는, 이 사례들이 일반적으로 그러하듯이, 사람들은 자기 선택에 따라 그것들을 행사할 수도 있고 하지 않을 수도 있다. 입법, 법인 설립, 계약, 혼인을 위한 법의 절차를 따르지 않는 사람은 그렇게 하는 데 실패하며, 그 결과 생긴 ‘혼인’은 예컨대 무효(null and void)가 될 것이다. 그러나 실패했다는 이유로 처벌받는 사람은 없다. 아니면 무효(nullity) 자체가 일종의 처벌이며, 결국 이것들도 강제적 법들(coercive laws)이라고 말해야 하는가? 하트는 우리가 그렇게 말해서는 안 되는 이유를 설명한다. 여기에는 무언가를 하라는 명령(order)과 불복종에 대한 제재(sanction)라는 별개의 두 가지가 있는 것이 아니다. 명령은 전혀 없고, 그 ‘제재’는 권한부여 규칙 자체와 다르지 않다. 켈젠(Kelsen)은 강제 이론(coercion theory)을 구하기 위한 우회로(work-around)를 제안했다. 그는 권한부여 규칙들은 실제로 법들의 파편들에 불과하므로, 그 안에서 제재가 발견되지 않는 것은 놀랄 일이 아니라고 말했다. 제재들은 법체계 안의 다른 곳에 감춰져 있다는 것이다. 배우자를 부양할 것을 요구하는 제재수반 규칙들이 있고, 혼인의 권한부여 규칙들이 하는 일은 어떤 사람에게 배우자가 있는지, 있다면 그가 누구인지를 우리에게 말해

¹⁸4 U.S.C. § 8 (h).

주는 일이다. 어떤 방식으로든, 결국 모두 강제(coercion)로 다시 연결된다. 이 움직임에 대한 하트의 응답은 시사적이다. 그는 켈젠의 재구성이 불가능하거나 비논리적이라고 말하지 않는다. 그는 그것이 동기를 결여하고(unmotivated), 법리학(jurisprudence)에 대한 방법론적 제약(methodological constraint)과 어긋난다고 말한다.

“사회 통제의 수단으로서 법의 주요 기능들(principal functions)은 사적 소송(private litigation)이나 형사 기소(prosecutions)에서 보이는 것이 아니다. 그것들은 체계의 실패에 대비한 필수적이지만 여전히 보조적인 장치들을 나타낸다. 그 기능들은 법이 법정 밖에서 삶을 통제하고, 인도하고, 설계하는 다양한 방식들에서 보아야 한다”(40쪽).

법적 자료(legal material)를 개별 법들(individual laws)로 어떻게 나눌 것인가라는 질문에는 본질주의적(essentialist), ‘형이상학적(metaphysical)’ 답이 없다. 최선의 접근은 법을 실제로 사용하는 이들, 그 대부분은 법정 밖에서 살아가는 이들에게 법이 무엇인지를 이해할 수 있게 해 주는 접근이다. 권한부여 규칙들(power-conferring rules)은 책무를 부과하는 규칙들과는 다르게 생각되고, 말해지고, 사회생활에서 사용되며, 다른 이유들로 가치 있게 여겨진다. “성격의 차이에 대한 다른 어떤 검사 기준들(tests)이 있을 수 있겠는가?”(41쪽) 이것은 하트의 방법(method)을 압축해 보여준다. 홈스(Holmes)의 ‘나쁜 사람(bad man)’에게 법은 피해야 할 비용들(costs)에 관한 전부이고, 법률가에게 법은 가능한 법정 사건들과 실제 법정 사건들, 그리고 벌어들일 법률비용(legal costs)에 관한 전부이다. 법이론들은 이러한 외눈박이(cyclopic) 관점들로부터 뿔뿔히 뿔났다. 그것들은 현실적이지만 주변적인 것을 마치 중심적인 것처럼 취급한다. 법적 중요성의 온전한 차원들이 그들의 평면적이고 환원적인 그림들에서 빠져 있다.

거기까지는 모두 옳다. 그러나 우리가 ‘사회 통제의 수단으로서 법의 주요 기능들’ 모두에 주의를 기울이고자 한다면, 여기서 하트가 나아간 것보다 더 멀리 가야 한다. 권한부여 규칙들을 책무부과 규칙들(duty-imposing rules)로

환원하려 하거나, 무효(nullity)를 일종의 제재로 표상하려 하는 것은 기실 잘못이다. 그러나 권한부여 규칙들이 사회적 권력(social power)과 결부되어 있는 방식들을 알아차리는 것은 잘못이 아니다. 애초에 왜 강제(coercion)에 관심을 가지는가? 한 가지 대답은 책임(responsibility)과 연결되어 있다. 위협(threat)에 의해 어떤 일을 하도록 강제된 사람들은 일반적으로 그것을 했다는 책임을 지지 않는 것으로 취급된다. 그들의 의지가 압도(overborne)되었기 때문이다. 그러나 많은 법적 벌칙들(legal penalties)은 그렇게 엄중하지 않다. 지속적으로 그것들을 지급하기를 거부하는 경우는 제외한다. 그럼에도 그것들은 여전히 사람들의 유인들(incentives)에 영향을 미치며, 이는 권한부여 규칙들의 경우에도 참이다. 강제(coercion)는 법의 권력(law's power)의 단단한 가장자리(hard edge)이다. 법규범들의 유인적(incentivizing) 성격과 표현적(expressive) 성격은 그 부드러운 가장자리(soft edge)에 속한다.

혼인할 권한(power to marry)을 부여하는 규칙들을 다시 생각해 보라. 그것들은 조건 아래에서 그렇게 한다. 예전에는, 그리고 어떤 곳들에서는 지금도, 이러한 조건들 안에 누구와 혼인할 수 있는지에 관한 인종 또는 성별 제약들(restrictions)이 포함되어 있었다. 서로 다른 인종의 사람들 사이의 혼인이나 같은 성별의 사람들 사이의 혼인은 법적 무효(legal nullities)였다. 이제 하트가 제시하는 이유들 때문에, 이것을 사람들을 이성애적 또는 동일 인종적 관계로 강제하는 일종의 강제로 보는 것은 잘못된 것이다. 누구도 혼인할 필요는 전혀 없다. 따라서 이러한 법들은 동성애 행위에 대한 형사처벌들이나 도망노예법들(fugitive slave laws)과 같지 않았다. 그래도 해당 권한부여 규칙들, 또는 권한 부여 규칙들과 해석 규칙들의 결합이 이러한 혼인들을 무효(void)로 만든 것은 우연도 의도되지 않은 부산물도 아니었다. 그것이 그 규칙들의 목적이었다. 명령들(orders)과 제재들(sanctions)만큼 조악한 어떤 것에도 의존하지 않으면서, 이러한 법들은 개인들의 삶과 공동문화를 형성하려고 시도했다. 그리고 어느 정도 성공했다. 하트가 호의적으로 '편의들(facilities)'을 제공한다고 부르는 규칙들의 기능을 생각할 때 우리는 이 점을 유념해야 한다. 모든 법들이 강제적인 것은 아니지만, 비강제적 법들도 강제적 법들이 하는 일을 한다. 그것들은 사회적 권력(social power)을 표현하고 통로화한다(channel). 그것들은 그

내용(content)을 통해서도, 더 일반적인 특징들을 통해서도 그렇게 할 수 있다. 예컨대 자발적 권한들(voluntary powers)은 자기 의지를 행사할 능력이 있는 이들에게 법적 통제를 배분하고, 개인적 권한들(individual powers)은 그것을 개인들에게 배분한다. 그것은 어떤 사람에게 무언가를 하도록 강제하지 않을 수 있지만, 그러한 법들을 창설하고 적용하는 이들에 의해 예측 가능할 뿐 아니라 흔히 의도되는 방식으로 사회 세계(social world)를 형성한다.

4. 법과 도덕 (LAW AND MORALITY)

이 책의 중심 문제 중 하나는 법과 도덕 사이의 다형적 관계들(pluriform relations)—관습적, 또는 ‘사회적’ 도덕(social morality)과 이상적, 또는 ‘비판적’ 도덕(critical morality) 양쪽—에 관한 것이다. 하트는 법과 도덕 사이에 어떤 종류의 분리(disjunction)가 존재한다고 고수한 것으로 유명하다. 그의 이론에 대해 다른 것은 아무것도 모르는 사람들조차도, 그가 역사적인 홈즈 강연에서 말했듯이, “법과 도덕규범들 사이에는 필연적 연결이 없다(no necessary connection between law and morals)”고 본다는 점은 안다.¹⁹ 우리는 이미 위의 3 (i)에서, 법이 그 법이 지배하는 인구가 실제로 지지하는 도덕적 가치들을 반드시 반영할 필요는 없는 이유를 보았다. 하지만 그들을 마땅히 지배해야 할 도덕적 가치들은 어떤가? 하트는 여기에도 필연적 연결이 없다고 말하려는 것인가? 『법의 개념(The Concept of Law)』에서 그는 때때로 그 생각을 다르게 정식화한다. 한 지점에서 그는 실증주의의 핵심 명제를, “법들(laws)이 도덕의 특정 요구들을 재현하거나 충족시킨다는 것은 어떤 의미에서도 필연적 진리가 아니다”(185-6쪽)라고 보는 것으로 묘사한다. 이것은 더 좁은 주장처럼 보인다. 모든 법들이 건전한 도덕 기준들을 ‘재현하거나 충족시킬’ 것을 요구하지 않으면서도, 법과 도덕 사이에 필연적 관계들이 존재할 수 있기 때문이다.

하트의 첫 번째이자 더 넓은 정식화는, 법이 사회적 구성물이라는 그의 견해를 공유하는 이들 사이에서조차 거의 호응을 얻지 못했다.²⁰ 법과 도덕이 모두

¹⁹H. L. A. Hart, ‘Positivism and the Separation of Law and Morals’ (1958) 71 *Harvard Law Review* 593, at 601 n. 25.

²⁰John Gardner, ‘Legal Positivism: 5½ Myths’, 그의 *Law as a Leap of Faith* (Oxford

인간 행위를 규율한다는 것이 단지 우연적 사안일 수 있겠는가? 우리가 어떻게 살아야 하는가에 대해 아무 말도 하지 않는 규범들의 체계라면, 그 규범들은 법적 규범들도 아니고 도덕적 규범들도 아닐 것이다. 이것은 법과 도덕 사이의 하나의 필연적 연결을 시사한다. 그리고 다른 연결들도 있다. 사실 하트의 성숙한 이론은 법과 도덕 사이의 두 가지 더 흥미로운 필연적 연결을 실제로 인정한다. 하나는 법의 목적을 경유하고, 다른 하나는 법과 정의 사이의 상정된 연결을 경유한다. 또한 하트의 이론은 많은 다른 실증주의자들이 인정하기를 꺼리는 법과 도덕 사이의 우연적 연결도 허용한다. 이 세 가지 주장들은 분리 명제의 어느 버전 못지않게 하트의 이론에서 중요하다. 그러나 그중 명확하게 옳은 것은 첫 번째 주장뿐이다.

(i) 법의 목적 (Law's Purpose)

법은 단순한 규칙들의 체계가 아니라, 여러 목적들에 봉사하는 체계이다. 토마스 아퀴나스는 법이 또한 전체적 목적(*overall purpose*)을 가진다고 생각했는데, 그가 주장하기로 법은 “공동선을 위해 마련된 이성의 규율(*an ordinance of reason made for the common good*)” 이기 때문이다.²¹ 이 노선의 현대적 제안들에는, 법이 행위를 인도하기 위해, 또는 공동선을 위해 활동을 조정하기 위해, 또는 정의를 행하기 위해, 또는 강제를 허가하기 위해 만들어진다는 관념이 포함된다.²² 이러한 주장들은 법에 대한 가능한 이상들에 관한 제안들이 아니라, 법의 구성적 목적들(*constitutive aims*)에 관한 주장들로 이해되어야 한다. 기본 관념은 다음과 같다. 이러한 목적들을 가지지 않는 사회적 통제 체계는 법체계가 아닐 것이며, 이는 지식 추구를 지향하지 않는 기관이 대학이 아닐 것인 것과

University Press, 2012) 제2장; Leslie Green, 「Positivism and the Inseparability of Law and Morals」 (2008) 83 *New York University Law Review* 1035 참조.

²¹ *Summa Theologica* II-I, q. 90 a. 4.

²² 행위 지도의 기능에 대해서는 Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (rev. edn., Yale University Press, 1969); 활동 조정의 기능에 대해서는 John Finnis, *Natural Law And Natural Rights* (Oxford University Press, 1980); 정의 실현의 기능에 대해서는 Michael Moore, 「Law as a Functional Kind」, R. P. George 편, *Natural Law Theory: Contemporary Essays* (Oxford University Press, 1992) 221; 강제 허용의 기능에 대해서는 Ronald Dworkin, *Law's Empire* 93 참조.

같다. 구성적 목적들을 가진다는 것만으로는 도덕과의 어떤 연결도 확립하지 않는다. 그것은 그 목적들이 무엇인지에 달려 있다. 어떤 기구도 설거지를 위한 것이 아니라면 식기세척기가 아니며, 설거지 능력은 식기세척기가 좋은지 판단하는 주요 기준들 가운데 하나이다. 그러나 설거지는 보통 도덕적으로 유의미한 활동이 아니므로, 좋은 식기세척기가 도덕적으로 좋은 식기세척기인 것은 아니다. 법의 구성적 목적에 관한 위 제안들은 도덕적 하중을 지닌 것에서 도덕적으로 중립적인 것까지 다양하다. 정의를 행하는 것은 도덕적으로 선하고, 행위 인도는 도덕적으로 중립적이며, 강제를 허가하는 것은 도덕적으로 양의적이다.²³

도덕과의 연결은 또한 구성적 목적이 얼마나 성공하는지에 달려 있다. 제9장에서 하트의 논증은 인간 생존이 도덕적으로 선하며, 그것을 지향하지 않는 규범 체계는 법체계가 아닐 것이라고 가정한다. 또한 법체계가 존재하려면, 모두에게 향상은 아니더라도 일부 사람들에게 많은 시간 동안은, 소기의 성과를 실제로 내야 한다(deliver the goods)고 본다. 그러나 일반적으로 말해, 구성적 목적을 가진 어떤 것은 우리가 그것을 관련 종류의 구성원으로서 실격시키기 전에 상당한 여지를 얻는다. 결함이 있거나 고장 난 식기세척기도, 수정되거나 수리된다면 설거지를 할 어느 정도의 능력을 가질 것이라면 여전히 식기세척기이다. 법체계들에도 마찬가지이다. 법들이 해야 할 일을 수행하는 데 매우 결함이 있는 통일된 법들의 집합들도 그럼에도 법체계로 간주될 수 있다. 이것은 무언가를 지향한다(aim)는 것이 그것에 성공한다(succeeding)는 것을 요구하지 않는다는 사실에서 따라 나온다.

이 문제에 대한 하트의 마지막 성찰들에서 그는 더 이상 법이 생존을 지향할 필요조차 있다고 생각하지 않는 듯하다. 그는 법이 어떤 종류의 흥미로운 구성적 목적도 가진다는 점을 부정하는 막스 베버(Max Weber)와 한스 켈젠(Hans Kelsen)에 합류한다. (켈젠은 “법은 목적이 아니라, 수단, 특정한 사회적

²³강제(coercion)를 허용한다는 것은, ‘현재 진행 중인 강제 행위에 대해 정당화(justification)를 제공한다’는 의미인가? 아니면 ‘정당화될 수 없는 강제가 발생하지 않도록 보장한다’는 의미인가? 혹은 ‘정당화될 경우에만 사람들에게 강제를 가한다’는 의미인가?

수단이다(Law is a means, a specific social means, not an end)” 라고 말했다.²⁴⁾ 하트는 이렇게 쓴다. “나는 법이 그 자체로 인간 행위에 지침들을 제공하고 그러한 행위에 대한 비판 기준들을 제공하는 것 이상으로 봉사하는 더 구체적인 목적을 찾는 것은 매우 헛되다고 생각한다”(249쪽). 여기에는 생존에 대한 언급이 없다. 그러나 어쩌면 하트는 법이 생존을 촉진하는 목적이나 다른 목적들을 가진다는 자신의 이전 주장을 철회하고 있는 것이 아닐 수 있다. 어쩌면 그는 법이 그러한 목적들 중 어떤 것에 의해서든 식별될 수 있다(identified)는 점을 부정하고 있는 것이다. 법체계들 사이에서 보편적이면서 동시에 법체계들에 고유한 목적은 없다는 말이다. 법은 생존을 촉진하려는 목적을 가질 수 있고, 행위를 인도하고 평가하려는 목적을 가질 수 있다. 어느 것도 법을 관습, 종교, 도덕 같은 것들로부터 구별하지 않을 것이다. 반대로 그것들은 중첩 지점들이다. 법과 도덕은 유사한 과업들에 주목하고, 관련된 이유들로 그렇게 하며, 일부 유사한 기법들을 사용한다.

(ii) 법과 정의 (Law and Justice)

제8장에서 하트는 법과 도덕 사이의 놀라운 연결을 옹호한다. 그의 논증은, 둘 모두에서 같은 사례들은 같게 취급되어야 한다는 관념을 통해, 규칙-따르기(rule-following)를 정의(justice)와 결부시킨다. 실천 이론(practice theory)에 따르면, 일반 규칙들(general rules)은 사람들이 그 규칙들에 어느 정도 항구성을 가지고 부합하거나(conform) 그 규칙들을 적용하지 않는 한 존재할 수 없다. 그런데 하트는 항구성(constancy) 자체가(itself) 일종의 정의라고 말한다. 그는 이렇게 쓴다. “[가장 혐오스러운 법조차도 정의롭게 적용될 수 있지만], 일반 법규칙을 적용한다는 기본 관념(bare notion) 안에는 적어도 정의의 씨앗(germ of justice)이 담겨 있다”(206쪽, cf. 160쪽). 그렇다면 이로부터 모든 존재하는 법체계는 일정한 정의를 행한다는 점이 따라 나온다. 물론 ‘실체적(substantive)’ 정의는 아니다. 혐오스러운 법을 꾸준히 적용하는 것은 그 혐오스러움을 어떤 식으로도 보상하거나 완화하지 않는다. 그러나 그 적용은 그럼에도 법의 적용

²⁴Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (A. Wedberg tr., Harvard University Press, 1949) 20.

(application)에서의 정의, 또는 어떤 이들이 말하듯 ‘형식적(formal)’ 정의를 산출한다.²⁵ 이것은 어떤 법이, 그 법 아래에서의 대우에 관련성이 있다고 그 법 자체가—옳든 그르든—간주하는 방식에서 같은 이들 모두에게, 그리고 오직 그들에게만 적용될 것을 요구한다. 그리고 그 요건은 모든 법을 포괄한다. ‘극도로 억압적인(hideously oppressive)’ 법들, 또는 ‘권리 없는 노예들(rightless slaves)’에게 작동하는 어떤 법체계의 최소한의 혜택조차 부정하는 법들까지도 포괄한다.²⁶

나는 법이 얼마나 나쁠 수 있는지를 두고 하트가 쓴 말들(‘혐오스러운(odious)’, ‘극도로 억압적인(hideously oppressive)’ 등)을 인용했다. 그의 ‘정의의 씨앗(germ of justice)’ 논제가 대담한 논제임을 분명히 하기 위해서이다. 적용에서의 항구성은, 단지 가벼운 정도로만 부정의한 법들을 생각하고 있다면 일리 있게 보일 수 있다. 예컨대 그 정당화 목적들에 비추어 과포괄적이거나 과소포괄적인 법들이다. (17세 미만 누구에게나 운전을 금지하는 규범은 어떤 이들 중 너무 적은 사람에게, 다른 이들 중 너무 많은 사람에게 운전을 허용한다.) 그러나 완전성은 얻을 수 없고, 작은 방식으로 미달하는 법들을 확고하게 적용할 이유들은 많다. 그러나 그것은 하트의 논지를 입증하지 못할 것이다. 그는 그것이 혐오스러운 법들에도 적용되며, 우리가 실체적 정의—또는 형평성(equity), 자비(mercy), 제정신(sanity)—가 이기게 할 때조차, 그 과정에서 가치 있는 무언가를 잃었다는 인식 속에서 그렇게 한다고 말한다. 우리는 적어도 하나의 측면에서는 부정의했다.

‘형식적(formal)’ 정의라는 이 관념에는 무언가 이상한 점이 있다. 결국, 정의의 형식(*the form of justice*)을 가진 모든 것이 정의의 한 형식(*a form of justice*)인 것은 아니다. 낙타의 형식(*the form of a camel*)을 가진 모든 것이 낙타(*a camel*)인 것은 아닌 것과 마찬가지로, 정의의 규범들(*norms of justice*)과 부정의 규범들(*norms of injustice*)은 그 형식들에서 다를 필요가

²⁵David Lyons는 「On Formal Justice」 (1973) 58 *Cornell Law Review* 833에서 그 명칭 아래 이를 비판한다. Matthew Kramer는 더 나은 명칭인 ‘constancy’ 아래 이를 옹호한다. Matthew Kramer, 「Justice as Constancy」 (1997) 16 *Law and Philosophy* 561 참조.

²⁶H. L. A. Hart, ‘Positivism and the Separation of Law and Morals’ 593, at 626.

없다.²⁷ “남성과 여성은 동등한 가치의 노동에 대해 동일한 보수를 받아야 한다”는 규범은 정의의 규범이다. “남성과 여성은 동등한 가치의 노동에 대해 서로 다른 보수를 받아야 한다”는 규범은 부정의 규범이다. 그 둘은 같은 형식을 가진다. “모든 규칙을 그것이 포괄하는 사람들 모두에게, 그리고 오직 그들에게만 적용하라”는 규범은 어떠한가? 그것은 “이미 친구로 삼기로 결정한 사람들 모두와, 그리고 오직 그들과 친구로 지내라”와 같은 형식을 가진다. 두 번째 것은 정의의 규범인가? 한 규범이 정의의 규범인지, 부정의의 규범인지, 또는 둘 다 아닌지를 그 형식만을 근거로는 알 수 없다는 점은 분명해 보인다.

간통죄에 대해 유죄 판결을 받은 여성을 돌로 쳐 죽이는 방식으로 처벌하도록 되어 있는 법체계에서 일하는 판사의 사례를 상상해 보자. 이 법을 그 법이 포괄하는 모든 사람에게 적용할 이유가 있는가? 특별한 사례들에서는 그럴지도 모른다. 그가 그렇게 하지 않으면 그의 생명이 위협에 처할 수 있고, 거부하면 폭동과 더 많은 여성들의 살해를 야기할 수 있으며, 그는 한 경우에 그것을 적용하여 다른 경우에 그것을 더 효과적으로 공격할 만큼 충분한 신뢰를 확보할 수도 있다. 그러나 그러한 법의 적용에서 모든(all) 경우에 확고해야 할 이유가 있는가? 여기서 우리는 법률 없이는 형벌 없다(*nulla poena sine lege*)라는 원칙 이상의 것이 필요하다. 그 원칙은 법을 위반하지 않은(have not) 사람들을 처벌하지 말라고 말한다. 그 조건은 우리의 가설적 사례에서 충족된다. 그러나 그 원칙은 법을 위반한(has) 모든 사람을 처벌하라고 말하지 않는다. 그렇게 하기를 거부하는 것이 부정의일 것인가? 그렇다면 누구에게? 돌로 맞아 죽을 다른 유죄 여성들이나, 이미 그렇게 죽은 여성들의 가족들이, 다른 모든 유죄 여성도 똑같이 혐오스럽게 대우받아야 한다고 요구할 자격이 있다고 상정하는 것은 도저히 믿기 어렵다.

하트는 아마도 ‘형식적(formal)’ 정의를 두 가지 건전하지만 관련 없는 관념들과 혼동하고 있을 수 있다. 하나는 결과들뿐 아니라 절차들(procedures)에도 정의와 부정의가 있을 수 있다는 점이다. 예컨대 법적 분쟁에서 양 당사자의 말을 들어야 한다는 것은 자연적 정의(natural justice)의 요건이다. 그것을

²⁷John Gardner, 「The Virtue of Justice and the Character of Law」, 그의 *Law as a Leap of Faith* 제10장을 따른 것이다.

보장하지 않는 절차는 부정의하다. 그러나 부정의한 규칙 자체(itself)가 자연적 정의의 위반을 규정할 수 있다. 법이 부유한 사람들에게 가난한 사람들보다 자기 사건을 제시할 시간을 두 배 허용한다면, 그 법의 엄격한 적용은 자연적 정의를 진전시키는 것이 아니라 후퇴시킬 것이다. 이 근방의 다른 관념은 우리가 규칙들을 적용할 때 불편부당(impartial)해야 하며, 판단하는 이들은 ‘편견, 이해관계, 또는 변덕(prejudice, interest or caprice)’에서 행동해서는 안 된다는 것이다(161쪽). 그것도 옳다. 그러나 부정의한 법을 그 규정 내용에 따라 적용하기를 거부하는 사람에게 그런 동기가 있어야 하는 것은 아니다. 사실 혐오스러운 법 자체가 편견에 따른 것이거나 변덕스러운 것일 수 있고, 그것을 선택적으로 적용하지 않는 일은 최선의 동기에서 이루어질 수 있다.

하트의 ‘정의의 씨앗(germ of justice)’ 논제로부터 우리가 무엇인가를 견져 낼 수 있는가? 어쩌면 이것일 수 있다. 일단 우리가 규칙-적용(rule-application)에 조율되면, 우리는 필연적으로 규칙들이 특정 사례들에서(in particular cases) 어떻게 적용되어야 하는지를 생각하고 있다. 곧 사람들이 그 규칙들 아래에서 처지가 어떠한지 또는 어떠한지 하는지를 생각하고 있는 것이다. 이것은 주의를 총량적 물음들(aggregative questions)에만이 아니라 분배적 물음들(distributive questions)에 맞춘다. 그것은 요즘 충분한 처벌이 내려지고 있는지를 묻는 데 그치지 않고, 올바른 대상자들이 올바른 방식으로 올바른 범죄행위들에 대해 처벌되고 있는지를 묻도록 요구한다. 혜택과 부담이 사람들 사이에 어떻게 분배되어야 하는지를 생각하는 것은 정의의 물음들을 생각하는 것이다. A가 A가 마땅히 받아야 할 대우를 받았는지, 또는 A와 B 사이의 대우 차이가 정당화될 수 있는지에 주의 깊은 관심을 갖는 것은 정의에 대한 관심이다. 법원과 같이 그러한 물음들을 검토하고 처리할 권한을 가진 제도들을 우리가 가지고 있을 때, 우리는 정의를 행할 수 있는 제도들을 가지고 있는 것이다. (그리고 물론 부정의도.) 어쩌면 크고 복잡한 사회에서는 그러한 제도들 없이는 정의가 행해질 수 없을 것이다.

(iii) 법적 유효성과 도덕 원칙 (Legal Validity and Moral Principles)

법과 도덕 사이의 세 번째 접점은 다르다. 하트는 도덕 원칙들(moral principles)이 반드시 법의 원천인 것은 아니지만, 법의 원천인 것들에 의해 그렇게 권위를 부여받는다면 법의 원천이 될 수 있다(could)고 인정한다. 이를 표현하는 한 방식은, 하트가 승인 규칙(rule of recognition)은 필연적으로 사회적 구성물(social construction)이지만 그것이 동원하는 기준들(criteria)은 반드시 그렇지는 않다고 본다고 말하는 것이다. 그는 도덕 원칙들이 가치 있는 원칙들이기 때문에 또는 현존 법을 정당화하기 때문에 법이라고 생각하지 않는다. 그러나 어떤 식으로든 법 안에 넣어진다면, 그것들은 법이 될 수 있다.

여기서 하트는 구성주의 논제(constructivist thesis)를 해석하는 두 방식 가운데 하나에 관해, 흔히 ‘포괄적(inclusive)’ 법실증주의라고 불리는 입장에 찬성하고, 법의 원천들(sources of law)은 이상적 도덕(ideal morality)의 원칙들을 포함할 수 없다고 보는 ‘배타적(exclusive)’ 법실증주의에 반대하는 입장을 취한다.²⁸ 그가 이 결론에 이르는 경로는, 부분적으로 그가 본문을 썼을 때에는 이러한 대안들이 아직 구별되어 있지 않았기 때문에, 되짚어가기 어렵다. 그러나 후기(Postscript)에서 그의 결론은, 법적 유효성(legal validity)이 순전히 어떤 규범(norm)의 ‘계보(pedigree)’, 곧 “법들이 법제도들(legal institutions)에 의해 채택되거나 창출되는 방식에만 관련되고 그 내용(content)과는 관련되지 않는” 특성들의 문제일 필요는 없다는 것이다(247쪽).²⁹ 대신 법적 유효성은 도덕적 적절성(moral propriety)에 좌우될 수 있다.

우리는 여기서 포괄적 실증주의 논제 자체를 평가할 수 없다.³⁰ 그러나 하트가 이 논쟁에 가져온 하나의 혼동을 걷어내려 시도할 가치는 있다. 승인

²⁸ 하트는 자신의 입장을 ‘연성(soft) 실증주의’ 라고 부르지만, 이 입장이 법이 참조하는 모든 것을 법이 포함한다고 보기 때문에 ‘포괄적(inclusive) 실증주의’ 라는 명칭이 더 명료하다.

²⁹ 이 은유는 Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* 17쪽에서 처음 사용된다.

³⁰ 이 이론은 W. J. Waluchow, *Inclusive Legal Positivism* (Oxford University Press, 1994) 및 Jules Coleman, *The Practice of Principle: In Defence of a Pragmatist Approach to Legal Theory* (Oxford University Press, 2001)에서 옹호된다. Joseph Raz, *Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics* (Oxford University Press, 1994) 제9장, 제10장 및 Scott Shapiro, 「On Hart's Way Out」 (1998) 4 *Legal Theory* 469에서 비판된다.

규칙 안의 기준들이 도덕 원칙들을 포함할 수 있는지라는 질문은, 이 기준들이 계보의 문제들인지라는 질문과 같지 않다. ‘계보(pedigree)’와 가능한 대비는 두 가지가 있다. 실체(substance)와의 대비가 있고, 도덕(morality)과의 다른 대비가 있다. 혼동이 지배하는 것은 ‘실체적(substantive)’이라는 말을 ‘정당화된(justified)’ 또는 ‘도덕적(moral)’이라는 뜻으로 쓰는 혼란 습관 때문이다 (위 4 (ii)에서 ‘실체적 정의(substantive justice)’라는 관념에서 보았듯이). 본문에서 하트는 모든 법체계가 법적으로 무제한적인 권한을 포함한다는 오스틴(Austin)의 견해를 비판하면서 이러한 문제들을 도입한다. 오스틴주의자는 아마 주권적 입법자가 자신이 입법하는 ‘방식과 형식(manner and form)’에 관해서는 제한될 수 있다고 인정할 수 있을 것이다. 예컨대 특별한 고지와 토론의 요건들, 또는 특별다수 의사결정에 종속될 수 있다. 그러나 많은 성문헌법들에는 그런 식으로 특징지을 수 없는 제약들도 있다. 그것들은 “특정 사안들을 그 입법 권능의 범위에서 완전히 배제하고, 그리하여 실체적 제한들(limitations of substance)을 부과한다” (68쪽). 그것들은 “단지 도덕적이거나 관행적인 것이 아니라 법적인” 무능력들(disabilities)을 부과한다(69쪽).³¹ 하트는 그 예로 미국 헌법 제16차 수정조항을 제시하는데, 그 일부는 “개인 인두세(capitation tax) 또는 기타 직접세(direct tax)는, 앞서 지시된 인구 조사 또는 산정에 비례하지 않는 한, 부과될 수 없다”고 요구한다. 그것은 분명히 방식-및-형식 요건이 아니므로, 한 의미에서는 실체적이다. 그러나 하트는 또한 “미국에서처럼 일부 법체계들에서는, 유효성의 궁극적 기준들이 계보 이외에도 정의의 원칙들이나 실체적 도덕 가치들을 명시적으로 편입할 수 있고, 이것들이 법적 헌법 제약들의 내용을 형성할 수 있다” (247쪽)고 말한다. 이것은 ‘실체적’이라는 말의 다소 다른 관념이다. 가능한 승인 규칙의 다음 단편들을 비교해 보라.

(S1) 의회는 국교를 설립하는 어떤 법도 제정할 수 없다.

(S2) 의회는 불공정한 법을 제정할 수 없다.

(P1) 의회는 은밀하게 법을 제정할 수 없다.

³¹여기서 하트는 ‘도덕적 또는 관행적(moral or conventional)’이라는 표현으로, 오스틴(Austin)이 법적 권한에 대한 ‘실정적 도덕(positive morality)’의 비법적(non-legal) 제약이라 부른 것과, 다이시(Dicey)가 말한 헌법적 ‘관행(conventions)’를 모두 포괄하고자 한다.

(P2) 의회는 불공정한 방식으로 법을 제정할 수 없다.

규칙 (S1)과 (S2)는 유효성의 실체적 기준들(substantive criteria of validity)을 설정하고, (P1)과 (P2)는 절차적 기준들(procedural criteria)을 설정한다. 그러나 우리는 그것들을 다른 방식으로도 짚지을 수 있다. (S2)와 (P2)는 유효성의 도덕적 기준들(moral criteria for validity)을 설정하는 반면, (S1)과 (P1)은 사실적 기준들(factual criteria)을 설정한다. (이것은 그 기준들이 완전히 확정적인 기준들을 설정한다는 말이 아니라, 어떤 법이 종교를 설립하는지 또는 비밀리에 만들어졌는지는 둘 중 어느 것을 하는 것의 적절성(propriety)에 관해 어떤 견해에도 이르지 않고도 알 수 있다는 말이다.) 그러나 이제 우리는 묻는다. (P2)도 계보 검사 기준(a test of *pedigree*)을 진술하는가? 그것은, 그것을 적용하려면 결국 채택된 법의 내용이 아니라 그 법이 채택된 방식을 검토한다는 의미에서는 그렇다. 그러나 (P2)가 충족되는지 여부(whether)를, 그것이 만들어진 방식의 도덕적 적절성(moral propriety)에 관해 결정하지 않고는 알 수 없다는 의미에서는 그렇지 않다. 따라서 계보(*pedigree*) 은유는 오도할 가능성이 크며, 우리는 그것을 버리고 사회적 사실의 사안들과 도덕 판단을 요구하는 사안들 사이의 구분을 채택해야 한다.

사안들은 세 가지 다른 것들로 인해 더 복잡해진다. 첫 번째는 동음이의(homonymy)이다. 헌법이나 그 밖의 곳에 도덕적으로 들리는 용어들(terms)이 있다는 사실은 법에 대한 도덕적 검사 기준들이 있을 수 있음을 시사하기조차 하지 않는다. 그러한 용어들 중 일부는 법적 맥락에서 특수한 의미를 가지거나 가지게 되었는데, 그 의미는 관습적 도덕(customary morality), 사법적 결정들(judicial decisions), 법적 해석의 전통들에 의해 통제되는 의미이다.³² “모든 개인은 법 앞에 평등하다” 라고 말하는 헌법은 평등이라는 도덕적 이상에 손을 뻗고 있을 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 우리는 법원들과 그 밖의 사람들이 실제로 그것을 가지고 무엇을 하는지 보아야 할 것이다. 그리고 어떤 규정이 도덕적 이상을 진술하면서 그 헌법적 생애를 시작하더라도, 사법적 결정들은 그것을 불평등의 사실적 전형들(factual paradigms) 및 불평등에 대한 다갈래 교의적 검사 기준들(multi-prong doctrinal tests)로 뒤덮을 수 있다. 이것들은

³²언제나 그렇듯, ‘통제됨(controlled)’ 이란 ‘완전히 통제됨’ 을 의미하지는 않는다.

법의 유효성에 대한 통상적인 원천 기반 검사 기준들(source-based tests)이다. 그것들은 원래의 추상적 도덕 이상으로부터 너무 멀어져서, 그것이 여전히 작동 중인지조차 불분명할 수 있다.

두 번째 복잡성은 속존(supervenience)이다. 예컨대 어떤 것이 ‘불공정하다(unfair)’ 면 그것을 불공정하게 만드는 사실들, 곧 그것이 불공정한 덕분이 되는(in virtue of which) 사실들이 있으며, 하나의 배열은 불공정하고 다른 배열은 공정하려면 이러한 사실들에도 어떤 차이가 있어야 한다고 생각하는 것은 그럴듯하다. 어떤 헌법이 차별적인 제정법들(statutes)을 금지한다고 가정하자. 여기서 차별(discrimination)이 도덕적으로 그른 것으로 이해된다. 그것이 통상적 사회적 사실들—예컨대 결정이 내려질 때의 의도에 관한 사실들, 또는 그 결정이 다양한 사람들에게 미치는 상대적 영향에 관한 사실들—덕분에 그른 것이라면, 이러한 사실들은 어느 견해에서든 법에 대한 검사 기준의 일부일 수 있다. 배타적 실증주의는 법에 대한 궁극적 검사 기준들이 어떤 것을 공정하거나 불공정하다고 생각하는 논거에서 언급될 수 있는 사실들을 전혀 포함하지 않아야 한다고 요구하지 않는다. 그것은 이해 불가능할 것이다. 그것은 관련 사실들을 그러한 도덕적 속성들에 미치는 영향에 관한 견해에 이르지 않고도 확인할 수 있어야 한다는 것만 요구한다.

세 번째 복잡성은 불확실성(uncertainty)이다. 하트는 입법부가 어떤 산업에 그 서비스에 대해 오직 ‘공정한 요금(fair rate)’ 만 부과할 것을 요구하는 사례를 검토한다(131-2쪽). “필수 서비스에 대해 공중을 인질로 잡는 것과 같은 높은 요금”(131쪽)처럼 입법에 의해 분명히 고려되었을 만큼 명백한 불공정의 몇몇 극단적 사례들이 있기는 할 것이다. 그러나 사전에 특정하려 시도하는 것이 불가능하고 현명하지도 않을 다른 많은 사례들이 있을 것이다.

이 경우들에서, 규칙제정 권위기관(rule-making authority)은 재량(discretion)을 행사해야 함이 분명하며, 다양한 사례들이 제기하는 물음을 하나의 유일하게 올바른 답이 찾아질 수 있는 것처럼, 곧 많은 상충하는 이해관계들 사이의 합리적 타협인 답과 구별되는 답이 있는 것처럼 다룰 가능성은 없다(131-2쪽).

그렇다면 적어도 ‘공정성(fairness)’ 이 불확실한 정도에서는, 제정법 안에서 이 용어에 대한 참조(reference)는 법원들이 재량(discretion)을 행사할 것을 요구한다. ‘공정한 요금(fair rate)’ 을 명하는 입법자는 이 점을 알고 있을 것이며, 법원들에게 재량적 권한(discretionary power)을 부여한 것으로 이해되어야 한다. 그것은 법원들이 좋아하는 것은 무엇이든 할 권한이 아니라, 무엇이 불공정한지를 판정하고 그들의 판정(determination)이 구속하도록 할 권한이다. 후기(Postscript)에서는 그림이 달라 보인다. 여기서 ‘적법절차(due process)’ , ‘평등(equality)’ 등을 참조하는 헌법 규정들은 도덕 원칙들(moral principles)이 법안으로 편입되는 사례들로 제시된다. 그것들이 재량을 부여하는지 여부는 이제 그 불확실성의 정도가 아니라, 그것들에 관한 분쟁들을 해소하는 데 필요할 도덕 판단들이 ‘객관적 지위(objective standing)’ 를 가지는지 또는 가지지 않는지에 달려 있다고 말해진다(253-4쪽). 도덕 판단들이 객관적이라면, 불확실성을 해소하는 판정들은 도덕 기준들을 참조하는 이미 존재하는 법(pre-existing law)을 적용할 뿐이다. 도덕 판단들이 객관적이지 않다면, 이것들은 “법원들에게 도덕에 따라 법을 만들라(make law)는 지시들을 구성할 수 있을 뿐이다”(254쪽). 하트는 법리학(jurisprudence)이 논쟁적인 메타윤리 이론들(meta-ethical theories)에 대한 약속들을 피하기를 원하므로, 그 물음을 열어둔다.

만약 이것이 헌법들 안의 도덕적 언어가 제정법들 안의 도덕적 언어와 다르게 기능한다고 느낀시 암시한다면, 그것은 동기가 부족해 보인다. 성문헌법(written constitution)은 결국 특수한 종류의 제정법일 뿐이다. 제정법에서는 ‘공정성(fairness)’ 에 대한 참조가 적어도 공정성이 무엇을 요구하는지가 불확실할 때 재량적 권한을 부여한다고 보면서, 헌법에서는 예컨대 ‘근본적 정의(fundamental justice)’ 에 대한 참조가, 그것이 무엇을 요구하는지가 불확실할 뿐 아니라 그 불확실성의 도덕적 해소가 ‘객관적(objective)’ 이지 않을 때에만 재량적 권한을 부여한다고 생각할 이유가 무엇인가? 그 해소를 달성하는 데 동원될 원칙들의 지위와 무관하게, 해소가 요구된다는 것만으로 충분하지 않은가? 헌법적 기본원칙들의 경우에는 단순한 제정법의 경우보다 재량이 더 걱정스럽게 보일 수 있다. 그러나 그것은 재량이 부재한다는 점을 보여주지 않는다. 게다가 재량은 전부-아니면-무의 사안(all-or-nothing affair)이 아니다.

사실 기반 기준들(fact-based criteria)은 재량적 판정들을 부분적으로 통제할 수 있다. 켈젠(Kelsen)의 은유에서처럼, 그 판정들이 부합해야 하는 ‘틀(frame)’을 제공함으로써뿐 아니라, 이런저런 종류의 판정들에 대한 비확정적 이유들(non-conclusive reasons)로서도 그럴 수 있다.³³

하트가 자신의 입장을 위한 논변에 가장 가까이 이르는 곳은 다음이다. 그는 넓은 도덕적 적절성(moral propriety)을 법에 대한 검사 기준(test for law)으로 삼는 가상의 헌법을 검토한다. 어떤 것이 어떤 방식으로든 그르거나, 부정의하거나, 불공정하다면, 어떤 것도 법으로 간주되어서는 안 된다. 그는 이것에 논리적으로 잘못된 점은 없을 것이라고 말한다. “이 비범한 장치에 대한 반대이유는 ‘논리(logic)’가 아니라 그러한 법적 유효성 기준들의 극심한 불확정성(gross indeterminacy)일 것이다. 헌법들은 이런 형식을 취함으로써 문제를 초대하지 않는다.”³⁴ 그러나 ‘논리(logic)’가 개념적 논변(conceptual argument)을 포함한다면, 그러한 반대이유가 있을 수 있다. 조셉 라즈(Joseph Raz)는, 이것은 단지 문제를 초대하는 데 그치는 것이 아니라 법이 주장하는 종류의 권위를 가지는 것과 양립 불가능할 것이라고 논변한다.³⁵ 모든 법은 정당한 권위를 주장하며, 권위를 가질 수 있는 종류의 것일 때에만 그렇게 일관되게 할 수 있다. 법의 주장은 공허할 수 있고(hollow), 불성실하거나 부정의하거나 지혜롭지 못할 수 있다. 그러나 그것은 이해 가능해야 한다(intelligible). 법체계들을 포함한 실천적 권위들(practical authorities)의 역할은 사람들이 그들이 할 이유가 있는 것에 부합하도록 돕는 것이다.³⁶ 권위들은 자신들의 지시들(directives)을 그 이유들에 기초시킬 때, 그리고 그들의 지시들을 따르려 시도하는 일이 수범자들이 그들에게 적용되는 기저 이유들(underlying reasons)이 요구하는 바를 준수할 개연성을 더 높일 때에만 그렇게 할 수 있다. 그것은

³³Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* 350–1.

³⁴H. L. A. Hart, *Essays in Jurisprudence and Philosophy* 361.

³⁵Joseph Raz, *The Morality of Freedom* (Oxford University Press, 1986), chap. 2; *Ethics in the Public Domain*, chap. 10; and *Between Authority and Interpretation: On the Theory of Law and Practical Reason* (Oxford University Press, 2009), chap. 5.

³⁶이는 단지 그들이 이기적(selfish) 이익에 부합하는 행동이거나, 자신이 이유(reason) 있다고 생각(think) 하는 행동이 아니라, 그들이 ‘객관적으로(objective)’ 이유가 있는 행위를 의미한다.

다시, 지시들이 바로 그 이유들에 대한 호소와 독립적인 방식으로 식별될 수 있을 때에만 가능하다. 따라서 법이 무엇을 요구하는지를 알기 위해 먼저 자신이 무엇을 해야 하는지 알아내야(*figure out*) 한다면, 법은 누구에게도 그가 무엇을 해야 하는지 아는 데 도움을 줄 수 없다. 제정법은 사람들에게 서로 공정하게 거래하라고 말하는 것만으로 더 공정한 결과들을 확보할 수 없고, 헌법은 모든 사람이 평등하다고 선언하는 것만으로 더 평등한 사회를 산출할 수 없다. 권위 있는 지시(*authoritative direction*)를 제공하려면, 그것들은 사람들에게 이러한 것들이 실제로 무엇을 요구하는지 말해 주어야 한다. 이것이 라즈의 논변이다. 이것은 분석법리학(*analytical jurisprudence*)에서 가장 많이 논의된 논변들 중 하나이다. 그 안에는 많은 단계들이 있고 그중 몇몇은 논쟁적이다. 그러나 그것은 하트가 이용 불가능하다고 선언하는 종류의 논변이며, 우리가 하트의 견해에 동의하기 전에 검토되어야 할 것이다.³⁷

포괄적 법실증주의(*inclusive legal positivism*)는 도덕(*morality*)이 법적 논증에서 적절하게 역할을 찾을 수 있으려면 그렇게 하도록 초대되어야 한다고 시사하는 듯하다. 하트는 유효성의 궁극적 기준들(*ultimate criteria of validity*)을 통해 초대장을 발한다.³⁸ 그러나 초대장이 정말 필요한가?³⁹ 누구도 판사들이 논리적 추론(*logical inference*)의 원리들이나 단순 산술(*simple arithmetic*)에 의존할 수 있는 것은 오직 법이 이 원리들을 특별히 안으로 초대했기 때문이라고 생각하지 않는다. 누구도 영어 문법의 규칙들이 영국법의 승인 규칙(*rule of recognition*) 안에 자리를 필요로 한다고 생각하지 않는다. 어찌면 결국 초대장은 필요하지 않을 수 있고, 도덕 원칙들은 이러한 다른 기준들처럼 이미 법원 안에 자리 잡고 있을 수 있다. 그렇다면 하트는 존재하지 않는 문제에 대한 해법을 제안하고 있는 것일 수 있다.

³⁷ 게다가 이후의 한 논문에서 하트 자신도 이 입장의 몇 가지 핵심 개념을 수용한다. 참고: H. L. A. Hart, 「Commands and Authoritative Legal Reasons」, *Essays on Bentham* (Oxford University Press, 1982).

³⁸ 토니 오노레(Tony Honore)는 법이 제기하는 도덕적 주장(*moral claims*)을 통해 그러한 요청(*invitation*)이 이루어진다고 본다. 참고: 「The Necessary Connection between Law and Morality」, (2002) *Oxford Journal of Legal Studies* 22:489.

³⁹ Joseph Raz, *Between Authority and Interpretation*, 제7장 참조.

5. 사실, 가치, 방법 (FACT, VALUE, AND METHOD)

하트(Hart)는 서문(Preface)에서 이 책의 목적이 “법(law), 강제(coercion), 도덕(morality)을 서로 다르지만 관련된 사회적 현상들(social phenomena)로서 이해하는 일을 증진하는 것” 이라고 말한다. 그는 법률가들이 이 책을 “분석법리학(analytical jurisprudence)” 의 한 작업으로 볼 것이라고 예측한다. 왜냐하면 이 책은 “법이나 법정책(legal policy)에 대한 비판보다는 법적 사고(legal thought)의 일반적 틀을 명료화(clarification)하는 일에 관심을 두기” 때문이다. 그는 또한 이 책을 “기술적 사회학(descriptive sociology)의 한 에세이” 로 생각할 수도 있다고 말한다(vi). 우리는 이 발언들을 어떻게 받아들여야 하는가?

(i) 법리학과 사회학 (Jurisprudence and Sociology)

현장조사도, 통계모형도, 심지어 법 사례들도 거의 제시하지 않는 이 책은 묘한 종류의 사회학이다. 하트는 나중에 돌아보며, 이 책이 사회학의 한 종류(kind)라고 시사하기보다는 어떤 식으로든 사회학을 위한 예비작업(preparatory)이라고 말했어야 했다고 한다⁴⁰. 이 다섯 단어는 그럴 만한 것보다 더 많은 골칫거리를 낳았다. 그 요점은 단지 하트의 방법이, 기술적 사회학의 방법들과 마찬가지로 (like), 사실들(facts)에 대해 책임을 지되 그것들에 관해 어떤 도덕적 또는 정치적 입장도 취하지 않는다는 점을 강조하는 데 있다. 그는 법철학의 주장들(claims)을 검사할 때 법 세계에 관해 식견 있는 사람이 가진 지식을 사용하라고 독자에게 거듭 호소한다. 정말 법규칙들(legal rules)이라는 것이 존재하는가? 보라(136). 모든 법체계가 무제한적 주권자(illimitable sovereign)를 가지는가? 보라. 선험적(a priori) 이론과 법에 대한 일상적 지식 사이에 충돌이 있다면, 후자를 택하라. 그것은 수정이 필요할 수 있고, 아마 규율도 필요할 것이지만, 출발해야 할 곳이다. 이 책의 경험적 기반(empirical basis)은 그보다 더 정교하지 않다. 그러나 기술적 사회학처럼 이 책에도 경험적 기반이 있다. 이 책은 정의(definitions)나 공리(axioms)에서 시작하여 법에 대한 필연적 진리들을 도

⁴⁰David Sugarman, ‘Hart Interviewed: H. L. A. Hart in Conversation with David Sugarman’ (2005) 32 *Journal of Law and Society* 267, 291.

출한다고 자처하지 않는다. 법이 어떠한가 하는가에 관한 도덕적 주장들에서 시작하여 법이 실제로 어떠한가에 관한 결론을 추론하지도 않는다.

기술적 사회학은 그 관찰들(observations)의 양과 질에서 일상적 지식을 넘어선다. 그것은 종종 그 관찰들을 일반화들로, 또는 더 야심차게는 예측들로 조립하려 한다. 하트는 둘 중 어느 것도 하지 않는다. 그는 우리가 이미 알고 있는 기본적인 것들을 가지고 작업한다. 그는 법의 본성에 관한 하나의 이론을 제시하며, 그 이론은 다른 영향력 있는 이론들과 달리 그러한 것들과 일관된다고 주장한다. 그의 이론은 사회-법적 데이터의 바다를 훑어 건져 올린 일반화들의 집합이 아니며, 아무것도 예측하려 하지 않는다. 그렇다면 그것은 우리가 이미 알고 있는 것에 어떻게 가치를 더할 수 있는가? 그것에 대한 우리의 이해를 깊게 함으로써이다. 그것은 일상적 사실들 사이의 놀라운 관계들, 그 사실들의 눈에 띄지 않았던 전제들(presuppositions), 그리고 특히 특정 사실들의 더 넓은 의의를 보여준다. 물론 설명(explanation)과 이해(understanding) 사이에 뚜렷한 단절은 없다. 법사회학과 법철학의 풍부한 연구들은 양쪽 일을 얼마간씩 수행한다. 이해는 법에 대한 설명적 탐구나 예측적 탐구의 경쟁자가 아니다. 또한 그것은 누가 무엇을 어떻게 연구해야 하는지를 규율한다고 자처하는 허가 체계도 아니다. 그것은 그 자체의 일이다.

이것은 분석적 법리학(analytic jurisprudence)과 법사회학이 대체로 병행해 진행될 수 있음을 시사한다. 그렇다면 첫째가 때로 둘째에 대한 예비작업이 될 수 있다는 하트의 시사에 대해 어떤 논거가 성립할 수 있을까? 켈젠(Kelsen)은 “[사]회학적 법리학(sociological jurisprudence)은 법의 법리학적 개념(juristic concept of law), 곧 규범적 법리학(normative jurisprudence)이 정의하는 법 개념을 전제한다”고 말했다⁴¹. 그의 기본 관념은, 사회학이 법제도들과 법적 실천들을 연구하고 그것들에 관해 일반화하려 하는 한, 그것들에서(with them) 시작해야 한다는 것이었다. 권한부여 규칙들(power-conferring rules)의 사회적 결과들에 관심이 있다면, 어느 것들이 그런 규칙들인지 말할 수 있어야 한다.

⁴¹Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* 178. 여기서 ‘규범적(normative)’이란 ‘규범(norms)과 관련된’이라는 뜻이지, ‘도덕적으로 평가적인’이라는 뜻이 아니다.

거기에는 어느 정도의 ‘규범적 법리학’이 필요하다. 또는 다른 예를 들 수 있다. 사회학자들은 법의 지배(rule of law)에 대한 실증적 측정치들(empirical measures)을 개발하려 한다. 이것들이 그 대상에 대한 타당한(valid) 측정치들 인지 알려면, 우리는 법의 지배가 무엇인지 알아야 한다. 내가 알기로, 주요 지표들(leading indices) 가운데 어느 것도 특정 관할권에서 법들(laws)이 소급적이지도, 모호하지도, 서로 충돌하지도 않는 정도를 추정하려 하지 않는다. 그런데 이것들은 모두 법의 지배의 중심적 요건들이다⁴². 그러나 그중 일부는 여러 관할권에서 사유 재산의 보장이나 계약 자유를 추정하고, 그러한 요소가 더 많은 곳에 더 높은 법의 지배 점수를 부여한다. 이것은 명백한 정치적 편향을 드러내며, 또한 개념적 혼란의 신호이기도 하다. 법의 지배 개념(concept)에 대해서는 논쟁이 있지만, 그것이 ‘자본주의의 전제 조건들’을 뜻한다고 생각하는 사람은 그 관념(idea)을 매우 빈약하게 파악하고 있는 것이다. 이에 대해 적어도 이러한 실증적 측정치들은 신뢰할 수 있고, 관심 변수들과 상관관계가 있으며, 법과 사회에 관해 우리가 가진 다른 지식들과 연속적이라고 답할 수도 있다⁴³. 그렇더라도 법사회학이 관련 개념들이 골라 지목하는 핵심에서 너무 멀리 표류하면, 그것은 주제를 바꾼 것이다. 어떤 주제들은 바뀔 필요가 있을 수 있다. 자연과학의 진보는 때때로 하나의 존재론을 찢어 버리고 다시 시작함으로써 이루어졌다. 그러나 사회과학의 진보가 규칙들, 책무들, 권한들, 법원들 등으로 이루어진 우리의 친숙한 법적 존재론, 또는 법의 지배 같은 친숙한 법적 가치들을 찢어 버릴 것을 요구한다면, 그것은 법 아닌 것의 사회학이 될 것이다. 이것은 법리학(jurisprudence)에 어느 정도의 우선성(priority)을 준다.

우리가 ‘법의 법리학적 개념(juristic concept of law)’과 관련 개념들을 붙들고 가려 한다면, 하트가 약속하는 더 깊은 이해를 우리는 어떻게 얻는가? 어디서 시작하는가? 하트는 종종 우리가 어떤 것들을 어떻게 판단하거나 분류할지를 묻는 방식으로 우리의 일상적 지식을 이끌어내려 하며, 때로는 우리가 그것들에

⁴²지표(index)를 구성하려는 몇몇 시도와 그 구성상의 문제에 대한 검토로는 Tom Ginsburg, 「Pitfalls of Measuring the Rule of Law」 (2011) 3 *Hague Journal on the Rule of Law* 269 참조.

⁴³법리학에 대한 사회과학적 접근의 적극적인 옹호로는 Brian Leiter, *Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy* (Oxford University Press, 2007) 참조.

관해 무엇이라고 말할(say) 것인지를 묻는 방식으로 그 일(that)을 한다. 이것이 그의 법리학을 의미론(semantics)의 한 분과로 만드는가? 하트는 철학에서의 ‘언어적 전환(linguistic turn)’에 영향을 받았고, 스스로도 그 주창자라고 보았다⁴⁴. 그의 특유한 경로는 옥스퍼드에서 동료들인 J. L. 오스틴(J. L. Austin)과 길버트 라일(Gilbert Ryle)이 발전시킨 일상 언어철학의 영향을 받았다⁴⁵. 그럼에도 이 책의 시대와 출처를 고려할 때 가장 두드러지는 점은 『법의 개념(The Concept of Law)』에 언어분석이 얼마나 적은지(little)이다. 우리는 언어가 다양한 기능들을 가진다는 것, 문장들이 맥락들을 가진다는 것, 그리고 어떤 이론들은 개념 사용의 기준들(criteria)을 제시하는 것으로 이해될 수 있다는 점을 상기하게 된다. 몇몇 지점은 언어적 구별들로 강화된다. (하트는 어떤 일을 ‘하지 않을 수 없는 상태(being obliged)’와 그것을 ‘할 의무를 지는 상태(being obligated)’ 사이에, 그리고 어떤 일을 ‘대체로(as a rule)’ 하는 것과 ‘규칙을 가지고 있는 것(having a rule)’ 사이에 차이가 있다고 주장한다.) 그 정도가 전부다. 언어철학자들에게 있었던 이론 구성에 대한 적대감은 없다. 법체계(legal system)가 ‘가족 유사성(family-resemblance)’ 개념이라거나 그와 비슷한 것이라는 시사도 없다. 하트는 심지어 어떤 것이 법체계이기 위한 필요충분조건들(necessary and sufficient conditions)까지 정식화한다! 그는 이 문제나 법리학의 어떤 중심 문제도 단어들의 의미에 호소함으로써 접근하지 않는다. 하트는 언어적 접근의 무용함을 거듭 경고한다. “‘법이란 무엇인가?’라는 질문에 대해 질문자에게 ‘법’과 ‘법체계’라는 단어들의 사용을 지배하는 기존 관행들을 상기시킴으로써 답하려는 것은,” 그가 말하듯, “‘쓸모없다’” (5). 더 넓은 법 개념과 더 좁은 법 개념 사이에서 선택하려면 의미론(semantics) 이상의 것이 필요하다. “이 쟁점을 언어 사용의 적절성(proprieties)에 관한 문제로 본다면 우리는 이 쟁점과 충분히 씨름할 수 없다” (209). 법리학에 관한

⁴⁴Richard Rorty 편, *The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method* (University of Chicago Press, 1967) 참조.

⁴⁵그리고 후기 비트겐슈타인(later Wittgenstein), 특히 그의 제자 프리드리히 바이스만(Friedrich Waismann)을 통해 수용된 견해도 참고할 수 있다. 하트와 그 당시 옥스퍼드 철학자들과의 개인적·지적 관계에 대한 통찰력 있는 논의는 니콜라 레이시(Nicola Lacey), *A Life of H. L. A. Hart: The Nightmare and the Noble Dream* (Oxford University Press, 2004)을 참조하라.

책이 아니라 법리학의 방법론(methodology of jurisprudence)에 관한 책을 쓰는 사람이라면, 이러한 경고들을 여기서 또한 드러나는 언어철학의 다른 측면들에 대한 우호성과 조화시켜야 할 것이다. 그러나 하트는 어떤 것의 방법론에 관한 책도 쓰고 있지 않다.

물론 이 책의 제목을 포함하여 책의 수사(rhetoric)가 언어철학의 색채를 띠는 점은 부인될 수 없다. 그러나 좋은 사상사가(historian of ideas)는 문체(style)를 넘어 실질(substance)을 보아야 한다. 한 철학자가 자신이 무엇을 하고 있다고 생각했는지, 무엇을 하고 있다고 말했는지, 실제로 무엇을 하고 있었는지 사이에는 차이가 있다. (데이비드 흄(David Hume)은 정치학이 과학으로 환원될 수 있다고 말했다. 그러나 논고(Treatise)나 탐구(Enquiry) 어느 쪽에서도 단 하나의 실험이나 증명도 보고되지 않았다.) 현재 철학의 수사적 스타일들은 하트의 스타일과 다르고, 그 차이는 하트 자신의 스타일이 벤담(Bentham)의 스타일과 달랐던 것만큼이나 크다. 이것들이 실제 기법상의 차이들을 얼마나 표시하는지는 말하기 어렵다.

(ii) 명료화(clarification)와 비판(criticism)

이 책은 하트(Hart)가 ‘일반적이고 기술적인(general and descriptive)’ 것이라고 부르는 한 종류의 법이론(legal theory)을 옹호한다(239-40). 그가 뜻하는 바는 이것이 영국법(English law), 관습법(common law), 자본주의적 법(capitalist law)에 관한 이론이 아니라 법 그 자체(as such)에 관한 이론이라는 것이다. 그리고 그것은 “도덕적으로 중립적(morally neutral)이며 정당화적 목적들(justificatory aims)을 가지지 않는다. 그것은 내 법의 일반적 설명 안에 나타나는 형식들과 구조들(forms and structures)을 도덕적 또는 그 밖의 근거들에서 정당화하거나 권장하려 하지 않는다. 다만” 그는 낙관적으로 덧붙인다. “이것들에 대한 명확한 이해는 법에 대한 유익한 도덕적 비판을 위한 중요한 예비조건(preliminary)이라고 나는 생각한다” (240).

이 책이 정당화적 목적들을 결여한다고 하더라도, 그것이 도덕적으로 중립적이라는 결론이 따라 나오지는 않는다. 어쩌면 도덕적 편향이 의도치 않게 스며들

수 있다. 어떤 사람들은 그렇게 생각하는데, 그 근거는 어떤 기술(description)이든 기술되는 것에 관한 사실들의 목록 이상이어야 한다는 점이다. 관찰들(observations)은 이론 적재적(theory-laden)이고, 관찰들로부터 만들어진 기술들은 가치 적재적(value-laden)이다. 따라서 기술적 법철학(descriptive legal philosophy)은 불가능하다는 것이다. 그러나 그것은 너무 성급하다. 사실 진술(statement of fact)은 참 또는 거짓으로 평가될 수 있다. 기술은 보통 참 또는 거짓인 것으로 생각되지 않고, 유익하거나 무익한지, 밝혀 주거나 밝혀 주지 못하는지 등으로 생각된다. 어떤 대상이나 사태(state of affairs)에 대해서도 가능한 기술들은 무한히 많다. 각각에 관한 사실들이 무한히 많기 때문이다. 어떤 것에 대한 실제의 기술은 그것에 관한 모든 사실들의 목록이 아니다. 그것은 어떤 이유로 중요하거나, 두드러지거나(salient), 관련 있거나, 흥미롭다고 여겨지는 사실들의 선별(selection)과 배열(arrangement)이다. 모든 기술은 어떤 가치들을 전제하거나, 어떤 가치들의 관점에서 이루어진다. 그러나 이것이 그 기술을 제시하는 사람이 그러한 가치들을 지지한다(endorses)는 것, 또는 그것들이 도덕적 가치들(moral values)이라는 것을 함축하지는 않는다. 사건관리시스템(case-management system)을 ‘비효율적(inefficient)’ 이라고 기술하는 것은 가치중립적이지 않다. 그것은 그 시스템의 특정 특징들을 주의의 대상으로 선별한다. 그러나 선별의 이유는 화자 자신이 효율성(efficiency)을 가치 있다고, 하물며 가장 가치 있다고 또는 도덕적 가치가 있다고 생각하기 때문일 필요가 없다. 그는 청중이 그것을 두드러진 것으로 생각한다고 보거나, 대부분의 사람들이 그렇게 생각한다고 보거나, 그 사건관리시스템을 사용하는 판사들이 그렇게 생각한다고 보기 때문에 거기에 초점을 맞출 수 있다. 가능성들은 많다.

비판자들이 하트의 기술적 기획 안으로 도덕이 스며든다고 감지한다고 여기는 한 지점을 살펴보는 것이 도움이 될 수 있다. 그는 자신의 주된 논증을 허구적 사회발전사(fictional history of social development)를 통해 도입하는 것으로 유명하다(91-9). 우리는 ‘원시적(primitive)’ 사회에서 시작한다. 그 사회에서는 해야 할 일에 관한 합의(consensus)를 통해 사회질서(social order)가 달성된다. 사회 변화와 함께 이러한 장치들은 불확실성에 취약하고, 정태적이며, 비효율적이 된다. 이차적 규칙들(secondary rules)을 갖춘 법의 출현은 이러한 ‘결함들

(defects)' 을 치유하고, 그리하여 '발전된(developed)' , '복잡한(complex)' 사회에서는 승인 규칙들(rules of recognition), 변경 규칙들(rules of change), 재판 규칙들(rules of adjudication)의 사용을 통해 우리가 확실성(certainty), 역동성(dynamism), 효율성(efficiency)을 얻는 만큼 사정이 더 나아진다. 여기서 비판자들이 달려든다⁴⁶. 하트는 법의 이점들(merits)에 대해 중립적이라고 주장하면서 어떻게 법이 '결함들' 을 치유한다고 말할 수 있는가? 그는 어떻게 전(前)법적(pre-legal) 사회들을 '원시적' 이라고 부르면서도 그것들을 암묵적으로 비난하지 않을 수 있는가?

이 문맥에서 '원시적(primitive)' 은 분명 단순하다는 뜻이다. 어리석거나 야만적이라는 뜻이 아니다. 그리고 단순한 사회들이 법을 가지지 않는 이유는 그것들이 법을 발명할 만큼 충분히 문명화되어 있지 않기 때문이 아니다. 그것은 그 사회들이 법을 필요로 하지(need) 않기 때문이다. 인간 본성이나 사회 안에는 법을 요구하는 것이 아무것도 없다. 많은 사회들이 법 없이도 잘 지내왔다(91). 국제 영역에서 볼 수 있듯, 고도로 체계화된 규칙 체계들은 “필수품이 아니라 사치품” 이다(235). 예컨대 사회들이 작고, 안정적이며, 사회적으로 또 이념적으로 결속되어 있을 때, 그 안에서 작동하는 단순한 사회질서의 형식들은 실제로 잘 작동한다(91). 그러나 “이와 다른 어떤 조건들에서도 그러한 단순한 사회통제의 형식은 결함 있는 것으로 판명될 수밖에 없고, 서로 다른 방식으로 보완될 필요가 있을 것이다” (92). 먼저 주목할 점은, 문제의 결함(defect)이 도덕적 악덕(moral vice)이 아니라 사회통제 메커니즘들 안의 기능적 결손(functional deficit)이라는 점이다. 그것이 도덕적으로 유감스러워할 일인지는 이 메커니즘들이 선(good)을 지향하는지 악(evil)을 지향하는지에 달려 있다. 더 효율적인 사회통제는 나쁜 것일 수 있다. 둘째, 결함은 단순한 사회 안에 있다기보다 통치 양식들과 사회적 복잡성 사이의 부조응(mis-match) 안에 있다. 결함은 낯선 사람들의 큰 사회를 친구들의 작은 사회인 것처럼 통치하려는데 있다. 예컨대 일부 현대 공동체주의(communitarian) 정치이론들의 실수가 그렇다. 여기에는 우리가 법 없는 단순한 사회와 법 있는 복잡한 사회 사이에서

⁴⁶수많은 비판적 포착자들 가운데 Stephen Guest, 「Two Strands in Hart's Concept of Law」, Stephen Guest 편, *Positivism Today* (Dartmouth, 1996) 29 참조.

선택할 수 있다면 후자를 선호해야 한다는 시사가 없다.

따라서 이 논변은 하트가 추구하는 종류의 중립성을 포기한 것으로 비난될 수 없다. 물론 하트는 이차적 규칙들의 출현에 초점을 맞춘다. 그가 그것을 법에 관해 두드러지고 중요한 사실이라고 생각하기 때문이다. 그러나 그가 그것을 바람직하다고 생각하기 때문은 아니다. 사실 위에서 보았듯 그는 그것을 도덕적으로 위협하다고 생각한다. 아이러니하게도, 편향은 오히려 그의 논변 안에 어떤 종류의 근대주의적 승리주의(modernist triumphalism)를 읽어 넣는 사람들에게 더 자주 있다. 그들은 어떤 사회가 법체계를 결여한다면 근대성의 성취들 중 하나를 결여한다고 상정한다. ‘원시적’ 사회들을 문명화되지 않았다고 생각하는 것은 편협하고 깎아내리는 일이므로, 후견부정법(modus tollens)에 의해 그 사회들은 법체계들을 가지고 있어야 한다. 따라서 이러한 사회들을 법체계들로서(as) 인정하지 못하는 모든 법리학은 근대법 또는 서구법에 유리하게 편향되어 있다. 그 논변의 형식은 놀랍다. 그것은 모든 사회가 법을 가져야 한다는 전제에서 시작하여, 모든 사회가 실제로 법을 가진다는 추론을 끌어낸다. 그 추론은 명백히 타당하지 않다(invalid). 또한 그것은 하트가 거부하는 전제에 기대고 있다. 그는 법에 대한 열광을 공유하지 않기 때문에, 법을 사방에서 찾아야 한다고 느끼지 않는다.

유사한 고려들은 제10장에서 국제법(international law)은 체계(system)가 아니라 규칙들의 집합(set of rules)이며, 그런 방식에서 단순한 사회질서와 조금 닮았다는 하트의 주장(claim)에도 적용된다. 국제법학자들은 분개한다. 하트가 국제법에 ‘낮은 점수’를 주며, 국제법을 그것이 지닌 특별한 것이라기보다 ‘추방자(outcast)’ 처럼 취급한다고 보는 것이다⁴⁷. 그들은 자신들의 주제의 지위를 너무 걱정할 나머지, 이 장의 주된 부담이 국제법을 방어하는(defend) 데 있다는 점을 거의 알아차리지 못한다. 곧 국제법이 중앙 주권자나 강제적 관할권을 결여하므로 법일 수 없다는 잘못된 생각으로부터 국제법을 방어하는 데 있다는 점이다. 하트는 국제법이 그다지 체계화되어 있지는 않다고 의심한다. 그는 그 분야에서 전반적 승인 규칙(overall rule of recognition)과 같은 것을 발견하지

⁴⁷ Ian Brownlie, ‘The Reality and Efficacy of International Law’ (1981) 52 *British Yearbook of International Law* 1, 7–8.

못한다. 그러나 이것이 다른 이차적 규칙들이 존재할 가능성을 배제하지는 않는다. 예컨대 어떤 실체(entity)가 국가(state)인지 또는 조약(treaty)을 채택하려면 무엇이 필요한지를 우리에게 알려주는 규칙들이 있을 수 있다. 두드러지는 점은, 국제법학자들이 국제질서 자체에 관해 쓸 때에는(그것에 대한 법리학 이론들에 관해 쓸 때가 아니라) 그 중심 규칙들 중 많은 것이 불균등한 실효성(effectiveness)을 가진다는 점, 일부 중요한 규범들에 대한 검사 기준들(tests)이 심각하게 미확정적이라는 점, 재판기관들이 특수 목적 재판소들로 파편화되어 있다는 점, 그리고 국제법의 많은 영역들이 여전히 열망적(aspirational)이라는 점을 기꺼이 인정한다는 것이다. 그러나 법의 체계화(systematization)는 어쨌든 정도의 문제이며, 국제법이 1961년보다 지금 더 체계적이라고 생각하는 것은 옳을 수 있다⁴⁸. 그것이 이미 국내 법체계들(domestic legal systems)에서 발견되는 것과 대등하다는 것은 그럴듯하지 않다. 이 점을 지적하면서 하트가 국제법을 비난하거나 베스트팔렌식 국가주의(Westphalian statism)를 찬양하는 것은 아니다. 그는 국제법이 어떤 방식들에서는 국내법과 같고, 어떤 방식들에서는 그렇지 않은지를 이해하려 한다.

이 모든 것이 『법의 개념(The Concept of Law)』이 정치도덕(political morality)에 관한 견해들에 의해 틀지어진 책이라는 점을 부인하는 것은 아니다. 여기에는 하트식 밀적 자유주의(Millian liberalism)나 그의 민주적 사회주의(democratic socialism)가 많이 담겨 있지는 않다. 그러나 그의 도덕적 견해들 중 또 다른 하나, 곧 가치 다원주의(value pluralism)의 뚜렷한 흔적들은 있다. 그의 친구 아이제이아 벌린(Isaiah Berlin)처럼⁴⁹, 하트는 좋은 것(what is good)이 환원 불가능하게 복수적이며, 세계는 진정한 선들(genuine goods)이 자주 충돌하는 그런 곳이라고 생각한다. 어떤 한쪽에서의 정당화된 이득(justified gain)조차 다른 한쪽을 희생시켜 얻어질 수 있다. 따라서 하트는 공리주의(utilitarianism)나 복지경제학(welfare economics)에서 보는 유형의 환원적 일원론

⁴⁸ 일부 쟁점에 대한 검토로는 Samantha Besson and John Tasioulas 편, *The Philosophy of International Law* (Oxford University Press, 2010) 1-13쪽의 편집자 서론 및 거기서 인용된 문헌들을 참조.

⁴⁹ Isaiah Berlin, *Four Essays on Liberty* (Oxford University Press, 1969), and also his 'On Value Pluralism' (1998) *New York Review of Books*, vol. XLV No. 8.

(reductive monism), 곧 추구할 가치가 있는 것은 실제로 단 하나뿐이라는 입장에 반대한다. 또한 그는 다양한 가치들을 허용하지만 그것들이 (적절히 해석되면) 결코 충돌할 수 없다고 주장하는 비환원적 입장(nonreductive position)에도 반대한다⁵⁰. 하트는 “법들(laws) 및 법들의 운영(administration of laws)은 서로 다른 종류들의 탁월성들(excellences)을 가질 수도 있고 결여할 수도 있다”(157)고 말하며, 정의(justice)조차 그러한 탁월성들 중 하나일 뿐이라고 말한다. 그의 가치 다원주의는 법적 추론에 관한 언급들에서도 두드러지게 드러난다. “사법적 결정(judicial decision)은, 특히 높은 헌법적 중요성을 지닌 사안들에서, 종종 도덕적 가치들 사이의 선택을 포함하며, 어떤 단일한 두드러진 도덕 원칙의 적용만을 포함하는 것이 아니다”(204). 이것은 사법적 추론(judicial reasoning)에 중대한 함의를 가질 것이다. “그러한 원칙들의 복수성이 언제나 가능하기 때문에, 어떤 [사법적] 결정이 유일하게 올바르다(uniquely correct)는 것은 입증될(demonstrated) 수 없다...” (205).

6. 의의 (THE POINT)

하트(Hart)의 노선에 따른 하나의 일반 법리학(general jurisprudence)이 성공적으로 전개될 수 있다고 가정해 보자. 그런데 왜 애를 써야 하는가? 이 책의 관념들(ideas)과 씨름하는 일은 현대 법철학의 방대한 문헌에 들어가기 위한 입장료가 되어 버렸다. 이 책은 더 이른 철학 저작들에 대한 유익한 논의들을 담고 있다. 그러나 우리가 주로 다른(other) 법리학 책들에 무엇이 들어 있는지 알아내기 위해 법리학 책을 읽어야 한다는 관념에는 하트 자신보다 더 날카로운 비판자가 없다. 『법의 개념(The Concept of Law)』에는 학술 주석들(scholarly notes)이 많지 않고, 그것들도 책 뒤로 물러나 있으며, 읽는다면 나중에 읽으라는 시사와 함께 배치되어 있다:

나는 이러한 배열이, 법이론에 관한 책은 일차적으로 다른 책들에 무엇이 들어 있는지를 배우는 책이라는 믿음을 약화시키기를 바

⁵⁰이 입장에 대한 가장 지속적인 옹호는 로널드 드워킨(Ronald Dworkin), *Justice for Hedgehogs* (Harvard University Press, 2011)을 보라.

란다. 이 믿음이 쓰는 이들에게 유지되는 한 그 분야에서는 거의 진전이 이루어지지 않을 것이며, 읽는 이들에게 유지되는 한 그 분야의 교육적 가치는 매우 작게 남을 수밖에 없다(vii).

그러나 진보의 장애물들을 제거하는 일이 가치 있으려면, 그 분야에서의 진보 자체가 가치 있어야 한다. 의심할 여지 없이 하트식 분석적 법철학(analytic legal philosophy)은 비특정적 가치(non-specific value)를 가진다. 그것은 면밀한 독해(close reading), 명료한 사고(clear thinking), 신중한 논변(careful argument)을 높이 평가하고 촉진한다. 이것들은 모두 유용한 기술들이며, 교육적 가치도 있다. 그러나 그것들을 배우는 방법은 많고, 법리학 연구가 가장 빠르거나 쉬운 경로라고 생각할 이유는 없다.

일반 법리학(general jurisprudence)에 대한 충분히 적절한 변호(apology)는 법이 중요한 사회 제도(social institution)이며, 그러한 제도들에 대한 더 깊은 이해가 그 자체로 가치 있다는 것이다. 우리는 시장이나 가족의 본성을 이해하고자 하는 것과 같은 이유들로 법의 본성을 이해하고자 한다. 그렇다고 해서 우리가 시장이나 가족보다 법에 주의를 집중해야 한다는 점이 입증되지는 않을 것이다. 심지어 법에 대한 더 깊은 이해를 법 관련 행태의 예측이나 법들(laws) 및 법제도들(legal institutions)의 개혁보다 추구해야 한다는 점도 입증되지는 않을 것이다. 그러나 이러한 대안들 중 어느 것도 법리학(jurisprudence)의 독특한 가치(distinctive value)를 약화하지는 않는다.

어떤 사람들은 삶과 법에 관한 지침을 바라며 법리학 책들을 읽는다. 어떤 사람들은 그것을 제공하기를 바라며 법리학 책들을 쓴다. (마키아벨리가 그랬던 이유로, 곧 군주의 귀를 붙잡기 위해 쓰는 사람들도 포함해서.) 그런 것이 당신의 야심이라면 일반 법리학(general jurisprudence)은 당신을 실망시킬 수 있다. 일종의 고급 *amicus curiae* 의견서(high-brow *amicus curiae* brief)로서 그것이 미친 영향은 두드러지지 않았다. 물론 소송 사건(court case)이 법리학적 테제들(jurisprudential theses)을 제기하거나 그것들에 의존할 수는 있다. 실제로 판사들이 법의 유효성(validity)과 실효성(efficacy) 사이의 관계, 벌칙들(penalties)과 조세들(taxes)의 차이, 심지어 법과 관습(custom)의 차이에

관해 견해를 표명하는 결정들이 있다. 그러나 법원들이 그러한 물음들을 다룰 때에는, 법철학(legal philosophy)이 존중할 의무가 없는 지역적 법교의적 제약들(local doctrinal constraints) 안에서 그것들에 답하려 한다. 우리에게는 관습적 사회질서들(customary social orders)과 법체계들(legal systems)을 구별할 좋은 이론적 근거들(grounds)이 있다. 그러나 특정 법체계는 원주민 관습(aboriginal custom)을 그 자체의 자격에서 하나의 법체계로 볼 수 있다. 그렇다면 그것이 하트의 이론을 반박하는가? 전혀 그렇지 않다. 「어업법(Fisheries Act)」이 포경(whaling)을 규율한다는 사실은 고래(whales)가 물고기(fish)가 아니라는 우리의 확신을 조금도 흔들지 않는다. (그것이 「어업법」에 무언가 잘못이 있음을 보여주는 것도 아니다.)

역사적으로 『법의 개념』은 영어권에서 정치철학(political philosophy)이 부흥하던 문턱에 서 있다. 이 책이 처음 출간된 직후, 관심은 상당히 극적으로 가치의 문제들(problems of value)로 향했다. 다음 세대의 큰 책들은 정의(justice), 자유(liberty), 평등(equality) 같은 관념들(ideas)에 초점을 맞추었고, 법제도들(legal institutions)과 구조들(structures)에 대한 주의를 줄어들었다⁵¹. 하트의 책은 평가적 쟁점들(evaluative issues)을 결눈질한다. 앞서 보았듯, 이 책은 정의에 관해 말할 것이 있다. 그러나 압도적으로 그것은 제도들과 구조들에 관한 책이다. 바로 그 때문에, 그리고 기술적 지향(descriptive orientation)에 머무르려는 꾸준한 결의 때문에, 이 책은 때때로 변론가(advocate)가 즐겨 쓰는 폼하어들을 끌어들인다. 그 이론은 ‘불모적(sterile)’ 이라거나 ‘지루하다(boring)’ 고 선언된다. 이것을 어떻게 받아들여야 할지는 알기 어렵다. 그 폼하어들은 지적 편협성을 드러내지만, 자기인식의 결여도 드러낸다. 법이 의심할 여지 없이(unquestionably) 흥미롭고, 다른 것들은 가능한 소송과의 관련성을 보여 줌으로써 흥미롭게 된다고 보는 것은 법률가의 자만이다. (이 관념은 진정으로(really) 흥미로운 물음이란 의뢰인이 그 답에 돈을 낼 만한 물음이라는 생각과 그리 멀지 않다.)

⁵¹이 주제가 응용 도덕철학(applied moral philosophy)의 방향으로 지나치게 나아갔다는 제안은 제레미 월드론(Jeremy Waldron), 「Political Political Theory: An Oxford Inaugural Lecture」, <http://ssrn.com/abstract=2060344>에서 제시된다.

로널드 드워킨(Ronald Dworkin)은 “판사들이 사건들을 어떻게 결정하는지가 중요하기 때문에” 법리학(jurisprudence)이 중요하다고 쓴다⁵². 훨씬 앞서 그는 이렇게 쓴 적도 있다. “일반적으로, 법원의 결정에 대한 좋은 이유란 무엇인가? 이것이 법리학의 그(the) 질문이다...”⁵³. 하트는 가치 다원주의자(value pluralist)일 뿐 아니라 지적 다원주의자(intellectual pluralist)이기도 하다. 그는 최종 결론으로 달려가는 경주에 참여하지 않는다. 이 책의 제1장은 ‘지속되는 질문들(Persistent Questions)’이라는 제목을 달고 있으며, 복수형이다. 그 질문들은 다음과 같다. 법은 강제적 위협들(coercive threats)과 어떻게 관련되는가? 법의 의무적 힘(obligatory force)은 무엇에 해당하며, 그것은 도덕적 의무(moral obligation)와 어떻게 관련되는가? 사회적 규칙들(social rules)이란 무엇이며, 법은 어떤 방식으로 규칙들에 관한 것인가? 그러나 이들 중 어느 것도 법리학의 그(the) 질문이 아니다. 그것들은 모두 그저 법리학의 질문들(questions)이다. 그것들은 결국 흥미로운 질문들인가? 물론 그렇다. 그러나 단순한 진실은 사람들이 서로 다른 것들에 관심을 가진다는 것이다. 자신의 삶을 돌아보며 데이비드 흄(David Hume)은 이렇게 썼다. “나의 학구적 성향, 절제, 근면은 내 가족에게 법률직(the law)이 내게 적합한 직업이라는 관념(notion)을 갖게 했다. 그러나 나는 철학과 일반 학문의 추구를 제외한 모든 것에 극복할 수 없는 반감을 느꼈다...”⁵⁴. 흄은 법률직(the law)을 견딜 수 없을 만큼 지루하게 여겼다. 그는 혼자가 아니다. 의심할 여지 없이 다른 이들에게는 반대 방향의 반감들이 있다. 그러나 지적 성향이 무엇이든, 누구나 볼 수 있어야 하는 점이 있다. 흄은 분명 보았다. ‘흥미롭다’는 것은 문제의 대상이 가진 성질이 아니라 그 대상과 한 사람 사이의 관계가 가진 성질이다. 하트의 법리학은 소송들과 관련되는 정도가 제한적일 수 있지만, 그 문제들의 내재적 중요성(intrinsic importance)을 보는 누구에게나, 또 더 큰 정치적 관심들을 가진 이들에게도 관심을 끌 만해야 한다. 법정 안에서는 당해 법(the law)이 무엇인지 아는 것이 법(law)이 무엇인지 아는

⁵²Ronald Dworkin, *Law's Empire* 1.

⁵³Ronald Dworkin, ‘Does Law Have a Function? A Comment on the Two-Level Theory of Decision’ (1965) 74 *Yale Law Journal* 640.

⁵⁴David Hume, ‘My Own Life’ in his *Essays, Moral, Political and Literary*, E. F. Miller, ed. (Liberty Press, 1987).

것보다 더 중요하다. 그러나 하트가 상기시키듯, 작동 중인 법(law-in-action)의 대부분이 일어나는 법정 바깥에서는 법의 본성에 관한 질문들이 제자리를 얻는다. 통치 수단으로서의 법으로부터 우리는 무엇을 바랄 수 있는가? 그것의 이점들과 위험들은 무엇인가? 법의 지배(rule of law)를 왜 가치 있게 여겨야 하는가? 우리는 법에 복종해야 하는가? 그렇다면 어디까지 그래야 하는가? 그리고 물론, 도대체 왜 법을 가져야 하는가? 그런 질문들을 묻게 되거나 더는 피할 수 없다고 느끼는 사람은 누구든, 답들을 찾기 위해 일반 법리학의 도움을 필요로 할 것이다. 하트가 그 일을 이렇게 잘 시작해 두었다는 것은 우리에게 극히 행운이다.

Contents

1961년 제1판의 하트의 머리말 (PREFACE)	i
1994년 제2판의 Bulloch와 Raz의 편집자 주 (Editors' Note)	iii
2012년 제3판의 Leslie Green의 머리말 (PREFACE TO THE THIRD EDITION)	vi
2012년 제3판의 Leslie Green의 서론 (INTRODUCTION)	viii
1. 하트의 메시지 (HART'S MESSAGE)	viii
2. 사회적 구성물로서의 법 (LAW AS A SOCIAL CONSTRUCTION)	x
3. 법과 권력 (LAW AND POWER)	xxiii
4. 법과 도덕 (LAW AND MORALITY)	xxx
5. 사실, 가치, 방법 (FACT, VALUE, AND METHOD)	xliv
6. 의의 (THE POINT)	liii
I. 지속되는 질문들	1
1. 법이론의 당혹스러움들	1
2. 세 가지 반복되는 쟁점들	6
3. 정의 (Definition)	15
주석 (Notes)	21
제1장 주석	21
제1장 제3판 주석	24
II. 법들(Laws), 사령들(Commands), 그리고 명령들(Orders)	27
1. 명법들의 다양상들(Varieties of Imperatives)	27
2. 강제적 명령들(coercive orders)로서의 법	30

제2장 주식	37
제2장 제3판 주식	40
III. 법들의 다양상	42
1. 법의 내용	43
2. 적용 범위(THE RANGE OF APPLICATION)	61
3. 기원 양식들(MODES OF ORIGIN)	64
제3장 주식	71
제3장 제3판 주식	75
IV. 주권자와 수범자(SOVEREIGN AND SUBJECT)	78
1. 복종의 습관과 법의 계속성	79
2. 법의 지속성	92
3. 입법 권한에 대한 법적 제한	97
4. 입법부 배후의 주권자	104
제4장 주식	113
제4장 제3판 주식	116
V. 일차 규칙들과 이차 규칙들의 결합으로서의 법(LAW AS THE UNION OF PRIMARY AND SECONDARY RULES)	118
1. 새로운 출발	118
2. 의무(obligation)라는 관념	121
3. 법의 구성요소 (The Elements of Law)	132
제5장 주식	142
제5장 제3판 주식	144
VI. 법체계의 토대들(THE FOUNDATIONS OF A LEGAL SYSTEM)	146
1. 승인 규칙과 법적 유효성(RULE OF RECOGNITION AND LE- GAL VALIDITY)	146
2. 새로운 질문들(New Questions)	158
3. 법체계의 병리학(THE PATHOLOGY OF A LEGAL SYSTEM)	166
제6장 주식	173
제6장 제3판 주식	178

VII. 형식주의(Formalism)와 규칙회의주의(Rule-Scepticism)	182
1. 법의 개방적 직조(The Open Texture of Law)	182
2. 규칙회의주의(rule-scepticism)의 다양상들	195
3. 사법적 결정에서의 최종성(Finality)과 무오류성(Infallibility)	201
4. 승인 규칙에서의 불확실성(UNCERTAINTY)	208
제7장 주석	216
제7장 제3판 주석	219
VIII. 정의(Justice)와 도덕(Morality)	222
1. 정의의 원칙들 (Principles of Justice)	224
2. 도덕적 의무(Moral Obligation)와 법적 의무(Legal Obligation)	235
3. 도덕 이상(Moral Ideals)과 사회적 비판(Social Criticism)	249
제8장 주석	254
제8장 제3판 주석	257
IX. 법들과 도덕규범들 (Laws and Morals)	259
1. 자연법과 법실증주의 (Natural Law and Legal Positivism)	259
2. 자연법의 최소한의 내용 (The Minimum Content of Natural Law)	268
3. 법적 유효성과 도덕적 가치	275
제9장 주석	289
제9장 제3판 주석	291
X. 국제법 (INTERNATIONAL LAW)	295
1. 의문의 원천들 (SOURCES OF DOUBT)	295
2. 의무들과 제재들 (OBLIGATIONS AND SANCTIONS)	298
3. 의무와 국가들의 주권 (OBLIGATION AND THE SOVEREIGNTY OF STATES)	302
4. 국제법과 도덕 (INTERNATIONAL LAW AND MORALITY)	309
5. 형식과 내용의 유비들 (ANALOGIES OF FORM AND CONTENT)	314
제10장 주석	320
제10장 제3판 주석	322

후기 (POSTSCRIPT)	324
서론 (INTRODUCTORY)	324
1. 법이론의 본성 (THE NATURE OF LEGAL THEORY)	325
2. 법실증주의의 본성 (THE NATURE OF LEGAL POSITIVISM)	331
3. 규칙의 본성 (THE NATURE OF RULES)	341
4. 원칙들과 승인 규칙 (PRINCIPLES AND THE RULE OF RECOG- NITION)	350
5. 법과 도덕 (LAW AND MORALITY)	355
6. 사법적 재량 (JUDICIAL DISCRETION)	359
후기 주석	364
후기 제3판 주석	365

I. 지속되는 질문들

1. 법이론의 당혹스러움들

‘법(law)이란 무엇인가?’ 라는 질문만큼 오랫동안 제기되어 왔고, 진지한 사상가들에 의해 이렇게 다양하고 기묘하며 때로는 역설적인 방식으로 답변되어 온 인간 사회에 관한 질문은 거의 없다. 고전 및 중세의 법 ‘본성(nature)’ 에 관한 사유를 제쳐두고, 지난 150년 동안의 법이론만을 살펴보더라도, 우리는 다른 어떤 독립된 학문 분야에서도 찾아볼 수 없는 독특한 상황을 발견하게 된다. ‘화학이란 무엇인가?’ 또는 ‘의학이란 무엇인가?’ 라는 질문에 대해 이처럼 방대한 문헌이 헌신된 예는 없다. 이러한 과학들을 배우는 학생은 교과서의 첫 페이지에 나오는 몇 줄의 설명 정도만 접할 뿐이며, 거기서 제시되는 답변은 법학도에게 주어지는 답변과는 매우 다르다. 그 누구도 의학이란 ‘의사가 병에 대해 하는 일’ 이라거나 ‘의사가 무엇을 할 것인지를 예측하는 것’ 이라고 고집하는 일이 해명적이거나 중요하다고 생각하지 않았다. 또한 일반적으로 화학의 핵심적이고 특징적인 일부로 간주되는, 예컨대 산(acid)에 대한 연구가 사실은 화학이 아니라고 선언하는 일이 해명적이거나 중요하다고 생각하지도 않았다. 그러나 법의 경우에는 이처럼 기묘하게 보이는 주장들이 종종 제기되어 왔으며, 단순히 제기되었을 뿐만 아니라, 그것이 법의 본질적 성격에 대한 심한 왜곡들에 의해 오랫동안 가려져 온 법에 관한 진리들을 제시하는 것인 양 열정적으로, 또 때로는 웅변적으로 주장되기도 했다.

‘공무담당자들이 분쟁에 대해 하는 일이 곧 ... 법이다’¹; ‘법원들이 무엇을 할 것인지에 대한 예언들이 ... 내가 말하는 법이다’²; 제정법들(statutes)은 ‘법의 원천들(sources of Law)이지 ... 법 자체의 부분들이 아니다’³; ‘헌법법(constitutional law)은 단지 실정적 도덕(positive morality)일 뿐이다’⁴; ‘도덕

¹Llewellyn, *The Bramble Bush* (2nd edn., 1951), p. 9.

²O. W. Holmes, ‘The Path of the Law’ in *Collected Papers* (1920), p. 173.

³J. C. Gray, *The Nature and Sources of the Law* (1902), s. 276.

⁴Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (1832), Lecture VI (1954 edn., p. 259).

질하지 말라(shall not); 누군가가 도둑질을 하면 그는 처벌받아야 한다(shall be). (p. 2) ... 만약 어떤 규범이 존재한다면, 첫 번째 규범은 두 번째 규범에 포함되어 있으며, 두 번째 규범이야말로 유일한 진정한 규범이다 ... 법이란 제재(sanction)를 규정하는 1차 규범(primary norm)이다.’⁵

이들은 법의 본성에 관해 제기된 수많은 주장(assertions)과 부정(denials) 중 일부일 뿐이며, 적어도 처음 보았을 때는 낯설고 역설적으로 보인다. 이들 중 일부는 우리의 가장 확고하게 뿌리내린 믿음들과 충돌하는 듯하며 쉽게 반박될 수 있는 것처럼 보인다. 그래서 우리는 다음과 같이 말하고 싶은 유혹을 느낀다. ‘제정법은 분명히 법이다. 적어도 법의 한 종류이며, 다른 종류들도 있을 수 있다’: ‘분명 법은 단지 공무담당자들이 하는 일이나 법원들이 할 일을 의미할 수는 없다. 공무담당자나 법원을 만들려면 법이 필요하기 때문이다’.

그러나 이러한 역설적으로 보이는 발언들은 상식의 명백한 사실을 의심하는데 종사하는 몽상가나 전문 철학자들에 의해 제기된 것이 아니다. 그것은 오랜 기간 법에 대해 성찰해온 이들, 즉 주로 법을 가르치거나 실무에서 다루거나, 때로는 판사로서 법을 집행하는 것을 직업으로 삼은 법률가들(lawyers)의 성찰의 산물이다. 더 나아가, 그들이 말한 것들은 실제로 그들의 시대와 맥락에서 법에 대한 우리의 이해를 심화시켰다. 이와 같은 주장들은 그 문맥 안에서 이해될 때, 밝혀 주면서도 동시에 당혹스럽다: 그것들은 차분한 정의들(definitions)이라기보다는, 법에 대한 어떤 진리를 지나치게 과장한 표현이며, 그 진리는 오랫동안 간과되어 왔던 것이다. 이러한 주장은 우리가 이전에는 보지 못했던 법의 측면을 보게 하는 빛을 비추지만, 그 빛이 너무 강렬한 나머지 나머지 부분을 가려버리고, 결국 전체를 명확히 파악하지 못하게 만든다.

책 속에서 끝없이 이어지는 이러한 이론적 논쟁과는 대조적으로, 대부분의 사람들은 ‘법’의 사례를 쉽게, 자신 있게 들 수 있는 능력을 지니고 있다. 대부분의 영국인은 살인을 금지하거나, 소득세 납부를 요구하거나, 유효한 유언장을 작성하기 위해 필요한 절차를 규정하는 법이 있다는 사실을 알고 있다. 영어 단어 ‘law’를 처음 접하는 어린이 또는 외국인을 제외하면, 거의 모든 사람들은 이와 같은 예시들을 얼마든지 더 많이 들 수 있다. 그리고 대부분의 사람들은 더

⁵Kelsen, *General Theory of Law and State* (1949), p. 61.

나아가, 어떤 것이 영국법인지 알아내는 방법에 대해서도 적어도 개요 정도는 설명할 수 있다. 사람들은 전문가에게 자문할 수 있으며, 이와 관련된 모든 질문에 대해 최종적이고 권위 있는 목소리를 가진 법원들이 있다는 사실을 알고 있다. (p. 3) 이보다 더 많은 사실들이 일반적으로 널리 알려져 있다. 대부분의 교육받은 사람들은 영국의 법들이 일종의 체계(system)를 이루고 있다는 관념(idea)을 가지고 있다. 또 프랑스, 미국, 소련 등 – 기실 독립된 ‘국가(country)’로 간주되는 세계의 거의 모든 지역에는, 중요한 차이가 있음에도 불구하고 대체로 구조가 유사한 법체계(legal systems)가 존재한다는 사실도 알고 있다. 기실 이러한 사실들을 모른 채 교육을 마쳤다면, 그 교육은 심각하게 실패한 것이며, 다른 법체계들 간의 중요한 유사 지점들이 무엇인지 말할 수 있다고 해서 그것이 대단한 교양의 표시라고 보기도 어렵다. 어느 정도 교육을 받은 사람이라면 누구나 다음과 같이 기본적 골격을 통해 그 두드러진 특징들을 식별할 수 있어야 한다. 그것들은 다음과 같은 요소들로 구성된다: (i) 특정한 유형의 행위를 금지하거나 명령하고 이를 위반할 경우 제재를 가하는 규칙들; (ii) 특정한 방식으로 타인에게 피해를 준 경우 배상을 요구하는 규칙들; (iii) 유언, 계약 또는 권리들을 부여하고 의무들을 창출하는 기타 약정들을 유효하게 만들기 위해 무엇이 행해져야 하는지를 특정하는 규칙들; (iv) 규칙들이 무엇인지, 언제 위반되었는지를 판정하고, 지급되어야 할 처벌이나 배상을 정하는 법원들(courts); (v) 새로운 규칙들을 만들고 오래된 규칙들을 폐지하는 입법기관(legislature).

만약 이 모든 것이 공통 지식(common knowledge)이라면, ‘법이란 무엇인가?’ 라는 질문은 왜 그토록 지속되어 왔으며, 그에 대해 이처럼 다양하고도 비범한 답변들이 제시되어 왔을까? 이는 현대 국가들의 법체계(legal systems)가 이루는 분명한 표준 사례들, 곧 정신이 온전한 사람이라면 누구도 법체계임을 의심하지 않는 사례들 외에도, 그 ‘법적 성질(legal quality)’에 대해 교육받은 일반인들뿐만 아니라 심지어 법률가들조차도 주저하는 의심스러운 사례들이 존재하기 때문일까? 원시법(primitive law)과 국제법(international law)은 그러한 의심스러운 사례들 중 대표적이며, 잘 알려져 있듯 많은 이들은 이러한 사례들에서 현재 관례화된 ‘법(law)’이라는 단어 사용의 적절성을 부정할 이유들이

있다고 느껴 왔다. 비록 그 이유들이 보통 확정적이지는 않지만 말이다. 이와 같은 의문스럽거나 다룰 수 있는 사례들의 존재는 기실 오랜 기간 이어져 온, 다소 불모의 논쟁을 야기해 왔으나, 그렇다고 해서 그것이 ‘법이란 무엇인가?’라는 지속적인 질문에서 표현되는 법의 일반적 본성에 대한 당혹스러움들을 설명할 수는 없다. 이러한 사례들이 그 난제의 뿌리일 수 없다는 점은 두 가지 이유로 명확하다.

첫째, 이러한 사례들에서 주저함이 느껴지는 이유는 자명하다. 국제법은 입법기관(legislature)이 없고, 국가들은 (p. 4) 사전 동의 없이는 국제법정에 회부될 수 없으며, 중앙집중적으로 조직된 실효적인 제재 체계도 존재하지 않는다. 일부 현대 법체계들이 점차 진화해 나왔을 수도 있는 유형들을 포함하여, 일정한 유형의 원시법도 이와 유사하게 이러한 특징들을 결여하고 있다. 그리고 이러한 사례들이 이 점들에서 표준 사례로부터 벗어난다는 사실이 그것들의 분류를 의문스러운 것으로 보이게 만든다는 점은 누구에게나 명확하다. 이 점에는 아무런 신비로움이 없다.

둘째, 명백한 표준 사례들과 다룰 수 있는 경계 사례들을 모두 인정하지 않을 수 없다는 점은 ‘법(law)’이나 ‘법체계(legal system)’ 처럼 복잡한 용어들에만 특이한 일이 아니다. 이제는 잘 알려진 사실이지만(한때는 충분히 강조되지 않았지만), 우리가 인간 삶이나 세계의 특징들을 분류할 때 사용하는 거의 모든 일반 용어들에 있어서도 이와 같은 구분은 필수적이다. 때로는, 어떤 표현의 사용에 있어 명백하고 표준적인 사례(또는 전형적 사례)와 의심스러운 사례들 간의 차이는 단지 정도의 차이일 뿐이다. 머리가 반짝이는 매끈한 두피를 가진 사람은 명백히 대머리(bald)이고, 무성한 머리숱을 가진 사람은 명백히 그렇지 않지만, 여기저기 머리칼이 드문드문 있는 제3의 사람을 대머리라고 할 수 있는 지에 대해서는 그럴 만한 가치가 있다고 여겨지거나 어떤 실천적 쟁점이 걸려 있다면 끝없이 논쟁될 수 있을 것이다.

때로는 표준 사례로부터의 벗어남이 단순한 정도 차이가 아니라, 표준 사례가 실제로는 보통 함께 나타나지만 서로 구별되는 여러 요소들의 복합체이고, 다툼에 열린 사례들에서는 그 요소들 중 하나 이상이 결여될 수 있을 때 발생한다. 예를 들어, 수상비행기(flying boat)는 ‘선박(vessel)’인가? 퀸(queen) 없이

진행되는 체스 게임은 여전히 ‘체스(chess)’ 인가? 이러한 질문들은 표준 사례의 구성에 대한 우리의 구상(conception)을 성찰하고 명시화하게끔 유도하기 때문에 교훈적일 수 있다. 그러나 이른바 사물들의 경계적 양상(borderline aspect)이 너무도 일반적이어서, 법에 대한 오랜 논쟁을 그것만으로 설명할 수는 없다는 점도 분명하다. 더구나, 가장 유명하고 논쟁적인 법이론들 가운데 상대적으로 작고 중요하지 않은 부분만이 ‘원시법’ 이나 ‘국제법’ 이라는 표현을 해당 사례들에 적용하는 것이 적절한지에 초점을 맞추고 있을 뿐이다.

사람들이 법들의 사례들을 인식하고 인용할 수 있는 매우 일반적인 능력과, 법체계의 표준 사례에 대해 일반적으로 알려진 사실들을 고려해보면, (p. 5) ‘법이란 무엇인가?’ 라는 지속적인 질문을 그저 이미 익숙한 것들을 상기시키는 방식으로 간단히 끝낼 수 있을 것처럼 보이기도 한다. 우리가 (앞서 3쪽에서) 한 교육받은 사람의 입을 빌려 낙관적으로 제시한 국내법체계(municipal legal system)의 핵심 요소에 대한 개요를 반복하는 방식으로 말이다. 만약 그렇다면 우리는 쉽게 이렇게 말할 수 있을 것이다. ‘이것이 “법(law)” 과 “법체계(legal system)” 라는 말로 의미되는 표준 사례이다. 이 표준 사례들 외에도, 이러한 주요 특징 중 일부를 공유하면서도 다른 일부는 결여한 장치들을 사회적 삶 속에서 발견하게 되리라는 점을 기억하라. 이것들은 법으로 분류하는 것에 찬성하거나 반대하는 확정적 논증이 있을 수 없는 논쟁적 사례들이다.’

이러한 방식은 기분 좋을 만큼 짧을 것이다. 그러나 그 외에는 특별히 추천할 만한 점이 없다. 무엇보다도, ‘법이란 무엇인가?’ 라는 질문에 대해 가장 크게 당혹스러움을 느끼는 이들은 이 요약적 답변이 제시하는 익숙한 사실들을 잊었거나, 그것을 상기시켜야 할 만큼 몰랐던 이들이 아니다. 이 질문을 지속시켜 온 깊은 당혹스러움은 무지나 망각, 혹은 ‘법(law)’ 이라는 단어가 통상 가리키는 현상들을 인식할 능력 부족 때문이 아니다. 더 나아가, 우리가 제시한 법체계에 대한 요약적 설명을 검토해 보면, 그것은 표준적이고 통상적인 사례에서 여러 종류의 법들이 함께 결합되어 있다는 사실 외에 거의 아무것도 주장하지 않는다. 이는 요약 설명 속에서 법체계의 전형적 요소로 등장하는 ‘법원(court)’ 과 ‘입법기관(legislature)’ 자체가 법의 산물이기 때문이다. 사람들에게 사건을 재판할 관할권(jurisdiction)이나 법들을 만들 권한(authority)을 부여하는 일정한

유형의 법들이 있을 때에만, 그 사람들이 법원이나 입법기관을 구성한다.

따라서 이러한 질문에 대한 간단한 접근법은, 결국 ‘법’과 ‘법체계’라는 단어 사용을 지배하는 기존의 관행들을 상기시키는 것 이상은 하지 못하므로 쓸모없다. 분명히 가장 바람직한 접근은, ‘법이란 무엇인가?’라는 질문에 어떤 답변을 제시하는 것도 유보하고, 그 질문을 제기하거나 답하려 했던 사람들이, 비록 법에 대한 친숙함이나 사례를 식별하는 능력은 의심할 여지 없이 충분함에도 불구하고, 실제로 법에 관하여 무엇에 대해 당혹감을 느껴왔는지를 먼저 파악하는 것이다. 그들은 무엇을 더 알고 싶어 하며, 왜 그것을 알고 싶어 하는가? 이 질문에 대해서는 일반적 수준에서의 답변이 가능하다. 왜냐하면 법의 본성에 관해 논변과 반론의 지속적 초점이 되어 온 몇 가지 반복되는 주요 주제들이 존재하며, (p. 6) 이것들이 앞서 언급한 바와 같은 과장되고 역설적인 주장들을 촉발시켜 왔기 때문이다. 법의 본성에 대한 사변(speculation)은 길고 복잡한 역사를 지니고 있지만, 회고해 보면 그것은 거의 끊임없이 소수의 주요 쟁점들에 집중되어 있었음이 분명하다. 이러한 쟁점들은 단순히 학술적 논의의 즐거움을 위해 공연히 선택되거나 발명된 것이 아니다. 그것들은 모든 시대에 걸쳐 법에 대해 자연스럽게 오해를 낳기 쉬운 측면들에 관련된 것이며, 따라서 법에 대한 확고한 숙달과 지식을 가진 사려 깊은 사람의 마음속에서도 혼란과 그에 따른 더 큰 명료성에 대한 요구가 공존할 수 있는 지점들이기 때문이다.

2. 세 가지 반복되는 쟁점들

여기에서는 그러한 주요 반복 쟁점들 중 세 가지를 구분하고, 왜 그것들이 결국 법의 정의(definition)에 대한 요구나 ‘법이란 무엇인가?’라는 질문에 대한 답변의 형태로, 혹은 ‘법의 본성(nature)이 (또는 본질(essence)이) 무엇인가?’라는 더 모호한 형태의 질문으로 함께 등장하는지를 이후에 설명할 것이다.

이 세 가지 쟁점 중 두 가지는 다음과 같은 방식으로 제기된다. 언제, 어디서나 법의 가장 두드러진 일반적 특징은, 법이 존재한다는 것은 어떤 종류의 인간 행위가 더 이상 선택 사항이 아니라, 어떤(some) 의미에서는 의무적(obligatory)이라는 것이다. 그러나 이처럼 겉보기에는 단순한 법의 특징은 실제로는 단순

하지 않다. 왜냐하면, 선택 불가능하고 의무적인 행위의 영역 내에서도 우리는 서로 다른 형식들을 구분할 수 있기 때문이다. 첫째, 가장 단순한 의미에서 어떤 행위가 더 이상 선택사항이 아니게 되는 경우는, 한 사람이 다른 사람에게 어떤 행동을 하도록 강요하는 상황이다. 이때 신체가 실제로 밀리거나 당겨지는 식의 물리적 강제가 있는 것이 아니라, 거부할 경우 불쾌한 결과가 따를 것이라는 협박(threat)에 의해 강요되는 경우이다. 예컨대, 권총강도가 희생자에게 지갑을 건네라고 명령하고, 거부할 경우 총을 쏠 것이라고 위협하는 경우, 희생자가 이를 준수한다면 우리는 그가 그렇게 하지 않을 수 없었다(obliged)고 말한다. 어떤 이들에게는, 이러한 상황 – 한 사람이 다른 사람에게 위협으로 뒷받침된 명령(order)을 내리고, 이러한 ‘그렇게 하지 않을 수 없게 함(oblige)’의 의미에서, 그에게 이를 준수하지 않을 수 없게 하는(obliges him to comply) 상황 – 에서야 말로 법의 본질(essence), 또는 최소한 ‘법리학이라는 학문의 열쇠’가 있다는 점이 명확해 보이기도 한다.⁶ 이것이 (p. 7) 영국의 법리학에 지대한 영향을 끼친 오스틴(Austin)의 분석이 출발한 지점이다.

물론, 법체계가 이러한 측면을 포함하는 경우가 자주 있다는 점에는 의심의 여지가 없다. 특정한 행위를 위반행위(offence)로 선언하고, 그 위반자(offender)가 부담하게 되는 처벌을 명시하는 형벌 제정법(penal statute)은 일종의 확대된 ‘권총강도’ 상황처럼 보일 수도 있으며, 유일한 차이점은 제정법들의 경우 명령들이 특정한 개인에게가 아니라, 그러한 명령들에 관습적으로 복종하는 집단을 일반적으로 향해 있다(addressed)는 상대적으로 작은 차이뿐일 수도 있다. 그러나 법의 복잡한 현상을 이처럼 단순한 요소로 환원하려는 시도는 매력적으로 보일 수 있음에도, 면밀히 살펴보면, 그러한 환원은 오히려 왜곡이며 혼란의 원천이 되어 왔다. 형벌 제정법의 경우조차도, 이 단순한 용어로 분석하는 것이 가장 그럴듯해 보일 때조차 그러하다. 그렇다면 법과 법적 의무(legal obligation)는 위협으로 뒷받침된 명령들과 어떻게 다르며, 어떠한 관련을 갖는가? 이것이야말로 항상 ‘법이란 무엇인가?’라는 질문 속에 잠재해 있는 핵심 쟁점이었다.

두 번째 쟁점은 또 다른 방식으로 어떤 행위가 선택 사항이 아니라 의무적일

⁶Austin, op. cit., Lecture I, p. 13. 그는 ‘and morals’를 덧붙인다.

수 있다는 점에서 제기된다. 도덕 규칙들(moral rules)은 의무들을 부과하고, 개인이 자기가 좋아하는 대로 할 자유로운 선택에서 일정한 행위 영역들을 빼낸다. 마치 법체계가 위협으로 뒷받침된 명령들의 단순한 사례들과 밀접하게 연결된 요소들을 명백히 포함하고 있는 것처럼, 그것은 또한 도덕의 일정한 측면들과도 밀접하게 연결된 요소들을 명백히 포함하고 있다. 두 경우 모두, 그 관계를 정확히 식별하는 데 어려움이 있으며, 명백히 가까운 연결 속에서 동일성을 보려는 유혹이 존재한다. 법과 도덕은 공통된 어휘를 공유하여 법적 의무들·책무들·권리들과 도덕적 의무들·책무들·권리들이 모두 존재하게 될 뿐만 아니라, 모든 국내법체계는 일정한 근본적 도덕적 요구사항들의 실질을 재현한다. 살해(killing)와 함부로 폭력을 사용하는 것은 법과 도덕의 금지가 일치하는 가장 명백한 예에 불과하다. 게다가, ‘정의(justice)’라는 하나의 관념(idea)은 두 영역을 연결해주는 것으로 보인다. 정의는 법에 특히 적합한 미덕(virtue)일 뿐만 아니라, 가장 ‘법적인’ 미덕이기도 하다. 우리는 ‘법에 따른 정의(justice according to law)’를 생각하고 말하면서도, 법들의 정의 또는 부정의(justice or injustice of the laws) 역시 논한다.

이러한 사실들은, 법은 도덕(morality)이나 정의(justice)의 한 ‘분야(branch)’로 이해하는 것이 가장 적절하며, 명령들과 위협들을 편입하고 있다는 점이라기보다는 도덕 또는 정의 원칙들과의 합치(congruence)가 (p. 8) 법의 ‘본질(essence)’이라는 견해를 시사한다. 이러한 견해는 중세 스콜라 자연법 이론(scholastic theories of natural law)뿐 아니라 오스틴으로부터 계승된 법실증주의(legal positivism)를 비판하는 일부 현대 법이론에도 특징적으로 나타나는 교설이다. 그러나 이와 같이 법을 도덕에 밀접하게 동화시키는 이론들 역시, 결국에는 서로 다른 유형의 의무적 행위를 혼동하는 경향이 있으며, 법규칙들과 도덕 규칙들 간의 종류 차이와 그 요구사항의 차이를 충분히 설명하지 못하는 경향이 있다. 이러한 차이들은 우리가 발견할 수도 있는 유사성과 수렴만큼이나 중요하다. 따라서 ‘부정의한 법은 법이 아니다(an unjust law is not a law)’⁷라는 단언은, ‘제정법들은 법들이 아니다’ 또는 ‘헌법법은 법이 아니다’라는 단언

⁷ ‘Nam mihi lex esse non videtur quae justa non fuerit’: St. Augustine I, *De Libero Arbitrio*; Aquinas, *Summa Theologica*, 1–11, Qu. 95 Art. 2; Qu. 96 Art. 4.

못지않게, 거짓은 아닐지라도 과장되고 역설적인 울림을 가진다. 법이론의 역사는 이러한 극단 사이의 진동으로 이루어져 있다는 점이 특징적이다. 법과 도덕의 밀접한 동화에서, 법과 도덕이 권리들과 책무들의 공통 어휘를 공유한다는 사실로부터 잘못 끌어낸 추론 이상의 아무것도 보지 않은 이들은, 그것에 대해 똑같이 과장되고 역설적인 말들로 향의하였다. ‘법이란 법원들이 실제로 무엇을 할 것인지에 대한 예언들이며, 그것 이상으로 거창하게 말할 것은 아무것도 아니다.’⁸

세 번째 주요 쟁점은 ‘법이란 무엇인가?’ 라는 질문을 끊임없이 자극하는 보다 일반적인 문제이다. 언뜻 보기에는, 법체계(legal system)가 적어도 일반적으로는 규칙들(rules)로 구성되어 있다는 진술(statement)은 거의 의심받을 일도, 이해하기 어려운 일도 없어 보인다. 위협으로 뒷받침된 명령이라는 관념(notion)에서 법 이해의 열쇠를 찾는 이들이든, 혹은 도덕(morality)이나 정의(justice)와의 관계에서 그것을 찾는 이들이든 모두, 법이 규칙들을 포함하거나, 아니면 상당 부분 규칙들로 구성된다고 말한다. 그러나 이처럼 별 문제가 없어 보이는 관념(notion)에 대한 불만, 혼란, 불확실성이야말로 법의 본성(nature)에 대한 당혹스러움의 상당 부분의 기저에 놓여 있다. 규칙들이란 무엇인가(are)? 규칙들이 존재한다(exist)고 말하는 것은 무슨 의미인가? 법원은 정말로 규칙들을 적용하는가(apply), 아니면 단지 그런 척을 하는 것인가? 이 관념에 대해 질문이 제기되기 시작하면—특히 20세기 법리학에서 그러하였듯이—의견의 심각한 분열이 나타난다. 우리는 여기서 그것들을 간략히 개요만 제시할 것이다.

(p. 9) 규칙들에는 여러 다른 유형들이 존재한다는 점은 물론 참이다. 이것은 단지 법규칙들 외에도 예절의 규칙들, 언어의 규칙들, 게임과 동호회의 규칙들 등이 존재한다는 명백한 의미에서뿐 아니라, 더 미묘한 의미에서도 그러하다. 즉, 이 영역들 가운데 어느 하나 안에서도 규칙이라 불리는 것들은 서로 다른 방식으로 기원할 수 있으며, 관련된 행위와의 관계에서도 매우 다를 수 있다. 예컨대 법 내에서도 어떤 규칙들은 입법(legislation)을 통해 만들어지지만, 다른 규칙들은 그러한 의도적 행위에 의해 만들어지지 않는다. 더 중요한 것은, 어떤

⁸Holmes, loc. cit.

규칙들은 의무부과적(mandatory)이라는 의미에서, 사람들에게 그들의 의사와 무관하게 폭력을 자제하거나 조세들을 납부하는 등 일정한 방식으로 행위할 것을 요구한다(require)는 점이다. 반면, 결혼, 유언, 계약을 성립시키기 위한 절차나 형식, 요건을 규정하는 규칙들은 사람들이 자신이 가진 의사들을 실현하기 위해 무엇을 해야 하는지를 지목한다(indicate). 이 두 가지 유형의 규칙간의 대조는 게임의 규칙들에서도 발견된다. 예컨대, 제재적-불이익 아래에서 일정한 유형의 행위를 금지하는 규칙들(반칙(foul play)이나 심판에 대한 모욕(abuse of the referee))과, 점수를 얻거나 승리하기 위해 무엇을 해야 하는지를 명시하는 규칙들이 그것이다. 그러나 이러한 복잡성을 잠시 제쳐두고, 형사법(criminal law)의 전형적 사례인 첫 번째 유형의 규칙만 고려하더라도, 이 단순한 의무부과적 유형의 규칙이 존재한다는 단언의 의미에 대해서는 현대의 많은 학자들 사이에서도 가장 폭넓은 견해 차이를 발견하게 된다. 기실 어떤 이들은 이 관념(notion)을 극히 불가해한 것으로 간주한다.

처음에 우리는 겉보기에 단순한 의무부과 규칙(mandatory rule)의 관념(idea)에 대해 아마도 자연스럽게 다음과 같은 설명을 하고 싶어질 수 있지만, 이 설명은 곧 포기되어야 한다. 그 설명은 이렇다. 규칙이 존재한다고 말하는 것은 단지 어떤 집단의 사람들, 혹은 그들 대부분이 일정한 종류의 상황들에서 ‘대체로(as a rule)’, 즉 일반적으로(generally) 특정된 유사한 방식으로 행동한다는 것을 의미할 뿐이라는 것이다. 예컨대, 영국에 남성이 교회에서 모자를 써서는 안 된다는 규칙이나, ‘God Save the Queen’이 연주될 때 일어셔야 한다는 규칙이 존재한다고 말하는 것은, 이 설명에 따르면, 단지 대부분의 사람들이 그러한 행동을 일반적으로 수행한다는 의미일 뿐이다. 하지만 분명 이것만으로는 부족하다. 비록 그 말이 뜻하는 바의 일부를 전달하기는 하지만 말이다. 사회 집단 구성원들 사이의 단순한 행태 수렴만으로는 ‘규칙’이 존재한다고 할 수 없다. 예컨대 모두에게 아침 식사 때 차를 마시거나 매주 영화관에 가는 반복적으로 일양적인 행태가 있다고 해도, 그것을 요구하는(requiring) 규칙이 있는 것은 아니다. 단순한 수렴적 행태(mere convergent behaviour)의 사회적 상황과 (p. 10) 사회적 규칙(social rule)의 존재라는 두 사회적 상황 사이의 차이는 종종 언어적으로 드러난다. 후자를 기술할 때 우리는—반드시 그럴 필요는

없지만—전자를 단지 진술하려는 경우에는 오해를 불러일으킬 수 있는 특정한 단어들을 사용할 수 있다. 그것이 바로 ‘~해야 한다(must)’, ‘~하는 것이 마땅하다(should)’, ‘~할 의무가 있다(ought to)’ 라는 말들인데, 이들은 서로 차이가 있음에도 불구하고, 특정한 행위를 요구하는 규칙의 존재를 지목한다는(indicating) 공통된 기능을 공유한다. 영국에는 모든 사람이 매주 영화관에 가야 하거나(must), 가는 것이 마땅하거나 가야 할 의무가 있다(ought to or should)는 규칙은 존재하지 않으며, 그러한 사실도 아니다. 단지 사람들이 매주 영화관을 찾는 반복적으로 일양적인 행태(regular resort)가 있다는 점만이 참일 뿐이다. 그러나 교회에서 남성이 모자를 벗어야 한다는 규칙(a rule)은 있다(there is a rule).

그렇다면 사회 집단 안의 단지 수렴하는 습관적 행태와, ‘must’, ‘should’, ‘ought to’ 같은 단어가 종종 징후(sign)가 되는 규칙의 존재 사이의 핵심적 차이는 무엇인가? 이 지점에서 기실 법이론가들은 특히 오늘날 들어 의견이 크게 나뉘고 있다. 여러 사정들이 이 쟁점을 전면에서 떠오르게 했기 때문이다. 법규칙들의 경우, 이 핵심적 차이—즉 ‘must’나 ‘ought’ 요소—는 특정 유형의 행위들로부터의 이탈이 적대적 반응을 맞을 개연성이 있고, 법규칙들의 경우에는 공무담당자들에 의해 처벌될 것이라는 점에 있다고 종종 여겨진다. 반면 매주 영화관에 가는 것과 같은 단순한 집단 습관(group habits)의 경우, 이러한 이탈은 처벌은 물론 질책조차 받지 않는다. 그러나 특정한 행위를 요구하는 규칙들이 존재하는 경우, 교회에서 남성이 모자를 벗어야 한다고 요구하는 규칙처럼 그것이 법적이지 않더라도, 이탈로부터 이러한 종류의 무엇인가가 발생할 개연성이 있다. 법규칙들의 경우, 이러한 예측 가능한(predictable) 귀결은 명확하게 정해져 있고 공식적으로 조직되어 있으나(officially organized), 비법적 규칙의 경우에는 이탈에 대한 유사한 적대적 반응이 개연적이기는 하지만(probable) 조직화되거나 명확하게 정해진 성격의 것은 아니다.

처벌의 예측 가능성(predictability of punishment)이 법규칙들(legal rules)의 중요한 측면이라는 것은 명백하다. 그러나 이를 사회적 규칙(social rule)이 존재한다는 진술이 의미하는 바에 대한 망라적 설명(exhaustive account)으로 받아들이거나, 규칙에 수반되는 ‘~해야 한다’ (must 또는 ought)의 요소를 설

명하는 것으로 받아들이는 것은 불가능하다. 이와 같은 예측적 설명(predictive account)에 대해서는 많은 비판이 제기되어 왔지만, 그중 특히 스칸디나비아의 한 법이론 학파 전체의 특징을 이루는 하나의 비판은 세심한 검토를 받을 만하다. 그 비판은 다음과 같다. 법규칙들로부터의 일탈(deviation)을 처벌하는 판사나 공무담당자(official)의 (또는 비법적(non-legal) 규칙으로부터의 일탈을 꾸짖거나 비판하는 사인들(private persons)의) 활동을 면밀히 살펴보면, (p. 11) 이 활동들 속에서 규칙들은 예측적 설명이 전혀 설명하지 못하는 방식으로 관여하고 있다는 것이다. 즉, 판사는 처벌할 때 그 규칙을 자신의 행위향도지침(guide)으로 삼고, 규칙의 위반을 위반자(offender)를 처벌하기 위한 자신의 이유(reason)이며 정당화(justification)로 삼는다. 그는 그 규칙을 ‘자신과 다른 이들이 그러한 일탈을 처벌할 개연성이 있다’는 진술(statement)로 보지 않는다. 물론 제3자의 관찰자(spectator)는 규칙을 바로 이러한 방식으로 볼 수는 있겠지만, 판사에게는 규칙의 예측적 측면이 충분히 실제적인 것이기는 해도 자신의 목적과 무관하며, 규칙이 행위향도지침이자 정당화라는 지위가 필수적이다. 이와 같은 구조는 비법적 규칙의 위반에 대해 이루어지는 비공식적인 질책(informal reproofs)에서도 마찬가지로 나타난다. 이러한 질책들 또한 일탈에 대한 단지 예측 가능한 반응(predictable reactions)에 그치지 않으며, 오히려 규칙의 존재가 향도하고 정당화한다고 여겨지는 어떤 것이다. 따라서 우리는 어떤 사람이 규칙을 위반했기 때문에(because) 그를 질책하거나 처벌한다고 말한다. 이는 단순히 우리가 그를 질책하거나 처벌할 개연성(probability)이 있었음을 말하는 것이 아니다.

그런데 이러한 예측적 설명(predictive account)에 대한 비판을 밀어붙인 학자들 가운데 일부는, 이 문제에 여전히 모호함이 존재한다고 고백한다. 명료하고 확고한 사실적(factual) 용어로 분석하기 어려운 어떤 요소가 존재한다는 것이다. 규칙(rule)이라는 것이, 통상적 행위 양식들에서 일탈한 사람들에 대한 반복적으로 일양적인, 따라서 예측 가능한 처벌(punishment)이나 질책(reproof) 외에, 단순한 집단 습관(group habit)과는 구별되는 무엇을 내포하고 있을 수(can) 있는가? 분명히 파악 가능한 이러한 사실들 이외에, 판사의 행위를 향도하고 그에게 처벌을 정당화하거나 그 이유(reason)를 제공하는 어떤 추가적인

요소가 정말 존재하는가? 바로 이 추가 요소가 정확히 무엇인지 말하기 어려운 점 때문에, 이러한 비판자들은 이 지점에서 모든 규칙에 관한 논의와 ‘must’, ‘ought’, ‘should’와 같은 단어의 사용은 혼란을 내포하고 있으며, 아마도 그것이 사람들의 눈에 중요해 보이게 만들지만, 실제로는 합리적 근거가 없다고 주장하게 된다. 이러한 비판자들의 입장에 따르면, 우리는 단지 어떤 규칙 속에 우리를 특정한 일들을 하도록 구속하는(binds us) 무언가가 있고, 우리가 그 일을 할 때 우리를 향도하거나(guide) 정당화해주는(justify) 무언가가 있다고 생각할(think) 뿐이며, 이는 비록 유용한 착각일 수는 있겠지만 환상이라는 것이다. 이들이 주장하기로는, 집단행동(group behaviour)의 명확히 확인 가능한 사실들과, 일탈에 대한 예측 가능한 반응이라는 사실을 넘어서 존재하는 것은 단지 규칙에 부합하게 행동하고 그렇게 하지 않는 자들에게 대항해야 한다는 우리 자신의 강력한 강제감(compulsion)의 ‘감정들(feelings)’ 뿐이다. 우리는 이러한 감정들을 있는 그대로 인식하지 못하고, 외부에 있는 어떤 것, 즉 이러한 활동들에서 우리를 향도하고 통제하는 우주의 직조(fabric of the universe)의 보이지 않는 일부가 존재한다고 상상한다. 여기서 우리는 허구(fiction)의 영역 안에 있으며, 법은 언제나 그 허구와 연결되어 왔다고 흔히 말해진다. 오직 우리가 이러한 허구를 채택했기 때문에만, 우리는 정부가 ‘사람들이 아니라 법들에 의한 정부(government of laws not men)’ 라고 엄숙하게 말할 수 있는 것이다. 이러한 유형의 비판은, 그 적극적 논지들의 이점이 무엇이든, 적어도 사회적 규칙(social rules)과 행동의 단순한 수렴적 습관(convergent habits of behaviour) 사이의 구별에 대한 보다 명확한 해명을 요청하는 것이다. 이 구별은 법을 이해하는 데 있어 핵심적이며, 본서의 초기 장들 상당 부분이 바로 이 문제를 다루고 있다.

그러나 법규칙들의 성격에 대한 회의(scepticism)가 항상, 구속력 있는 규칙(binding rule)이라는 관념 자체를 혼란스럽거나 허구적이라 비판하는 극단적 형태로만 나타나는 것은 아니다. 오히려 영국과 미국에서 가장 널리 퍼져 있는 회의적 시각은, 법체계(legal system)가 전적으로(wholly), 혹은 심지어 주로(primarily) 규칙들로 구성되어 있다는 관점을 재검토하라고 요청한다. 물론 법원(courts)은 그들의 판결(judgments)을, 그 결정이 고정되고 명확한 의미를

가진 미리 정해진 규칙들(predetermined rules)의 필연적 귀결인 것 같은 인상을 주도록 구성한다. 아주 단순한 사건에서는 그럴 수도 있다. 그러나 법원을 곤란하게 만드는 대다수의 사건들에서는, 그러한 규칙이 담겨 있다고 주장되는 제정법(statutes)이나 선례(precedents) 어느 것도 오직 하나의 결과만을 허용하지 않는다. 중요한 사건들의 대부분에서 판사(judge)는 언제나 선택해야 한다. 그는 하나의 제정법 문언에 주어질 수 있는 여러 가지 의미들 중에서 선택해야 하며, 특정 선례가 무엇에 ‘해당하는지(amounts to)’에 관한 경쟁하는 해석들 중에서 결정해야 한다. 단지 판사는 법을 ‘창출(make)’ 하는 것이 아니라 ‘발견(find)’ 한다는 전통만이 이러한 사실을 은폐하고, 마치 그들의 판결이 판사의 선택이 끼어들지 않은 채 명료한 이미 존재하는 규칙들로부터 매끄럽게 이루어진 연역(deductions)인 것처럼 제시한다. 법규칙들(legal rules)은 중심(core)에는 누구도 이견을 제기하지 않는 명확한 의미를 가질 수 있으며, 어떤 경우에는 그 규칙의 의미에 대해 분쟁이 발생한다는 것을 상상하기조차 어려울 수 있다. 예를 들어, 1837년 유언법(Wills Act) 제9조(s. 9)는 유언에는 두 명의 증인이 있어야 한다고 규정하고 있는데, 이는 해석상의 문제를 거의 일으킬 것 같지 않다. 그러나 모든 규칙은 그 반음영(penumbra)에는 불확실성(uncertainty)이 존재하며, 이 영역에서는 판사가 대안들 사이에서 선택을 해야 한다. 유언자가 유언장에 서명(sign)해야 한다는 유언법의 별문제 없어 보이는 규정조차도 특정 상황에서는 의심스러워질 수 있다. 유언자가 가명(pseudonym)을 사용했다면? 그의 손이 다른 사람에 의해 이끌렸다면(guided)? 이니셜만 기입했다면? (p. 13) 도움 없이 자신의 완전하고 정확한 이름을 적었지만 마지막 페이지 하단이 아니라 첫 번째 페이지 상단에 적었다면? 이 모든 경우가 그 법규칙의 의미 내에서 ‘서명(signing)’에 해당하는가?

만약 이러한 정도의 불확실성이 사법(private law)의 소박한 영역에서도 발생할 수 있다면, “어떠한 사람도 적법절차(due process of law) 없이 생명, 자유 또는 재산을 박탈당해서는 안 된다”고 규정하는, 미국 헌법 제5수정 및 제14수정(Fifth and Fourteenth Amendments to the Constitution of the United States)과 같은 장엄한 표현(magniloquent phrases) 속에서는 훨씬 더 큰 불확실성이

존재하지 않겠는가? 이에 대해 한 저자⁹는 다음과 같이 말한 바 있다. 이 표현의 진정한 의미는 실은 매우 분명하다는 것이다. 즉, “w는 z 없이는 x 또는 y가 되어서는 안 되는데, 여기서 w, x, y, 그리고 z는 모두 넓은 범위의 어떤 값도 취할 수 있다.”는 의미이다. 이야기의 끝을 장식하듯, 회의론자들은 우리에게 다음 사실을 상기시킨다. 규칙들이 불확실할 뿐만 아니라, 법원의 해석은 권위적(authoritative)일 뿐 아니라 최종적(final)일 수도 있다는 것이다. 이러한 모든 점을 고려할 때, 법을 본질적으로 규칙들의 문제로 간주하는 구상은, 오류가 아니라 하더라도, 심한 과장(gross exaggeration)이 아닌가? 이러한 생각들은 앞서 인용한 역설적 부정(paradoxical denial)으로 이어진다. 즉, “제정법들(statutes)은 법의 원천들(sources)이지, 그 자체가 법의 일부는 아니다.”¹⁰

3. 정의 (Definition)

여기 이제 세 가지 반복되는 쟁점이 있다. 첫째, 법은 위협으로 뒷받침된 명령들과 어떻게 구별되며 어떤 관계에 있는가? 둘째, 법적 의무(legal obligation)는 도덕적 의무(moral obligation)와 어떻게 구별되며 어떤 관계에 있는가? 셋째, 규칙들(rules)이란 무엇이며, 법은 어느 정도까지 규칙들의 문제인가? 이 세 가지 쟁점에 대한 의심과 당혹스러움을 해소하려는 것이 ‘법의 본성(nature)’에 대한 대부분의 사변(speculation)의 주된 목적이었다. 이제 왜 이러한 사변이 대개 ‘법의 정의(definition)’에 대한 탐구로 여겨져 왔는지, 또 익숙한 정의의 형식들이 왜 지속되는 난점과 의문들을 거의 해소하지 못했는지도 알 수 있다. 정의라는 말이 암시하듯, 정의는 본질적으로 구분선을 긋는 일, 즉 언어가 독립된 단어로 구획해 온 서로 다른 사물의 종류를 나누는 일이다. 이러한 구분선의 필요는, 일상에서 그 단어를 아무 문제 없이 사용하는 사람이라 할지라도, 자신이 감지하는 구별이 어떤 것인지 명확히 말하거나 (p. 14) 설명하지 못할 때 자주 나타난다. 우리 모두는 때때로 이러한 곤경에 빠진다. ‘코끼리는 보면 알아볼 수 있지만, 그것을 정의할 수는 없다’고 말하는 사람의 상황이 근본적으로

⁹J. D. March, ‘Sociological Jurisprudence Revisited’, 8 *Stanford Law Review* (1956), p. 518.

¹⁰Gray, loc. cit.

그것이다. 성 아우구스티누스(St. Augustine)의 시간 관념에 대한 유명한 말¹¹도 같은 곤경을 표현한 것이다. “그렇다면 시간은 무엇인가? 아무도 묻지 않으면 나는 안다. 그러나 누군가 그것을 설명하라 하면 나는 모른다.” 많은 숙련된 법률가들도 이와 같은 방식으로 느껴 왔다. 즉, 그들은 법을 알고 있지만, 법과 다른 사물과의 관계에 대해 설명할 수 없는 많은 것들이 있으며, 그것을 완전히 이해하지는 못한다고 느낀다. 마치 익숙한 도심에서 목적지까지 길은 잘 찾아가지만, 다른 사람에게 그 길을 설명해줄 수는 없는 사람과 같다. 정의를 요구하는 사람은 자신이 어렴풋이 감지하고 있는 법과 다른 사물들 사이의 관계를 명확히 보여주는 지도가 필요한 것이다.

때로 이러한 경우에 어떤 단어의 정의는 그러한 지도를 제공할 수 있다. 즉, 정의는 한편으로는 우리가 어떤 단어를 사용하는 것을 이끄는 잠재적 원리를 명시적으로 드러내고, 다른 한편으로는 우리가 그 단어를 적용하는 현상 유형과 다른 현상들 사이의 관계를 제시할 수 있다. 정의는 흔히 ‘단지 언어적인 것 (verbal)’ 이거나 ‘단어들(words)에 관한 것일 뿐’ 이라고 말해지지만, 정의되는 표현이 현재 사용 중인 것일 경우 이러한 평가는 크게 오해를 불러일으킬 수 있다. 예컨대 삼각형을 ‘세 변을 가진 직선 도형’ 으로 정의하거나, 코끼리를 ‘두꺼운 피부, 뼈드렁니, 긴 코를 지닌 점에서 다른 것들과 구별되는 네 발 달린 동물’ 로 정의하는 것조차, 소박한 방식이기는 하지만 이 단어들의 표준적 사용법과 그 단어들이 적용되는 대상들에 대해 우리에게 가르침을 준다. 이러한 친숙한 유형의 정의는 동시에 두 가지 일을 수행한다. 그것은 그 단어를 다른 잘 이해된 용어들로 번역하는 하나의 코드나 공식(code or formula)을 제공하는 동시에, 더 넓은 사물의 집합과 공유하는 특징들과 동일한 집합 내의 다른 것들과 그것을 구별 짓는 특징들을 지목함으로써, 그 단어가 가리키는 데 사용되는(refer to) 대상의 종류를 우리에게 자리매김해 준다. 이러한 정의를 탐구하고 발견하는 과정에서 우리는 “단지 단어들을만 살펴보는 것이 아니라 … 우리가 말을 통해 이야기하는 현실들 또한 살펴보고 있다. 우리는 단어들에 대한 예리한 자각을 사용하여 현상들에 대한 우리의 인식을 예리하게 하고 있는 것이다.”¹²

¹¹ *Confessiones*, xiv. 17.

¹² J. L. Austin, ‘A Plea for Excuses’, *Proceedings of the Aristotelian Society*, vol. 57

(p. 15) 이러한 정의 형식은 (*per genus et differentiam*, 즉 속(genus)과 종차(differentia)를 통한 정의) 삼각형이나 코끼리 같은 단순한 사례에서 볼 수 있으며, 가장 단순하면서도 어떤 이들에게는 가장 만족스러운 정의 방식이다. 왜냐하면 그것은 정의된 단어를 언제든지 대체할 수 있는 표현을 제공해 주기 때문이다. 하지만 이 정의 형식은 항상 사용 가능한 것도 아니며, 사용 가능하더라도 항상 해명적인 것도 아니다. 그것의 성공은 특정한 조건들이 충족될 때에만 가능하다. 그중에서도 가장 중요한 조건은, 우리가 그 특성을 분명히 이해하고 있는 더 넓은 범주, 즉 속(genus)이 존재해야 한다는 것이다. 정의는 우리가 알고 있는 일반적인 것들 속에서 어떤 특수하고 종속된 종류를 위치시키는 것이기 때문이다. 그런데 그 속 자체에 대해 모호하거나 혼란스러운 관념들만 갖고 있다면, 그 속의 일원이 무엇인지를 알려주는 정의는 아무런 도움이 되지 못한다. 이 조건은 법의 경우에 이러한 정의 형식을 쓸모없게 만든다. 법이 속하는 친숙하고 잘 이해된 일반 범주라는 것이 존재하지 않기 때문이다. 법의 정의에 있어 가장 뚜렷한 후보는 행위 규칙들(rules of behaviour)이라는 일반 범주일 것이다. 그러나 우리가 이미 본 바와 같이, 규칙 개념 자체가 법 개념만큼이나 당혹스럽기 때문에, 법들을 규칙의 한 종(species)으로 식별하는 데서 출발하는 법의 정의들은 보통 법에 대한 우리의 이해를 더 이상 나아가게 하지 못한다. 법을 익숙하고 잘 이해된 일반 종류 속의 특수하고 종속된 종류로 위치시키는 데 성공하는 정의 형식보다 더 근본적인 무언가가 요구된다.

그러나 법(law)의 경우, 이러한 단순한 형태의 정의(definition)를 유용하게 사용하는 데에는 더욱 만만치 않은 장애들이 존재한다. 어떤 일반 표현(*general expression*)이 이러한 방식으로 정의될 수 있다는 상정(*supposition*)은, 정의 대상이 되는 삼각형이나 코끼리의 모든 사례들이 그 정의된 표현에 의해 나타내어지는(*signified*) 공통된 특성들(*common characteristics*)을 가진다는 암묵적 가정(*tacit assumption*)에 기초한다. 물론 비교적 기초적인 단계에서도 경계 사례(*borderline cases*)의 존재가 우리의 주의를 강하게 끌며, 이는 일반 용어의 여러 사례들이 같은 특성들을 가져야 한다는 가정(*assumption*)이 독단적일 수 있음을 보여준다. 종종 어떤 용어의 일상적 용례나 심지어 기술적 용례조차도

(1956-7), p. 8.

매우 ‘열려(open)’ 있어서, 통상적으로 수반되는 특성들 중 일부만 존재하는 경우에도 그 용어의 확장을 금지하지(forbid) 않는다. 이미 언급했듯 이러한 점은 국제법(international law)이나 특정한 형태의 원시법(primitive law)에 그대로 적용되며, 따라서 그 용어의 확장을 찬성하거나 반대하는 논증이 언제나 그럴듯하게 제시될 수 있다. 더 중요한 것은, (p. 16) 이러한 경계 사례와 무관하게, 일반 용어의 여러 사례들이 단순한 정의 형식이 상정한(postulated) 방식과는 전혀 다른 방식으로 서로 연결될 수 있다는 점이다. 예를 들어, ‘발(foot)’ 이라는 말이 인간의 발에도 적용되고 산의 하단부에도 적용될 때처럼, 이들은 유추(analogy)에 의해 연결될 수 있다. 또는 서로 다른(different) 관계들로 중심 요소(central element)와 연결될 수도 있다. 이러한 통일 원리는 ‘건강하다(healthy)’라는 단어가 사람뿐 아니라 그의 안색(complexion)이나 아침 운동(morning exercise)에도 적용되는 사례에서 발견된다. 이때, 첫 번째 중심적 특성에 대하여, 두 번째는 징후(sign)이며 세 번째는 그 원인(cause)이다. 또는—그리고 여기서 우리는 법체계를 구성하는 서로 다른 유형의 규칙들(rules)을 통일하는 원리와 유사한 사례를 볼 수 있을 것이다—여러 사례들이 어떤 복합적 활동(complex activity)의 서로 다른 구성요소(constituents)일 수 있다. 형용사적 표현 ‘철도(railway)’가 열차(train)뿐 아니라 선로들(lines), 역(station), 운반인(porter), 그리고 유한회사(limited company)에도 적용되는 경우가 바로 이러한 유형의 통일 원리에 의해 지배된다.

물론 우리가 지금까지 논의한 매우 단순한 전통적 형태 외에도 정의(definition)에는 다른 많은 종류들이 존재한다. 그러나 우리가 “법이란 무엇인가(What is law?)”라는 반복적으로 제기되는 질문의 배후에 존재하는 세 가지 주요 문제들의 성격을 떠올려보면, 정의로 인식될 수 있을 정도로 간결한 어떠한 것도 이 질문에 만족스러운 해답을 줄 수 없다는 점은 분명해 보인다. 이들 근처의 문제들은 서로 간에 너무나도 이질적이며, 또한 너무 근본적인 것이어서 이와 같은 방식의 해소는 불가능하다. 간결한 정의를 제시하려는 시도들의 역사가 바로 이를 보여준다. 그러나 이 세 가지 질문들을 단일한 질문 또는 정의 요청으로 종종 결합시켰던 그 본능은 결코 잘못된 것이 아니었다. 왜냐하면 이 책의 서술 과정에서 보게 되겠지만, 이 세 가지 질문 모두에 대한 해답의 공통

부분을 구성하는 중심적인 요소들의 집합을 분리해내고 성격을 규정하는 것이 가능하기 때문이다. 이러한 요소들이 무엇이며, 왜 이 책에서 그토록 중요한 위치를 차지하게 되었는지는, 우리가 먼저 오스틴(Austin)이 그것을 상세히 제시한 이후 영국의 법리학을 지배해온 이론의 결함을 자세히 살펴볼 때 가장 잘 드러날 것이다. 그것은 법을 이해하기 위한 열쇠는 위협(threats)으로 뒷받침된 명령(order)이라는 단순한 관념(notion)에서 찾아야 한다는 주장(claim)이다. 오스틴은 이 관념을 ‘사령(command)’ 이라고 불렀다. 이러한 이론의 결함에 대한 탐구는 다음 세 장에 걸쳐 다루어진다. (p. 17) 이 이론을 먼저 비판하고, 그 주요한 경쟁 이론에 대한 검토를 이 책의 뒷장들로 미루는 데 있어, 우리는 현대 법이론(modern legal theory)이 발전해온 역사적 순서를 의도적으로 무시하였다. 왜냐하면, 법은 도덕과의 ‘필연적(necessary)’ 연결을 통해 가장 잘 이해된다는 경쟁 주장은 오히려 더 오래된 교설이며, 오스틴은 이전의 벤담(Bentham)과 마찬가지로 그것을 주요한 비판 대상으로 삼았기 때문이다. 이런 비역사적 처리에 대해 해명(excuse)이 필요하다면, 그것은 다음과 같다. 단순 명법 이론(simple imperative theory)의 오류들이, 그보다 복잡한 경쟁 이론들의 오류들보다 진리로 이끄는 더 나은 길잡이라는 것이다.

이 책의 여러 지점에서 독자는 법이론가들이 ‘법(law)’ 또는 ‘법체계(legal system)’ 라는 표현의 적용에 관하여 의문을 제기해 온 경계적 사례들(borderline cases)에 대한 논의를 발견하게 될 것이다. 또한 이러한 의문들에 대한 제안된 해소도 함께 발견하게 되겠지만, 그것은 이 책의 부차적인 관심사에 불과하다. 이 책의 목적은 ‘그 규칙을 참조(reference)하여 단어의 사용이 올바른지 여부를 검사할 수 있는 어떤 규칙’ 이라는 의미에서의 법의 정의(definition of law)를 제시하는 데 있지 않기 때문이다. 그 목적은 오히려, 국내법체계(municipal legal system)의 고유한 구조(distinctive structure)에 대한 보다 개선된 분석을 제공하고, 사회적 현상의 유형들로서 법(law), 강제(coercion), 도덕(morality) 사이의 유사점들과 차이점들에 대한 더 나은 이해를 제시함으로써 법이론을 진전시키는 데 있다. 다음 세 장에 걸친 비판적 논의 과정에서 식별되고, 제5장과 제6장에서 상세히 기술되는 일련의 요소들은, 이 책의 나머지 부분에서 입증되는 방식으로 이러한 목적에 기여한다. 바로 이러한 이유 때문에, 이 요

소들은 법 개념(concept of law)의 중심 요소들(central elements)로, 그리고 그
해명(elucidation)에 있어 가장 중요한 것으로 다루어진다.

주석 (Notes)

이 책의 본문은 자족적인(self-contained) 구조를 가지고 있으므로, 독자는 각 장을 처음부터 끝까지 읽은 뒤에 이 주석 부분을 참고하는 것이 가장 좋을 수 있다. 본문의 각주는 인용문들의 출처들(sources of quotations), 그리고 인용된 판례들이나 제정법들(statutes)에 대한 참조만을 제공한다. 이에 반해, 다음의 주석들은 다음과 같은 세 가지 유형의 내용을 독자의 주의를 환기시키기 위해 마련되었다: (i) 본문에 제시된 일반적 진술에 대한 추가적인 예시나 사례; (ii) 본문에서 채택하거나 언급한 견해를 더 상술하거나 비판한 문헌; (iii) 본문에서 제기된 물음들에 대한 추가적인 탐구를 위한 제안. 이 책 자체에 대한 모든 참조들(references)은 장 번호와 절 번호만으로 간단히 표시된다 (예: 제1장 제1절). 다음은 본문에 사용된 주요 약어들(abbreviations)이다:

약어	출전 또는 설명
Austin, The Province	오스틴, 『법리학의 범위는 어떻게 결정되는가(The Province of Jurisprudence Determined)』 (하트 편, 런던, 1954)
Austin, The Lectures	오스틴, 『실정법 철학 강의(Lectures on the Philosophy of Positive Law)』
Kelsen, General Theory	켈젠, 『법과 국가의 일반이론(General Theory of Law and State)』
BYBIL	영국 국제법 연보(British Year Book of International Law)
HLR	하버드 로 리뷰(Harvard Law Review)
LQR	법 분기별 리뷰(Law Quarterly Review)
MLR	현대 법 리뷰(Modern Law Review)
PAS	아리스토텔레스 학회 발표집(Proceedings of the Aristotelian Society)

제1장 주석

1-2쪽. Llewellyn, Holmes, Gray, Austin, Kelsen의 인용문들은 모두, 저자의 견해에 따르면, 일반적인 법률 용어에 의해 가려졌거나 이전의 이론가들에 의해 과도하게 간과된 법의 어떤 측면을 강조하기 위해 사용된 역설적이거나 과장된 표현이다. 중요한 법리학자에 관해서는, 그가 한 법에 대한 진술들이 문자 그대로 참인지 거짓인지라는 문제에 대한 검토를 유보하고, (1) 그가 자신의 진술들을 뒷받침하기 위해 제시한 구체적

이유와, (2) 그 진술이 대체하도록 설계된 법 구상 또는 법 이론을 먼저 검토하는 것이 종종 유익하다.

간과된 진리를 강조하는 방법으로서, 역설적이거나 과장된 단언들(assertions)을 이와 유사하게 사용하는 일은 철학에서도 흔히 볼 수 있다. J. Wisdom, 'Metaphysics and Verification' (*Philosophy and Psychoanalysis*, 1953); Frank, *Law and the Modern Mind* (런던, 1949), 부록 VII ('Notes on Fictions') 참조.

이 페이지들에 인용된 다섯 개의 인용문 각각에서 단언되거나 함축된 교설들은 다음에서 분석된다: 제7장 제2·3절 (Holmes, Gray, Llewellyn), 제4장 제3·4절 (Austin), 제3장 제1절 35-42쪽 (Kelsen).

4쪽. 표준 사례와 경계 사례. 여기서 언급된 언어적 특징은 일반적으로 제7장 제1절 '법의 개방적 직조(The Open Texture of Law)' 라는 표제 아래에서 논의된다. 이 특징은 '법', '국가', '범죄' 등의 일반 용어에 대한 정의가 명시적으로 요구될 때 뿐만 아니라, 일반 용어들로 정식화된 규칙들을 특정 사례들에 적용하는 데 수반되는 추론의 성격을 규정하려는 시도에서도 염두에 두어야 한다. 이 언어적 특징의 중요성을 강조한 법률 저술가들로는 다음이 있다: Austin, *The Province*, Lecture VI, 202-207쪽, 및 *Lectures in Jurisprudence* (5판, 1885), 997쪽 ('Note on Interpretation'); Glanville Williams, 'International Law and the Controversy Concerning the Word "Law"', 22 *BYBIL* (1945); 'Language in the Law' (5편의 논문), 61 및 62 *LQR* (1945-6). 단, 후자의 경우 J. Wisdom이 *Philosophy and Psycho-Analysis* (1953) 수록 논문 'Gods' 및 'Philosophy, Metaphysics and Psycho-Analysis'에서 제시한 비평 참조.

6쪽. Austin의 의무 관념. *The Province*, Lecture I, 14-18쪽; *The Lectures*, Lecture 22, 23 참조. 의무라는 관념 및 '의무를 가진 것(having an obligation)' 과 '강제에 의해 하지 않을 수 없게 되는 것(being obliged)' 사이의 차이들은 제5장 제2절에서 자세히 분석된다. Austin의 분석에 대한 주석은 제2장 아래, 282쪽 참조.

8쪽. 법적 의무와 도덕적 의무. 법이 도덕과의 연결을 통해 가장 잘 이해된다는 주장(claim)은 제8·9장에서 분석된다. 이 주장은 매우 다양한 형태들을 띠어 왔다. 고전 및 중세 스콜라 자연법 이론에서처럼, 이 주장은 근본적인 도덕적 구별이 인간 이성에 의해 발견 가능한 '객관적 진리' 라는 단언(assertion)을 수반하기도 하지만, 법과 도덕의 상호의존성을 강조하는 데 똑같이 관심을 가진 다른 많은 법리학자들은 도덕의 본성에 대한 이러한 견해에 구속되어 있지 않다. 제9장 주석, 아래 302쪽 참조.

10쪽. 스칸디나비아 법이론과 구속력 있는 규칙이라는 관념. 영어 독자에게 가장 중요한

이 학파의 저작은 Hägerström (1868-1939), *Inquiries into the Nature of Law and Morals* (Broad 번역, 1953), 그리고 Olivecrona, *Law as Fact* (1939)이다. Olivecrona는 법규칙들의 성격에 대한 그들의 견해를 가장 명확히 서술하고 있다. 그는 많은 미국 법리학자들이 선호한 법규칙들에 대한 예측적 분석을 비판하는데 (op. cit. 85-88쪽, 213-215쪽), 이 비판은 Kelsen, *General Theory* (165쪽 이하, 'The Prediction of the Legal Function')에 나타난 유사한 비판과 비교할 가치가 있다. 이 두 법리학자가 많은 점에서 견해를 공유하면서도 왜 법규칙들의 성격에 대해 전혀 다른 결론에 도달하는지를 묻는 것도 흥미롭다. 스칸디나비아 학파에 대한 비판으로는 다음을 참조: Hart, Hägerström 서평, *Philosophy* 제30권 (1955); 'Scandinavian Realism', *Cambridge Law Journal* (1959); Marshall, 'Law in a Cold Climate', *Juridical Review* (1956).

12쪽. 미국 법이론에서의 규칙 회의론(rule-scepticism). 제7장 제1·2절 '형식주의와 규칙 회의론(Formalism and Rule-scepticism)' 참조. 여기서는 이른바 '법현실주의(Legal Realism)'로 알려지게 된 주요 교설들 중 일부가 검토된다.

12-13쪽. 일상어 의미에 대한 의심. 'sign(서명하다)' 또는 'signature(서명)'의 의미에 관한 판례들로는 *Halsbury, Laws of England* (2판) 제34권, 제165-169절 및 *In the Estate of Cook* (1960), 1 AER 689 및 거기에 인용된 판례들 참조.

13쪽. 정의. 정의의 형식과 기능에 대한 현대 일반 이론은 Robinson, *Definition* (옥스퍼드, 1952) 참조. 법 용어들을 해명하는 방법으로서 전통적인 *per genus et differentiam* 정의 방식의 부적절성에 대해서는 Bentham, *Fragment on Government* (제5장 제6절 주석), Ogden, *Bentham's Theory of Fictions* (75-104쪽) 참조. Hart, 'Definition and Theory in Jurisprudence', 70 *LQR* (1954); Cohen and Hart, 'Theory and Definition in Jurisprudence,' *PAS* 보충권 제29권 (1955)도 참조.

'법(law)'이라는 용어의 정의에 대해서는 다음을 참조: Glanville Williams, 앞서 인용한 저작; R. Wollheim, 'The Nature of Law', 2 *Political Studies* (1954); Kantorowicz, *The Definition of Law* (1958), 특히 제1장. 개별 사례들에서의 일상적 사용에 대해서는 아무런 의심이 느껴지지 않는 경우에도 용어들의 정의가 일반적으로 왜 필요한지, 그리고 어떤 명료화 기능을 수행하는지에 대해서는 다음을 참조: Ryle, *Philosophical Arguments* (1945); Austin, 'A Plea for Excuses', 57 *PAS* (1956-7), 15쪽 이하.

15쪽. 일반 용어(general terms)와 공통 속성(common qualities). 어떤 일반 용어(예: '법', '국가', '국민', '범죄', '좋은 것', '정의로운 것')가 정확히 사용되기 위해서는 그 용어가 적용되는 사례들의 범위가 모두 '공통된 속성'을 공유해야 한다는 무비판적

인 믿음은 많은 혼란의 원천(source)이 되어 왔다. 법리학에서는, 이러한 견해에서 볼 때 같은 단어를 서로 다른 많은 사물들에 사용하는 유일하게 존중할 만한 이유가 된다고 여겨지는 공통 속성들을 정의의 목적상 찾아내려는 헛된 시도에 많은 시간과 재간이 낭비되어 왔다(예: Glanville Williams, 앞서 인용). 다만, 일반 단어들의 성격에 대한 이러한 잘못된 견해가 항상, 이 저자가 시사하는 바와 같은 ‘언어적 질문’ 과 사실 문제간의 추가적 혼동까지 수반하는 것은 아니라는 점에 주의해야 한다.

법적, 도덕적, 정치적 용어들에 있어, 일반 용어의 여러 사례들이 어떻게 상이하게 관련될 수 있는지를 이해하는 것은 특히 중요하다. 유추적 관계에 대해서는 Aristotle, *Nicomachean Ethics* 제1권 제6장(‘good’의 다양한 사례들이 이와 같은 관계로 연결되어 있다고 암시) 참조; Austin, *The Province*, Lecture V, 119–124쪽. 중심 사례와의 다른 방식의 관계(예: ‘healthy’)에 대해서는 Aristotle, *Categories* 제1장 및 *Topics* 제1권 제15장, 제2권 제9장의 ‘파생어(paronyms)’ 사례들 참조. ‘가족 유사성(family resemblance)’이라는 관념에 대해서는 Wittgenstein, *Philosophical Investigations*, 제1부, 제66–76절 참조. 제8장 제1절 ‘just’라는 용어의 구조에 대한 논의도 비교 참조. Wittgenstein의 조언(op. cit., 제66절)은 법적·정치적 용어 분석에서 특히 적절하다. 그는 ‘게임(game)’이라는 단어의 정의를 논하면서 이렇게 말했다. “‘게임’이라 불리는 것들 사이에 반드시 공통점이 있어야 한다(must)고 말하지 말고, 보라(look) 그리고 살펴보라(see). 그러면 그 모든 것들(all)에 공통된 무언가가 있는 것이 아니라, 유사성, 관계, 그러한 것들의 전체 계열이 있을 뿐임을 보게 될 것이다.”

제1장 제3판 주석

Hart 자신의 주석은 이 판에서도 변경 없이 유지되었다. 그것들은 여전히 그의 논증의 미묘한 차이, 본문에서 충분히 전개되지 않은 생각들, 그리고 그의 견해와 다른 이들의 견해 사이의 비교를 이해하는 데 유용하다. 그러나 학술적 자료로서 이 주석들은 종종 후속 연구들에 의해 대체된다. 아래는 Hart의 논변들을 확장하거나 비판하는 최근 영어권 연구들에 대한 안내이며, 문헌이 방대하기 때문에 포괄성을 목표로 하지 않고, 학생들에게 특히 유용할 수 있는 일부 항목만을 제시한다. 가능하다면 Hart와 지속적인 논쟁을 벌였던 인물들, 또는 그의 저작을 직접 논의하거나 발전시킨 다른 이들의 저작을 중심으로 선정했다. Hart의 법철학에 대한 일반 연구는 매우 많으며, 권위 있는 단행본 두 권은 다음과 같다: Neil MacCormick, *H. L. A. Hart* (2판, Stanford University Press, 2008; 이하의 모든 쪽수 표기는 1판, 1981 기준), Michael D. Bayles, *Hart’s Legal Philosophy: An Examination* (Kluwer Academic, 1992). 간결한 개요로는 Joseph Raz의

부고문 ‘H. L. A. Hart (1907–1992)’ (1993) *Utilitas* 제5권 145쪽이 있다. Hart의 생애와 지적 배경은 Nicola Lacey, *A Life of H. L. A. Hart: The Nightmare and the Noble Dream* (Oxford University Press, 2004) 참조.

3–4쪽. 법에 관한 공통 지식(common knowledge). 통상적 이해들과 자기이해(self-understanding)가 법이론에 가지는 중요성에 대해서는 Joseph Raz, *Between Authority and Interpretation* (Oxford University Press, 2009), 제2장 참조.

4쪽. 법체계의 경계 사례(borderline cases). Hart의 요지는, 법에 대한 철학적 논쟁은 일반적으로 경계 사례의 존재에서 비롯되는 것이 아니라는 것이다. Ronald Dworkin도 이 점에 동의한다: *Law's Empire* (Harvard University Press, 1986), 40–43쪽 참조. 국내법체계가 법의 중심 사례인지 여부에 의문을 제기하는 견해로는 다음을 참조: John Griffiths, ‘What is Legal Pluralism?’ (1986) *Journal of Legal Pluralism & Unofficial Law* 제24권 1쪽; William Twining, *General Jurisprudence: Understanding Law from a Global Perspective* (Cambridge University Press, 2009), 제4장; Keith Culver and Michael Giudice, *Legality's Borders* (Oxford University Press, 2010).

6–13쪽. 반복되는 쟁점들(recurrent issues). Hart는 이후 법철학의 과제를 약간 다르게 보게 되었다. 그는 1967년에 본서에서 다룬 쟁점들에 추가하여 법적 추론(legal reasoning)의 문제와 법 비판(criticism of law)의 문제들—법을 평가할 적절한 기준, 법의 도덕적 권위의 근거 등—을 법철학의 주요 과제로 포함시켰다. 관련 논의는 *Essays in Jurisprudence and Philosophy* (Oxford University Press, 1983), 제3장 ‘Problems of the Philosophy of Law’ 참조.

법이론의 과제를 상반된 방식으로 제시하는 견해들은 다음에서 찾아볼 수 있다: Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (개정판, Harvard University Press, 1978), 14–16쪽; Ronald Dworkin, *Law's Empire*, 1–6쪽; John Finnis, *Natural Law and Natural Rights* (2판, Oxford University Press, 2011), 제1장; Hugh Collins, *Marxism and Law* (Oxford University Press, 1984), 제1장. Hart의 과제 목록에 대한 평가로는 Leslie Green, ‘General Jurisprudence: A 25th Anniversary Essay’ (2005) *Oxford Journal of Legal Studies* 제25권 565쪽 참조.

14쪽. 단어와 대상 간의 관계. P. M. S. Hacker, ‘Hart’s Philosophy of Law’, in P. M. S. Hacker and J. Raz eds., *Law, Morality, and Society: Essays in Honour of H. L. A. Hart* (Oxford University Press, 1977), 특히 2–12쪽 참조. Neil MacCormick, *H. L. A. Hart*, 12–19쪽도 참조. Dworkin은 Hart가 “법률가들이 모두 법명제들을 판단할 때 특정한

언어적 기준을 따른다”고 본다고 해석했으며, 이는 *Law's Empire* 45-46쪽에서 ‘의미론적 독침(semantic sting)’ 논변의 기초를 이룬다. Hart 방법론의 이 측면에 대한 비판은 Nicos Stavropoulos, ‘Hart’s Semantics’, in Jules Coleman ed., *Hart’s Postscript* (Oxford University Press, 2001)에서도, 그리고 서로 다른 근거에서 Brian Leiter, ‘Beyond the Hart/Dworkin Debate: The Methodology Problem in Jurisprudence’, (2003) *American Journal of Jurisprudence* 제48권 17쪽, 특히 43-51쪽에서도 찾아볼 수 있다.

‘법(law)’이라는 단어의 의미론적 분석은 Jules Coleman and Ori Simchen, ‘Law’ (2003) *Legal Theory* 제9권 1쪽 참조. 법리학이 과연 의미론(semantics)과 관계가 있는지에 대한 의문은 Joseph Raz, *Ethics in the Public Domain* (개정판, Oxford University Press, 1995), 제9장, 특히 195-198쪽 및 *Between Authority and Interpretation*, 49-59쪽 참조. 정치이론의 언어적 접근에 대한 일반적 회의론은 David Miller, ‘Linguistic Philosophy and Political Theory’, in David Miller and Larry Siedentop eds., *The Nature of Political Theory* (Oxford University Press, 1983) 참조.

15-16쪽. 속·종차에 따른 정의(Definition per genus et differentiam). Hart의 입장에 대한 비판은 P. M. S. Hacker, ‘Definition in Jurisprudence’ (1969) *Philosophical Quarterly* 제19권 343쪽 참조.

16쪽. 답변의 공통된 부분을 형성하는 중심적 요소들의 집합. 이 요소들은 91-99쪽에서 제시된다. 이것이 ‘법’이나 ‘법체계’에 대한 개념 분석(conceptual analysis)을 이루는지 여부는, 그러한 분석이 무엇을 요구한다고 보는가에 달려 있다. 비교문헌으로는 Frank Jackson, *From Metaphysics to Ethics: A Defense of Conceptual Analysis* (Oxford University Press, 1998), Colin McGinn, *Truth by Analysis: Games, Names, and Philosophy* (Oxford University Press, 2012), 특히 제2장 참조. Hart가 제시한 종류의 이론과 사회학적 이론 간의 관계에 대해서는 다음을 참조: H. L. A. Hart, ‘Analytical Jurisprudence in Mid-Twentieth Century: A Reply to Professor Bodenheimer’ (1956) *University of Pennsylvania Law Review* 제105권 953쪽; M. Krygier, ‘“The Concept of Law” and Social Theory’ (1982) *Oxford Journal of Legal Studies* 제2권 155쪽; B. Z. Tamanaha, ‘Socio-Legal Positivism and a General Jurisprudence’ (2001) *Oxford Journal of Legal Studies* 제21권 1쪽; Denis Galligan, ‘Legal Theory and Empirical Research’, in Peter Cane and Herbert Kritzer eds., *Oxford Handbook of Empirical Legal Research* (Oxford University Press, 2010).

II. 법들(Laws), 사령들(Commands), 그리고 명령들(Orders)

1. 명법들의 다양상들(Varieties of Imperatives)

법(law)의 개념을 사령(command)과 습관(habit)이라는 겉보기에는 단순한 요소들로 분석하려 한 가장 명확하고도 철저한 시도는 오스틴(Austin)이 『법리학의 범위는 어떻게 결정되는가(Province of Jurisprudence Determined)』에서 한 시도이다. 이 장과 다음 두 장에서 우리는 실질적으로 오스틴의 교설과 동일하지만 몇몇 지점에서는 아마도 그로부터 벗어나는 입장을 서술하고 비판할 것이다. 우리의 주요 관심은 오스틴 개인에 있지 않고, 결합에도 불구하고 지속적인 매력을 지니는 특정 유형의 이론이 가진 자격 근거(credentials)에 있다. 따라서 오스틴의 의미가 의심스럽거나 그의 견해가 일관되지 않아 보이는 지점에서는 그 점을 무시하고 명확하고 일관된 입장을 서술하는 데 주저하지 않았다. 또한 오스틴이 비판에 대응할 수 있는 방식들에 관해 단서만 제시한 경우, 우리는 (Kelsen 등의 이후 이론가들이 취한 노선들을 일부 따라) 그러한 대응 방식을 발전시켜, 우리가 고찰하고 비판할 교설이 가장 강한 형태로 진술되도록 했다.

사회생활의 여러 상이한 상황에서, 한 사람이 다른 사람에게 어떤 행위를 하거나 하지 않기를 바라는 바람(a wish)을 표현할 수 있다. 이 바람이 단순한 흥미로운 정보 제공이나 의도적인 자기-드러내기(deliberate self-revelation)가 아니라, 말을 건네받은 사람이 그 표현된 바람에 부합하여 행위하도록 하려는 의도로 표현되는 경우, 영어를 포함한 많은 언어들에서는 (비록 필수는 아니지만) 명령법(imperative mood)이라 불리는 특별한 언어적 형식을 사용하는 것이 관습적이다. 예컨대 ‘집에 가라!’ (Go home!), ‘이리 와!’ (Come here!), ‘멈춰!’ (Stop!), ‘그를 죽이지 마라!’ (Do not kill him!) 등이 그러하다. 이러한 명령법 형식으로 타인에게 말을 건네는 사회적 상황은 극도로 다양하지만, 그 안에는 반복적으로 나타나는 몇 가지 주요 유형들이 포함되며, 그 중요성은 일정한 익숙한 분류들에 의해 표시된다. 예를 들어 ‘소금 좀 주세요’는 보통 단순한

요청(request)이다. 일반적으로 그것은 화자가 자신에게 어떤 서비스를 제공할 수 있는 상대방에게 건네는 말이고, 어떤 큰 긴급성이 있다는 시사도, 준수하지 않을 경우 어떤 일이 뒤따를지에 관한 암시도 없기 때문이다. ‘나를 (p. 19) 죽이지 마시오’ 는 보통, 화자가 말을 건네받은 사람의 자비에 맡겨져 있거나 그 상대방이 자신을 풀어줄 힘을 가진 곤경에 처한 경우의 간청(plea)으로 발화될 것이다. 반면에 ‘움직이지 마!’ 는 경우에 따라 경고(warning)가 된다. 예컨대 화자가 말을 건네받은 사람에게 임박한 위험(풀숲의 뱀 등)을 알고 있고, 그가 가만히 있음으로써 그 위험을 피할 수도 있는 상황이 그렇다.

명령법 형식의 언어가 전형적으로, 비록 반드시 항상은 아니지만, 사용되는 사회적 상황의 다양상들은 그 수가 많을 뿐 아니라 서로 경계가 흐려지며 이어지기도 한다. ‘간청’, ‘요청’, ‘경고’ 와 같은 용어들은 단지 몇 가지 거친 구별을 가능케 할 뿐이다. 이 가운데 가장 중요한 상황은 ‘명법(imperative)’ 이라는 단어가 특히 적절해 보이는 경우이다. 그것은 권총강도가 은행 직원에게 “돈을 내놓지 않으면 쏠겠다” 고 말하는 사례가 보여주는 상황이다. 여기서 우리가 ‘돈을 내놓으라’ 고 은행 직원에게 단순히 요청하거나(asking) 더구나 간청하는(pleading with) 것이 아니라 권총강도가 명령하고(ordering) 있다고 말하게 되는 뚜렷이 구분되는 특징은, 화자가 자신이 표현한 바람에 대한 준수(compliance)를 확보하기 위해 일반인이 해롭거나 불쾌하게 여길 만한 일을 하겠다고 위협함으로써, 돈을 계속 보유하는 것이 해당 직원에게 실질적으로 덜 선택할 만한 행위노선이 되도록 만든다는 점이다. 만약 권총강도가 성공한다면, 우리는 그가 직원을 강제했다(coerced)고 말하며, 직원이 그런 의미에서 권총강도의 힘(power) 아래 놓였다고 말하게 된다. 이와 같은 경우에는 언어적으로 미묘한 문제들이 발생할 수 있다. 우리는 ‘권총강도가 직원에게 돈을 내놓으라고 명령했다(ordered)’ 고 적절히 말할 수 있고, ‘직원이 복종했다(obeyed)’ 고도 말할 수 있다. 그러나 ‘권총강도가 직원에게 돈을 내놓으라는 명령을 내렸다(gave an order)’ 고 말하는 것은 다소 오해를 낳을 수 있다. 이 표현은 군대식 표현처럼 들리며, 이 사안에서는 존재하지 않는, 명령(order)을 내릴 어떤 권리나 권위(authority)를 시사하기 때문이다. 그러나 ‘권총강도가 자신의 부하에게 문을 지키라고 명령을 내렸다(gave an order)’ 는 식의 표현은

자연스럽다.

우리는 여기서 이러한 미묘한 차이들에 대해 깊이 들어갈 필요는 없다. 비록 ‘명령(order)’ 이나 ‘복종(obedience)’ 이라는 단어에는 종종 권위(authority)와 권위에 대한 존중적 순응(deference to authority)의 시사가 붙을 수 있지만, 우리는 ‘위협으로 뒷받침된 명령들(orders backed by threats)’ 또는 ‘강제적 명령들(coercive orders)’ 이라는 표현을, 권총강도의 명령처럼 오직 위협에 의해서만 뒷받침되는 명령들을 지칭하는 데 사용할 것이다. 그리고 우리는 ‘복종(obedience)’ 또는 ‘복종하다(obe)’ 라는 표현을 그러한 명령에 대한 준수(compliance)까지 포함하는 의미로 사용할 것이다. 그러나 사령이라는 개념적 파악(notion of a command)에 대한 오스틴의 정의가 법리학자들에게 끼친 큰 영향 때문에만이라도, (p. 20) 해악의 위협만, 그 밖에는 아무것도 없이, 복종을 강제하는 데 사용되는 단순한 상황은 우리가 자연스럽게 ‘사령’ 이라고 말하는 상황이 아니라는(not) 점은 주목하는 것이 중요하다. 이 단어는 군사적 맥락 외에는 흔히 사용되지 않으며, 사령이라는 표현에는 일반적으로 다음과 같은 강한 함의가 따라붙는다. 즉, 군대나 제자 집단처럼 상대적으로 안정된 위계 조직이 존재하고, 그 속에서 사령자는 우위의 지위(position of pre-eminence)를 차지한다는 것이다. 일반적으로는 하사관이 아니라 장군(general)이 사령자(commander)로서 사령들을 내리는 것이며, 이러한 특수한 우위(pre-eminence)의 다른 형태도 이와 같은 방식으로 표현된다. 예컨대 신약성경에서 예수가 제자들에게 사령한(command) 것으로 표현되는 경우가 그러하다. 더 중요한 점은—그리고 이는 명법(imperative)의 서로 다른 형태들 사이에서 핵심적인 구분이다—사령이 존재하는 경우라고 해서 항상 불복종 시 해악이 가해질 수 있다는 잠재적 위협(threat)이 있어야 하는 것은 아니라는 점이다. 사령한다는 것은 특징적으로, 해악을 가할 힘(power)이 아니라 사람들에게 대한 권위(authority)를 행사하는 것이며, 비록 해악의 위협과 결합될 수는 있어도, 사령은 일차적으로 공포가 아니라 권위에 대한 존중을 호소하는 행위이다.

명백하게도, 사령이라는 관념(idea)은 권위(authority)와 매우 강하게 연관되어 있기 때문에, 위협으로 뒷받침된 우리의 권총강도 명령보다는 법(law)이라는 관념에 훨씬 더 가깝다. 비록 오스틴은 앞 단락에서 지적된 구분을 무시하고

후자의 경우(권총강도의 명령)를 사령이라고 오도하여 부르고 있지만 말이다. 그러나 우리의 목적에서, 사령은 오히려 법에 지나치게 가깝다. 왜냐하면 법에 관여하는 권위의 요소는 법이 무엇인지 쉽게 설명하기 어렵게 만드는 장애물 가운데 하나이기 때문이다. 그러므로 우리는 법을 해명함에 있어, 동일하게 권위를 포함하고 있는 사령이라는 개념적 파악(notion of a command)을 유익하게 사용할 수 없다. 기실 오스틴 분석의 미덕(virtue)은, 그 결점들이 무엇이든 간에, 권총강도 상황(gunman situation)에 등장하는 요소들이 권위의 요소와 달리 그 자체로 모호하지 않으며 많은 설명을 요하지 않는다는 데 있다. 이러한 이유로 우리는 오스틴을 따라 그로부터 법이라는 관념(idea of law)을 구성해보려 할 것이다. 다만 우리는 오스틴처럼 그것이 성공하리라 기대하기보다는, 실패를 통해 배우기를 희망할 것이다.

2. 강제적 명령들(coercive orders)로서의 법

현대 국가와 같은 복잡하고 대규모의 사회에서도, 어떤 공무담당자(an official)가 개인과 직접 마주하여 무언가를 하라고 명령하는(order) 경우들이 있다. 예컨대 경찰관이 (p. 21) 특정 운전자에게 정지하라고 하거나, 특정 거지에게 자리를 옮기라고 명령하는 경우가 있다. 그러나 이러한 단순한 상황들은 법이 기능하는 표준적 방식이 아니며, 그럴 수도 없다. 단지 사회의 모든 구성원에게 그들이 해야 할 모든 행위가 공식적으로 또 각각 별도로 통지되도록 보장하는 데 필요한 공무담당자들의 수를 어느 사회도 감당할 수 없기 때문이다. 대신 이러한 개별화된 통제 형식들은 예외적이거나, 특정 개인들의 이름을 들지 않고, 그들에게 말을 건네지도 않으며, 수행되어야 할 특정 행위를 지목하지도(indicate) 않는 일반적 지시 형식들(general forms of directions)의 부수적 동반물 또는 강화물에 불과하다. 따라서 (법들의 모든 다양상들 가운데서도 위협으로 뒷받침된 명령(order)과 가장 유사한) 형사 제정법(criminal statute)의 표준적(standard) 형식조차도 다음의 두 가지 측면에서 일반적이다(general). 즉, 그것은 일반적인 행위 유형을 지목하고(indicate), 그것이 자신에게 적용된다는 점을 알아보고 그것을 준수할 것으로 기대되는 사람들의 일반 부류에 적용된다. 이때 공식적이고

개별화된 대면 지시들은 이차적 지위를 가진다. 만약 일차적인 일반 지시들이 특정 개인에 의해 복종되지 않을 경우, 공무담당자들은 그의 주의를 그것들로 돌리고 준수를 요구할 수 있으며(세무 조사관이 그러하듯), 또는 불복종이 공식적으로 식별되고 기록되어, 위협된 처벌이 법원에 의해 부과될 수 있다.

따라서 법적 통제는 일차적으로(primarily), 비록 배타적으로는 아니지만, 이러한 이중의 의미에서 일반적(general)인 지시에 의한 통제이다. 이것이 우리가 법의 특성들을 재현하기 위해 권총강도의 단순한 모델에 추가해야 할 첫 번째 특징이다. 영향을 받는 사람들의 범위와 그 범위가 지목되는(indicated) 방식은 서로 다른 법체계들, 심지어 서로 다른 법들에 따라 달라질 수 있다. 현대 국가에서는 그 부류를 확대하거나 축소하는 특별한 표시들(indications)이 없는 한, 그 일반 법들은 해당 영토 경계 안의 모든 사람에게 미친다고 통상 이해된다. 교회법(canon law)에서도 이와 유사하게, 더 좁은 부류가 지목되는(indicated) 경우를 제외하면 교회의 모든 구성원이 그 법의 범위 안에 있다고 통상 이해된다. 모든 경우에 어떤 법의 적용 범위는, 그러한 일반적 이해들의 도움을 받는 해당 특정 법의 해석 문제이다. 이 지점에서 주목할 만한 것은, 오스틴을 포함한 여러 법리학자들이 법들이 사람들의 부류에 향하여 있다(addressed)고 말하지만,¹ 이러한 표현은 (p. 22) 실제로 존재하지 않으며 이 표현을 사용하는 사람들이 의도하지도 않은 대면 상황(face-to-face situation)과의 병행관계를 시사하기 때문에 오해를 불러일으킬 수 있다는 점이다. 사람들에게 무언가를 하도록 명령(order)하는 것은 일종의 의사소통 방식으로, 실제로 그들에게 말을 건네는 것, 곧 그들의 주의를 끌거나(attracting their attention) 그것을 끌기 위한 조치를 취하는 것을 포함한다. 그러나 사람들에게 대하여 법들을 제정하는 것은 그렇지 않다. 예컨대 권총강도는 ‘그 지폐들을 내놔라’ 라는 하나의 동일한 발화로, 직원이 무언가를 하길 바란다는 자신의 바람(wish)을 표현하고 실제로 직원에게 말을 건넨다(addresses). 곧 그는 이 표현을 직원의 주위에 도달하게 하기에 통상 충분한 일을 하는 것이다. 만약 권총강도가 후자의 일을 하지 않고 빈 방에서 같은 말을 했을 뿐이라면, 그는 결코 직원에게 말을 건넨(addressed)

¹ ‘공동체 전체를 향한(addressed to the community at large)’ 것. Austin, above, p. 1 n. 4 at p. 22.

것이 아니며, 직원에게 어떤 행위를 하라고 명령한(order) 것도 아니다. 우리는 그 상황을 단지 권총강도가 ‘그 지폐들을 내놔라’ 는 말을 한 경우라고 서술할 수 있을 뿐이다. 이 점에서 법 제정은 타인에게 무언가를 하도록 명령하는 행위와 다르며, 법에 대한 모델로서 이러한 단순한 관념(idea)을 사용할 때는 이 차이를 반드시 고려해야 한다. 기실 법들은 제정된 뒤 가능한 한 곧 그 법들이 적용되는 자들의 주위에 도달하게 되는 것이 바람직할 수 있다. 입법자의 법 제정 목적은 일반적으로 이것이 이루어지지 않으면 좌절될 것이고, 법체계는 종종 공포(promulgation)에 관한 특별 규칙들을 통해 이것이 이루어지도록 마련한다. 그러나 법들은 이러한 절차가 이루어지기 이전에도 법들로서 완결될 수 있으며, 아예 이루어지지 않더라도 그러하다. 반대되는 특별 규칙이 없는 한, 법들은 그 영향을 받는 사람들이 어떤 법들이 제정되었고 그 법들에 의해 누가 영향을 받는지를 스스로 알아내도록 남겨진 경우에도 유효하게 제정된다(validly made). 일반적으로 법들이 특정한 사람들에게 ‘향하여 있다’ 고 말하는 이들이 보통 의도하는 바는, 바로 그 사람들이 해당 법이 적용되는 자들(the persons to whom the particular law applies), 즉 그 법이 특정한 방식으로 행동할 것을 요구하는 자들이라는 것이다. 만약 우리가 여기서 ‘향하여 있다’ 는 단어를 사용할 경우, 법 제정과 대면 명령(face-to-face order) 간의 중요한 차이를 간과할 수 있으며, 동시에 두 개의 상이한 질문— ‘그 법은 누구에게 적용되는가?’ 와 ‘그 법은 누구에게 공포되었는가?’ —를 혼동할 수 있다.

이러한 일반성(generality)의 특성을 도입하는 것 외에도, 우리가 법이 존재하는 상황에 대한 그럴듯한(plausible) 모델을 얻고자 한다면, 권총강도 상황에 대해 보다 근본적인 변경이 필요하다. 물론 어떤 의미에서 권총강도는 은행 직원보다 우세(ascendancy) 또는 우위(superiority)를 가진다. 그 우세 또는 우위는 (p. 23) 권총강도가 위협을 가할 수 있는 일시적 능력에 있으며, 이는 은행 직원이 그에게 하라는 말을 들은 특정 행위를 수행하게 만들기에 충분할 수 있기 때문이다. 이 둘 사이에는 이러한 단명한 강제적 관계 외에 다른 어떤 우위와 열위의 관계도 존재하지 않는다. 그러나 권총강도의 목적에는 그것으로 충분할 수 있다. ‘그 지폐들을 내놓지 않으면 쏠겠다’ 는 단순한 대면 명령은 그 상황과 함께 사라진다. 권총강도는 은행 직원에게 (자신의 부하들에게는

가능할지 몰라도) 사람들의 부류가 여러 번 반복하여 따라야 할 계속적 명령들(standing orders)을 내리지 않는다. 그러나 법들은 두드러지게 이러한 ‘계속적(standing)’ 또는 지속적인(persistent) 성격을 지닌다. 따라서 우리가 위협으로 뒷받침된 명령들(orders backed by threats)이라는 관념(notion)을 법이 무엇인가에 대한 설명으로 사용하고자 한다면, 반드시 법들이 지니는 이러한 존속적 성격(enduring character)을 재현하려는 노력이 필요하다.

그러므로 우리는 일반 명령들(the general orders)이 적용되는 사람들 쪽에, 불복종에는 그 명령이 처음 공포될 때뿐 아니라 그 명령이 철회되거나 취소될 때까지 계속해서 위협의 실행이 뒤따를 개연성이 있다는 일반적인 믿음(a general belief)이 존재한다고 상정해야 한다. 불복종의 귀결에 관한 이러한 계속적 믿음은, 원래의 명령들을 살아 있게 또는 ‘계속적(standing)’ 상태로 유지한다고 말할 수 있다. 다만, 우리가 뒤에서 보게 되듯이, 법들의 지속적 성질(persistent quality)을 이러한 단순한 용어들로 분석하는 데는 어려움이 있다. 물론 위협의 실행에 관한 이러한 계속적 개연성(continuing likelihood)에 대한 일반적 믿음이 존재하려면, 권총강도 상황에서는 재현될 수 없는 여러 요인들의 동시발생(concurrence)이 실제로 요구될 수도 있다. 즉 다수의 사람들에게 영향을 미치는 그러한 계속적 명령들에 부착된 위협들을 실행할 수 있는 힘(power)은, 인구 중 상당수가 스스로 자발적으로—곧 위협에 대한 공포와는 독립적으로—복종할 준비가 되어 있을 뿐만 아니라, 복종하지 않는 자들에 대해 위협들을 집행하는 데 협력할 준비가 되어 있다는 점이 알려져 있을 때에만 실제로 존재할 수 있으며, 또한 존재한다고 여겨질 수 있을지도 모른다.

이러한 위협이 실행될 개연성(likelihood)에 대한 일반적인 믿음의 기초(basis)가 무엇이든 간에, 법이 존재하는 정착된 상황에 근접한 모델을 구성하기 위해, 우리는 권총강도 상황에 추가해야 할, 그와 구별되는 또 하나의 필수적 요소(a further necessary feature)를 구분해야 한다. 즉, 동기가 무엇이든 간에, 영향을 받는 사람들 대부분에 의해 대부분의 명령들이 불복종되기보다는 더 자주 복종된다는 점을 상정해야 한다. 우리는 이를 오스틴을 따라 (p. 24) ‘일반적 복종 습관(general habit of obedience)’ 이라고 부를 것이며, 그와 함께, 이 관념(notion)이 법의 여러 다른 측면들과 마찬가지로 본질적으로 모호하거나

불분명한 것임을 지적할 것이다. 얼마나 많은 사람들이 얼마나 많은 그러한 일반 명령들에 얼마 동안 복종해야 법이 존재하게 되는가라는 질문이 확정적인 답을 허용하지 않는 것은, 사람이 얼마나 적은 머리카락을 가져야 대머리인지를 묻는 질문이 확정적인 답을 허용하지 않는 것과 마찬가지로, 그러나 이와 같은 일반 복종의 사실 안에야말로, 법들과 권총강도의 원래의 단순한 명령 사례 사이의 핵심적 구별이 존재한다. 단기간 동안 한 사람이 다른 사람에 대해 가지는 일시적 우세는 본래 법의 상대적으로 존속적이고 정착된 성격에 정반대 되는 것으로 여겨지며, 기실 대부분의 법체계에서는 권총강도가 가지는 이와 같은 단기적 강제적 힘(coercive power)을 행사하는 것 자체가 범죄(criminal offence)를 구성할 것이다. 기실 여전히 살펴보아야 할 것은, 위협으로 뒷받침된 일반 명령들에 대한 일반적이고 습관적인 복종이라는 이 단순하지만 인정권대 모호한 관념(notion)이, 법체계들이 가지는 정착된 성격과 계속성(continuity)을 충분히 재현해낼 수 있는지이다.

우리가 권총강도 사례의 단순한 상황에 차례차례 요소를 덧붙여 구성한, 일반적으로 복종받는 자가 내린 위협으로 뒷받침된 일반 명령들의 개념은, 분명히 법들의 다른 어떤 다양상보다도 근대 국가의 입법부가 제정한 형벌 제정법(penal statute)에 더 가깝다. 그러나 이러한 형벌 제정법들과는 일견(prima facie) 매우 달라 보이는 법의 유형들(types of law)이 존재하며, 우리는 이후에 법들의 이러한 다른 다양상들도 그와 반대되는 외관에도 불구하고 실은 단지 이러한 동일한 형식의 복잡하거나 위장된 변형일 뿐이라는 주장에 대해 살펴볼 것이다. 그러나 우리가 일반적으로 복종되는 일반 명령이라는 구성된 모델을 통해 형벌 제정법의 특징들만이라도 재현하고자 한다면, 명령을 내리는 사람에 대해 좀 더 말해야 한다. 근대 국가의 법체계는 그 영토 내에서의 일정한 최고성(supremacy)과 다른 법체계로부터의 독립성(independence)이라는 특징을 지닌다. 이 두 관념은 보이는 것만큼 단순하지 않지만, 상식적 관점에서 볼 때(그 관점이 충분하지 않은 것으로 드러날 수도 있겠지만) 그것들에 본질적인 것은 다 음과 같이 표현될 수 있다. 영국법, 프랑스법, 또는 여타 근대 국가의 법은 비교적 명확한 지리적 경계를 가진 영토 내에 거주하는 인구의 행위를 규율한다. 각 국가의 영토 내에는 (p. 25) 위협으로 뒷받침된 일반 명령들을 내리고 이에 대해

습관적 복종을 받는 여러 개인들 또는 개인들의 단체들이 있을 수 있다. 그러나 우리는 이들 가운데 일부(예컨대 런던 카운티 의회(LCC)나 우리가 위임입법 권한들(powers of delegated legislation)이라고 부르는 것을 행사하는 장관 등)를 종속된(subordinate) 입법자로서 최고(supreme)인 영국 의회 내의 여왕(Queen in Parliament)과 구분해야 한다. 이 관계는 습관의 단순한 용어로도 표현될 수 있다. 즉, 영국 의회 내의 여왕은 법을 만들 때 아무에게도 습관적으로 복종하지 않는 반면, 종속된 입법자들은 제정법으로 정해진 한계들(limits) 안에 머무르며, 따라서 법을 만들 때 영국 의회 내의 여왕의 대리인(agent)이라고 말할 수 있다. 만약 이들이 그렇게 하지 않는다면, 우리는 더 이상 하나의 영국법 체계를 갖는 것이 아니라 복수의 법체계를 갖게 될 것이다. 그러나 실제로는 영국 의회 내의 여왕이 바로 이 의미에서 영토 내의 모든 자들에 대한 관계에서 최고이며, 다른 기구들은 그렇지 않기 때문에, 우리는 영국 내에서 하나의 단일한 체계를 갖고 있으며, 그 안에서 최고 요소와 종속된 요소들의 위계를 구별할 수 있는 것이다.

영국 의회 내의 여왕이 다른 사람들의 명령들에 습관적으로 복종하지 않는다(not)는 이와 같은 부정적 성격의 설명은, 서로 다른 국가들의 별개 법체계에 대해 우리가 말할 때 사용하는 독립성(independence)이라는 관념(notion)을 대략적으로 정의해 준다. 예컨대 소비에트 연방의 최고 입법부(supreme legislature)는 영국 의회 내의 여왕에게 복종하는 습관을 가지지 않으며, 후자가 소련 사무에 관하여 무엇을 제정하든(비록 그것이 영국법의 일부를 이루겠지만) 그것은 소련법의 일부가 되지는 않을 것이다. 그것이 그렇게 되려면 오직 영국 의회 내의 여왕이 소련의 입법부에 의해 습관적으로 복종받는 경우뿐일 것이다.

이러한 단순한 설명에 따르면(우리는 이후 이를 비판적으로 검토할 것이다), 법체계가 존재하는 곳에서는 어디에나 위협으로 뒷받침되고 일반적으로 복종되는 일반 명령들을 발령하는 어떤 개인들 또는 개인들의 단체가 있어야 하며, 그 위협들이 불복종의 경우 실행될 개연성이 있다고 일반적으로 믿어져야 한다. 이러한 개인 또는 단체는 내부에서는 최고(supreme)이며 외부에서는 독립(independent)적이어야 한다. 오스틴을 따라 이러한 최고이자 독립적인 개인 또는 개인들의 단체를 주권자(sovereign)라고 부른다면, 어떤 국가의 법들도 주권자 또는 주권자에게 복종하여 종속된 자들이 발령한, 위협으로 뒷받침된

일반 명령들이 될 것이다.

제2장 주석

18쪽. 명법들의 다양상들(The varieties of imperatives). 명법을 ‘명령(order)’ , ‘간청(plea)’ , ‘논평(comment)’ 등으로 분류하는 것은, 사회적 상황, 당사자들 사이의 관계, 힘의 사용에 대한 의도와 같은 여러 요소에 의존하며, 이는 사실상 아직 거의 탐구되지 않은 주제이다. 명법에 관한 대부분의 철학적 논의는 (1) 명법적 언어와 직설적(indicative) 혹은 서술적(descriptive) 언어 간의 관계 및 전자를 후자로 환원할 수 있는 가능성에 관한 문제(예: Bohnert, 「The Semiotic Status of Commands」, *Philosophy of Science* 제12권 (1945))나, (2) 명법들 사이에 어떤 연역적 관계가 존재하는지, 존재한다면 그것이 어떤 것인지에 관한 문제(예: Hare, 「Imperative Sentences」, *Mind* 제58권 (1949), 또한 *The Language of Morals* (1952); Hofstadter and McKinsey, 「The Logic of Imperatives」, *Philosophy of Science* 제6권 (1939); Hall, *What is Value* (1952), 제6장; Ross, 「Imperatives and Logic」, *Philosophy of Science* 제11권 (1944))에 집중되어 있다. 이러한 논리적 문제에 대한 연구는 중요하지만, 맥락적 사회 상황들을 참조하여 명법들의 다양상들을 구별하는 작업 역시 큰 필요성이 있다. 문법적 명령법(imperative mood) 문장이 어떤 표준적 상황에서 일반적으로 ‘명령(order)’ , ‘간청(plea)’ , ‘요청(request)’ , ‘사령(command)’ , ‘지시(directions)’ , ‘지침(instructions)’ 등으로 분류되는지를 묻는 것은, 단순히 언어에 관한 사실을 밝히는 것이 아니라, 여러 사회적 상황과 관계들 사이의, 언어에서 인정되는 유사점들과 차이점들을 발견하는 방법이기도 하다. 이러한 구별에 대한 인식은 법, 도덕, 사회학의 연구에 매우 중요하다.

18쪽. 타인이 어떤 행위를 하거나 하지 않기를 바라는 바의 표현으로서의 명법들. 언어에서 명령법의 표준적 사용을 이와 같이 설명할 때, 주의해야 할 점은 화자가 단순히 타인이 특정 방식으로 행동하길 바란다는 것을 자기 자신에 관한 정보로서 드러내는 경우와, 그 발화를 통해 실제로 말을 건네받은 사람이 화자의 바람대로 행위하도록 움직이게 하려는 의도를 지닌 경우를 구분해야 한다는 것이다. 전자의 경우에는 통상 명령법이 아니라 직설법(indicative mood)이 적절하다(이 구분에 대해서는 Hägerström, *Inquiries into the Nature of Law and Morals*, 제3장, §4, 116–126쪽 참조). 그러나 화자의 발화 목적이 말을 건네받은 사람이 자신이 바라는 방식으로 행위하는 것이라는 점은, 명령법의 표준적 사용을 설명하기 위해 필요하기는 하지만 충분하지는 않다. 왜냐하면, 화자는 말을 건네받은 사람이 이것이 자신의 발화 목적임을 인식하고, 그에 따라 영향을 받아 자신이 바라는 대로 행위하기를 의도해야 하기 때문이다. 이러한 복잡성(complication)은 본문에서는 생략되었으나, 이에 대해서는 Grice, 「Meaning」, *Philosophical Review*

제66권 (1957), Hart, 「Signs and Words」, *The Philosophical Quarterly* 제2권 (1952)을 참조하라.

19쪽. 권총강도(gunman) 상황, 명령(order), 복종(obedience). ‘명법(imperative)’이라는 일반 관념(notion)을 분석함에 있어 직면하는 어려움 중 하나는, 명령들(orders), 사령들(commands), 요청들(requests), 그리고 다른 많은 다양상들에 공통된 것, 즉 타인이 어떤 행동을 하거나 하지 않기를 바라는 의도의 표현을 가리키는 단어가 존재하지 않는다는 점이다. 이와 마찬가지로, 그러한 행동을 실제로 수행하거나 자제하는 것을 지칭하는 단일 단어도 없다. ‘명령들(orders)’, ‘요구들(demands)’, ‘복종(obedience)’, ‘준수(compliance)’와 같은 자연스러운 표현들은, 각각이 통상 사용되는 특수한 상황의 성격에 의해 채색되어 있다. 가장 무색적으로 보이는 ‘~하라고 말하기(telling to)’라는 표현조차, 어느 한쪽이 다른 쪽에 대해 일정한 우세를 점하고 있음을 시사한다. 권총강도 상황을 설명하기 위해, 우리는 ‘명령들(orders)’과 ‘복종(obedience)’이라는 표현을 선택했는데, 이는 권총강도가 은행 직원에게 돈을 건네라고 명령하였다(ordered)고 말하거나, 은행 직원이 이에 복종하였다(obeyed)고 말하는 것이 자연스럽기 때문이다. 물론, ‘명령들(orders)’과 ‘복종(obedience)’이라는 추상 명사들은 이 상황을 묘사하기 위해 자연스럽게 쓰이지는 않을 수 있다. 왜냐하면 전자에는 일정한 권위(authority)의 시사가 붙고, 후자는 종종 미덕으로 간주되기 때문이다. 그러나 강제적 명령들(coercive orders)로서의 법 이론을 설명하고 비판하는 데 있어, 우리는 이러한 권위나 적절성(propriety)의 함축 없이 ‘명령들(orders)’과 ‘복종(obedience)’이라는 명사들과, ‘명령하다(order)’와 ‘복종하다(obey)’라는 동사들을 사용하였다. 이는 단지 편의상 선택된 것이며, 어떠한 쟁점에 대해 결론을 미리 내리는 것은 아니다. 벤담(Bentham)은 (*Fragment of Government*, 제1장, 제12절 주석에서), 오스틴(Austin)은 (*The Province*, 14쪽에서) 이러한 방식으로 ‘복종(obedience)’이라는 용어를 사용하였다. 벤담은 여기서 언급된 모든 어려움을 인식하고 있었으며, 이에 대해서는 *Of Laws in General*, 298쪽 주석(a) 참조.

20쪽. 강제적 명령들(coercive orders)로서의 법, 그리고 오스틴(Austin) 교설과의 관계. 본 장의 제2절에서 구성된 강제적 명령들(coercive orders)로서의 법에 관한 단순 모델은 오스틴의 『법리학의 범위는 어떻게 결정되는가(*The Province of Jurisprudence Determined*)』에서의 교설과 다음과 같은 점에서 다르다.

(a) 용어 사용. 본문에서 설명된 이유로 인해, ‘사령(command)’이라는 용어 대신 ‘위협으로 뒷받침된 명령(order backed by threats)’ 혹은 ‘강제적 명령들(coercive orders)’이라는 표현이 사용되었다.

(b) 법의 일반성. 오스틴은 (같은 책, 19쪽) ‘법들(laws)’ 과 ‘개별 사령들(particular commands)’ 을 구분하며, 사령(command)은 그것이 “어떤 부류의 작위 또는 부작위에 대하여 일반적으로 하지 않을 수 없게 한다(obliges generally)” 면 법 또는 규칙이라고 주장한다. 이 관점에 따르면, 사령이 비록 주권자(sovvereign)에 의해 단 한 명의 개인에게 ‘향하여(addressed)’ 있더라도, 그것이 단일 행위나 개별적으로 특정된 서로 다른 행위들의 집합이 아니라 어떤 행위의 부류 또는 종류를 하거나 하지 말 것을 요구한다면, 법으로 간주될 수 있다. 본문의 법체계 모델에서는 명령들이 일반적이며, 이는 그것들이 개인들의 부류에 적용되고, 행위들의 부류를 가리킨다는 이중적 의미에서이다.

(c) 공포(fear)와 의무(obligation). 오스틴은 때때로 어떤 사람이 실제로 제재(sanction)를 두려워할 경우에만 구속되거나 하지/삼가지 않을 수 없게 된다고 암시한다(같은 책, 15쪽과 24쪽 및 『강의록』 제22강 (5판), 444쪽: “그 당사자는 해약에 노출되어 있고 그 해약을 두려워하기 때문에 행하거나 삼가도록 구속되거나(bound) 그렇게 하지 않을 수 없게 된다(obliged)”). 그러나 그의 주요 교설은, 구속된 사람이 그것을 두려워 하든 말든, “아주 사소한 해약을 입게 될 아주 작은 가망(chance)” 만 있어도 충분하다는 것처럼 보인다(『The Province』, 16쪽). 강제적 명령들로서의 법의 모델에서는, 단지 불복종이 위협된 해약으로 이어질 개연성이 있다는 일반적인 믿음이 존재해야 한다는 조건만을 설정하였다.

(d) 힘(power)과 법적 의무. 이와 유사하게, 사령(command)과 의무(obligation)를 분석하면서, 오스틴은 처음에는 사령의 발령자가 장차 닥칠 해약을 가할 힘(power)을 실제로 보유해야 한다고 시사한다(즉 ‘할 수 있고, 하려는(able and willing)’ 자이어야 한다). 하지만 이후에는 그 요건을 “가장 사소한 해약의 가장 작은 가망” 으로 약화시킨다(같은 책, 14쪽, 16쪽). 오스틴의 사령과 의무 정의에 나타나는 이러한 모호성에 대해서는 하트(Hart), 『법적·도덕적 의무(Legal and Moral Obligation)』, Melden 편 『도덕철학 에세이(Essays in Moral Philosophy)』(1958), 제5장 §2 참조.

(e) 예외 사례들. 오스틴은 선언적 법(declaratory laws), 허용적 법(permissive laws, 예: 폐지 제정물들), 불완전한 법(imperfect laws)을 그의 사령 중심의 일반적 법 정의의 예외로 간주한다(같은 책, 25-29쪽). 본 장 본문에서는 이 점을 고려하지 않았다.

(f) 주권자로서의 입법부. 오스틴은 민주주의에서 선거권자 집단(electorate)이 입법부에 있는 대표자들이 아니라 주권자 집단을 구성하거나 그 일부를 이룬다고 보았다. 비록 영국에서는 선거권자 집단이 자신의 주권을 행사하는 유일한 방식이 대표자들을 선출하고 나머지 주권적 권한들을 그들에게 위임하는 것이지만 말이다. 그는 ‘정확하게 말하면’ 이러한 입장이 옳다고 주장했으나, 모든 헌법학자들이 그러하듯이 의회

(parliament)가 주권을 가진다고도 말했다(같은 책, 강의 VI, 228-235쪽). 본문의 논의에서는 의회와 같은 입법부를 주권자와 동일시하고 있으나, 오스틴 교설의 이 측면에 대한 상세한 검토는 제4장 §4를 참조하라.

(g) 오스틴 교설의 정교화와 한계들. 본서의 후속 장들에서는, 오스틴 이론을 비판들로부터 방어하기 위해 사용되어 온 몇몇 관념들이 자세히 검토되지만, 이들은 본장에서 구성된 모델에는 재현되어 있지 않다. 이들 관념은 오스틴이 직접 도입한 것이나, 경우에 따라서는 개략적 또는 미정형(inchoate)의 형태로만 제시되었으며, 켈젠(Kelsen)과 같은 후속 이론가들의 교설들을 예견하는 요소도 있다. 여기에는 다음이 포함된다: ‘묵시적 사령(tacit command)’이라는 관념(notion) (위 제3장 §3, 45쪽 및 위 제4장 §2, 64쪽 참조), 무효(nullity)를 하나의 제재(sanction)로 보는 견해 (제3장 §1), ‘진정한 법’은 공무담당자들에게 향하여 있으며(addressed to officials) 그들에게 제재들을 적용할 것을 요구하는 규칙이라는 교설 (제3장 §1), 선거권자 집단을 비통상적 주권 입법부(extraordinary sovereign legislature)로 보는 관점 (제4장 §4), 주권 기구(sovereign body)의 통일성과 계속성 (제4장 §4, 76쪽). 오스틴에 대한 어떤 평가에서든 W. L. Morison, 「법실증주의에 대한 몇 가지 신화(Some Myth about Positivism)」, *Yale Law Journal* 제68권 (1958)에 주의를 기울여야 한다. 이는 오스틴에 대한 초기 학자들의 심각한 오해들을 바로잡는다. 또한 A. Agnelli, 『존 오스틴: 법실증주의의 기원에 대하여(John Austin alle origini del positivismo giuridico)』 (1959), 제5장도 참고하라.

제2장 제3판 주석

18쪽. 오스틴(Austin)의 이론. 하트(Hart)는 여기서 오스틴 이론의 단순화된 재구성을 다루고 있음을 명확히 하고 있다(오스틴의 이론 자체도 벤담(Bentham)의 이론의 단순화 버전이다). 오스틴 자신의 견해에 대해서는 다음 문헌들을 참조하라: W. L. Morison, 『존 오스틴(John Austin)』 (스탠퍼드 대학 출판부, 1982); W. E. Rumble, 『존 오스틴의 사상: 법리학, 식민지 개혁, 영국 헌정(John Austin: Jurisprudence, Colonial Reform, and the British Constitution)』 (애슬론 출판사, 1985). 18세기 후반부터 19세기 중반까지의 영국 법사상 전반에 대해서는 마이클 롭번(Michael Lobban), 『보통법과 영국 법리학 1760-1850(The Common Law and English Jurisprudence 1760-1850)』 (옥스퍼드 대학 출판부, 1991)를 참고하라.

18-20쪽. 명법들(imperatives)로서의 법. 이 주제에 대해서는 닐 매크믹(Neil MacCormick), 「법적 의무와 명법 오류(Legal Obligation and the Imperative Fallacy)」, A.

W. B. 심프슨 편 『옥스퍼드 법리학 에세이 제2집(Oxford Essays in Jurisprudence, 2nd series)』(옥스퍼드 대학 출판부, 1973)도 참조하라. 하트 자신의 이론 속에도 일종의 명법적 이론(imperative theory)이 남아 있다는 제안에 대해서는 G. J. 포스테마(G. J. Postema), 「사령으로서의 법: 현대 법리학 속 사령 모델(Law as Command: The Model of Command in Modern Jurisprudence)」, (2001) *Philosophical Issues* 제11권 470쪽을 참고하라. 명법적 이론의 측면들을 구제하려는 시도들로는 매튜 H. 크레이머(Matthew H. Kramer), 『법실증주의의 옹호: 불필요한 장식을 걷어낸 법(In Defense of Legal Positivism: Law Without Trimmings)』(옥스퍼드 대학 출판부, 1999), 83-87쪽; 로버트 레이든슨(Robert Ladenson), 「홉스적 법 구상의 옹호(In Defense of a Hobbesian Conception of Law)」, (1980) *Philosophy and Public Affairs* 제9권 134쪽 등을 참조하라.

20-22쪽. 법의 일반성(generality). 일반성 개념에 대한 두꺼운(thicker) 해석과 얇은(thinner) 해석을 비교하고자 한다면 다음을 참조하라: 프리드리히 하이에크(Friedrich Hayek), 『법, 입법, 자유(Law, Legislation, and Liberty)』 제1권 (시카고 대학 출판부, 1973), 제2장; 론 L. 풀러(Lon L. Fuller), 『법의 도덕성(The Morality of Law)』 개정판 (예일 대학 출판부, 1969), 46쪽 이하; 티모시 엔디콧(Timothy Endicott), 「법의 일반성(The Generality of Law)」, 루이스 두아르트 달메이다(Luís Duarte d'Almeida), 안드레아 돌체티(Andrea Dolcetti), 제임스 에드워즈(James Edwards) 편 『『법의 개념』 읽기(Reading *The Concept of Law*)』(하트 출판사, 2013).

24-25쪽. 최고성과 독립성(Supremacy and Independence). 이 주제에 대해서는 조셉 라즈(Joseph Raz), 『법체계 개념(The Concept of a Legal System)』 제2판 (옥스퍼드 대학 출판부, 1980), 제1장도 함께 참고하라.

III. 법들의 다양상

현대의 법체계, 예컨대 영국법에서 발견되는 여러 종류의 법들의 다양상(varieties)을 앞 장에서 구성한 강제적 명령들(coercive orders)이라는 단순한 모델과 비교해보면, 무수한 이의들이 즉시 떠오른다. 모든 법들이 사람들에게 어떤 일을 하거나 하지 말라고 명령하는 것은 분명 아니다. 유언장을 작성하거나 계약을 체결하거나 혼인을 성립시킬 권한들을 사적 개인들에게 부여하는 법들이나, 공무원담당자들에게 권한들을 부여하는 법들, 예컨대 판사에게 사건들을 재판할 권한을, 장관에게 규칙들을 제정할 권한을, 카운티 의회에게 조례들을 제정할 권한을 부여하는 법들을 그렇게 분류하는 것은 오해를 불러일으키는 것 아닐까? 모든 법들이 제정된(enacted) 것도 아니며, 그것들 모두가 우리 모델의 일반 명령들에서처럼 어떤 사람의 욕구(desire)를 표현한 것도 아니다. 대부분의 법체계에서 진정한, 비록 제한적인 자리를 차지하는 관습에 대해서는 이는 참이 아닌 것처럼 보인다. 법들은, 그것들이 의도적으로 제정된 제정법들(statutes)이라 하더라도, 반드시 오직 타인들에게만 내려진 명령들이어야 하는가? 제정법들이 종종 입법자들 자신을 구속하는 경우도 있지 않은가? 마지막으로, 제정된 법들이 법들이기 위해서는 반드시 어떤 입법자의 실제 욕구들(desires), 의도들(intentions), 또는 바람들(wishes)을 정말로 표현해야 하는가? 만약 적법하게 통과된 제정물(enactment)이 (영국의 재정법(Finance Act) 조항 중 많은 경우가 틀림없이 그렇듯) 그것에 찬성표를 던진 사람들이 그것이 무슨 의미인지 알지 못했다면 법이 아니게 되는가?

이러한 이의들은 가능한 수많은 이의들 중에서 가장 중요한 것들 중 일부이다. 분명히 원래의 단순한 모델에 일정한 수정을 가해야만 이러한 이의들에 대응할 수 있을 것이며, 그 모든 이의들을 수용한 뒤에는 위협으로 뒷받침된 일반 명령들이라는 관념(notion)이 원형을 알아볼 수 없을 정도로 변형되어 있을 수도 있다.

우리가 언급한 이의들은 세 가지 주요 부류로 나뉜다. 일부는 법들의 내용(content)에 관한 것이고, 다른 일부는 그것들의 기원 방식(mode of origin)에, 또 다른 일부는 그것들의 적용 범위(range of application)에 관한 것이다. 모든

법체계는—어쨌든 겉보기에는(seem)—이 세 가지 사항 중 하나 이상에서 우리가 설정한 일반 명령들의 모델에서 벗어나는 법들을 포함하고 있는 것처럼 보인다. 이 장의 나머지 부분에서는 이러한 세 가지 유형의 이의를 각각 따로 고찰할 것이다. 그리고 다음 장에서는 이보다 더 근본적인 비판, (p. 27) 즉 내용, 기원 방식, 적용 범위에 근거한(on the score of) 이러한 이의들과는 별개로, 이 모델이 기초하고 있는, 습관적으로 복종받는 최고이고 독립적인 주권자라는 전체 구상(conception)이 실제의 어떤 법체계에서도 그에 대응하는 것이 거의 없기 때문에 오해를 불러일으킨다는 비판을 다루기로 하겠다.

1. 법의 내용

형사법은 우리가 복종하거나 불복종하는 대상이며, 그 규칙들이 요구하는 바는 ‘책무(duty)’ 라고 말해진다. 우리가 불복종하면 우리는 법을 ‘어긴(break)’ 다고 말해지고, 우리가 한 것은 법적으로 ‘그른(wrong)’ 것, ‘책무 위반(breach of duty)’, 혹은 ‘위반행위(offence)’ 라고 말해진다. 형사 제정법(criminal statute)이 수행하는 사회적 기능은 특정 행위 유형들을, 그 법이 적용되는 자들의 바람과 무관하게, 피해야 하거나 해야 하는 것으로 설정하고 규정하는 데 있다. 형사법의 위반들(breaches) 또는 침해들(violations)에 법이 부착하는 형벌 또는 ‘제재(sanction)’ 는 (형벌이 다른 목적을 지닐 수도 있지만) 이러한 활동들을 삼가도록 하는 하나의 동기를 제공하려는 것이다. 이 모든 점에서 형사법과 그 제재들, 그리고 우리 모델의 위협으로 뒷받침된 일반 명령들 사이에는 적어도 강한 유비가 있다. 이러한 일반 명령들과 불법행위법(tort law) 사이에도 (많은 중요한 차이들에도 불구하고) 일정한 유비가 존재하는데, 후자의 일차적 목적은 타인의 행위 결과로 입은 손해(harm)에 대해 개인들에게 배상을 제공하는 데 있다. 여기서도 어떤 행위 유형들이 소송상 청구 가능한 그른 행위들(actionable wrongs)을 구성하는지를 결정하는 규칙들은 사람들에게, 그들의 바람과 무관하게, 그러한 행위를 삼갈 ‘책무들(duties)’ (혹은 드물게는 ‘의무들(obligations)’)을 부과하는 것으로 말해진다. 이러한 행위 자체는 ‘책무 위반(breach of duty)’ 이라고 불리며, 배상이나 기타 법적 구제수단은 ‘제재(sanction)’ 라고 불린다.

그러나 법의 중요한 부류들 중에는 위협으로 뒷받침된 명령들과의 이러한 유비가 전혀 성립하지 않는 것들이 존재하는데, 그것들은 전혀 다른 사회적 기능을 수행하기 때문이다. 유효한 계약이나 유언, 혼인이 이루어지는 방식들을 규정하는 법규칙들은, 사람들이 그것을 원하든 원하지 않든 간에 특정한 방식으로 행위할 것을 요구하지 않는다. 이러한 법들은 책무들이나 의무들을 부과하지 않는다. 대신 개인들이 특정 절차에 따라 그리고 일정한 (p. 28) 조건 아래에서 법의 강제적 틀 안에 권리들과 책무들의 구조를 창출할 수 있는 법적 권한들 (legal powers)을 그들에게 부여함으로써, 그들의 바람들을 실현할 수 있는 편의 수단들(facilities)을 제공한다.

계약, 유언, 혼인 등을 통해 개인이 타인과의 법적 관계를 빚어낼 수 있도록 이렇게 개인들에게 부여되는 권한은 법이 사회생활에 기여한 가장 위대한 기여들 중 하나이며, 모든 법을 위협으로 뒷받침된 명령들의 문제로 표상함으로써 가려져 온 법의 한 특징이다. 이러한 권한을 부여하는 법들과 형사 제정법 사이의 근본적 기능 차이는 우리가 이 부류의 법들에 대해 일상적으로 말하는 많은 방식들에도 반영되어 있다. 우리는 유언장을 작성할 때 1837년 유언법 제9조(s. 9 of the Wills Act, 1837)의 증인 수에 관한 규정을 ‘준수할(comply)’ 수도 있고 하지 않을 수도 있다. 준수하지 않을 경우, 우리가 작성한 문서는 권리들과 책무들을 창출하는 ‘유효한(valid)’ 유언이 아니라 법적 ‘효력(force)’이나 ‘효과(effect)’를 갖지 않는 ‘무효(nullity)’가 된다. 그러나 그것이 무효라고 하더라도, 우리가 제정법 규정(statutory provision)을 준수하지 못한 것은 어떤 의무나 책무의 ‘위반(breach)’이나 ‘침해(violation)’도 아니며, 또한 ‘위반행위(offence)’도 아니고, 이를 그런 용어들로 생각하는 것은 혼란을 초래할 수 있다.

사적 개인에게 법적 권한들을 부여하는 여러 법규칙들을 들여다보면, 그것들 자체도 서로 구별 가능한 종류들로 나뉜다는 것을 알 수 있다. 예컨대, 유언장을 작성하거나 계약을 체결할 권한 배후에는, 그 권한을 행사하는 자들이 보유해야 하는 (예컨대 성년일 것, 정신적으로 온전할 것 등과 같은) 행위능력(capacity) 또는 최소한의 개인적 자격요건(qualification)에 관한 규칙들이 있다. 다른 규칙들은 그 권한이 행사되어야 하는 방식과 형식을 상세히 규정하고, 유언이나 계약이 구두로 이루어질 수 있는지 또는 서면으로 이루어져야 하는지, 서면이

라면 그 작성(execution)과 증인인증(attestation)의 형식은 어떠해야 하는지를 확정한다. 또 다른 규칙들은 개인들이 그러한 법-내-행위들(acts-in-the-law)에 의해 창출할 수 있는 권리들과 책무들의 구조가 가지는 다양상(variety), 또는 그 최대·최소 지속기간을 한정한다. 이러한 규칙들의 예로는 계약과 관련한 공서양속 규칙들이나, 유언·재산처분(settlements)에서의 축적금지 규칙들이 있다.

이후 우리는 “당신이 이것을 하고자 한다면, 이렇게 하라”고 말하며 편의 수단들 또는 권한들을 제공하는 법들을, “당신이 원하든 원하지 않든, 이렇게 하라”고 말하는, 위협으로 뒷받침된 명령들과 같은 형사법들과 동화시키려는 법리학자들의 시도들을 살펴볼 것이다. 하지만 여기에서는, 방금 논의한 권한들은 사적 성격을 갖는 데 반해, 공적(public) 또는 공무담당적(official) 성격의 법적 권한들을 부여하는 또 하나의 법 부류를 살펴보겠다. (p. 29) 그 예들은 정부가 관행적으로, 비록 모호하게나마, 사법·입법·행정으로 나누어지는 세 부문 모두에서 발견된다.

우선, 법원의 작동 배후에 놓인 법들을 고려해 보자. 법원의 경우 어떤 규칙들은 판사의 관할권의 사항적 범위와 내용(subject-matter and content)을 특정하거나, 우리가 말하듯이, 그에게 특정 유형의 사건들을 ‘재판할 권한(power to try)’을 부여한다. 다른 규칙들은 사법 직위의 임명 방식, 자격요건, 임기를 특정한다. 또 다른 규칙들은 올바른 사법적 행태(correct judicial behaviour)에 관한 준칙들을 세우고 법정에서 따라야 할 절차를 정한다. 일종의 사법 법전(judicial code)을 형성하는 이러한 규칙들의 예는 1959년 카운티 법원법(County Courts Act, 1959), 1907년 형사항소법(Court of Criminal Appeal Act, 1907), 또는 미국 연방법전 제28편(Title 28 of the United States Code)에서 찾을 수 있다. 이러한 제정법들(statutes)에서 법원의 구성과 정상적 작동을 위해 마련된 규정들(provisions)의 다양상을 관찰하는 것은 유익하다. 겉보기에는 이들 중 극히 일부만이 판사에게 어떤 행위를 하거나 하지 말라고 내려진 명령처럼 보인다. 물론 법이 특별한 규칙들을 통해, 판사가 관할권을 초과하거나 재정적 이해관계가 있는 사건을 심리하는 것을 제재적-불이익(penalty) 아래 금지할 수도 있음은 당연하지만, 그러한 법적 책무들을 부과하는 이 규칙들은 판사에게

사법적 권한들을 부여하고 그의 관할권을 규정하는 규칙들에 부가되는 것일 뿐이다. 그러한 권한들을 부여하는 규칙들의 관심사는 판사로 하여금 부적절한 행위를 하지 못하도록 억지하는 데 있는 것이 아니라, 법원의 결정들이 유효하게 되는 조건들과 한계들을 규정하는 데 있다.

이어서, 법원의 관할권 범위를 특정하는 전형적인 규정 하나를 간략히 살펴보는 것이 유익할 것이다. 가장 단순한 예로, 개정된 1959년 카운티 법원법에 따라 토지 반환 소송에 대한 관할권이 카운티 법원에 부여된 조항을 들 수 있다. 이 조항의 언어는 ‘명령’의 언어와는 매우 동떨어져 있으며 다음과 같다:

카운티 법원은, 문제된 토지의 연간 순과세가액이 100파운드를 초과하지 않을 경우, 해당 토지 반환 소송을 심리하고 판결할 수 있는 관할권을 갖는다.¹

만약 카운티 법원 판사(county court judge)가 연간 가치가 £100을 초과하는 토지의 회복을 구하는 사건을 심리함으로써 (p. 30) 자신의 관할권(jurisdiction)을 넘어서는 경우, 그리고 그러한 토지에 관하여 명령을 내린다 하더라도, 그 판사나 소송 당사자 어느 쪽도 위반행위(offence)를 저지르는 것은 아니다. 그러나 그 상황은, 어떤 사인(private person)이 어떤 법적 권한(legal power)의 유효한 행사를 위해 필수적인 조건을 준수하지 못하여 ‘무효(nullity)’인 무엇인가를 하는 경우와 완전히 같지는 않다. 예컨대 유언을 하려는 자(would-be testator)가 유언장에 서명하지 않거나 두 명의 증인을 확보하지 않는다면, 그가 작성한 것은 어떠한 법적 지위나 효과(effect)도 갖지 않는다. 그러나 법원의 명령은, 그것이 명백히 그 법원이 내릴 관할권 밖의 명령인 경우에도, 이와 같은 방식으로 취급되지는 않는다. 법원이 법적으로 내려서는 안 되었던 명령이라 하더라도 상급법원(superior court)이 그 유효하지 않음(invalidity)을 확인할 때까지는 법원의 결정이 법적 권위(legal authority)를 갖는 것이 공공질서(public order)의 이익상 명백히 필요하다. 따라서 관할권 초과로 내려진 명령으로서 항소심에서 취소되기(set aside) 전까지는, 그 명령은 당사자 사이에서 법적으로 효력 있는(effective) 명령으로 존속하며 집행된다. 다만 그것은 하나의 법적

¹Section 48 (1).

결함(legal defect)을 가진다. 즉 관할권 결여 때문에 항소심에서 취소되거나(set aside) ‘파기(quashed)’ 될 수 있다(is liable). 여기서, 영국에서 통상 하급법원의 명령에 대해 상급법원이 내리는 ‘번복(reversal)’ 과, 관할권 결여를 이유로 한 명령의 ‘파기(quashing)’ 사이에는 중요한 차이가 있음을 주목해야 한다. 명령이 번복되는(reversed) 경우, 이는 하급법원이 해당 사건에 적용된 법이나 사실에 관하여 말한 것이 그르다고(wrong) 여겨지기 때문이다. 그러나 관할권 결여로 파기되는(quashed) 하급법원의 명령은 이 두 측면 모두에서 흠잡을 데가 없을 수도 있다. 문제는 하급법원 판사가 말하거나 명령한 내용(what)이 그른 것이 아니라, 그것을 그가(his) 말하거나 명령했다는 것 자체에 있다. 그는 다른 법원들은 그러한 권한을 부여받았을 수 있더라도 자신에게는 법적으로 권한이 부여되지 않은 일을 한다고 표방한(purported to do) 것이다. 공공질서의 이익 때문에 관할권을 초과하여 내려진 결정이라도 상급법원에 의해 파기되기 전까지는 존속한다는(stand) 복잡한 사정을 제외하면, 관할권 규칙에 부합하거나 부합하지 못하는 것(conformity and failure to conform to rules of jurisdiction)은 사인이 법적 권한을 유효하게 행사하기 위한 조건을 규정하는 규칙에 부합하거나 부합하지 못하는 것과 같다. 이러한 경우에서 규칙에 부합하는 행위(conforming action)와 규칙 사이의 관계는, 규칙들이 명령(orders)과 유비적인 형사법의 경우에 더 적절한 ‘복종하다(obey)’ 나 ‘불복종하다(disobey)’ 라는 말들로 제대로 전달되지 않는다.

제정법(statute)이 종속된 입법기관에게 입법 권한을 부여하는 경우 역시, 일반 명령에, (p. 31) 왜곡이라는 대가를 치르지 않고는, 동화될 수 없는 법규칙의 한 유형을 예시한다. 이 경우에도 사적 권한의 행사에서처럼, 입법 권한들을 부여하는 규칙들이 정한 조건들에 부합하는 것은 체스와 같은 게임에서의 ‘수(move)’ 와 같은 단계에 해당한다. 그것은 체계가 개인들이 달성할 수 있도록 해주는, 규칙들의 관점에서 규정 가능한 귀결들을 가진다. 입법은 법적 권한들의 행사이며, 법적 권리와 책무들을 창출하는 데 ‘작용적(operative)’ 이거나 효력 있는(effective) 것이다. 수권 규칙(enabling rule)의 조건들에 부합하지 못할 경우, 행해진 것은 효력이 없게 되고(ineffective), 그래서 이 목적에서는 무효(nullity)가 된다.

입법 권한들의 행사 배후에 놓인 규칙들은 법원의 관할권(jurisdiction) 배후에 놓인 규칙들보다도 훨씬 더 다양하다. 이는 그러한 규칙들이 입법의 여러 상이한 측면들을 위해 마련되어야 하기 때문이다. 따라서 어떤 규칙들은 입법 권한이 행사될 수 있는 사항적 범위(subject-matter)를 특정하고, 다른 규칙들은 입법기관 구성원의 자격요건들이나 동일성(qualifications or identity)을, 또 다른 규칙들은 입법의 방식과 형식(manner and form), 그리고 입법기관이 따라야 할 절차(procedure)를 특정한다. 이는 관련 사항들 가운데 일부에 불과하다. 예컨대 하급 입법기관이나 규칙제정기관(rule-making body)의 권한들을 부여하고 규정하는 1882년 「지방자치법(Municipal Corporations Act)」와 같은 제정물(enactment)을 잠시 살펴보는 것만으로도 훨씬 더 많은 규칙들이 드러난다. 이러한 규칙들에 부합하지 못한 결과는 항상 동일하지 않을 수 있지만, 적어도 어떤 규칙들에 대해서는 그 규칙에 부합하지 못하는 것이 입법 권한의 행사로 표방된 것(purported exercise of legislative power)을 무효(nullity)로 만들거나, 하급 법원의 결정과 마찬가지로 유효하지 않다고 선언될 수 있는 상태(liable to be declared invalid)에 이르게 한다. 때로는 요구된 절차가 준수되었음을 증명하는 증명서(certificate)가 내부 절차(internal procedure)에 관한 사항에 대해서는 법에 의해 확정적인(conclusive) 것으로 만들어지기도 하고, 때로는 규칙상 자격을 갖추지 못한 자가 입법 절차에 참여한 경우, 이를 위반행위(offence)로 만드는 특별한 형사 규칙(criminal rules)에 따라 제재적-불이익을 받을 수 있다(may be liable to a penalty). 그러나 이러한 복잡성들에 의해 부분적으로 가려져 있기는 하지만, 입법 권한들을 부여하고 그 행사 방식(manner of exercise)을 규정하는 규칙들과, 적어도 위협으로 뒷받침된 명령들(orders backed by threats)과 닮아 있는 형사법 규칙들 사이에는 근본적인(radical) 차이가 존재한다.

일부 경우에는 이 두 넓은 유형의 규칙을 동화시키는 것이 기괴한 일일 수 있다. 입법기관 앞에 놓인 어떤 법안(a measure)이 요구되는 다수의 투표를 얻었고 그에 따라 적법하게 통과되었다면, 그 법안에 찬성한 투표자들이 다수결 결정을 요구하는 법에 ‘복종한(obeyed)’ 것이 아니고, (p. 32) 반대한 이들 역시 그것에 복종했거나 ‘불복종한(disobeyed)’ 것이 아니다. 그 법안이 필요한 다수에 도달하지 못하여 법이 통과되지 못했다면, 이 역시 물론 마찬가지이다.

이러한 규칙들과 같은 규칙들의 기능에 있어서의 근본적인 차이가, 형사법 규칙과의 관계 속에 있는 행위에 적절한 용어법을 이곳에 사용하는 것을 막는다.

모두가 단일한 단순 유형으로 반드시(must) 환원되어야 한다는 편견으로부터 자유로운, 현대 법체계에 포함된 법들의 다양상(varieties)을 포괄하는 완전하고 상세한 분류학(taxonomy)은 아직도 완성되어야 할 과제로 남아 있다. 권한을 부여하는 법들(laws that confer powers)을, 책무를 부과하고 위협으로 뒷받침된 명령들(orders backed by threats)과 유비적인 법들로부터, 매우 거친 표제 아래 구분함으로써 우리는 겨우 출발점에 섰을 뿐이다. 그러나 이러한 정도의 논의만으로도, 법체계의 고유한 특징들 가운데 일부가 바로 이러한 유형의 규칙들에 의해 사적·공적 법적 권한들의 행사를 가능하게 하는 마련(provision)에 놓여 있음을 보여주기에 충분하다고 할 수 있다. 이러한 독특한 종류의 규칙들이 존재하지 않는다면, 우리는 사회생활에서 가장 친숙한 개념들 가운데 일부를 결여하게 될 것인데, 이는 그러한 개념들이 논리적으로 이러한 규칙들의 존재를 전제하기 때문이다. 위협으로 뒷받침된 명령들과 닮아 있는 명령적(mandatory) 종류의 형사법들이 존재하지 않는다면 범죄들(crimes)이나 위반행위들(offences), 따라서 살인이나 절도도 존재할 수 없듯이, 권한 부여 규칙들(power-conferring rules)이 존재하지 않는다면 매수(buying), 매도(selling), 증여(gifts), 유언(wills), 혼인(marriages)도 존재할 수 없다. 왜냐하면 이러한 후자의 것들은 법원의 명령들(orders of courts)이나 입법기관의 제정물들(enactments of law-making bodies)과 마찬가지로, 모두 법적 권한들의 유효한 행사(valid exercise of legal powers)로서 성립하는 것이기 때문이다.

그럼에도 불구하고 법리학에서의 통일성(uniformity)에 대한 갈망은 강력하다. 그리고 그것이 결코 불명예스러운 것이 아니므로, 위대한 법리학자들이 제시해 온, 그것을 지지하는 두 가지 대안적 논증을 검토할 필요가 있다. 이 논증들은 우리가 강조해 온 법들의 다양상들(varieties of law) 사이의 구별이 피상적이거나, 심지어 실재하지 않는 것에 불과하며, ‘궁극적으로(ultimately)’ 위협으로 뒷받침된 명령들(orders backed by threats)이라는 관념(notion)이 형사법 규칙들뿐만 아니라 권한부여 규칙들(rules conferring powers)의 분석에도 충분하다는 점을 보이기 위해 고안된 것이다. 법리학에서 오랫동안 지속되어

은 대부분의 이론들과 마찬가지로, 이 논증들에도 진리의 요소는 존재한다. 우리가 구별한 두 종류의 법규칙들 사이에는 분명한 유사점들이 있다. 양 경우 모두에서 행위들은 그 규칙들을 참조하여(by reference to the rules) 법적으로 ‘옳은(right)’ 일인지 ‘그른(wrong)’ 일인지로 비판되거나 (p. 33) 평가될 수 있다. 유언의 작성을 규율하는 권한부여 규칙들(power-conferring rules)과, 제재적-불이익(penalty)을 수반하여 폭행을 금지하는 형사법 규칙은 모두 이러한 방식으로 개별 행위들을 비판적으로 평가할 수 있게 하는 기준들(standards)을 구성한다. 이 정도는 아마 이들 모두를 규칙이라고 말하는 데 이미 함축되어 있을 것이다. 더 나아가 권한부여 규칙들은, 책무(duty)를 부과하며 그래서 위협으로 뒷받침된 명령들과 일정한 유비를 갖는 규칙들과 다르기는 하지만, 언제나 그러한 규칙들과 연관되어 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다. 왜냐하면 권한부여 규칙들이 부여하는 권한들(powers)이란, 바로 후자와 같은 유형의 일반적 규칙들을 제정하거나, 그러한 권한들이 없었다면 그러한 책무들을 부담하지 않았을 특정 개인들에게 책무들을 부과할 수 있는 권한들이기 때문이다. 이는 부여된 권한이 통상적으로 입법할 권한(power to legislate)이라 불리는 경우에 가장 명백히 드러난다. 그러나 우리가 보게 되겠지만, 다른 법적 권한들의 경우에도 마찬가지로 그러하다. 다소의 부정확성을 감수한다면, 형사법과 같은 규칙들이 책무들을 부과하는 반면, 권한부여 규칙들은 책무들을 창출하기 위한 처방들(recipes)이라고 말할 수도 있을 것이다.

제재로서의 무효(Nullity as a sanction)

첫 번째 논변은, 두 종류의 규칙의 근본적 동일성을 보이고 둘 모두를 강제적 명령들(coercive orders)로 제시하려는 시도로, 권한 행사에 필수적인 어떤 조건이 충족되지 않을 때 뒤따르는 ‘무효(nullity)’에 초점을 맞춘다. 이 논변에 따르면, 무효란 형사법에 부착된 처벌처럼, 규칙 위반에 대해 법에 의해 부과되는 위협된 해악(threatened evil) 또는 제재(sanction)와 마찬가지로 하는 것이다. 물론 어떤 경우에는 그러한 제재가 단지 약간의 불편에 이를 뿐일 수도 있다는 점은 인정된다. 이러한 시각에서 우리는 다음과 같은 사례를 바라보도록 요청받는다. 즉

어떤 사람이 자신에게 한 약속을 계약상 구속력 있는 것으로 법에 의해 강제하려 하지만, 그 약속이 날인증서 방식(*under seal*)으로 이루어진 것이 아니고 자신이 그 약속에 대해 약인(*consideration*)을 제공하지 않았기 때문에, 그 서면 약속이 법적으로 무효(*nullity*)라는 사실을 유감스럽게도 알게 되는 경우이다. 이와 유사하게, 두 명의 증인이 없는 유언장은 효력을 발하지 않는다(*inoperative*)고 정하는 규칙은, 유언자들(*testators*)로 하여금 유언법 제9조를 준수하도록 움직이는 것으로, 우리가 수감(*imprisonment*)을 생각하여 형사법에 복종하도록 움직이는 것과 마찬가지로 생각하라고 요구받는다.

어떤 경우들에서는 무효(*nullity*)와, 거래가 유효할 것이라는 기대가 좌절되는 데서 비롯되는 실망(*disappointment*)과 같은 심리적 요인들 사이에 그러한 연관성이 존재한다는 점을 누구도 부인할 수는 없다. 그럼에도 불구하고 제재(*sanction*)의 관념(*idea*)을 무효까지 포함하도록 확장하는 것은 (p. 34) 혼란의 원천이자(그리고 그 징후(*sign*)이기도 한) 것이다. 이에 대한 몇 가지 사소한 반론들은 이미 잘 알려져 있다. 예컨대 많은 경우, 무효는 법적 유효성(*legal validity*)에 요구되는 어떤 조건을 충족시키지 못한 사람에게 ‘해악(*evil*)’ 이 아닐 수도 있다. 판사는 자신의 명령의 유효성에 대해 물질적 이해관계를 가지지 않을 수도 있고, 그 유효성 여부에 무관심할 수도 있다. 또한 어떤 당사자가, 자신이 미성년자였거나 특정 계약에 요구되는 서면 각서(*memorandum in writing*)에 서명하지 않았다는 이유로 자신을 상대로 제기된 계약이 자신을 구속하지 않는다는 사실을 알게 되더라도, 그가 여기서 ‘위협된 해악(*threatened evil*)’ 이나 ‘제재(*sanction*)’ 를 인식하지 않을 수도 있다. 그러나 이러한 사소한 점들—약간의 기교를 발휘하면 얼마든지 수용될 수 있는 점들—을 떠나서도, 무효는 더 중대한 이유들 때문에, 규칙이 금지하는 활동들을 삼가도록 하는 유인으로서 규칙에 부가된 처벌(*punishment*)에 동화될 수 없다. 형사법 규칙의 경우에는 두 가지를 식별하고 구분할 수 있다. 규칙이 금지하는 일정한 유형의 행위와, 그 행위를 억제하기 위해 의도된 제재이다. 그러나 계약의 형식(*form*)에 관한 법적 요건을 충족하지 못하는 약속을 사람들이 서로에게 하는 것과 같은, 사회적으로 바람직한 활동을 어떻게 이러한 관점에서 이해할 수 있겠는가? 이는 형사법이 억제하려는 행위와 같은 것이 아니며, 계약의 법적 형식들을 규정하는 법규칙

들이 억누르도록 설계된 무엇도 아니다. 그 규칙들은 단지 그러한 행위들에 대해 법적 인정(legal recognition)을 부여하지 않을 뿐이다. 더 나아가, 어떤 입법 조치가 요구되는 다수결을 얻지 못하여 법으로서의 지위(status of a law)를 획득하지 못하는 사실을 제재로 간주하는 것은 더욱 터무니없다. 이를 형사법의 제재에 동화시키는 것은, 경기의 득점 규칙을 골(goal)이나 득점(run)을 제외한 모든 움직임을 제거하기 위해 설계된 것으로 생각하는 것과 같다. 만약 그것이 성공한다면, 모든 경기는 끝장날 것이다. 그럼에도 불구하고 권한부여 규칙들(power-conferring rules)을 사람들이 일정한 방식으로 행동하도록 만들기 위해 설계된 것이며, 복종의 동기로서 ‘무효(nullity)’를 추가하는 것으로 이해할 때에만, 그러한 규칙들을 위협으로 뒷받침된 명령들에 동화시킬 수 있게 되는 것이다.

무효를 형사법상의 위협된 해악이나 제재와 유사한 것으로 생각하는 데 내재한 혼란은 또 다른 방식으로도 드러날 수 있다. 형사법 규칙의 경우에는, 비록 어떠한 처벌이나 다른 해악도 위협되지 않는다 하더라도 그러한 규칙들이 존재하는 것이 논리적으로 가능하며, 경우에 따라서는 바람직할 수도 있다. 물론 그런 경우 그것들이 법적(legal) 규칙이 아닐 것이라고 주장할 수도 있다. 그럼에도 불구하고 우리는 (p. 35) 특정한 행위를 금지하는 규칙과, 그 규칙이 위반될 경우 부과될 제재적-불이익들(penalties)에 관한 규정을 명확히 구분할 수 있으며, 후자가 없이 전자만이 존재한다고 가정할 수도 있다. 어떤 의미에서 우리는 제재를 제외하면서도(subtract), 그 규칙이 유지하려고 설계된 이해 가능한 행위 기준(standard of behaviour)을 여전히 남겨 둘 수 있다. 그러나 유효한 유언(valid will)을 위한 증인인증(attestation)과 같이 일정한 조건을 준수할 것을 요구하는 규칙과, 이른바 ‘무효’라는 제재 사이에서는 이러한 구분을 논리적으로 행할 수 없다. 이 경우 필수적 조건을 준수하지 않았음에도 무효가 발생하지 않는다면, 그 규칙 자체는 비법적(non-legal) 규칙으로서조차 제재 없이 존재한다고 이해가능하게 말해질 수 없다. 무효에 관한 규정은 이러한 유형의 규칙 그 자체의 일부(part)이며, 이는 책무들을 부과하는 규칙에 부착된 처벌(punishment)과는 전혀 다른 방식이다. 만약 공을 골대 사이로 넣지 못한 것이 득점하지 못함(not scoring)이라는 ‘무효(nullity)’를 의미하지 않는다면,

득점 규칙(scoring rules)이 존재한다고 말할 수 없을 것이다.

우리가 여기서 비판해 온 논변은, 제재 또는 위협된 해악의 의미를 확장하여(widening), 그러한 규칙들을 준수하지 못함(non-compliance)으로 인해 흠이 생긴(vitiated) 법적 거래의 무효까지 포함시킴으로써, 권한부여 규칙들(power-conferring rules)과 강제적 명령들(coercive orders)의 근본적 동일성을 보이려는 시도이다. 반면, 다음에서 살펴볼 두 번째 논변은 전혀 다른, 기실 정반대의 노선을 취한다. 이 논변은 이러한 규칙들이 강제적 명령들의 한 종이라는 점을 보여주려 하기보다는, 아예 그것들에게서 ‘법(law)’의 지위를 부인한다. 그것들을 배제하기 위해 단어 ‘법’의 의미를 좁히는 것이다(narrows). 이 논변은 서로 다른 법리학자들에게서 더 극단적이거나 덜 극단적인 형태로 나타난다. 그 일반적 형식은, 느슨하게 또는 일상적 표현 방식에서 완전한 법규칙들(complete rules of law)이라고 지칭되는 것들이, 실제로는 유일하게 ‘진정한(genuine)’ 법규칙들인 강제적 규칙들(coercive rules)의 불완전한 파편들에 지나지 않는다고 주장하는 것이다.

법들의 파편들로서의 권한부여 규칙들(Power-conferring rules as fragments of laws)

이 논증의 극단적인 형태에서는 형사법의 규칙들조차, 그것들이 흔히 진술되는 문구로 보았을 때, 진정한 법들(genuine laws)이 아니라고 부정하게 된다. 이와 같은 형태로 이 논증을 채택한 인물이 켈젠(Kelsen)이다. 그는 다음과 같이 말한다. “법은 제재(sanction)를 규정하는 일차 규범(primary norm)이다.”² 살인을 금지하는 법은 존재하지 않는다. 오직 (p. 36) 살인을 저지른 자에게 특정한 상황에서 특정한 제재들을 적용하도록 공무담당자들(officials)에게 지시하는 법만이 있을 뿐이다. 이 관점에서, 일반 시민의 행위를 향도하기 위해 설계된 것으로 통상 생각되는 법의 내용은, 실제로는 그들에게가 아니라 공무담당자들에게 향하여 있는 규칙의 전건 또는 “if-절”에 불과하며, 그 규칙은 특정 조건들이 충족되면 특정 제재들을 적용하라고 공무담당자들에게 명령한다. 이

²General Theory of Law and State, p. 63. 위 2쪽 참조.

관점에 따르면, 모든 진정한 법들은 공무담당자들에게 제재들을 적용하라는 조건적 명령들이다. 그것들은 모두 다음과 같은 형식을 갖는다. “X 종류의 어떤 것이 행해지거나(done) 부작위되거나(omitted) 발생한 경우(happens), 그러면 Y 종류의 제재를 적용하라.”

전건(antecedent) 또는 if-절들을 점점 더 정교하게 확장함으로써, 사적 또는 공적 권한들을 부여하고 그 행사 방식을 규정하는 규칙들을 포함하여 모든 유형의 법규칙들은 이 조건적 형식(conditional form)으로 다시 진술될 수 있다. 따라서 두 명의 증인을 요구하는 유언법의 규정들은, 유언의 규정들을 위반하여 유증금 지급을 거부한 유언집행자(executor)에게 제재들(sanctions)을 적용하도록 법원들에 내리는 서로 다른 많은 지시들(directions)에 공통적으로 포함되는 부분으로 나타난다. 즉 “이러한 규정들을 포함하고 적법하게 증인된 유언이 있는 경우 그리고 오직 그 경우에만(if and only if), 그리고 만약 ... 라면(if ... then), 그에게 제재들이 적용되어야 한다”는 형식이다. 이와 유사하게, 법원의 관할권(jurisdiction)의 범위를 특정하는 규칙 역시, 법원이 어떠한 제재들을 적용하기에 앞서 충족되어야 하는 조건들의 공통 부분으로 나타난다. 마찬가지로, 입법 권한들을 부여하고 입법의 방식과 형식을 규정하는 규칙들(최고 입법부에 관한 헌법의 규정들을 포함하여) 또한, 그 조건들이 다른 조건들과 함께 충족되면 법원이 제정법들(statutes)에 언급된 제재들을 적용하게 되는 일정한 공통 조건들을 특정하는 것으로 재진술되고 제시될 수 있다. 따라서 이 이론은 우리에게 실질(substance)을 그것을 가리는 형식들(obscuring forms)로부터 풀어내라고 요구한다. 그러면 우리는 ‘영국 의회 내의 여왕(Queen in Parliament)이 제정하는 것은 법이다’와 같은 헌법적 형식이나, 의회(Congress)의 입법 권한에 관한 미국 헌법의 규정들이, 법원이 제재들을 적용해야 하는 일반적 조건들을 단지 특정할 뿐임을 알게 될 것이다. 이러한 형식들은 본질적으로 완결된 규칙들이 아니라 ‘if-절들(if-clauses)’이다. 즉 만약(If) 영국 의회 내의 여왕이 그렇게 제정하였다면 ...’ 또는 ‘만약(if) 헌법에 특정된 한계들(limits) 내에서 의회(Congress)가 그렇게 제정하였다면 ...’이라는 형식은, 법원이 제재를 적용하거나 특정 유형의 행위를 처벌하도록 하는 방대한 수의 지시들에 공통적으로 포함되는 조건들의 형식인 것이다.

(p. 37) 이는 법을 가리는 통상적 형식들과 표현들의 다양상 배후에 잠재한 법의 참되고 통일적인 성격을 드러낸다고 표방하는, 강력하면서도 흥미로운 이론이다. 그 결함을 검토하기에 앞서, 이러한 극단적 형태에서 이 이론은, 법을 명령들이 불복종될 때 부과될 제재들의 위협으로 뒷받침된 명령들로 이루어진 것으로 파악하던 원래의 법 구상(conception)으로부터의 전환을 포함한다는 점을 주목해야 한다. 대신 이제 중심 구상은, 제재들을 적용하도록 공무원담당자들에게 내리는 명령들(orders to officials to apply sanctions)이라는 것이다. 이 관점에 따르면, 모든 법의 위반(breach)에 대해 제재가 규정되어 있을 필요는 없으며, 오직 모든 ‘진정한(genuine)’ 법이 어떤 제재의 적용을 지시하기만 하면 된다. 따라서 그러한 지시들을 무시하는 공무원담당자가 처벌되지 않을 수도 있으며, 실제로 많은 법체계에서 그러한 경우는 흔히 존재한다.

이러한 일반 이론은, 앞서 말했듯이, 하나가 다른 하나보다 덜 극단적인 두 형태 가운데 하나를 취할 수 있다. 덜 극단적인 형태에서는, 법을 일반 시민들(ordinary citizens)을 비롯한 이들에게 향한 위협으로 뒷받침된 명령들로 파악하는 원래의 법 구상(conception)(많은 이들이 직관적으로 더 받아들이기 쉬워하는 구상)이, 적어도 상식적 관점에서 공무원담당자들(officials)에게만이 아니라 일반 시민들의 행위를 주된 대상으로 삼는 규칙들에 대해서는 유지된다. 이 보다 온건한 관점에 따르면, 형사법의 규칙들은 그 모습 그대로 법들이며, 다른 완전한 규칙들의 파편들(fragments)로 재구성될 필요가 없다. 왜냐하면 그것들은 이미 위협으로 뒷받침된 명령들이기 때문이다. 그러나 다른 경우들에서는 재구성이 필요하다. 사적 개인들에게 법적 권한들을 부여하는 규칙들은, 이 온건한 이론에서도, 더 극단적인 이론에서와 마찬가지로, 실제의 완전한 법들, 즉 위협으로 뒷받침된 명령들의 단순한 파편들에 불과하다. 이 실제의 완전한 법들은 다음과 같은 질문을 통해 발견되어야 한다. 법은 누구에게, 그들이 준수하지 않을 경우 제재적-불이익(penalty)을 받게 하면서, 어떤 행위를 하라고 명령하는가? 이 점이 밝혀지면, 1837년 유언법(Wills Act, 1837)의 증인에 관한 규정들과, 개인들에게 권한들을 부여하고 그 유효한 행사 조건들을 규정하는 다른 규칙들은, 궁극적으로 그러한 법적 책무(legal duty)가 발생하는 조건들 가운데 일부를 특정하는 것으로 재구성될 수 있다. 그러한 규칙들은 그 결과,

위협으로 뒷받침된 조건부 명령들(conditional orders backed by threats) 또는 책무를 부과하는 규칙들(rules imposing duties)의 전건(antecedent) 혹은 ‘if-절(if-clause)’의 일부로 나타나게 된다. “유언이 유언자(testator)에 의해 서명되고 특정된 방식에 따라 두 명의 증인에 의해 증명된 경우 그리고 오직 그 경우에만(if and only if) (p. 38) 그리고 만약 … 라면(if … then) 그 집행자(executor)(또는 기타 법적 대리인)는 유언의 규정들에 효력을 부여하여야 한다.” 계약 성립(formation of contract)에 관한 규칙들 또한 마찬가지로, 일정한 것들이 사실이거나 일정한 말이나 행위가 있었을 경우(당사자가 성년이고, 날인증서 방식으로 약정하였거나(covenanted under seal) 약인(consideration)을 약속받았을 경우), 계약에 따라 행해져야 할 일들을 하라고 사람들에게 명령하는 규칙들의 단순한 파편들로 나타나게 된다.

(최고 입법부에 관한 헌법의 규정들을 포함하여) 입법 권한들을 부여하는 규칙들을 ‘진정한(real)’ 규칙들의 파편들로 표상하기 위한 재구성은, 이 이론의 보다 극단적인 버전에 관해 앞의 36쪽에서 설명된 것과 유사한 노선을 따라 수행될 수 있다. 유일한 차이는, 보다 온건한 관점에서는 권한부여 규칙들이 제재들의 위협 아래에서 일반 시민에게 어떤 행위를 하라고 명령하는 규칙들의 전건들(antecedents) 또는 if-절들(if-clauses)로서 재현된다는 점이다. 그것들은 (보다 극단적인 이론에서처럼) 공무원담당자들에게 제재들을 적용하라고 지시하는 지시들(directions)의 if-절들로만 재현되지는 않는다.

이 이론의 두 가지 버전은 모두, 겉보기에는 서로 구별되는 법규칙의 다양상들(varieties)을 법의 정수(quintessence)를 전달한다고 주장되는 하나의 단일한 형식으로 환원하려고 시도한다. 두 버전 모두 서로 다른 방식으로 제재를 중심으로 중요한 요소로 만들며, 제재 없는 법이 완전히 생각 가능하다(conceivable)는 것이 입증된다면 둘 다 실패하게 될 것이다. 다만 이러한 일반적 반론은 뒤로 미루어야 한다. 여기서 우리가 전개할 양 형태에 대한 구체적 비판은, 이 이론들이 모든 법들을 환원시키는 만족스러운 패턴의 통일성(pleasing uniformity of pattern)을 지나치게 큰 대가를 치르고 얻는다는 점이다. 그 대가란 서로 다른 유형의 법규칙들이 수행하는 상이한 사회적 기능들을 왜곡한다는 것이다. 이는 이 이론의 두 형태 모두에 해당하지만, 보다 극단적인 형태의 이론이 요구하는

형사법의 재구성에서 가장 분명하게 드러난다.

통일성의 대가로서의 왜곡

이러한 재구성이 초래하는 왜곡은 법의 여러 서로 다른 측면들을 조명해 주기 때문에 숙고할 가치가 있다. 사회가 통제될 수 있는 기법들은 여러 가지가 있지만, 형사법의 특징적인 기법은 규칙들을 통해 특정한 행위 유형들을 사회 구성원 전체 또는 그 안의 특수한 부류들을 위한 향도의 기준들(standards for the guidance)로 지목하는 데 있다. 그 구성원들은 공무담당자들의 도움이나 개입 없이 (p. 39) 규칙들을 이해하고, 그 규칙들이 자신들에게 적용된다는 점을 알아보며(see), 그 규칙들에 부합할(conform to) 것이 기대된다. 법이 어겨지고 이러한 법의 일차적 기능(primary function)이 실패할 때에만 비로소 공무담당자들은 위반 사실을 확인하고 위협된 제재들(threatened sanctions)을 부과하는 데 관여한다. 교통근무 중인 경찰관과 같이 공무담당자가 운전자에게 내릴 수 있는 개별화된 대면 명령들(individuated face-to-face orders)과 비교할 때, 이러한 기법의 독특성은 사회 구성원들이 스스로 규칙들을 발견하고 자신의 행위를 그 규칙들에 부합시키도록 맡겨진다는 점에 있다. 이러한 의미에서 그들은 규칙에 부가된 제재가 규칙 부합(conformity)을 위한 동기를 제공하기는 하지만, 규칙들을 스스로 자신에게 ‘적용한다(apply)’ 고 말할 수 있다. 따라서 불복종의 경우 법원이 제재들을 부과하도록 요구하는 규칙들에만 집중하거나 이를 일차적인 것으로 삼는다면, 우리는 그러한 규칙들이 실제로 기능하는 고유한 방식을 은폐하게 될 것이다. 왜냐하면 후자의 규칙들은 체계의 일차적 목적(primary purpose)이 붕괴되거나 실패하는 경우에 대한 마련을 하기 때문이다. 그것들은 기실 필수불가결할 수는 있으나, 보조적인(ancillary) 성격을 지닌다.

형사법의 실체적 규칙들(substantive rules)이 수행하는 기능이 (그리고 넓은 의미에서 그 의미가) 단지 제재적-불이익들의 체계(system of penalties)를 운용하는 공무담당자들에 대한 향도에 그치는 것이 아니라, 비-공무적 생활(non-official life)의 활동 속에서 일반 시민을 향도하는 데 있다는 관념은, 핵심적인 구별들을 폐기하고 법이 사회적 통제 수단(means of social control)으로서

지니는 특유한 성격을 흐리게 하지 않고서는 제거될 수 없다. 범죄에 대한 처벌(punishment), 예컨대 벌금(fine)은 행위 경로(course of conduct)에 부과되는 조세(tax)와 동일하지 않다. 비록 두 경우 모두 동일한 금전적 손실(money loss)을 부과하도록 공무담당자들에게 지시한다는 점에서는 같지만, 이러한 관념들을 구별짓는 것은 전자는 후자와 달리 일반 시민의 행위를 향도하기 위해 세워진 규칙의 침해(violation)라는 형태의 위반행위(offence) 또는 책무 위반(breach of duty)을 포함한다는 점이다. 물론 이 일반적으로 명확한 구별은 특정한 상황에서는 흐려질 수 있다. 조세는 재정 수입을 목적으로 하지 않고 과세 대상이 되는 활동들을 억제하기 위해 부과될 수도 있는데, 이 경우 법은 ‘그것들을 범죄화(makes them criminal)’ 할 때와는 달리 해당 활동들이 포기되어야 한다는 명시적 표지들(indications)을 제공하지 않는다. 반대로, 어떤 형사 위반행위(criminal offence)에 대해 납부되어야 하는 벌금이 화폐 가치 하락으로 인해 매우 소액이 되면, 그것은 기꺼이 납부될 수 있고, 그 결과 아마도 ‘단순한 조세들(mere taxes)’ 로 느껴지기도 한다. 그러면 바로 이러한 상황에서는 그 규칙이, 형사법의 대부분과 마찬가지로, 행위의 기준(standard of behaviour)으로서 진지하게 받아들여져야 한다는 감각이 상실되기 때문에 ‘위반행위들(offences)’ 가 빈번하게 발생하게 된다.

(p. 40) 때때로 검토 중인 것과 같은 이론들을 옹호하는 논거로서, 법을 제재들을 적용하라는 지시(direction)의 형식으로 재구성함으로써 명료성이 증진된다고 주장된다. 이러한 형식은 이른바 ‘나쁜 사람(bad man)’ 이 법에 관하여 알고자 하는 모든 것을 분명히 드러내 준다는 것이다. 이것이 참일 수는 있으나, 그러한 점만으로는 이 이론에 대한 옹호로서 충분하다고 보이지 않는다. 왜 법은, 요구되는 바를 기꺼이 따를 의사가 있으나 그것이 무엇인지 들을 수 있거나 하면 되는 ‘혼란스러운 사람(puzzled man)’ 이나 ‘무지한 사람(ignorant man)’ 에게 동등하게, 아니 그보다 더 큰 관심을 기울여서는 안 되는가? 또는 자신의 사무를 정리하고자 하나 그것을 어떻게 해야 하는지만 들을 수 있으면 되는 ‘자신의 사무를 정리하고자 하는 사람(man who wishes to arrange his affairs)’ 에게는 왜 관심을 두지 말아야 하는가? 물론 법을 이해하려면 법원이 제재들을 적용하게 될 때 법원이 그것을 어떻게 운용하는지(administer)를 보는

것이 매우 중요하다. 그러나 이것이 우리가 이해해야 할 전부가 법정에서 일어나는 일이라고 생각하도록 이끌어서는 안 된다. 사회적 통제의 수단으로서 법의 주된 기능들은, 체계의 실패에 대비한 중요하지만 여전히 부차적인 마련들(ancillary provisions)을 나타내는 사적 소송(private litigation)이나 형사 기소(prosecutions)에서 보이는 것이 아니다. 그것들은 법정 밖에서 삶을 통제하고(control), 향도하며(guide), 계획하는(plan) 데 법이 사용되는 다양한 방식들 속에서 보인다.

이 이론의 극단적 형태가 수행하는 부차적인 것과 주된 것의 전도(inversion of ancillary and principal)는, 다음과 같은 게임 규칙의 재구성 제안에 비유될 수 있다. 크리켓이나 야구의 규칙을 고찰하는 한 이론가는, 규칙들의 용어법과 일부 규칙은 주로 선수들(players)에게, 일부는 주로 경기 담당자들(심판(umpire)과 득점 기록원(scorer))에게, 또 일부는 양자 모두에게 향하여 있다(addressed)는 관습적 주장에 의해 가려져 있던 통일성을 자신이 발견했다고 주장할지도 모른다. 이 이론가는 ‘모든 규칙은 실제로는(really) 특정한 조건 하에서 경기 담당자들에게 어떤 행위를 하도록 지시하는 규칙들이다’ 라고 주장할 수 있다. 공을 친 뒤의 특정한 움직임이 ‘득점(run)’을 구성한다는 규칙이나, 잡히면 한 선수가 ‘아웃(out)’이 된다는 규칙은, 실은 경기 담당자들에 대한 복합적 지시들(complex directions)일 뿐이라는 것이다. 전자의 경우에는 득점 기록원에게 기록부(scoring-book)에 ‘득점(a run)’을 기재하라는 지시이고, 후자의 경우에는 심판에게 해당 선수를 ‘필드 밖으로 나가라(off the field)’고 명령하라는 지시라는 것이다. 이에 대한 자연스러운 항변은, 이러한 규칙의 변형을 통해 규칙들에 부과된 통일성이 규칙들이 작동하는 방식들, 그리고 선수들이 목적지향적 활동들을 향도하는 데 규칙들을 사용하는 방식을 은폐함으로써, 게임 그 자체인 경쟁적이지만 협동적인 사회적 사업에서의 규칙들의 기능을 흐리게 만든다는 점이다.

이 이론의 덜 극단적인 형태는 형사법과 (p. 41) 그 밖의 책무를 부과하는 모든 법들을 그대로 두게 될 것이다. 왜냐하면 이러한 법들은 이미 강제적 명령들(coercive orders)이라는 단순한 모델에 부합하기(conform to) 때문이다. 그러나 이 이론은 법적 권한들을 부여하고 그 행사 방식을 규정하는 모든 규칙들을

이 단일한 형태로 환원한다. 이 점에서 그것은 이론의 극단적 형태와 동일한 비판에 열려 있다. 만약 우리가 모든 법을 오로지 그 책무들이 부과되는 사람들의 관점에서만 바라보고, 법의 다른 모든 측면을 그들에게 책무들이 귀속되는 다소 정교한 조건들의 지위로 축소한다면, 우리는 적어도 책무만큼이나 법의 고유한 특징을 이루고 사회에 대해 동일한 가치를 지니는 요소들을 단지 종속된(subordinate) 것으로 취급하게 된다. 사적 권한들(private powers)을 부여하는 규칙들은, 그것들이 이해되기 위해서는, 그것을 행사하는 사람들의 관점에서 보아야 한다. 그렇게 볼 때 이러한 규칙들은 강제적 통제(coercive control)라는 요소를 넘어, 법이 사회생활에 추가로 도입한 하나의 부가적 요소로 나타난다. 이는 이러한 법적 권한들의 보유(possession)가, 만약 그러한 규칙이 없다면 단지 책무-담지자(duty-bearer)에 불과했을 사인(private citizen)을 사적 입법자(private legislator)로 만들기 때문이다. 그는 계약들(contracts), 신탁들(trusts), 유언들(wills), 그리고 그가 구축할 수 있도록 가능하게 된 권리들과 책무들의 기타 구조들(structures of rights and duties)의 영역 내에서 법의 경로(course of the law)를 결정할 권능을 부여받는다(is made competent). 이러한 특별한 방식으로 사용되며, 이처럼 거대하고 독특한 편익(amenity)을 부여하는 규칙들이, 그 책무의 귀속양상(incidence), 곧 그 책무가 누구에게 어떻게 귀속되는지가 기실 부분적으로 바로 그러한 권한들의 행사에 의해 결정되는, 책무를 부과하는 규칙들과 구별되는 것으로 인정되지 않아야 할 이유가 무엇인가? 이러한 권한부여 규칙들(power-conferring rules)은 사회생활 속에서 책무를 부과하는 규칙들과는 다르게 사고되고(thought of), 말해지며(spoken of), 사용되고, 또한 상이한 이유로 가치평가된다. 성격상의 차이를 가르는 다른 검사 기준들(tests)이 과연 무엇일 수 있겠는가?

입법 권한과 사법 권한을 부여하고 그 행사를 규정하는 규칙들을, 책무들이 발생하는 조건들에 대한 진술로 환원하는 것은 공적 영역에서도 유사하게 가리는 결함(obscurating vice)을 지닌다. 이러한 권한들을 행사하여 권위 있는 제정물들(enactments)과 명령들(orders)을 만들어내는 사람들은, 책무의 이행(performance of duty)이나 강제적 통제(coercive control)에의 복종과는 전혀 다른 형태의 목적지향적 활동(purposive activity) 속에서 이러한 규칙들을 사용

한다. 이러한 규칙들을 책무 규칙들의 단순한 측면들이나 파편들로 표상하는 것은, 사적 영역에서보다도 더욱, 법의 고유한 특징들과 그 틀 안에서 가능한 활동들의 특수성을 흐리게 만든다. 왜냐하면 사회 안에 입법자가 책무 규칙들을 변경하고 추가할 수 있게 하는 규칙들, (p. 42) 그리고 판사가 언제 책무 규칙들이 어겨졌는지를 판단할 수 있게 하는 규칙들을 도입하는 것은, 사회에 있어 바퀴의 발명만큼이나 중요한 진전이기 때문이다. 이는 단지 중요한 진전이었을 뿐만 아니라, 제5장에서 우리가 논증하겠지만, 법-이전 세계(pre-legal world)에서 법적 세계(legal world)로의 이행을 이루는 단계로 정당하게 평가될 수 있는 것이다.

2. 적용 범위(THE RANGE OF APPLICATION)

명백히 형벌 제정법(penal statute)은 법들의 모든 다양상들(varieties of law) 가운데서도 강제적 명령들(coercive orders)의 단순한 모델에 가장 근접한다. 그럼에도 불구하고 이러한 법들조차도, 이 절에서 검토되는 바와 같은 일정한 특성들을 지니고 있으며, 이 모델은 바로 그러한 특성들에 대해 우리를 눈멀게 만들기 쉽다. 우리는 그 영향에서 벗어나기 전까지는 그것들을 이해할 수 없다. 위협으로 뒷받침된 명령은 본질적으로 타인들(others)이 특정한 일을 하거나 삼가기를 바라는 바람의 표현(expression of a wish)이다. 물론 입법이 이러한 오직 타인지향적인 형태(exclusively other-regarding form)를 취할 가능성도 있다. 입법 권한을 행사하는 절대 군주는 어떤 제도들에서는 자신이 제정한 법들의 포괄 범위(scope of the laws)로부터 항상 제외되는 것으로 간주될 수 있으며, 민주적 제도에서도 법을 제정한 자들에게는 적용되지 않고 법 안에서 지목된(indicated) 특정 부류들에만 적용되는 법들이 만들어질 수 있다. 그러나 하나의 법의 적용 범위(range of application)는 언제나 그 해석의 문제이다. 해석상 그것을 만든 자들을 제외하는 것으로 발견될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있으며, 실제로 오늘날에는 법을 만든 자들 자신에게 법적 의무들(legal obligations)을 부과하는 많은 법들이 제정되고 있다. 입법은, 위협 아래에서 단지 타인들에게 무엇을 하라고 명령하는 것과 구별되어, 이와 같은 자기구속적(self-binding)

효력(force)을 충분히 가질 수 있다. 입법에는 본질적으로 타인지향적인 것이 없다. 이러한 법적 현상은, 우리가 이 모델의 영향 아래에서 법들을 언제나 법 위에 있는 한 사람 또는 여러 사람이 그 법에 종속된 타인들을 상대로 정립한 것으로 생각하는 한에서만 수수께끼처럼 보인다.

이처럼 단순함 때문에 매우 매력적인, 법창출(law-making)의 수직적 혹은 ‘상하(top-to-bottom)’ 심상(image)은, 입법자를 그의 공적 행위능력(official capacity)에서는 하나의 인격으로, 사적 행위능력(private capacity)에서는 또 다른 인격으로 구별하는 장치(device)를 통해서만 현실과 조화될 수 있다. 이 첫 번째 행위능력에서 행위할 때 그는 다른 사람들, 그리고 그의 ‘사적 행위능력’에서의 자기 자신을 포함한 다른 사람들에게 의무들(obligations)을 부과하는 법을 제정하는 것으로 이해된다. 이러한 표현 형식들(forms of expression)에는 비난할 만한 점은 없지만, (p. 43) 제IV장에서 보게 되듯이, 이러한 상이한 행위 능력들(capacities)의 관념(notion)은 강제적 명령들로 환원될 수 없는 권한부여 법규칙들(power-conferring rules of law)의 관점에서만 이해 가능하다. 한편 이러한 복잡한 장치는 사실 전혀 필요하지 않다는 점을 주목해야 한다. 우리는 입법적 제정(legislative enactment)의 자기구속적 성질(self-binding quality)을 그것 없이도 설명할 수 있다. 왜냐하면 우리는 일상생활과 법 모두에서, 그것을 훨씬 더 잘 이해할 수 있게 해 줄 어떤 것을 이미 수중에 가지고 있기 때문이다. 그것은 바로 약속(promise)의 작용(operation)이며, 이는 법의 모든 특징은 아니지만 많은 특징들을 이해하는 데 있어 강제적 명령들의 모델보다 여러 방식에서 훨씬 더 나은 모델이다.

약속한다는 것은 약속자(promisor)에게 의무(obligation)를 발생시키는 무엇인가를 말하는 것이다(say). 말들(words)이 이러한 종류의 효과를 갖기 위해서는, 적절한 사람들이 적절한 경우에 (즉 자신의 처지를 이해하는 정신이 온전한 사람들로서 다양한 종류의 압력에서 자유로운 경우) 말을 사용하면, 그 말을 사용하는 자들은 그 말들에 의해 지정된(designated) 일들을 해야 할 구속을 받는다고 정하는 규칙들(rules)이 존재해야 한다. 따라서 우리가 약속할 때에는, 우리 스스로에게 의무들(obligations)을 부과하고 타인에게 권리들(rights)을 부여함으로써 자신의 도덕적 상황(moral situation)을 변경하기 위해 특정된

절차들(specified procedures)을 사용하는 것이며, 법률가들의 어법(parlance)으로 말하면 이를 위해 규칙들에 의해 부여된 ‘권한(a power)’을 행사하는 것이다. 그 약속자 ‘내부에(within)’ 두 인격들(persons)을 구별하여, 하나는 의무 창설자의 행위능력에서 행위하고 다른 하나는 구속되는 인격의 행위능력에서 행위하는 것으로 상정하고, 하나가 다른 하나에게 어떤 행위를 하라고 명령하는 것으로 생각하는 것도 기실 가능하기는 하겠지만, 도움이 되지는 않는다.

마찬가지로 입법의 자기구속력을 이해하기 위해서도 이러한 장치를 생략할 수 있다. 법을 제정하는 행위는 약속을 하는 행위와 마찬가지로, 그 과정을 규율하는 일정한 규칙들의 존재를 전제하기 때문이다. 이 규칙들에 의해 자격이 부여된 사람들이 말하거나 쓴 말들(words said or written)이, 그 규칙들이 특정한 절차를 따를 때에는, 그 말들에 의해 명시적으로 또는 묵시적으로 지정된(designated) 범위(ambit) 안에 있는 모든 사람들에게 의무들(obligations)을 발생시킨다. 여기에는 입법 과정에 참여한 사람들 자신도 포함될 수 있다.

물론 입법의 자기구속적 성질을 설명해 주는 이러한 유비(analogy)가 존재하지만, 약속을 하는 행위와 법을 제정하는 행위 사이에는 많은 차이점들이 있다. 후자를 규율하는 규칙들은 훨씬 더 복잡하며, 약속이 갖는 쌍방적 성격(bilateral character)도 존재하지 않는다. 일반적으로는, 약속이 누구에게(to whom) 이루어지는지라는 의미에서 약속수령자(promisee)라는 특수한 지위에 있는 사람이 존재하지 않으며, 또한 그 이행(performance)에 대하여 특별한 청구권을, (p. 44) 설령 그것이 유일한 청구권은 아닐지라도, 가지고 있는 사람도 존재하지 않는다. 이러한 점들에서 보면, 잉글랜드 법에 알려진 의무의 자기부과(self-imposition of obligation)의 다른 형태들, 예컨대 어떤 사람이 재산에 관하여 자신을 타인을 위한 수탁자(trustee)로 선언하는 경우는, 입법의 자기구속적 측면에 대해 더 가까운 유비를 제공한다. 그럼에도 불구하고 일반적으로, 제정(enactment)에 의한 입법 행위는 이러한 사적인 방식들, 즉 개별적인 법적 의무들(legal obligations)을 창설하는 방식들을 고찰함으로써 가장 잘 이해될 수 있다.

강제적 명령들 또는 규칙들이라는 모델에 대한 가장 필요한 교정은, 입법을 사회가 일반적으로 따라야 할 일반적 행위 기준들(general standards of behaviour)의 도입 또는 수정으로 보는 새로운 구상(fresh conception)이다. 입

법자는 반드시 타인에게 명령을 내리는 자, 즉 정의상 자신이 하는 일의 적용 범위 밖에 있는 누군가와 같은 것은 아니다. 그는 약속을 하는 사람(the giver of a promise)처럼, 규칙들에 의해 부여된 권한들(powers)을 행사하는 자이다. 그리고 종종, 약속자(promisor)가 반드시 그러해야(must) 하듯이, 그 자신도 그 범위(ambit) 안에 포함될 수 있다.

3. 기원 양식들(MODES OF ORIGIN)

지금까지 우리는 법들의 다양상들(varieties of law)에 관한 논의를, 앞서 강조한 차이점들에도 불구하고 강제적 명령들(coercive orders)과 하나의 두드러진 유비점을 지니는 제정법들(statutes)에 국한해 왔다. 하나의 법을 제정하는 것(enactment of a law)은, 명령을 내리는 것과 마찬가지로, 의도적이고 날짜를 특정할 수 있는 행위이다(is a deliberate datable act). 입법에 참여하는 자들은 의식적으로(consciously) 법을 만드는 절차를 운용하며, 이는 마치 명령을 내리는 자가 자신의 의도들이 인정(recognition)되고 준수(compliance)되도록 확보하기 위해 특정한 말의 형식(form of words)을 의식적으로(consciously) 사용하는 것과 같다. 따라서 법의 분석에서 강제적 명령들의 모델을 사용하는 이론들은, 모든 법이, 그 위장들을 벗겨내면(strip away the disguises), 이 점에서 입법과 닮아 있으며, 법으로서의 그 지위를 의도적인 법창출 행위(law-creating act)에 빚지고 있다고 볼 수 있다는 주장(claim)을 제기한다. 이 주장과 가장 명백하게 충돌하는 법 유형(type of law)은 관습(custom)이다. 그러나 관습이 ‘정말로(really)’ 법인가에 관한 논의는 두 가지 구별되는 쟁점들을 풀어내지 못했기 때문에 종종 혼란스러웠다. 첫 번째 쟁점은 ‘관습 그 자체로서(custom as such)’가 법인지 아닌지이다. 관습 그 자체가 법이 아니라는 부정의 의미와 일리는, 어떤 사회든 그 법의 일부를 전혀 이루지 않는 많은 관습들이 존재한다는 단순한 진리에 있다. 여성에게 모자를 벗지 않는 것은 어떤 법규칙(rule of law)의 위반도 아니며, 법에 의해 허용(permitted)된다는 것 외에는 아무런 법적 지위도 갖지 않는다. 이것은 관습이 특정 법체계에 의해 법으로서 ‘인정된’(‘recognized’ as law) 부류의 관습들 중 하나인 경우에만 (p. 45) 법이라는 점을 보여준다. 두

번째 쟁점은 ‘법적 인정(legal recognition)’의 의미에 관한 것이다. 하나의 관습이 법적으로 인정된다(legally recognized)는 것은 무엇인가? 강제적 명령들의 모델이 요구하듯, 그것은 누군가, 어쩌면 ‘주권자(the sovereign)’ 혹은 그의 대리인(agent)이 그 관습에 복종하라고 명령했다는 사실로 이루어져 있어서, 그 법으로서의 지위가 이 점에서 입법 행위와 닮은 어떤 것에 빚지고 있다는 뜻인가?

현대 세계에서 관습은 그다지 중요한 법의 ‘원천(source)’이 아니다. 그것은 보통 종속된(subordinate) 원천인데, 이는 입법부가 제정법(statute)으로 관습 규칙의 법적 지위를 박탈할 수 있다는 의미이다. 또한 많은 체계에서 법원이 어떤 관습이 법적 인정(legal recognition)에 적합한지를 판단할 때 적용하는 검사 기준들(tests)은 ‘합당성(reasonableness)’이라는 관념(notion)과 같은 유동적인 관념들을 포함하며, 이것들은 관습을 수용하거나 배제할 때 법원이 사실상 통제되지 않는 재량(discretion)을 행사한다고 보는 견해에 적어도 어느 정도의 토대를 제공한다. 그렇다 하더라도, 관습의 법적 지위를 법원이나 입법부 또는 주권자가 그렇게 ‘명령했다(ordered)’는 사실에 귀속시키는 것은, 이론의 요점을 빼앗아 갈 만큼 확장된 의미를 ‘명령(order)’에 부여해야만 관철될 수 있는 이론을 채택하는 것이다.

이러한 법적 인정(legal recognition) 교설을 제시하기 위해, 우리는 강제적 명령들로서의 법 구상(conception of law as coercive orders)에서 주권자(the sovereign)가 수행하는 역할을 상기해야 한다. 이 이론에 따르면, 법은 주권자 또는 그가 자신을 대신하여 명령들을 내리도록 선택할 수 있는, 그에게 종속된 자(subordinate)의 명령이다. 첫 번째 경우, 법은 ‘명령(order)’이라는 가장 문자적인 의미에서 주권자의 명령에 의해 만들어진다. 두 번째 경우, 종속된 자가 내린 명령은, 그것이 다시 주권자가 발한 어떤 명령을 좇아(in pursuance of) 내려진 것일 때에만 법으로서의 지위에 오른다(rank as law). 이 종속된 자는 주권자를 대신하여 명령들을 발령할(issue orders) 일정한 권한(authority)을 주권자로부터 위임받아야 한다. 때때로 이러한 권한은, 예컨대 장관에게 일정한 사항적 범위(subject-matter)에 대해 ‘명령들을 제정하도록(make orders)’ 지시하는 명시적 지시(express direction)를 통해 부여될 수 있다. 그러나 이 이

론이 여기서 멈춘다면 현실을 설명하지 못함이 분명하므로, 이 이론은 확장되어 주권자가 자신의 의지(will)를 덜 직접적인 방식으로 표현하는 경우도 있다고 주장하게 된다. 그의 명령들은 ‘묵시적(tacit)’ 일 수 있다. 즉, 주권자가 명시적 명령을 내리지 않더라도, 그에게 종속된 자들이 수범자들(subjects)에게 명령들을 내리고 불복종에 대해 그들을 처벌할 때 개입하지 않음으로써, 수범자들이 특정한 일을 하기를 바란다는 자신의 의도들(intentions)을 나타낼 수 있다는 것이다.

(p. 46) 군사적 예시는 ‘묵시적 명령(tacit order)’이라는 관념을 가능한 만큼 명확하게 만들어 줄 수 있다. 자신보다 상급자인 자들에게 스스로 반복적으로 일양적인 복종을 하는 어느 하사가 자기 부하들에게 특정한 잡무(fatigues)를 하라고 명령하고, 그들이 불복종하면 처벌한다. 장군은 이 사실을 알고도 사태가 계속되도록 허용한다. 비록 그가 하사에게 잡무를 중지하라고 명령했다면 하사는 그 명령에 복종했을 터이지만 말이다. 이러한 상황에서는, 장군이 병사들이 잡무를 수행하기를 바라는 자신의 의지(will)를 묵시적으로 표현했다고 볼 수 있다. 개입할 수 있었을 때의 그의 비개입(non-interference)은, 그가 잡무를 명령할 때 사용했을지도 모를 말들에 대한 침묵의 대체물이다.

우리는 이러한 관점에서 법체계 안에서 법의 지위를 갖는 관습 규칙들을 바라보도록 요청받는다. 법원이 구체적 사건들에서 그것들을 적용하기 전까지, 이러한 규칙들은 단지(mere) 관습들일 뿐이며, 어떤 의미에서도 법은 아니다. 법원이 그것들을 사용하고, 그것들에 따라 집행되는 명령들을 만들 때, 그때 비로소 이 규칙들은 법적 인정(legal recognition)을 받는다. 개입할 수도 있었던 주권자는, 이미 존재한 관습(pre-existing custom)을 토대로 ‘만들어진(fashioned)’ 법관들의 명령들에 수범자들(subjects)이 복종하도록 묵시적으로 명령한 셈이 되는 것이다.

관습(custom)의 법적 지위에 대한 이러한 설명은 두 가지 상이한 비판에 열려 있다. 첫 번째 비판은, 관습 규칙들이 소송(litigation)에서 사용되기 전까지는 법으로서의 지위를 전혀 갖지 못한다는 것이 반드시(necessarily) 그런 것은 아니라는 점이다. 이것이 반드시 그렇다는 단언은 단순한 독단(dogma)이거나, 어떤 체계들에서 그러할 수 있는 것과 필연적인 것을 구별하지 못하는

것이다. 만일 특정하게 규정된 방식으로 제정된 제정법들(statutes)이, 법원이 구체적 사건들에서 그것들을 적용하기 이전에도 법이라면, 특정하게 규정된 종류의 관습들 역시 그렇게 될 수 없는 이유가 무엇인가? 입법부가 제정하는 것은 법이라는 일반 원칙을 법원이 구속적인 것으로 인정하듯이(recognize as binding), 특정하게 규정된 종류의 관습들은 법이라는 또 다른 일반 원칙을 법원이 구속적인 것으로 인정한다고 보는 것이 왜 참일 수 없는가? 구체적 사건들이 발생했을 때, 법원이 제정법을 적용하듯이 관습을, 이미 법이고 법이기 때문에 적용한다고 주장하는 데 어떤 불합리가 있는가? 물론 어떤 법체계가, 법원이 통제되지 않는 재량으로 그렇게 선언하기 전까지는 어떠한 관습 규칙도 법의 지위를 갖지 않는다고 규정할 수도 있다(possible). 그러나 이것은 단지 하나의(one) 가능성일 뿐이며, 법원이 그와 같은 재량을 갖지 않는 체계들의 가능성을 배제할 수는 없다. 그렇다면 이것이 어떻게 (p. 47) 관습 규칙은 법원에서 적용되기 전까지 법의 지위를 가질 수 없다(cannot)는 일반적 주장을 확립할 수 있겠는가?

이러한 이의들에 대한 답변은 종종, 단지 “무언가가 법이 되기 위해서는 반드시 누군가에 의해 그렇게 되도록 명령(order) 되어야 한다”는 독단을 다시 단언하는 데 그친다. 그러면 법원이 제정법과 관습에 대해 가지는 관계 사이에 제안된 병행성은, 법원이 적용하기 전에 제정법은 이미 ‘명령’ 되었지만 관습은 그렇지 않다는 근거에서 거부된다. 덜 독단적인 논증들도 특정 체계들의 특수한 장치들에 지나치게 많은 의미를 부여하기 때문에 부적절하다. 예컨대, 영국법에서는 어떤 관습이 ‘합당성(reasonableness)’ 검사 기준을 통과하지 못하면 법원에 의해 거부될 수 있다는 사실이, 관습은 법원이 적용하기 전까지는 법이 아니라는 점을 보여준다고 때때로 말해진다. 하지만 이것은 기껏해야 영국법에서의 관습에 관해 무언가를 증명할 수 있을 뿐이다. 일부가 주장하듯, 법원이 합당한 경우에만 일정한 관습 규칙들을 적용하도록 구속되는 체계와 법원이 통제되지 않는 재량을 갖는 체계를 구별하는 것이 무의미하다는 점이 참인 경우가 아니라면, 그것조차도 확립될 수 없다.

관습이 법일 경우 그 법적 지위를 주권자의 묵시적 명령에 빚지고 있다는 이론에 대한 두 번째 비판은 더욱 근본적이다. 설령 그것이 개별 사건에서

법원에 의해 집행되기 전까지는 법이 아니라고 인정한다 하더라도, 주권자가 개입하지 않았다는 사실을 그 규칙들이 준수되기를 바랐다는(wish) 묵시적 표현으로 취급하는 것이 과연 가능한가? 46쪽의 매우 단순한 군대 사례에서도, 장군이 하사의 명령들에 개입하지 않았다는 사실로부터 그가 그 명령들에 복종하기를 바랐다고 보는 것은 필연적 추론이 아니다. 그는 단지 자신이 소중히 여기는 부하를 달래기를 바랐고 병사들이 잡무(fatigues)를 회피할 어떤 방법을 찾기를 바랐을 뿐일 수도 있다. 물론 어떤 경우에는 그가 잡무가 수행되기를 바랐다고 추론할 수도 있겠지만, 그렇게 추론한다면 우리의 증거에서 중요한 부분은 장군이 그 명령들이 내려졌다는 사실을 알고 있었고, 그것들을 숙고할 시간이 있었으며, 아무 조치도 취하지 않기로 결정했다는 점일 것이다. 관습의 법적 지위를 설명하기 위해 주권자의 의지(will)의 묵시적 표현이라는 관념(idea)을 사용하는 데 대한 주된 반대 이유는, 어떤 현대 국가에서도 주권자를 최고 입법부나 선거권자 집단(electorate)으로 동일시하든 간에, 그러한 앎, 숙고, 그리고 개입하지 않기로 한 결정을 ‘주권자’에게 귀속시키는 것이 (p. 48) 거의 불가능하다는 점에 있다. 물론 대부분의 법체제에서 관습은 제정법(statute)에 종속된 법의 원천(source of law)이라는 점은 참이다. 이는 입법부가 그것들의 법적 지위를 박탈할 수는 있었음을(could) 의미한다. 그러나 그렇게 하지 않았다는 사실이 입법자의 바람들(wishes)의 징후(sign)라고 보기는 어렵다. 법원이 적용하는 관습 규칙들에 입법부의 주의가 기울여지는 경우는 매우 드물고, 선거권자 집단의 주의를 더욱 드물다. 따라서 그들의 비개입은 장군이 하사의 명령들에 개입하지 않은 경우와 비교될 수 없으며, 설령 장군의 경우에 그 비개입으로부터 그의 부하의 명령들에 복종하기를 바랐다는 추론을 우리가 받아들일 준비가 되어 있다 하더라도 그러하다.

그렇다면 관습의 법적 인정(legal recognition)은 무엇으로 이루어지는가? 관습 규칙(customary rule)은, 그것을 특정 사건에 적용한 법원의 명령(order)이나 최고 법창출 권력(supreme law-making power)의 묵시적 명령(tacit order)에 의한 것이 아니라면, 무엇에 그 법적 지위를 빚지고 있는가? 그리고 그것은 어떻게 제정법(statute)처럼, 법원이 그것을 적용하기 이전에도 법일 수 있는가? 이러한 질문들은, 다음 장에서 우리가 상세히 검토하게 될 바와 같이, 법이

존재하는 곳에는 그 명시적이거나 묵시적인 일반 명령들만이 법인 어떤 주권적 인격이나 인격들(some sovereign person or persons)이 반드시 존재해야 한다는 교설(doctrine)을 면밀히 검토한 후에야 비로소 충분히 답할 수 있다. 그때까지는, 이 장의 결론을 다음과 같이 요약할 수 있다.

강제적 명령들로서의 법 이론은, 모든 체계들에서 세 가지 주요한 점에서 이 설명에 들어맞지 않는 법들의 다양상들(varieties of law)이 발견된다는 이의에 처음부터 직면한다. 첫째, 이에 가장 근접한 형벌 제정법(penal statute)조차도 흔히 타인들에게 내려지는 명령들과는 다른 적용 범위(range of application)를 가지는데, 그러한 법은 타인들뿐만 아니라 그것을 제정한 자들 자신에게도 책무들(duties)을 부과할 수 있기 때문이다. 둘째, 다른 제정법들(statutes)은 명령들과 달리 사람들에게 어떤 행위를 요구하지 않을 수 있으며, 대신 그들에게 권한들(powers)을 부여할 수 있다. 즉, 그것들은 책무들을 부과하지 않고, 법의 강제적 틀 안에서 법적 권리들과 책무들을 자유롭게 창출할 수 있는 편의수단들(facilities)을 제공한다. 셋째, 비록 제정법의 제정(enactment of a statute)이 어떤 점에서는 명령의 발령과 유비적이며, 일부 법규칙들(rules of law)은 관습(custom)에서 기원하며, 그와 같은 어떤 의식적인 법창출 행위(conscious law-creating act)에도 그 법적 지위를 빚지고 있지 않다.

이러한 이의들에 맞서 이 이론을 방어하기 위해 여러 가지 방책들(expedients)이 채택되어 왔다. 원래는 단순했던 해약의 위협 또는 ‘제재(sanction)’라는 관념(idea)은 (p. 49) 법적 거래(legal transaction)의 무효(nullity)까지 포함하도록 늘어났고, 법규칙(legal rule)의 관념(notion)은 권한들을 부여하는 규칙들을 법의 단순한 파편들로 보아 배제하도록 좁혀졌으며, 그 제정물들(enactments)이 자기구속적인 입법자라는 단일한 자연인(natural person) 안에서 두 인격들(two persons)이 발견되었고, 명령의 관념(notion)은 언어적 표현(verbal expression)에서, 종속된 자들(subordinates)이 내린 명령들에 비개입하는 것(non-interference)으로 이루어진 의지의 ‘묵시적(tacit)’ 표현으로까지 확장되었다. 이러한 장치들의 기발함(ingenuity)에도 불구하고, 위협으로 뒷받침된 명령들의 모델은 법을 드러내기보다 오히려 법의 더 많은 부분을 가려버린다. 법들의 다양상(the variety of laws)을 이 하나의 단순한 형식으로 환원하려는

시도는 결국 그것들에 허위적 통일성(spurious uniformity)을 강요하는 결과로 끝난다. 기실, 여기에서 통일성을 찾는 것 자체가 오류일지도 모른다. 왜냐하면 제5장에서 우리가 논증하겠지만, 법의 하나의 구별적 특징—아니 어쩌면 바로 그 구별적 특징—은 서로 다른 유형의 규칙들의 융합(fusion)에 있기 때문이다.

제3장 주석

26쪽. 법의 다양상들(The varieties of law). 법에 대한 일반적 정의를 추구하는 과정에서, 서로 다른 유형의 법규칙들 사이에 존재하는 형식과 기능상의 차이들이 가려지게 되었다. 이 책의 주된 논증은, 의무들(obligations) 또는 책무들(duties)을 부과하는 규칙들과 권한들(powers)을 부여하는 규칙들 사이의 차이들이 법리학(jurisprudence)에서 핵심적으로 중요하다는 것이다. 법은 이 두 가지 상이한 유형의 규칙의 결합체(union)로 이해될 때 가장 잘 설명된다. 따라서 본 장에서는 법규칙 유형들 사이의 주요 구분으로 이 점을 강조하고 있지만, 다른 여러 구분 역시 가능하며, 어떤 목적에서는 반드시 이루어져야 한다. 법들의 상이한 사회적 기능들을 반영하고, 그러한 기능이 흔히 그 언어적 형식에서도 드러나는 더 유익한 분류들에 대해서는 Daube의 *Forms of Roman Legislation* (1956)을 참조할 수 있다.

27쪽. 형사법과 민사법에서의 책무(Duties in criminal and civil law). 책무들을 부과하는 규칙들과 권한들을 부여하는 규칙들 사이의 구분에 주의를 집중하기 위해, 우리는 형사법상의 책무들과 불법행위법(tort) 및 계약법(contract)상의 책무들 간의 많은 차이들을 생각하였다. 이러한 차이들에 주목한 일부 이론가들은, 계약이나 불법행위의 경우에 일정한 행위들을 하거나 삼갈 ‘일차적(primary)’ 또는 ‘선행적(antecedent)’ 책무들(예컨대 계약으로 정해진 어떤 행위를 이행하거나 명예훼손을 삼갈 책무들)은 허상이며, ‘진정한(genuine)’ 책무들은 이른바 일차적 책무를 이행하지 못한 경우를 포함한 일정한 사정들(eventualities)에서 손해배상을 하도록 하는 구제적(remedial) 또는 제재적(sanctioning) 책무들뿐이라고 주장하기도 한다. 이에 대해서는 Holmes의 *The Common Law* 제8장을 참조하되, Buckland의 *Some Reflections on Jurisprudence* 96쪽과 *The Nature of Contractual Obligation*, *Cambridge Law Journal* 제8권(1944년)에서의 비판을 함께 참고하라. 또한 Jenks의 *The New Jurisprudence* 179쪽도 참조할 것.

27쪽. 의무(obligation)와 책무(duty). 영미법(Anglo-American Law)에서는 이 두 용어가 현재 대체로 동의어로 사용되지만, 형사법이 ‘의무(obligations)’를 부과한다고 말하는 것은 (법의 요구 사항에 대한 추상적 논의, 예컨대 도덕적 의무와 대비되는 법적 의무의 분석과 같은 경우를 제외하면) 일반적이지 않다. 법률가들은 여전히 계약상의 의무나 불법행위 후 손해배상 의무 등처럼 특정 개인이 다른 특정 개인에 대해 가지는 대인적 권리(right in personam)가 존재하는 경우에 ‘의무(obligation)’라는 단어를 가장 흔히 사용한다. 그 외의 경우에는 ‘책무(duty)’라는 표현이 보다 일반적이다. 이는 현대 영어법에서, 로마법의 *obligatio*가 특정한 개인들 사이를 묶는 법적 유대(vinculum

juris)라는 본래 의미에서 살아남은 유일한 흔적이다. (Salmond, *Jurisprudence*, 제11판, 제10장 260쪽 및 제21장 참조; 또한 본서 제5장 제2절 참조).

28쪽. 권한부여 규칙들(Power-conferring rules). 대륙법계의 법리학에서는 법적 권한들(legal powers)을 부여하는 규칙들을 종종 ‘권능 규범들(norms of competence)’이라 부른다. (Kelsen, *General Theory*, 90쪽, A. Ross, *On Law and Justice* (1958), 34, 50–59, 203–225쪽 참조). Ross는 사적 권능(private competence)과 사회적 권능(social competence)을 구분하며, 이에 따라 계약과 같은 사적 처분들(private dispositions)과 공적 법적 행위들(public legal acts)을 구별한다. 그는 또한 권능 규범들은 책무들을 규정하지 않는다고 지적한다. “권능 규범은 그 자체로는 직접적인 지시(directive)가 아니며, 절차를 책무로 규정하지 않는다. … 권능 규범 자체는 권능을 가진 자가 자신의 권능을 행사할 의무가 있다고 말하지 않는다.” (위 책, 207쪽). 그러나 이러한 구분에도 불구하고, Ross는 본 장에서 비판된 관점을 받아들인다. 즉, 그는 권능 규범들도 결국 ‘행위 규범들(norms of conduct)’로 환원될 수 있다고 주장하며, 두 유형의 규범은 모두 “법원들에 대한 지시들(directives to the Courts)”로 해석되어야 한다고 본다. (같은 책, 33쪽).

이 장의 본문에서 이 두 규칙 유형의 구분을 제거하거나 그것이 단지 피상적이라는 것을 보이려는 다양한 시도들을 비판한 내용을 검토할 때에는, 법 이외에도 이러한 구분이 중요해 보이는 사회생활의 형식들이 있음을 기억해야 한다. 도덕(morals)에서, 어떤 사람이 구속력 있는 약속을 했는지를 판단하는 모호한 규칙들은 개인들에게 제한된 도덕적 입법 권한들을 부여하며, 따라서 의사에 반하여(in invitum) 책무들을 부과하는 규칙들과 구별될 필요가 있다 (Melden, ‘On Promising’, *Mind* 제65권 (1956); Austin, ‘Other Minds’, *PAS* 보충권 20권 (1946), *Logic and Language* 2집에 재수록; Hart, ‘Legal and Moral Obligation’, Melden 편, *Essays on Moral Philosophy* 참조). 복잡한 게임의 규칙들도 이 관점에서 유익하게 분석될 수 있다. 일부 규칙은 형사법과 유비적으로, 제재적-불이익을 조건으로 특정 행위 유형들을 금지한다(예: 반칙 행위나 심판에 대한 무례). 또 다른 규칙들은 경기 담당자들(심판, 기록원, 주심)의 관할권(jurisdiction)을 규정한다. 다시 다른 규칙들은 득점하려면 무엇이 행해져야 하는지를 규정한다(예: 골(goal)이나 득점(run)). 득점이나 골을 위한 조건을 충족하는 것은 경기에서 승리를 향한 핵심적 국면을 표시하며, 이를 충족하지 못한 것은 득점 실패이고, 이 관점에서 ‘무효(nullity)’이다. 여기에는 일응(prima facie) 게임 안에서 다양한 기능을 수행하는 서로 다른 유형의 규칙들이 있다. 그러나 어떤 이론가는 득점 실패라는 무효가 금지된 행위에 대한 ‘제재(sanction)’ 또는 제재적-불이익(penalty)으로 간주될 수 있기 때문

에, 또는 모든 규칙이 일정한 사정 아래 경기 담당자들에게 일정한 조치를 취하라는 지시들로 해석될 수 있기 때문에(예: 득점을 기록하거나 선수를 필드 밖으로 내보내는 것), 이러한 규칙들이 모두 하나의 유형으로 환원될 수 있으며 또 환원되어야 한다고 주장할 수도 있다. 그러나 이러한 방식으로 두 유형의 규칙을 하나의 유형으로 환원하는 것은, 그것들의 성격을 흐리게 만들며, 게임에서 중심적으로 중요한 것을 단지 보조적인 것에 종속시키는 결과를 낳는다. 본 장에서 비판한 환원주의적 법이론들이, 여러 유형의 법규칙들이 그 일부를 이루는 사회 활동 체계 안에서 갖는 다양한 기능들을 이와 유사하게 어느 정도 은폐하는지 숙고할 가치가 있다.

29쪽. 사법적 권한들을 부여하는 규칙들과 판사에게 책무들을 부과하는 추가 규칙들(Rules conferring judicial powers and additional rules imposing duties on the judge). 동일한 행위가 관할권 초과(excess of jurisdiction)로 취급되어 사법 결정이 무효(nullity)로 파기될 수 있게 만드는 동시에, 판사가 자신의 관할권을 넘지 않도록 요구하는 특별한 규칙 아래에서 책무 위반으로 취급될 수 있다고 해도, 이 두 규칙 유형의 구분은 여전히 유지된다. 예컨대, 판사가 자신의 관할권을 넘어 사건을 심리하거나 그 결정이 유효하지 않게 될 다른 방식으로 행동하는 것을 막기 위한 금지명령(injunction)을 받을 수 있다면, 혹은 그러한 행위에 대해 제재적-불이익들(penalties)이 규정되어 있다면 이러한 경우에 해당한다. 마찬가지로, 법적으로 자격이 없는 사람이 공적 절차에 참여한 경우, 이는 그를 제재적-불이익에 노출시킬 뿐 아니라 그 절차를 유효하지 않게 만들 수 있다. (이와 관련된 제재적-불이익에 대해서는 *Local Government Act 1933*, 제76조 및 *Rands v. Oldroyd* (1958), 3 AER 344 참조. 다만 이 법은 지방정부의 절차가 구성원 자격의 결함으로 인해 유효하지 않게 되지는 않는다고 규정한다—같은 법, 부속서 III, 제5부 제5항).

33쪽. 제재로서의 무효(Nullity as a sanction). Austin은 *The Lectures* 제23강에서 이 구상(conception)을 채택하였으나, 별도로 전개하지는 않았다. 이에 대한 비판은 Buckland, 앞서 인용한 책의 제10장에서 참조하라.

35쪽. 권한부여 규칙을 책무를 부과하는 규칙의 파편들로 보는 이론(Power-conferring rules as fragments of rules imposing duties). 이 이론의 극단적인 형태는 Kelsen이 전개한 것으로, 법의 일차 규칙들(primary rules of law)은 법원들이나 공무원들이 일정 조건 하에서 제재들을 적용하도록 요구하는 규칙들이라는 견해와 함께 제시된다(*General Theory*, 58–63쪽; 헌법 관련 논의는 143–144쪽 참조). 그는 “헌법 규범들은 독립적이고 완결된 규범들이 아니라, 법원과 기타 기관들이 적용해야 하는 모든 법규

법들의 내재적 부분들(intrinsic parts)이다” 라고 주장한다. 이러한 교설은 법의 동적(dynamic) 제시와 구별되는 정적(static) 제시로 제한됨으로써 한정된다 (같은 책, 144 쪽). Kelsen의 논의는 또한 다음과 같이 복잡해진다. 즉, 그는 예컨대 계약을 체결할 권한과 같은 사적 권한들을 부여하는 규칙들의 경우, 계약에 의해 창출되는 ‘이차 규범(secondary norm)’ 또는 책무들은 “단순한 법리학적 이론(juristic theory)의 보조적 구성물이 아니다” 라고 주장한다 (같은 책, 90쪽, 137쪽). 그럼에도 본질적으로 Kelsen의 이론은 본 장에서 비판된 이론이다. 보다 단순한 형태로는 Ross의 주장을 참조할 수 있다: “권능 규범들은 간접적 형식의 행위 규범들이다” (Ross, 같은 책, 50쪽). 모든 규칙을 책무들을 창출하는 규칙들로 환원하는 보다 온건한 이론으로는 Bentham의 *Of Laws in General*, 제16장 및 부록 A-B 참조.

39쪽. 예측으로서의 법적 책무와 행위에 대한 조세로서의 제재. 이 두 이론은 Holmes의 “The Path of the Law” (1897, *Collected Legal Papers*)를 참조하라. Holmes는 책무라는 관념이 도덕적 책무와 혼동되었다고 보고, 그것을 “냉소적 산(acid of cynicism)”에 담가 씻어내야 한다고 주장하였다. “우리는 ‘책무(duty)’ 라는 단어에 도덕에서 끌어온 모든 내용을 채워 넣는다” (같은 책, 173쪽). 그러나 법규칙을 행위 기준들(standards of conduct)로 간주하는 구상은, 그것들을 도덕적 기준들과 동일시(identification)할 필요는 없다 (제5장 제2절 참조). Holmes가 ‘그가[나쁜 사람(the Bad Man)이] 어떤 일을 할 경우 불쾌한 결과를 겪게 될 것이라는 예언(prophecy)’ 으로 책무를 동일시한 데 대한 비판은 A. H. Campbell의 Frank 저서 *Courts on Trial*에 대한 서평, *Modern Law Review* 제13권(1950), 그리고 본서 제5장 제2절, 제7장 제2절과 제3절에서 확인할 수 있다.

미국 연방대법원은 제1조 제8절(의회에 과세 권한을 부여하는 미국 헌법 조항)의 목적상 제재적-불이익(penalty)과 조세(tax)를 구별하는 데 어려움을 겪어왔다. 참조: *Charles C. Steward Machine Co. v. Davis*, 301 U.S. 548 (1937).

41쪽. 책무-담지자(duty-bearer)로서 그리고 사적 입법자(private legislator)로서의 개인. Kelsen의 법적 행위능력(legal capacity)과 사적 자율성(private autonomy) 논의와 비교하라 (*General Theory*, 90쪽, 136쪽).

42쪽. 입법자가 자신을 구속하는 입법(Legislation binding the legislator). 명령들(orders)과 사령들(commands)은 오직 타인에게만 적용된다는 전제에 기반하여 명법 이론(imperative theories of law)을 비판하는 논의는 Baier의 *The Moral Point of View* (1958), 136-139쪽을 참조하라. 그러나 일부 철학자들은 자기지향 사령(self-addressed

command)이라는 관념을 수용하며, 이를 1인칭 도덕 판단(first-person moral judgments) 분석에도 사용한다. (Hare, *The Language of Morals*, 제11-12장에서 ‘Ought’ 논의 참조). 본문에서 입법과 약속의 유비를 제시한 부분은 Kelsen, *General Theory*, 36쪽도 함께 보라.

45쪽. 관습과 묵시적 사령(Custom and tacit commands). 본문에서 비판된 교설은 Austin의 것으로, *The Province of Jurisprudence Determined*, 제1강 30-33쪽 및 *The Lectures*, 제30강 참조. 묵시적 사령이라는 관념(notion of tacit command)을 사용하여 명법 이론과 조화되게 법의 여러 양태에 대한 인정(recognition)을 설명하는 시도는 Bentham의 ‘수용(adoption)’ 및 ‘수습(susception)’ 교설, *Of Laws in General*, 21쪽을 참조하라. 또한 Morison, ‘Some Myth about Positivism’, *Yale Law Journal* 제68권 (1958) 및 본서 제4장 제2절도 참고. 묵시적 사령이라는 관념에 대한 비판은 Gray, *The Nature and Sources of the Law*, §§ 193-199 참조.

49쪽. 명법 이론들과 제정법 해석(Imperative theories and statutory interpretation). 법들이 본질적으로 명령들(orders)이며, 따라서 입법자의 의지(will) 또는 의도의 표현이라는 교설은, 본 장에서 제기한 것 외에도 다양한 비판에 직면한다. 어떤 비판자들은, 이러한 교설이 제정법 해석(statutory interpretation)의 과업을 ‘입법자의 의도(the intention of the legislator)’를 찾는 것으로 보는 오도적인 구상(conception)에 책임이 있다고 보았다. 이는 입법자가 복합적이고 인위적인 집단(body)일 경우, 그 의도의 증거를 찾거나 산출하는 데 어려움이 있을 뿐 아니라, “입법자의 의도”라는 표현 자체에 명확한 의미가 부여되지 않을 수 있다는 사실을 고려하지 않은 것이다. 관련 논의는 Hägerström, *Inquiries into the Nature of Law and Morals*, 제3장 74-97쪽 참조. 입법 의도라는 관념(idea)에 수반된 허구에 대해서는 Payne, ‘The Intention of the Legislature in the Interpretation of Statute’, *Current Legal Problems* (1956) 참조. 입법자의 ‘의지(will)’ 관념에 대한 논의는 Kelsen, *General Theory*, 33쪽도 함께 보라.

제3장 제3판 주석

27-32쪽. 권한부여 규칙들(Power conferring rules). Hart는 『벤담에 대한 에세이: 법리학과 정치이론』(*Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Theory*, 옥스퍼드대 출판부, 1982) 제8장 “법적 권한들(Legal Powers)”에서 자신의 견해를 수정하였다. 권한부여 규칙들에 대한 보다 일반적인 논의로는 Joseph Raz의 『실천적 이유와 규범(Practical Reason and Norms)』(제2판, 옥스퍼드대 출판부, 1990) 97-106쪽을 참조하라.

또한 Joseph Raz와 D. N. MacCormick 간의 「자발적 의무와 규범적 권한들」('Voluntary Obligation and Normative Powers')에 대한 심포지엄도 참고할 것 (1972년 아리스토텔레스 학회 회보 보충판, 제46권, 59쪽). 공적 권한들(public powers)에 대해서는 G. H. Von Wright, 『규범과 행위(Norm and Action)』(Humanities Press, 1963) 제10장을 참조하고, 또한 Eugenio Bulygin, 「권능 규범들에 관하여」(*On Norms of Competence*) (1992) *Law and Philosophy* 제11권 201쪽도 참고할 수 있다.

32쪽. 법들의 분류법(Taxonomy of laws). 보다 세밀한 분류에 대해서는 A. M. Honoré의 「실질적 법들(Real Laws)」을 참조하라. 이 글은 P. M. S. Hacker와 J. Raz가 편집한 『법, 도덕, 그리고 사회(Law, Morality and Society)』에 수록되어 있다.

38-39쪽. 제재들과 법의 사회적 기능들(Sanctions and the social functions of law). Hans Oberdiek, 「법과 법체계들을 이해하는 데 있어 제재와 강제의 역할」(*The Role of Sanctions and Coercion in Understanding Law and Legal Systems*) (1976) *American Journal of Jurisprudence* 제71권 21쪽 참조. Joseph Raz, 『실천적 이유와 규범』 157-162쪽, John Finnis, 『자연법과 자연권(Natural Law and Natural Rights)』 266-270쪽, Grant Lamond, 「강제와 법의 본성」(*Coercion and the Nature of Law*) (2001) *Legal Theory* 제7권 35쪽, Frederick Schauer, 「Austin이 결국 옳았는가?—법 이론에서 제재의 역할」(*Was Austin Right After All? On the Role of Sanctions in a Theory of Law*) (2010) *Ratio Juris* 제23권 1쪽도 참조할 것. 법이 강제를 ‘허가’ 하는 방식으로 기능한다는 관념에 대해서는 Ronald Dworkin, 『법의 제국(Law's Empire)』 제3장을 참조하라. 특히 92-94쪽을 주목할 것.

38-42쪽. ‘나쁜 사람’의 관점(The 'bad man's' point of view). William Twining, 「‘나쁜 사람’ 다시 보기」(*The Bad Man Revisited*) (1972) *Cornell Law Review* 제58권 275쪽 참조. Stephen Perry는 Hart의 이론이 ‘나쁜 사람’의 관점을 주변화할 자원을 갖추고 있지 않다고 논변한다. 그의 글 「Holmes 대 Hart: 법이론에서의 나쁜 사람」(*Holmes versus Hart: The Bad Man in Legal Theory*)은 Steven J. Burton 편, 『법의 길과 그 영향: 올리버 웬델 홈즈 주니어의 유산』(*The Path of the Law and Its Influence: The Legacy of Oliver Wendell Holmes Jr.*), 캠브리지대 출판부, 2000년에 수록되어 있다. 법을 전적으로 유인 수단(incentivizing device)으로 이해하려는 시도는 특히 경제학자들 사이에서 지속되고 있다. 관련 저작으로는 Richard Posner의 『법경제학(Economic Analysis of Law)』(제8판, Aspen Publishers, 2010)과 『법리학의 문제들(The Problems of Jurisprudence)』(하버드대 출판부, 1990)이 있다. 가장 정교한 논의는 Lewis A. Kornhauser, 「법의 규범성」(*The Normativity of Law*) (1999) *American Law and Economics Review* 제1권 3쪽 참조.

44-49쪽. 법의 원천으로서의 관습(Custom as a source of law). John Gardner, 『신념의 도약으로서의 법(*Law as a Leap of Faith*)』 제3장 「법의 몇몇 유형들(Some Types of Law)」 참조. 또한 Amanda Perreau-Saussine과 James B. Murphy 편집, 『관습법의 본성: 법적·역사적·철학적 관점(*The Nature of Customary Law: Legal, Historical and Philosophical Perspectives*)』(케임브리지대 출판부, 2007)의 수록 논문들도 참고할 것. Dworkin은 Hart가 그의 승인 규칙(rule of recognition) 교설과 일관되게 관습을 설명할 수 없다고 논변한다. 관련 논의는 *Taking Rights Seriously*, 41-44쪽 참조.

IV. 주권자와 수범자(SOVEREIGN AND SUBJECT)

강제적 명령들로서의 법이라는 단순한 모델을 비판하면서, 우리는 지금까지 이 구상(conception)에 따르면 어떤 사회의 법을 구성하는 일반 명령들(general orders)을 내리는 ‘주권자(sov​er​eign)’ 인격 또는 인격들에 관해서는 아무런 문제도 제기하지 않았다. 기실, 위협으로 뒷받침된 명령이라는 관념(idea)이 법의 서로 다른 다양상들(different varieties of law)에 대한 설명으로서 적합한지를 논의함에 있어, 우리는 잠정적으로 다음과 같은 가정을 두었다. 즉, 법이 존재하는 모든 사회에는 실제로 하나의 주권자가 존재하며, 그는 복종의 습관(habit of obedience)을 참조하여(by reference to) 다음과 같이 긍정적·부정적으로 특징지어질 수 있다: 사회의 대다수가 그의 명령들(orders)에 습관적으로 복종하는 반면, 그 자신은 다른 어떤 인격 또는 인격들에게도 습관적으로 복종하지 않는 인격 또는 인격들의 단체(body of persons).

이제 우리는 모든 법체계의 토대들(foundations)에 관한 이 일반 이론을 다소 상세히 검토해야 한다. 극단적으로 단순함에도 불구하고, 주권 교설(doctrine of sovereignty)은 바로 이 일반 이론에 다름 아니기 때문이다. 이 이론은, 법이 존재하는 모든 인간 사회에서는, 민주정이든 절대군주정이든 정치적 형태들의 다양상(variety) 배후에 잠재하여, 습관적 복종을 제공하는 수범자들과 누구에게도 습관적 복종을 제공하지 않는 주권자 사이의 이 단순한 관계가 궁극적으로 발견된다고 단언한다. 이 이론에 따르면, 주권자와 수범자들로 구성된 이러한 수직적 구조는, 법을 보유한 사회에 있어 인간에게 척추가 필수적인 것과 마찬가지로 필수적인 요소이다. 이러한 구조가 현존한다면, 우리는 그 사회를 그 주권자와 함께 하나의 독립된 국가라고 부를 수 있으며, 그 사회의 법(its law)에 대해서도 말할 수 있다. 반대로 이러한 구조가 존재하지 않는 경우에는, 이러한 표현들 가운데 어느 것도 적용할 수 없는데, 이는 주권자와 수범자의 관계가 이 이론에 따르면 그러한 표현들의 바로 그 의미의 일부를 구성하기 때문이다.

이 교설에는 특별히 중요한 두 가지 논점이 있으며, 우리는 이 장의 나머지

부분에서 상세하게 추구될 비판의 노선들을 지목하기 위해 여기서 이를 일반적인 용어로 강조하고자 한다. 첫째 논점은 주권자의 법들(sov^{er}ign's laws)이 적용되는 자들에게 (p. 51) 요구되는 전부라고 여겨지는 복종의 습관(a habit of obedience)이라는 관념에 관한 것이다. 여기서 우리는 그러한 습관이 대부분의 법체계의 두 가지 두드러진 특징 – 즉 서로 다른 입법자들의 승계 속에서 보유되는 입법 권위(authority to make law)의 계속성(continuity)과, 그 법들을 만든 자와 그에게 습관적 복종(habitual obedience)을 제공했던 자들이 사망한 이후에도 법들이 존속하는 지속성(persistence) – 을 설명하기에 충분한지 여부를 검토할 것이다. 둘째 논점은 법 위에 존재하는 주권자의 지위(position)에 관한 것이다. 그는 타인들을 상대로 법을 창출하고 그리하여 그들에게 법적 책무들 또는 '제한들(limitations)' 을 부과하는 반면, 그 자신은 법적으로 무제한적이며 제한 불가능한(legally unlimited and illimitable) 존재로 간주된다. 여기서 우리는 최고 입법자(supreme lawgiver)의 이러한 법적으로 제한 불가능한 지위가 법의 존재(existence of law)에 필수적인지 여부, 그리고 입법 권한(legislative power)에 대한 법적 한계들(legal limits)의 존재 또는 부재가, 이 이론이 이러한 관념들을 습관과 복종이라는 단순한 용어로 분석하는 방식 속에서 이해될 수 있는지를 검토할 것이다.

1. 복종의 습관과 법의 계속성

복종(obedience)이라는 관념은, 엄밀한 검토 없이 사용되는 다른 많은 겉보기에는 단순한 관념들과 마찬가지로, 복잡성으로부터 자유롭지 않다. 우리는 이미 지적된 복잡성¹, 즉 '복종'이라는 단어가 종종 위협으로 뒷받침된 명령들에 대한 단순한 준수(compliance)만이 아니라 권위에 대한 존중을 시사한다는 점은 여기서 논외로 하겠다. 그럼에도 불구하고, 한 사람이 다른 사람에게 대면하여 단일한 명령(single order)을 내리는 경우조차도, 특정된 행위(specified act)의 수행(performance)이 복종을 구성하기 위해서는 그 명령의 제시와 그 행위의 수행 사이에 어떠한 정확한 연결이 존재해야 하는지를 명확히 진술하기는 쉽지

¹위 19쪽 참조.

않다. 예컨대, 명령을 받은 사람이 어떠한 명령도 없었더라도 바로 그 동일한 일을 확실히 했을 것이라는 사실이, 사실로서 그러한 경우, 어떠한 관련성을 가지는가? 이러한 어려움은 특히 법들의 경우에 더욱 첨예하게 나타나는데, 그중 일부는 많은 사람들이 애초에 할 생각조차 하지 않았을 행위를 금지하기 때문이다. 이러한 어려움들이 해소될 때까지는, 한 나라의 법들에 대한 ‘일반적 복종의 습관(*general habit of obedience*)’이라는 전체적 관념은 다소 불분명한 상태로 남을 수밖에 없다. 그러나 우리의 현재 목적을 위해서는, ‘습관’과 ‘복종’이라는 단어들이 비교적 분명하게 적용될 수 있다고 인정될 법한 매우 단순한 사례를 상정해 볼 수 있을 것이다.

(p. 52) 우리는 다음과 같은 상황을 가정해 보자. 어떤 영토에 인구가 거주하고 있고, 그곳에서는 절대군주인 렉스(Rex)가 매우 오랜 기간 동안 통치하고 있다. 그는 위협으로 뒷받침된 일반 명령들로 자기 인민을 통제하며, 그들이 그렇지 않았다면 하지 않았을 여러 행위를 하도록 요구하고, 또 그렇지 않았다면 했을 행위를 하지 않도록 요구한다. 통치 초기에는 혼란이 있었으나, 오래전에 사태는 안정되었고, 일반적으로 사람들은 그에게 복종할 것이라고 기대할 수 있다. Rex가 요구하는 내용은 종종 부담스러운 것이며, 불복종하고 처벌을 감수하고자 하는 유혹도 상당하기 때문에, 일반적으로 복종이 제공된다 하더라도 그것이 이 단어의 온전한 의미나 가장 통상적인 의미에서의 ‘습관(*habit*)’ 또는 ‘습관적인(*habitual*)’ 복종이라고 보기는 어렵다. 사람들은 기실 어떤 법들을 준수하는 습관을 문자 그대로 획득할 수 있다. 예컨대 영국인에게 도로의 좌측으로 운전하는 것은 그러한 획득된 습관의 전형적인 사례일 것이다. 그러나 세금 납부를 요구하는 법들처럼 강한 성향에 반하는 경우에는, 우리가 결국 그러한 법들을 준수하더라도, 심지어 그 준수가 반복적으로 일양적인 준수(*regular compliance*)라 하더라도, 그 준수는 습관이 지니는 무반성적이고, 노력이 들지 않으며, 몸에 배어 있는 성격을 갖지 않는다. 그럼에도 불구하고 Rex에게 제공되는 복종은 흔히 이러한 습관적 요소를 결여하고 있을지라도, 다른 중요한 요소들은 지니게 된다. 어떤 사람이 예컨대 아침 식사 때 신문을 읽는 습관을 가지고 있다고 말하는 것은, 그가 상당한 기간 동안 그렇게 해왔고, 또한 그러한 행위를 반복할 개연성이 있다는(*likely*) 것을 함축한다. 그렇다면

상정된 이 공동체의 대부분의 사람들에게 대하여, 초기의 혼란기를 지난 어느 시점 이후에는, 그들이 일반적으로 Rex의 명령들에 복종해 왔고 앞으로도 계속하여(continue) 그렇게 할 개연성이 있다는(likely) 점은 참일 것이다.

여기서 주목할 점은, Rex의 통치 하에서의 이 사회적 상황에 대한 설명에 따르면, 복종의 습관(habit of obedience)은 Rex와 각 수범자 간의 인격적 관계(personal relationship)라는 점이다. 각자는, Rex가 자신을 포함한 여러 사람에게 하라고 명령하는 바에 반복적으로 일양적인 복종을 한다(regularly). 우리가 “이 인구 전체(population)가 그런 습관을 갖고 있다”고 말할 경우, 이는 “사람들이 토요일 밤마다 주점에 가는 습관이 있다”고 말할 때와 마찬가지로, 단지 대다수 사람들의 습관이 수렴한다(convergent)는 의미일 뿐이다. 즉, 그들 각각이 Rex에게 습관적으로 복종하듯, 각각이 토요일 밤마다 습관적으로 주점에 가는 것일 수 있다.

이 매우 단순한 상황에서는, 공동체가 Rex를 주권자로 성립시키기 위해 요구되는 것은 오직 인구 구성원들 편에서의 개인적 복종 행위(personal acts of obedience)뿐이라는 점에 유의할 필요가 있다. 각 개인은 자기 몫으로 단지 복종하기만 하면 되고, (p. 53) 반복적으로 일양적인 복종이 제공되기만 한다면(regularly), 공동체의 누구도 자기 자신의 복종이나 타인의 Rex에 대한 복종이 어떤 의미에서 옳은지(right), 적절한지(proper), 또는 정당하게 요구되는 것인지(legitimately demanded)에 관하여 어떠한 견해를 가질 필요도, 그것을 표현할 필요도 없다. 분명히 우리가 묘사한 이 사회는 복종의 습관(habit of obedience)이라는 관념에 가능한 한 문자 그대로 적용하기 위해 설정된, 매우 단순한 사회이다. 이는 아마도 실제로는 어디에서도 존재한 적이 없을 만큼 지나치게 단순한 사회일 가능성이 크며, 또한 결코 원시 사회도 아니다. 왜냐하면 원시 사회는 Rex와 같은 절대적 통치자들(absolute rulers)을 거의 알지 못하고, 그 구성원들 역시 단지 복종하는 데에만 관심을 두기보다는, 관련된 모든 사람들 편에서의 복종이 옳은지에 관하여 뚜렷한 견해를 가지는 것이 보통이기 때문이다. 그럼에도 불구하고, Rex의 지배하에 있는 이 공동체는 적어도 Rex의 생존 기간 동안에는 법에 의해 지배되는 사회가 지니는 몇 가지 중요한 표지들을 분명히 갖추고 있다. 이 공동체는 심지어 일정한 통일성(unity)도 지니고 있어서 ‘국가

(state)’ 라고 불릴 수도 있다. 이러한 통일성은 구성원들이 그렇게 하는 것이 옳은지에 대한 견해를 전혀 갖지 않을 수 있음에도, 모두가 동일한 한 사람에게 복종한다는 사실에 의해 구성된다.

이제 성공적인 통치 이후 Rex가 사망하고, 그의 아들 Rex 2세가 남아 일반 명령들(general orders)을 발하기 시작했다고 가정해 보자. Rex 1세의 생전 동안 그에게 복종의 일반적인 습관(general habit of obedience)이 존재했다는 사실만으로는, 그것만으로 Rex 2세 역시 습관적으로 복종을 받으리라는 점을 개연성 있게 만들지도(render probable) 않는다. 따라서 우리가 Rex 1세에 대한 복종의 사실과, 그가 계속하여(continue) 복종을 받을 개연성(likelihood)만을 근거로 삼는다면, Rex 1세의 마지막 명령에 대해서는 말할 수 있었던 것—즉 그것이 주권자(sovverign)에 의해 내려졌고 따라서 법(law)이었다는 점—을 Rex 2세의 첫 번째 명령에 대해서는 말할 수 없게 된다. 아직 Rex 2세에 대한 확립된 복종의 습관이 존재하지 않기 때문이다. 우리는 이 이론에 따르면, Rex 2세가 이제 주권자이며 그의 명령들이 법이라고 말할 수 있으려면, 그의 부친에게 그랬던 것처럼 Rex 2세에게도 복종이 실제로 제공될 것인지를 기다려 보아야 한다. 출발 시점에서 그를 주권자로 만들어 주는 것은 아무것도 없다. 그의 명령들이 일정 기간 동안 복종을 받아 왔다는 사실을 알게 된 이후에야 비로소, 복종의 습관이 확립되었다고 말할 수 있을 것이다. 그때가 되어서야, 그리고 그때에 이르러서야, 우리는 이후에 내려지는 어떤 명령에 대해서도 그것이 발해지는 즉시, 그리고 실제로 복종되기 이전에도 이미 법이라고 말할 수 있게 된다. 이 단계에 도달하기 전까지는, 어떠한 법도 제정될 수 없는 공백기(interregnum)가 존재하게 된다.

이러한 사태는 물론 가능하며 혼란의 시기에는 때때로 현실화되기도 했다. 그러나 계속성 단절(discontinuity)의 위험은 분명하며, 보통은 이를 감수하려 하지 않는다. 그 대신, (p. 54) 절대군주제하에서도 법체계(legal system)의 특징은 한 입법자에서 다른 입법자로의 이행을 연결하는 규칙들에 의해 법창출 권한(law-making power)의 중단 없는 계속성(uninterrupted continuity)을 확보하는 데 있다. 이러한 규칙들은 미리(in advance) 승계를 규율하며, 입법자를 특정 개인으로 지명하거나, 보다 일반적인 방식으로 그 자격요건들과 입법자를

결정하는 방식을 특정한다. 현대 민주국가에서는 이러한 자격요건들이 매우 복잡하고 구성원이 빈번히 교체되는 입법부의 구성과 관련되지만, 계속성을 위해 요구되는 규칙들의 본질은 우리가 상정한 가상의 군주제에 적합한 보다 단순한 형태에서도 확인될 수 있다. 만약 규칙이 장자의 승계를 규정한다면, Rex 2세는 부친의 뒤를 이을 권원(title)을 가진다. 그는 부친의 사망 시 법을 제정할 권리(right)를 가지며, 그의 첫 명령들(first orders)이 발해질 때에는 그 개인과 수범자들 사이에 습관적 복종(habitual obedience)의 관계가 성립할 시간이 아직 없었더라도, 그것들이 이미 법이라고 말할 좋은 이유(good reason)가 있을 수 있다. 기실 그러한 관계는 끝내 성립하지 않을 수도 있다. 그럼에도 그의 말은 법이 될 수 있다. 왜냐하면 Rex 2세는 첫 명령들을 발한 직후 곧바로 사망할 수도 있으며, 그는 복종을 받으며 살 기회를 갖지 못했더라도 법을 제정할 권리를 가졌고, 그의 명령들은 법일 수 있기 때문이다.

개별 입법자들(individual legislators)의 교체되는 승계를 통해 법창출 권한(law-making power)의 계속성을 설명할 때, ‘승계 규칙(rule of succession)’, ‘권원(title)’, ‘승계할 권리(right to succeed)’, ‘법을 제정할 권리(right to make law)’와 같은 표현을 사용하는 것은 자연스럽다. 그러나 분명한 것은, 이러한 표현들과 함께 우리는 새로운 요소들의 집합을 도입하게 되며, 주권 이론(theory of sovereignty)의 처방을 따라 Rex 1세의 단순한 법적 세계를 구성할 때 사용했던 일반 명령들(general orders)에 대한 복종의 습관들(habits of obedience)의 관점에서는 이 요소들을 전혀 설명할 수 없다는 점이다. 왜냐하면 그 세계에는 규칙들이 존재하지 않았고, 따라서 권리들이나 권원들도 존재하지 않았으며, 그러므로 더더군다나(a fortiori) 승계할 권리나 권원은 존재하지 않았기 때문이다. 그곳에는 단지 Rex 1세가 명령들을 발했고, 그의 명령들이 습관적으로 복종되었다는 사실들만이 있었다. 그의 생존 기간 동안 Rex를 주권자로 구성하고 그의 명령들을 법으로 만드는 데에는 그 이상이 필요하지 않았지만, 이것만으로는 그의 승계자의 권리들(rights)을 설명하기에는 충분하지 않다. 실제로, 습관적 복종이라는 관념은 한 입법자가 다른 입법자를 승계할 때 모든 정상적인 법체계(normal legal system)에서 관찰되는 계속성(continuity)을 두 가지 서로 연관되지만 구별되는 방식으로 설명하지 못한다. 첫째, 한 입법자가

발한 명령들에 대한 단순한 복종의 습관들만으로는 (p. 55) 새로운 입법자에게 구(舊) 입법자를 승계하여 그의 자리에 서고 명령들을 발할 어떤 권리(right)도 부여할 수 없다. 둘째, 구(舊) 입법자에 대한 습관적 복종만으로는 새로운 입법자의 명령들에 복종이 이루어질 것이라는 점을 그 자체로 개연성 있게 만들거나 (render probable), 그러한 추정(presumption)을 기초지을 수 없다. 만약 승계의 순간에 이러한 권리와 이러한 추정이 존재하려면, 이전 입법자의 통치 기간 동안 사회 어딘가에는 복종의 습관이라는 용어로 설명될 수 있는 어떠한 실천보다도 더 복잡한 일반적 사회적 실천(general social practice)이 존재했어야 한다. 즉, 새로운 입법자가 그 아래에서 승계할 권리를 부여받는 규칙의 수용(acceptance of the rule)이 있었어야 한다.

그렇다면 이러한 더 복잡한 실천(more complex practice)이란 무엇인가? ‘규칙의 수용(acceptance of a rule)’이란 무엇인가? 여기서 우리는 제1장에서 이미 개괄해 두었던 탐구를 다시 이어가야 한다. 이 질문에 답하기 위해 우리는 한동안 법규칙의 특수한 경우에서 벗어나야 한다. 습관(habit)과 규칙(rule)은 어떻게 다른가? 사람들이 토요일 밤마다 영화관에 가는 습관이 있다고 말하는 것과, 교회에 들어설 때 남성은 반드시 모자를 벗어야 한다는 규칙이 있다고 말하는 것 사이에는 어떤 차이가 있는가? 우리는 이미 제1장에서 이러한 유형의 규칙을 분석하기 위해 반드시 도입되어야 할 몇 가지 요소들을 언급한 바 있으며, 이제는 그 분석을 한 걸음 더 진전시켜야 할 것이다.

사회적 규칙과 습관 사이에는 확실히 하나의 유사점이 존재한다. 두 경우 모두에서 문제 되는 행위(예: 교회에서 모자를 벗는 행위)는 일반적이어야 하지만 반드시 불변적일 필요는 없다. 즉, 기회가 생기면 대다수 집단 구성원이 그 행위를 반복한다는 점에서 “그들은 그것을 대체로(as a rule) 한다”고 말하는 표현은 바로 이 의미를 담고 있다. 하지만 이러한 유사성이 있음에도 불구하고, 양자 사이에는 세 가지 중요한 차이점이 있다.

첫째, 집단이 어떤 습관(habit)을 갖고 있다고 하기 위해서는, 단지 그들의 행동이 실제로 수렴하면(converge) 충분하다. 즉, 반복적으로 일양적인 흐름(regular course)에서 벗어나는 일이 있어도 그것이 어떤 비판의 대상이 될 필요는 없다. 그러나 행동의 일반적 수렴 또는 일치만으로는, 그 행동을 요구하는

규칙이 존재한다고 말하기에 충분하지 않다. 규칙이 있는 경우에는, 그로부터의 이탈은 일반적으로 과오(lapse) 또는 잘못(fault)으로 간주되어 비판의 대상이 되고, 이탈이 예상될 경우 부합에 대한 압력(pressure for conformity)을 받는다. 이러한 비판과 압력의 양상은 규칙의 유형에 따라 다양하다.

둘째로, 그러한 규칙들이 존재하는 경우에는, 실제로 그러한 비판이 이루어질 뿐만 아니라, 그 기준에서의 이탈 자체가 일반적으로 그러한 비판을 제기하기 위한 하나의 좋은 이유(good reason)로 받아들여진다. 기준에서의 이탈에 대한 비판은 (p. 56) 이와 같은 의미에서 정당하거나(legitimate) 정당화된(justified) 것으로 간주되며, 이탈이 예상될 때 그 기준을 준수하라는 요구(demands for compliance) 역시 마찬가지로 정당하거나 정당화된 것으로 간주된다. 더 나아가, 완고한 소수의 위반자들(hardened offenders)을 제외하면, 이러한 비판과 요구는 그것을 제기하는 사람들뿐만 아니라 그것을 받는 사람들에게 의해서도 일반적으로 정당한 것으로, 또는 좋은 이유에 근거한 것으로 받아들여진다. 이러한 여러 방식으로 집단 구성원들 중 몇 명이, 그리고 얼마나 자주 또 얼마나 오랫동안, 반복적으로 일양적인 행태 양식(regular mode of behaviour)을 비판의 기준(standard of criticism)으로 취급해야 비로소 그 집단이 하나의 규칙(rule)을 가지고 있다고 말할 수 있는지는 명확히 정해진 문제가 아니다. 이는 사람이 대머리라고 불릴 수 있으면서도 머리카락을 몇 가닥이나 가질 수 있는지에 관한 문제와 마찬가지로, 우리를 지나치게 괴롭힐 필요는 없다. 우리가 기억해야 할 것은, 어떤 집단이 특정한 규칙을 가지고 있다는 진술은, 그 규칙을 위반할 뿐만 아니라 그 규칙을 자기 자신이나 타인에 대해 기준으로 보기를 거부하는 소수가 존재하는 것과도 양립 가능하다는 점이다.

사회적 규칙(social rules)을 습관(habits)과 구별하는 세 번째 특징은 이미 앞에서 말한 내용 속에 암묵적으로 포함되어 있지만, 법리학에서 매우 중요함에도 불구하고 자주 간과되거나 잘못 표상되어 온 것이므로 여기서 이를 좀 더 상세히 설명하고자 한다. 이 특징을 우리는 이 책 전반에 걸쳐 규칙의 내부 측면(internal aspect)이라고 부를 것이다. 어떤 습관이 사회 집단 내에서 일반화되어 있을 때, 이러한 일반성은 그 집단 구성원 대다수의 관찰 가능한 행동에 관한 하나의 사실에 불과하다. 그러한 습관이 존재하기 위해서는, 집단의 구성원들 중 누

구도 그 일반적인 행동을 어떤 방식으로든 의식할 필요가 없고, 나아가 문제의 행동이 일반적이라는 사실을 알 필요조차 없다. 더더욱 그 행동을 가르치거나 유지하려고 노력하거나 의도할 필요도 없다. 각자가 다른 사람들도 실제로 그렇게 행동하고 있다는 점에서 자신 또한 그렇게 행동하기만 하면 충분하다. 이에 반해, 사회적 규칙이 존재하려면 적어도 일부 구성원들은 문제의 행동을 집단 전체가 따라야 할 일반적 기준(*general standard*)으로 간주해야 한다. 사회적 규칙은 사회적 습관과 공유하는 외부 측면(*external aspect*), 즉 관찰자가 기록할 수 있는 반복적으로 일양적인 행동(*regular uniform behaviour*)이라는 측면에 더하여, 이러한 ‘내부’ 측면을 함께 가진다.

이러한 규칙의 내부 측면은 어떤 게임의 규칙에서 쉽게 예시할 수 있다. 체스 플레이어들은 단지 외부 관찰자가 그들이 둔 수들에 대한 그들의 태도를 전혀 모르더라도 기록할 수 있을 정도로, 같은 방식으로 퀸을 움직이는 유사한 습관들만 갖고 있는 것이 아니다. 이에 더해, (p. 57) 그들은 이 행동 양식에 대해 성찰적이고 비판적인 태도를 취한다. 즉, 그것을 체스를 두는 사람 모두가 따라야 할 기준으로 본다. 각자는 단지 스스로 퀸을 일정한 방식으로 움직이는데 그치지 않고, 모두가 그런 방식으로 퀸을 움직이는 것이 적절한지(*propriety*)에 관한 견해를 가진다. 이러한 견해는, 이타이 실제로 일어나거나 예고될 때 타인을 비판하고 그에게 부합을 요구하는 방식으로 표현되며, 다른 사람이 자신에게 비판이나 요구를 할 때 이러한 비판과 요구의 정당성을 인정하는 방식에서도 드러난다. 이러한 비판, 요구, 인정(*acknowledgements*)의 표현에는 다양한 규범적 언어(*normative language*)가 사용된다. 예컨대 “퀸을 그렇게 움직이면 안 됐어(I/You ought not to have moved the Queen like that)”, “그렇게 해야 해(I/You must do that)”, “그건 옳아(That is right)”, “그건 그르다(That is wrong)” 등이 이에 해당한다.

규칙의 내부 측면(*internal aspect*)은 종종 외부에서 관찰 가능한 물리적 행동(*physical behaviour*)에 대비되는 단순한 ‘감정(*feelings*)’의 문제로 잘못 표상된다. 물론 규칙이 어떤 사회 집단에 의해 일반적으로 수용되고, 사회적 비판과 부합을 요구하는 압력에 의해 일반적으로 지지되는 경우, 개인들은 제약(*restriction*)이나 강제(*compulsion*)의 경험과 유사한 심리적 경험을 흔히

가질 수 있다. 사람들이 자신이 특정한 방식으로 행동하도록 ‘구속되어 있다고 느낀다(feel bound)’고 말할 때, 기실 이러한 경험들을 가리키고 있을 수도 있다. 그러나 이러한 감정들은 ‘구속력 있는(binding)’ 규칙들의 존재를 위해 필요조건도 아니고 충분조건도 아니다. 사람들이 특정한 규칙을 수용하면서도 그러한 강제의 감정을 전혀 경험하지 않는다고 말하는 데에는 아무런 모순도 없다. 필요한 것은, 일정한 행동 패턴(patterns of behaviour)을 공동의 기준(common standard)으로 간주하는 비판적·성찰적 태도가 존재하는 것이며, 이러한 태도가 비판(자기비판을 포함하여), 부합 요구(demands for conformity), 그리고 그러한 비판과 요구가 정당화된다는 인정(acknowledgements) 속에서 드러나는 것이다. 이 모든 것은 ‘~해야 한다(ought)’, ‘~해야만 한다(must)’, ‘~하는 것이 당연하다(should)’, ‘옳다(right)’와 ‘그르다(wrong)’라는 규범적 용어(normative terminology)에서 그 특유한 표현을 발견한다.

이것들이 바로 사회적 규칙(social rules)을 단순한 집단적 습관(mere group habits)과 구별하는 핵심적 특징들이며, 이러한 점들을 염두에 두고 우리는 다시 법으로 돌아갈 수 있다. 우리는 우리의 사회 집단이 교회에서 모자를 벗는 것에 관한 규칙처럼 특정한 유형의 행위를 기준(standard)으로 만드는 규칙들뿐만 아니라, 일정한 사람의 말—구두로 표현되었든 문서로 표현되었든—을 참조함으로써(by reference to) 보다 간접적인 방식으로 행위의 기준을 식별하도록 하는 규칙을 가지고 있다고 가정할 수 있다. 가장 단순한 형태에서 이러한 (p. 58) 규칙은, Rex가 (아마도 일정한 형식적 방식으로) 특정하는(specifies) 어떠한 행위들이 행해져야 한다는 내용일 것이다. 이는 우리가 처음에 Rex에 대한 단순한 복종의 습관이라는 관점에서 묘사했던 상황을 변형시킨다. 왜냐하면 이러한 규칙이 수용되는 경우, Rex는 단지 사실상 무엇을 해야 하는지를 특정하는 데 그치지 않고, 그렇게 할 권리(the right)를 가지게 되며, 그의 명령들에 대한 일반적인 복종이 존재할 뿐 아니라, 그에게 복종하는 것이 옳다(right)(it is right to obey him)는 점 또한 일반적으로 수용되기 때문이다. Rex는 사실상 입법할 권위(authority)를 가진 입법자(legislator)가 되며, 즉 집단의 삶 속에 새로운 행위 기준들(standards of behaviour)을 도입하는 권위를 갖게 된다. 그리고 이제 우리가 ‘명령들’이 아니라 기준들(standards)을 다루고 있는 이상, 그가

자신의 입법에 의해 구속되어서는 안 될 이유는 전혀 없다.

이러한 입법적 권위(legislative authority)의 기초를 이루는 사회적 실천들(social practices)은 교회에서 모자를 벗는 행위에 관한 규칙과 같은 단순하고 직접적인 행위 규칙들(simple direct rules of conduct)의 기초를 이루는 실천들과, 모든 본질적인 점들에서 동일하다. 우리는 이제 그러한 규칙들을 단순한 관습 규칙들(mere customary rules)로 구별할 수 있으며, 그것들은 일반적 습관(general habits)과도 같은 방식으로 구별된다. 이제 Rex의 말(word)은 행위의 기준이 되어, 그가 지정한(designates) 행위로부터의 이탈은 비판의 대상이 될 수 있으며; 그의 말은 일반적으로 비판과 준수 요구(demands for compliance)를 정당화하는 것으로 참조되고 수용될 것이다.

이러한 규칙들이 입법적 권위의 계속성(continuity of legislative authority)을 어떻게 설명하는지를 이해하기 위해서는, 어떤 경우에는 새로운 입법자가 실제로 입법을 시작하기도 전에, 그에게 하나의 부류(class) 또는 계열(line)에 속한 사람으로서 자기 차례에 이를 할 권리(right)를 부여하는 확고히 확립된 규칙이 존재한다는 점에 주목하기만 하면 된다. 예컨대 Rex 1세의 생존 기간 동안, 집단 전체에 의해 일반적으로 수용되는 바에 따르면, 그 말(word)이 복종의 대상이 되는 사람은 개별 인물 Rex 1세에 한정되는 것이 아니라, 일정한 방식으로 자격을 갖춘 사람, 예컨대 특정 조상의 직계(line)에 있는 생존한 최연장 후손으로서 그 시점에 자격을 갖춘 바로 그 사람이라는 것이다. Rex 1세는 단지 특정한 시점에 그러한 자격을 갖춘 특정 인물에 불과하다. 이러한 규칙은 Rex 1세에게 복종하는 습관과는 달리, 현재의 실제 입법자뿐만 아니라 장차 가능하게 등장할 미래의 입법자들까지 가리킨다(refer to)는 점에서 미래를 향해 있다.

이러한 규칙의 수용(acceptance), 그리고 따라서 그 존재(existence)는 Rex 1세의 생존 기간 동안 부분적으로는 그에 대한 복종을 통해 드러나지만, 또한 일반 규칙(general rule)에 따른 그의 자격(qualification)에 의해 복종이 그가 권리를 가진 어떤 것이라는 점에 대한 인정(acknowledgements)을 통해서도 드러난다. (p. 59) 어떤 집단에 의해 특정 시점에 수용된 규칙의 범위(scope)가 이와 같은 방식으로 미래를 향해 입법자 공직(office of legislator)의 승계자들을 일반적 용어로 포괄할 수 있다는 바로 그 이유 때문에, 그 규칙의 수용은 승계자가

실제로 입법을 시작하기 이전부터 입법할 권리(right to legislate)를 가진다는 법적 진술(statement of law)에 대해서도, 그리고 그가 전임자와 동일한 복종을 받을 개연성이 있다는(likely) 사실 진술(statement of fact)에 대해서도 둘 모두(both)에 대한 근거(grounds)를 제공한다.

물론, 어떤 사회가 어느 한 시점에서 규칙을 수용한다고 해서 그 규칙의 계속 존재(continued existence)가 보장되는(guarantee) 것은 아니다. 혁명이 일어날 수 있으며, 그 사회가 해당 규칙을 더 이상 수용하지 않게 될 수도 있다. 이는 한 입법자, Rex 1세의 생존 기간 중에 발생할 수도 있고, 새로운 입법자 Rex 2세로의 이행 시점에서 발생할 수도 있으며, 만약 그러한 일이 발생한다면 Rex 1세는 입법할 권리(right to legislate)를 상실하게 되거나, Rex 2세는 그 권리를 취득하지 못하게 된다. 상황이 불분명해질 수도 있다는 점은 사실이다. 즉, 단순한 봉기(insurrection)나 기존 규칙의 일시적 중단(temporary interruption)에 직면해 있는 것인지, 아니면 그것의 전면적이고 실효적인 포기(full-scale effective abandonment)에 직면해 있는 것인지가 명확하지 않은 중간적이고 혼란스러운 단계가 존재할 수 있다. 그러나 원칙적으로 이 문제는 분명하다. 새로운 입법자가 입법할 권리를 가진다는 진술(statement)은, 그가 그 권리를 가지게 하는 규칙이 사회 집단 내에 존재함을 전제한다. 만약 현재 그에게 자격을 부여하는 규칙이, 동일하게 그의 전임자에게도 자격을 부여했던 것으로서, 전임자의 생존 기간 동안 수용되었음이 분명하다면, 반대 증거가 없는 한, 그 규칙은 포기되지 않았으며 여전히 존재하고 있다고 가정되어야 한다. 유사한 계속성은 경기(game)에서도 관찰된다. 즉, 득점 기록자는 지난 이닝(last innings) 이후 경기 규칙이 변경되었다는 증거가 없는 한, 새로운 타자가 올린 득점(runs)을 통상적인 방식으로 산정하여 그에게 인정한다.

Rex 1세와 Rex 2세의 단순한 법적 세계를 고찰하는 것만으로도, 대부분의 법체계를 특징짓는 입법 권위(legislative authority)의 계속성이 한 규칙의 수용을 구성하는 사회적 실천의 한 형태에 의존하며, 우리가 이미 지목한 방식들에서 단순한 습관적 복종의 사실들과는 구별된다는 점을 보여주기에 충분할 것이다. 논증은 다음과 같이 요약될 수 있다. Rex와 같이 그의 일반적 명령들이 습관적으로 복종되는 사람이 입법자(legislator)라 불릴 수 있고 그의 명령들이

법이라 불릴 수 있다는 점을 우리가 인정하더라도(*concede*), 그러한 입법자들 각각에 대한 복종의 습관들만으로는 승계자(*successor*)가 승계할 권리(*right*)와 그에 따른 입법 권한(*legislative power*)의 계속성을 설명하기에 충분하지 않다. 첫째, (p. 60) 습관은 ‘규범적이지(*normative*)’ 않다. 즉, 그것들은 누구에게도 권리(*rights*)나 권위(*authority*)를 부여할 수 없다. 둘째, 한 개인에 대한 복종의 습관들은, 수용된 규칙들(*accepted rules*)과는 달리, 현재의 입법자뿐만 아니라 장차 이어질 승계 입법자들의 부류나 계열(*class or line of future successive legislators*)을 가리키거나(*refer to*), 그들에게 복종이 제공될 것이라는 점을 개연성 있는 것으로 만들 수 없다(*likely*). 따라서 한 입법자에 대한 습관적 복종이 존재한다는 사실은, 그의 승계자가 입법할 권리를 가진다는 진술(*statement*)에 대해서도, 그가 실제로 복종을 받을 개연성이 있다는(*likely*) 사실 진술(*factual statement*)에 대해서도, 아무런 근거(*grounds*)를 제공하지 않는다.

그러나 이 지점에서, 우리가 뒤의 장에서 충분히 전개할 중요한 논점 하나를 주목하지 않을 수 없다. 이는 오스틴의 이론이 지니는 강점 가운데 하나를 이룬다. 수용된 규칙들(*accepted rules*)과 습관들(*habits*) 사이의 본질적 차이를 드러내기 위해 우리는 매우 단순한 형태의 사회를 가정해 왔다. 주권(*sovereignty*)의 이 측면을 떠나기 전에, 입법할 권위를 부여하는 규칙(*rule conferring authority to legislate*)의 수용에 대한 우리의 설명이 현대 국가(*modern state*)에 어느 정도까지 적용될 수 있을지 검토해야 한다. 우리의 단순한 사회를 언급하면서 우리는 마치 대부분의 일반 시민들이 법에 단지 복종할 뿐만 아니라, 잇따른 입법자들이 입법할 자격을 갖추게 하는 규칙(*rule qualifying a succession of lawgivers to legislate*)을 이해하고 수용하고 있는 것처럼 말했다. 단순한 사회에서는 이것이 사실일 수 있다. 그러나 현대 국가에서는, 아무리 법을 잘 지키는(*law-abiding*) 사람들이라 하더라도, 입법할 권리를 가진, 계속해서 변화하는 인격들의 단체(*body of persons*)의 자격요건들(*qualifications*)을 특정하는 규칙들에 대해 인구 대다수가 명확한 인식을 가지고 있다고 생각하는 것은 터무니없을 것이다. 어떤 소규모 부족의 구성원들이 대대로 이어지는(*successive*) 추장들에게 권위를 부여하는 규칙을 수용하는 것과 동일한 방식으로, 대중이 이러한 규칙들을 ‘수용한다(*accept*)’고 말하는 것은, 보통의 시민들이 실제로는 갖고 있지 않을지도

모르는 헌법적 사안에 대한 이해를 그들의 머릿속에 부여하는 것을 함의하게 된다. 우리는 이러한 이해를 체계의 공무담당자들 또는 전문가들에게만 요구하면 된다. 즉, 법이 무엇인지를 결정할 책임(responsibility)을 부여받은 법원(courts)과, 일반 시민이 법이 무엇인지 알고자 할 때 자문하는 법률가들(lawyers)이 그것이다.

단순한 부족 사회와 현대 국가 사이의 이러한 차이들은 주목할 가치가 있다. 그렇다면, 승계적으로 교체되는 입법자들의 변화 속에서도 보존되는 영국 의회 내의 여왕(Queen in Parliament)의 입법적 권위의 계속성을, 일반적으로 수용된 어떤 근본 규칙 또는 규칙들에 기초한 것으로 우리는 어떤 의미에서 이해해야 하는가? 분명히 여기서의 일반적 수용(general acceptance)은 (p. 61) 복합적인 현상으로서, 어떤 의미에서는 공무담당자들과 일반 시민들 사이에 분할되어 있으며, 이들은 서로 다른 방식으로 이에 기여함으로써 법체계의 존재(existence)에 기여한다. 체계의 공무담당자들은 입법 권위를 부여하는 이러한 근본 규칙들을 명시적으로 인정(acknowledge explicitly)한다고 말할 수 있다. 입법자들은 자신들에게 권한을 부여하는(empower) 규칙들에 따라 법들을 제정할 때 그렇게 하고, 법원은 그러한 자격을 갖춘 자들에 의해 제정된 법들을 자신들이 적용할 법들로 식별할(identify) 때 그렇게 하며, 전문가들은 그렇게 제정된 법들을 참조하여 일반 시민들의 행위를 향도할(guide) 때 그렇게 한다. 일반 시민은 이러한 공무담당 작용들(official operations)의 결과에 대한 묵인(acquiescence)을 통해 자신의 수용을 주로 표출한다. 그는 이러한 방식으로 제정되고 식별된 법을 지키고(keeps the law), 그 법에 의해 부여된 청구들(claims)을 제기하며 권한들(powers)을 행사한다. 그러나 그는 그 법의 기원(origin)이나 제정자들(makers)에 대해서는 거의 알지 못할 수도 있다. 어떤 이들은 법들에 대해 그것들이 단지 ‘법(the law)’ 이라는 점 이상을 전혀 알지 못할 수도 있다. 법은 일반 시민들이 하고 싶어 하는 일들을 금지하며(forbids), 그들은 이를 불복종할 경우 경찰관에 의해 체포되고 판사에 의해 징역형에 처해질 수 있다는 사실을 알고 있다. 위협으로 뒷받침된 명령들에 대한 습관적 복종이 법체계의 토대라는 점을 고집하는 이 교설의 강점은, 우리가 법체계의 존재라고 부르는 이 복합적 현상의 상대적으로 수동적인 측면을 현실적인 용어로 사유하

도록 강제한다는 데 있다. 이 교설의 약점은, 체계의 공무담당자나 전문가들의 법창출(law-making), 법식별(law-identifying), 법적용(law-applying) 작용들에서 주로—비록 배타적으로는 아니지만—드러나는, 다른 상대적으로 능동적인 측면을 흐리게 하거나 왜곡한다는 데 있다. 우리가 이 복합적인 사회적 현상을 실제로 그러한 것으로 이해하려면, 이 두 측면을 모두 염두에 두어야 한다.

2. 법의 지속성

1944년, 한 여성은 영국에서 점을 치는 행위로 1735년 제정된 「주술법(Witchcraft Act)」을 위반한 혐의로 기소되어 유죄 판결을 받았다.² 이는 매우 익숙한 법적 현상의 하나를 보여주는 다소 인상적인 사례에 불과하다. 즉, 수세기 전에 제정된 제정법(statute)이 오늘날에도 여전히 법일 수 있다는 것이다. 그러나 이 현상이 아무리 익숙하다고 하더라도, 이러한 방식의 법들의 지속성(persistence of laws)은, (p. 62) 법들을 습관적으로 복종받는 한 인격(person)이 내린 명령들로 파악하는 단순한 도식으로는 이해 가능하게 만들 수 없다. 우리는 여기서 사실상 방금 살펴본 입법 권위의 계속성(continuity) 문제의 역(converse)에 직면해 있다. 앞의 경우에는, 복종의 습관이라는 단순한 도식에 기초하여, 입법자 지위(office)의 승계자(successor)가 제정한 최초의 법이, 그가 개인적으로 아직 습관적 복종을 받기 이전임에도 이미(already) 법이라고 말할 수 있는지가 문제였다. 여기서의 문제는 이와 반대로, 오래전에 사망한 선행 입법자가 제정한 법이, 그에게 습관적으로 복종한다고 말할 수 없는 사회에서 어떻게 여전히(still) 법일 수 있는가 하는 것이다. 첫 번째 경우와 마찬가지로, 우리가 입법자의 생존 기간(lifetime of the legislator)으로 시야를 한정한다면, 이 단순한 도식에는 아무런 어려움도 발생하지 않는다. 기실 그것은 왜 「주술법」이 영국에서는 법이었지만 프랑스에서는 법이 아니었는지를 매우 훌륭하게 설명하는 것처럼 보인다. 설령 그 법의 문언(terms)이 프랑스에서 점을 치는 프랑스 시민에게까지 미쳤다 하더라도 마찬가지이다. 물론 불운하게도 영국 법원에 회부된 프랑스인들에게는 그 법이 적용될 수 있었을 것이다. 이 단순한 설명에 따르면, 영국에서는 이 법을

²R. v. *Duncan*[1944] 1 KB 713.

제정한 자들에 대한 복종의 습관이 존재했으나, 프랑스에서는 그러한 습관이 존재하지 않았다는 것이다. 따라서 이 법은 영국에서는 법이었지만 프랑스에서는 법이 아니었던 것이다.

그러나 우리는 법들을 그 제정자들의 생존 기간으로만 한정하여 볼 수는 없다. 우리가 설명해야 할 특징은 바로 법들이 그 제정자들과 그들에게 습관적으로 복종하던 사람들까지 사라진 이후에도 끈질기게 존속할 수 있는 능력(capacity)에 있기 때문이다. 「주술법」이 동시대의 프랑스인들에게는 법이 아니었다면, 왜 그것이 오늘날 우리에게도 여전히 법인 것인가? 분명히, 아무리 말뜻을 늘려도, 20세기의 영국인들인 우리가 지금 George 2세와 그의 의회(Parliament)에 습관적으로 복종한다고 말할 수는 없다. 이 점에서 오늘날의 영국인들과 당시의 프랑스인들은 동일하다. 즉, 오늘날의 영국인들은 이 법의 제정자에게 습관적으로 복종하지 않고, 당시의 프랑스인들도 그에게 습관적으로 복종하지 않았다. 「주술법」이 이 재위로부터 존속해 온 유일한 제정법(Act)이라고 하더라도, 그것은 오늘날에도 여전히 영국에서 법일 것이다. 이 ‘왜 여전히 법인가?’라는 문제에 대한 해답은, 원칙적으로, 우리가 앞서 제기한 ‘왜 이미 법인가?’라는 첫 번째 문제에 대한 해답과 동일하다. 그것은 주권자인 인격(sov^{er}ign person)에 대한 복종의 습관이라는 지나치게 단순한 관념을, 그들의 말(word)이 사회에서 행동의 기준(standard of behaviour)을 구성하게 되는 자들의 부류(class) 또는 계열(line of persons), 다시 말해 입법할 권리(right)를 가진 자들을 특정하는, 현재 수용된 근본 규칙들(currently accepted fundamental rules)이라는 관념으로 대체하는 것을 포함한다. 그러한 규칙은 비록 현재(now) 존재해야 하지만, 어떤 의미에서는 시간 초월적(timeless)인 참조(reference)를 가질 수 있다. 즉, 그것은 (p. 63) 미래를 향해 장차의 입법자(future legislator)의 입법 작용(legislative operation)을 참조할 뿐만 아니라, 과거를 향해 과거의 입법자(past one)의 작용을 참조할 수도 있다.

Rex 왕조라는 단순한 틀로 제시하면, 상황은 다음과 같다. Rex 1세, 2세, 3세로 이어지는 입법자들의 계열에 속한 각자는, 직계(direct line)에 있는 생존한 최연장 후손에게 입법할 권리를 부여하는 동일한 일반 규칙(general rule)에 따라 자격을 갖추 수 있다. 개별 통치자(individual ruler)가 사망할 때 그의 입법 작업

(legislative work)은 존속한다. 이는 그것이, 각 입법자가 생존해 있던 때마다 사회의 잇따른 세대들(successive generations)이 계속 존중해 온 일반 규칙이라는 토대에 기초해 있기 때문이다. 단순한 사례에서 Rex 1세, 2세, 3세는 모두 동일한 일반 규칙에 따라, 입법을 통해 행동 기준들(standards of behaviour)을 도입할 권리를 부여받는다. 대부분의 법체계에서는 사정이 이처럼 단순하지 않다. 과거의 입법을 법으로 인정하는 현재 수용된 규칙(presently accepted rule)이, 동시대의 입법에 관한 규칙과 서로 다를 수도 있기 때문이다. 그러나 그 기초가 되는 규칙(underlying rule)이 현재 수용되고 있다는 점을 전제로 한다면, 법들의 지속성(persistence of laws)은, 구성원이 변경된 팀들 사이의 토너먼트 첫 라운드에서 내려진 심판의 판정(decision)이, 세 번째 라운드에서 그 자리를 대신한 심판의 판정과 마찬가지로 최종 결과(final result)에 동일한 관련성(relevance)을 갖는다는 사실만큼이나 신비로운 것이 아니다. 그럼에도 불구하고, 신비롭지는 않다 하더라도, 과거와 미래, 그리고 현재의 입법자들의 명령들에까지 권위를 부여하는 수용된 규칙이라는 관념(notion)은, 현재의 입법자에 대한 복종의 습관들(habits of obedience)이라는 관념(idea)보다 분명히 더 복잡하고 정교하다. 그렇다면 이러한 복잡성을 제거하고, 위협으로 뒷받침된 명령들이라는 단순한 구상(conception)을 어떤 기발한 확장(ingenious extension)을 통해 발전시켜, 법들의 지속성이 결국에는 현재의 주권자에 대한 습관적 복종이라는 더 단순한 사실들에 기초하고 있음을 보여줄 수는 없는가?

이를 달성하려는 한 가지 기발한 시도가 제시된 바 있다. 홉스(Hobbes)는, 여기서 벤담(Bentham)과 오스틴에 의해 반복되듯이, “입법자(legislator)란 그의 권위에 의해 법들이 처음 만들어진 자가 아니라, 그의 권위에 의해 그 법들이 지금도 법들로 계속 존재하는(continue to be laws) 자이다”라고 말하였다.³ 규칙의 관념을 배제하고 보다 단순한 습관의 관념을 택한다면, 입법자의 ‘권위(authority)’가 그의 ‘권한(power)’과 구별되어 무엇을 의미할 수 있는지는 즉각적으로 명확하지 않다. 그러나 이 인용문에 표현된 일반적 (p. 64) 논증은 분명하다. 그것은 「주술법」과 같은 법의 원천(source)이나 기원(origin)이 역사적 사실로서 과거의 주권자(past sovereign)의 입법 작용에 있었음에도

³Leviathan, chap. xxvi.

불구하고, 20세기 잉글랜드에서 그 법이 현재 법으로서의 지위(status as law)를 가지는 것은 현재의 주권자에 의해 법으로 인정(recognition)되기 때문이라는 주장이다. 이러한 인정은, 현재 살아있는 입법자들에 의해 제정된 제정법들(statutes)의 경우와 같은 명시적(explicit) 명령의 형태를 취하지 않고, 주권자의 의지의 묵시적(tacit) 표현의 형태를 취한다. 이는, 주권자가 그럴 수 있음에도 불구하고, 오래전에 제정된 그 제정법(statute)을 자신의 대리인들(agents)-법원과 경우에 따라서는 행정부-에 의해 집행되는 것을 방해하지 않는다는 사실로 구성된다.

이는 물론, 어느 누구에 의해서도 어느 시점에서든 명령된 것처럼 보이지 않는 일정한 관습적 규칙들(customary rules)의 법적 지위를 설명하기 위해 원용되었던, 이미 검토된 묵시적 명령들에 관한 동일한 이론이다. 제Ⅲ장에서 우리가 이 이론에 대해 제기한 비판들은, 과거의 입법(past legislation)이 법으로서 계속 인정되는 것(continued recognition)을 설명하는 데 이 이론이 사용될 때 더욱 분명하게 적용된다. 법원이 합당하지 않은(unreasonable) 관습 규칙들을 배제할 수 있는 광범위한 재량(wide discretion)을 부여받고 있기 때문에, 특정 사건에서 법원이 실제로 관습 규칙을 적용하기 전까지는 그것이 법으로서의 지위를 갖지 않는다는 견해에는 어느 정도의 그럴듯함(plausibility)이 있을 수 있다. 그러나 과거의 ‘주권자’에 의해 제정된 제정법(statute)이, 특정 사건에서 법원에 의해 실제로 적용되고, 현재의 주권자의 묵인 아래 집행되기 전까지는 법이 아니라는 견해에는 거의 그럴듯함이 없다. 만약 이 이론이 옳다면, 법원은 그것이 이미 법이기 때문에 집행하는 것이 아니라는 결론이 따라야 한다. 그러나 이러한 결론은, 현재의 입법자가 과거의 제정물들(enactments)을 폐지(repeal)할 수 있었음에도 그 권한(power)을 행사하지 않았다는 사실로부터 도출하기에는 터무니없는(absurd) 추론이다. 빅토리아 시대 제정법들(statutes)과 오늘날 영국 의회 내의 여왕(Queen in Parliament)에 의해 통과된 제정법들은 분명히 현재의 영국에서 정확히 동일한 법적 지위(legal status)를 가진다. 양자는 모두, 그것들이 적용될 사건들이 법원에 제기되기 이전부터 이미 법이다. 그리고 그러한 사건들이 발생했을 때, 법원은 빅토리아 시대 제정법들과 현대 제정법들 모두를, 그것들이 이미 법이기 때문에 적용한다. 어느 경우에서도 이들 법들은

법원에 의해 적용된 이후에야 비로소 법이 되는 것이 아니며, 양 경우 모두에서 그 법으로서의 지위는, 이 법들이 현재 수용된 규칙들에 따라 권위를 가지는 (authoritative) 자들에 의해 제정되었다는 사실에 기인하며, 그 사람들이 생존해 있는지 사망했는지의 여부와는 무관하다.

(p. 65) 과거의 제정법들(past statutes)이 현재 법으로서의 지위를 법원에 의한 적용에 대해 현 입법부가 묵인하고 있기 때문에 갖게 된다는 이론의 비일관성(incoherence)은, 오늘날의 법원들이 폐지되지(repealed) 않은 빅토리아 시대 제정법을 여전히 법으로 취급하는 반면, Edward 7세 치하에서 폐지된 제정법을 더 이상 법이 아닌 것으로 구별해야 하는 이유를 설명하지 못한다는 점에서 가장 분명하게 드러난다. 분명히 이러한 구별을 할 때, 법원들은(그리고 그와 함께 이 체계를 이해하는 법률가나 일반 시민들도) 과거와 현재의 입법 작용을 모두 포괄하는, 무엇이 법으로 간주되어야 하는지를 규정하는 근본 규칙(fundamental rule) 또는 규칙들(rules)을 기준(criterion)으로 사용한다: 그들은 두 제정법들(statutes) 사이의 구별을, 현재의 주권자가 한쪽은 묵시적으로 명령했지만(즉, 집행되도록 허용했지만) 다른 쪽은 그렇지 않았다는 사실에 대한 앎(knowledge)에 기초시키지 않는다.

또, 우리가 배척한 이 이론에서 유일하게 미덕이라고 할 만한 것은 현실주의적 상기(a realistic reminder)의 흐릿한 판본이라는 점뿐인 듯하다. 이 경우 그 상기(reminder)란, 해당 체계의 공무담당자들, 특히 무엇보다도 법원이, 특정한 입법 작용들이 과거이든 현재이든 권위를 가진다는 규칙을 수용하지 않는다면, 법으로서의 지위에 필수적인 어떤 것이 결여될 것이라는 점을 상기시키는 것이다. 그러나 이러한 단조로운 유형의 현실주의는, 그 주요 특징들이 뒤에서 상세히 논의되는⁴ 이른바 법현실주의(Legal Realism)라는 이론으로 과도하게 확대되어서는 안 된다. 이 이론은 일부 버전에서, 어떤 제정법도 법원에 의해 실제로 적용되기 전까지는 어떠한(no) 제정법(statute)도 법이 아니라고 주장한다. 어떤 제정법이 법이 되기 위해서는 법원이 특정한 입법 작용들이 법을 만든다는 규칙을 수용해야 한다는 진실(truth)과 법원이 특정 사건에서 그것을 적용하기 전까지는 아무것도 법이 아니라는 오도된 이론(misleading theory) 사이에는,

⁴아래 136-47쪽 참조.

법을 이해하는 데 있어 핵심적으로 중요한 차이가 있다. 물론 법현실주의 이론의 일부 버전들은, 우리가 비판해 온 법들의 지속성에 대한 거짓 설명보다도 한참 넘어서나. 왜냐하면 그것들은 과거의 주권자에 의해 제정되었든 현재의 주권자에 의해 제정되었든, 법원이 실제로 적용하기 전에는 어떠한 제정법도 법의 지위(status of law)를 가질 수 없다고 전면적으로 부정하기 때문이다. 그러나 완전한 현실주의 이론(full Realist theory)에까지 이르지는 않으면서도, 과거의 주권자와 구별하여 현재의 주권자가 제정한 제정법들은 법원에 의해 적용되기 이전에도 법이라고 인정하는 한편, 법들의 지속성을 설명하려는 이론은 (p. 66) 양쪽 세계의 최악을 취하는 것이며, 분명히 터무니없다. 이러한 중간적 입장은 옹호될 수 없다. 왜냐하면 현재의 주권자가 제정한 제정법의 법적 지위와, 이전 주권자에 의해 제정되었으나 폐지되지 않은 제정법의 법적 지위를 구별할 아무런 근거도 없기 때문이다. 둘 다(보통의 법률가들이 인정하듯이) 법원이 오늘날의 특정 사건에 적용하기 이전부터 법이거나, 아니면 완전한 현실주의 이론이 주장하듯이 둘 다 법이 아니어야 한다.

3. 입법 권한에 대한 법적 제한

주권 교설에서 수범자의 일반적 복종 습관에는, 그 상보물(complement)로서, 주권자에게는 그러한 습관이 없다는 점이 대응한다. 그는 수범자들을 상대로 법을 만들며, 어떠한 법의 바깥에 있는 지위(position outside any law)에서 법을 만든다. 그의 법창출 권한(law-creating power)에는 법적 한계들(legal limits)이 존재하지 않으며, 존재할 수도 없다. 주권자의 권한이 법적으로 무제한이라는 점은 정의상(by definition) 그러하다는 것을 이해하는 것이 중요하다: 이 이론은 단순히 다음을 단언할 뿐이다. 즉, 입법 권한에 법적 한계들이 존재할 수 있는 경우는 오직 그 입법자가 자신이 습관적으로 복종하는 다른 입법자의 명령들 아래 놓여 있을 때뿐이며, 그 경우 그는 더 이상 주권자가 아니라는 것이다. 그가 주권자라면 그는 어떤 다른 입법자에게도 복종하지 않으며, 따라서 그의 입법 권한에는 법적 한계들이 존재할 수 없다. 물론 이 이론의 중요성은, 사실에 관해 아무것도 말해 주지 않는 이러한 정의(definitions)와 그 단순하고 필연적인

귀결들(simple necessary consequences)에 있는 것은 아니다. 그 중요성은, 법이 존재하는 모든 사회에는 이러한 속성(attributes)을 지닌 주권자가 존재한다는 주장(claim)에 있다. 우리는 법적 또는 정치적 형식들의 배후를 들여다볼 필요가 있을지도 모른다. 이 형식들은 모든 법적 권한들이 제한되어 있다는 것과 어떠한 인격이나 인격들도 주권자에게 귀속되는 법 바깥의(outside) 지위를 차지하고 있지 않다는 점을 시사하기 때문이다. 그러나 우리가 단호하게 탐색한다면, 이 이론이 주장하듯이 그러한 형식들의 배후에 실제로 존재하는 현실(reality)을 발견하게 될 것이다.

우리는 이 이론을 실제로 그것이 주장하는 바보다 더 약하거나 더 강한 주장을 하는 것으로 오해해서는 안 된다. 이 이론은 법적 한계들을 받지 않는 주권자가 발견되는 어떤(some) 사회들이 존재한다는 점만을 진술하는 것이 아니라, 법의 존재는 어디에서나 그러한 주권자의 존재를 함의한다는 점을 주장한다. 한편 이 이론은 주권자의 권한에 아무런 한계들도 없다고 주장하는 것이 아니라, 오직 그 권한에 법적 한계들(legal limits)이 없다고 주장할 뿐이다. 따라서 주권자는 입법 권한을 행사함에 있어 실제로는 대중 여론(popular opinion)을 따를 수도 있다. (p. 67) 이는 그것을 공공연히 거스를 경우의 결과에 대한 두려움 때문일 수도 있고, 혹은 자신이 도덕적으로 그것을 존중할 구속을 받는다고 스스로 생각하기 때문일 수도 있다. 매우 다양한 요인들이 이러한 점에서 그에게 영향을 미칠 수 있으며, 만약 대중의 반란에 대한 두려움이나 도덕적 확신(moral conviction) 때문에 그가 그렇지 않았다면 했을 방식으로 입법하지 않게 된다면, 그는 기실 이러한 요인들을 자신의 권한에 대한 ‘한계들’ 이라고 생각하고 말할 수도 있다. 그러나 그것들은 법적 한계들(legal limits)은 아니다. 그는 그러한 입법을 삼가야 할 법적 책무(legal duty)를 지고 있지 않으며, 법원(law courts)은 자신들 앞에 주권자의 법이 존재하는지를 판단함에 있어, 대중 여론이나 도덕의 요구들로부터 벗어났다는 점이 그 법이 법으로서의 지위를 갖지 못하게 만든다는 논변(argument)을, 주권자가 그렇게 하라고 명령한 경우가 아니라면, 받아들이지 않을 것이다.

이 이론이 법에 대한 일반적 설명(general account of law)으로서 지니는 매력은 분명하다. 이 이론은 두 가지 주요한 질문에 대해 만족스러울 만큼 단순한

형태로 답을 제시해 주는 것처럼 보인다. 습관적 복종을 받지만 자신은 누구에게도 습관적 복종을 하지 않는 주권자를 발견하게 되면, 우리는 두 가지 일을 할 수 있다. 첫째, 우리는 그의 일반 명령들 속에서 특정 사회의 법을 식별할 수 있고, 그 사회 구성원들의 삶을 또한 규율하는 다른 많은 규칙들(rules), 원칙들(principles), 또는 기준들(standards)—도덕적이거나 단순히 관습적인(moral or merely customary) 것들과—을 그것과 구별할 수 있다. 둘째, 법의 영역(area of law) 안에서, 우리가 독립적인 법체계(independent legal system)에 직면해 있는지, 아니면 어떤 더 광범위한 체계(wider system)의 종속된 부분(subordinate part)에 불과한 것에 직면해 있는지를 판단할 수 있다.

일반적으로, 단일하고 계속적인 입법적 존재자(single continuing legislative entity)로서 이해되는 영국 의회 내의 여왕(Queen in Parliament)은 이 이론의 요건(requirements)을 충족시키며, 의회의 주권성은 바로 그것이 그렇게 한다는 사실에 있다고 주장된다. 이 믿음의 정확성 여부가 어떠하든(그 일부 측면은 제 VI장에서 나중에 검토한다), 우리는 이 이론이 요구하는 바를 Rex 1세의 상상 속의 단순화된 세계 속에서 충분히 일관되게 재현할 수 있다. 보다 복잡한 현대 국가의 사례를 검토하기에 앞서 이를 수행하는 것은 이해에 도움이 될 것인데, 이 방식으로 이 이론의 전체 함의(full implications)가 가장 잘 드러나기 때문이다. 제1절에서 복종의 습관이라는 관념에 대해 제기된 비판들을 수용하기 위해, 우리는 상황을 습관이 아니라 규칙의 관점에서 구상할 수 있다. 이러한 토대 위에서, 우리는 법원(courts), 공무원담당자들, 시민들에 의해 일반적으로 수용된 규칙이 존재하는 사회를 상정할 것이다. 그 규칙에 따르면, Rex가 무엇이든 하라고 명령할 때마다 그의 말(word)은 집단을 위한 행위 기준(standard of behaviour)을 구성한다. 이러한 명령들 가운데에서, Rex가 ‘공식적(official)’ 지위를 부여하고자 하지 않는 (p. 68) ‘사적(private)’ 바람들의 표현과, 그러한 지위를 부여하고자 하는 표현을 구별하기 위해, 보조적 규칙들(ancillary rules)도 채택될 수 있다. 이 규칙들은 군주(monarch)가 ‘군주의 지위에서(in the character of a monarch)’ 입법할 때 사용해야 할 특별한 양식(style)을 특정하되, 아내나 정부(情婦)에게 사적 명령들을 내릴 때에는 이를 사용하지 않도록 할 것이다. 입법의 방식과 형식(manner and form)에 관한 이러한 규칙들은 그

목적을 달성하기 위해서는 진지하게 받아들여져야 하며, 때로는 Rex에게 불편(inconvenience)을 초래할 수도 있다. 그럼에도 불구하고, 우리가 그것들을 법적 규칙(legal rules)으로 분류할 수는 있겠지만, 그의 입법 권한(legislative power)에 대한 ‘한계들(limits)’로 간주할 필요는 없다. 요구된 형식(required form)을 따르기만 한다면, 그의 바람들(wishes)을 실현하기 위해 그가 입법할 수 없는 사항(subject)은 존재하지 않기 때문이다. 그의 입법 권한의 ‘형식(form)’은 법에 의해 한계지어질 수 있을지 모르나, 그 ‘영역(area)’은 법에 의해 한계지어지지 않는다.

법에 대한 일반 이론(general theory of law)으로서 이 이론에 제기될 수 있는 반론은, 이 상상된 사회에서의 Rex와 같은 어떠한 법적 제한도 받지 않는 주권자의 존재가 법의 존재를 위한 필요조건(necessary condition)이나 전제(presupposition)가 아니라는 점이다. 이를 입증하기 위해 우리는 논쟁의 여지가 있거나 이의를 제기할 만한 법의 유형들(types of law)을 원용할 필요가 없다. 따라서 우리의 논증은, 입법부가 결여되어 있다는 이유만으로 법이라는 명칭(title of law)을 부정하고자 하는 이들도 있는 관습법 체계나 국제법에서 도출되는 것이 아니다. 이러한 사례들에 호소할 필요는 전혀 없다. 왜냐하면 법적으로 무제한적인 주권자라는 구상(conception)은, 법이 존재한다는 점에 대해 누구도 의문을 제기하지 않을 많은 현대 국가들에서의 법의 성격(character of law)을 잘못 표상하기 때문이다. 이러한 국가들에는 입법부들이 존재하지만, 체계 내에서의 최고 입법 권한이 무제한과는 거리가 먼 경우도 종종 있다. 성문헌법(written constitution)은, 입법의 형식과 방식을 규정함으로써—이를 우리는 제한으로 보지 않아도 된다고 인정할 수 있지만—입법부의 권능(competence)을 제한할 뿐만 아니라, 입법 권능의 범위(scope)에서 특정 사안들을 전면적으로 배제함으로써, 내용상 제한(limitations of substance)을 부과할 수도 있다.

다시 한 번, 현대 국가의 복잡한 사례를 검토하기에 앞서, Rex가 최고 입법자인 단순화된 세계에서 그의 입법 권한에 대한 ‘법적 제한들’이 실제로 무엇을 의미하는지, 그리고 왜 그것이 완전히 정합적인 관념(notion)인지를 살펴보는 것이 유용하다.

Rex의 단순화된 사회에서는, (성문헌법에 구현되어 있든 그렇지 않든 간

예) Rex의 어떠한 법도 토착 주민을 영토(territory)에서 배제하거나 재판 없는 구금을 규정한다면 유효하지 않으며, 이러한 규정들에 반하는 어떠한 제정물(enactment)도 (p. 69) 무효(void)로서 간주되고 모두에 의해 그렇게 취급된다는 규칙이 수용되어 있을 수도 있다. 이러한 경우 Rex의 입법할 권한들(powers to legislate)은 분명히 법적(legal)이라고 할 수밖에 없는 제한들을 받게 될 것이다. 설령 우리가 이러한 근본적인 헌법 규칙(fundamental constitutional rule)을 ‘하나의 법(a law)’ 이라고 부르기를 꺼린다 하더라도 말이다. 그가 종종 자신의 성향(inclinations)에 반하여서까지도 따를 수 있는 대중 여론이나 대중의 도덕적 확신(popular moral convictions)을 무시하는 경우와는 달리, 이러한 특정한 제약들(specific restrictions)을 무시하는 것은 그의 입법을 무효로 만들 것이다. 따라서 법원(courts)은 입법자의 권한 행사에 대한 다른 단지 도덕적 또는 사실상의(de facto) 한계들에는 관여하지 않을 방식으로, 이러한 제약들에는 관여하게 될 것이다. 그럼에도, 이러한 법적 제한들에도 불구하고, 그 범위(scope) 내에서 이루어진 Rex의 제정물들(enactments)은 분명히 법들(laws)이며, 그의 사회에는 독립적인 법체계가 존재한다.

우리는 이러한 상상의 단순한 사례를 좀 더 자세히 들여다볼 필요가 있다. 그래야만 이러한 유형의 법적 한계들(legal limits)이 정확히 무엇인지 분명해지기 때문이다. 우리는 종종 Rex의 입장을 다음과 같이 표현할 수 있다: “그는 재판 없는 구금을 규정하는 법들을 제정할 수 없다(cannot).” 이때의 “~할 수 없다(cannot)”는 표현은, 어떤 사람이 어떤 것을 하지 않아야 할 법적 책무(legal duty)나 의무(obligation)를 지고 있음을 의미하는 경우와 대조하면 잘 드러난다. 후자의 의미에서 “할 수 없다(cannot)”가 사용되는 경우는 예를 들어 “자전거를 인도에서 탈 수 없다(You cannot ride a bicycle on the pavement.)”고 말하는 경우이다. 체계 내 최고 입법부의 입법 권한들을 실효적으로 제한하는 헌법은, 입법부에게 특정 방식으로 입법하려고 시도하지 말라는 책무들을 부과함으로써 그렇게 하지 않는다(또는 적어도 반드시 그렇게 할 필요는 없다). 그 대신, 그러한 입법으로 표방된 것은 무효(void)가 된다고 규정한다. 그것은 법적 책무들을 부과하는 것이 아니라 법적 무능력들(legal disabilities)을 부과한다. 따라서 여기서 ‘한계(limits)’란 것은 책무의 현존(the presence of duty)이 아니라 법적

권한의 부재(the absence of legal power)를 의미한다.

Rex의 입법 권한에 대한 이러한 제약들은 헌법적(constitutional)이라고 불릴 수 있을 것이다. 그러나 그것들은 법원이 관여하지 않는 단순한 관행들(conventions)이나 도덕적 사안들(moral matters)이 아니다. 그것들은 입법할 권위를 부여하는 규칙(rule conferring authority to legislate)의 일부를 이루며, 법원에게 중대한 관련성을 가진다. 왜냐하면 법원은 그러한 규칙을 자신들 앞에 제시되는 입법으로 표방된 제정물들(purported legislative enactments)의 유효성(validity)에 관한 기준(criterion)으로 사용하기 때문이다. 그럼에도 불구하고, 이러한 제약들이 법적이며 단순히 도덕적이거나 관행적인(conventional) 것이 아님에도 불구하고, 그 존재나 부재는 Rex가 다른 사람들에게 습관적으로 복종하는지 여부라는 용어로는 표현될 수 없다. Rex는 그러한 제약들을 받을 수 있으며, 그것들을 회피하려는 시도를 (p. 70) 전혀 하지 않을 수도 있다; 그럼에도 불구하고, 그가 습관적으로 복종하는 대상은 아무도 없을 수 있다. 그는 단지 유효한 법(valid law)을 제정하기 위한 조건들(conditions)을 충족시킬 뿐이다. 혹은 그는 그 제약들과 불일치하는 명령들(orders inconsistent with them)을 발함으로써 그 제약들을 회피하려고 시도할 수도 있다. 그러나 그가 그렇게 하더라도 그는 누구에게도 불복종한 것이 아니며, 우위의 입법자(superior legislator)의 법을 위반하거나 법적 책무를 위반한 것도 아니다. 그는 분명히 유효한 법을 제정하는 데 실패했을 것이다(그는 유효한 법을 어긴 것은 아니다). 반대로, Rex에게 입법 자격을 부여하는 헌법적 규칙 안에 Rex의 입법할 권위에 대한 법적 제약들이 전혀 존재하지 않는다면, 그가 인접한 영토의 왕인 Tyrannus의 명령들에 습관적으로 복종한다는 사실은, Rex의 제정물들(enactments)을 법으로서의 지위(status as law)에서 박탈하지도 않으며, 그것들이 Tyrannus가 최고 권위를 가지는 단일 체계(single system)의 종속된 부분들(subordinate parts)임을 보여주지도 않는다.

앞서 논의한 명백한 고찰들은, 비록 단순한 주권 이론에 의해 자주 가려져 있지만, 법체계의 토대를 이해하는 데 필수적인 여러 사항들을 확립해 준다. 이를 다음과 같이 요약할 수 있다: 첫째, 입법 권위(legislative authority)에 대한 법적 제한들은 입법자에게 어떤 우위의 입법자(superior legislator)의 명령에

복종하라는 책무들을 부과하는 것이 아니라, 입법 자격을 부여하는 규칙들에 포함된 무능력들(disabilities)로 이루어진다.

둘째, 제정물로 표방된 것(purported enactment)이 법임을 확립하기 위해, 그것을 어떤 ‘주권자’ 혹은 ‘무제한적’ 입법자의 명시적 또는 묵시적 제정 행위(enactment)까지 거슬러 추적할 필요는 없다. 여기서 ‘무제한적’ 이라는 말은, 그의 입법 권위(authority to legislate)가 법적으로 제한받지 않는다는 의미이거나, 그가 다른 누구에게도 습관적으로 복종하지 않는 인격이라는 의미일 수 있다. 그 대신 우리가 보여주어야 하는 것은, 해당 제정물(enactment)이 현존하는 규칙 아래에서 입법 자격을 갖춘 입법자에 의해 이루어진 것이며, 그 규칙에 아무런 제약도 포함되어 있지 않거나, 제약이 있더라도 이 특정 제정물에 영향을 미치는 것은 없다는 점이다.

셋째, 우리 앞에 독립된 법체계가 있음을 보이기 위해, 그 최고 입법자가 법적으로 제한받지 않거나 다른 어떤 인격에게도 습관적으로 복종하지 않는다는 점을 보여줄 필요는 없다. 필요한 것은 단지, 그 입법자에게 자격을 부여하는 규칙들이, 다른 영토에 대해서도 권위를 가진 자들에게 우위의 권위(superior authority)를 부여하지 않는다는 사실을 보여주는 것이다. 반대로, 그가 그러한 외부 권위에 종속되어 있지 않다는 사실은, 그가 자기 영토 내에서 무제한적 권위를 가진다는 뜻이 아니다.

넷째, 법적으로 무제한적인 입법 권위와, (p. 71) 제한은 있지만 그 체계 내에서 최고인 입법 권위는 구분되어야 한다. Rex는 헌법에 의해 일정한 제한을 받는다 하더라도, 그의 입법이 다른 모든 입법을 폐지할 수 있는 의미에서 그 나라 법이 인정하는 가장 높은 입법 권위를 가질 수 있다.

다섯째, 그리고 마지막으로, 입법자의 입법 권능(competence to legislate)을 제한하는 규칙들의 존재 여부는 핵심적인 반면, 그 입법자의 복종 습관들은 기껏해야 약간의 간접적인 증거적 중요성만을 가진다. 입법자가 다른 사람들에게 복종하는 습관을 가지고 있지 않다는 사실이, 만약 사실이라면, 가지는 유일한 관련성은, 그것이 때때로 그의 입법 권위가 헌법적 또는 법적 규칙에 의해 다른 이들의 권위에 종속되어 있지 않다는 점에 대한 약간의, 하지만 확정적이기에는 한참 모자란, 증거를 제공할 수 있다는 점이다. 마찬가지로, 입법자가 실제로

다른 누군가에게 습관적으로 복종한다는 사실의 유일한 관련성은, 이것이 규칙들 아래에서 그의 입법 권위가 다른 이들의 권위에 종속되어 있다는 점에 대한 얼마간의 증거라는 점이다.

4. 입법부 배후의 주권자

현대 세계에는, 통상적으로 그 체계 내에서 최고 입법부로 간주되는 기구(body)가 그 입법 권한들(legislative powers)의 행사에 있어 법적 제한을 받는 법체계가 이 다수 존재한다. 그럼에도 불구하고, 법률가와 법이론가 모두가 동의하듯이, 그러한 입법부가 자신에게 부여된 제한된 권한들의 범위(scope) 안에서 만든 제정물들(enactments)은 분명히 법(law)이다. 이러한 경우들에서, 만약 우리가 법이 존재하는 곳마다 법적 제한을 받을 수 없는 주권자(sov^{er}ign incapable of legal limitation)가 존재한다는 이론을 유지하고자 한다면, 우리는 법적으로 제한된 입법부 배후에 있는 그러한 주권자를 찾아야 한다. 그가 실제로 거기에 존재하는지 여부가, 이제 우리가 검토해야 할 문제이다.

우리는 잠시 동안, 모든 법체계가 어떤 형태로든—비록 반드시 성문헌법에 의해서일 필요는 없지만—입법자들의 자격요건(qualification)과 입법의 ‘방식과 형식(manner and form)’에 관해 마련해야 하는 규정들을 논외로 둘 수 있다. 이러한 규정들은 입법 권한의 범위에 대한 법적 제한이라기보다는, 입법 기구(legislative body)의 동일성(identity)과 그것이 입법하기 위해 무엇을 해야 하는지를 특정하는 사항들(specifications)로 생각될 수 있다. 그러나 실제로는, 남아프리카(South Africa)의 경험이 보여주듯이,⁵ (p. 72) 입법의 ‘방식과 형식’에 관한 단순한 규정들이나 입법 기구의 정의들(definitions)을 ‘실질적(substantial)’ 제한과 만족스럽게 구별해 주는 일반적 기준들(criteria)을 제시하기는 어렵다. 그럼에도 불구하고 실체적 제한(substantive limitations)의 명확한 사례들은, 미합중국이나 오스트레일리아의 연방헌법에서 찾아볼 수 있다. 이들 헌법에서는 중앙정부와 구성 주(states) 사이의 권한 분할(division of powers), 그리고 또한 일정한 개인적 권리들(individual rights)이 통상적 입법 절차들(ordinary

⁵Harris v. Dönges[1952] 1 TLR 1245 참조.

processes of legislation)에 의해 변경될 수 없다. 이러한 경우, 주 입법부나 연방 입법부 중 어느 쪽이든, 연방적 권한 분할을 변경한다고 표방하거나(purporting to alter) 그 권한 분할과 불일치하는 제정물(enactment), 또는 이러한 방식으로 보호되는 개인적 권리들과 양립할 수 없는 제정물은 권한초과(ultra vires)로 취급되고, 헌법 규정과 충돌하는 범위 내에서 법원에 의해 법적으로 유효하지 않다(legally invalid)고 선언될 수 있다. 이러한 입법 권한들에 대한 법적 제한들 가운데 가장 유명한 것은 미합중국 헌법의 수정 제5조(Fifth Amendment)이다. 이 조항은, 다른 내용들과 함께, 어떠한 사람도 적법절차(due process of law) 없이 ‘생명, 자유 또는 재산(life liberty or property)’을 박탈당해서는 안 된다고 규정한다. 그리고 연방의회(Congress)의 제정법들(statutes)이 이러한 규정들 또는 헌법이 그 입법 권한들에 부과한 다른 제약들(restrictions)과 충돌하는 것으로 판명될 경우, 법원에 의해 유효하지 않다고 선언되어(declared invalid) 왔다.

물론 헌법의 규정들을 입법부의 작용으로부터 보호하기 위한 다양한 장치들이 존재한다. 어떤 경우들에서는, 예컨대 스위스의 경우처럼, 연방 구성 주의 권리와 개인의 권리에 관한 일부 규정들이 형식상으로는 의무부과적(mandatory)임에도 불구하고, ‘단지 정치적(merely political)’이거나 권고적인(hortatory) 것으로 취급된다. 이러한 경우 법원에는 연방 입법부의 제정물(enactment)을 ‘심사하여(review)’, 비록 그것이 입법부 작용의 적절한 범위에 관한 헌법 규정과 명백히 충돌하더라도 이를 유효하지 않다(invalid)고 선언할 관할권(jurisdiction)이 부여되지 않는다.⁶ 미합중국 헌법의 특정 규정들 역시 ‘정치적 문제들(political questions)’을 제기하는 것으로 판시되어 왔으며, 사건이 이 범주에 속하는 경우 법원은 해당 제정법(statute)이 헌법을 위반하는지 여부를 심리하지 않는다.

최고 입법부의 통상적 작용(normal operations)에 대한 법적 제한이 헌법에 의해 부과되는 경우, 이러한 제한들 자체는 (p. 73) 특정한 형태의 법적 변경(legal change)으로부터 면역되어(immune) 있을 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 이는 헌법이 그 개정(amendment)을 위해 어떠한 규정을 두고 있는지의 성격에

⁶스위스 헌법 제113조 참조.

달려 있다. 대부분의 헌법은, 통상의 입법부와 구별되는 기구(body)에 의해 행사되거나, 또는 통상의 입법부 구성원들이 특별한 절차(special procedure)를 사용하여 행사하는, 광범위한 개정 권한(amending power)을 포함하고 있다. 미합중국 헌법 제5조가, 각 주의 입법부 4분의 3 또는 각 주의 4분의 3에서 소집된 회의(conventions)에 의해 비준되는(ratified) 개정을 규정하고 있는 것은 전자의 유형에 속하는 개정 권한의 한 사례이며, 1909년 남아프리카법(South Africa Act of 1909) 제152조(s. 152)에 규정된 개정 절차는 후자의 유형에 속하는 사례이다. 그러나 모든 헌법이 개정 권한을 포함하고 있는 것은 아니며, 또한 개정 권한이 존재하는 경우에도, 입법부에 한계를 부과하는 헌법의 특정 규정들이 그 개정 권한의 범위 밖에 두어지는 경우가 있다. 이 경우 개정 권한 자체가 제한되는 것이다. 이러한 점은(비록 그중 일부 제한은 더 이상 실질적 중요성을 가지지 않지만) 미합중국 헌법에서도 관찰될 수 있다. 왜냐하면 제5조는, ‘1808년 이전에 이루어진 어떠한 개정도 제1조 제9절의 제1항과 제4항에 어떠한 방식으로든 영향을 미칠 수 없으며, 어떠한 주도 그 동의 없이는 상원(Senate)에서의 동등한 표결권(equal suffrage)을 박탈당하지 않는다’ 고 규정하고 있기 때문이다.

입법부가 남아프리카의 경우처럼, 입법부 구성원들이 특별한 절차를 사용함으로써 제거할 수 있는 제한들을 받는 경우에는, 그 입법부를 해당 이론이 요구하는 바와 같은 법적 제한을 받을 수 없는 주권자와 동일시할 수 있다는 주장이 가능하다. 이 이론에 있어 곤란한 사례는, 미합중국의 경우처럼 입법부에 대한 제약들(restrictions)이 특별한 기구에 위임된 개정 권한의 행사를 통해서만 제거될 수 있는 경우이거나, 혹은 그러한 제약들이 모두 개정 권한의 범위 밖에 있는 경우이다.

이러한 사례들을 일관되게 설명할 수 있다는 이 이론의 주장을 검토함에 있어, 종종 간과되지만 반드시 상기해야 할 점은, 오스틴 자신이 이 이론을 전개함에 있어 영국에서조차 주권자를 입법부와 동일시하지는 않았다(not)는 점이다. 이는 영국 의회 내의 여왕(Queen in Parliament)이 통상적으로 받아들여지는 교설에 따르면 그 입법 권한에 대해 법적 제한으로부터 자유롭고, 따라서 ‘경성(rigid)’ 헌법에 의해 제한되는 연방의회(Congress)나 다른 입법부들과 대

비되는 의미에서 (p. 74) ‘주권적 입법부(sov​er​eign legislature)’가 무엇인지를 보여주는 전형(paradigm)으로 자주 인용됨에도 불구하고 그러하였다. 그럼에도 불구하고 오스틴의 견해에 따르면, 어떤 민주정(democracy)에서도 주권적 기구(sov​er​eign body)를 구성하거나 그 일부를 이루는 것은 선출된 대표자들(elected representatives)이 아니라 선거권자들(electors)이다. 따라서 잉글랜드에서는 “엄밀하게 말하자면 하원의원들(members of the commons house)은 자신들을 선출하고 임명한 집단을 위한 단순한 수탁자들(trustees)에 불과하며, 결과적으로 주권은 항상 국왕(King), 귀족들(Peers), 그리고 하원의 선거권자 집단(electoral body of the commons)에 귀속된다”고 하였다.⁷ 마찬가지로 그는 미합중국에서도 각 주의 주권과, “연방 결합(Federal Union)으로부터 발생한 더 큰 국가의 주권 역시 주 정부들(states’ governments)이 하나의 집합적 기구(aggregate body)를 형성하는 데에 귀속되는데, 여기서 주 정부란 통상의 입법부(ordinary legislature)가 아니라, 통상의 입법부를 임명하는 시민들의 집단(body of citizens)을 의미한다”고 보았다.⁸

이러한 관점에서 보면, 통상의 입법부(ordinary legislature)가 법적 제한으로부터 자유로운 법체계와, 입법부가 그러한 제한을 받는 법체계 사이의 차이는, 주권적 선거권자 집단(sov​er​eign electorate)이 자신의 주권적 권한들(sov​er​eign powers)을 행사하기로 선택하는 방식의 차이에 불과한 것으로 보인다. 이 이론에 따르면 영국에서는, 선거권자 집단이 주권에서 자신들이 가진 몫을 직접 행사하는 유일한 방식은 의회(Parliament)에 앉을 대표자들을 선출하고 그들에게 자신의 주권적 권한을 위임하는 데에 있다. 이러한 위임은 어떤 의미에서는 절대적이다. 왜냐하면 그렇게 위임된 권한들이 남용되지 않도록 그들에게 신탁(trust)이 설정되어 있기는 하지만, 그러한 경우 이 신탁은 오직 도덕적 제재(moral sanctions)의 문제일 뿐이며, 입법 권한에 대한 법적 제한과 달리 법원이 관여하는 사안은 아니기 때문이다. 이에 반해, 통상의 입법부가 법적으로 제한되는 모든 민주정에서와 마찬가지로 미합중국에서는, 선거권자 집단(electoral body)이 자신의 주권적 권한 행사를 대표자 선출에만 국한하지 않고,

⁷ Austin, *Province of Jurisprudence Determined*, Lecture VI, pp. 230–1.

⁸ Ibid., p. 251.

그 대표자들에게 법적 제약들(legal restrictions)을 부과해 왔다. 이 경우 선거권자 집단은, 헌법적 제약들(constitutional restrictions)을 준수하도록 법적으로 ‘구속된(bound)’ 통상의 입법부에 비해 우위에 있는, ‘비통상적이고 배후적인 입법부(“extraordinary and ulterior legislature”)’로 간주될 수 있으며, 충돌이 발생하는 경우 법원은 통상의 입법부의 법률들(Acts)을 유효하지 않다(invalid)고 선언할 것이다. 따라서 이 경우, 이 이론이 요구하는 바와 같이 모든 법적 제한으로부터 자유로운 주권자는 바로 선거권자 집단(electorate)에 존재하게 된다.

(p. 75) 이 이론의 이러한 추가적 전개 국면에서는, 초기의 단순한 주권자 구상이 급진적인 변형까지는 아니더라도 일정한 정교화를 거쳤다는 점이 분명하다. ‘사회 구성원의 대다수가 습관적으로 복종하는 대상인 인격 또는 인격들(the person or persons to whom the bulk of the society are in the habit of obedience)’로서의 주권자에 대한 기술은, 이 장 제1절에서 우리가 보여주었듯이, Rex가 절대 군주였고 입법자로서의 승계(succession)에 관한 어떠한 규정도 존재하지 않았던 가장 단순한 형태의 사회에 대해서는 거의 문자 그대로 적용될 수 있었다. 그러나 그러한 규정이 마련된 경우에는, 현대 법체계의 매우 두드러진 특징인 그에 따른 입법적 권위의 계속성(consequent continuity)은 복종의 습관이라는 단순한 용어로는 표현될 수 없었고, 실제로 입법을 수행하고 복종을 받기 이전에 이미 승계자(successor)가 입법할 권리를 가진다는 점을 규정하는 수용된 규칙(accepted rule)이라는 관념(notion)을 필요로 하였다. 그러나 민주국가의 선거권자 집단(electorate)과 주권자를 동일시하는 현재의 설명은, 핵심어인 ‘복종의 습관’과 ‘인격 또는 인격들’에, 단순한 사례에 적용되었을 때와는 전혀 다른 의미를 부여하지 않는 한, 전혀 그럴듯함을 갖지 못한다. 그리고 이러한 의미는 수용된 규칙이라는 관념(notion)이 은밀하게 도입되지 않는 한 명확해질 수 없다. 복종의 습관과 명령이라는 단순한 도식만으로는 이에 충분할 수 없다.

이 점은 여러 방식으로 입증될 수 있지만, 가장 분명하게 드러나는 예는 다음과 같은 경우이다. 선거권자 집단이 유아와 정신적 결함자만을 제외하여 그 자체로 인구의 ‘대다수(bulk)’를 구성하는 민주정을 생각해 보거나, 정신적으로 온전한 성인들(sane adults) 모두가 투표권을 가진 단순한 사회집단을 상상해

보자. 이러한 경우 선거권자 집단을 주권자로 간주하고, 원래 이론의 단순한 정의를 적용하려 하면, 우리는 결국 사회의 ‘대다수’가 스스로에게 습관적으로 복종한다고 말하게 된다. 따라서 “법적으로 제한을 받지 않는 주권자가 명령을 내리고, 수범자들은 이에 습관적으로 복종한다”는 명확한 사회 구도는 사라지고, 다수에 의해 내려진 명령에 다수가 복종하거나, 전체 구성원에 의해 내려진 명령에 전체가 복종한다는 모호한 이미지로 대체된다. 그러나 이것은 더 이상 원래 의미의 ‘명령’ (타인(others)이 특정 방식으로 행동하길 의도한 표현)도 아니고, ‘복종’도 아니다.

이러한 비판에 대응하기 위해, 사회 구성원들을 개인으로서의 사적 행위능력(private capacity)에서의 개인들과 (p. 76) 선거권자(electors)나 입법자로서의 공적 행위능력에서의 동일한 인격들로 구분할 수 있을 것이다. 이러한 구분은 완전히 이해 가능한 것이며, 기실 많은 법적·정치적 현상들은 이러한 용어로 가장 자연스럽게 설명된다. 그러나 설명 우리가 한 걸음 더 나아가 공적 행위능력에서의 개인들이 또 다른 인격(another person)을 구성하며, 그 인격이 습관적으로 복종을 받는다고 말할 준비가 되어 있다 하더라도, 이러한 구분만으로는 주권 이론을 구출할 수 없다. 왜냐하면 어떤 사람들의 집단이 대표자를 선출하거나 명령을 발할 때, 그들이 ‘개인으로서’가 아니라 ‘공적 행위능력에서(in their official capacity)’ 행위했다고 말하는 것이 무엇을 의미하는지를 묻는다면, 그에 대한 답변은 오직 특정한 규칙들에 따른 그들의 자격요건들(qualifications)과, 유효한 선거(valid election)나 법을 성립시키기 위해 그들이 해야 할 일을 규정하는 다른 규칙들에 대한 준수라는 용어로만 주어질 수 있기 때문이다. 바로 이러한 규칙들에 대한 참조(reference)를 통해서만, 우리는 어떤 것을 이 사람들의 집단에 의해 이루어진 선거 또는 만들어진 법으로 식별할(identify) 수 있다. 이러한 것들은, 개인의 발언이나 서면 명령을 그 개인에게 귀속시키는 데 사용하는 것과 동일한 단순하고 자연적인 판별 기준(simple natural test)에 의해, 그것을 ‘만든(making)’ 집단(body)에게 귀속되는 것이 아니다.

그렇다면 그러한 규칙들이 존재한다는 것은 무엇을 의미하는가? 그것들은 사회 구성원들이 선거권자 집단(electorate)으로서 기능하기 위해—그리고 따라서 그 이론의 목적상 주권자로서 기능하기 위해—무엇을 해야 하는지를

규정하는 규칙들이므로, 그 자체가 주권자에 의해 발령된 명령들(orders issued by the sovereign)의 지위를 가질 수는 없다. 왜냐하면 그 규칙들이 이미 존재하고 따라져(followed) 있지 않는 한, 어떠한 것도 주권자에 의해 발령된 명령들(orders issued by the sovereign)로 간주될 수 없기 때문이다.

그렇다면 우리는 이러한 규칙들이 인구(population)의 복종의 습관(habits)에 대한 기술(description)의 일부에 불과하다고 말할 수 있는가? 사회의 대다수가 주권자인 단일한 개인을, 그가 특정한 형식-예컨대 서면으로 작성되고 서명 및 증인이 갖추어진 형식-으로 명령을 내릴 경우에, 그리고 그 경우에만(if, and only if) 복종하는 단순한 사례에서는, (제1절에서 이 맥락에서의 ‘습관’ 개념 사용에 대해 제기된 의의들을 유보한다면) 그가 이러한 방식으로 입법해야 한다는 규칙은 사회의 복종의 습관에 대한 기술의 일부에 불과하다고 말할 수 있을 것이다. 즉, 사회는 그가 이러한 방식으로 명령을 내릴 때(when) 습관적으로 그에게 복종한다는 것이다. 그러나 주권자인 개인이 규칙들과 독립적으로 식별될 수 없는 경우에는, 이러한 규칙들을 사회가 주권자에게 습관적으로 복종하는 조건들이나 요건들(terms or conditions)로서 단지 그렇게 표상할 수는 없다. 이 규칙들은 주권자를 구성하는(constitutive) 것이지, 주권자에 대한 복종의 습관을 기술할 때 (p. 77) 언급해야 할 사항들에 불과한 것이 아니다. 따라서 현재의 경우, 선거권자 집단(electorate)의 절차를 규정하는 규칙들이, 개별 개인들의 집합으로서의 사회가 선거권자 집단으로서의 자기 자신에게 복종하는 조건들을 나타낸다고 말할 수는 없다. 왜냐하면 ‘선거권자 집단으로서의 자기 자신(itself as an electorate)’이라는 표현은 규칙들과 별도로 식별 가능한 어떤 인격(person)에 대한 참조(reference)가 아니기 때문이다. 그것은 선거권자들(electors)이 대표자를 선출함에 있어 규칙들을 준수하였다는 사실에 대한 압축된 참조(condensed reference)에 불과하다. 기껏해야 우리는(제1절의 의의들을 유보한다면) 이러한 규칙들이 선출된 인격들(elected persons)이 습관적으로 복종을 받는 조건들을 제시한다고 말할 수 있을 뿐이다. 그러나 그렇게 되면 우리는 입법부(legislature)가 아니라 선거권자 집단이 주권자라는 현재의 설명에서 벗어나, 입법부가 주권자인 이론의 한 형태로 되돌아가게 되며, 그러한 입법부가 그 입법 권한에 대해 법적 제한들(legal limitations)을 받을 수 있다는

사실에서 비롯되는 모든 난점들은 여전히 해결되지 않은 채로 남게 될 것이다.

이 장의 앞선 절에서 제시된 논증들과 마찬가지로, 이 이론에 대한 이러한 논증들은, 단지 세부에서 오류가 있다는 주장에 그치지 않고, 명령들, 습관들, 그리고 복종이라는 단순한 관념(idea)만으로는 법에 대한 분석에 충분할 수 없다는 논지(contention)를 구성한다는 의미에서 근본적이다. 그 대신 요구되는 것은, 특정한 절차를 준수함으로써 입법할 자격을 갖춘 사람들에게, 제한될 수도 있고 제한되지 않을 수도 있는, 권한들을 부여하는 규칙이라는 관념(notion of a rule conferring powers)이다.

이 이론이 지니는 일반적 개념적 부적합성과는 별도로, 통상적으로 최고 입법부로 간주되는 기구가 법적으로 제한될 수 있다는 사실을 이 이론 안에 수용하려는 시도에는 많은 보조적 반론들(ancillary objections)이 존재한다. 그러한 경우 주권자를 선거권자 집단(electorate)과 동일시해야 한다면, 설령 선거권자 집단이 통상 입법부에 대한 모든 제약들(restrictions)을 제거할 수 있는 무제한의 개정 권한(unlimited amending power)을 가지고 있는 경우라 하더라도, 그러한 제약들이 법적인 것은 선거권자 집단이 통상 입법부가 습관적으로 복종하는 명령들을 내렸기 때문이라고 말할 수 있는지 우리는 물어볼 수 있다. 우리는 입법 권한에 대한 법적 제한들이 명령들로, 그리고 그에 따른 책무들(duties)로 잘못 표상된다는 우리의 반론을 일단 접어들 수도 있을 것이다. 그렇다 하더라도, 이러한 제약들이 선거권자 집단이 입법부에게 이행하도록 심지어 묵시적으로(tacitly) 명령한 책무들이라고 가정할 수 있을까? 앞선 장들에서 묵시적 명령들(tacit orders)이라는 관념에 대해 제기된 모든 반론들은, 이 맥락에서 그 사용에 대해 더욱 강력한 힘으로 적용된다. 미합중국 헌법에 규정된 것처럼 (p. 78) 그 행사 방식이 극히 복잡한 개정 권한(amending power)을 행사하지 않는다는 사실은, 선거권자 집단의 바람들(wishes)을 보여주는 징후로서는 빈약할 수 있으며, 오히려 그들의 무지와 무관심을 보여주는 신뢰할 만한 징후인 경우가 많다. 우리는, 장군이 병사들에게 하사관이 지시하는 바를 따르라고 묵시적으로 명령했다고, 아마도 그럴듯하게, 간주될 수 있는 경우와는 기실 거리가 멀다.

다시, 선거권자 집단에 위임된 개정 권한의 범위 바깥에 전적으로 놓여 있는 입법부에 대한 제약들이 존재하는 경우, 이 이론의 용어로 우리는 무엇이라고

말해야 하는가? 이는 단지 상상 가능한 경우에 그치지 않고, 실제로 일부 사례들에서는 그러한 상태가 존재한다. 이러한 경우 선거권자 집단은 법적 제한을 받으며, 비록 그것을 비통상적 입법부(extraordinary legislature)라고 부를 수는 있을지라도, 법적 제한으로부터 자유롭지 않으므로 주권자는 아니다. 그렇다면 우리는, 사회가 이러한 제한들에 맞서 봉기하지 않았다는 이유로, 전체로서의 사회(the society as a whole)가 주권자이며 이러한 법적 제한들이 그것(it)에 의해 묵시적으로 명령되어 왔다고 말해야 하는가? 이것이 혁명과 입법 사이의 구별을 유지할 수 없게 만든다는 점만으로도, 아마 이 주장을 배척하기에 충분한 이유가 될 것이다. 마지막으로, 선거권자 집단을 주권자로 취급하는 이 이론은, 기껏해야 선거권자 집단이 존재하는 민주정에서의 제한된 입법부에 대해서만 설명을 제공한다. 그러나 Rex와 같은 세습 군주(hereditary monarch)가, 체계 내에서 제한되어 있으면서도 최고인(supreme) 입법 권한들(legislative powers)을 향유한다는 관념(notion)에는 아무런 부조리도 존재하지 않는다.

제4장 주석

50쪽. 오스틴의 주권 이론. 본 장에서 검토된 주권 이론은 오스틴이 『법리학의 범위는 어떻게 결정되는가』(*The Province*) 제5강과 제6강에서 전개한 것이다. 우리는 오스틴이 단지 일정한 형식적 정의들이나 법체계를 논리적으로 배열하기 위한 추상적 도식을 제시한 것이 아니라, 영국이나 미합중국과 같은 법이 존재하는 모든 사회에서는 오스틴이 정의한 속성을 갖춘 주권자가 어딘가에 반드시 존재한다는 사실 주장(factual claim)을 하고 있다고 해석했다. 다만 이러한 주권자의 존재는 다양한 헌법적·법적 형식들에 의해 가려질 수 있다. 일부 이론가들은 오스틴을 달리 해석하여 그가 그러한 사실 주장들을 한 것이 아니라고 본다(예: 스톤, 『법의 영역과 기능』, 제2장 및 제6장, 특히 60, 61, 138, 155쪽. 여기서 오스틴이 여러 공동체에서 주권자를 식별하려 한 시도는 그의 주된 목적에서 벗어난 무관한 우회들(irrelevant diversions)로 다뤄진다). 이러한 해석에 대한 비판은 Morison, ‘Some Myth about Positivism’, loc. cit., pp. 217–22 참조. 또한 Sidgwick, *The Elements of Politics*, Appendix (A) ‘On Austin’s Theory of Sovereignty’도 참조.

54쪽. 오스틴에서의 입법적 권위의 계속성. 『법리학의 범위는 어떻게 결정되는가(The Province)』에서 ‘승계의 방식으로 주권을 취득하는 인격들(persons who “take the sovereignty in the way of succession”)’에 대한 간략한 언급들(제5강(Lecture V), pp. 152–4)은 시사적이지만 불분명하다. 오스틴은, 주권을 취득하는 인격들이 교체되는 일련의 승계를 통해 주권의 계속성을 설명하기 위해서는 그의 핵심 개념들인 ‘습관적 복종’과 ‘사령들(commands)’에 더하여 무엇인가 추가적인 요소가 필요하다는 점을 인정하는 듯 보이지만, 그 추가 요소를 결코 명확히 식별하지는 않는다. 그는 이와 관련하여 ‘권원(title)’, 승계에 대한 ‘청구들(claims)’, 그리고 ‘정당한(legitimate) 권원’에 관해 말하지만, 이러한 표현들은 통상적으로 사용될 때 모두 승계를 규율하는 규칙의 존재를 함축하며, 승계되는 주권자들(successive sovereigns)에 대한 단순한 복종의 습관들만을 의미하지는 않는다. 오스틴이 사용하는 이러한 용어들과 ‘일반적 권원(generic title)’ 및 주권을 취득하는 ‘일반적 방식(the generic mode)’이라는 표현들에 대한 그의 설명은, 주권자의 ‘확정적(determinate)’ 성격에 관한 그의 교설로부터 풀어내야 한다(op. cit., 제5강(Lecture V), pp. 145–55). 여기서 그는 주권자인 개인 또는 개인들이 개별적으로—예컨대 이름으로—식별되는 경우와, ‘어떤 일반적 기술(generic description)에 부합하는 것으로서’ 식별되는 경우를 구별한다. 따라서 (가장 단순한 예를 들면) 세습 군주제에서는 일반적 기술이 특정 조상의 ‘생존한 최연장 남계 후손’일 수 있고, 의회

민주정(parliamentary democracy)에서는 입법부 구성원 자격요건들(qualifications for membership of the legislature)을 재현하는 고도로 복잡한 기술이 될 것이다.

오스틴(Austin)의 견해는, 어떤 사람이 그러한 ‘일반적’ 기술(‘generic’ description)을 충족할 때 그는 승계에 대한 ‘권원(title)’ 또는 ‘권리(right)’를 가진다는 것인 듯하다. 그러나 주권자에 대한 이러한 일반적 기술(description)에 의존한 설명은, 오스틴이 이 맥락에서 ‘기술’이라는 말로 승계를 규율하는 수용된 규칙을 의미하지 않는 한, 그 자체로는 불충분하다. 왜냐하면, 사회의 구성원들이 사실상(as a matter of fact) 그때 그때 일정한 기술에 부합하는 누구에게든 습관적으로 복종하는 경우와, 그러한 기술에 부합하는 누구든지 복종받을 권리 또는 권원을 가진다는 규칙이 수용되어 있는 경우 사이에는 분명한 구별이 존재하기 때문이다. 이는 사람들이 체스 말을 습관적으로 일정한 방식으로 움직이는 경우와, 그렇게 행동할 뿐만 아니라 그것이 말을 움직이는 올바른(right) 방식이라는 규칙을 수용하고 있는 경우 사이의 차이와 평행(parallel)을 이룬다. 승계에 대한 ‘권리’나 ‘권원’이 존재하려면, 승계를 규정하는 규칙(rule providing for the succession)이 반드시 있어야 한다. 오스틴의 일반적 기술(generic descriptions)에 관한 교설은 그러한 규칙을 대체할 수는 없으며, 다만 그 필요성(necessity)을 분명히 드러낼 뿐이다. 입법자로서의 자격을 부여하는 규칙(rule qualifying persons as legislators)이라는 관념을 인정하지 않은 오스틴에 대한 유사한 비판으로는, Gray, *The Nature and Sources of the Law*, 제3장(chap. iii), 특히 제151-157절(ss. 151-7)을 보라. 또한 주권적 기구(sovvereign body)의 통일성(unity)과 법인적(corporate) 또는 ‘합의 체적(collegiate)’ 행위능력(capacity)에 관한 오스틴의 제5강(Lecture V)의 설명 역시 동일한 결함을 지니고 있다(이 장 제4절(s. 4) 참조).

55쪽. 규칙과 습관. 여기서 강조된 규칙의 내부 측면(internal aspect)은 제5장 §2(p.88), §3(p.98), 제6장 §1, 제7장 §3에서 더 논의된다. 또한 Hart, “Theory and Definition in Jurisprudence”, 29 *PAS Supplementary vol.* (1955), 247-250쪽도 참고. 유사한 관점으로는 Winch, 『사회과학의 개념』(1958), 제2장 57-65쪽, 제3장 84-94쪽, 그리고 Piddington, “Malinowski의 욕구 이론”, 『인간과 문화』(Firth 편) 참조.

60쪽. 헌법의 기본 규칙에 대한 일반적 수용. 헌법의 수용, 나아가 법체계의 존재와 관련하여, 공무원담당자들과 사인들(private citizens)이 법규칙들(rules of law)에 대해 보이는 여러 상이한 태도들의 복합체는 제5장 §2 (88-91쪽), 제6장 §2 (114-117쪽)에서 더 깊이 논의된다. 또한 Jennings, 『헌법법』(3판) 부록 3: “법 이론에 대한 노트” 참조.

63쪽. 흡스와 묵시적 사령 이론. 앞선 제3장 §3 및 해당 주석 참조. 또한 Sidgwick, 『정

치의 요소들』 부록 A. 동시대 입법부의 제정법들(statutes)조차도 집행되기 전까지는 법이 아니라고 보는 부분적으로 유사한 ‘현실주의적’ 이론으로는 Gray, 『법의 본성과 원천』 제4장, J. Frank, 『법과 현대정신』 제13장 참조.

66쪽. 입법 권한에 대한 법적 제한. 오스틴과 달리, 벤담은 최고 권한이 ‘명시적 합의(express convention)’에 의해 제한될 수 있으며, 그 합의를 위반하여 제정된 법들(laws)은 무효(void)가 될 수 있다고 보았다. 이에 관해서는 『정부에 관한 단편(A Fragment on Government)』 제4장 제26, 34-38절 참조. 주권자의 권한에 대한 법적 제한의 가능성을 부정하는 오스틴의 논증은, 그러한 제한에 종속된다는 것이 곧 책무(duty)에 종속된다는 가정에 기초하고 있다. 이에 대해서는 『법리학의 범위는 어떻게 결정되는가(The Province)』 제6강, 254-268쪽 참조. 그러나 실제로 입법적 권위(legislative authority)에 대한 제한들은 책무들(duties)이 아니라 법적 무능력들(disabilities)로 구성된다(호펠드(Hohfeld), 『Fundamental Legal Conceptions』(1923), 제1장 참조).

68쪽. 입법의 방식 및 형식에 관한 규정. 이러한 규정들을 입법 권한에 대한 실체적 제한(substantive limitations)과 구별하는 것이 어렵다는 점은 제7장 제4절, 149-152쪽에서 추가로 논의된다. 주권 기구(sovvereign body)의 행위능력을 ‘규정하는 것(defining)’과 ‘족쇄를 채우는 것(fettering)’ 사이의 구분에 대한 소진적 논의는 마셜, 『의회 주권과 영연방』(Parliamentary Sovereignty and the Commonwealth, 1957), 제1-6장 참조.

72쪽. 헌법적 안전장치와 사법심사. 사법심사가 허용되지 않는 헌법에 대해서는 휘어, 『현대 헌법』(Modern Constitutions) 제7장 참조. 여기에 해당하는 국가는 (칸톤 입법을 제외한) 스위스, 제3공화국 시기의 프랑스, 네덜란드, 스웨덴 등이 포함된다. 미합중국 대법원이 ‘정치적 문제(political questions)’를 야기하는 위헌성 주장들(claims of unconstitutionality)을 심판하기를 거부한 사례로는 루터 대 보든(Luther v. Borden), 7 Howard 1, 12 L. Ed. 581 (1849) 참조. 프랑크퍼터의 「대법원」, 『사회과학 백과사전』 제14권, 474-476쪽도 참조.

74쪽. ‘비통상적 입법부(extraordinary legislature)’로서의 선거권자 집단. 많은 체계에서 통상의 입법부가 법적 제한을 받는다는 비판을 피하려는 시도로 오스틴이 이 관념(notion)을 사용한 것에 대해서는 『법리학의 범위는 어떻게 결정되는가』 제6강, 222-233쪽 및 245-251쪽 참조.

76쪽. 사적 행위능력에서 그리고 공적 행위능력에서의 입법자들. 오스틴은 종종 주권 기구(sovvereign body)의 구성원들을 ‘개별적으로 고려했을 때’와 ‘구성원으로서 또는 합의체적·주권적 행위능력에서 고려했을 때’를 구분한다(『법리학의 범위는 어떻게

결정되는가』 제6강, 261-266쪽). 그러나 이 구분은 주권 기구의 입법 활동을 규율하는 규칙이라는 관념을 수반한다. 오스틴은 이러한 공적 또는 합의체적 행위능력(official or collegiate capacity)이라는 관념에 대한 분석을 ‘일반적 기술(generic description)’이라는 불충분한 용어로 암시만 할 뿐이다(54쪽 주석 참조).

78쪽. 개정 권한들의 제한된 범위. 미합중국 헌법 제5조의 단서 조항 참조. 독일 연방 공화국의 기본법(1949년) 제1조와 제20조는 제79조 제3항이 부여한 개정 권한의 범위 밖에 전적으로 놓여 있다. 터키 헌법(1945년)의 제1조 및 제102조도 참조.

제4장 제3판 주석

55-57쪽. 사회 규칙의 본성에 대하여. 하트의 ‘실천 이론(practice theory)’에 대한 비판은 다음 저작들을 참조할 것: G. J. 워녹(G. J. Warnock), 『도덕성의 대상(The Object of Morality)』(메튜언, 1971) 제4장; 로널드 드워킨(Ronald Dworkin), 『권리를 진지하게 대하기(Taking Rights Seriously)』 48-58쪽; 조셉 라즈(Joseph Raz), 『실천적 이성과 규범(Practical Reason and Norms)』 49-58쪽.

하트는 이후의 저술에서 사령들(commands)에 관한 하나의 생각(thought)을 발전시켜 규칙들에 관해 또 다른 제안(suggestion)을 한다. 그는 사령들이 ‘결정적(peremptory)’인 것, 즉 “행위를 할 것인지에 대한 찬반의 장단점에 관해 청자가 하는 어떤 독립적 숙고도 배제하거나 차단하도록 의도된 것”이며, 또한 ‘내용 독립적(content-independent)’인 것, 곧 “실행될 행위들의 본성이나 성격과 독립적으로 이유로 기능하도록 의도된 것”이라고 말한다. 그는 이어, “사회에서 사령자의 말들이 결정적 행위 이유들(peremptory reasons for action)로 일반적으로 인정되는 것은 사회 규칙의 존재와 동일하다”고 주장한다(H. L. A. Hart, 「사령과 권위 있는 법적 이유(Commands and Authoritative Legal Reasons)」, 『벤담에 관한 에세이(Essays on Bentham)』 제10장, 258쪽 참조). 하트는 ‘법적·도덕적 의무(Legal and Moral Obligation)’라는 논문에서 ‘내용 독립적’ 이유들(content-independent reasons)이라는 관념을 처음 도입하였으며, 이는 A. I. 멜든(A. I. Melden) 편 『도덕철학 에세이(Essays in Moral Philosophy)』(워싱턴 대학 출판부, 1958), 82-107쪽에 수록되어 있다. 이 관념은 라즈의 『자유의 도덕성(The Morality of Freedom)』(옥스퍼드 대학 출판부, 1986) 제2장에서, 그리고 레슬리 그린(Leslie Green)의 『국가의 권위(The Authority of the State)』(옥스퍼드 대학 출판부, 1990), 36-42쪽에서 더욱 발전되었으며, P. 마크위크(P. Markwick)의 「법과 내용 독립적 이유들(Law and Content-Independent Reasons)」(*Oxford Journal of Legal Studies*,

2000년 제20권, 579쪽)에서는 비판받았다.

56-58쪽. 법의 ‘내부 측면’ (internal aspect). 하트는 종종 ‘내부 관점(internal point of view)’ 과 ‘내부 측면(internal aspect)’ 을 혼용해서 사용한다(예: 88-89쪽 참조). 이 일반 관념에 대해서는 닐 매클릭(Neil MacCormick), 『H. L. A. Hart』 29-40쪽 참조. 이 관념의 모호성에 대한 논의로는 스티븐 페리(Stephen Perry), 「하트의 사회 규칙과 법의 기초: 내부 관점의 해방(Hart on Social Rules and the Foundations of Law: Liberating the Internal Point of View)」(*Fordham Law Review*, 2006년 제75권, 1171쪽), 스콧 샤피로(Scott J. Shapiro), 「내부 관점이란 무엇인가?(What is the Internal Point of View?)」(*Fordham Law Review*, 2006년 제75권, 1157쪽) 참조. 법이론에서 이 관념의 방법론적 중요성은 라즈, 『권위와 해석 사이(Between Authority and Interpretation)』 제2장에서 논의된다. 이 방법론적 주장에 대한 비판으로는 스티븐 페리, 「법이론에서의 해석과 방법론(Interpretation and Methodology in Legal Theory)」, 안드레이 마머(Andrei Marmor) 편 『법과 해석(Law and Interpretation)』(옥스퍼드 대학 출판부, 1997), 존 피니스(John Finnis), 『자연법과 자연권(Natural Law and Natural Rights)』 제1장 등이 있다. 피니스의 비판은 줄리 디슨(Julie Dickson), 『평가와 법이론(Evaluation and Legal Theory)』(하트 출판사, 2001), 제2-4장에서 면밀히 분석된다.

66-71쪽. 입법 권한에 대한 법적 제한. 하트는 『벤담에 관한 에세이(*Essays on Bentham*)』 제9장 「주권과 법적으로 제한된 정부(Sovereignty and Legally Limited Government)」에서 벤담이 법적으로 제한된 정부를 이해하려 한 시도들을 검토한다. 오스틴의 제한 불가능성(illimitability)에 대한 라즈의 비판은 『법체계의 개념(The Concept of a Legal System)』 제2장에서 다루어진다. 오스틴의 분석이 헌법에 대해 가질 수 있는 함의에 대해서는 제프리 마셜(Geoffrey Marshall), 『헌법 이론(Constitutional Theory)』(옥스퍼드 대학 출판부, 1980), 제1, 3장 참조.

V. 일차 규칙들과 이차 규칙들의 결합으로서의 법 (LAW AS THE UNION OF PRIMARY AND SECONDARY RULES)

1. 새로운 출발

앞선 세 장에서 우리는 법을 주권자의 강제적 명령들로 이해하는 단순한 모형이 법체계의 두드러진 특징들(salient features) 중 일부를 재현하는 데 여러 핵심적 지점들(crucial points)에서 실패했다는 점을 확인하였다. 이를 입증하기 위해, 이전 비평가들이 그랬던 것처럼 국제법이나 원시적 법(primitive law), 곧 어떤 이들이 법의 논쟁적이거나 경계적인 사례들(disputable or borderline examples of law)로 여길 수 있는 것들을 끌어올 필요는 없었다. 대신 우리는 현대 국가의 국내법에서 익숙하게 발견되는 일정한 특징들을 지목하였고, 이러한 특징들이 지나치게 단순한(over-simple) 이 이론에서는 왜곡되거나 아예 재현되지 않는다는 점을 보였다.

이 이론이 실패한 주요 방식들은 다시 요약할 만할 만큼 시사적이다. 첫째, 법들의 모든 다양상들(varieties of law) 가운데, 특정 행위들을 제재적-벌의(penalty) 아래에서 금지하거나 명하는 형사 제정법(criminal statute)은, 한 사람이 다른 사람들에게 내리는 위협으로 뒷받침된 명령들과 가장 닮아 있음이 분명해졌다. 그럼에도 그러한 제정법은 일반적으로 타인에게만이 아니라 그것을 제정한 자들에게도 적용된다는 중요한 점에서 그러한 명령들과 다르다. 둘째, 법의 다른 다양상들도 있는데, 특히 재판하거나 입법할 법적 권한들(공적 권한들)을 부여하거나 법적 관계들(legal relations)을 창설하거나 변경할 법적 권한들(사적 권한들)을 부여하는 것들은 터무니없음을 감수하지 않고서는 위협으로 뒷받침된 명령들로 해석될 수 없다. 셋째, 법규칙들 중에는 그 기원의 방식(mode of origin)에서 명령들과 다른 것들이 있는데, 이는 그것들이 명시적 처방(prescription)과 유사한 어떤 것에 의해 성립되는 것이 아니기 때문이다. 마지막으로, 법을, 습관적으로 복종을 받고 모든 법적 제한(legal limitation)

으로부터 필연적으로 면제되는 주권자의 관점에서 분석하려는 시도는 현대 법체계에 특징적인 입법 권위의 계속성을 설명하지 못했으며, 주권자인 인격 또는 인격들을 현대 국가의 선거권자 집단이나 입법부 어느 쪽과도 동일시할 수 없었다.

(p. 80) 이와 같이 법을 주권자의 강제적 명령들로 보는 구상에 대한 비판 과정에서, 우리는 이 이론을 난점에서 구하기 위해 그 원초적 단순성을 훼손하는 대가로 도입되었던 여러 보조 장치들도 함께 검토했음을 상기할 수 있다. 그러나 이들 역시 실패하였다. 예컨대 ‘묵시적 명령(tacit order)’이라는 관념(notion)은, 부하들이 내린 명령에 일부러 간섭하지 않는 장군의 경우와 같은 훨씬 더 단순한 상황에만 적용될 뿐, 현대 법체계의 복잡한 현실에는 적용되지 않는 듯했다. 다른 장치들, 예컨대 권한부여 규칙을 책무를 부과하는 규칙의 단순한 파편으로 취급하거나, 모든 규칙을 오직 공무담당자들에게만 향한 것으로 취급하는 장치들은, 실제 사회생활에서 이러한 규칙들이 말해지고(spoken of), 사고되고(thought of), 실제로 사용되는 방식들을 왜곡한다. 이것은 경기의 모든 규칙이 ‘실제로는’ 심판과 기록원을 향한 지시라는 이론보다 우리의 동의를 얻을 자격이 더 크지 않았다. 입법의 자기구속적 성격을 제정법은 타인들에게 내려진 명령이라는 이론과 조화시키기 위해 고안된 장치는, 공적 행위능력에서 행위하는 입법자들을, 사적 행위능력에서의 자기 자신들을 포함하는 타인들에게 명령하는 하나의 인격으로 구별하는 것이었다. 이 장치는 그 자체로는 흠잡을 데 없지만, 본래 이 이론에는 포함되지 않은 어떤 것으로 그 이론을 보충하는 일을 수반한다. 그것은 바로 입법하기 위해 무엇을 해야 하는지를 규정하는 규칙이라는 관념(notion)이다. 왜냐하면 입법자들이 공적 행위능력과 사적 개인으로서의 자기 자신들과 대비되는 별개의 인격성을 가지는 것은 오직 그러한 규칙에 부합할 때뿐이기 때문이다.

이러한 이유로 앞선 세 장은 실패의 기록이며, 우리는 명백히 새로운 출발이 필요하다. 그러나 이 실패는 우리가 그것에 부여한 상세한 검토를 받을 가치가 있는, 시사적인 실패이기도 하다. 이론이 사실들과 맞아 들어가지 못한 지점마다, 그 실패가 왜 필연적이었는지, 또 더 나은 설명을 위해 무엇이 필요한지를 적어도 개략적으로 확인할 수 있었기 때문이다. 이러한 실패의 근본 원인은,

해당 이론이 구성되는 데 사용된 요소들, 곧 명령들, 복종, 습관들, 위협들이라는 관념들이 규칙이라는 관념을 포함하지 않으며, 그러한 요소들을 조합해도 규칙의 관념을 산출할 수 없다는 점에 있다. 하지만 규칙 없이는 법의 가장 기초적인 형태들조차도 해명할(elucidate) 수 있기를 기대할 수 없다. 물론 규칙이라는 관념은 결코 단순한 것이 아니다. 우리는 이미 제3장에서, 법체계의 복잡성을 정당하게 다루려면(do justice), (p. 81) 서로 관련되지만 구별되는 두 종류의 규칙을 구별할(discriminate) 필요가 있음을 보았다. 그 중 첫 번째 유형, 즉 기본적인거나 일차적인 유형으로 보아도 좋을 유형은, 인간들이 원하는 원하지 않는 특정한 행위를 하거나 삼가도록 요구하는 규칙이다. 다른 유형의 규칙들은 어떤 의미에서는 첫 번째 유형에 기생하거나 이차적인 것이다. 왜냐하면 그것들은 인간들이 일정한 일을 하거나 말함으로써 일차 유형의 새로운 규칙들을 도입하거나, 기존 규칙들을 소멸시키거나 수정하거나, 다양한 방식으로 그 귀속양상(incidence)을 결정하거나 그 작동을 통제할 수 있다고 정하기 때문이다. 첫 번째 유형의 규칙들은 책무들(duties)을 부과하며, 두 번째 유형의 규칙들은 공적 또는 사적 권한들을 부여한다. 첫 번째 유형의 규칙들은 신체적 움직임이나 변화가 관련된 행위들에 관한 것이고, 두 번째 유형의 규칙들은 단지 물리적 움직임이나 변화에 그치지 않고 책무들(duties)이나 의무들(obligations)의 생성 및 변경으로 이어지는 작용들(operations)을 마련한다(provide for).

우리는 이미 특정한 사회 집단 안에 이 두 유형의 규칙들이 존재한다는 단언(assertion)에 무엇이 포함되는지에 관해 예비적 분석을 제시한 바 있다. 이 장에서는 그러한 분석을 조금 더 밀고 나갈 뿐만 아니라, 이 두 유형의 규칙들의 결합 속에 오스틴이 강제적 명령들이라는 관념(notion)에서 잘못 발견하였다고 주장했던 바로 그것, 즉 “법리학이라는 학문의 열쇠”가 놓여 있다는 일반적 주장(claim)을 제기할 것이다. 기실 우리는 ‘법’이라는 단어가 ‘적절하게’ 사용되는 곳마다 이러한 일차 규칙들과 이차 규칙들의 결합이 발견된다고 주장하려는 것은 아니다. 왜냐하면 ‘법’이라는 단어가 사용되는 다양한 범위의 사례들은 그러한 단순한 통일성(uniformity)에 의해 연결되는 것이 아니라, 중심 사례와 형태나 내용 면에서의 유비에 기초한, 덜 직접적인 관계들에 의해 연결되어 있음이 분명하기 때문이다. 우리가 이 장과 이후의 장들에서 시도할 것은, 가장

난해한 것으로 드러났고 정의(definition)를 찾으려는 시도를 불러일으키면서도 동시에 그 시도를 피해 왔던 법의 특징들 대부분이, 이 두 유형의 규칙들과 그 상호작용을 이해할 때 가장 잘 명료하게 드러날 수 있다는 점을 보여주는 것이다. 우리는 이러한 요소들의 결합에 중심적 지위를 부여하는데, 그것이 법적 사고의 틀을 구성하는 개념들을 해명하는 설명력을 가지기 때문이다. 외견상 이질적인 범위의 사례들에 대해 ‘법’이라는 단어를 사용하는 것의 정당화는 이차적인 문제이며, 이 중심 요소들이 파악된 뒤에 수행될 수 있다.

2. 의무(obligation)라는 관념

(p. 82) 지금까지의 검토를 통해 알 수 있는 것은, 법을 강제적 명령들(coercive orders)로 이해하는 이론은 여러 오류에도 불구하고, “법이 존재하는 곳에서는 인간 행위가 어떤 의미에서는 선택 불가능하고(non-optional), 의무적(obligatory)이 된다”는 사실을 정확히 인식하고 출발했다는 점이다. 이러한 출발점 선택은 좋은 착안이었으며, 본 장에서 우리가 새롭게 구성하고자 하는 일차 규칙들(primary rules)과 이차 규칙들(secondary rules)의 상호작용에 기초한 법 설명 역시 동일한 관념에서 출발할 것이다. 그러나 바로 이 핵심적 첫 단계(crucial first step)에서, 우리는 강제적 명령 이론의 오류들로부터 아마도 가장 많은 교훈을 얻을 수 있다.

이제 “권총강도 상황(the gunman situation)”을 떠올려보자. A는 B에게 돈을 건네라고 명령하고, B가 준수하지 않으면 총을 쏠 것이라고 위협한다. 강제적 명령 이론에 따르면, 이 상황은 일반적인 의미에서 의무(obligation) 또는 책무(duty)에 대한 관념(notion)을 예시한다. 이 이론은 법적 의무(legal obligation)가 이 상황의 확대판에서 발견된다고 본다. 즉, A는 습관적으로 복종받는 주권자여야 하고, 그의 명령들은 단일 행위가 아니라 일반적인 행위노선들(courses of conduct)을 규정해야 한다. 권총강도 상황이 의무(obligation)의 의미를 보여준다는 주장(claim)의 그럴듯함은, 우리가 이 상황에서 B가 복종했다면 “B는 돈을 건네지 않을 수 없었다(obliged)”고 말할 것임이 분명하다는 점에 있다. 그러나 동시에, 이 사실들에 기초하여 “B는 돈을 건넬 의무(obligation)를 지니고

있었다”거나 “책무(duty)를 지니고 있었다”고 말한다면, 이는 그 상황을 잘못 기술하는 것임도 마찬가지로 분명하다. 따라서 처음부터 우리는 의무라는 개념을 이해하기 위해 다른 무엇인가가 필요하다는 점이 명백하다. “어떤 사람이 어떤 행위를 하지 않을 수 없었다(*was obliged to do something*)”는 단언과 “그 사람은 그 행위를 할 의무를 가졌다(*had an obligation*)”는 단언 사이에는, 아직 설명되지 않은 차이가 존재한다. 첫 번째 진술은 주로 어떤 행위가 수행될 때 동반된 믿음들(beliefs)과 동기들(motives)에 관한 진술이다. 예컨대 “B는 돈을 건네지 않을 수 없었다”는 진술은, 권총강도 상황에서처럼, 그가 돈을 건네지 않는다면 해를 입거나 불쾌한 결과가 발생할 것이라고 믿었으며, 그 결과를 피하고자 돈을 건넸다는 의미일 수 있다. 이러한 경우, 불복종했을 때 행위자에게 일어날 일에 대한 전망은, 그가 원래 선호했을 행위(즉 돈을 지니는 것)를 덜 선택할 만한 것으로 만든 것이다.

어떤 일을 하지 않을 수 없음이라는 관념(the notion of being obliged to do something)의 해명을 약간 더 복잡하게 만드는 두 가지 추가적 요소가 있다. 위협된 해악(harm)이, 통상적인 (p. 83) 판단에 비추어 볼 때, 명령들을 준수하는 것이 B 자신이나 타인에게 가져올 불이익이나 중대한 결과에 비해 사소한 것에 불과하다면, 예컨대 A가 단지 B를 꼬집겠다고 위협하는 경우처럼, 우리는 B가 돈을 건네지 않을 수 없었다(obliged to hand over)고 생각해서는 안 될 것이 분명해 보인다. 또한 상대적으로 중대한 해악(harm)에 대한 위협을 A가 실행할 수 있거나 실제로 실행할 개연성이 있다고 생각할 합리적 근거가 없다면, 그 경우에도 아마 B가 돈을 건네지 않을 수 없었다고 말해서는 안 될 것이다. 그러나 해악의 비교(comparative harm)에 대한 통상적 판단과 개연성에 대한 합당한 평가(reasonable estimates of likelihood)에 대한 그러한 참조들(references)이 이 관념에 암묵적으로 포함되어 있기는 하지만, 어떤 사람이 누군가에게 복종하지 않을 수 없었다(*was obliged to obey*)는 진술(statement)은 주로 그 행위가 수행될 때 동반된 믿음과 동기를 참조하는 심리적인(psychological) 진술이다. 이에 반해, 어떤 사람이 무언가를 할 의무를 가졌다(*had an obligation*)는 진술은 전혀 다른 유형에 속하며, 이 차이를 보여 주는 징후들(signs)은 많다. 즉, 권총강도 사례에서 B의 행위에 관한 사실들과 그의 믿음과 동기에 관한 사실들이 B가

지갑을 건네지 않을 수 없었다(obliged to hand over)는 진술을 정당화하기에는 충분하지만, 그것만으로는 그가 그렇게 할 의무를 가졌다고 말하기에는 충분하지 않다(not sufficient)는 점뿐만 아니라, 이러한 종류의 사실들, 즉 믿음과 동기에 관한 사실들은 어떤 사람이 무언가를 할 의무를 가졌다는 진술이 참이기 위해 필요하지도 않다(not necessary)는 점도 그렇다. 예컨대 어떤 사람이 진실을 말하거나 군 복무에 응할 의무를 가졌다는 진술은, 그가 (합리적으로든 비합리적으로든) 결코 발각되지 않을 것이라고 믿었고 불복종으로 인해 두려워할 것이 아무것도 없다고 생각했더라도 여전히 참으로 남는다. 더 나아가, 그가 실제로 복무에 응했는지 여부와는 무관하게 그가 이러한 의무를 가졌다는 진술이 성립하는 반면, 어떤 사람이 어떤 일을 하지 않을 수 없었다(obliged to do)는 진술은 통상적으로 그가 실제로 그것을 했다는 함의를 전달한다.

일부 이론가들, 그중에는 오스틴도 있는데, 이들은 개인의 믿음이나 공포, 동기가 그가 어떤 일을 할 의무를 가졌는지 여부의 질문과 일반적으로 무관하다는 점을 보고, 이 관념을 주관적 사실들(subjective facts)이 아니라 불복종 시 그 의무를 지닌 사람이 타인의 손에 의해 처벌(punishment)을 받거나 ‘악(evil)’을 당하게 될 가망(chance) 또는 개연성(likelihood)이라는 용어로 정의해 왔다. 이는 사실상 의무에 관한 진술을 심리적 진술이 아니라, 처벌을 받거나 ‘악(evil)’을 당할 가망(chances)에 대한 예측 또는 평가로 취급하는 것이다. 많은 후대 이론가들에게 이것은, (p. 84) 포착하기 어려운 관념을 현실로 끌어내려, 과학(science)에서 사용되는 것과 동일한 명확하고 엄밀한 경험적 용어로 그것을 재진술해 주는 계시(revelation)처럼 보였다. 기실 이는, 일상적이고 관찰 가능한 사실들의 세계 ‘위(above)’ 또는 ‘배후에(behind)’ 신비롭게 존재하는 보이지 않는 대상들로서의 의무(obligation)나 책무(duty)에 관한 형이상학적 구상들에 대한 유일한 대안으로 받아들여지기도 하였다. 그러나 의무에 관한 진술을 예측으로 해석하는 이러한 해석을 배척해야 할 이유들은 많으며, 이것은 사실상 불명료한 형이상학에 대한 유일한 대안도 아니다.

근본적인 반론은, 규칙이 존재하는 경우, 규칙으로부터의 이탈(deviations)이 단지 적대적 반응이 뒤따를 것이라는 예측이나, 법원이 위반자들에게 제재를 적용할 것이라는 예측의 근거에 그치는 것이 아니라, 그러한 반응과 제재의

적용을 위한 이유(reason) 또는 정당화(justification)이기도 하다는 사실을, 예측적 해석(predictive interpretation)이 가린다는 점에 있다. 우리는 이미 제4장에서 규칙의 내부 측면(internal aspect of rules)에 대한 이러한 간과를 지적한 바 있으며, 이 장의 후반부에서 이를 더욱 상세히 전개할 것이다.

그러나 의무에 대한 예측적 해석에는 두 번째이자 보다 단순한 반론이 있다. 만약 “어떤 사람에게 의무가 있다(had an obligation)”는 진술이 “그 사람이(he) 불복종할 경우 고통을 겪을 개연성이 있다(he was likely to suffer in the event of disobedience)”는 의미라면, 예컨대 “그가 군 복무에 응할 의무를 지니고 있다”면서 동시에 “그가 관찰권 밖으로 도피했거나, 경찰이나 법원을 성공적으로 매수하여, 발각되거나 고통을 당할 가망이 조금도 없다”고 말하는 것은 모순이 되어야 할 것이다. 그러나 실제로 그러한 말을 하는 데에는 아무런 모순이 없으며, 이러한 진술은 실제로 자주 행해지며 이해된다.

물론, 정상적인 법체계에서는 제재(sanctions)가 위반행위들(offences)의 상당한 비율에 대해 실제 부과되므로, 위반자(offender)는 대체로 처벌받을 위험에 놓인다(runs a risk). 따라서 보통 “그에게 의무가 있다”는 진술과 “그가 불복종으로 인해 고통을 겪을 개연성이 있다”는 진술은 함께 참이 되는 경우가 많다. 기실(Indeed), 이 두 진술 사이의 연결은 이보다 조금 더 강하다. 적어도 국내법 체계에서는, 일반적으로(in general) 제재가 위반자에게 부과될 개연성이 없다면, 특정한 개인의 의무에 관한 진술들을 하는 데 거의 또는 전혀 의미가 없게 될 수도 있다. 이러한 의미에서, 그러한 진술들은 제재 체계의 계속적인 정상 작동에 대한 (p. 85) 믿음을 전제한다(presuppose)고 말할 수 있다. 이는 마치 크리켓 경기에서 “그는 아웃이다(he is out)”라는 진술이, 선수, 심판, 기록원이 통상적인 조치를 취할 개연성이 있음을 단언하지는 않지만 전제하는 것과 같다. 그럼에도 불구하고, 개별 사례(individual cases)에서는 “어떤 사람이 어떤 규칙 아래에서 의무를 지닌다(has an obligation under some rule)”는 진술과 “그가 불복종으로 인해 고통을 겪을 개연성이 있다”는 예측이 서로 분기할 수 있다(diverge)는 점을 이해하는 것이 의무라는 관념 이해에 있어 핵심적이다.

“~하지 않을 수 없음(being obliged)”이라는 보다 단순한 관념은 그 상황의 구성요소들로부터 정의될 수 있을지도 모르지만, 의무(obligation)는 권충강도

상황(gunman situation)에서 발견될 수 없다는 것은 명백하다. 의무를 법적 형태로 이해하기 위한 필수적인 예비단계로서 그 일반적 관념(idea)을 파악하려면, 사회적 규칙들(social rules)이 존재하는, 권총강도 상황과는 다른 사회적 상황을 살펴보아야 한다. 왜냐하면 이 상황은 한 개인이 어떤 의무를 지닌다는 진술의 의미에 두 가지 방식으로 기여하기 때문이다. 첫째, 그러한 규칙들의 존재는, 특정한 유형의 행위를 행동 기준(standard)으로 만들면서, 이러한 의무 진술에 대해 정상적인, 진술되지는 않더라도, 배경 또는 적절한 맥락(background or proper context)이다. 둘째, 이러한 진술의 특유한 기능은 어떤 개인의 사례가 일반 규칙의 적용 대상에 해당한다는 사실에 주의를 환기함으로써 일반 규칙을 특정인에게 적용(apply a general rule to a particular person)하는 데 있다. 우리는 이미 제4장에서, 어떤 사회 규칙들이 존재한다는 것은 반복적으로 일양적인 행위(regular conduct)와 그 행위를 행동 기준으로 간주하는 특유한 태도(distinctive attitude)의 결합을 포함한다는 점을 본 바 있다. 우리는 또한 사회적 습관들(social habits)과 사회 규칙들 사이의 주된 차이점이 무엇인지, 그리고 어떻게 다양한 규범적 어휘—예컨대 ‘~해야 한다(ought)’, ‘반드시 해야 한다(must)’, ‘그렇게 하는 것이 마땅하다(should)’—가 행동 기준 및 그로부터의 이탈(deviations)에 주의를 환기하고, 이를 근거로 요구(demands), 비판(criticisms), 인정(acknowledgements)을 정식화하는 데 사용되는지를 확인하였다. 이러한 규범적 단어들의 부류(class) 중 ‘의무(obligation)’와 ‘책무(duty)’는 중요한 하위부류(sub-class)를 형성하며, 보통 다른 어휘들에는 포함되지 않는 몇 가지 함의를 지닌다. 따라서, 사회 규칙들을 단순한 습관들과 일반적으로 구분해 주는 요소들을 파악하는 것은 의무 또는 책무라는 관념을 이해하기 위해 반드시 필요하지만, 그것만으로는 충분하지 않다.

누군가에게 “의무가 있다(has an obligation)” 또는 “그는 의무를 지고 있다(is under an obligation)”는 진술은 기실 규칙의 존재를 함축한다. 그러나 규칙이 존재하는 모든 경우에 그 규칙이 요구하는 행동 기준이 (p. 86) 의무(obligation)라는 틀에서 이해되는 것은 아니다. 예컨대 “그는 그렇게 했어야 했다(He ought to have)”와 “그는 그렇게 할 의무가 있었다(He had an obligation to)”는 표현은, 비록 둘 다 현존하는 행위 기준들에 대한 암묵적 참조(implicit reference to

existing standards of conduct)를 포함하거나 일반 규칙으로부터 특정 사례에 대한 결론을 이끌어낼 때 사용된다는 점에서는 유사하지만, 항상 호환 가능한(interchangeable) 표현은 아니다. 예절(etiquette)이나 올바른 말씨(correct speech)의 규칙은 분명히 규칙이다. 단지 수렴적 습관들이나 행태의 반복적 일양성들(regularities of behaviour) 이상의 것으로서, 가르쳐지고 유지되기 위해 노력되며, 자기 자신이나 타인의 행동을 평가하고 비판할 때 규범적 어휘로 표현된다. 예를 들어 “모자를 벗는 것이 예의다(You ought to take your hat off)” 라거나, “‘you was’라고 말하는 것은 그르다(It is wrong to say ‘you was’)”와 같은 진술이 그 예이다. 그러나 이러한 규칙들과 관련하여 ‘obligation(의무)’이나 ‘duty(책무)’라는 단어를 사용하는 것은 단순히 문체적으로 부자연스러울 뿐 아니라, 사회적 상황을 잘못 기술하는 것이다. 물론 의무의 규칙들과 그 밖의 규칙들을 구분하는 경계는 경우에 따라 모호할 수 있으나, 그 구분의 핵심 근거(main rationale of the distinction)는 비교적 명확하다.

규칙은, 그에 대한 일반적인 부합 요구(general demand for conformity)가 집요하고(insistent), 일탈하거나 일탈하려는 자들에게 가해지는 사회적 압력이 클 때, 의무들(obligations)을 부과하는 것으로 구상되고 그렇게 말해진다(spoken of). 이러한 규칙들은 기원상 전적으로 관습적(customary)일 수도 있다. 규칙 위반에 대해 중앙집중적으로 조직된 처벌 체계가 전혀 존재하지 않을 수도 있으며, 사회적 압력은 물리적 제재에까지 이르지 않는, 일반적이고 분산된 적대적 또는 비판적 반응의 형태만을 취할 수도 있다. 그 압력은 불승인의 언어적 표명(verbal manifestations of disapproval)이나, 위반된 규칙에 대한 개인의 존중에 호소하는 방식으로 제한될 수도 있고, 수치심(shame), 후회(remorse), 죄책감(guilt)과 같은 감정의 작용에 크게 의존할 수도 있다. 압력이 이러한 마지막 유형의 것일 때, 우리는 그 규칙들을 사회 집단의 도덕(morality)의 일부로, 그리고 그 규칙에 따른 의무를 도덕적 의무(moral obligation)로 분류하려는 경향을 갖게 된다. 반대로, 물리적 제재가 압력의 형태들 가운데 두드러지거나 통상적인 경우에는, 비록 그러한 제재들이 엄밀하게 규정되어 있지 않거나 공무 담당자들에 의해 집행되지 않고 공동체 전체에 맡겨져 있다 하더라도, 우리는 그 규칙들을 원시적이거나 기초적인 형태의 법(primitive or rudimentary form

of law)으로 분류하려는 경향을 보이게 된다. 물론 우리는, 명백한 의미에서 동일한 행위 규칙(rule of conduct) 배후에 이 두 유형의 심각한(serious) 사회적 압력이 모두 존재하는 경우를 발견할 수도 있다. 때로는 이 둘 가운데 어느 하나가 일차적(primary)이고 다른 (p. 87) 하나가 이차적(secondary)으로서 특별히 적합하다는 표지(indication)가 전혀 없는 채로 그러한 상황이 발생할 수도 있으며, 그러한 경우 우리가 도덕 규칙(rule of morality)에 직면해 있는지 아니면 기초적 법(rudimentary law)에 직면해 있는지에 대한 질문은 답을 가질 수 없을 수도 있다. 그러나 당장은 법과 도덕 사이에 선을 긋는 가능성이 우리를 붙잡아 둘 필요는 없다. 중요한 것은, 규칙들 배후에 놓인 사회적 압력의 중요성 또는 심각성(seriousness)에 대한 강조가, 그 규칙들이 의무를 발생시키는 것으로 사고되는지를 결정하는 일차적 요인(primary factor)이라는 점이다.

의무(obligation)의 다른 두 가지 특성은 이러한 일차적 특성과 자연스럽게 결합된다. 이러한 심각한 압력에 의해 뒷받침되는 규칙들은, 사회적 삶(social life) 또는 그 가운데서도 특히 중시되는 어떤 특징을 유지하는 데에 필요하다고(necessary) 믿어지기 때문에 중요하다고 여겨진다. 전형적으로, 폭력의 자유로운 사용을 제한하는 것과 같이 명백히 필수적인 규칙들은 의무의 관점에서 이해된다. 마찬가지로 정직(honesty)이나 진실(truth)을 요구하거나 약속의 유지(keeping of promises)를 요구하는 규칙들, 또는 사회 집단 내에서 특정한 역할이나 기능을 수행하는 자가 무엇을 해야 하는지를 규정하는 규칙들 역시, ‘의무(obligation)’ 혹은—아마도 더 자주—‘책무(duty)’의 관점에서 이해된다. 둘째로, 이러한 규칙들이 요구하는 행위는 타인에게 이익을 주는 경우라 하더라도, 그 책무를 지는 사람(the person who owes the duty)이 하고자 하는 바와 충돌할 수 있다는 점이 일반적으로 인식된다. 따라서 의무와 책무는 전형적으로 희생(sacrifice)이나 포기(renunciation)를 수반하는 것으로 이해되며, 의무 또는 책무와 이익(interest) 사이의 상존하는 충돌 가능성(standing possibility)은 모든 사회에서 법률가와 도덕론자 모두에게 자명한 이치들(truisms) 가운데 하나로 여겨진다.

‘의무(obligation)’라는 단어 속에 잠재해 있는, 의무를 지는 사람을 구속하는 유대(bond)라는 형상(figure)과, 책무(duty)라는 단어 속에 잠재해 있는 채무

(debt)라는 유사한 관념(notion)은, 의무 또는 책무의 규칙들을 다른 규칙들과 구별해 주는 이러한 세 가지 요소들에 비추어 설명될 수 있다. 법적 사고의 많은 부분을 떠도는 이 형상 속에서, 사회적 압력(social pressure)은 의무를 지닌 자들을 묶어 그들이 원하는 대로 자유롭게 행동하지 못하도록 하는 사슬(chain)로 나타난다. 이 사슬의 다른 한쪽 끝은 때로는, 이행(performance)을 요구하거나 제재적-불이익(penalty)을 부과하는, 집단(group)이나 그 공무담당 대표자들(official representatives)이 쥐고 있다. 때로는 그 사슬이 집단에 의해, 이행이나 그에게 가치상 등가인 것(equivalent)을 요구할 것인지 말 것인지 여부를 선택할 수도 있는 사적 개인(private individual)에게 위임된다. 첫 번째 상황은 형사법(criminal law)의 책무 또는 의무를 전형적으로 보여 주며, 두 번째 상황은 민사법(civil law)의 책무 또는 의무를 전형적으로 보여 주는데, 이 경우 우리는 (p. 88) 사적 개인들이 그 의무들에 상관적인 권리들(rights correlative to the obligations)을 가진다고 생각하게 된다.

이러한 형상들 또는 은유들(figures or metaphors)이 자연스럽고 어찌면 설명을 돕기는 할지라도, 우리는 그것들 때문에 의무(obligation)에 관한 오도적 구상, 곧 의무가 본질적으로 의무를 가진 사람들이 경험하는 어떤 압박감이나 강제감의 감정(feeling)으로 이루어진다는 구상에 빠지지 않도록 해야 한다. 의무의 규칙들이 일반적으로 강한 사회적 압력에 의해 지지된다는 사실이, 그 규칙들 아래에서 의무를 가진다는 것이 곧 강제나 압박의 감정을 경험하는 것이라는 점을 함축하는 것은 아니다. 따라서 어떤 노련한 사기꾼(hardened swindler)에 대해, 그가 집세를 지불할 의무가 있었지만 아무런 압박도 느끼지 않은 채 지불하지 않고 달아났다고 말하는 데에는 모순이 없으며, 실제로 그러한 경우는 흔히 참일 수 있다. 하지 않을 수 없다고 느끼는 것(to feel obliged)과 의무를 갖는 것(to have an obligation)은 서로 다른 것이며, 다만 흔히 동반될 뿐이다. 이 둘을 동일시하는 것은, 제3장에서 우리가 주목한 규칙의 중요한 내부 측면(internal aspect)을 심리적 감정의 용어로 오해하는 하나의 방식이 될 것이다.

기실, 규칙의 내부 측면(internal aspect of rules)은 예측 이론(predictive theory)의 주장들(claims)을 최종적으로 처리하기 전에 우리가 다시 참조해야

할 대상이다. 왜냐하면 그 이론의 옹호자는, 사회적 압력이 의무의 규칙들(rules of obligation)의 중요한 특징이라면, 왜 우리가 예측 이론의 불충분함을 그토록 강조하는지 충분히 물을 수 있기 때문이다. 왜냐하면 예측 이론은, 의무를 특정한 행위 노선으로부터의 일탈에 대해 위협된 처벌이나 적대적 반응이 뒤따를 개연성(likelihood)의 관점에서 정의함으로써, 바로 그 특징을 중심에 두기 때문이다. 의무에 관한 진술을, 일탈에 대한 적대적 반응의 예측 또는 그 가망(chances)에 대한 평가로 분석하는 것과, 그러한 진술이 규칙으로부터의 일탈이 일반적으로 적대적 반응으로 대응되는 배경을 전제하되, 그 특징적인 사용은 이를 예측하는 데 있는 것이 아니라 어떤 사람의 경우가 그러한 규칙 아래에 해당함을 말하는 데 있다는 우리의 논지(contention) 사이의 차이는 사소해 보일 수 있다. 그러나 실제로 이 차이는 사소한 것이 아니다. 오히려 기실, 이 차이의 중요성이 파악되지 않는 한, 우리는 규칙의 존재에 수반되는 인간의 사고, 언어, 행위의 전체적인 독특한 양식을 제대로 이해할 수 없으며, 바로 그것이 사회의 규범적 구조(normative structure of society)를 구성한다.

다음의 대비는 규칙의 ‘내부(internal)’ 측면과 (p. 89) ‘외부(external)’ 측면이라는 용어로 다시 한 번 제시되며, 이 구별이 법뿐만 아니라 모든 사회의 구조를 이해하는 데 왜 그토록 중요한지를 분명히 하는 데 도움이 될 수 있다. 어떤 사회 집단이 일정한 행위 규칙들을 가지고 있다는 사실은, 서로 밀접하게 관련되어 있으나 서로 다른 여러 종류의 단언(assertion)을 가능하게 한다. 왜냐하면 우리는 그 규칙들에 대해, 그것들을 스스로 수용하지 않는 단순한 관찰자의 입장에서 관심을 가질 수도 있고, 또는 그것들을 행위의 향도지침으로 수용하고 사용하는 집단의 구성원으로서 관심을 가질 수도 있기 때문이다. 우리는 전자를 ‘외부 관점(external point of view)’, 후자를 ‘내부 관점(internal point of view)’ 이라고 부를 수 있다. 외부 관점에서 이루어지는 진술들 또한 그 자체로 여러 유형일 수 있다. 왜냐하면 관찰자는 자신이 그 규칙들을 수용하지 않으면서도, 그 집단이 그 규칙들을 수용하고 있다는 사실을 단언할(assert) 수 있으며, 이로써 그들이(they) 내부 관점에서 그 규칙들과 어떤 방식으로 관계하는지를 외부에서 참조할(refer) 수도 있기 때문이다. 그러나 규칙이 무엇이든, 그것이 체스나 크리켓과 같은 게임의 규칙이든, 도덕 규칙이든, 법규칙들이든 간에,

우리는 원한다면 집단의 내부 관점을 이와 같은 방식으로조차 참조하지 않는 관찰자의 위치에 설 수도 있다. 이러한 관찰자는 규칙에의 부합(conformity)이 부분적으로 구성하는 관찰 가능한 행동의 반복적 일양성들(regularities)과, 규칙으로부터의 이탈에 대해 적대적 반응, 질책, 또는 처벌의 형태로 나타나는 추가적인 반복적 일양성들을 단지 기록하는 데 만족한다. 시간이 지나면 외부 관찰자는 관찰된 이러한 반복적 일양성들에 기초하여 이탈과 적대적 반응을 상관시키고, 집단의 정상적인 행태로부터의 이탈이 적대적 반응이나 처벌을 불러올 것이라는 가망(chances)을 상당한 성공률로 예측하고 평가할 수 있게 된다. 이러한 지식은 그 집단에 대해 많은 것을 드러낼 뿐만 아니라, 그러한 지식 없이 그들 사이에서 살려고 시도하는 사람에게 따를 불쾌한 결과를 피하면서 그들 속에서 살아갈 수 있도록 해 줄 수도 있다.

그러나 만일 관찰자가 이러한 극단적인 외부 관점(external point of view)에 엄격히 머무르며, 그 규칙들을 수용하는 집단 구성원들이 자신들의 반복적으로 일양적인 행동(regular behaviour)을 어떻게 바라보는지를 전혀 설명하지 않는다면, 그는 그들의 삶을 규칙의 관점에서 기술할 수 없으며, 따라서 규칙에 의존하는 관념들(notions), 즉 의무(obligation)나 책무(duty)에 대한 관념들을 사용할 수도 없다. 그의 기술은 오로지 행위의 관찰 가능한 반복적 일양성들(observable regularities of conduct), 예측(predictions), 확률(probabilities), 징후(signs)의 용어로만 이루어질 것이다. 이러한 관찰자에게 있어, (p. 90) 집단 구성원이 정상적인 행동에서 이탈(deviation)할 경우, 그것은 그저 적대적인 반응이 뒤따를 개연성이 있다는 징후(sign)에 불과하다. 그의 관점은 마치 어떤 이가 분주한 거리에서 일정 시간 동안 교통 신호등의 작동을 관찰한 후, 신호등이 빨간불로 바뀌면 차량이 멈출 확률이 높다고만 말하는 것과 같다. 그는 신호등을, 마치 구름이 비가 올 것이라는 징후(a sign that)인 것과 마찬가지로, 단지 사람들이 특정한 방식으로 행동할 것이라는 자연적 징후(a natural sign that)로만 취급한다. 그러나 이렇게 함으로써, 그는 자신이 관찰하고 있는 사람들의 사회적 삶의 한 전체 차원(a whole dimension of the social life)을 놓치게 된다. 왜냐하면, 그 사람들에게 있어서 빨간불은 단지 다른 사람들이 멈출 것이라는 징후(sign)가 아니라, 자신들이 멈추어야 한다는 신호(a signal for them to

stop)이며, 빨간불일 때 정지하는 것을 행동 기준이자 의무로 만드는 규칙들에 부합하여 멈출 하나의 이유(a reason)가 되기 때문이다. 이를 언급하는(mention) 것은 그 집단이 그들 자신의 행동을 어떻게 이해하고 있는지를 기술에 도입하는 것이며, 이는 곧 그들의 내부 관점에서 본 규칙의 내부 측면(the internal aspect of rules)을 참조하는(refer) 것이다.

이 외부 관점은 집단 내 특정 구성원들, 즉 그 규칙을 거부하고, 오직 그것을 위반 시 불쾌한 결과가 따를 것으로 판단할 때 그리고 그 이유에서만 관심을 가지는 자들의 삶에서 규칙이 작동하는 방식을 상당히 비슷하게 재현할 수 있다. 이들의 관점은 표현을 위해 다음과 같은 형식들을 필요로 할 것이다: “나는 그렇게 하지 않을 수 없었어(I was obliged to do it)”, “만약 … 한다면, 나는 그것 때문에 고통을 겪을 개연성이 있어(I am likely to suffer for it if…)”, “만약 … 하면, 너는 그것 때문에 아마 고통을 겪을 거야(You will probably suffer for it if…)”, “만약 … 하면, 그들은 너에게 그렇게 할 거야(They will do that to you if…)”. 그러나 이들은 “나는 의무가 있다(I had an obligation)” 또는 “너는 의무가 있다(You have an obligation)”와 같은 표현을 사용할 필요는 없다. 이러한 표현들은 자신과 타인의 행동을 내부 관점에서 바라보는 자들에게만 필요한 표현이기 때문이다. 반면, 행동의 관찰 가능한 반복적 일양성들(regularities)에만 주목하는 외부 관점은, 규칙이 어떻게 규칙으로서 사회 구성원의 삶에 작용하는지, 특히 그것이 통상 사회의 다수를 이루는 사람들, 즉 공무담당자들, 법률가들, 또는 사적 개인들의 삶에서, 규칙에 따른 삶의 익숙한 모든 상호작용들 속에서(in all the familiar transactions of life according to rules), 상황에서 상황으로 사회생활의 향도지침(guide to conduct)으로 작동하고, 청구(claims), 요구, 시인(admissions), 비판, 처벌의 근거가 되는 방식은 재현할 수 없다. 이들에게 있어 규칙 위반이란, 단순히 적대적 반응이 따를 것이라는 예측의 근거가 아니라, 그러한 적대적 반응의 이유(reason for hostility)이다.

어느 주어진 시점에서든, 법적이든 그렇지 않은 규칙들에 따라 살아가는 사회의 삶은 (p. 91) 다음 두 부류 사이의 긴장(tension)으로 이루어질 개연성이 있다. 한편으로는 규칙을 수용하고 자발적으로 그 규칙의 유지에 협력하며, 자기 자신과 타인의 행동을 규칙의 관점에서 이해하는 자들이 있고, 다른 한편

으로는 규칙을 거부하고, 그것을 오직 외부 관점에서 가능한 처벌의 징후로서만 주목하는 자들이 있다. 사실들의 복잡성(complexity of the facts)을 정당하게 다루려는(do justice) 어떠한 법이론이든 반드시 이 두 관점을 모두 고려해야 하며, 그중 하나를 정의상 존재하지 않는 것으로 만들어 버리지 않아야 한다. 아마도, 우리가 예측 이론에 대해 제기한 모든 비판을 가장 잘 요약할 수 있는 말은 다음과 같은 비판(accusation)일 것이다. 즉, 예측 이론은 의무적 규칙들(obligatory rules)의 내부 측면에 대해 바로 그런 일을 한다.

3. 법의 구성요소 (The Elements of Law)

물론 우리는 입법부도, 법원도, 어떠한 종류의 공무담당자도 존재하지 않는 사회를 상상할 수 있다. 기실, 원시 공동체에 관한 많은 연구들은 이러한 가능성(possibility)이 단지 상상 속의 것이 아니라 실제로 실현되고 있다고 주장(claim)할 뿐만 아니라, 오직 집단이 자기 자신의 표준적 행동양식(standard modes of behaviour)에 대해 가지는 일반적인 태도만을 사회 통제의 수단으로 삼는 사회의 삶을 상세히 묘사하고 있다. 우리는 앞서 이러한 태도에 근거하여 의무의 규칙들(rules of obligation)을 특징지은 바 있다. 이러한 사회 구조는 흔히 ‘관습(custom)’의 구조라고 지칭되지만(referred to), 우리는 이 용어를 사용하지 않을 것이다. 왜냐하면 ‘관습’이라는 표현은 종종 그러한 관습 규칙들(customary rules)이 매우 오래되었으며, 다른 규칙들보다 약한 사회적 압력만으로 지지되고 있다는 함축을 포함하기 때문이다. 이러한 함의를 피하기 위해 우리는 이러한 사회 구조를 의무의 일차 규칙들(primary rules of obligation)의 구조라고 지칭할(refer to) 것이다. 만약 어떤 사회가 오직 이러한 의무의 일차 규칙들에 의해서만 살아간다고 한다면, 인간 본성과 우리가 살아가는 세계에 대한 가장 명백한 몇 가지 자명한 이치들(truisms)을 전제할 때, 그 사회가 유지되기 위해서는 반드시 충족되어야 할 몇 가지 조건들이 명백히 존재한다. 첫 번째 조건은, 그 규칙들 속에 반드시 어떤 형태로든 폭력, 절도, 기만의 자유로운 사용에 대한 제약(restrictions on the free use of violence, theft, and deception)이 포함되어야 한다는 것이다. 인간은 이러한 행위들에 쉽게 유혹되지만, 서로 가까이 공존하며

살아가기 위해서는 일반적으로 이를 억제해야 한다. 실제로, 우리가 알고 있는 원시 사회들에서는 항상 이러한 규칙들이 존재하며, 동시에 공동체의 삶을 위해 봉사를 수행하거나 기여를 하도록 개인들에게 다양한 적극적 책무들(positive duties)을 부과하는 다양한 다른 규칙들도 존재한다. 둘째, 이러한 사회에서도 (p. 92) 앞서 기술한 바와 같이 규칙을 수용하는 자들과, 사회적 압력에 대한 두려움이 작동할 때만 규칙에 부합하는 자들 사이에 긴장이 존재할 수 있지만, 신체적 힘이 대체로 균등한 사람들로 이루어진, 그렇게 느슨하게 조직된 사회가 지속되려면 후자의 부류가 소수를 넘어서서는 안 됨이 분명하다. 왜냐하면 그렇지 않다면 규칙을 거부하는 자들이 두려워할 사회적 압력이 너무 적기 때문이다. 이 역시 우리가 알고 있는 원시 공동체들에 의해 확인된다. 그 사회들에는 물론 이탈자(dissidents)나 악행자들(malefactors)이 존재하지만, 대다수는 내부 관점에서 본 규칙들에 따라 살아간다.

우리의 현재 목적에 더 중요한 것은 다음과 같은 고려사항이다. 혈연, 공통된 감정과 믿음의 유대로 긴밀히 결속되어 있고, 안정된 환경에 놓여 있는 소규모 공동체만이 이러한 비공식적 규칙들(unofficial rules)의 체제에 의해 성공적으로 살아갈 수 있음은 분명하다. 다른 어떠한 조건하에서는 이러한 단순한 형태의 사회적 통제는 결함을 드러낼 수밖에 없으며, 다양한 방식의 보충을 필요로 하게 된다. 우선, 그 집단이 살아가는 규칙들은 하나의 체제를 이루지 못하고, 단지 개별적인 기준들의 집합에 그칠 뿐이며, 물론 그것들이 특정한 인간 집단이 수용하는 규칙이라는 점을 제외하면, 식별 표지나 공통 표지(identifying or common mark)를 가지지 않는다. 이러한 점에서 그것들은 우리의 예절 규칙들(rules of etiquette)과 유사하다. 따라서 어떤 규칙들이 존재하는지, 또는 특정 규칙의 정확한 적용 범위(scope)가 무엇인지에 관해 의문이 제기될 경우, 이러한 의문을 해소할 절차가 존재하지 않게 된다. 즉, 권위 있는 문헌을 참조하거나 (by reference to), 이 점에 관해 권위 있는 선언을 하는 공무담당자를 참조하여 그러한 의문을 해소할 수 없다. 이는 명백히 그러한 절차와, 권위 있는 문헌 또는 사람들(persons)에 대한 인정(acknowledgement) 자체가, 가정상(ex hypothesi) 집단이 보유한 전부라고 상정된 의무 또는 책무의 규칙들(rules of obligation or duty)과는 다른 유형의 규칙들의 존재를 전제하기 때문이다. 우리는 이러한

일차 규칙들(primary rules)로 이루어진 단순한 사회 구조의 결함을 그 사회의 불확실성(uncertainty)이라 부를 수 있다.

두 번째 결함은 규칙들의 정적(static) 성격이다. 그러한 사회에서 알려진 규칙 변화의 유일한 방식은 느린 성장의 과정일 뿐일 것이다. 이 과정에서는 한 때 선택적인 것으로 여겨졌던 행위노선들(courses of conduct)이 먼저 습관적이거나 통상적인 것이 되었다가, 그다음에는 의무적인 것이 되며, 그 반대의 쇠퇴 과정에서는 한때 엄격하게 다루어지던 일탈들이 먼저 용인되다가 마침내는 눈에 띄지 않게 된다. 그러한 사회에는 변화하는 상황에 맞추어 규칙들을 의도적으로 조정할 수 있는 수단이 없을 것이다. (p. 93) 즉, 기존 규칙들을 제거하거나 새로운 규칙들을 도입하는 방식으로 조정하는 것이 불가능한데, 이는 다시 그러한 조정 가능성 자체가 그 사회가 오직 그것들에 의해 살아가는 의무의 일차 규칙들(primary rules of obligation)과는 다른 유형의 규칙들이 존재함을 전제하기 때문이다. 극단적인 경우에는 규칙들이 더욱 극단적인 의미에서 정적일 수도 있다. 이는 실제의 어떤 공동체에서도 완전히 실현되지는 않았을지 모르지만, 이에 대한 구제책이 법의 매우 특징적인 요소이기 때문에 고려할 가치가 있다. 이러한 극단적 경우에는 일반 규칙들을 의도적으로 변경할 방법이 전혀 없을 뿐만 아니라, 개별 사안에서 규칙들 아래에서 발생하는 의무들도 어떤 개인의 의도적 선택에 의해 변형되거나 수정될 수 없다. 각 개인은 단지 어떤 것들을 행하거나 또는 행하지 말아야 할 고정된 의무들(obligations) 또는 책무들(duties)을 가질 뿐이다. 기실 이러한 의무의 이행으로 타인이 이익을 얻는 경우가 매우 흔할 수 있다. 그러나 오직 의무의 일차 규칙들만이 존재한다면, 그러한 의무에 구속된 사람을 이행으로부터 해방시키거나(release), 이행으로부터 발생하는 이익을 다른 사람에게 이전할 수 있는 권한은 누구에게도 없을 것이다. 왜냐하면 이러한 해방이나 이전의 작용들은 의무의 일차 규칙들 아래에서 개인들이 차지하는 초기적 지위를 변화시키는 것이며, 그러한 작용들이 가능하려면 일차 규칙들과는 다른 종류의 규칙들이 존재해야 하기 때문이다.

이 단순한 사회생활 형식의 세 번째 결함은 규칙들이 유지되는 분산된 사회적 압력(diffuse social pressure)의 비효율성(inefficiency)이다. 어떤 인정된 규칙(admitted rule)이 위반되었는지 여부를 두고 분쟁이 발생하는 것은 불가피하며,

위반 사실을 최종적으로, 그리고 권위 있게 확인할 특별한 권한을 부여받은 기관이 존재하지 않는 한, 이러한 분쟁은 가장 작은 사회들을 제외하고는 끝없이 계속될 것이다. 이러한 최종적이고 권위 있는 판정들(*final and authoritative determinations*)의 부재는 그것과 결부된 또 다른 약점과 구분되어야 한다. 그것은 규칙 위반에 대한 처벌과, 신체적 노력이나 힘의 사용을 수반하는 다른 형태의 사회적 압력이 특별한 기관에 의해 집행되는 것이 아니라, 그 영향을 받는 개인들이나 공동체 전체에 맡겨진다는 점이다. 자명한 사실이지만, 위반자를 찾아내고 처벌하기 위해 조직되지 않은 집단이 들이는 시간의 낭비와, 제재의 공적 독점(*monopoly of sanctions*)이 부재할 때 자력구제(*self-help*)로부터 생겨날 수 있는 꺼지지 않는 복수전(*vendettas*)은 심각할 수 있다. 그러나 법의 역사가 강하게 시사하는 바는, 규칙 위반 사실을 권위 있게 판정하는 공적 기관들(*official agencies*)의 부재가 (p. 94) 훨씬 더 심각한 결함이라는 점이다. 실제로 많은 사회들이 이러한 결함에 대해서는 그와 결부된 다른 약점보다 훨씬 먼저 구제책을 갖추었기 때문이다.

이 가장 단순한 형태의 사회 구조에서 나타나는 이 세 가지 주요 결함 각각에 대한 구제책은, 의무의 일차 규칙들(*primary rules of obligation*)을 성격이 다른 이차 규칙들(*secondary rules*)로 보충하는 데에 있다. 각 결함에 대한 구제책의 도입은 그 자체로 전(前)법적 상태(*pre-legal*)에서 법적 세계(*legal world*)로 나아가는 하나의 단계로 간주될 수 있는데, 이는 각 구제책이 법에 스며 있는 많은 요소들을 수반하기 때문이다. 확실히 이 세 가지 구제책이 함께 도입되면, 일차 규칙들의 체제를 의문의 여지 없이 하나의 법체계(*legal system*)로 전환시키기에 충분하다. 우리는 이어서 이들 각각의 구제책을 차례로 검토하고, 왜 법이 그러한 이차 규칙들과 결합된 의무의 일차 규칙들의 결합(*union*)으로 가장 해명력 있게 특징지어질 수 있는지를 보일 것이다. 그러나 이를 수행하기에 앞서, 다음의 일반적 사항들에 주목할 필요가 있다. 구제책들은 서로서로뿐만 아니라, 그것들이 보충하는 의무의 일차 규칙들과도 분명히 서로 다른 규칙들의 도입으로 구성되어 있지만, 그럼에도 불구하고 중요한 공통된 특징들을 가지며 다양한 방식으로 상호 연결되어 있다. 따라서 이들 모두는 일차 규칙들과는 다른 수준(*level*)에 속한다고 말할 수 있는데, 이는 이들 규칙이 모두 그러한

일차 규칙들에 관한(about) 규칙들이기 때문이다. 즉, 일차 규칙들이 개인들이 행해야 하거나 행해서는 안 되는 행위들에 관한 것인 반면, 이 이차 규칙들은 모두 일차 규칙들 자체에 관한 것이다. 이들은 일차 규칙들이 어떻게 확정적으로 확인될 수 있는지, 어떻게 도입·폐지·변경될 수 있는지, 그리고 그 위반의 사실이 어떻게 확정적으로 판정될 수 있는지를 명시한다.

일차 규칙들의 체제가 지니는 불확실성(uncertainty)에 대한 가장 단순한 구제책은, 우리가 ‘승인 규칙(rule of recognition)’이라 부를 규칙을 도입하는 것이다. 이 규칙은 어떤 특징 또는 특징들을 명시한다. 어떤 후보 규칙(suggested rule)이 그 특징을 갖추고 있다는 점은, 그 규칙이 해당 집단의 규칙이며 그 집단이 행사하는 사회적 압력에 의해 뒷받침될 규칙임을 보여 주는 확정적 인정표지(conclusive affirmative indication)로 받아들여진다. 이러한 승인 규칙의 존재는 아주 다양한 형태들(forms)을 취할 수 있으며, 단순하거나 복잡할 수 있다. 예컨대, 많은 사회들의 초기 법에서 승인 규칙은 단지 규칙들의 권위 있는 목록이나 문헌이 문서에 적혀 있거나 공공 기념비에 새겨져 있다는 것에 불과할 수 있다. 물론 역사적으로 보면, 법 이전 상태에서 법적 상태로 나아가는 이러한 단계는 여러 구별 가능한 단계들로 이루어질 수 있으며, (p. 95) 그 첫 번째 단계는 기존의 비문서화된 규칙들을 기록(writing)으로 전환하는 것일 수 있다. 이는 매우 중요한(important) 단계이긴 하나, 핵심적인(crucial) 단계는 아니다. 핵심적인 것은, 그 기록물이나 새겨진 문구에 대한 참조(reference)를 권위 있는(authoritative) 것으로, 즉 규칙의 존재에 대한 의문을 해소하는 적절한(proper) 방식으로 인정하는 것(acknowledgement)이다. 이러한 인정(acknowledgement)이 있는 곳에는 가장 단순한 형태의 이차 규칙, 즉 의무의 일차 규칙들을 확정적으로 식별하기 위한 규칙이 존재한다고 할 수 있다.

발달된 법체제에서는 승인 규칙들(rules of recognition)이 물론 더 복잡한데, 규칙들을 오로지 어떤 문헌(text)이나 목록(list)에 대한 참조(reference)에 의해 서만 식별하는(identify) 대신, 일차 규칙들이 지니는 어떤 일반적 특성에 대한 참조(reference)에 의해 이를 식별한다. 그 특성은 특정한 기구(body)에 의해 제정되었다는 사실일 수도 있고, 장기간의 관습적 관행이라는 점일 수도 있으며, 사법적 결정과의 관련성일 수도 있다. 더 나아가 이러한 일반적 특성들 가운데

둘 이상이 식별 기준으로 취급되는 경우에는, 그들 사이에 발생할 수 있는 충돌을 대비하여 우위의 순서(order of superiority)를 설정하는 규정이 마련될 수 있는데, 예컨대 관습이나 판례가 제정법(statute)에 통상 종속(subordination)되는 경우가 그러하며, 이때 제정법은 법의 '우위의 원천' ('superior source' of law)이 된다. 이러한 복잡성은 현대 법체계에서의 승인 규칙들을 권위 있는 하나의 문헌을 단순히 수용하는 것과 매우 다른 것으로 보이게 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 가장 단순한 형태에서도, 이러한 규칙은 법에 고유한 많은 요소들을 수반한다. 권위 있는 표지(authoritative mark)를 제공함으로써, 그것은 비록 배아적 형태이기는 하나 법체계라는 관념(idea)을 도입한다. 이제 규칙들은 더 이상 서로 무관한 개별적 집합이 아니라, 단순한 방식으로나마 통일된 것이다. 더 나아가, 어떤 주어진 규칙이 권위 있는 규칙 목록에 포함된 항목이라는 요구된 특성을 지니고 있는지를 식별하는 이 단순한 작동 속에서, 우리는 법적 유효성(legal validity)이라는 관념(idea)의 싹(germ)을 발견하게 된다.

일차 규칙들의 체제가 지니는 정적(static) 성격에 대한 구체책은, 우리가 '변경 규칙들(rules of change)' 이라고 부를 규칙들의 도입으로 이루어진다. 이러한 규칙의 가장 단순한 형태는, 개인이나 사람들의 집단에게 집단의 삶, 또는 그 내부의 어떤 부류의 삶의 영위를 규율하기 위한 새로운 일차 규칙들을 도입하고 기존의 규칙들을 제거할 수 있는 권한을 부여하는 것이다. 이미 제4장에서 논증했듯이, 입법적 제정(legislative enactment)과 폐지(repeal)의 관념들(ideas)은 위협으로 뒷받침된 명령들의 관점이 아니라, 바로 이러한 규칙의 관점에서 이해되어야 한다. 이러한 (p. 96) 변경 규칙들은 매우 단순할 수도 있고 매우 복잡할 수도 있으며, 부여되는 권한들은 무제한적일 수도 있고 다양한 방식으로 제한될 수도 있다. 또한 이러한 규칙들은 입법을 담당할 사람들을 지정하는 것 외에도, 입법에서 따라야 할 절차를 다소 엄격한 문언으로 규정할 수도 있다. 분명히 변경 규칙들과 승인 규칙들(rules of recognition) 사이에는 매우 밀접한 관련이 존재하는데, 이는 전자가 존재하는 경우 후자는 규칙들을 식별하는 (identify) 특징으로서 입법에 대한 참조(reference)를, 그것이 입법에 수반되는 모든 절차적 세부사항을 참조할(refer) 필요는 없지만, 반드시 포함하게 되기 때문이다. 통상적으로 승인 규칙에 따라 어떤 공식 증명서나 공식 등본(official

certificate or official copy)이 적법한 제정이 이루어졌음을 보여 주는 충분한 증거로 받아들여진다. 물론 사회 구조가 극히 단순하여 법의 ‘원천(source)’이 오직 입법뿐인 경우에는, 승인 규칙은 제정이라는 사실만을 규칙들의 유효성에 대한 유일한 식별 표지 또는 기준으로 명시하게 될 것이다. 이는 예컨대 제4장에서 묘사된 가상적 왕국 Rex 1세의 경우에 해당하는데, 그곳에서 승인 규칙은 단순히 Rex 1세가 제정한 것은 무엇이든 법이라는 것이 될 것이다.

우리는 이미 일차 규칙들 아래에서 개인들이 차지하는 초기적 지위를 변경할 수 있는 권한을 개인들에게 부여하는 규칙들을 어느 정도 상세하게 서술하였다. 이러한 사적 권한부여 규칙들(private power-conferring rules)이 없다면, 사회는 법이 부여하는 주요한 편익들 가운데 일부를 결여하게 될 것이다. 왜냐하면 이러한 규칙들이 가능하게 하는 작용들은 유언의 작성, 계약의 체결, 재산의 이전, 그리고 법 아래에서의 삶을 특징짓는, 자발적으로 창출된 권리들과 책무들의 많은 구조들이기 때문이다. 물론 약속(promise)이라는 도덕적 제도 또한 그 기초에는 권한부여 규칙의 기초적 형태가 놓여 있다. 이러한 규칙들이 입법이라는 관념(notion)에 포함된 변경 규칙들(rules of change)과 친연성을 가진다는 점은 분명하며, 켈젠(Kelsen)의 이론과 같은 최근의 이론이 보여주듯이, 계약이나 재산 제도에서 우리를 혼란스럽게 만드는 많은 특징들은 계약 체결이나 재산 이전의 작용들을 개인들이 행사하는 제한된 입법적 권한들(limited legislative powers)의 행사로 사고함으로써 명확해진다.

일차 규칙들의 단순한 체제가 지니는 비효율성(inefficiency), 즉 분산된 사회적 압력의 비효율성을 보완하기 위한 세 번째 보충은, 특정한 경우에 일차 규칙이 위반되었는지의 문제를 권위 있게 판정할 수 있는 권한을 개인들에게 부여하는 이차 규칙들로 구성된다. (p. 97) 재판(adjudication)의 최소 형태는 바로 이러한 판정들(determinations)로 이루어지며, 우리는 이러한 판정들을 내릴 권한을 부여하는 이차 규칙들을 ‘재판 규칙들(rules of adjudication)’이라고 부를 것이다. 이러한 규칙들은 재판을 담당할 개인들을 식별하는(identify) 것뿐만 아니라, 따라야 할 절차 또한 규정한다. 다른 이차 규칙들과 마찬가지로, 이들 규칙 역시 일차 규칙들과는 다른 수준에 속한다. 비록 판사들에게 재판을 수행할 책무들(duties)을 부과하는 추가 규칙들에 의해 강화될 수는 있지만, 이들

규칙 자체는 책무들을 부과하는 것이 아니라, 의무들(obligations)의 위반에 관한 사법적 선언에 대해 사법적 권한들(judicial powers)과 특수한 지위를 부여한다. 다시 말해, 이 규칙들 또한 다른 이차 규칙들과 마찬가지로 중요한 법 개념들의 한 집단을 정의하는데, 이 경우에는 판사 또는 법원, 관할권(jurisdiction), 판결(judgment)이라는 개념들이 그것이다. 이러한 다른 이차 규칙들과의 유사성 외에도, 재판 규칙들은 그것들과 긴밀한 연관을 가진다. 기실, 재판 규칙들을 갖춘 체계는 필연적으로 초보적이고 불완전한 종류의 승인 규칙(rule of recognition)도 수반한다. 이는 법원이 어떤 규칙이 위반되었다는 사실에 대해 권위 있는 판정을 내릴 권한을 부여받는다면, 그러한 판정들은 곧 규칙이 무엇인지를 권위 있게 판정한 것으로 받아들여질 수밖에 없기 때문이다. 따라서 관할권을 부여하는 규칙은 동시에 승인 규칙이 되며, 법원의 판결들을 통해 일차 규칙들을 식별하고, 이러한 판결들은 법의 ‘원천(source)’이 된다. 물론, 관할권의 최소 형태와 불가분적으로 결합된 이러한 승인 규칙의 형태는 매우 불완전할 것이다. 권위 있는 문헌이나 제정법전(statute book)과 달리, 판결들은 일반적 문언으로 표현되지 않을 수 있으며, 규칙에 대한 권위 있는 향도지침으로서 판결들을 사용하는 것은 개별 결정들로부터의 다소 불안정한 추론에 의존한다. 그리고 이러한 추론의 신뢰성은 해석자의 능숙함과 판사들의 일관성에 따라 변동할 수밖에 없다.

거의 말할 필요도 없겠지만, 사법적 권한들(judicial powers)이 일차 규칙의 위반 사실에 대한 권위 있는 판정들(authoritative determinations)로만 한정되어 있는 법체계는 거의 없다. 대부분의 체계는 일정한 시간이 지난 뒤 사회적 압력을 더욱 중앙집중화하는 것의 이점을 인식하게 되었고, 그 결과 사적 개인에 의한 신체적 처벌들이나 폭력적 자력구제(self-help)의 사용을 부분적으로 금지해 왔다. 그 대신 이들은 의무의 일차 규칙들을 추가적인 이차 규칙들로 보충하여, 위반에 대한 제재적-불이익들(penalties)을 구체적으로 정하거나 최소한 그 한계를 설정하고, (p. 98) 판사들에게는 위반 사실을 확인한 경우에 다른 공무담당자들에 의해 제재적-불이익들(penalties)이 적용되도록 지시할 수 있는 배타적 권한을 부여하였다. 이러한 이차 규칙들은 체계의 중앙집중화된 공적 ‘제재(sanctions)’를 제공한다.

한걸음 물러나 의무의 일차 규칙들과 승인 규칙들(rules of recognition), 변경 규칙들(rules of change), 재판 규칙들(rules of adjudication)이라는 이차 규칙들이 결합함으로써 형성된 구조를 고찰해 보면, 여기에는 단지 법체계의 핵심이 있을 뿐만 아니라, 법리학자와 정치 이론가 모두를 오랫동안 혼란스럽게 해 온 많은 문제들을 분석하기 위한 매우 강력한 도구가 존재함이 분명하다.

법률가가 직업적으로 다루는 의무(obligation)와 권리들(rights), 유효성(validity)과 법의 원천(source of law), 입법(legislation)과 관할권(jurisdiction), 그리고 제재(sanction)와 같은 특유한 법 개념들은 이러한 요소들의 결합이라는 관점에서 가장 잘 해명된다. 그뿐만 아니라 국가(state), 권위(authority), 공무담당자(official)라는 개념들—법과 정치이론을 가로지르는 이 개념들—역시 그 주변에 여전히 남아 있는 모호함을 해소하기 위해서는 이와 유사한 분석을 요구한다. 일차 규칙들과 이차 규칙들의 이러한 결합의 관점에서 이루어지는 분석이 이와 같은 설명력을 갖는 이유는 어렵지 않게 찾을 수 있다. 법적·정치적 개념들을 둘러싼 대부분의 모호함과 왜곡은, 그것들이 본질적으로 우리가 내부 관점(internal point of view)이라고 부른 것에 대한 참조(reference)를 포함하고 있다는 사실에서 비롯된다. 즉, 규칙에 부합하는 행태를 단지 기록하고 예측하는 데 그치지 않고, 규칙을 자기 자신과 타인의 행위를 평가하는 기준으로 사용하는(use) 사람들의 관점이다. 이는 법적·정치적 개념의 분석에서 통상적으로 받아온 것보다 훨씬 더 세심한 주의를 요구한다. 일차 규칙들의 단순한 체제 아래에서 내부 관점은 가장 단순한 형태로 나타나는데, 그것은 규칙들을 비판의 근거로 사용하고, 규칙에 부합하라는 요구, 사회적 압력, 처벌을 정당화하는 데 사용하는 방식에서 드러난다. 이러한 내부 관점의 가장 기초적인 발현에 대한 참조는 의무(obligation)와 책무(duty)라는 기본 개념들을 분석하는 데 필수적이다. 여기에 이차 규칙들이 체제에 추가되면, 내부 관점에서 말해지고 행해지는 것들의 범위는 크게 확장되고 다양화된다. 이러한 확장과 함께 일련의 새로운 개념들이 등장하며, 이들 또한 분석을 위해 내부 관점에 대한 참조를 요구한다. 여기에는 입법(legislation), 관할권(jurisdiction), 유효성(validity), 그리고 일반적으로 (p. 99) 사적·공적 법적 권한들(legal powers)이라는 관념들(notions)이 포함된다. 이들 개념을 일상적이거나 ‘과학적’인 사실 진술적 또는 예측적

담론의 용어로 분석하려는 지속적인 유혹이 존재한다. 그러나 그러한 분석은 오직 그 외부 측면만을 재현할 뿐이다. 이들의 고유한 내부 측면을 정당하게 다루려면(do justice), 입법자의 법창출 작용, 법원의 재판(adjudication), 사적 또는 공무담당 권한들의 행사, 그리고 다른 ‘법 속의 행위들(acts-in-the-law)’이 이차 규칙들과 어떤 상이한 방식으로 연관되는지를 살펴볼 필요가 있다.

다음 장에서는 법의 유효성(validity of law)과 법의 원천들(sources of law)이라는 관념들, 그리고 주권 교설(doctrines of sovereignty)의 오류들 속에 잠재해 있는 진리들이 어떻게 승인 규칙들(rules of recognition)의 관점에서 재진술되고 명확화될 수 있는지를 보일 것이다. 그러나 이 장을 마무리하면서 하나의 경고를 덧붙이고자 한다. 일차 규칙들과 이차 규칙들의 결합은 법의 많은 측면을 설명해 준다는 점에서 중심적인 위치를 부여받을 만하지만, 그것만으로 모든 문제를 해명할 수는 없다. 일차 규칙들과 이차 규칙들의 결합은 법체계의 중심에 놓여 있지만, 그것이 전부는 아니다. 그리고 우리가 그 중심으로부터 멀어질수록, 이후의 장들에서 지목될 방식에 따라, 성격이 다른 요소들을 수용해야 할 필요가 있을 것이다.

제5장 주석

83쪽. 위협된 해악의 개연성으로서의 의무(obligation). 의무에 대한 ‘예측적(predictive)’ 분석들에 대해서는 다음을 보라: 오스틴(Austin), 법리학의 범위는 어떻게 결정되는가 (The Province) 제1강, 15–24쪽, 및 *The Lectures* 제22강; 벤담(Bentham), *A Fragment on Government* 제5장, 특히 제6절 및 그에 대한 주석; 홈스(Holmes), *The Path of the Law*. 오스틴의 분석에 대한 비판으로는 Hart, 「Legal and Moral Obligation」 (*Essays in Moral Philosophy*, 편집: Melden) 참조. 일반적인 의무 관념에 대해서는 Nowell-Smith, *Ethics* (1954), 제14장 참조.

87쪽. 의무와 유대(bond)의 형상('vinculum juris'). A. H. Campbell, *The Structure of Stairs Institute* (Glasgow, 1954), 31쪽 참조. ‘책무(duty)’는 프랑스어 *devoir*를 통해 라틴어 *debitum*에서 유래하였다. 따라서 책무라는 말에는 채무(debt)의 잠재적 관념이 들어 있다.

88쪽. 의무와 강제감(feelings of compulsion). 로스(Ross)는 유효성(validity) 개념을 두 요소—즉 규칙의 실효성(effectiveness)과 “그 규칙이 동기를 부여한다고 느껴지는 방식, 곧 사회적으로 구속적 socially binding)이라고 느껴지는 방식”—으로 분석한다. 이는 의무 개념을 경험된 행동 패턴들에 수반되는 정신적 경험의 관점에서 분석하는 것이다. 이에 대해서는 Ross, *On Law and Justice*, 제1, 2장을 비롯하여 *Kritik der sogenannten praktischen Erkenntnis* (1933), 280쪽 참조. 책무 관념이 감정과 맺는 관계에 대한 상세한 논의는 Hägerström, *Inquiries into the Nature of Law and Morals*, 127–200쪽 참조. 이에 대한 논평으로는 Broad, 「Hägerström's Account of Sense of Duty and Certain Allied Experiences」, *Philosophy* 제26권 (1951); Hart, 「Scandinavian Realism」, *Cambridge Law Journal* (1959), 236–240쪽 참조.

86쪽. 규칙의 내부 측면(internal aspect of rules). 관찰자의 외부 예측적 관점(external predictive point of view)과 규칙들을 행위의 향도지침들로 수용하고 사용하는 사람들의 내부 관점(internal point of view) 사이의 대비는, 비록 이러한 용어들로 표현되지는 않았지만, Dickinson, 「Legal Rules. Their Function in the Process of Decision」, 79 *University of Pennsylvania Law Review*, p. 833 (1931)에서 제시된다. 또한 L. J. Cohen, *The Principles of World Citizenship* (1954), 3장을 참조하라. 외부 관점, 즉 관찰 대상 사회의 규칙들을 수용하지 않는 관찰자의 관점에서는 여러 가지 상이한 유형의 진술이 가능하다는 점에 유의해야 한다. 즉 (i) 그는 그 규칙들을 준수하는 사람들의 행태에

서 나타나는 행동의 반복적 일양성들(regularities)을, 그것들이 사회 구성원들에 의해 올바른 행위의 기준으로 간주된다는 사실을 참조하지 않은 채, 마치 단순한 습관들인 것처럼 단순히 기록할 수 있다; (ii) 그는 이에 더하여, 통상적 행동 양식으로부터의 이탈에 대해 나타나는 반복적으로 일양적인(regular) 적대적 반응을 또한 하나의 습관적 사실로서 기록할 수 있는데, 이 경우에도 그러한 이탈들이 사회 구성원들에 의해 그러한 반응의 이유와 정당화로 간주된다는 사실을 참조하지 않는다; (iii) 그는 이러한 관찰 가능한 행동과 반응의 반복적 일양성들(regularities)뿐만 아니라, 사회 구성원들이 특정한 규칙들을 행위의 기준으로 수용하고 있으며, 관찰 가능한 행동과 반응이 그들(they)에 의해 그 규칙들이 요구하거나 정당화하는 것으로 간주된다는 사실(the fact that)까지도 기록할 수 있다. 사회 구성원들이 어떤 규칙을 수용하고 있다는 점을 단언하는 외부 사실 진술(external statement of fact)과, 그 규칙을 스스로 수용하는 사람이 행하는 규칙의 내부 진술(internal statement)을 구별하는 것은 중요하다. Wedberg, 「Some Problems on the Logical Analysis of Legal Science」, 17 Theoria (1951)을 보라; 또한 Hart, 「Theory and Definition in Jurisprudence」, 29 PAS 보충권(Suppl. vol.) (1955), pp. 247-50을 참조하라. 아울러 제6장 1절, pp. 102-5 및 109-10도 참조하라.

91쪽. 원시 공동체에서의 관습 규칙들(Customary rules). 입법 기관과 재판 기관, 그리고 중앙집중적으로 조직된 제재들(sanctions)의 체계가 전혀 존재하지 않았던 사회는 극히 드물다. 이와 같은 상태에 가장 근접한 사례에 대한 연구로는 다음을 참조하라: Malinowski, *Crime and Custom in Savage Society*; A. S. Diamond, *Primitive Law* (1935), 제18장; Llewellyn and Hoebel, *The Cheyenne Way* (1941).

94쪽. 조직화된 제재들 없이 이루어지는 재판(Adjudication without organized sanctions). 결정을 강제할 수 있는 중앙집중적으로 조직된 제재들의 체계는 없지만, 분쟁 해결을 위한 기초적인 형태의 재판 절차는 존재하는 원시 사회에 대해서는 다음을 참조하라: Evans-Pritchard, *The Nuer* (1940), 117쪽 이하에서 다루는 ‘질서 있는 무정부 상태(ordered anarchy)’, 이는 Gluckman, *The Judicial Process among the Barotse* (1955), 262쪽에 인용됨. 로마법에서는 민사 판결을 강제할 수 있는 국가 장치가 마련되기 훨씬 이전부터 정교한 소송 체계가 존재했다. 후기 제정 로마 이전까지는, 승소한 원고도 피고가 지급하지 않으면 스스로 피고 또는 그의 재산을 압류하도록 남겨졌다. 이에 대해서는 Schulz, *Classical Roman Law*, 26쪽 참조.

94쪽. 전법적 상태에서 법적 세계로의 이행(The step from the pre-legal into the legal world). 이 주제에 대해서는 Baier, 「Law and Custom」, *The Moral Point of View*, 127-133

쪽 참조.

94쪽. 승인 규칙(rule of recognition). 법체계 내에서 이 요소가 갖는 역할과 Kelsen의 기초규범(*Grundnorm*)과의 관계에 대해서는 제6장 제1절 및 제10장 제5절과 그에 대한 주석 참조.

95쪽. 규칙들의 권위 있는 문헌들(authoritative texts of rules). 전해지는 바에 따르면, 로마에서는 평민(Plebeians)이 법의 권위 있는 문헌(authoritative text of the law) 공표를 요구한 결과, '12표법' 이 시장 광장에 청동판으로 게시되었다고 한다. 이용 가능한 빈약한 증거로 보건대, 이 12표법은 전통적 관습 규칙들에서 크게 벗어나지는 않았던 것으로 보인다.

96쪽. 계약, 유언 등을 입법적 권한들의 행사로 이해하기(Contracts, wills, &c., as the exercise of legislative powers). 이러한 비교에 대해서는 Kelsen, *General Theory*, 136쪽에서 '법창출 행위(law creating act)'로서의 법률행위(legal transaction)를 다룬 논의 참조.

제5장 제3판 주석

80-81쪽. 일차 규칙들(primary rules)과 이차 규칙들(secondary rules). Hart는 이 구별을 일관되지 않게 사용하여 다음과 같은 다양한 차이를 표시한다: (a) 규범적 유형(81쪽: 일차 규칙들은 책무부과적이고, 이차 규칙들은 권한부여적임), (b) 대상(94, 97쪽: 일차 규칙들은 행위를 규율하고, 이차 규칙들은 규칙들을 규율함), (c) 사회적 기능(40-41쪽: 일차 규칙들은 행동을 지시하고, 이차 규칙들은 편의수단들을 제공함), (d) 중요성(91, 235쪽: 일차 규칙들은 인간 사회에 필수적이며, 이차 규칙들은 가치 있지만 선택적임), (e) 발생(91, 95쪽: 일차 규칙들이 먼저 등장하고, 이차 규칙들은 그 이후에 생김). 이러한 변이들 중 일부는 다음의 저자들에 의해 지적된 바 있다: Colin Tapper, 「Powers and Secondary Rules of Change」, A. W. B. Simpson (편), *Oxford Essays in Jurisprudence*, 248-68쪽; Neil MacCormick, *H. L. A. Hart*, 103-6쪽; Joseph Raz, *The Authority of Law* (Oxford University Press, 1979), 177-9쪽; P. M. S. Hacker, 「Hart's Philosophy of Law」, P. M. S. Hacker 및 Joseph Raz (편), *Law, Morality, and Society*, 19-21쪽.

82-87쪽. 의무들(obligations)의 성격. Hart가 원용하는 용례상의 지점(82쪽)에는 의문의 여지가 있다. 이에 대해선 Edgar Page, 「On Being Obligated」 (1973), *Mind* 제82권,

283쪽 참조. 또한 86-87쪽의 분석은 규칙들이 ‘의무들을 발생시키는 것으로 사고되는(thought of as)’ 상황에 대한 설명임을 유의해야 한다(87쪽, 강조 추가). 즉, 이는 정당화적 설명(justificatory account)이 아니다. 또한 Hart에게 있어 의무부와 규칙들과 그 밖의 규칙들 사이의 구별은 정도의 문제이다. 즉, 이는 부합을 향한 압력이 얼마나 심각한지, 그리고 그 규칙들이 얼마나 중요한 것으로 여겨지는지에 달려 있다.

Hart는 이 문제를 *Essays on Bentham* 제6장 「Legal Duty and Obligation」에서 다시 다룬다. 여기서 그는 Bentham의 입장을 검토하고 Dworkin과 Raz의 비판에 응답한다. 이 글에서 그는 법적 책무 진술은 “그 책무를 가진 수범자들에게서 응당 나와야 하거나 그 수범자들이 해야 할 것으로 부담하는 행위들을 참조하며, 이는 그 행위들이 그들에게 정당하게 요구되거나 그들에게서 받아내질 수 있다는 의미에서 그러하다”고 시사한다(160쪽). 이러한 점이 그가 앞서 제시한 설명과 어떻게 연결되는지는 불분명하다.

88-91쪽. 예측 이론들(Predictive theories)과 ‘외부 관점(external point of view)’ . 법적 의무들에 대한 진술들은 일반적으로 이론적(예컨대 행위 예측적)이 아니라 실천적(곧 행위 지침적)을 목적으로 한다. Hart는 이러한 점을 포착하기 위해 법을 의무부와 규칙들을 수용하는(accepts) 자의 ‘내부 관점’에서 이해해야 한다고 본다(위의 56-58쪽 주석 참조). 이에 대해 Kelsen은 의무와 행위 사이의 관계를 귀속(imputation)이라는 sui generis 원칙을 통해 이해할 것을 제안한다. (*Pure Theory of Law*, Max Knight 번역, University of California Press, 1967, 75-81쪽). Raz는 이를 ‘분리된(detached) 법적 관점’에서 이해해야 한다고 제안한다 (*Practical Reason and Norms*, 170-177쪽). 이와 관련된 유익한 논의는 Kevin Toh, 「Raz on Detachment, Acceptance and Describability」(2007), *Oxford Journal of Legal Studies* 제27권, 403쪽 참조.

91-98쪽. 법의 발생(emergence of law). 전법적(pre-legal) 사회에서 법적 사회로 이행한다는 Hart의 주장에 관한 방법론적 전제들에 대해서는 Neil MacCormick, *H. L. A. Hart*, 제9장 특히 106-108쪽을 참조하라. 이에 대비되는 입장은 John Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, 제1장 특히 6-18쪽 참조. ‘단순한 사회 질서들(simple social orders)’에서의 ‘결함들(defects)’이라는 관념에 대해서는 이 책의 서론에서 Leslie Green이 논의한 내용을 참고하라(xlix-1쪽).

VI. 법체계의 토대들(THE FOUNDATIONS OF A LEGAL SYSTEM)

1. 승인 규칙과 법적 유효성(RULE OF RECOGNITION AND LEGAL VALIDITY)

제4장에서 비판된 이론에 따르면, 한 법체계의 토대들은 사회 집단의 다수가, 스스로는 누구에게도 습관적으로 복종하지 않는 주권자인 인격 또는 인격들의 위협으로 뒷받침된 명령들에 습관적으로 복종하는 상황으로 이루어진다. 이 이론에서 이러한 사회적 상황은 법의 존재에 대한 필요조건이자 충분조건이다. 우리는 이미 이 이론이 현대의 국내법 체계의 몇몇 두드러진 특징들을 설명할 수 없는 무능력(incapacity)을 상당히 상세하게 보여 주었다. 그럼에도 불구하고, 많은 사상가들의 정신을 사로잡아 온 이 이론이 시사하듯이, 그것은 비록 흐릿하고 오도적인 형태이기는 하나, 법의 몇몇 중요한 측면들에 관한 일정한 진리들을 포함하고 있기는 하다. 그러나 이러한 진리들은, 의무의 일차 규칙들을 식별하기(identify) 위해 이차적 승인 규칙(rule of recognition)이 수용되고 사용되는 보다 복잡한 사회적 상황의 관점에서만 비로소 명확하게 제시될 수 있고, 그 중요성 또한 올바르게 평가될 수 있다. 바로 이 상황이야말로, 무엇인가가 한 법체계의 토대들이라고 불릴 만하다면, 그렇게 불릴 자격이 있는 것이다. 이 장에서는 주권 이론 및 다른 곳들에서 부분적으로만 또는 오도된 방식으로 표현되어 온 이 상황의 여러 요소들을 논의할 것이다.

이러한 승인 규칙이 수용되는 곳에서는 어디에서나, 사적 개인들과 공무원 담당자들 모두에게 의무의 일차 규칙들을 식별하기(identify) 위한 권위 있는 기준들이 제공된다. 앞서 보았듯이, 이렇게 제공되는 기준들은 다음의 다양한 형태들 가운데 하나 또는 그 이상의 형태를 취할 수 있다: 여기에는 권위 있는 문헌에 대한, 입법적 제정에 대한, 관습적 실천에 대한, 특정된 사람들의 일반적 선언에 대한, 또는 개별 사건들에서의 과거 사법적 결정들에 대한 참조(reference)가 포함된다. 제4장에서 묘사된 Rex I의 세계와 같이 매우 단순한

체계에서는, 그가 제정한 것만이 법이며 관습 규칙이나 헌법적 (p. 101) 문헌에 의해 그의 입법 권한에 법적 제한들이 전혀 부과되지 않기 때문에, 법을 식별하는 유일한 기준은 Rex I에 의한 제정이라는 사실에 대한 단순한 참조가 될 것이다. 이러한 단순한 형태의 승인 규칙의 존재는, 공무담당자들이나 사적 개인들이 이 기준에 따라 규칙들을 식별하는 일반적 실천 속에서 분명히 드러난다. 법의 다양한 ‘원천들(sources)’ 이 존재하는 현대의 법체계에서는 승인 규칙도 이에 상응하여 더 복잡해지며, 법을 식별하기 위한 기준들은 복수적이고, 통상적으로 서면 헌법, 입법부에 의한 제정, 그리고 사법적 선례를 포함한다. 대부분의 경우 이러한 기준들 사이에 발생할 수 있는 충돌을 대비하여, 그것들을 상대적 종속성과 우위성(primacy)의 질서 속에 배열하는 규정이 마련되어 있다. 바로 이러한 방식으로, 우리 체계에서는 ‘보통법(common law)’ 이 ‘제정법(statute)’ 에 종속된다.

한 기준이 다른 기준에 대해 갖는 이러한 상대적 종속성(subordination)은 도출(derivation)과 구별하는 것이 중요한데, 왜냐하면 이 두 관념을 혼동함으로써, 모든 법은 본질적으로 또는 ‘실제로(really)’ (설령 단지 ‘묵시적으로(tacitly)’ 일 뿐이라 하더라도) 입법의 산물이라는 견해에 대해 그럴듯하지만 허위적인 지지가 제공되어 왔기 때문이다. 우리 체계에서 관습과 판례는 입법에 종속되는데, 이는 관습법 및 보통법 규칙들이 제정법(statute)에 의해 그 법적 지위를 박탈당할 수 있기 때문이다. 그러나 이 규칙들은, 그 지위가 불안정하다는 점은 인정하더라도, 법으로서의 지위를 ‘묵시적인’ 입법 권한의 행사에 빚지고 있는 것이 아니라, 그것들에게 이러한 독립적이되 종속된(subordinate) 지위를 부여하는 승인 규칙의 수용에 빚지고 있다. 또, 단순한 경우에서와 마찬가지로, 이러한 상이한 기준들이 위계적으로 배열된 복합적인 승인 규칙의 존재는, 그러한 기준들에 의해 규칙들을 식별하는 일반적 실천 속에서 드러난다.

법체계의 일상적 운영 속에서 승인 규칙(rule of recognition)은 규칙으로서 명시적으로 정식화되는(expressly formulated) 경우가 극히 드물다. 다만 영국의 법원들이 때때로 법의 한 기준이 다른 기준에 대해 차지하는 상대적 지위를 일반적인 표현으로 공표하는(announce) 경우는 있는데, 예컨대 의회 제정법들(Acts of Parliament)이 법의 다른 원천들(sources)이나 법의 후보 원천들(suggested

sources of law)에 대해 최고성(supremacy)을 가진다고 단언하는(assert) 때가 그러하다. 대체로 승인 규칙은 진술되지 않지만, 법원이나 다른 공무담당자들, 또는 사적 개인들이나 그들의 조언자들이 개별 규칙들을 식별하는(identify) 방식 속에서 그 존재가 드러난다(shown). 물론 승인 규칙이 제공하는 기준들을 법원이 사용하는 방식과, 다른 이들이 사용하는 방식 사이에는 차이가 있다. 왜냐하면 법원이 특정한 규칙이 법으로서 올바르게 식별되었다는 전제하에 어떤 특정한 (p. 102) 결론에 도달할 경우, 그들이 하는 말은 다른 규칙들에 의해 부여된 특별한 권위 있는 지위를 가지기 때문이다. 이러한 점에서, 그리고 다른 많은 점에서, 법체계의 승인 규칙은 게임의 득점 규칙(scoring rule)과 유사하다. 게임의 진행 과정에서 득점을 구성하는 행위들(득점(runs), 골 등)을 규정하는 일반 규칙은 거의 정식화되지 않으며, 대신 경기 임원들과 선수들이 승리에 산입되는 특정 국면들을 식별하는 데 그것을 사용(use)한다. 여기에서도 경기 임원들(심판이나 득점기록원)의 선언은 다른 규칙들에 의해 부여된 특별한 권위 있는 지위를 가진다. 더 나아가, 두 경우 모두에서 이러한 규칙의 권위 있는 적용들과, 그 규칙의 문언에 비추어 볼 때 명백히 요구되는 바에 대한 일반적 이해 사이에 충돌이 발생할 가능성이 존재한다. 이는 우리가 뒤에서 보게 되겠지만, 이러한 유형의 규칙 체계가 존재한다는 것이 무엇을 의미하는지에 대한 어떠한 설명에서도 반영되어야 할 복잡성이다.

법원과 그 밖의 사람들에 의해, 체계의 개별 규칙들을 식별하는(identify) 데에 명시되지 않은 승인 규칙(rule of recognition)이 사용되는 것은 내부 관점(internal point of view)의 특징이다. 이러한 방식으로 승인 규칙을 사용하는 사람들은, 그것들을 향도규칙들(guiding rules)로 자신들이 수용하고 있음을 드러내며, 이러한 태도와 함께 외부 관점(external point of view)의 자연스러운 표현들과는 다른, 특징적인 어휘가 수반된다. 아마도 이러한 표현들 가운데 가장 단순한 것은 ‘…은 법이다(It is the law that …)’ 라는 표현일 것인데, 이는 판사들뿐만 아니라 법체계 아래에서 살아가는 보통 사람들의 입에서도, 체계의 어떤 주어진 규칙을 식별할 때 발견될 수 있다. 이는 ‘아웃(Out)’ 이나 ‘골(Goal)’ 이라는 표현과 마찬가지로, 다른 사람들과 함께 그 목적에 적절한 것으로 인정하는(acknowledges) 규칙들에 대한 참조(reference)로 한 사람이 상황을 평

가하는(assessing a situation) 언어이다. 이러한 규칙에 대한 공유된 수용(shared acceptance)의 태도는, 사회 집단이 그러한 규칙들을 수용하고 있다는 사실을 외부로부터(ab extra) 기록할 뿐, 자신은 그 규칙들을 수용하지 않는 관찰자의 태도와 대비된다. 이 외부 관점의 자연스러운 표현은 ‘…은 법이다(It is the law that …)’가 아니라, ‘영국에서는 의회 내 여왕이 제정하는 것은 무엇이든 법으로 인정한다(In England they recognize as law … whatever the Queen in Parliament enacts…)’와 같은 것이다. 이 두 표현 형식 가운데 첫 번째를 우리는 내부 진술(internal statement)이라고 부를 것인데, 이는 내부 관점을 드러내며, 승인 규칙을 수용하고 있으면서도 그것이 수용되고 있다는 사실을 진술하지 않은 채, 그 규칙을 적용하여 체계의 어떤 특정 규칙을 유효한(valid) 것으로 인정하는 사람이 자연스럽게 사용하는 표현이기 때문이다. (p. 103) 두 번째 표현 형식은 외부 진술(external statement)이라고 부를 것인데, 이는 체계의 승인 규칙을 스스로 수용하지 않으면서, 다른 사람들이 그것을 수용하고 있다는 사실을 진술하는 외부 관찰자의 자연스러운 언어이기 때문이다.

수용된 승인 규칙을 사용하여 내부 진술을 하는 이러한 방식이 이해되고, 그 규칙이 수용되고 있다는 사실에 대한 외부 사실 진술(external statement of fact)과 신중하게 구별된다면, 법적 ‘유효성(validity)’이라는 관념(notion)을 둘러싼 많은 모호함은 사라진다. 왜냐하면 ‘유효한(valid)’이라는 말은 언제나 그런 것은 아니지만, 가장 흔히 바로 그러한 내부 진술에서 사용되며, 법체계의 어떤 특정 규칙에 대하여, 명시되지는 않았으나 수용된 승인 규칙을 적용하기 때문이다. 어떤 주어진 규칙이 유효하다고 말하는 것은, 그것이 승인 규칙이 제공하는 모든 검사 기준들(tests)을 통과하였음을, 따라서 체계의 규칙임을 인정하는 것이다. 기실 우리는, 어떤 특정 규칙이 유효하다는 진술이란 그것이 승인 규칙이 제공하는 모든 기준들(criteria)을 충족한다는 것을 의미한다고 간단히 말할 수 있다. 이는 그러한 진술들의 내부 성격을 가릴 수 있다는 점에서만 부정확한데, 왜냐하면 이러한 유효성 진술들은 크리켓 선수의 ‘아웃(Out)’이라는 표현과 마찬가지로, 화자와 다른 사람들이 수용하고 있는 승인 규칙을 어떤 특정 사례에 적용하는 것이지, 그 규칙이 충족되었다는 사실을 명시적으로 진술하는 것이 아니기 때문이다.

법적 유효성(legal validity)이라는 관념과 관련된 몇몇 난점들은, 법의 유효성과 법의 ‘실효성(efficacy)’ 사이의 관계에 관한 것이라고들 말해진다. 만약 ‘실효성’이란, 특정한 행위를 요구하는 어떤 법규칙이 대체로(more often than not) 복종된다는 사실을 의미하는 것이라면, 개별 규칙의 유효성과 그 규칙의(its) 실효성 사이에는 필연적인 연관(necessary connection)이 없다는 점은 분명하다. 다만 체계의 승인 규칙(rule of recognition)이 그 기준들(criteria) 가운데—일부 체계가 그러하듯—어떤 규칙이 오랫동안 실효성을 상실한 경우에는 더 이상 그 체계의 규칙으로 간주되지 않는다는 규정(때때로 실효상실 규칙(rule of obsolescence)이라 불리는 것)을 포함하는 경우는 예외이다.

어떤 개별 규칙의 실효성 결여(inefficacy)는—그것이 그 규칙의 유효성에 불리하게 작용할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있지만—체계 전체의 규칙들에 대한 일반적인 무시(general disregard)와는 구별되어야 한다. 이러한 무시는 그 성격상 완전하고 또한 장기간 지속될 수 있는데, 그 경우 우리는 새로운 체계에 대해서는 그것이 특정 집단의 법체계로서 결코 확립된 적이 없다고 말하게 되거나, 한때 확립되었던 체계에 대해서는 그것이 더 이상 그 집단의 법체계가 아니게 되었다고 말하게 될 것이다. 어느 경우든, 체계의 규칙들에 근거하여(p. 104) 내부 진술(internal statement)을 하는 데 필요한 정상적인 맥락 또는 배경은 결여되어 있다. 이러한 경우에는, 특정 개인들의 권리들과 책무들을 그 체계의 일차 규칙들을 참조하여 평가하는 것도, 그 체계의 승인 규칙들을 참조하여 그 규칙들 가운데 어느 것의 유효성을 평가하는 것도, 일반적으로 무익한(pointless) 일이 된다. 실제로 한 번도 실효적이었던 적이 없거나 이미 폐기된 규칙 체계를 적용하겠다고 고집하는 것은, 아래에서 언급할 특수한 사정을 제외하면, 한 번도 수용된 적이 없거나 이미 폐기된 득점 규칙(scoring rule)을 참조하여 경기의 진행 상황을 평가하려는 것만큼이나 무익하다.

체계의 특정 규칙의 유효성에 관하여 내부 진술을 하는 사람은, 그 체계가 일반적으로 실효성을 갖고 있다는 외부 사실 진술의 참임(truth)을 전제(presuppose)하고 있다고 말할 수 있다. 왜냐하면 내부 진술의 정상적인 사용은 그러한 일반적 실효성의 맥락 속에서 이루어지기 때문이다. 그러나 유효성에 관한 진술이 체계가 일반적으로 실효적이라는 것을 ‘의미한다(mean)’

고 말하는 것은 잘못일 것이다. 어떤 체계가 한 번도 확립된 적이 없거나 이미 폐기된 경우, 그 체계의 규칙의 유효성에 대해 말하는 것은 대체로 무익하거나 공허한(normally pointless or idle) 말이기 는 하지만, 그렇다고 해서 그것이 전혀 의미 없거나(meaningless) 언제나 무익한(always pointless) 것은 아니다. 로마법(Roman Law)을 가르치는 하나의 생생한 방식은, 그 체계가 여전히 실효적인 것처럼(as if) 말하며, 개별 규칙들의 유효성을 논하고 그 규칙들에 따라 문제를 해결하는 것이다; 또한 혁명에 의해 파괴된 옛 사회질서의 회복에 대한 희망을 품고 새로운 질서를 거부하는 하나의 방식은, 구체제의 법적 유효성 기준들(criteria of legal validity)에 집착하는 것이다. 이는 차르 체제 러시아(Tsarist Russia)에서 유효했던 어떤 상속 규칙(rule of descent)에 근거하여 여전히 재산권을 주장하는 백계 러시아인(White Russian)에 의해 암묵적으로 행하여진다.

체계의 특정 규칙이 유효하다는 내부 진술과, 그 체계가 일반적으로 실효적이라는 외부 사실 진술 사이의 정상적인 맥락적 연관을 파악하면, 규칙의 유효성을 단언하는(assert) 것은 그것이 법원에 의해 집행되거나 그 밖의 어떤 공무담당 작용이 취해질 것임을 예측하는 것이라는 통상적 이론을 그에 걸맞은 관점에서 이해하는 데 도움이 된다. 이러한 이론은 우리가 지난 장에서 검토하고 배척한 의무의 예측적 분석과 여러 면에서 유사하다. 두 경우 모두에서 이 예측적 이론을 제시하게 되는 동기는, 오직 이러한 방식으로만 형이상학적 해석을 회피할 수 있다는 다음과 같은 확신이다: 즉, 규칙이 유효하다는 진술은 (p. 105) 경험적 수단으로는 탐지될 수 없는 어떤 신비한 성질을 귀속시키는 것이거나, 아니면 공무담당자들의 장래 행태에 대한 예측이어야 한다는 것이다. 또한 두 경우 모두에서 이 이론의 그럴듯함은 동일한 다음의 중요한 사실에 기인한다: 즉 체계가 일반적으로 실효적이며 앞으로도 그러할 개연성이 높다는, 관찰자가 기록할 수 있는, 외부 사실 진술의 참임(truth)이, 규칙을 수용하고 의무나 유효성에 관한 내부 진술을 하는 사람에 의해 정상적으로(normally) 전제된다는 점이다. 이 둘은 분명히 매우 밀접하게 연관되어 있다. 마지막으로, 두 경우 모두에서 이 이론의 오류는 동일하다. 그것은 내부 진술의 특수한 성격을 간과하고, 이를 공무담당 작용(official action)에 관한 외부 진술로 취급하는 데에 있다.

이러한 오류는 특정 규칙이 유효하다는 판사 자신의 진술이 사법적 결정에서 어떻게 기능하는지를 고려하면 즉각적으로 드러난다. 왜냐하면 이 경우에도 판사는 그러한 진술을 하면서 체계의 일반적 실효성을 전제할 뿐 이를 진술하지는 않지만, 분명히 자기 자신의 또는 타인의 공무담당 작용을 예측하는 데에는 관심이 없기 때문이다. 규칙이 유효하다는 그의 진술은, 그 규칙이 그의 법정에서 무엇이 법으로 간주될 것인지를 식별하기 위한 검사 기준들(tests)을 충족한다는 점을 인정하는 내부 진술이며, 결정에 대한 예언(prophecy)이 아니라 결정의 이유(reason)의 일부를 구성한다. 기실 이러한 진술이 사적 개인에 의해 이루어지는 경우에는, 규칙이 유효하다는 진술을 예측으로 간주하는 것이 더 그럴듯해 보일 수 있다. 왜냐하면 비공무담당자의 유효성 또는 유효하지 않음에 관한 진술들과 사안을 판단하는 법원의 진술 사이에 충돌이 발생하는 경우, 전자는 철회되어야 한다고 말하는 데에 종종 상당한 일리가 있기 때문이다. 그러나 이 경우에도, 제7장에서 공무담당자들의 선언과 규칙의 명백한 요구 사이의 이러한 충돌의 의미를 검토하게 되면 보게 되듯이, 그것이 법원이 무엇이라고 말할지를 예측하는(predicted) 데에서 오류를 범했기 때문에 이제 그른(wrong) 진술로 드러나 철회되는 것이라고 단정하는 것은 독단적일 수 있다. 왜냐하면 진술을 철회하는 이유는 그것이 그르다는 사실만이 아니며, 또한 그른 방식 역시 이러한 설명이 허용하는 것보다 더 다양하기 때문이다.

다른 규칙들의 유효성을 평가하기 위한 기준들을 제공하는 승인 규칙(rule of recognition)은 중요한 의미에서 궁극적(ultimate) 규칙이다. 이 점은 우리가 곧 명확히 해설하려 한다. 그리고 통상 그렇듯이 여러 기준들이 상대적 종속성과 우위성(primacy)의 서열로 정렬되어 있는 경우, 그중 하나는 최고(supreme) 기준이 된다. (p. 106) 승인 규칙의 궁극성(ultimacy)과 그 기준 중 하나의 최고성(supremacy)에 관한 이러한 관념들은 주의 깊게 다룰 만한 가치가 있다. 우리는 이 관념들을, 앞서 우리가 기각했던 이론—즉, 모든 법체계에는, 설령 그것이 법적 형식 배후에 숨어 있다 하더라도, 반드시 법적으로 무제한인 주권적 입법 권력(sovvereign legislative power)이 존재해야 한다는 이론—으로부터 분리해내는 것이 중요하다.

이 두 관념, 즉 최고 기준(supreme criterion)과 궁극적 규칙(ultimate rule)

가운데 전자는 정의하기가 가장 쉽다. 법적 유효성의 기준 또는 법의 원천이 최고(supreme)라고 말할 수 있는 경우는, 그 기준을 참조(reference)하여 식별된 규칙들이 다른 기준들을 참조하여 식별된 규칙들과 충돌하더라도 여전히 체계의 규칙으로 인정되는 반면, 후자의 기준들을 참조하여 식별된 규칙들은 최고 기준을 참조하여 식별된 규칙들과 충돌하는 경우 그러한 인정이 이루어지지 않을 때이다. 우리가 이미 사용해 온 ‘우위의(superior)’ 기준과 ‘종속된(subordinate)’ 기준이라는 관념들도 이와 유사한 비교적 설명에 의해 해명될 수 있다. 우위의 기준과 최고 기준이라는 관념들은 단지 척도상에서의 상대적인(relative) 위치를 가리킬 뿐이며, 법적으로 무제한인(unlimited) 입법 권한에 대한 어떠한 관념도 함의하지 않는다는 점은 명백하다. 그럼에도 불구하고 ‘최고(supreme)’라는 것과 ‘무제한적(unlimited)’이라는 것은—적어도 법이론에서는—쉽게 혼동된다. 그 이유 중 하나는, 보다 단순한 형태의 법체계에서는 궁극적 승인 규칙(ultimate rule of recognition), 최고 기준, 그리고 법적으로 무제한적인 입법부라는 관념들이 서로 수렴하는 것처럼 보이기 때문이다. 헌법적 제한을 받지 않는 입법부가 존재하고, 그 입법부가 자신의 제정(enactment)을 통해 다른 원천들로부터 나온 다른 모든 법규칙들의 법적 지위를 박탈할 권능을 가진(competent) 경우, 그러한 체계의 승인 규칙의 일부로서 그 입법부의 제정이 유효성의 최고 기준이 된다. 헌법이론에 따르면, 이것이 영국(United Kingdom)의 경우이다. 그러나 미합중국과 같이 그러한 법적으로 무제한적인 입법부가 존재하지 않는 체계를조차도, 유효성의 기준들로 이루어진 하나의 집합을 제공하는 궁극적 승인 규칙을 충분히 포함할 수 있으며, 그 기준들 가운데 하나는 최고일 수 있다. 이는 일반 입법부의 입법 권능(legislative competence)이 개정 권한을 포함하지 않거나, 또는 그 개정 권한의 범위 밖에 놓인 조항들을 포함하는 헌법에 의해 제한되는 경우에 해당한다. 이 경우, ‘입법부’라는 개념을 가장 넓게 해석하더라도 법적으로 무제한적인 입법부는 존재하지 않지만, 그 체계는 물론 궁극적 승인 규칙을 포함하고 있으며, 헌법 조항들 속에 유효성의 최고 기준을 포함하고 있다.

(p. 107) 승인 규칙(rule of recognition)이 한 체계의 궁극적(ultimate) 규칙이라는 의미는, 매우 익숙한 하나의 법적 추론 연쇄를 따라가 보면 가장 잘

이해된다. 어떤 후보 규칙(suggested rule)이 법적으로 유효한지 여부가 문제로 제기되는 경우, 그 질문에 답하기 위해서는 다른 어떤 규칙이 제공하는 유효성의 기준을 사용해야 한다. 옥스퍼드셔 카운티 의회(Oxfordshire County Council)의 이 이른바 조례(purported by-law)는 유효한가? 그렇다: 왜냐하면 그것은 보건부 장관(Minister of Health)이 제정한 법정 명령(statutory order)에 의해 부여된 권한을 행사하여, 그 명령에 명시된 절차에 따라 제정되었기 때문이다. 이 첫 단계에서 법정 명령은 조례의 유효성이 평가되는 기준을 제공한다. 실 천적으로는 더 나아갈 필요가 없을 수도 있지만, 그렇게 할 수 있는 상존하는 가능성은 있다. 우리는 그 법정 명령의 유효성을 문제 삼고, 그러한 명령을 제정할 권한을 장관에게 부여한 제정법(statute)을 참조하여 그 유효성을 평가 할 수 있다. 마지막으로, 그 제정법의 유효성마저 문제 삼아 의회 내 여왕이 제정하는 것은 법이라는 규칙을 참조하여 평가하게 되면, 유효성에 관한 탐구는 여기서 멈추게 된다: 왜냐하면 이는 우리가 다른 규칙들의 유효성을 평가하기 위한 기준을 제공하는 규칙에 도달했기 때문이며, 동시에 그 규칙은 중간 단계의 법정 명령이나 제정법과는 달리, 그 자신의 법적 유효성을 평가하기 위한 기준을 제공하는 어떠한 규칙도 더 이상 존재하지 않는다는 점에서 그들과 구별된다.

기실 이 궁극적 규칙에 대하여 제기할 수 있는 질문들은 많다. 우리는 영국 에서 법원들, 입법부들, 공무원당자들, 또는 사적 시민들이 실제로 이 규칙을 궁극적 승인 규칙으로 사용하고 있는 실천이 존재하는지 물을 수 있다. 아니면 우리의 법적 추론 과정은 이제 폐기된 체계의 유효성 기준을 가지고 벌이는 공허한 놀이에 불과한 것인가? 우리는 또한 이러한 규칙을 근간으로 하는 법 체계가 만족스러운 형태의 법체계인지 물을 수 있다. 그것은 악보다 선을 더 많이 산출하는가? 그것을 지지할 타산적 이유들(prudential reasons)은 존재하 는가? 그렇게 할 도덕적 의무(moral obligation)는 있는가? 이러한 질문들은 분명히 매우 중요하다. 그러나 이와 동일하게 분명한 것은, 우리가 승인 규칙에 관하여 이러한 질문들을 제기할 때, 우리는 더 이상 그 규칙을 도구로 삼아 다른 규칙들에 관해 답했던 것과 같은 종류의 질문에 답하려 하고 있는 것이 아니라는 점이다. 우리가 어떤 특정한 제정(enactment)이 의회 내 여왕이 제정 하는 것은 법이다라는 규칙을 충족하기 때문에 유효하다고 말하는 단계에서,

영국에서 바로 이 마지막 규칙이 법원들, 공무원들, 그리고 사적 개인들에 의해 궁극적 승인 규칙으로 사용되고 있다고 말하는 단계로 이동할 때, (p. 108) 우리는 체계의 한 규칙의 유효성을 단언하는 내부 법 진술(internal statement of law)에서, 그 규칙을 수용하지 않더라도 체계의 관찰자가 할 수 있는 사실에 관한 외부 진술(external statement of fact)로 이동한 것이다. 마찬가지로, 어떤 특정한 제정이 유효하다는 진술에서, 그 법체계의 승인 규칙이 훌륭한 것이며 그것에 기초한 체계가 지지할 가치가 있는 체계라는 진술로 이동할 때, 우리는 법적 유효성에 관한 진술에서 가치에 관한 진술로 이동한 것이다.

일부 저자들은 승인 규칙(rule of recognition)의 법적 궁극성(legal ultimacy)을 강조하면서, 체계의 다른 규칙들의 법적 유효성은 이를 참조하여 입증될(demonstrated) 수 있는 반면, 승인 규칙 자체의 유효성은 입증될 수 없고 ‘가정된다(assumed)’거나 ‘상정된다(postulated)’거나 하나의 ‘가설(hypothesis)’이라고 표현해 왔다. 그러나 이러한 표현은 심각하게 오해를 불러일으킬 수 있다. 법체계의 일상적 삶 속에서 판사, 법률가, 또는 일반 시민에 의해 특정 규칙들에 관하여 행해지는 법적 유효성에 대한 진술들은 기실 일정한 전제들을 수반한다. 이러한 진술들은 체계의 승인 규칙을 수용하는 자들의 관점을 표현하는 내부 법 진술들(internal statements of law)이며, 그러한 것으로서 체계에 관한 외부 사실 진술들(external statements of fact)에서 진술될 수 있는 많은 내용들을 명시하지 않은 채로 남겨 둔다. 이렇게 명시되지 않은 것들은 법적 유효성 진술들의 정상적인 배경 또는 맥락을 이루며, 따라서 그러한 진술들에 의해 ‘전제된다(presupposed)’고 말해진다. 그러나 이러한 전제된 사항들이 정확히 무엇인지를 분명히 파악하고, 그 성격을 흐리게 하지 않는 것이 중요하다. 그것들은 두 가지로 구성된다. 첫째, 어떤 주어진 법규칙, 예컨대 특정한 제정법(statute)의 유효성을 진지하게 단언하는 사람은, 법을 식별하는 데 적절한 것으로 자신이 수용하는 승인 규칙을 스스로 사용하고 있다. 둘째, 그가 특정한 제정법의 유효성을 평가하는 기준으로 삼는 이 승인 규칙은 그 자신에게만 수용되는 것이 아니라, 체계의 일반적 작동 속에서 실제로 수용되고 사용되고 있는 승인 규칙이라는 점이다. 만약 이 전제(presupposition)의 참임이 의심된다면, 그것은 실제 실천을 참조함으로써 확립될 수 있다: 즉, 법원들이 무엇을 법으로

간주할지를 식별하는 방식, 그리고 이러한 식별들에 대한 일반적인 수용 또는 묵인(acquiescence)을 참조함으로써이다.

이 두 전제(presuppositions) 중 어느 것도, 입증할 수 없는 ‘유효성(validity)’에 대한 ‘가정(assumption)’으로 제대로 설명될 수는 없다. 우리는 ‘유효성’이라는 단어를 오직 (p. 109) 규칙 체계 내부(within)에서 어떤 규칙이 그 체계의 구성원으로서의 지위를 갖기 위해 승인 규칙(rule of recognition)에 의해 제공된 특정 기준들을 충족해야 할 때, 그러한 질문에 답하기 위해서만 필요로 하며, 대체로 그러한 경우에만 사용한다. 승인 규칙 자체의 유효성에 대해서는 이러한 질문이 제기될 수 없다. 그것은 유효하거나 유효하지 않은 것이 아니라, 단지 그러한 방식으로 사용되기에 적절한 것으로 수용될 뿐이다. 이러한 단순한 사실을, 그 규칙의 유효성은 ‘가정되었지만 입증될 수 없다(assumed but cannot be demonstrated)’고 모호하게 표현하는 것은, 미터 단위 측정의 정확성(correctness)에 대한 궁극적 검사 기준(ultimate test)인 파리의 표준 미터 자(metre bar) 자체가 정확하다는 것을 ‘우리가 가정하지만 결코 입증할 수 없다’고 말하는 것과 같다.

보다 심각한 반론은, 궁극적 승인 규칙(ultimate rule of recognition)이 유효하다는 ‘가정(assumption)’에 관한 말이, 법률가들의 유효성 진술 배후에 놓인 두 번째 전제의 본질적으로 사실적(factual) 성격을 은폐한다는 점이다. 의심할 여지 없이, 승인 규칙의 실제 존재를 구성하는 판사들, 공무원담당자들, 기타 행위자들의 실천(practice)은 복합적인 사안이다. 우리가 뒤에서 보게 되겠지만, 이러한 종류의 규칙의 정확한 내용과 범위, 나아가 그 존재 여부에 관한 질문들이 명확하거나 확정적인(determinate) 답변을 허용하지 않는 상황들도 분명히 존재한다. 그럼에도 불구하고, 이러한 규칙의 ‘유효성을 가정하는 것(assuming the validity)’과 그 ‘존재를 전제하는 것(presupposing the existence)’을 구별하는 것은 중요하다. 최소한 이러한 구별의 실패가, 그러한 규칙이 존재한다(exists)고 단언하는 것이 무엇을 의미하는지를 흐리게 만들기 때문이다.

지난 장에서 개괄한 의무의 일차 규칙(primary rules of obligation)으로 이루어진 단순한 체계에서는, 어떤 특정 규칙이 존재한다고 단언하는 것은, 그 규칙을 수용하지 않는 관찰자가 제시할 수 있는 외부 사실 진술(external statement of

fact)에 불과하다. 이러한 진술은, 실제로 어떤 행위 양식이 일반적으로 표준으로 수용되고 있는지, 그리고 우리가 보았듯이 단순한 수렴적 습관들(convergent habits)과 사회적 규칙(social rule)을 구별하는 그러한 특징들이 수반되는지를 확인함으로써 검증될 수 있다. 마찬가지로, 현재 우리가 “잉글랜드에서는—비록 법적 규칙은 아니지만—교회에 들어갈 때 모자를 벗어야 한다는 규칙이 존재한다”는 단언을 해석하고 검증해야 하는 방식도 바로 이러한 방식이다. 이러한 유형의 규칙들이 사회 집단의 실제 실천 속에서 존재하는 것으로 확인된다면, 그 유효성에 관하여 별도로 논의할 문제는 없다. 물론 그 가치나 바람직성은 문제 삼을 수 있다. 그러나 일단 그 존재가 사실로 확립되었다면, 그것들이 유효하다고 말하거나 유효하지 않다고 부정하거나, (p. 110) 혹은 “우리는 그것들의 유효성을 가정했을 뿐 이를 입증할 수는 없다”고 말하는 것은 오히려 사안을 혼란스럽게 만들 뿐이다. 반면에, 성숙한 법체제와 같이 승인 규칙을 포함하는 규칙 체계를 갖는 경우에는, 어떤 규칙이 체계의 구성원으로서의 지위를 갖는지는 이제 승인 규칙이 제공하는 일정한 기준들을 충족하는지 여부에 달려 있다. 이는 ‘존재한다(exist)’라는 단어에 새로운 용법을 가져온다. 이제 어떤 규칙이 존재한다고 말하는 진술은, 관습 규칙의 단순한 경우에서와 같이, 특정한 행위 양식이 실제 실천에서 일반적으로 표준으로 수용되고 있다는 사실(fact)에 관한 외부 사실 진술이 더 이상 아닐 수 있다. 그것은 이제 수용되었으나 진술되지 않은 승인 규칙을 적용하는 내부 진술일 수 있으며, 대략적으로 말해 ‘그 체계의 유효성 기준들에 비추어 유효하다(valid given the system’s criteria of validity)’는 의미에 불과할 수 있다. 그러나 이러한 점에서, 그리고 다른 점들에서도, 승인 규칙은 체계의 다른 규칙들과는 다르다. 승인 규칙이 존재한다고 단언하는 것은 오직 외부 사실 진술일 수밖에 없다. 종속된 규칙(subordinate rule)은 일반적으로 무시되고 있더라도 유효할 수 있으며, 그 의미에서 ‘존재’할 수 있는 반면, 승인 규칙은 일정한 기준들을 참조하여 법을 식별하는 법원, 공무원, 사적 개인들(private persons)의 복합적이지만 통상적으로 일치하는 실천으로서만 존재한다. 그 존재는 하나의 사실 문제이다.

2. 새로운 질문들(New Questions)

법체계의 토대들이 법적으로 무제한인 주권자에 대한 복종 습관에 있다고 보는 관점을 버리고, 대신 규칙 체계에 유효성의 기준들을 제공하는 궁극적 승인 규칙이라는 구상(conception)으로 대체하게 되면, 우리는 흥미롭고 중요한 일련의 질문들과 마주하게 된다. 이러한 질문들은 비교적 새로운 것들인데, 그 이유는 오랫동안 법리학과 정치이론이 구시대적인 사유방식에 매여 있었던 동안에는 그러한 질문들이 가려져 있었기 때문이다. 이들은 또한 어려운 질문들이며, 충분한 답변을 위해서는 한편으로는 헌법(constitutional law)의 몇몇 근본 문제들에 대한 이해가, 다른 한편으로는 법적 형식들(legal forms)이 조용히 전환되고 변화하는 특유의 방식을 파악할 수 있는 통찰이 요구된다. 따라서 우리는 이 질문들을, 법 개념의 해명에서 일차 규칙들과 이차 규칙들의 결합에 중심적인 위치를 부여해야 한다고 우리가 해왔듯이 고수하는 것이 현명한지 또는 현명하지 않은지와 관련되는 범위 내에서만 탐구할 것이다.

(p. 111) 첫 번째 어려움은 분류(classification)의 문제이다. 왜냐하면 궁극적으로 법을 식별하기(identify) 위해 사용되는 그 규칙은, 흔히 전부를 포괄하는(exhaustive) 것으로 간주되는 법체계를 기술하는 관행적(conventional) 범주들로부터 벗어나 있기 때문이다. 따라서 다이시(Dicey) 이후의 영국 헌법 이론가들은 대체로, 영국의 헌정적 배치들이 한편으로는 엄밀히 그렇게 불리는 법들(laws strictly so called)—즉 제정법들(statutes), 추밀원 명령들(orders in council), 그리고 선례(precedents)에 구현된 규칙들—로, 다른 한편으로는 단지 용례(usages), 양해(understandings), 또는 관습(customs)에 불과한 관행들(conventions)로 구성되어 있다고 반복하여 진술해 왔다. 후자에는, 예컨대 여왕은 상원과 하원에서 적법하게 통과된 법안에 대해 동의를 거부할 수 없다는 것과 같은 중요한 규칙들이 포함된다. 그러나 여왕에게 그러한 동의를 할 법적 책무는 존재하지 않으며, 이러한 규칙들이 관행이라고 불리는 이유는 법원이 그것들을 법적 책무를 부과하는 것으로 인정하지 않기 때문이다. 분명히, 의회 내 여왕이 제정하는 것은 법이다라는 규칙은 이들 어느 범주에도 속하지 않는다. 그것은 법원이 그 규칙과 가장 밀접하게 관련되어 있고 이를 사용하여

법을 식별하는 점에서 관행이 아니며, 동시에 그것이 식별의 기준으로 사용되는 ‘엄밀히 그렇게 불리는 법들’과 동일한 수준의 규칙도 아니다. 설령 이 규칙이 제정법으로 제정되었다고 하더라도, 그것이 단순한 제정법의 수준으로 낮아지는 것은 아니다. 그러한 제정 행위의 법적 지위는 필연적으로, 그 규칙이 해당 제정에 선행하고 그 제정과 독립적으로 존재했다는 사실에 의존하기 때문이다. 더 나아가, 앞 절에서 보였듯이, 그 존재는 제정법의 존재와는 달리 실제 실천(actual practice)으로 구성되어야 한다.

이러한 측면은 일부에게서 절망의 외침을 끌어낸다: 즉, 분명히 법인 헌법의 근본 규정들이 정말로 법이라는 것을 우리는 어떻게 입증할 수 있는가? 이에 대해 다른 이들은, 법체계의 토대에는 ‘법이 아닌 것’, 즉 ‘전법적인(pre-legal) 것’, ‘메타-법적인(meta-legal) 것’, 또는 단순히 ‘정치적 사실(political fact)’이 존재한다고 고집한다. 이러한 불안감은 모든 법체계에서 가장 중요한 이 특징을 기술하기 위해 사용되어 온 범주들이 지나치게 거칠다는 확실한 징후이다. 승인 규칙을 ‘법’이라고 부를 수 있다는 근거는, 체계 내의 다른 규칙들을 식별하기 위한 기준을 제공하는 규칙이야말로 법체계를 정의하는 특징(defining feature)으로 충분히 간주될 수 있으며, 따라서 그 자체가 ‘법’이라고 불릴 만하다는 점에 있다. 반대로 그것을 ‘사실’이라고 부를 수 있다는 근거는, 그러한 규칙이 존재한다고 단언하는 것이 기실 (p. 112) ‘실효성 있는(efficacious)’ 체계에서 규칙들이 어떠한 방식으로 식별되는지에 관한 실제 사실(actual fact)에 대한 외부 진술이기 때문이다. 이 두 측면은 모두 주목을 요구하지만, 우리는 ‘법’ 또는 ‘사실’이라는 어느 한 명칭(label)을 선택하는 것만으로는 이 둘 모두를 정당하게 다룰 수 없다(do justice). 대신, 우리는 궁극적 승인 규칙을 두 가지 관점에서 바라볼 수 있음을 기억해야 한다. 하나는 그 규칙이 체계의 실제 실천(actual practice) 속에 존재한다는 외부 사실 진술로 표현되는 관점이며, 다른 하나는 그 규칙을 사용하여 법을 식별하는 사람들이 행하는 유효성(validity)에 관한 내부 진술로 표현되는 관점이다.

두 번째 질문군은 특정 국가나 사회 집단 안에 법체계가 존재한다(exists)고 하는 단언(assertion)의 숨겨진 복잡성과 모호성(vagueness)에서 비롯된다. 우리가 이러한 단언을 할 때, 실제로는 대개 함께 수반되는 서로 이질적인 여러 사회적

사실들(heterogeneous social facts)을 압축적 포괄 형식(portmanteau form)으로 가리키고 있는 것이다. 오해를 불러일으키는 이론의 그림자 아래 발전된 법적 사고와 정치적 사고의 표준 용어법(standard terminology)은 사실들을 지나치게 단순화하고 가리기 쉽다. 그러나 이러한 용어법이 구성하는 안경(spectacles)을 벗고 사실들을 바라보면, 법체계(legal system)는 인간과 마찬가지로, 어떤 단계에서는 아직 태어나지 않은 상태(unborn)에 있고, 또 어떤 단계에서는 아직 모체로부터 완전히 독립하지 않은 상태(not yet wholly independent)에 있으며, 이후 건강하고 독립적인 존재(healthy independent existence)를 누리다가, 쇠퇴(decay)하고 마침내 사망(die)하기도 한다는 것이 분명해진다. 이러한 ‘출생과 정상적 독립 존재 사이’, 또는 ‘그 독립된 존재와 죽음 사이’의 중간 단계들은 우리가 익숙하게 사용하는 법 현상에 대한 설명 방식을 어긋나게 만든다(put out of joint). 그러나 이 중간 단계들은 그만큼 우리가 정상 사례에서 “특정 국가에는 법체계가 존재한다”라는 확신에 찬 참된 단언을 할 때 당연하게 여기는 것의 온전한 복잡성을 부각시키기 때문에, 혼란스러울지라도 연구할 가치가 있다.

이러한 복잡성을 인식하는 한 가지 방식은, 명령들에 대한 일반적 복종의 습관이라는 단순한 오스틴식 공식(Austinian formula)이, 사회가 법체계를 갖기 위해 충족해야 하는 최소 조건들을 구성하는 복합적 사실들을 재현하는 데서 정확히 어디에서 실패하거나 왜곡하는지를 살펴보는 데 있다. 우리는 이 공식이 하나의 필요조건을 지목한다(designate)는 점은 인정할 수 있다. 즉, 법들이 의무(obligation)나 책무(duty)를 부과하는 경우, 그 법들에는 일반적으로 복종이 이루어져야 하거나 적어도 일반적으로 불복종이 이루어지지 않아야 한다는 점이다. 그러나 이는 필수적이긴 하나, 법체계가 사적 시민에게 영향을 미치는 지점에서 나타나는 우리가 ‘최종 산물(end product)’이라 부를 수 있는 것만을 다룰 뿐이며, 법체계의 일상적 존재는 (p. 113) 또한 공무담당자들에 의한 법의 창출(official creation), 공무담당자들에 의한 식별, 그리고 공무담당자들에 의한 사용 및 적용으로도 이루어져 있다. 여기에서 관련되는 법과의 관계를 ‘복종(obedience)’이라 부를 수 있으려면, 그 단어를 통상적 용법을 훨씬 넘어 확장하여, 결국에는 이러한 작용들을 정보를 주는 방식으로 특징짓는 기능을 상실하게 해야 한다. 입법자들이 법들을 제정할 때 자신들의 입법 권한들을 부여하는

규칙들에 부합하는 경우, 그러한 권한들을 부여하는 규칙들이 그것들을 따를 책무를 부과하는 규칙들에 의해 강화되지 않는 한, 어떤 통상적 의미에서도 입법자들이 규칙에 ‘복종’ 한다고 말할 수는 없다. 또한 이러한 규칙들에 부합하지 않았다고 해서 그들이 법에 ‘불복종하는(disobey)’ 것도 아니며, 다만 법을 만들어내는 데 실패할 뿐이다. 마찬가지로, 판사가 체계의 승인 규칙(rule of recognition)을 적용하여 어떤 제정법(statute)을 유효한 법으로 인정하고 분쟁의 판정(determination)에 이를 사용하는 경우에, ‘복종’ 이라는 말은 그가 하는 일을 적절히 묘사하지 못한다. 물론 우리는 사실들 앞에서 ‘복종’ 이라는 단순한 용어를 유지하고자 한다면, 여러 장치를 통해 그렇게 할 수는 있다. 그 한 예로, 판사가 제정법을 인정하는 데서 사용하는 일반적 유효성 기준을, ‘헌법 제정자들(Founders of the Constitution)’ 이 내린 명령들에 대한 복종의 사례로 표현하거나, (그러한 ‘제정자들’ 이 없는 경우에는) 지휘관 없는 사령, 즉 ‘탈심리화된 사령(depsychologized command)’ 에 대한 복종으로 표현할 수 있을 것이다. 그러나 후자의 관념은, 삼촌 없는 조카라는 관념만큼이나, 우리의 주의를 진지하게 요구할 이유가 없을지도 모른다. 다른 한편으로는, 법의 공무담당 측면 전체를 시야에서 밀어내고 입법과 재판에서 이루어지는 규칙의 사용에 대한 서술을 포기한 채, 공무담당 세계 전체를 하나의 인격(‘주권자’)이 여러 대리인이나 대변자를 통해 명령들을 발하는 것으로 생각하고, 시민이 그 명령들에 습관적으로 복종한다고 간주할 수도 있다. 그러나 이는 여전히 서술을 기다리는 복합적 사실들에 대한 편의적 축약에 불과하거나, 아니면 재앙적으로 혼란을 초래하는 신화적 구성물일 뿐이다.

법체계가 존재한다는 것을, 기실 일반 시민과 법의 관계를 특징짓기는 하지만 그것을 언제나 남김없이 서술하지는 않는 습관적 복종(habitual obedience)이라는 기분 좋을 만큼 단순한 표현으로 설명하려는 시도가 실패한 데 대한 반작용으로, 그 반대의 오류를 범하는 일은 자연스러운 일이다. 그 오류는 공무담당 활동들(official activities)—특히 사법적 태도(judicial attitude)나 법에 대한 관계—의 특징이지만 역시 남김없는 설명은 아닌 것을 취하여, 그것을 법체계를 가진 사회집단에서 반드시 존재해야 하는 것에 대한 충분한 설명으로 취급하는 데 있다. 이러한 오류는 사회 구성원의 대다수가 법에 대해 단순히 습관적으로

복종한다는 단순한 구상을, 그들이 법들의 유효성을 최종적으로 평가하는 기준을 특정하는 궁극적 승인 규칙(rule of recognition)을 일반적으로 공유하거나, 수용하거나, 구속력 있는 것으로 간주해야 한다는 구상으로 대체하는 데 이른다. 물론 우리는 3장에서 살펴본 것처럼, 법의 원천들에 관한 지식과 이해가 사회 전반에 널리 퍼진 단순한 사회를 상상할 수 있다. 그곳에서는 ‘헌법(constitution)’이 너무 단순해서, 일반 시민뿐 아니라 공무원당자들과 법률가들 역시 그 헌법을 알고 있으며 수용하고 있다고 말해도 아무런 허위가 없을 것이다. 렉스 1세의 단순한 세계에서는, 인구 다수가 그의 말에 단순히 습관적으로 복종한 것 그 이상이 있었다고 말할 수도 있다. 그 사회에서는 수범자들과 체계의 공무원당자들 모두가 렉스의 말(Rex's word)을 사회 전체를 위한 유효한 법의 기준으로 규정하는 하나의 승인 규칙을 명시적이고 의식적인 방식으로 ‘수용하고(accepted)’ 있었을 수 있다. 물론 수범자들과 공무원당자들은 수행해야 할 역할과 이 기준에 따라 식별되는 법규칙들에 대한 관계가 서로 달랐겠지만 말이다. 그러나 이렇게 단순한 사회에서 가능한 상태를, 복잡한 현대 국가에서도 항상 또는 일반적으로 존재한다고 주장하는 것은 허구를 고집하는 일일 것이다. 여기서 상황의 현실은 분명 이렇다: 상당수의 일반 시민, 어쩌면 과반수는 법적 구조나 그 유효성 기준들에 대한 일반적 구상을 가지고 있지 않다. 그가 복종하는 당해 법(the law)은 그에게 단지 ‘법’으로만 알려져 있는 어떤 것일 뿐이다. 그는 여러 서로 다른 이유들로 그 법에 복종할 수 있으며, 그 이유들 중에는 그러한 것이 자신에게 가장 이롭다는 지식이 자주, 비록 항상은 아니지만, 포함될 수 있다. 그는 불복종 시 발생할 수 있는 일반적으로 개연성 있는 결과들—예컨대 자신을 체포할 수 있는 공무원당자들이 있고, 자신을 재판하여 법을 어겼다는 이유로 감옥에 보낼 수 있는 이들이 있다는 것—을 알고 있을 것이다. 그 체계의 유효성 검사 기준들에 따라 유효한 법들에 인구 대다수가 복종하는 한, 이는 특정한 법체계가 존재한다는 것을 확립하기 위해 필요한 증거 전부이다.

그러나 법체계가 일차 규칙들과 이차 규칙들의 복합적 결합이라는 바로 그 이유 때문에, 이러한 증거만으로는 법체계의 존재에 수반되는 법과의 관계들을 모두 서술하기에 충분하지 않다. 이는 체계의 공무원당자들이 공무원당자로서 관련되는 이차 규칙들에 대해 갖는 관계에 관한 (p. 115) 서술로 보충되어야

한다. 여기서 핵심적인 것은 체계의 유효성 기준들을 포함하는 승인 규칙에 대한 공무담당자들의 통일적이거나 공유된 수용(a unified or shared official acceptance)이 존재해야 한다는 점이다. 그러나 바로 이 지점에서, 일반 시민의 경우에 불가결한 최소를 특징짓기에는 충분했던 일반적 복종이라는 단순한 관념은 부적절해진다. 요점은 ‘복종(obedience)’이라는 표현이 법원과 다른 공무담당자들이 이러한 이차 규칙들을 규칙으로서 존중하는 방식을 가리키는 데 자연스럽게 사용되지 않는다는 ‘언어적(linguistic)’ 문제가 아니며, 적어도 단지 그 문제만은 아니다. 필요하다면, 우리는 ‘따르다(follow)’, ‘준수하다(comply)’, 또는 ‘부합하다(conform to)’와 같은 보다 포괄적인 표현을 찾아낼 수 있을 것이다. 이러한 표현들은 시민이 병역에 응하기 위해 법과 관련하여 수행하는 행위와, 판사가 의회 내 여왕이 제정하는 것은 법이라는 전제하에 자신의 법정에서 특정 제정법(statute)을 법으로 식별하는 행위를 모두 특징지을 수 있을 것이다. 그러나 이러한 포괄 용어들(blanket terms)은, 우리가 법체계라고 부르는 이 복합적 사회 현상의 존재에 포함된 최소 조건을 이해하기 위해 반드시 파악되어야 할 중대한 차이들을 단지 가려버릴 뿐이다.

입법자들이 자신들의 권한들을 부여하는 규칙들에 부합하여 입법 활동을 하거나, 법원이 수용된 궁극적 승인 규칙(ultimate rule of recognition)을 적용할 때, 이를 ‘복종(obedience)’이라고 묘사하는 것이 오해를 불러일으키는 이유는 다음과 같다. 어떤 규칙(또는 명령)에 복종한다고 해서, 그 복종하는 사람이 자신이 하는 일이 자기 자신뿐 아니라 다른 사람들에게도 옳은 일이라고 생각해야 할 필요는(need) 없다. 그는 자신이 하는 행동을 사회집단의 다른 구성원들에게도 적용되는 행동 기준을 실현하는 것으로 보지 않아도 된다. 그는 자신이 보이는 부합 행위를 ‘옳다(right)’, ‘올바르다(correct)’, 또는 ‘의무적이다(obligatory)’라고 생각할 필요가 없다. 즉, 그의 태도에는 사회 규칙이 수용되거나 특정 행위 유형이 일반적 기준으로 간주될 때 수반되는 비판적 성격(critical character)이 전혀 없을 수 있다. 그는 그러한 규칙들을 그 규칙들이 적용되는 모든 사람을 위한 기준으로 수용하는 내부 관점(internal point of view)을 공유하지 않을 수도 있다. 대신 그는 그 규칙을 단지 그에게(him) 요구되는 것, 즉 제재적-불이익(penalty)의 위협 아래 행동을 요구하는 것으로만 여길

수 있다. 그는 그저 결과에 대한 두려움 때문에, 혹은 관성에 따라 복종할 수 있으며, 자신이나 타인이 그것을 따를 의무가 있다고 여기지 않고, 규칙을 여기는 자신이나 타인을 비판할 의향도 없을 수 있다. 하지만, (p. 116) 모든 일반 시민이 규칙에 복종할 때 가질 수도 있는(may) 이러한 개인적인 차원의 관심만으로는, 법원이 자신이 법원으로서 다루는 규칙들에 대해 갖는 태도를 설명할 수 없다. 이는 특히 다른 규칙들의 유효성을 평가하는 데 쓰이는 궁극적 승인 규칙(ultimate rule of recognition)의 경우에 분명하다. 이 규칙은, 존재하기 위해서 반드시 하나의 공적인(public), 공통의(common) 올바른 사법적 결정의 기준(standard of correct judicial decision)으로서 내부 관점(internal point of view)에서 수용되어야 하며, 단순히 각 판사가 자기 몫으로만 ‘복종’ 하는 어떤 것으로 여겨져서는 안 된다. 그 법체계의 법원들 중 개별적인 법원이 때때로 이 규칙들로부터 이탈하는 일이 있을 수는 있으나, 일반적으로 그러한 이탈을 공통적이거나 공적인 기준(common or public standards)에서의 이탈(lapses)로 비판적으로 다루어야 한다. 이는 단지 법체계의 효율성이나 건전성과 관련된 문제가 아니라, 하나의 법체계(single legal system)가 존재한다고 말할 수 있기 위한 논리적으로 필수적인 조건(logically necessary condition)이다. 가령 어떤 판사들만이 ‘자기 몫으로만’ 행동하며 “의회 내 여왕이 제정하는 것은 법이다”라는 전제에 서고, 이 승인 규칙을 존중하지 않는 이들을 아무도 비판하지 않는다면, 법체계의 특유의 통일성 및 계속성(characteristic unity and continuity)은 사라지고 말 것이다. 이러한 통일성과 계속성은 바로 이 핵심적 지점에서 법적 유효성에 관한 공통된 기준(common standards of legal validity)이 수용되는 데 의존하기 때문이다. 이러한 사법적 행태의 변칙들과, 평범한 사람들이 서로 상반되는 사법 명령들에 직면하게 될 때 결국 초래될 혼란 사이의 그 사이 구간에서, 우리는 그 상황을 어떻게 묘사해야 할지 난처할 것이다. 우리는 오직 그것이 평소에는 너무 자명해서 인식되지 않는 것들을 날카롭게 의식하게 해주기 때문에만 생각해볼 만한 가치가 있는 하나의 자연의 기이함(lusus naturae)과 마주하게 될 것이다.

따라서 하나의 법체계가 존재하기 위해 필요하고 충분한 최소 조건은 두 가지이다. 첫째, 그 법체계의 궁극적 유효성 기준들(ultimate criteria of validity)에

따라 유효한 것으로 간주되는 행위 규칙들(rules of behaviour)에는 일반적으로 복종이 이루어져야 한다. 둘째, 법적 유효성 기준들을 특정하는 승인 규칙들(rules of recognition)과 변경 규칙들(rules of change) 및 재판 규칙들(rules of adjudication)은, 해당 체계의 공무담당자들 사이에서 공무담당 행위의 공통된 공적 기준들(common public standards of official behaviour)로 실효적으로 수용되어야 한다. 첫 번째 조건은 일반 시민들이 만족시킬 필요가 있는(need) 유일한 조건이다: 그들은 각자 ‘자기 몫으로만’ 복종할 수 있으며, 그 동기는 어떠한 상관없다; 물론 건강한 사회에서는 실제로 많은 시민들이 이 규칙들을 공통의 행동 기준으로 수용하고, 그것들에 복종할 의무가 있음을 인정하거나(acknowledge), 심지어 이러한 의무를 (p. 117) 헌법을 존중할 보다 일반적인 의무로 거슬러 추적하기도 할 것이다. 두 번째 조건은 법체계의 공무담당자들이 반드시 만족시켜야 한다. 그들은 해당 규칙들을 공무담당 행위의 공통된 기준들(common standards of official behaviour)로 간주하고, 자기 자신과 동료들의 이탈(deviations)을 기준에서의 이탈(lapses)로 비판적으로 평가해야 한다. 물론 여기에 덧붙여, 공무담당자가 단지 개인적 행위능력(personal capacity)에서 복종하기만 하면 되는 일차 규칙들도 많다는 점은 사실이다.

따라서 “법체계가 존재한다”는 단언은 이중적인 얼굴을 가진(Janus-faced) 진술이다. 한편으로는 일반 시민들의 복종을, 다른 한편으로는 공무담당자들이 이차 규칙들을 공무담당 행위의 비판적 공통 기준들(critical common standards of official behaviour)으로 수용하는 것을 함께 가리킨다. 이러한 이중성에 놀랄 필요는 없다. 이것은 단지 법체계의 복합적 성격(composite character)—즉 단순하고 분권적인 전법적 사회 구조와 대비되는—을 반영하는 것일 뿐이다. 단지 일차 규칙들만으로 구성된 더 단순한 사회 구조에서는, 공무담당자가 존재하지 않기에, 해당 규칙들은 집단의 행위에 대한 비판적 기준으로서 널리 수용되어야 한다. 만약 그러한 경우에 내부 관점(internal point of view)이 널리 퍼져 있지 않다면, 논리적으로 규칙이 존재할 수 없다. 하지만, 우리가 주장해온 바와 같이, 법체계를 이해하는 가장 유익한 방식은 일차 규칙들과 이차 규칙들의 결합(union of primary and secondary rules)으로 보는 것이며, 이 경우 집단 전체의 공통 기준으로서 규칙을 수용하는 일은, 일반 개인이 자신 몫으로 복종함으

로써 그 규칙에 묵인하는 비교적 수동적인 태도와 분리될 수 있다. 극단적인 경우에는, 법적 언어의 특유의 규범적 사용(예: “이것은 유효한 규칙이다”)을 포함한 내부 관점이 오직 공무담당 세계 내부에만 존재할 수도 있다. 이처럼 보다 복잡한 체계에서는, 오직 공무담당자들만이 법적 유효성에 대한 체계의 기준들을 수용하고 사용할 수 있다. 그러한 사회는 비참할 만큼 양처럼 순응적인 (sheeplike) 사회일 수 있고, 결국 도살장으로 향하게 될지도 모른다. 하지만 그 사회가 실제로 존재할 수 없다고 보거나, 그것이 법체계라는 명칭을 가질 수 없다고 단정할 이유는 별로 없다.

3. 법체계의 병리학(THE PATHOLOGY OF A LEGAL SYSTEM)

따라서 법체계의 존재에 대한 증거는 사회생활의 두 가지 서로 다른 영역으로부터 도출되어야 한다. 우리가 법체계가 존재한다고 확신을 가지고 말할 수 있는 정상적이고 문제없는 경우란, 바로 이 두 영역이 (p. 118) 법에 대한 각자의 전형적인 관심사에 있어서 서로 일치(congruent)하고 있음이 분명한 경우이다. 거칠게 말하면, 사실관계는 다음과 같다. 즉, 공무담당자 수준에서 유효한 것으로 인정되는 규칙들에 일반적으로 복종이 이루어진다. 그러나 때로는 공무담당 영역이 사적 영역으로부터 분리될(detached) 수 있는데, 이는 법원에서 사용되고 있는 유효성 기준들(criteria of validity)에 따라 유효한 규칙들에 더 이상 일반적 복종이 존재하지 않는다는 의미에서 그러하다. 이러한 상황이 발생하는 다양한 방식들은 법체계의 병리(pathology of legal systems)에 속한다. 왜냐하면 그것들은, 우리가 법체계가 존재한다는 외부 사실 진술(external statement of fact)을 할 때 지칭되는(referred to) 복합적이고 상호 일치적인 실천의 붕괴를 나타내기 때문이다. 여기에는, 특정한 체계 내부로부터 법에 관한 내부 진술을 할 때마다 전제(presupposed)되는 것의 부분적 실패가 존재한다. 이러한 붕괴는 서로 다른 교란 요인들의 산물일 수 있다. 집단 내부에서 통치에 대한 경쟁적 주장들이 제기되는 ‘혁명(revolution)’은 그 한 사례에 불과하며, 이는 언제나 기존 체계의 일부 법들의 위반을 수반하겠지만, 새로운 헌법이나 새로운 법체계가 아니라 단지 공무담당자들을 새로운 개인 집합으로 법적 권한 없이 대체하는 것만을

수반할 수도 있다. 기존 체계 하에서의 권한 없이 외부로부터 통치에 대한 경쟁적 주장이 제기되는 적군 점령(enemy occupation)도 또 하나의 사례이며, 통치에 대한 정치적 주장조차 없이 무정부 상태나 도적 행위에 직면하여 질서 있는 법적 통제가 단순히 붕괴되는 경우 역시 또 다른 사례이다.

이러한 각각의 경우에서, 법원이 해당 영토에서든 망명 상태에서든 기능하면서, 한때 안정적으로 확립된 옛 체계의 유효성 기준을 여전히 사용하는 중간 단계들(half-way stages)이 있을 수 있다. 그러나 이러한 법질서들은 해당 영토에서 실효적이지 않다. 이러한 경우에 “법체계가 완전히 소멸되었다”고 말할 수 있는 시점은, 어떤 정확한 확정(exact determination)도 허용하지 않는 사안이다. 명백하게, 복구될 상당한 가망(chance)이 있거나, 기존 체계의 혼란이 결과가 아직 확정되지 않은 전면적 전쟁의 일부 사건일 경우에는, 그 체계가 더 이상 존재하지 않는다는 무조건적 단언(assertion)은 정당화될 수 없다. 이는 바로 “법체계가 존재한다”는 진술(statement)이 중단을 허용할 만큼 충분히 폭넓고 일반적인 유형이기 때문이다. 이 진술은 짧은 시간 동안 일어나는 일들에 의해 검증되거나 반증되는 것이 아니다.

물론 이러한 중단 이후에 법원과 인구 간의 정상적인 (p. 119) 관계가 회복된 뒤에는 어려운 질문들이 제기될 수 있다. 점령군의 축출이나 반란 정부의 패배 이후 망명 정부가 귀환하면, 그 중단의 시기에 해당 영토에서 무엇이 ‘법’이었는지, 혹은 무엇이 아니었는지에 대한 질문들이 생긴다. 여기서 가장 중요한 점은, 이 질문이 사실(fact)의 문제가 아닐 수도 있다는 점이다. 만약 그것이 사실의 문제라면, 해당 중단이 너무나 장기적이고 완전했기 때문에 기존 법체계가 소멸되었고 망명 귀환 시 유사한 새로운 체계가 수립되었다고 기술해야 하는지를 묻는 방식으로 확정되어야(settled) 할 것이다. 그러나 실제로는 이 질문은 국제법상의 문제로 제기되거나, 다소 역설적으로, 복귀 이후 존재하게 된 바로 그 법체계 내부의 법 문제로 제기될 수 있다. 후자의 경우, 복귀한 체계가, 그 체계가 계속해서 해당 영토의 법이었다고 소급적으로 선언하는 법을 포함할 수도 있다—혹은 좀 더 솔직히 말해, 그 체계가 해당 시기 동안 법이었던 것으로 간주된다(deemed)고 선언할 수 있다. 이러한 선언은, 그 중단 기간이 사실 문제로 취급되었을 경우 도달했을 결론과는 상당히 불일치해 보일 수 있음에도

불구하고, 그렇게 이루어질 수 있다. 그런 경우에, 해당 선언은 중단 기간 중 발생한 사건들과 거래들에 대해 법원이 적용해야 할 법을 정하는 복귀 체계의 하나의 규칙으로서, 얼마든지 존립할(stand) 수 있다.

여기에 역설이 있는 것은 오직, 법체계가 스스로의 과거, 현재, 또는 미래의 존재 단계로 간주되어야 하는 것에 관하여 내리는 법 진술들(statements of law)을, 외부 관점에서 제시되는 그 존재에 대한 사실 진술과 경쟁하는(rivals) 것으로 생각할 때뿐이다. 자기-참조(self-reference)의 겉보기 수수께끼를 제외하면, 어떤 현행 체계 안에서 그 체계가 존재한 것으로 간주되어야 하는 기간에 관한 규정의 법적 지위는, 한 체계의 법이 다른 나라에 어떤 체계가 아직 존재한다고 선언하는 경우와 다르지 않다. 물론 후자의 경우 실천적 귀결이 많을 개연성은 높지 않다. 예를 들어, 우리는 소련 영토에서 현재 존재하는 법체계가 사실상 차르 체제의 법체계가 아니라는 점을 분명히 알고 있다. 그러나 만약 영국 의회의 제정법(statute)이 차르 시대 러시아의 법이 여전히 러시아 영토의 법이라고 선언한다면, 이 제정법은 소련(USSR)에 관한 영국법의 일부로서 기실 의미와 법적 효과를 가질 것이다. (p. 120) 그러나 이는 직전 문장에 담긴 사실 진술의 참임에 전혀 영향을 미치지 않는다. 그 제정법의 효력(force)과 의미는, 영국 법원이 적용할 법을 규정하고, 그 결과로 영국 내에서 러시아와 관련된 사안에 적용될 법을 정하는 것에 있을 뿐이다.

방금 서술한 상황의 역상황(converse)은, 새로운 법체계가 옛 법체계의 자궁으로부터—때로는 제왕절개(Caesarian operation)를 거친 뒤에야—출현하는 매혹적인 전환기의 순간들에서 볼 수 있다. 영연방(Commonwealth)의 최근 역사는 법체계 발생론(embryology of legal systems)의 이러한 측면을 연구하기에 훌륭한 장(場)을 제공한다. 이 발전 과정을 도식적이고 단순화하여 개관하면 다음과 같다. 한 시기의 초기에 우리는 지방 입법부(local legislature), 사법부(judiciary), 행정부(executive)를 갖춘 식민지를 발견할 수 있다. 이러한 헌정 구조는 영국 의회(United Kingdom Parliament)의 제정법에 의해 설정된 것으로, 영국 의회는 식민지에 대해 입법할 완전한 법적 권능(legal competence)을 보유하고 있다. 여기에는 지방 법들(local laws)뿐 아니라, 식민지 헌법에 관한(referring to) 제정법들을 포함하여, 자기 자신의 제정법들(statutes)을 개정하

거나 폐지할 권한도 포함된다. 이 단계에서 식민지의 법체계는, 의회 내 여왕(Queen in Parliament)이 제정하는(enact) 것은 (다른 것들 중에서도(inter alia)) 식민지에 대하여 법이다라는 궁극적 승인 규칙(rule of recognition)에 의해 특징지어지는 더 넓은 체계의 명백한 종속된(subordinate) 부분이다. 발전 단계의 말미에 이르면, 궁극적 승인 규칙이 전환되었음(shift)을 확인하게 되는데, 이는 웨스트민스터 의회(Westminster Parliament)가 옛 식민지에 대해 입법할 법적 권능(legal competence)이 더 이상 그곳의 법원들에서 인정되지 않기 때문이다. 옛 식민지의 헌정 구조 상당 부분이 여전히 웨스트민스터 의회의 원래 제정법(statute)에서 발견된다는 점은 여전히 사실이다. 그러나 이는 이제 단지 역사적 사실에 불과하며, 그것은 더 이상 해당 영토에서의 현재적 법적 지위를 웨스트민스터 의회의 권위에 빚지고 있지 않다. 옛 식민지의 법체계는 이제 ‘지역적 뿌리(local root)’를 가지게 되는데, 이는 법적 유효성의 궁극적 기준들을 특징하는 승인 규칙이 더 이상 다른 영토의 입법부가 제정한 것들(enactments)을 참조(refer)하지 않기 때문이다. 새로운 규칙은, 그것이 해당 지역 체계의 사법적 및 기타 공무원당 작용에서 그러한 규칙으로 수용되고 사용된다는 사실에 단순히 기초해 있다. 이 지역 체계의 규칙들에는 일반적으로 복종이 이루어진다. 따라서 비록 지방 입법부의 구성, 제정 방식, 구조가 여전히 원래 헌법에서 규정된 바와 동일할 수 있다 하더라도, 그 제정물들(enactments)이 현재 유효한 것은 (p. 121) 더 이상 웨스트민스터 의회의 유효한 제정법(statute)이 부여한 권한들의 행사이기 때문이 아니다. 그것들은, 지역적으로 수용된 승인 규칙에 따라, 지방 입법부의 제정이 유효성의 궁극적 기준이기 때문에 유효한 것이다.

이러한 발전은 여러 방식으로 달성될 수 있다. 모국 입법부는 일정 기간 동안 사실상 식민지의 동의 없이는 식민지에 대한 자신의 형식적 입법 권위(formal legislative authority)를 행사하지 않다가, 마침내 해당 옛 식민지에 대한 입법 권한을 포기함으로써 무대에서 퇴장할 수 있다. 이때 주목할 점은, 웨스트민스터 의회가 이와 같이 스스로의 권한들을 불가역적으로 줄일(cut down) 법적 권능(legal competence)을 가지고 있는지를 영국 법원이 인정할지에 대해 이론적인 의문이 존재한다는 것이다. 반대로, 이러한 단절은 폭력을 통해서만 이루어질 수도 있다. 그러나 어느 경우이든, 이 발전의 말미에는 두 개의 독립된

법체계가 존재하게 된다. 이것은 하나의 사실 진술(factual statement)이며, 비록 그것이 법체계의 존재에 관한 것이라 할지라도, 그렇다고 해서 덜 사실적인 것은 아니다. 이에 대한 주된 증거는, 이전 식민지에서는 현재 수용되고 사용되는 궁극적 승인 규칙이 더 이상 타 지역의 입법부 작용에 대한 어떠한 참조도 유효성 기준들 가운데 포함하지 않는다는 사실이다.

그런데 다시, 영연방(Commonwealth)의 역사에서 흥미로운 사례들이 보여 주듯이, 사실상 식민지의 법체계가 이제 모국으로부터 독립되었음에도 불구하고, 모국의 법체계는 이 사실을 인정하지 않을 수도 있다. 웨스트민스터 의회가 식민지에 대해 입법할 권한을 보유하고 있거나 법적으로 되찾을 수 있다는 것이 여전히 영국법의 일부일 수 있으며, 실제로 그러한 경우에, 만약 웨스트민스터 제정법(Westminster statute)과 현지 입법부의 법 하나가 충돌하는 사건이 영국 국내 법원에 회부된다면, 영국 법원은 이 사태에 대한 이러한 관점에 효력을 부여할 수도 있다(give effect). 이 경우, 영국법명제들(propositions of English law)은 사실과 충돌하는 듯 보인다. 식민지의 법은 사실상 독립된 법체계이며, 자체의 지역적 궁극적 승인 규칙을 가진 체계인데, 영국 법원은 이를 사실상 그러한 바로 그것으로 인정하지 않는다(not). 사실상은 두 개의 법체계가 존재하지만, 영국법은 오직 하나만 존재한다고 고집한다(insist). 그러나, 한쪽 단언은 사실 진술(statement of fact)이고 다른 쪽은 (영국)법명제(proposition of law)이기 때문에, 이 둘은 논리적으로 충돌하지 않는다. 이 입장을 명확히 하기 위해, 우리는 사실 진술이 참이며(true), 영국법명제는 “영국법상 올바른(correct in English law)” 것이라고 말할 수 있다. (p. 122) 이러한 독립된 법체계의 존재 여부에 대한 사실적 단언(또는 부정)과 법체계의 존재에 관한 법명제들 간의 구별은, 국제공법과 국내법 사이의 관계를 논할 때에도 반드시 유념해야 한다. 어떤 매우 기이한 이론들이 그럴듯해 보이는 유일한 이유는 이 구별을 무시하기 때문이다.

이러한 법체계의 병리학(pathology)과 발생학(embryology)에 대한 거친 개관을 마무리하려면, 이제 우리는, “하나의 법체계가 존재한다”는 무조건적 단언(assertion)에 의해 그 일치(congruence)가 단언되는 정상 조건들이 부분적으로 실패하는 다른 형태들도 주목해야 한다. 법체계 내부에서 법에 대한 내부 진술이

행해질 때 일반적으로 전제되는, 공무담당자들 사이의 통일성(unity)은 부분적으로 붕괴될 수 있다. 헌법적 문제들—그리고 오직 그 문제들에 한해서—에 대해, 공무담당 세계 내부에서 분열이 발생하고 궁극적으로 사법부 내부의 분열로 이어질 수 있다. 법을 식별하는 데 사용되는 궁극적 기준들에 대한 이러한 분열의 시작은 1954년 남아프리카 공화국에서 발생한 헌법적 위기에서 볼 수 있었으며, 이는 *Harris* 대 *Dönges* 사건으로 법원에 회부되었다. 여기서 입법부는 자신이 보유한 법적 권능(legal competence)과 권한들(powers)에 대해 법원과 다른 견해를 취하며 입법 조치들을 제정하였고, 법원은 그 조치들을 유효하지 않다고(invalid) 선언하였다. 이에 대한 대응으로 입법부는, 입법부의 제정물들(enactments)을 유효하지 않게 한 통상 법원들의 판결들에 대해 항소가 제기될 수 있도록 특별 항소 ‘법원’을 창설하였다. 이 법원은 실제로 그러한 항소를 심리하고 통상 법원들의 판결들을 번복했으며, 다시 통상 법원들은 그 특별 법원들을 창설한 입법을 유효하지 않다고 선언하고 해당 판결들을 법적으로 무효(nullity)라고 판시하였다. 이 절차가 중단되지 않았더라면(정부가 자신의 뜻을 관철하는 이 수단을 계속 추구하는 것이 지해롭지 못하다고 판단했기 때문에 중단되었다), 우리는 입법부의 권능(competence)과 그에 따라 유효한 법의 기준들에 대한 두 견해 사이에서 무한 반복되는 진동 현상을 보았을 것이다. 법체계의 승인 규칙을 식별하는 것이 오직 그 조건 아래에서만 가능한 공무담당자들 사이의—특히 사법적—조화라는 정상 조건은 일시적으로 정지되었을 것이다. 그럼에도 불구하고, 이 헌법적 문제와 직접적으로 관련되지 않은 대부분의 법적 작용들은 이전과 마찬가지로 계속되었을 것이다. 인구가 분열되고, ‘법과 질서’가 (p. 123) 붕괴되기 전까지는, 원래의 법체계가 소멸했다고 말하는 것은 오해를 불러올 수 있다. 왜냐하면 ‘동일한 법체계(same legal system)’라는 표현은 너무 넓고 유연하기 때문에, 유효한 법의 모든(all) 원래 기준들에 대한 공무담당자들의 통일적 합의가 유지되는 것을 그 법체계가 ‘동일한 것’으로 남아 있기 위한 필요조건으로 삼을 수는 없기 때문이다. 우리가 할 수 있는 일은 지금까지 기술해온 방식대로 해당 상황을 설명하고, 그것을 하나의 표준 이하(substandard), 비정상적인 사례로 기록해 두는 것이다. 이 사례는 그 속에 법체계가 해체될(dissolve) 수 있는 잠재적 위협을 품고 있다.

이 마지막 사례는, 우리가 다음 장에서 논의하게 될 보다 넓은 주제의 경계로 우리를 이끈다. 이는 법체계의 궁극적 유효성 기준이라는 중대한 헌법적 사안(high constitutional matter)과, 그 법체계의 ‘일상적(ordinary)’ 법 양자 모두와 관련된다. 모든 규칙에는 특정 사례들을 일반적 용어의 사례로 식별하거나 분류하는 과정이 포함되며, 우리가 어떤 것을 규칙(rule)이라고 부를 준비가 되어 있는 모든 경우에 있어서, 해당 규칙이 분명히 적용되는 명확한 중심 사례들과, 그 적용 여부를 단언할 이유와 부정할 이유가 모두 존재하는 경계 사례들을 구별하는 것이 가능하다. 우리가 구체적인 상황들을 일반 규칙 아래로 포섭할 때, 이와 같은 확실성의 핵심(core of certainty)과 의문의 반음영(penumbra of doubt)이라는 이중성은 결코 제거될 수 없다. 이로 인해 모든 규칙에는 모호함의 가장자리(fringe), 곧 ‘개방적 직조(open texture)’가 부여되며, 이는 법을 식별하는 데 사용되는 궁극적 기준들을 명시하는 승인 규칙(rule of recognition)에도, 하나의 특정한 제정법(statute)에도 마찬가지로 영향을 미칠 수 있다. 법의 이러한 측면은 흔히, 규칙이라는 틀로 법 개념을 해명하려는 시도가 오해를 낳을 수 있다는 점을 보여주는 것으로 여겨진다. 상황의 현실에도 불구하고 이를 고수하는 것은 흔히 ‘개념주의(conceptualism)’나 ‘형식주의(formalism)’라는 낙인이 찍히곤 한다. 우리는 이제 이와 같은 비판을 평가하는 논의로 넘어가게 될 것이다.

제6장 주석

100쪽. 승인 규칙(rule of recognition)과 켈젠(Kelsen)의 ‘기초규범(basic norm)’ . 본서의 중심 논제 중 하나는, 법체계의 토대들은 법적으로 무제한인 주권자에 대한 일반적 복종 습관(habit of obedience)에 있는 것이 아니라, 그 체계의 유효한 규칙들을 식별하는 권위 있는 기준들을 제공하는 궁극적 승인 규칙(ultimate rule of recognition)에 있다는 것이다. 이 논제는 켈젠의 기초규범(basic norm) 구상과 일정 부분 유사하며, 더 나아가서는 셀몬드(Salmond)의 충분히 전개되지 않은 ‘궁극적 법 원칙들(ultimate legal principles)’ 구상과도 가깝다(켈젠, *General Theory*, pp. 110–124, 131–134, 369–373, 395–396 참조; 셀몬드, *Jurisprudence*, 11판, p. 137 및 부록 I 참조). 그러나 본서는 켈젠과는 다른 용어 체계를 채택하였으며, 그 이유는 아래의 주요한 점들에서 본서의 입장이 켈젠과 다르기 때문이다.

1. 승인 규칙이 존재하는지, 또 그것의 내용—즉 주어진 법체계에서의 유효성 기준들(criteria of validity)—이 무엇인지는, 본서 전반에서 경험적이면서도 복합적인 사실 문제(question of fact)로 간주된다. 이는 다음의 점이 사실이라든가 마찬가지이다: 즉, 법체계 안에서 활동하는 법률가가 어떤 특정 규칙이 유효하다고 단언할(assert) 때, 그는 그 특정 규칙의 유효성을 검사하기 위해 참조한 승인 규칙이 그 체계의 수용된 승인 규칙으로서 존재한다는 사실을 명시적으로 진술하지는 않지만(explicitly state) 암묵적으로 전제한다(tacitly presupposes). 만약 이 점에 대해 이의가 제기된다면, 이처럼 전제되었지만 진술되지 않은 것은 사실들에 호소함으로써, 즉 적용해야 할 법을 식별할 때 그 체계의 법원들과 공무원들이 보이는 실제 실천에 호소함으로써 확립될 수 있다. 켈젠이 기초규범을 ‘법리학적 가설(juristic hypothesis)’ (*ibid.* xv), ‘가설적(hypothetical)’ (*ibid.* 396), ‘상정된 궁극 규칙(postulated ultimate rule)’ (*ibid.* 113), ‘법리학적 의식 내에 존재하는 규칙(rule existing in the juristic consciousness)’ (*ibid.* 116), ‘가정(an assumption)’ (*ibid.* 396) 등으로 분류하는 용어는, 이 책에서 강조되는 요점, 곧 “어떤 법체계에서 법적 유효성의 기준들이 무엇인가” 라는 물음이 사실 문제라는 요점을 흐리게 하며, 실제로 그 요점과 양립하지 않을 수도 있다. 그것은 사실 문제이지만, 하나의 규칙의 존재와 내용에 관한(about) 문제이다. Cf. 아고(Ago), “Positive Law and International Law,” *American Journal of International Law* 제51권 (1957), pp. 703–707.

2. 켈젠은 기초규범의 유효성(validity)을 전제한다고 말한다. 그러나 본문(pp. 108–

110)에서 제시된 이유에 따르면, 일반적으로 수용된 승인 규칙에 관해 그 존재 여부와는 별도로 그 유효성 또는 비유효성(invalidity)을 묻는 것은 부적절하며, 그런 질문 자체가 성립할 수 없다.

3. 켈젠의 기초규범은 어떤 의미에서는 언제나 동일한 내용을 갖는다. 왜냐하면 그것은 모든 법체계에서 단지 “헌법 또는 ‘최초의 헌법을 정한 자들’에게 복종해야 한다”는 규칙이기 때문이다(*General Theory*, pp. 115–116). 그러나 이러한 일양성과 단순성의 외관은 오해를 낳을 수 있다. 만약 하나의 헌법이 법의 다양한 원천들(sources of law)을 명시하며, 그 법체계 내의 법원들과 공무원당자들이 실제로 그 헌법이 제공하는 기준들에 따라 법을 식별한다는 의미에서 살아있는 현실(living reality)이라면, 그러한 헌법은 수용된 것이며 실제로 존재하는 것이다. 이런 경우, 헌법 또는 그것을 ‘정한’ 자들에게 복종해야 한다는 별도의 규칙이 존재한다고 말하는 것은 불필요한 중복처럼 보인다. 특히, 영국처럼 성문 헌법이 존재하지 않는 경우에는 더욱 그렇다. 이 경우, 법을 식별할 때 특정한 유효성 기준들, 예컨대 의회 내 여왕에 의한 제정이 사용되어야 한다는 규칙에 덧붙여 ‘헌법에 복종해야 한다’는 규칙이 자리할 곳은 없어 보인다. 이 규칙 자체가 수용된 규칙이며, 이 규칙에 복종해야 한다는 규칙을 말하는 것은 신비화할 뿐이다.

4. 켈젠의 견해에 따르면(*General Theory*, pp. 373–375, 408–410), 특정한 법규칙을 유효한 것으로 간주하면서 동시에 그 법규칙이 요구하는 행위를 금지하는 도덕규칙을 도덕적으로 구속력 있는 것으로 수용하는 것은 논리적으로 불가능하다. 그러나 본서에서 제시한 법적 유효성에 대한 설명에서는 그러한 결과가 전혀 도출되지 않는다. ‘기초(basic) 규범’이라는 표현 대신 ‘승인 규칙(rule of recognition)’이라는 표현을 사용하는 이유 중 하나는, 법과 도덕 사이의 충돌에 관한 켈젠의 견해를 따를 어떤 입장도 전제하지 않기 위함이다.

101쪽. 법의 원천들(sources of law). 일부 저자들은 법들의 ‘형식적(formal)’ 또는 ‘법적(legal)’ 원천들과 ‘역사적(historical)’ 또는 ‘실질적(material)’ 원천들을 구분한다(Salmond, *Jurisprudence*, 11판, 제5장). Allen은 이 구분을 비판하지만(*Law in the Making*, 6판, p. 260), 이를 ‘원천(source)’이라는 단어의 두 가지 의미의 구분으로 해석하면 이 구분은 중요한 것이다(Kelsen, *General Theory*, pp. 131–132, 152–153 참조). 한 의미에서(즉 ‘실질적(material)’, ‘역사적(historical)’ 의미에서) 원천이란, 특정한 시간과 장소에서 주어진 법규칙이 존재하게 된 원인적 또는 역사적 영향력들을 의미한다. 이 의미에서 현대 영국법의 특정 규칙들의 원천은 로마법 규칙일 수도 있고, 교회법

규칙이나 심지어 대중 도덕 규칙일 수도 있다. 그러나 ‘제정법(statute)’이 법의 원천이라고 말할 때, ‘원천(source)’이라는 단어는 단순한 역사적·인과적 영향력이 아니라, 문제의 법체계에서 수용된 법적 유효성의 기준들(criteria of legal validity) 중 하나를 가리킨다. 권능을 가진 입법부(competent legislature)에 의해 제정법으로 제정되었다는 점은, 주어진 제정법 규칙(statutory rule)이 단순히 존재하게 된 원인(cause)이 아니라 그것이 유효한 법(valid law)인 이유(reason)이다. 주어진 법규칙의 역사적 원인과 그 유효성의 이유 사이의 이러한 구분은, 입법부에 의한 제정, 관습적 실천, 선례 등을 유효한 법의 식별 표지들(identifying marks)로 수용하는 승인 규칙(rule of recognition)이 체계 내에 존재할 때만 가능하다.

그러나 실제 실천에서는 역사적 또는 인과적 원천들과 법적 또는 형식적 원천들 간의 이 분명한 구분이 흐려질 수 있으며, Allen과 같은 저자들이 이 구분을 비판하게 된 것도 바로 이 점 때문이다. 어떤 체계에서 제정법(statute)이 법의 형식적 또는 법적 원천인 경우, 법원은 사건을 결정하면서 관련 제정법에 주의를 기울여야 할 구속을 받지만, 물론 제정법 문언의 의미를 해석하는 데 상당한 자유가 남겨져 있기는 하다(제7장 제1절 참조). 그러나 때때로 판사에게 남겨지는 것은 해석의 자유보다 훨씬 더 크다. 즉, 자기 앞의 사건을 결정하는 제정법이나 법의 다른 형식적 원천이 없다고 판단할 경우, 그는 예컨대 학설휘찬(Digest)의 한 문헌이나 프랑스 법학자의 저술에 자기 결정을 근거지을 수도 있다(예: Allen, *op. cit.*, p. 260 이하 참조). 해당 법체계가 그러한 원천들을 사용하라고 그에게 요구하는(require) 것은 아니지만, 그가 그렇게 하는 것은 완전히 적절한 것으로 수용된다. 그러므로 이러한 저술들은 단순한 역사적 또는 인과적 영향력 이상이다. 그러한 저술들은 결정들을 위한 ‘좋은 이유들(good reasons)’로 인정되기 때문이다. 아마도 우리는 이러한 원천들을, 제정법과 같은 ‘구속적(mandatory)’ 법적 또는 형식적 원천들과 역사적 또는 실질적 원천들 양자와 구별하기 위해, ‘허용적(permissive) 법적 원천들’이라고 부를 수 있을 것이다.

103쪽. 법적 유효성과 실효성(Legal validity and efficacy). 켈젠은 전체적으로 실효적인 법질서의 실효성과 개별 규범의 실효성을 구분한다(*General Theory*, pp. 41-2, 118-22). 그에게 있어 하나의 규범이 유효하다는 것은, 만약 그리고 오직 그 경우에만(if, and only if), 그것이 전반적으로(on the whole) 실효적인 체계에 속할 때이다. 그는 이 견해를 좀 더 난해하게 다음과 같이 표현하기도 한다. 즉, 체계 전체의 실효성은 그 체계의 규칙 유효성에 대한 필요조건(conditio sine qua non)이지, 충분조건(conditio per quam)은 아니라고 말한다(*sed quaere*). 이 구분의 요점은 본서의 용어로 다음과 같이 정리될 수 있다. 법체계의 일반적인 실효성은 승인 규칙(rule of recognition)이 제공하는 유효성

기준은 아니지만, 체계 내의 어떤 규칙이 그 유효성 기준들을 참조하여 그 체계의 유효한 규칙으로 식별될 때마다 언제나 암묵적으로 전제되며 명시적으로 진술되지는 않는다. 그리고 체계가 일반적으로 실효성을 갖추고 있지 않다면, 유효성에 관한 의미 있는 진술 자체가 불가능해진다. 본문의 입장은 이 점에서 켈젠과 다르다. 여기서는 체계의 실효성이 유효성 진술이 이루어지는 정상적 맥락(normal context)이긴 하지만, 특별한 상황에서는 그 체계가 더 이상 실효적이지 않더라도 유효성 진술이 여전히 의미를 가질 수 있다고 논변되기 때문이다(ante, p. 104 참조).

켈젠은 또한 불사용에 의한 폐지(desuetudo) 항목에서, 하나의 법체계가 특정 규칙의 유효성을 그 규칙의 지속적인 실효성에 의존하도록 할 가능성에 대해서도 논의한다. 이러한 경우, (개별 규칙의) 실효성은 체계의 유효성 기준 중 하나가 되며, 단순한 ‘전제(presupposition)’는 아니다(op. cit., pp. 119-22).

104쪽. 유효성과 예측(Validity and prediction). 법이 유효하다는 진술은 미래의 사법적 행위와 그에 따른 특유의 동기 부여 감정에 대한 예측이라는 견해에 대해서는 Ross, *On Law and Justice*, 제1장 및 제2장 참조. 이에 대한 비판은 Hart, ‘Scandinavian Realism’ (*Cambridge Law Journal*, 1959년)을 보라.

106쪽. 개정권이 제한된 헌법(Constitutions with limited amending powers). 서독과 터키의 사례는 제4장 주석(ante, p. 290)을 참조하라.

111쪽. 관행적 범주와 헌정 구조(Conventional categories and constitutional structures). ‘법(law)’과 ‘관행(convention)’으로의 전부를 포괄한다고 주장되는 구분에 대해서는 Dicey, *Law of the Constitution*, 10판, pp. 23 이하; Wheare, *Modern Constitutions*, 제1장 참조.

111쪽. 승인 규칙(rule of recognition): 법인가 사실인가? 정치적 사실로 분류할 것인지에 대한 찬반 논증은 Wade, ‘The Basis of Legal Sovereignty’, *Cambridge Law Journal* (1955), 특히 p. 189, 그리고 Marshall, *Parliamentary Sovereignty and the Commonwealth*, pp. 43-46을 참조하라.

112쪽. 법체계의 존재, 습관적 복종, 승인 규칙의 수용(The existence of a legal system, habitual obedience, and the acceptance of the rule of recognition). 일반 시민의 복종과 공무원당자들 쪽에서의 헌정 규칙 수용을 모두 포함하는 복합적 사회 현상을 지나치게 단순화할 위험에 대해서는 제4장 제1절, pp. 60-61 및 Hughes, ‘The Existence of a Legal System’, 35 *New York University LR* (1960), p. 1010 참조. Hughes는 이 점에서 Hart가 ‘Legal and Moral Obligation’ (*Essays in Moral Philosophy*, Melden 편, 1958)에서

사용한 용어를 정당하게 비판하고 있다.

118쪽. 법질서의 부분적 붕괴(Partial breakdown of legal order). 법체계가 완전히 정상적으로 존재하는 상태와 전혀 존재하지 않는 상태 사이의 많은 가능한 중간 상태들 중 극히 일부만이 본문에서 언급되었다. 혁명(revolution)에 대한 법적 관점에서의 논의는 Kelsen, *General Theory*, pp. 117 ff., 219 ff.를 참조하고, Cattaneo, *Il Concetto di Rivoluzione nella Scienza del Diritto* (1960)에서는 상세히 다루어진다. 적군 점령(enemy occupation)에 의한 법체계의 중단은 다양한 형태를 띌 수 있으며, 이 중 일부는 국제법상으로 범주화되어 있다. 이에 대해서는 McNair, 'Municipal Effects of Belligerent Occupation', 57 *LQR* (1941), 그리고 Goodhart, 'An Apology for Jurisprudence' (*Interpretations of Modern Legal Philosophies*, pp. 288 ff.)의 이론적 논의를 참조하라.

120쪽. 법체계의 발생학(The embryology of a legal system). Wheare, *The Statute of Westminster and Dominion Status*, 5판에서 추적되는 식민지에서 도미니언으로의 발전 과정은 법이론 연구에 보람 있는 분야이다. 또한 Latham, *The Law and the Commonwealth* (1949)을 참조하라. Latham은 영연방(Commonwealth)의 현정 발전을 '지역적 뿌리(local root)'를 가진 새로운 기초규범의 성장이라는 관점에서 최초로 해석하였다. 또한 Marshall, 앞서 인용한 저서, 특히 캐나다에 대한 제7장을 참고하고, Wheare, *The Constitutional Structure of the Commonwealth* (1960), 제4장 '자생성(Autochthony)'도 참고하라.

121쪽. 입법 권한의 포기(Renunciation of legislative power). 웨스트민스터 제정법(Statute of Westminster) 제4조의 법적 효력에 대한 논의는 Wheare, *The Statute of Westminster and Dominion Status*, 5th edn., pp. 297-8을 참조하라. 또한 *British Coal Corporation v. The King* (1935), AC 500; Dixon, 'The Law and the Constitution', 51 *LQR* (1935); Marshall, 앞서 인용한 저서, pp. 146 ff.; 그리고 제7장 제4절도 함께 보라.

121쪽. 모국 체계에 의해 인정되지 않은 독립(Independence not recognized by the parent system). 아일랜드 자유국(Irish Free State)에 대한 논의는 Wheare, 앞서 인용한 저서 참조; *Moore v. AG for the Irish Free State* (1935), AC 484; *Ryan v. Lennon* (1935), IRR 170 참조.

121쪽. 법체계의 존재에 관한 사실적 단언들과 법 진술들(Factual assertions and statements of law concerning the existence of a legal system). Kelsen은 국내법과 국제법 사이의 가능한 관계들('국가법의 우위성 또는 국제법의 우위성')에 대한 자신의 설명(op. cit., pp. 373-83)에서, 법체계가 존재한다는 진술은 반드시 한 법체계의 관점에서

다른 법체계에 대해, 그 다른 체계를 ‘유효한(valid)’ 것으로 그리고 자기 자신과 하나의 단일 체계를 형성하는 것으로 수용하면서 행해지는 법 진술(statement of law)이어야 한다고 전제한다. 이에 반해 상식적 견해에서는 국내법과 국제법이 별개의 법체계들을 구성한다고 보며, 어떤 법체계(국가적이든 국제적이든)가 존재한다는 진술을 사실 진술(statement of fact)로 취급한다. Kelsen에게는 이러한 견해가 용납될 수 없는 ‘다원주의(pluralism)’ 이다(Kelsen, loc. cit.; Jones, ‘The “Pure” Theory of International Law’, 16 BYBIL 1935 참조). 또한 Hart, ‘Kelsen’s Doctrine of the Unity of Law’, *Ethics and Social Justice, Contemporary Philosophical Thought*, vol. 4 (New York, 1970) 참조.

122쪽. 남아프리카(South Africa). 남아프리카 헌정 위기에서 배울 수 있는 중요한 법리학적 교훈을 보다 심층적으로 검토하려면, Marshall, 앞서 인용한 저서, 제11장을 참조하라.

제6장 제3판 주석

100-1쪽. 법의 원천들(Sources of law). 법이 원천들(sources)을 가진다는 관념의 이론적 중요성에 대해서는 Joseph Raz, *The Authority of Law*, chap. 3을 보라. 보통법(common law)과 관습(custom)을 법의 원천들로 다룬 논의는 Gerald J. Postema, *Bentham and the Common Law Tradition* (Oxford University Press, 1986) 및 John Gardner, ‘Some Types of Law’, 그의 저서 *Law as a Leap of Faith* 제3장을 참조하라.

Hart의 승인 규칙(rule of recognition) 구상(conception)에 대한 비판은 Joseph Raz, *The Concept of a Legal System*, chap. 8, 특히 pp. 197-200; Joseph Raz, *The Authority of Law*, chap. 5, 특히 pp. 90-97; Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, pp. 39-45, 62-68을 참조하라. 승인 규칙을 의미론적 교설로 해석한 그의 견해는 Ronald Dworkin, *Law’s Empire*, pp. 31-35에서 볼 수 있다.

101-3쪽. 승인 규칙과 법원들의 실천(The rule of recognition and the practice of the courts). Hart에게서 궁극적 승인 규칙들(ultimate rules of recognition)은 공무담당자들의 관습적 실천들 속에 내재한다. 그런데 공무담당자란 법에 의해 그렇게 식별되는 사람이라면, 순환성이 다가오는 것처럼 보일 수 있다. 즉, 어떤 것이 법인 것은 오직 그것이 승인 규칙에 의해 식별되는 경우뿐이고, 어떤 것이 승인 규칙인 것은 오직 그것이 공무담당자들에 의해 실천되는 경우뿐이며, 어떤 사람이 공무담당자인 것은 오직 그가 법에 의해 그렇게 권한을 부여받은 경우뿐이라는 식이다. 이 문제의 해소 방안들(resolutions)에 관해서는 Neil MacCormick, *H. L. A. Hart*, pp. 108-120; Michael Bayles,

Hart's Legal Philosophy, pp. 81-83을 참조하라.

103-4쪽. 법적 유효성(Legal validity). Hart는 '유효성(validity)'을 주로 체계 소속(system membership)의 문제로 다룬다. 이에 대비되는 견해로는 Kelsen, *Pure Theory of Law*, pp. 10-15, 193-195가 있다. 그는 “‘유효한(valid)’은 그것이 구속력을 가진다는 것, 곧 한 개인이 그 규범이 정한 방식으로 행위해야 한다는 것을 의미한다”(p. 193)고 말한다. 법적 맥락들에서 '유효성(validity)'의 다양한 의미들(senses)에 대해서는 J. W. Harris, *Law and Legal Science: An Inquiry into the Concepts Legal Rule and Legal System* (Oxford University Press, 1979), chap. 4를 참조하라. Hart의 유효성 설명에 대한 평가는 Joseph Raz, *The Authority of Law*, chap. 8에 실려 있다. 유효성의 정도들(degrees of validity)이라는 가능성에 대해서는 John Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, pp. 276-281을 보라.

103-5쪽. 법의 실효성(The efficacy of law). Hart의 실효성 정의는 의무부과 규칙들(mandatory rules)에만 적용된다(“특정한 행위를 요구하는 법규칙이 대체로 복종된다는 사실”: p. 103). 그렇다면 허용적 규칙들(permissive rules) 혹은 권한-부여 규칙들(power-conferring rules)의 실효성은 어떻게 되는가? 이에 대해서는 Joseph Raz, *The Concept of a Legal System*, chap. 9; *The Authority of Law*, chap. 5, 특히 pp. 85-90을 참조하라. 또한 Gerald Postema, 'Conformity, Custom, and Congruence: Rethinking the Efficacy of Law', Matthew H. Kramer et al. 편, *The Legacy of H. L. A. Hart: Legal, Political, and Moral Philosophy* (Oxford University Press, 2008)도 함께 보라.

105-10쪽. 궁극적이고 최고인 승인 규칙(The rule of recognition as ultimate and supreme). Hart는 '승인 규칙(rule of recognition)'이라는 용어를 한 법체계 안의 다른 모든 규칙들의 유효성을 평가할 기준들을 제공하지만, 그 자체는 다른 어떤 규칙에 의해서도 유효화되지(validated) 않는 하나의 관습적 사회 규칙을 지칭하는 데 사용한다. 다음 사항에 유의하라.

- (1) 승인 규칙은 판사들과 기타 공무담당자들의 관습적 규칙이지, 법으로 제정된 것이 아니며 실정법(positive law)이 아니다. 특히, 그것은 형식적 헌법(formal constitution)이나 그 일부가 아니다. (그러한 헌법은 그 자체로 승인 규칙에 의해 유효화되어야(validated) 한다.) 이 점에 대해 혼란이 매우 많다. 이에 대한 논의로는 Kent Greenawalt, 'The Rule of Recognition and the Constitution' (1987) 85 *Michigan Law Review* 621; Matthew Adler and Kenneth Himma 편, *The Rule of Recognition and the U.S. Constitution* (Oxford University Press, 2009) 수록

논문들; John Gardner, 'Can there be a Written Constitution', Leslie Green and Brian Leiter 편, *Oxford Studies in Philosophy of Law*, vol. I (Oxford University Press, 2011) 및 그의 저서 *Law as a Leap of Faith* (Oxford University Press, 2012) 제4장을 참조하라.

(2) Hart는 승인 규칙이 “그것이 그 집단의 규칙임을 보여 주는 확정적 인정 표지 (conclusive affirmative indication)를 제공하는 특징들”을 명시한다고 말하고(94 쪽), 그것이 “일차 규칙들을 확정적으로 식별하기 위한 규칙”(95쪽)이라고 말하지만, 이를 승인 규칙의 기준들이 완전하고 확정적이라는 의미로 이해해서는 안 된다. 그는 그것을 명시적으로 부정한다(147-154쪽, 257-259쪽 참조).

(3) Hart는 각 법체계에 정확히 하나의 승인 규칙이 존재한다고 아무런 논증 없이 전제한다. 그러나 이는 의문의 여지가 있다. Joseph Raz, *The Authority of Law*, 95-96쪽 참조.

114-16쪽. 공무담당자들과 이차 규칙들(Officials and secondary rules). 흔히 두 가지 서로 다른 질문이 융합된다: (a) 누구의 행위가 승인 규칙을 구성하는가? (b) 누구의 행위가 승인 규칙에 의해 규율되는가? (a)에 답할 때 Hart는 때로 ‘공무담당자들(officials)’(115, 116쪽)을, 때로는 ‘판사들(judges)’(108, 116쪽, 256쪽 참조)을 언급한다. Joseph Raz는 판사와 같은 법 적용 공무담당자들이 특히 중요하다고 논변한다: *The Authority of Law*, chap. 6 참조. (b)에 관해서는 의문의 여지가 없다. 승인 규칙은 모든 공무담당자를 구속한다. 공무담당자들의 우위성, 그리고 법 적용 공무담당자들의 우위성은 정치적 도덕의 교설이 아니라는 점에 유의하라. 법원들이 실제로 그러한 영향력을 갖는 것이 유감스러울 수 있다는 점도 Hart가 논변하는 모든 것과 양립한다. 이에 대한 정치성 문제는 예컨대 Mark Tushnet, *Taking the Constitution Away from the Courts* (Princeton University Press, 1999)를 보라.

116-17쪽. 복종과 일반 시민(Obedience and the ordinary citizen). 이 부분들은 Hart가 법을 사회 제도로 평가하는 맥락을 이해하는 데 핵심이 되는 대목들이다. 그는 법이 도덕적 위험들을 가져온다는 점뿐 아니라, 그 위험들이 법의 본성과 긴밀하게 연결되어 있다는 점을 논변한다. 이에 대한 논의로는 Jeremy Waldron, 'All We Like Sheep' (1999) 12 *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 169 및 Leslie Green, 'Positivism and the Inseparability of Law and Morals' (2008) 83 *New York University Law Review* 1035, 특히 1052-1054쪽을 참조하라.

117-23쪽. 법체계의 병리학(Pathology of a legal system). John Finnis, 'Revolutions

and Continuity of Law', 그의 저서 *Philosophy of Law: Collected Essays Volume IV* (Oxford University Press, 2011)의 제21장도 보라. 법체계들 사이의 상호작용 가능성들은 Neil MacCormick, *Questioning Sovereignty: Law, State and Nation in the European Commonwealth* (Oxford University Press, 1999), chap. 7에서 탐구된다.

VII. 형식주의(Formalism)와 규칙회의주의 (Rule-Scepticism)

1. 법의 개방적 직조(The Open Texture of Law)

어떤 대규모 집단에서든, 일반 규칙들, 기준들, 원칙들은 사회 통제의 주요 수단이어야 하며, 각 개인에게 별도로 내려지는 개별 지시들이 주요 수단이어서는 안 된다. 수많은 개인들이 추가 지시 없이도, 어떤 경우가 발생했을 때 자신들에게 일정한 행위가 요구된다는 것으로 이해할 수 있는 일반적 행위 기준들을 전달할 수 없다면, 우리가 현재 법으로 인정하는 것은 아무것도 존재할 수 없을 것이다. 따라서 법은 주로, 그러나 결코 전적으로는 아니게, 사람의 부류들(classes), 그리고 행위, 사물, 상황의 부류들(classes)을 가리켜야 하며, 사회생활의 광범위한 영역에서 법이 성공적으로 작동하는 것은, 구체적인 행위들, 사물들, 상황들을 법이 만드는 일반적 분류들의 사례들로 식별할 수 있는 능력(capacity)이 널리 퍼져 있는 데 의존한다.

그러한 일반적 행위 기준들을, 그것들이 적용될 이어지는 경우들에 앞서 전달하기 위해 사용되어 온 두 가지 주요 장치가 있다. 처음 보기에는 서로 매우 달라 보이는 이 두 장치 가운데 하나는 일반적 분류어(classifying words)를 최대한 사용하고, 다른 하나는 최소한 사용한다. 첫 번째 방식은 우리가 입법(legislation)이라고 부르는 것으로 대표되고, 두 번째 방식은 선례(precedent)로 대표된다. 우리는 다음의 단순한 비법적 사례들에서 이 둘의 구별되는 특징들을 볼 수 있다. 한 아버지는 교회에 가기 전에 아들에게 이렇게 말한다. “모든 남성과 소년은 교회에 들어갈 때 모자를 벗어야 한다.” 다른 아버지는 교회에 들어가면서 자기 모자를 벗으며 말한다. “보아라. 이런 경우에는 이렇게 행동하는 것이 옳은 방식이다.”

예시에 의해 행위 기준들(standards of conduct)을 전달하거나 가르치는 것은, 우리의 단순한 사례보다 훨씬 더 정교한 여러 형태를 취할 수 있다. 만약 특정한 경우에 아이에게 교회에 들어갈 때 아버지가 한 행동을 옳은 행위의

본보기로 간주하라고 말하는 대신, 아버지가 (p. 125) 아이가 자신을 적절한 행위에 관한 권위로 간주하고 어떻게 행동해야 하는지를 배우기 위해 자신을 관찰할 것이라고 가정한다면(assumed), 우리의 사례는 법에서의 선례(precedent) 사용에 더 가까워질 것이다. 법에서의 선례 사용에 더 가까이 접근하려면, 아버지가 자기 자신과 타인들에 의해 전통적인 행위 기준들을 지지하는 사람으로 이해되고 있으며 새로운 기준들을 도입하는 것이 아니라고 상정해야 한다.

예시에 의한 전달은 그 모든 형태에서, ‘내가 하는 대로 하라’와 같은 얼마간의 일반적 언어 지시가 동반되더라도, 의도된 것이 무엇인지에 관하여, 전달하려는 사람이 스스로 명확히 염두에 둔 사항들에 대해서조차, 가능성들의 범위와 따라서 의문의 범위를 열어둘 수 있다. 수행의 어느 정도까지가 모방되어야 하는가? 모자를 벗을 때 오른손 대신 왼손을 쓰는 것이 문제가 되는가? 느리게 하는가 재빠르게 하는가가 문제가 되는가? 모자를 좌석 아래에 두는 것이 문제가 되는가? 교회 안에서 모자를 다시 쓰지 않는 것이 문제가 되는가? 이 모든 것은 아이가 스스로에게 물을 수 있는 보다 일반적인 질문들의 변형들이다. ‘내 행위가 그의 행위와 어떤 방식으로 유사해야 옳은가?’ ‘그의 행위에서 정확히 무엇이 나의 지침이 되어야 하는가?’ 예시를 이해하면서 아이는 그 예시의 어떤 측면들에 주목하고 다른 측면들에는 주목하지 않는다. 그렇게 할 때 아이는 상식과, 어른들이 중요하다고 생각하는 사물들과 목적들의 일반적 종류에 관한 지식, 그리고 그 경우(교회에 가는 것)의 일반적 성격과 그에 적절한 행위 종류에 대한 이해에 의해 인도된다.

예시들의 불확정성들(indeterminacies)과 대조적으로, 명시적인 일반 언어 형식(예: “모든 남성은 교회에 들어갈 때 모자를 벗어야 한다”)에 의한 일반 기준들의 전달은 분명하고, 신뢰할 수 있으며, 확실한 것처럼 보인다. 행위의 일반적 지침들로 받아들여져야 할 특징들은 여기서 말로 식별된다. 그것들은 구체적인 예시 속에 다른 것들과 함께 묻혀 남겨져 있지 않고, 언어적으로 끄집어내어져 있다. 아이는 다른 경우들에서 무엇을 해야 할지를 알기 위해 더 이상 무엇이 의도되었는지, 또는 무엇이 승인될 것인지를 추측할 필요가 없다. 아이는 자기 행위가 옳기 위해서는 그 예시와 어떤 방식으로 유사해야 하는지를 추측해야 하는 처지에 남겨져 있지 않다. 대신 아이에게는 앞으로 무엇을

해야 하는지, 그리고 언제 그것을 해야 하는지를 골라낼 수 있는 언어적 기술(description)이 있다. 그는 명확한 언어 용어들의 사례들을 식별하고, 구체적인 사실들을 일반적 분류 표제들 아래에 ‘포섭(subsume)’ 하며, 단순한 삼단논법적 결론을 도출하기만 하면 된다. (p. 126) 그는 자기 위험 부담 아래 선택하거나 추가적인 권위 있는 지침을 구해야 하는 선택지 앞에 놓여 있지 않다. 그는 자기 혼자서 자기에게 적용할 수 있는 규칙(rule)을 가지고 있다.

20세기의 법리학의 많은 부분은, 권위 있는 예시(선례(precedent))를 통한 전달의 불확실성과 권위 있는 일반 언어(입법(legislation))를 통한 전달의 확실성 사이의 구분이 이 순진한 대비가 시사하는 것만큼 확고하지 않다는 중요한 사실을 점차 인식하거나(때때로는 과장되게) 강조해온 과정이었다. 언어적으로 정식화된 일반 규칙이 사용될 때조차, 그 규칙이 요구하는 행위의 형태에 관한 불확실성은 특정한 구체적인 사례에서 발생할 수 있다. 구체적인 사실 상황은 일반 규칙의 적용 여부가 문제되는 사안의 사례들로 미리 서로 구분되고 명명되어 있는 것이 아니며, 규칙 자체가 나서서 스스로의 사례라고 주장할 수도 없다. 규칙의 영역뿐 아니라 모든 경험의 영역에서는, 일반 언어가 제공할 수 있는 지침에는 언어의 본성에 내재한 한계가 존재한다. 기실 유사한 맥락에서 반복적으로 발생하며 일반적 표현이 분명히 적용가능한 명백한 사례들(예: “무엇이 탈 것(a vehicle)이라면, 자동차는 틀림없이 그 중 하나다(If anything is a vehicle a motor-car is one)”)이 존재하지만, 그 표현이 적용되는지 불분명한 사례들(예: “여기서 ‘탈 것(vehicle)’ 이라는 표현은 자전거(bicycles)나 비행기(airplanes), 롤러스케이트(roller skates)도 포함하는가?”)도 있다. 후자의 경우는, 자연이나 인간의 발명에 의해 끊임없이 등장하며, 명백한 사례의 일부 특징만을 가지되 다른 특징은 결여한 사실 상황들이다. ‘해석’의 준칙들(canons of ‘interpretation’)은 이러한 불확실성을 줄일 수는 있어도 없앨 수는 없다. 왜냐하면 이 준칙들 역시 언어 사용에 관한 일반 규칙들이며, 그 자체가 해석을 요하는 일반 용어들을 사용하기 때문이다. 이러한 규칙들 역시 다른 규칙들과 마찬가지로 자기 자신의 해석을 제공할 수 없다. 해석이 필요 없어 보이며 사례들의 식별이 문제없거나 ‘자동적’으로 보이는 명백한 사례들은, 사실 유사한 맥락에서 반복적으로 나타나는 친숙한 것들일 뿐이다. 이러한

경우에는 분류 용어의 적용에 대해 판단이 일치하는 일반적 합의가 존재한다.

일반 용어들(*general terms*)은 그러한 친숙하고 일반적으로 다투어지지 않는 사례들이 없다면 의사소통의 매체로서 우리에게 무용할 것이다. 그러나 친숙한 것의 변형들(*variants*) 역시, (p. 127) 어느 특정 시점에 우리의 언어적 자원의 일부를 이루는 일반 용어들 아래에서의 분류(*classification*)를 요구한다. 여기서 의사소통에서 일종의 위기가 촉발된다. 일반 용어를 사용하는 데에는 찬성하는 이유들과 반대하는 이유들이 모두 있으며, 분류해야 하는 당사자에게 그 용어의 사용을 명하거나, 반대로 그 사용의 거부를 명하는 확고한 관행이나 일반적 합의는 없다. 이러한 경우에 의문들이 해소되어야 한다면, 그것들을 해소해야 할 자는 열린 대안들(*open alternatives*) 사이에서 일종의 선택을 해야만 한다.

이 지점에서 규칙이 표현되어 있는 권위 있는 일반 언어(*authoritative general language*)는 권위 있는 예시가 그러하듯이 불확실한 방식으로만 인도할 수 있다. 이 지점에서는 규칙의 언어가 우리로 하여금 쉽게 식별 가능한 사례들을 단순히 골라낼 수 있게 해 줄 것이라는 느낌이 무너진다. 포섭(*subsumption*)과 삼단논법적 결론의 도출(*drawing of a syllogistic conclusion*)은 무엇이 해야 할 옳은 일인지를 정하는 데 관여하는 추론의 핵심을 더 이상 특징짓지 못한다. 대신 규칙의 언어는 이제 권위 있는 예시 하나, 곧 명백한 사례(*plain case*)에 의해 구성되는 예시를 지목하는 것처럼 보일 뿐이다. 이것은 선례와 거의 같은 방식으로 사용될 수 있지만, 규칙의 언어는 선례보다 더 지속적이고 더 촘촘하게 주목을 요구하는 특징들을 제한한다. 공원에서 차량 사용을 금지하는 규칙이 그 적용 여부가 불확정적으로 보이는 어떤 상황들의 결합에 적용되는가라는 질문에 직면할 때, 답해야 하는 사람이 할 수 있는 전부는 (선례를 사용하는 사람이 그러하듯이) 현재 사례가 명백한 사례와 ‘관련된’ 측면들에서 ‘충분히’ 유사한지를 고려하는 것이다. 언어가 그에게 남겨 두는 이러한 재량(*discretion*)은 매우 넓을 수 있다. 그래서 그가 그 규칙을 적용한다면, 그 결론은 자의적이거나 비합리적이지 않을 수 있음에도 불구하고 사실상 하나의 선택이다. 그는 법적으로 관련되고 충분히 가까운 것으로 합리적으로 옹호될 수 있는 유사성들 때문에, 하나의 새로운 사례를 사례들의 계열(*line of cases*)에 추가하기로 선택한다. 법규칙들의 경우, 관련성(*relevance*)과 유사성의 가까움(*closeness of*

resemblance)의 기준들은 법체계 전반을 관통하는 많은 복잡한 요소들과 그 규칙에 귀속될 수 있는 목적들 또는 취지(aims or purpose)에 의존한다. 이것들을 특징짓는 것은 법적 추론(legal reasoning)에 특유하거나 고유한 것이 무엇이든 그것을 특징짓는 일이 될 것이다.

행위 기준들의 전달을 위해 선례(precedent)든 입법(legislation)이든 어느 장치가 선택되더라도, 그것들은 보통 사례들의 대다수에서는 아무리 매끄럽게 작동한다 하더라도, 그 적용이 문제되는 어떤 지점에서는 불확정적(indeterminate)임이 드러날 것이다. 그것들은 이른바 개방적 직조(open texture)를 지닐 것이다. 지금까지 우리는 입법의 경우에 관하여 이것을 인간 언어의 일반적 특징으로 제시해 왔다. 경계선(borderline)에서의 불확실성은 사실의 문제들에 관한 어떤 형태의 의사소통에서든 일반적 분류 용어들을 사용하는 데 치러야 할 대가이다. 영어와 같은 자연언어는 그렇게 사용될 때 환원 불가능하게 개방적 직조를 지닌다. 그러나 실제 언어가 개방적 직조의 특성들을 가진다는 점에 의존한다는 이 사실과는 별도로, 특정 사례에 적용되는지 여부가 언제나 사전에 확정되어 있고 실제 적용 지점에서 열린 대안들 사이의 새로운 선택을 전혀 수반하지 않는, 그토록 상세한 규칙이라는 구상을—이상(ideal)으로서조차—왜 우리가 품어서는 안 되는지를 이해하는 것이 중요하다. 짧게 말해 그 이유는, 그러한 선택의 필요성이 우리가 신들(gods)이 아니라 인간들(men)이기 때문에 우리에게 떠맡겨지기 때문이다. 특정한 경우마다 추가적인 공무담당 지시(official direction) 없이 사용될 일반 기준들에 의해, 어떤 행위 영역을 모호성 없이 사전에 규율하려 할 때마다, 우리가 서로 연결된 두 가지 불리한 조건 아래에서 애쓰는 점은 인간적 처지(the human predicament)의 특징이며, 따라서 입법적 처지의 특징이다. 첫 번째 불리한 조건은 사실에 대한 우리의 상대적 무지(relative ignorance of fact)이고, 두 번째는 목적의 상대적 불확정성(relative indeterminacy of aim)이다. 만약 우리가 사는 세계가 유한한 수의 특징들로만 특징지어지고, 이 특징들과 그것들이 결합할 수 있는 모든 방식이 우리에게 알려져 있다면, 모든 가능성에 대해 사전에 대비할 수 있을 것이다. 우리는 특정 사례들에 대한 적용이 결코 추가적 선택을 요구하지 않는 규칙들을 만들 수 있을 것이다. 모든 것이 알려질 수 있을 것이고, 모든 것에 대해, 그것이 알려질 수

있기 때문에, 무언가가 행해질 수 있으며 규칙에 의해 사전에 특정될 수 있을 것이다. 이것은 ‘기계적(mechanical)’ 법리학(jurisprudence)에 알맞은 세계일 것이다.

명백히 이 세계는 우리의 세계가 아니다. 인간 입법자들은 미래가 가져올 수 있는 모든 가능한 상황 조합들에 관해 그러한 지식을 가질 수 없다. 이러한 예견할 수 없음(inability to anticipate)은 목적의 상대적 불확정성(indeterminacy of aim)을 동반한다. 우리가 어떤 일반적 행위 규칙을 과감히 정식화할 때(예: 어떤 차량도 공원에 들어와서는 안 된다는 규칙), (p. 129) 이 맥락에서 사용되는 언어는 어떤 것이 그 범위 안에 들려면 충족해야 하는 필요조건들을 고정하며, 확실히 그 범위 안에 드는 것의 몇몇 명확한 예들이 우리의 마음에 떠오를 수 있다. 그것들은 전범적(paradigm) 명백한 사례들(clear cases), 곧 자동차, 버스, 오토바이이다. 그리고 우리의 입법 목적은 지금까지는 확정적(determinate)인데, 이는 우리가 일정한 선택을 했기 때문이다. 우리는 적어도 이러한 것들을 배제하는 대가를 치르더라도 공원의 평온과 조용함이 유지되어야 한다는 문제를 처음에 확정해 두었다. 다른 한편, 우리가 공원의 평온이라는 일반 목적을 처음에 예견하지 않았거나 어쩌면 예견할 수 없었던 사례들(예컨대 전기로 움직이는 장난감 자동차)과 결합시키기 전까지, 이 방향에서 우리의 목적은 불확정적(indeterminate)이다. 우리는 예견되지 않은 사례가 발생할 때 제기될 문제를, 우리가 예견하지 않았기 때문에, 아직 확정해 두지 않았다. 즉, 이러한 것들을 사용하는 것이 즐거움이나 이익이 되는 아이들을 위해 공원의 어느 정도 평온을 희생할 것인지, 아니면 그 아이들에 맞서 그 평온을 방어할 것인지의 문제이다. 예견되지 않은 사례가 실제로 발생하면, 우리는 걸려 있는 쟁점들에 직면하고, 그때 서로 경쟁하는 이익들 사이에서 우리에게 가장 만족스러운 방식으로 선택함으로써 그 문제를 확정할 수 있다. 그렇게 함으로써 우리는 우리의 최초 목적을 더 확정적으로 만들게 되며, 부수적으로는 이 규칙의 목적상 어떤 일반 단어의 의미에 관한 문제도 확정하게 된다.

서로 다른 법체계들이나 동일한 법체계라도 서로 다른 시기에는, 일반 규칙들을 특정 사례들에 적용할 때 추가적인 선택 행사가 필요하다는 점을 어느 정도로든, 그리고 더 많거나 더 적게 명시적으로 무시하거나 인정할 수 있다.

법이론에서 형식주의(formalism) 또는 개념주의(conceptualism)로 알려진 폐해는, 일반 규칙이 일단 설정되고 나면 그러한 선택의 필요성을 은폐하고 최소화하려는 언어로 정식화된 규칙들에 대한 태도에 있다. 이를 수행하는 한 가지 방식은 규칙의 의미를 동결하여, 그 일반 용어들이 적용이 문제되는 모든 경우에서 동일한 의미를 가져야 한다고 하는 것이다. 이를 확보하기 위해 우리는 명백한 사례(plain case)에 존재하는 특정 특징들을 붙잡고, 어떤 것이 그러한 특징들을 가지면 그것이 다른 어떤 특징들을 더 가지거나 결여하든, 그리고 이 방식으로 규칙을 적용할 때 사회적 결과가 무엇이든, 그것을 규칙의 범위 안에 포함시키기에 그러한 특징들이 필요충분하다고 주장할 수 있다. 이렇게 하는 것은, 우리가 그 구성에 대해 무지한 장래의 사례들의 범위에서 무엇이 행해져야 하는지를 맹목적으로 미리 판단하는 대가로 일정한 확실성 또는 (p. 130) 예측가능성(predictability)을 확보하는 것이다. 따라서 우리는 기실 사전에 쟁점들을 확정하는 데 성공하겠지만, 동시에 어둠 속에서, 그것들이 발생하고 식별될 때에만 합리적으로 확정될 수 있는 쟁점들을 확정하게 된다. 이러한 기법은 합리적인 사회적 목적들에 효력을 부여하기 위해 우리가 배제하고 싶어 할 사례들, 그리고 우리가 그것들을 덜 경직적으로 정의된 채로 두었더라면 우리 언어의 개방적 직조(open texture)를 지닌 용어들이 우리로 하여금 배제할 수 있게 했을 사례들을, 규칙의 범위 안에 포함하도록 우리를 강제할 것이다. 이로써 우리의 분류들의 경직성은 그 규칙을 가지거나 유지하려는 우리의 목적들과 충돌하게 될 것이다.

이 과정의 완성은 법리학자들의 ‘개념의 천국(heaven of concepts)’이다. 이는 하나의 일반 용어가 단일한 규칙의 모든 적용에서 동일한 의미를 갖는 데 그치지 않고, 법체계 내의 어떤 규칙에서 등장하든 언제나 동일한 의미를 부여받을 때에 도달한다. 그러한 경우에는, 그 용어가 여러 차례 재현될 때마다 서로 다른 이해관계나 쟁점을 고려하여 그 의미를 해석하려는 어떠한 노력도 더 이상 요구되거나 시도되지 않는다.

사실 모든 체계들은 각기 다른 방식으로 두 가지 사회적 필요 사이에서 타협한다. 하나는 넓은 행위 영역들에 걸쳐, 새로운 공무담당 지침(official guidance)이나 사회적 쟁점들의 형량 없이도 사적 개인들이 자기 자신에게 안전하게

적용할 수 있는 확실한(certain) 규칙들에 대한 필요이고, 다른 하나는 구체적 사례에서 발생할 때에만 비로소 적절하게 이해되고 확정될 수 있는 쟁점들을, 나중에 정보를 갖춘 공무담당 선택(official choice)에 의해 확정되도록 열어 두어야 할 필요이다. 어떤 법체계들에서는 어떤 시기에는 확실성(certainty)에 지나치게 많은 것이 희생되어, 제정법들(statutes)이나 선례에 대한 사법적 해석이 지나치게 형식적이고, 그래서 사회적 목적들의 관점에서 고려될 때에만 보이는 사례들 사이의 유사성과 차이에 응답하지 못할 수 있다. 다른 체계들이나 다른 시기에는, 법원이 선례들에서 지나치게 많은 것을 영구히 열려 있거나 수정 가능한 것으로 취급하고, 입법 언어가 그 개방적 직조에도 불구하고 결국 제공하는 한계들에 지나치게 적은 존중을 보이는 것처럼 보일 수 있다. 이 문제에서 법이론은 기묘한 역사를 가진다. 그것은 법규칙들의 불확정성들(indeterminacies)을 무시하거나 과장하는 경향이 있기 때문이다. 이러한 극단들 사이의 진동에서 벗어나려면, 이 (p. 131) 불확정성의 뿌리에 놓인 미래를 예견하지 못하는 인간적 한계가 행위의 서로 다른 영역들에서 정도를 달리하며, 법체계들이 그 한계에 상응하는 다양한 기법들로 대응한다는 점을 상기해야 한다.

때로 법적으로 통제되어야 할 영역은 처음부터, 개별 사례들의 특징들이 사회적으로 중요한 그러나 예측 불가능한 측면들에서 너무나 다양하게 변할 것이어서, 추가적인 공무담당 지시(official direction) 없이 사례에서 사례로 적용될 일양적 규칙들을 입법부가 사전에 유용하게 정식화할 수 없는 영역으로 인정된다. 따라서 그러한 영역을 규율하기 위해 입법부는 매우 일반적인 기준들을 세우고, 다양한 사례 유형들에 정통한 행정적 규칙제정 기관에, 그 특수한 필요들에 맞추어진 규칙들을 만들어 내는 과업을 위임한다. 예컨대 입법부는 어떤 산업에 일정한 기준들을 유지하라고 요구할 수 있다. 즉 공정한 요율(fair rate)만을 부과하거나 안전한 작업 체계들(safe systems)을 제공하라고 요구할 수 있다. 서로 다른 기업들이 이 모호한 기준들을 스스로에게 적용하도록 맡겨 두어, 사후적으로(ex post facto) 그것들을 위반한 것으로 판정될 위험을 부담하게 하기보다는, 행정기관이 규정으로 특정 산업에 대해 무엇이 ‘공정한 요율’ 또는 ‘안전한 체계’로 간주될 것인지를 특정할 때까지 위반에 대한 제재 사용을 유보하는 것이 최선이라고 판명될 수 있다. 이러한 규칙제정 권한은 해당 산업에

관한 사실들에 대한 사법적 조사와 유사한 것 및 특정한 규제 형식에 찬반하는 논변들의 청문을 거친 뒤에만 행사될 수 있을지도 모른다.

물론 매우 일반적인 기준들(very general standards)이 있더라도, 무엇이 그것들을 충족하거나 충족하지 않는지에 관한 명백하고 다툼의 여지가 없는 예들은 있을 것이다. 무엇이 ‘공정한 요율’ 또는 ‘안전한 체계’ 인지, 또는 아닌지에 관한 몇몇 극단적 사례들은 언제나 처음부터(ab initio) 식별 가능할 것이다. 따라서 무한히 다양한 사례들의 범위 한쪽 끝에는 필수 서비스에 대해 공중을 사실상 인질로 잡으면서 기업가들에게 막대한 이윤을 안겨주는 너무 높은 요율이 있을 것이고, 다른 끝에는 기업 운영의 유인을 제공하지 못하는 너무 낮은 요율이 있을 것이다. 이 둘은 서로 다른 방식으로 요율 규제에서 우리가 가질 수 있는 어떤 가능한 목적도 좌절시킬 것이다. 그러나 이것들은 서로 다른 요소들의 범위에서 극단들일 뿐이며 실제로 마주칠 개연성이 높지 않다. 그 사이에 주의를 요구하는 어려운 실제 사례들이 놓여 있다. 관련 요소들의 예견 가능한 조합들은 적고, 이는 공정한 요율 또는 안전한 체계라는 우리의 최초 목적에 상대적 불확정성을 수반하며, 추가적인 공무담당 (p. 132) 선택(official choice)의 필요를 수반한다. 이러한 경우에는 규칙제정 기관(rule-making authority)이 재량(discretion)을 행사해야 한다는 점이 명확하며, 여러 사례들이 제기하는 문제를 많은 상충하는 이익들 사이의 합리적 타협인 답과는 구별되는, 발견되어야 할 하나의 유일하게 올바른 답이 있는 것처럼 다를 가능성은 없다.

두 번째 유사한 기법은, 통제되어야 할 영역이 일률적으로 행해지거나 삼가야 할 특정 행위들의 부류를 식별하여 그것들을 단순 규칙(simple rule)의 대상으로 삼는 것은 불가능하지만, 상황들의 범위가 매우 다양하더라도 공통 경험의 친숙한 특징들을 포괄하는 경우에 사용된다. 여기서는 무엇이 ‘합리적(reasonable)’ 인지에 관한 공통 판단들이 법에 의해 사용될 수 있다. 이 기법은 여러 예견 불가능한 형태로 발생하는 사회적 요구들(social claims) 사이에서 형량하고 합리적 균형을 맞추는 과업을, 법원의 교정을 받을 수 있는 개인들에게 남겨 둔다. 이 경우 개인들은 가변적 기준(variable standard)이 공식적으로 규정되기 전에(before) 그 기준에 부합할 것을 요구받으며, 그들이 그것을 위반했을 때에만 사후적으로(ex post facto) 법원으로부터, 특정 행위들이나 부작위들의

관점에서 자신들에게 요구된 기준이 무엇이었는지를 알게 될 수 있다. 그러한 사안들에 대한 법원의 결정들이 선례로 간주되는 곳에서는, 가변적 기준에 대한 법원의 특정화는 행정기관이 위임된 규칙제정 권한(delegated rulemaking power)을 행사하는 것과 매우 유사하지만, 또한 명백한 차이들도 있다.

영미법(Anglo-American law)에서 이 기법의 가장 유명한 예는 과실(negligence) 사건들에서 상당한 주의(due care)의 기준을 사용하는 것이다. 타인에게 신체적 손해를 입히는 것을 피하기 위해 합리적 주의를 기울이지 않은 자들에게는 민사 제재가, 더 드물게는 형사 제재가 적용될 수 있다. 그러나 구체적인 상황에서 합리적 주의 또는 상당한 주의란 무엇인가? 물론 우리는 상당한 주의의 전형적 예들을 들 수 있다. 예컨대 통행이 예상되는 곳에서 멈추고, 살피고, 듣는 것과 같은 일들이다. 그러나 우리 모두는 주의가 요구되는 상황들이 엄청나게 다양하며, 이제는 ‘멈추고, 살피고, 듣기’ 외에 또는 그 대신에 많은 다른 행위들이 요구된다는 점을 잘 알고 있다. 기실 보는 것이 위험을 피하는데 도움이 되지 않는다면 이것들은 충분하지 않을 수 있고 전혀 쓸모없을 수도 있다. 합리적 주의 기준들을 적용하면서 우리가 추구하는 것은 (1) 중대한 해악을 피하게 할 (p. 133) 예방조치들이 취해지게 하면서도, (2) 그 예방조치들이 적절한 예방조치들의 부담이 다른 존중할 만한 이익들의 지나치게 큰 희생을 수반하지 않도록 하는 것이다. 물론 피를 흘리며 죽어가는 사람이 병원으로 이송되는 경우가 아니라면, 멈추고, 살피고, 듣는 것에 의해 그리 많은 것이 희생되지는 않는다. 그러나 주의가 요구되는 가능한 사례들의 엄청난 다양성 때문에, 해악에 대한 예방조치가 취해져야 한다면 어떤 상황들의 조합이 발생할지, 또는 어떤 이익들이 어느 정도로 희생되어야 할지를 우리는 처음부터(ab initio) 예견할 수 없다. 따라서 우리는 특정 사례들이 발생하기 전에는, 해악의 위험을 줄이기 위해 이익들이나 가치들의 어떤 희생 또는 타협을 정확히 하고자 하는지를 고려할 수 없다. 다시 말해, 사람들을 해악으로부터 보호하려는 우리의 목적은, 경험만이 우리 앞에 가져다줄 가능성들과 결합시키거나 그것들에 비추어 시험하기 전까지는 불확정적(indeterminate)이다. 경험이 그것을 가져오면, 그때 우리는 하나의 결정에 직면해야 하며, 그 결정은 내려질 때 우리의 목적을 그만큼(pro tanto) 확정적으로 만들 것이다.

이 두 가지 기법(techniques)을 고려하면, 가변적 기준(variable standard)이 아니라 특정 행위들을 요구하는 규칙(rule)에 의해, 개방적 직조(open texture)의 가장자리(fringe)만을 남긴 채 처음부터(ab initio) 성공적으로 통제되는 넓은 행위 영역들의 특징들이 두드러진다. 그것들은 다음 사실에 의해 특징지어진다. 어떤 구별 가능한 행위들, 사건들, 또는 사태들이 우리에게 회피되어야 하거나 생겨나야 할 것으로서 실천적으로 매우 중요하여, 그것들과 함께 나타나는 부수적 상황들이 우리로 하여금 그것들을 달리 보도록 기울게 하는 경우가 거의 없다는 것이다. 이것의 가장 거친 예는 인간 존재의 살해(killing of a human being)이다. 인간 존재들이 다른 인간 존재들을 살해하는 상황들은 매우 다양하지만, 우리는 가변적 기준(‘인간 생명에 대한 상당한 존중’)을 세우는 대신 살해를 금지하는 규칙을 만들 수 있는 위치에 있다. 이는 생명 보호의 중요성에 대한 우리의 평가보다 더 큰 무게를 갖거나 그 평가를 수정하게 하는 요소들이 우리에게 거의 없는 것으로 보이기 때문이다. 거의 언제나 살해는 말하자면 그것에 수반되는 다른 요소들을 지배한다(dominates). 따라서 우리가 그것을 ‘살해(killing)’로서 사전에 배제할 때, 우리는 서로 형량되어야 하는 쟁점들을 맹목적으로 미리 판단하고 있는 것이 아니다. 물론 예외들, 이 통상적으로 지배적인 요소를 압도하는 요소들이 있다. 정당방위에서의 살해와 기타 정당화 가능한 살해(justifiable homicide)의 형태들이 그것이다. 그러나 이것들은 적고 상대적으로 단순한 용어들로 식별 가능하며, 일반 규칙에 대한 예외들로 인정된다.

(p. 134) 쉽게 식별 가능한 어떤 행위, 사건, 또는 사태의 지배적 지위가 어떤 의미에서는 관행적(conventional)이거나 인위적(artificial)일 수 있으며, 인간 존재로서 우리에게 그것이 가지는 ‘자연적(natural)’ 또는 ‘내재적(intrinsic)’ 중요성 때문이 아닐 수 있다는 점을 주목하는 것이 중요하다. 도로 통행 규칙(rule of the road)이 어느 쪽 도로를 지정하는지는 중요하지 않으며, 부동산 양도 증서(conveyance)의 작성(execution)을 위해 어떤 형식요건들이 규정되는지도(일정 한계 안에서는) 중요하지 않다. 그러나 이러한 사항들에 대해 쉽게 식별 가능하고 일양적인 절차가 있어야 하며, 따라서 명확한 옳고 그름(right and wrong)이 있어야 한다는 점은 대단히 중요하다. 이것이 법에 의해 도입되면, 소

수의 예외를 제외하고는 그것을 고수하는 것의 중요성이 최우선적(paramount)이 된다. 왜냐하면 상대적으로 적은 수의 부수적 상황들만이 그것보다 더 큰 무게를 가질 수 있고, 그러한 상황들은 쉽게 예외로 식별되어 규칙으로 환원될 수 있기 때문이다. 영국 부동산법(real property law)은 규칙들의 이러한 측면을 매우 명확하게 예증한다.

권위 있는 예시들(authoritative examples)에 의한 일반 규칙들의 전달은, 우리가 보았듯이, 더 복잡한 종류의 불확정성들을 수반한다. 선례를 법적 유효성의 기준으로 인정하는 것은 서로 다른 체계들에서, 그리고 동일한 체계의 서로 다른 시기들에서 서로 다른 것들을 의미한다. 영국의 선례 ‘이론(theory)’에 대한 서술들은 어떤 지점들에서는 여전히 매우 논쟁적이다. 기실 그 이론에서 사용되는 핵심 용어들, 즉 ‘판결 이유(ratio decidendi)’, ‘중요 사실(material facts)’, ‘해석(interpretation)’조차도 각자 고유한 불확실성의 반음영(penumbra)을 지닌다. 우리는 어떤 새로운 일반적 서술을 제시하지는 않고, 제정법(statute)의 경우에서와 마찬가지로, 개방적 직조(open texture)의 영역과 그 안에서 이루어지는 창조적 사법 활동을 간략하게 특징짓고자 할 뿐이다.

영국법에서 선례(precedent)의 사용에 대한 정직한 서술은 다음과 같은 대조적 사실들의 쌍들을 위한 자리를 반드시 마련해야 한다. 첫째, 주어진 권위 있는 선례(authoritative precedent)가 어떤 규칙에 대한 권위(authority)인지를 결정하는 단일한 방법은 없다. 그럼에도 불구하고 판결이 내려진 사건들의 압도적 다수에서는 의문이 거의 없다. 사건요지(head-note)는 보통 충분히 정확하다. 둘째, 사건들로부터 추출될 어떤 규칙에 대해서도 권위 있거나 유일하게 올바른 정식화(authoritative or uniquely correct formulation)는 없다. 다른 한편, 선례가 후속 사건에 대해 가지는 관련성(bearing)이 문제될 때, 주어진 정식화가 적절하다는 데 매우 일반적인 합의가 있는 경우가 흔하다. 셋째, 선례에서 추출된 규칙이 어떤 권위 있는 지위(authoritative status)를 가지든, 그것은 그 규칙에 구속되는 법원들이 (p. 135) 다음 두 유형의 창조적 또는 입법적 활동을 행사하는 것과 양립 가능하다. 한편으로 후속 사건을 판단하는 법원들은 선례에서 추출된 규칙을 좁히고, 이전에 고려되지 않았거나 고려되었더라도 열려 있던 어떤 예외를 인정함으로써 선례와 반대되는 결정에 이를 수 있다. 이처럼

앞선 사건을 ‘구별(distinguishing)’ 하는 과정은 그 사건과 현재 사건 사이에서 법적으로 관련된 어떤 차이를 발견하는 것을 포함하며, 그러한 차이들의 부류는 결코 소진적으로 확정될 수 없다. 다른 한편, 법원들은 앞선 선례를 따르면서도, 앞선 사건에서 정식화된 규칙 안에서 발견되는 어떤 제약(restriction)을, 그것이 제정법(statute)이나 더 앞선 선례에 의해 확립된 어떤 규칙에 의해서도 요구되지 않는다는 근거로 폐기할 수 있다. 이렇게 하는 것이 규칙을 넓히는 것이다. 선례의 구속력(binding force)에 의해 열려 있는 이러한 두 형태의 입법적 활동에도 불구하고, 영국 선례 체계의 결과는 그 사용을 통해 중요도가 큰 것과 작은 것을 모두 포함하는 매우 많은 수의 규칙들의 집합을 산출한 것이며, 그 가운데 많은 규칙들은 어떤 제정법 규칙(statutory rule) 못지않게 확정적(determinate)이다. 이제 그것들은 제정법(statute)에 의해서만 변경될 수 있으며, 법원들 자신도 확립된 선례들의 요구와 ‘실질적 타당성(merits)’ 이 배치되는 것처럼 보이는 사건들에서 흔히 그렇게 선언한다.

법의 개방적 직조(open texture)는, 기실 많은 행위 영역들에서 사안마다 무게가 달라지는 상충하는 이익들 사이의 균형을 상황에 비추어 맞추는 법원들이나 공무담당자들에 의해 많은 것이 발전되도록 남겨져야 함을 의미한다. 그럼에도 불구하고 법의 삶(life of the law)은 매우 큰 정도로, 가변적 기준들(variable standards)의 적용과는 달리 사례마다 새로운 판단을 요구하지 않는 확정적 규칙들(determinate rules)에 의한 공무담당자들과 사적 개인들 모두의 지도로 이루어진다. 이러한 사회생활의 두드러진 사실은, 어떤 규칙이든(문서화된 것이든 선례에 의해 전달된 것이든) 구체적 사례에 대한 적용가능성을 둘러싸고 불확실성들이 터져 나올 수 있음에도 불구하고 여전히 참이다. 여기, 규칙들의 주변부에서 그리고 선례 이론에 의해 열려 있는 영역들에서, 법원들은 행정기관들이 가변적 기준들을 정교화할 때 중심으로 수행하는 규칙-생산 기능을 수행한다. 선례구속 원칙(stare decisis)이 확고히 인정된 체계에서, 법원의 이 기능은 행정기관에 의한 위임된 규칙제정 권한(delegated rule-making powers)의 행사와 매우 유사하다. 영국에서는 이 사실이 형식들(forms)에 의해 자주 가려진다. 법원들이 (p. 136) 흔히 그러한 창조적 기능을 부인하고, 제정법 해석과 선례 사용의 적절한 과업은 각각 ‘입법자의 의도(intention of the

legislature)’ 와 이미 존재하는 법을 탐색하는 것이라고 고수하기 때문이다.

2. 규칙회의주의(rule-scepticism)의 다양상들

우리는 법의 개방적 직조(open texture)에 대해 상당히 길게 논의했는데, 이는 이 특징을 정당한 관점에서 보는 것이 중요하기 때문이다. 그것을 정당하게 다루지 못하면(do justice) 언제나 법의 다른 특징들을 흐리게 할 과장들이 유발될 것이다. 모든 법체계에는 처음에는 모호한 기준들을 확정적으로 만들고, 제정법들(statutes)의 불확실성들을 해소하며, 권위 있는 선례들(authoritative precedents)에 의해 단지 넓게만 전달된 규칙들을 발전시키고 한정하는 데서, 법원들과 기타 공무담당자들이 재량(discretion)을 행사하도록 넓고 중요한 영역이 열려 있다. 그럼에도 불구하고 이러한 활동들은, 중요하고 충분히 연구되지 않았더라도, 그것들이 일어나는 틀(framework)과 그것들의 주된 최종 산물이 모두 일반 규칙들로 이루어져 있다는 사실을 가려서는 안 된다. 이것들은 개인들이 사례마다 그 적용을 스스로 볼 수 있는 규칙들로서, 추가적인 공무담당 지시(official direction)나 재량에 더 호소할 필요가 없다.

규칙들이 법체계의 구조에서 중심적 자리를 가진다는 논지(contention)가 진지하게 의심받을 수 있었다는 것은 이상해 보일 수 있다. 그러나 ‘규칙회의주의(rule-scepticism)’, 곧 규칙에 관한 말은 법이 단지 법원의 결정들과 그것들에 대한 예측들로 이루어진다는 진실을 가리는(cloaking) 하나의 신화라는 주장(claim)은 법률가의 솔직함에 강력하게 호소할 수 있다. 이 주장이 이차 규칙들과 일차 규칙들을 모두 포괄하도록 무제한적인 일반 형식으로 진술된다면, 그것은 기실 매우 비정합적(incoherent)이다. 법원의 결정들이 존재한다는 단언은 아무 규칙도 전혀 존재하지 않는다는 부정과 일관되게 결합될 수 없기 때문이다. 이는 우리가 보았듯이 법원의 존재가 관할권(jurisdiction)을 계속 바뀌는 일련의 개인들에게 부여하고 그래서 그들의 결정들을 권위 있는 것으로 만드는 이차 규칙들의 존재를 수반하기 때문이다. 어떤 사람들의 공동체가 결정과 결정에 대한 예측이라는 관념들(notions)은 이해하지만 규칙이라는 관념(notion)은 이해하지 못한다면, 그들에게는 권위 있는(authoritative) 결정이라는

관념(idea)이 결여될 것이며 그와 함께 법원이라는 관념(idea)도 결여될 것이다. 사인의 결정과 법원의 결정을 구별할 아무것도 없을 것이다. 우리는 (p. 137) ‘습관적 복종’이라는 관념(notion)으로, 법원에서 요구되는 권위 있는 관할권의 토대로서 결정의 예측가능성이 가지는 결함을 보충하려 할지도 모른다. 그러나 이렇게 하면, 입법 권한들을 부여하는 규칙의 대체물로 제4장에서 습관을 검토했을 때 드러난 모든 부적합성들을, 이 목적에서도, 습관이라는 관념(notion)이 가진다는 것을 발견하게 될 것이다.

이 이론의 더 온건한 몇몇 형태에서는, 법원들이 존재하려면 그것들을 구성하는 법규칙들이 있어야 하며, 따라서 이러한 규칙들 자체는 단순히 법원의 결정들에 대한 예측들일 수 없다는 점이 인정될 수 있다. 그러나 이 양보만으로는 실제로 거의 진전을 이룰 수 없다. 이러한 유형의 이론의 특징적 단언은 제정법들(statutes)이 법원에 의해 적용되기 전에는 법이 아니라 단지 법의 원천들(sources of law)이라는 것이고, 이는 존재하는 유일한 규칙들은 법원들을 구성하는 데 필요한 규칙들이라는 단언과 일관되지 않기 때문이다. 계속 바뀌는 일련의 개인들에게 입법 권한들을 부여하는 이차 규칙들도 있어야 한다. 왜냐하면 이 이론은 제정법들(statutes)이 있다는 것을 부정하지 않기 때문이다. 기실 그것은 그것들을 법의 단순한 ‘원천들(sources)’로 인용하고, 제정법들이 법원에 의해 적용되기 전에는 법이라는 것만 부정한다.

이러한 반론들은 중요하며, 이 이론의 경솔한 형태에 대해서는 적절하지만, 그 모든 형태에 적용되지는 않는다. 규칙회의주의는 사법적 또는 입법적 권한을 부여하는 이차 규칙들의 존재를 부정하려는 의도가 전혀 없었고, 그것들이 결정들이나 결정들에 대한 예측들에 불과하다고 보일 수 있다는 주장에 결부된 적도 전혀 없었을 수 있다. 분명히 이러한 유형의 이론이 가장 자주 의존해 온 예들은 사인들에게 책무를 부과하거나 권리들 또는 권한들을 부여하는 규칙들에서 끌어온 것이다. 그러나 규칙들이 있다는 부정과 규칙들이라 불리는 것이 법원의 결정들에 대한 예측들일 뿐이라는 단언을 이러한 방식으로 제한한다고 상정하더라도, 적어도 한 의미에서는 그것이 명백히 거짓이다. 왜냐하면 적어도 근대 국가의 어떤 행위 영역들과 관련해서는, 개인들이 우리가 내부 관점(internal point of view)이라 불렀던 행위와 태도의 전 범위를 실제로 보인다는

점은 의심될 수 없기 때문이다. 법들은 그들의 삶에서 단순히 습관들이나 법원들의 결정들 또는 다른 공무담당자들의 행위들을 예측하는 토대로 기능하는 것이 아니라, 수용된 법적 행위 기준들(accepted legal standards of behaviour)로 기능한다. 즉 그들은 단지 법이 자신들에게 요구하는 것을 (p. 138) 상당한 정도의 반복적 일양성(tolerable regularity)으로 행할 뿐만 아니라, 그것을 법적 행위 기준으로 바라보고, 타인들을 비판하거나 요구들을 정당화할 때 그것을 참조하며, 타인들이 자신들에게 가하는 비판들과 요구들을 받아들일 때에도 그것을 참조한다. 법규칙들을 이러한 규범적 방식으로 사용할 때 그들은 물론 법원들과 기타 공무담당자들이 해당 체계의 규칙들에 따라 반복적으로 일양적인, 따라서 예측 가능한 일정한 방식들로 계속 결정하고 행동할 것이라고 상정한다. 그러나 개인들이 법원들의 결정들이나 제재가 적용될 개연성을 기록하고 예측하는 외부 관점(external point of view)에 자신들을 한정하지 않는다는 것은 분명히 관찰 가능한 사회생활의 사실이다. 그 대신 그들은 행위의 지침으로서 법에 대한 공유된 수용을 규범적 용어들로 계속 표현한다. 우리는 제3장에서 ‘의무(obligation)’와 같은 규범적 용어들이 공무담당 행위에 대한 예측 이상의 아무것도 의미하지 않는다는 주장을 상세히 검토했다. 우리가 논변했듯이 그 주장이 거짓이라면, 법규칙들은 사회생활 속에서 그러한 것으로 기능한다. 그것들은 습관들이나 예측들의 서술이 아니라 규칙들로서 사용된다(used). 물론 그것들은 개방적 직조를 지닌 규칙들이며, 그 직조가 열린 지점들에서 개인들은 법원들이 어떻게 결정할지를 예측하고 그에 따라 자기 행위를 조정할 수 있을 뿐이다.

규칙회의주의는 우리의 진지한 주의를 요구하지만, 오직 사법적 결정(judicial decision)에서 규칙들이 수행하는 기능에 관한 이론으로서만 그렇다. 이 형태에서, 앞서 우리가 주의를 환기한 모든 반론들을 인정하면서도, 그것은 법원들에 관한 한 개방적 직조의 영역을 경계 지을 아무것도 없다는 논지(contention)에 이른다. 따라서 판사들을 그들이 하는 방식으로 사건들을 결정하도록 스스로 규칙들에 종속되어 있거나 규칙들에 ‘구속되어(bound)’ 있다고 보는 것은, 무의미하지 않더라도 거짓이라는 것이다. 판사들은 충분히 예측 가능한 정도의 반복적 일양성(regularity)과 일양성(uniformity)을 가지고 행동하여,

다른 사람들이 긴 기간에 걸쳐 법원의 결정들에 의해 규칙들처럼 살아갈 수 있게 할 수 있다. 판사들은 심지어 자신들이 그렇게 결정할 때 강제감(feelings of compulsion)을 경험할 수도 있고, 이러한 감정들 역시 예측 가능할 수 있다. 그러나 이 너머에는 그들이 준수하는 규칙으로 특징지을 수 있는 것은 아무것도 없다. 법원들이 올바른 사법적 행위의 기준들(standards of correct judicial behaviour)로 취급하는 것은 아무것도 없으며, 따라서 그 행위 안에는 규칙들의 수용에 특징적인 내부 관점(internal point of view)을 드러내는 것도 아무것도 없다는 것이다.

이 이론의 이러한 형태는 매우 다양한 성격과 중요도를 지닌 근거들로부터 지지를 얻는다. 규칙회의주의자는 (p. 139) 때로는 실망한 절대주의자(absolutist)이다. 그는 규칙들이 형식주의자의 이상세계(formalist's heaven)에서 그러할 모습 그대로도 아니며, 인간이 신들처럼 되어 모든 가능한 사실의 조합을 예견할 수 있고 그래서 개방적 직조가 규칙들의 필수적 특징이 아닌 세계에서 그러할 모습 그대로도 아니라는 점을 발견한 것이다. 규칙이 존재한다는 것이 무엇인지에 관한 회의주의자의 구상은 도달 불가능한 이상(ideal)일 수 있고, 소위 규칙이라 불리는 것에서 그 이상이 달성되지 않는다는 것을 발견할 때, 그는 규칙들이 존재한다거나 존재할 수 있다는 것을 부정함으로써 자신의 실망을 표현한다. 이렇게 해서, 판사들이 사건을 판결할 때 자신들을 구속한다고 주장하는 규칙들이 개방적 직조를 갖고 있다거나, 사전에 소진적으로 특정될 수 없는 예외들을 가진다는 사실, 그리고 규칙으로부터의 일탈이 판사에게 물리적 제재(physical sanction)를 불러오지 않는다는 사실은 회의주의자의 주장을 확립하는 데 자주 이용된다. 이 사실들은 다음과 같은 점을 보이기 위해 강조된다. “규칙들이 중요한 것은 판사들이 무엇을 할지를 예측하는 데 도움을 주는 한에서이다. 예쁜 장난감(pretty playthings)으로서의 중요성을 제외하면 그것이 규칙들의 중요성의 전부이다.”¹

이런 식으로 논변하는 것은 현실 생활의 어떤 영역에서든 규칙들이 실제로 무엇인지를 무시하는 것이다. 그것은 우리가 다음의 딜레마에 직면해 있다고 시사한다. “규칙들은 형식주의자의 천국(formalist's heaven)에서 그러할 모습

¹Llewellyn, *The Bramble Bush* (2nd edn.), p. 9.

그대로이며 족쇄가 구속하듯 구속하거나, 아니면 규칙들은 없고 예측 가능한 결정들이나 행위 양식들만 있다.” 그러나 분명 이것은 거짓 딜레마다. 우리는 다음 날 친구를 방문하겠다고 약속한다. 그 날이 오자 그 약속을 지키는 것이 위험하게 아픈 누군가를 방치하는 것을 수반하게 된다. 이것이 약속을 지키지 않는 적절한 이유로 수용된다는 사실은, 약속을 지킬 것을 요구하는 규칙은 없고 약속을 지키는 데 어떤 반복적 일양성만 있을 뿐이라는 것을 결코 의미하지 않는다. 그러한 규칙들에 소진적으로 진술될 수 없는 예외들이 있다는 사실로부터, 모든 상황에서 우리가 우리의 재량에 맡겨져 있고 결코 약속을 지키도록 구속되지 않는다는 결론은 따르지 않는다. ‘…하지 않는 한(unless …)’이라는 말로 끝나는 규칙도 여전히 규칙이다.

때때로 법원들을 구속하는 규칙들의 존재는, 어떤 사람이 특정한 방식으로 행위함으로써 자신에게 그렇게 행위할 것을 요구하는 규칙에 대한 수용을 드러냈는지 여부라는 문제가, 그 사람이 행위하기 전이나 행위하면서 거친 사고 과정들에 관한 심리학적 문제들과 (p. 140) 혼동되기 때문에 부정된다. 매우 자주, 어떤 사람이 규칙을 구속력 있는 것으로, 그리고 자신과 타인들이 자유롭게 바꿀 수 없는 것으로 수용할 때, 그는 주어진 상황에서 그것이 무엇을 요구하는지를 아주 직관적으로 보고, 먼저 그 규칙과 그것이 요구하는 것을 생각하지 않고도 그것을 행할 수 있다. 우리가 체스에서 규칙들에 부합하여 말을 움직이거나 신호등이 빨간색일 때 멈출 때, 우리의 규칙-준수(rule-complying) 행위는 종종 규칙들의 관점에서 계산에 의해 매개되지 않은, 상황에 대한 직접 반응이다. 그러한 행위들이 규칙의 진정한 적용이라는 증거는 그것들이 특정한 상황들 속에 놓여 있다는 점이다. 이 상황들 가운데 일부는 특정 행위에 앞서 있고, 다른 일부는 그 뒤를 따른다. 또 그 일부는 일반적이고 가설적인 용어들로만 진술될 수 있다. 행위하면서 우리가 규칙을 적용했다는 것을 보여 주는 이 요소들 가운데 가장 중요한 것은, 만약(if) 우리의 행위가 문제 제기된다면 우리는 그 행위를 그 규칙을 참조하여 정당화하려는 성향이 있다는 점이다. 그리고 규칙에 대한 우리의 수용의 진정성은 그것에 대한 우리의 과거 및 이후의 일반적 인정(acknowledgements)과 그것에의 부합(conformity)뿐 아니라, 우리 자신의 일탈과 타인의 일탈에 대한 비판에서도 드러날 수 있다. 이러한 증거나 유사한 증

거에 근거하여 우리는 기실, 규칙에 대한 우리의 ‘생각 없는’ 준수(compliance)에 앞서 무엇이 해야 할 옳은 일이고 왜 그런지를 말하라는 질문을 받았다면, 정직할 경우 우리는 답변에서 그 규칙을 인용했을 것이라고 결론 내릴 수 있다. 진정으로 규칙의 준수(observance)인 행위를, 단지 우연히 그것과 일치하는(coincide with) 행위와 구별하는 데 필요한 것은, 우리의 행위가 그러한 상황들 속에 놓여 있다는 점이지, 규칙에 대한 명시적 사고가 그 행위에 수반되었다는 점이 아니다. 바로 이렇게 우리는, 수용된 규칙의 준수(compliance)로서의 성인 체스 플레이어의 수와, 단지 말을 옳은 자리로 밀어 넣은 아기의 행위를 구별할 것이다.

이것은 가장이나 ‘겉치레(window dressing)’가 불가능하다는 말이 아니며, 그것은 때때로 성공할 수도 있다. 어떤 사람이 자신이 규칙에 근거하여 행위했다고 단지 사후적으로(ex post facto) 가장했는지를 가리는 검사들은, 모든 경험적 검사들처럼 본질적으로 오류 가능하지만, 고질적으로 그런 것은 아니다. 어떤 사회에서 판사들이 언제나 먼저 직관적으로 또는 ‘직감으로(by hunches)’ 결정을 내리고, 그런 다음 법규칙들의 목록에서 당면 사건과 닮았다고 가장한 규칙 하나를 단지 선택할 수도 있다. 그러고 나서 그들은 이것이 자신들의 결정을 요구하는 것으로 자신들이 간주한 규칙이라고 주장할 수 있지만, 그들의 행위나 말의 다른 어떤 것도 (p. 141) 그들이 그것을 자신들을 구속하는 규칙으로 간주했다는 것을 시사하지 않을 수 있다. 일부 사법적 결정들은 이와 같을 수 있다. 그러나 대부분의 경우 결정들은 체스 플레이어의 수처럼, 결정의 인도 기준들로 의식적으로 받아들인 규칙들에 부합하려는 진정한 노력에 의해 도달되거나, 만약 직관적으로 도달되었다면, 판사가 사전에 준수하려는 성향을 가지고 있었고 당면 사건과의 관련성이 일반적으로 인정될 규칙들에 의해 정당화된다는 점은 분명하다.

규칙회의주의(rule-scepticism)의 마지막이자 가장 흥미로운 형태는 법규칙들의 개방적 성격이나 많은 결정들의 직관적 성격에 근거하지 않고, 법원의 결정이 권위 있는 것(something authoritative)으로서 독특한 지위를 가지며, 최고 법원들(supreme tribunals)의 경우에는 최종적(final)이라는 사실에 근거한다. 우리가 다음 절을 할애할 이 형태의 이론은, 그레이(Gray)가 *The Nature and*

*Sources of Law*에서 그렇게 자주 되풀이한 호들리(Hoadly) 주교의 유명한 구절에 암묵적으로 들어 있다. “글로 쓰였든 말로 발화되었든 어떤 법들을 해석할 절대적 권위(absolute authority)를 가진 자가 있다면, 사실상 모든 면에서 입법자(lawgiver)는 바로 그 사람이니 그것들을 처음 쓰거나 말한 사람이 아니다.”

3. 사법적 결정에서의 최종성(Finality)과 무오류성(Infallibility)

최고 법원(supreme tribunal)은 법이 무엇인지를 말하는 데 최후의 말(last word)을 가지며, 일단 그렇게 말하면 그 법원이 ‘그르다(wrong)’는 진술은 그 체계 안에서는 아무런 귀결도 갖지 않는다. 그로 인해 누구의 권리들이나 책무들도 변경되지 않는다. 그 결정은 물론 입법(legislation)에 의해 법적 효과(legal effect)를 박탈당할 수 있지만, 이에 호소하는 것이 필요하다는 바로 그 사실은, 법에 관한 한 법원의 결정이 그르다는 진술의 공허한 성격을 보여 준다. 이러한 사실들을 고려하면, 최고 법원의 결정들의 경우 그 최종성(finality)과 무오류성(infallibility)을 구분하는 것은 현학적인 것처럼 보인다. 이것은 법원들이 결정할 때 언제나 규칙들에 구속된다는 것을 부정하는 또 다른 형태로 이어진다. “법(또는 헌법)은 법원들이 그것이라고 말하는 것이다.”

이러한 형태의 이론에서 가장 흥미롭고 교훈적인 특징은 ‘법(또는 헌법)은 법원들이 그것이라고 말하는 것이다’와 같은 진술들의 애매성(ambiguity)을 이용한다는 점, 그리고 이 이론이 일관되려면 (p. 142) 법에 대한 비공식 진술들과 법원의 공식 진술들 사이의 관계에 관해 제시해야 하는 설명이다. 이 애매성을 이해하기 위해 우리는 잠시 돌아서 게임의 경우에 있는 유비를 검토할 것이다. 많은 경쟁적 게임들은 공식 득점기록자(official scorer) 없이 행해진다. 경쟁하는 이익들에도 불구하고, 선수들은 득점 규칙을 특정 사례들에 적용하는데 상당히 잘 성공한다. 그들은 보통 자기 판단들에서 일치하며, 해소되지 않은 다툼들은 적을 수 있다. 공식 득점기록자 제도가 도입되기 전에, 어떤 선수가 한 득점 진술은, 그가 정직하다면, 그 게임에서 수용된 특정 득점 규칙을 참조하여 게임의 진행을 평가하려는 노력이다. 그러한 득점 진술들은 득점 규칙을 적용하는 내부 진술들(internal statements)이며, 선수들이 일반적으로

규칙들을 지키고 그 위반에 이의를 제기할 것임을 전제하지만, 이러한 사실들의 진술들이나 예측들은 아니다.

관습 체제에서 성숙한 법체제로의 변화와 마찬가지로, 그 판정들이 최종적인 득점기록자 제도를 마련하는 이차 규칙들(secondary rules)이 게임에 추가되면, 체계 안에는 새로운 종류의 내부 진술이 들어온다. 선수들의 득점 진술들과 달리, 득점기록자의 결정들(determinations)은 이차 규칙들에 의해 다룰 수 없는 지위를 부여받기 때문이다. 게임의 목적상 ‘득점은 득점기록자가 말하는 것이다’ 라는 말이 참인 것은 이런(this) 의미에서이다. 그러나 득점 규칙(scoring rule)은 이전 그대로 남아 있으며, 득점기록자의 책무(duty)는 그것을 자신이 할 수 있는 최선으로 적용하는 것임을 보는 것이 중요하다. ‘득점은 득점기록자가 말하는 것이다’ 가, 득점기록자가 자기 재량으로 적용하기로 선택한 것 외에는 득점 규칙이 없다는 뜻이라면 거짓일 것이다. 기실 그러한 규칙을 가진 게임도 있을 수 있고, 득점기록자의 재량이 어느 정도 반복적으로 일양적인 행사 양상을 보인다면 그것을 하는 데서 얼마간 즐거움을 찾을 수도 있을 것이다. 그러나 그것은 다른 게임일 것이다. 우리는 그러한 게임을 ‘득점기록자의 재량(scorer’s discretion)’ 게임이라고 부를 수 있다.

득점기록자가 가져오는 분쟁의 신속하고 최종적인 처리라는 이점들이 대가를 치르고 사들여진다는 점은 명백하다. 득점기록자 제도는 선수들을 곤경(predicament)에 직면시킬 수 있다. 이전과 같이 게임이 득점 규칙에 의해 규율되기를 바라는 소망과, 그 적용이 의심스러운 곳에서 그 적용에 관하여 최종적이고 권위 있는 결정들을 바라는 소망은 충돌하는 목적들로 드러날 수 있다. 득점기록자는 정직한 (p. 143) 실수를 할 수도 있고, 술에 취했을 수도 있으며, 자기 능력의 최선으로 득점 규칙을 적용해야 한다는 책무(duty)를 함부로 위반할 수도 있다. 그는 이 이유들 중 어느 하나 때문에, 타자가 전혀 움직이지 않았는데도 ‘득점(run)’ 을 기록할 수 있다. 상급 권위기관에 대한 항소로 그의 판정들을 교정하는 장치가 마련될 수 있다. 그러나 이것은 어딘가에서 최종적이고 권위 있는 판단(judgment)으로 끝나야 하며, 그것은 오류 가능성이 있는 인간 존재들에 의해 내려질 것이므로 정직한 실수, 남용, 또는 위반의 동일한 위험을 수반할 것이다. 모든 규칙의 위반을 교정하기 위한 규칙을 마련하는

것은 불가능하다.

규칙들을 최종적이고 권위 있게 적용할 권위기관(authority)을 세우는 데 내재한 위험은 어느 영역에서든 현실화될 수 있다. 게임이라는 소박한 영역에서 현실화될 수 있는 위험들은 고려할 가치가 있는데, 그것들이 이 형태의 권위(authority)가 사용되는 곳이면 어디서나 그것을 이해하는 데 필요한 몇몇 구별들을 규칙회의주의자가 무시한다는 점을 특히 분명한 방식으로 보여주기 때문이다. 공식 득점기록자(official scorer)가 세워지고 그의 득점 판정들(determinations)이 최종적인 것으로 만들어지면, 선수들이나 기타 비공식 인물들(non-officials)이 한 득점에 관한 진술들은 게임 안에서 아무런 지위를 갖지 않는다. 그것들은 그 결과에 무관하다. 그것들이 득점기록자의 진술과 우연히 일치하면 문제될 것이 없지만, 충돌한다면 결과를 산정할 때 무시되어야 한다. 그러나 이러한 매우 명백한 사실들은 선수들의 진술들이 득점기록자의 판정들에 대한 예측들로 분류된다면 왜곡될 것이며, 이러한 진술들이 득점기록자의 판정들과 충돌할 때 무시되는 것을 그것들이 거짓으로 드러난 판정들에 대한 예측들이었다고 말함으로써 설명하는 것은 터무니없을 것이다. 공식 득점기록자가 도입된 뒤에도, 선수는 자기 자신의 득점 진술들을 하면서 이전에 하던 일을 하고 있다. 즉 득점 규칙을 참조하여, 자신이 할 수 있는 최선으로 게임의 진행을 평가하고 있다. 득점기록자 자신도 자기 지위의 책무들을 이행하는 한 바로 이것을 하고 있다. 양자의 차이는 한쪽이 다른 쪽이 무엇을 말할지를 예측한다는 데 있지 않고, 선수들의 진술들은 득점 규칙의 비공식 적용들(unofficial applications)이어서 결과를 산정하는 데 의미가 없지만, 득점기록자의 진술들은 권위 있고 최종적이라는 데 있다. 만약 행해지는 게임이 ‘득점기록자의 재량(scorer’s discretion)’이라면, 비공식 진술들과 공식 진술들 사이의 관계가 (p. 144) 필연적으로 달라진다는 점을 관찰하는 것이 중요하다. 선수들의 진술들은 득점기록자의 판정들에 대한 예측일 것(would)일 뿐 아니라, 그 밖의 아무것도 될 수 없을(could) 것이다. 왜냐하면 그 경우 ‘득점은 득점기록자가 말하는 것이다’ 자체가 득점 규칙일 것이기 때문이다. 선수들의 진술들이 득점기록자가 공식적으로 하는 것의 단순한 비공식 판본들일 가능성은 없을 것이다. 그러면 득점기록자의 판정들은 최종적이고 무오류적

(infallible)일 것이다. 아니 오히려 그것들이 오류 가능한지 무오류적인지를 묻는 질문은 무의미할 것이다. 그에게 ‘옳게’ 또는 ‘그르게’ 할 것이 아무것도 없기 때문이다. 그러나 보통의 게임에서 ‘득점은 득점기록자가 말하는 것이다’는 득점 규칙이 아니다. 그것은 특정 사례들에서 득점 규칙에 대한 그의 적용의 권위와 최종성을 마련하는 규칙이다.

권위 있는 결정(authoritative decision)의 이 예에서 배울 두 번째 교훈은 더 근본적인 문제들에 닿아 있다. 우리는 보통의 게임과 ‘득점기록자의 재량’ 게임을 구별할 수 있는데, 이는 득점 규칙이 다른 규칙들과 마찬가지로 득점 기록자가 선택을 행사해야 하는 개방적 직조(open texture)의 영역을 가지고 있음에도 불구하고, 확정된 의미의 핵심(core of settled meaning)을 가지고 있기 때문이다. 바로 이것이 득점기록자가 자유롭게 이탈할 수 없는 것이며, 그것이 미치는 한에서 선수의 득점에 관한 비공식 진술들과 득점기록자의 공식 판정들 모두에 대해 올바른 득점과 올바르지 않은 득점의 기준을 구성한다. 바로 이것이 득점기록자의 판정들은 비록 최종적이지만 무오류적이지는 않다고 말하는 것을 참으로 만든다. 법에서도 동일하다.

어느 지점까지는 득점기록자가 내린 몇몇 판정들이 명백히 그르다는 사실은 게임이 계속되는 것과 양립하지 않는 것이 아니다. 그것들은 명백히 옳은 판정들만큼이나 동등하게 산입된다(count as much). 그러나 올바르지 않은 결정들(incorrect decisions)에 대한 관용이 동일한 게임의 계속된 존재와 양립할 수 있는 정도에는 한계가 있으며, 이것은 중요한 법적 유비를 가진다. 고립적이거나 예외적인 공식적 일탈들(official aberrations)이 용인된다는 사실은 크리켓이나 야구가 더 이상 행해지고 있지 않다는 것을 의미하지 않는다. 다른 한편, 이러한 일탈들이 빈번하거나 득점기록자가 득점 규칙을 거부한다면, 어느 지점에는 반드시 선수들이 득점기록자의 일탈적 판정들을 더 이상 수용하지 않거나, 만약 그들이 수용한다면 게임이 달라진 지점이 오게 된다. 그것은 더 이상 크리켓이나 야구가 아니라 ‘득점기록자의 재량’이다. 왜냐하면 이러한 다른 게임들의 규정적 특징(defining feature)은, 그 개방적 직조가 득점기록자에게 어떤 (p. 145) 재량의 폭(latitude)을 남겨두든, 일반적으로 그 결과들이 규칙의 명백한 의미(plain meaning)가 요구하는 방식으로 평가되어야 한다는 점이기 때문이다. 어

떤 상상 가능한 조건에서는 실제로 행해지고 있는 게임이 ‘득점기록자의 재량’이라고 말해야 할 것이다. 그러나 모든 게임들에서 득점기록자의 판정들이 최종적이라는 사실은 모든 게임들이 그것이라는 것을 의미하지 않는다.

특정 사례에서 법이 무엇인지에 대한 최종적이고 권위 있는 진술로서 법원의 결정이 가지는 고유한 지위에 근거한 규칙회의주의(rule-scepticism)의 형태를 평가할 때에는 이러한 구별들을 마음에 두어야 한다. 법의 개방적 직조는 법원들에게, 그 결정들이 법창출 선례들(law-making precedents)로 사용되지 않는 득점기록자들에게 남겨진 것보다 훨씬 더 넓고 중요한 법창출 권한(law-creating power)을 남긴다. 법원들이 무엇을 결정하든, 그것이 모두에게 명백해 보이는 규칙 부분 안에 놓인 문제이든 논쟁 가능한 경계에 놓인 문제이든, 입법에 의해 변경될 때까지 존립한다. 그리고 그 입법의 해석에 대해서도 법원들은 다시 동일한 최후의 권위 있는 목소리를 가질 것이다. 그럼에도 불구하고, 법원 체계를 세운 뒤 법은 최고 법원이 적합하다고 생각하는 것이면 무엇이든 된다고 규정하는 헌법과, 실제의 미국 헌법—또는 그 문제에 관해서는 어떤 현대 국가의 헌법—사이에는 여전히 구별이 남아 있다. ‘헌법(또는 법)은 판사들이 그것이라고 말하는 것이 무엇이든 그것이다’가 이 구별을 부정하는 것으로 해석된다면, 그것은 거짓이다. 어느 특정 시점에서 판사들, 심지어 최고 법원의 판사들도 그 규칙들이 중심에서는 올바른 사법적 결정의 기준들을 제공할 만큼 충분히 확정적인 체계의 일부이다. 이러한 기준들은 법원들에 의해, 체계 안에서 다룰 수 없는 결정들을 내릴 권위를 행사할 때 자유롭게 무시할 수 없는 것으로 간주된다. 어떤 개별 판사도 자기 직무에 올 때, 어떤 득점기록자가 자기 직무에 올 때와 마찬가지로, 의회 내 여왕의 제정물들(enactments)은 법이라는 규칙과 같은 규칙이 전통으로 확립되어 있고 그 직무 수행의 기준으로 수용되어 있음을 발견한다. 이것은 그 직무 점유자들의 창조적 활동을 허용하면서도 경계 짓는다. 이러한 기준들은 기실 그 시대 판사들 대부분이 그것들을 고수하지 않는다면 계속 존재할 수 없는데, 특정 시점에서 그것들의 존재는 단순히 올바른 재판의 기준들로 그것들이 수용되고 사용되는 데 있기 때문이다. 그러나 이것이 그 기준들을 사용하는 판사를 그 기준들의 창안자(author)로 만들거나, 호들리(Hoadly)의 언어로 말해 자기가 원하는 대로 (p. 146) 결정할 권능을 가진

‘입법자(lawgiver)’로 만들지는 않는다. 기준들을 유지하기 위해 판사의 고수는 필요하지만, 판사가 그것들을 만드는 것은 아니다.

물론 사법적 결정들을 최종적이고 권위 있는 것으로 만드는 규칙들의 보호막(shield) 배후에서, 판사들이 결합하여 기존 규칙들을 거부하고 심지어 가장 명확한 의회 법률들(Acts of Parliament)조차도 자신들의 결정들에 어떤 한계도 부과하는 것으로 간주하기를 중단할 가능성은 있다. 그들의 판정들 대다수가 이러한 성격을 가지고 수용된다면, 이것은 크리켓에서 ‘득점기록자의 재량’으로 게임이 전환되는 것과 평행한 체계의 변형에 해당할 것이다. 그러나 그러한 변형들의 상존 가능성은, 그 변형이 일어났다면 체계가 그러했을 바로 그것이 현재의 체계라는 것을 보여 주지 않는다. 어떤 규칙들도 위반이나 거부(repudiation)에 대해 보장될 수 없다. 인간 존재들이 그것들을 깨거나 거부하는 것은 결코 심리적으로나 물리적으로 불가능하지 않기 때문이다. 그리고 충분히 많은 사람들이 충분히 오래 그렇게 한다면, 그 규칙들은 존재를 중단할 것이다. 그러나 특정 시점에서 규칙들이 존재한다는 것은 파괴에 대한 이러한 불가능한 보장들이 있어야 한다는 것을 요구하지 않는다. 어떤 시점에 판사들이 의회 법률들(Acts of Parliament) 또는 연방의회 법률들(Acts of Congress)을 법으로 수용할 것을 요구하는 규칙이 있다고 말하는 것은, 첫째, 이 요구사항에 대한 일반적 준수(compliance)가 있고 개별 판사들의 이탈이나 거부는 드물다는 것, 둘째, 그것이 발생하거나 발생한다면 우세한 다수(preponderant majority)에 의해 심각한 비판의 대상으로, 그리고 그른(wrong) 것으로 취급되거나 취급될 것이라는 것을 수반한다. 비록 특정 사례에서 그에 따라 내려진 결정의 결과는, 결정들의 최종성에 관한 규칙 때문에, 그 결정의 올바름(correctness)이 아니라 유효성(validity)을 인정하는 입법에 의해서만 상쇄될 수 있다고 하더라도 말이다. 인간 존재들이 자기 약속들을 모두 어기는 것은 논리적으로 가능하다. 처음에는 아마도 그것이 그른 행위라는 감각을 가지고, 그다음에는 그러한 감각 없이 그럴 수 있다. 그러면 약속을 지키는 것을 의무적인 것으로 만드는 규칙은 존재를 중단할 것이다. 그러나 이것은 현재 그러한 규칙이 존재하지 않고 약속들이 실제로 구속력이 없다는 견해를 빈약하게 지지할 뿐이다. 판사들의 경우에서, 그들이 현재 체계의 파괴를 기획해 이끌어낼 가능성에 근거한 평행

논변은 이보다 더 강하지 않다.

규칙회의주의의 주제를 떠나기 전에 우리는, 규칙들이 법원들의 결정들에 대한 예측들이라는 그 적극적 논지(contention)에 관해 마지막 말을 해야 한다. 여기에 어떤 진리가 있든, 그것은 기껏해야 사적 개인들이나 그 조언자들이 제시하는 법 진술들(statements of law)에 적용될 수 있다는 점은 명백하며 자주 (p. 147) 언급되어 왔다. 그것은 법원들 자신의 법규칙 진술들에는 적용될 수 없다. 이것들은 일부 더 극단적인 ‘현실주의자들(Realists)’이 주장했듯이 속박 없는 재량 행사를 위한 언어적 덮개(verbal covering)이거나, 아니면 법원들이 내부 관점에서 올바른 결정의 기준으로 진정으로 간주하는 규칙들의 정식화여야 한다. 다른 한편, 사법적 결정들에 대한 예측들은 법 안에서 부정할 수 없이 중요한 자리를 가진다. 개방적 직조(open texture)의 영역에 도달할 때, ‘이 문제에서 법은 무엇인가?’라는 질문에 대한 답으로 우리가 유익하게 제공할 수 있는 전부가 법원들이 무엇을 할지에 대한 조심스러운 예측인 경우가 매우 흔하다. 더 나아가, 규칙들이 요구하는 것이 모두에게 명확한 경우에도 그것에 대한 진술은 법원의 결정에 대한 예측의 형식으로 이루어지는 경우가 많다. 그러나 주로 후자의 경우에, 그리고 전자의 경우에는 다양한 정도로, 그러한 예측의 토대는 법원들이 법규칙들을 예측들로서가 아니라 결정에서 따라야 할 기준들로 간주한다는 지식이라는 점을 주목하는 것이 중요하다. 그 기준들은 그 개방적 직조에도 불구하고 법원의 재량을 배제하지는 않더라도 제한할 만큼 충분히 확정적이다. 따라서 많은 경우 법원이 무엇을 할지에 대한 예측들은, 체스 선수들이 비숍을 대각선으로 움직일 것이라고 우리가 할 수 있는 예측과 같다. 그것들은 궁극적으로 규칙들의 비예측적(non-predictive) 측면과, 그 예측들이 관련되는 자들이 기준들로서 수용한 규칙들의 내부 관점에 대한 이해에 기초한다(rest on). 이것은, 어떤 사회 집단에서 규칙들이 존재한다는 사실이 예측들을 가능하게 하고 자주 신뢰할 수 있게 만들지만 그것과 동일시될 수는 없다는, 제5장에서 이미 강조한 사실의 또 다른 측면일 뿐이다.

4. 승인 규칙에서의 불확실성(UNCERTAINTY)

형식주의와 규칙회의주의는 법리학적 이론(juristic theory)의 스킬라(Scylla)와 카립디스(Charybdis)이다. 그것들은 서로를 교정하는 곳에서는 유익한 거대한 과장들이며, 진리는 그 사이에 있다. 이 중도적 길을 유익한 세부 내용으로 특징 짓고, 제정법(statute)이나 선례에서 법의 개방적 직조가 법원들에게 남겨 두는 창조적 기능을 수행할 때 법원들이 특징적으로 사용하는 다양한 추론 유형들을 보여 주기 위해서는, 기실 여기에서 시도될 수 없는 많은 일이 행해져야 한다. 그러나 우리는 (p. 148) 이 장에서, 제6장 말미에 미뤄 두었던 중요한 주제로 유익하게 돌아갈 수 있을 만큼은 말했다. 이것은 특정 법규칙들의 불확실성이 아니라 승인 규칙의 불확실성, 따라서 법원들이 유효한 법규칙들을 식별할 때 사용하는 궁극적 기준들의 불확실성에 관한 것이었다. 특정 규칙의 불확실성과 그것을 체계의 규칙으로 식별하는 데 사용되는 기준의 불확실성 사이의 구별은 그 자체로 모든 경우에 명확한 것은 아니다. 그러나 규칙들이 권위 있는 텍스트를 가진 제정법 형식의 제정물들(statutory enactments)인 경우에 그 구별은 가장 명확하다. 제정법(statute)의 문언과 그것이 특정 사례에서 요구하는 것은 완전히 명백할 수 있다. 그런데도 입법부가 이런 방식으로 입법할 권한(power)을 가지는지에 관해서는 의문들이 있을 수 있다. 때때로 이러한 의문들의 해소(resolution)는 입법 권한을 부여한 또 다른 법규칙의 해석만을 요구하며, 이 규칙의 유효성은 의심스럽지 않을 수 있다. 예컨대 종속된 권한기관(subordinate authority)이 만든 제정물(enactment)의 유효성이 문제되는 경우가 그럴 것이다. 종속된 권한기관의 입법 권한들을 규정하는 모법(parent Act of Parliament)의 의미에 관해 의문들이 발생하기 때문이다. 이것은 특정 제정법(statute)의 불확실성 또는 개방적 직조의 사례일 뿐이며 어떤 근본적 문제도 제기하지 않는다.

그러한 통상적 문제들과 구별되어야 할 것은 최고 입법부(supreme legislature) 자체의 법적 권능(legal competence)에 관한 문제들이다. 이것들은 법적 유효성의 궁극적 기준들(ultimate criteria of legal validity)에 관한 것이며, 최고 입법부의 권능을 특정하는 성문헌법(written constitution)이 없는 우리 자신의 체계와 같은 법체계에서도 발생할 수 있다. 압도적 다수의 사례들에서 ‘의회

내 여왕이 제정하는 것은 무엇이든 법이다' 라는 공식은 의회의 법적 권능에 관한 규칙의 적절한 표현이며, 그렇게 식별된 규칙들이 그 주변부에서는 아무리 열려 있을 수 있더라도, 법의 식별을 위한 궁극적 기준으로 수용된다. 그러나 그 의미나 범위에 관해 의문들이 발생할 수 있다. 우리는 '의회에 의해 제정된(enacted by Parliament)' 이라는 말이 무엇을 의미하는지 물을 수 있으며, 의문들이 발생하면 그것들은 법원들에 의해 해소될 수 있다. 한 법체계의 궁극적 규칙이 이처럼 의심스러울 수 있고 법원들이 그 의문을 해소할 수 있다는 사실로부터, 법체계 안에서 법원들의 위치에 관해 어떤 추론이 도출되어야 하는가? 그것은 법체계의 토대가 법적 유효성의 기준들을 특정하는 수용된 승인 규칙이라는 테제에 어떤 한정을 요구하는가?

(p. 149) 이러한 질문들에 답하기 위해 여기서는 영국 의회주권(parliamentary sovereignty) 교설의 몇몇 측면들을 검토할 것이다. 물론 유사한 의문들은 어떤 체계에서든 법적 유효성의 궁극적 기준들과 관련하여 발생할 수 있다. 법은 본질적으로 법적으로 제약받지 않는 의지의 산물이라는 오스틴주의 교설의 영향 아래에서, 오래된 헌법이론가들은 마치 주권적인 입법부가 존재해야 한다는 것이 논리적 필연성인 것처럼 썼다. 여기서 주권적이라는 것은, 그 입법부가 계속적 기구(continuing body)로 존재하는 모든 순간에 외부로부터(ab extra) 부과된 법적 제한들뿐 아니라 자기 자신의 선행 입법(prior legislation)으로부터도 자유롭다는 의미이다. 이러한 의미에서 의회가 주권적이라는 점은 이제 확립된 것으로 간주될 수 있으며, 이전 의회는 자기 입법을 폐지하지 못하도록 자신의 '승계자들(successors)' 을 막을 수 없다는 원칙은 법원들이 유효한 법규칙들을 식별할 때 사용하는 궁극적 승인 규칙의 일부를 구성한다. 그러나 그러한 의회가 존재해야 한다고 명하는 것은 논리의 필연성도, 하물며 자연의 필연성도 아니라는 점을 보는 것이 중요하다. 그것은 똑같이 상상 가능한 여러 배치들 가운데 하나일 뿐이며, 우리의 체계에서 법적 유효성의 기준으로 수용되게 된 것이다. 그러한 다른 배치들 가운데에는 아마도 더 나을지도 모르겠지만, 똑같이 '주권' 이라는 이름을 받을 자격이 있는 또 다른 원칙이 있다. 그것은 의회가 자신의 승계자들의 입법 권능(legislative competence)을 불가역적으로 제한할 수 없는 상태여서는 안 되며(not), 반대로 이러한 더 넓은 자기제한 권한(self-limiting

power)을 가져야 한다는 원칙이다. 그러면 의회는 그 역사에서 적어도 한 번은 수용되고 확립된 교설이 허용하는 것보다 훨씬 더 큰 입법 권능의 영역을 행사할 능력을 가지게 될 것이다. 의회가 그 존재의 모든 순간에, 심지어 자기 자신에 의해 부과된 것들을 포함한 법적 제한들로부터 자유로워야 한다는 요구는, 결국 법적 전능(legal omnipotence)이라는 애매한 관념의 한 해석일 뿐이다. 그것은 사실상, 잇따른 의회들(successive parliaments)의 입법 권능에 영향을 미치지 않는 모든 사항에서의 계속적(continuing) 전능과, 그 행사가 오직 한 번만 향유될 수 있는 제한 없는 자기포섭적(self-embracing) 전능 사이에서 선택한다. 이 두 전능 구상들은 전능한 신에 관한 두 구상에서 평행을 가진다. 한편에는 자기 존재의 모든 순간에 동일한 능력들(powers)을 누리고 따라서 그 능력들을 줄일 수 없는 신이 있고, 다른 한편에는 장래를 향해 자기 전능을 파괴할 능력(power)을 포함하는 능력들을 가진 신이 있다. 우리의 의회가 어떤 형태의 전능-계속적 전능인지 자기포섭적 전능인지-을 누리는지는 법을 식별하는 궁극적 기준으로 수용되는 규칙의 형식에 관한 경험적 질문이다. 그것은 법체계의 토대에 놓인 규칙에 관한 질문이지만, 여전히 어느 주어진 시점에는 적어도 어떤 점들에 관해 상당히 확정적인 답이 있을 수 있는 사실의 문제이다. 따라서 현재 수용된 규칙은 계속적 주권의 규칙이며, 그래서 의회는 자기 제정법들(statutes)을 폐지로부터 보호할 수 없다는 점은 명확하다.

그러나 다른 모든 규칙에서와 마찬가지로, 의회주권(parliamentary sovereignty)의 규칙이 이 지점에서 확정적(determinate)이라는 사실은 그것이 모든 지점에서 그러하다는 것을 의미하지 않는다. 현재 명확히 옳거나 그른 답이 없는 질문들이 그것에 관해 제기될 수 있다. 이것들은 이 문제에서 결국 그 선택들에 권위가 부여되는 누군가가 하는 선택에 의해서만 확정될 수 있다. 의회주권 규칙 안의 그러한 불확정성들(indeterminacies)은 다음 방식으로 나타난다. 현행 규칙 아래에서는, 의회가 제정법(statute)에 의해 어떤 사항을 장래 의회의 입법 범위에서 불가역적으로 철회할 수 없다는 점이 인정된다. 그러나 단순히 그렇게 한다고 표방하는 제정물(enactment)과, 의회가 여전히 어떤 사항에 관해서든 입법할 가능성을 열어 두면서도 입법의 ‘방식과 형식(manner and form)’을 변경한다고 표방하는 제정물 사이에는 구별이 그어질 수 있다. 후자는 예컨대

특정 쟁점들에 대해서는 양원이 함께 앉아 다수결로 통과시키거나 국민투표(plebiscite)로 확인되지 않는 한 어떤 입법도 법으로서 효력을 갖지 못한다고 요구할 수 있다. 그것은 그 조항 자체가 동일한 특별 절차에 의해서만 폐지될 수 있다는 규정으로 그러한 조항을 ‘강화 고착(entrench)’ 할 수 있다. 입법 과정에서 그러한 부분적 변경은 의회가 자기 승계자들을 불가역적으로 구속할 수 없다는 현행 규칙과 충분히 양립할 수 있다. 그것이 하는 일은 승계자들을 구속(bind)한다기보다는, 특정 쟁점들에 관한 한(quoad) 그들을 제거하고 이 쟁점들에 관한 그들의 입법 권한들을 새로운 특별 기구(body)로 이전하는 것이기 때문이다. 따라서 이러한 특별 쟁점들과 관련하여 의회는 의회를 ‘구속’하거나 ‘족쇄를 채우거나(fettered)’ 그 계속적 전능을 감소시킨 것이 아니라, ‘의회’와 입법하기 위해 행해져야 하는 것을 ‘재규정(redefined)’ 했다고 말할 수 있다.

명백히 이 장치가 유효하다면, 의회는 (p. 151) 그것을 사용하여 의회가 자기 승계자들을 구속할 수 없다는 수용된 교설이 자신의 권한 밖에 두는 것처럼 보이는 결과들과 매우 유사한 결과들을 달성할 수 있을 것이다. 왜냐하면 의회가 입법할 수 있는 영역을 경계 짓는 것과 입법의 방식과 형식만을 변경하는 것 사이의 차이는 기실 몇몇 경우에는 충분히 명확하지만, 실제 효과상 이 범주들은 서로 점차 맞물리며 경계가 흐려지기 때문이다(shade into each other). 엔지니어들의 최저임금을 정한 뒤, 엔지니어 임금에 관한 어떤 법안도 엔지니어 노동조합(Engineers' Union)의 결의로 확인되지 않는 한 법으로서 효력을 가지지 않는다고 규정하고, 이어서 이 조항을 강화 고착한 제정법(statute)은, 임금을 ‘영원히’ 고정하고 그 폐지를 거칠게 전면 금지한 제정법(statute)이 실제로 할 수 있는 모든 것을 기실 확보할 수도 있다. 그러나 법률가들이 어느 정도 설득력을 가진 것으로 인정할 논변(argument)은, 비록 후자는 현재의 계속적 의회주권 규칙 아래에서는 효력이 없을 것이지만 전자는 그렇지 않을 것임을 보이도록 제시될 수 있다. 이 논변의 단계들은 의회가 무엇을 할 수 있는지에 관한 일련의 논지들(contentions)로 이루어지며, 각 논지는 그 앞의 논지와 일정한 유비를 가지면서도 그 앞의 논지보다 더 적은 동의를 얻을 것이다. 그중 어떤 것도 그르다고 배제될 수 없고, 옳다고 자신 있게 수용될 수도 없다. 우리는 체계의 가장 근본적인 규칙의 개방적 직조 영역 안에 있기 때문이다. 여기서는 어느

순간에도 답은 없고 오직 답들만 있는 질문이 제기될 수 있다.

따라서 의회가 상원을 완전히 폐지함으로써 의회의 현재 구성을 불가역적으로 변경할 수도 있고, 그래서 특정 입법에 대한 상원의 동의를 면제했으며 일부 권위 있는 논자들이 단지 여왕과 하원에 대한 의회 권한들 일부의 철회 가능한 위임으로 해석하기를 선호하는 1911년 및 1949년 의회법들(Parliament Acts)을 넘어서 수 있다는 점이 인정될지도 모른다. 또한 다이시(Dicey)가 단언했듯이,² 의회가 자기 권한들이 끝났음을 선언하고 장래 의회들의 선거를 마련하는 입법을 폐지하는 법률(Act)에 의해 자기 자신을 완전히 파괴할 수 있다는 점도 인정될지도 모른다. 그렇다면 의회는 맨체스터 법인(Manchester Corporation) 같은 어떤 다른 기관에 자신의 모든 권한들을 이전하는 법률을 통해 이러한 입법적 자살(legislative suicide)을 유효하게 수반시킬 수도 있을 것이다. 의회가 이것을 할 수 있다면, 그보다 적은 것을 실효적으로 할 수는 없는가? 특정 사항들에 관해 (p. 152) 입법할 자신의 권한들을 끝내고, 그것들을 자기 자신과 어떤 추가 기관을 포함하는 새로운 복합 실체(composite entity)에 이전할 수는 없는가? 이러한 기초 위에서, 도미니언(Dominion)에 영향을 미치는 어떤 입법에 대해서도 도미니언의 동의를 요구한 웨스트민스터 제정법(Statute of Westminster) 제4조가, 도미니언을 위해 입법할 의회의 권한들과 관련하여 실제로 이 일을 했을 수도 있지 않은가? 이 조항이 도미니언의 동의 없이 실효적으로 폐지될 수 있다는 논지(contention)는, 상키 경(Lord Sankey)이 말했듯이 ‘현실과 아무 관계가 없는’ ‘이론’ 일 뿐만 아니라, 나쁜 이론일 수도 있다. 또는 적어도 반대 이론보다 나은 것이 없을 수 있다. 마지막으로, 의회가 자기 자신의 행위에 의해 이런 방식으로 재구성될 수 있다면, 왜 그것은 엔지니어 노동조합(Engineers' Union)이 특정 유형의 입법에서 필수적인 동의 요소(consenting element)가 되도록 규정함으로써 자기 자신을 재구성할 수 없는가?

이 논변에서 의심스럽지만 명백히 잘못된 것은 아닌 단계들을 구성하는 몇몇 의문스러운 명제들이, 언젠가 그 문제를 결정하도록 요청받은 법원에 의해 승인되거나 거부될 가능성은 충분히 있다. 그러면 우리는 그것들이 제기하는

² *The Law of the Constitution*(10th edn.), p. 68 n.

질문들에 대한 답을 갖게 될 것이며, 그 답은 체계가 존재하는 한, 주어질 수 있는 답들 가운데 유일한 권위 있는 지위를 가질 것이다. 법원들은 이 지점에서 유효한 법을 식별하는 궁극적 규칙을 확정적인 것으로 만들었을 것이다. 여기서 ‘헌법은 판사들이 말하는 것이다’는 말은 최고 법원들(supreme tribunals)의 특정 결정들이 다투어질 수 없다는 것만을 의미하지 않는다. 처음 보기에는 그 광경이 역설적으로 보인다. 여기에는 법원들이, 판사로서 자신들에게 관할권(jurisdiction)을 부여하는 바로 그 법들의 유효성 자체가 그 기준들에 의해 검사되어야 하는 궁극적 기준들을 확정하는 창조적 권한들을 행사하고 있기 때문이다. 어떻게 헌법이 헌법이 무엇인지를 말할 권위를 부여할 수 있는가? 그러나 모든 규칙이 어떤 지점들에서는 의심스러울 수 있지만, 모든 규칙이 모든 지점에서 의심에 열려 있지는 않다는 것이 기실 법체계가 존재하기 위한 필요조건이라는 점을 기억하면 이 역설은 사라진다. 어느 주어진 시점에 법원들이 궁극적 유효성 기준들에 관한 이러한 한계 질문들(limiting questions)을 결정할 권위를 가질 가능성은, 단지 그 시점에는 그 권위를 부여하는 규칙들을 포함하여 광대한 법 영역에 대한 그 기준들의 적용이 아무 의문도 제기하지 않는다는 사실에 의존한다. 비록 그 기준들의 정확한 범위(scope)와 적용범위(ambit)에 대해서는 의문이 제기되더라도 말이다.

(p. 153) 그러나 이 답은 어떤 이들에게는 그 문제를 너무 쉽게 처리하는 것처럼 보일 수 있다. 그것은 법적 유효성의 기준들을 특정하는 근본 규칙들(fundamental rules)의 가장자리에서 법원들이 하는 활동을 매우 부적절하게 특징짓는 것처럼 보일 수 있다. 그 이유는 아마도 그것이 이 활동을, 불확정적인 것으로 드러난 특정 제정법(statute)을 해석하면서 법원들이 창조적 선택을 행사하는 통상적 사례들에 지나치게 가깝게 동화시키기 때문일 수 있다. 그러한 통상적 사례들은 어떤 체계에서든 발생해야 한다는 점은 명확하며, 그래서 법원들이 그 사례들을, 제정법이 열어 둔 대안들 사이에서 선택함으로써 확정할 관할권을 가진다는 점은, 그들이 이 선택을 발견(discovery)으로 위장하기를 선호하더라도, 법원들이 근거하여 행위하는 규칙들의 일부, 비록 암묵적 일부일 뿐이더라도, 명백히 일부인 것처럼 보인다. 그러나 적어도 성문헌법(written constitution)이 없는 경우에는, 유효성의 근본 기준들에 관한 질문들은 종종 이

렇게 사전에 염두에 둘 수 있는 성질을 가지지 않는(not) 것처럼 보인다. 그리고 바로 이러한 사전에 염두에 둘 수 있는 성질이 있어야, 그러한 질문들이 발생할 때 법원들이 이미 기존 규칙들 아래에서 이 종류의 질문들을 확정할 명확한 권위를 가지고 있다고 말하는 것이 자연스럽다.

‘형식주의적(formalist)’ 오류의 한 형태는 어쩌면 법원이 취하는 모든 단계가 그것을 취할 권위를 사전에 부여하는 어떤 일반 규칙에 의해 포괄되어 있어서, 법원의 창조적 권한들이 언제나(always) 위임된 입법 권한(delegated legislative power)의 한 형태라고 생각하는 바로 그것일 수 있다. 진실은, 법원들이 가장 근본적인 헌법 규칙들에 관한 사전에 염두에 두어지지 않았던 질문들을 확정할 때, 그 질문들이 발생하고 결정이 내려진 뒤에야 그 질문들을 결정할 권위가 수용되게 된다는 것일 수 있다. 여기서는 성공하는 것은 오직 성공뿐이다(all that succeeds is success). 문제된 헌법적 질문이 사회를 너무 근본적으로 분열시켜 사법적 결정에 의한 처리를 허용하지 않을 수도 있다는 것은 상상 가능하다. 1909년 남아프리카법(South Africa Act)의 고착 조항들(entrenched clauses)에 관한 남아프리카의 쟁점들은 한때 법적 처리를 하기에는 너무 분열적일 위험이 있었다. 그러나 덜 중요한 사회적 쟁점들이 관련된 곳에서는, 법의 바로 그 원천들에 관한 매우 놀라운 사법적 법창출(judicial law-making)도 조용히 ‘삼켜질(swallowed)’ 수 있다. 그러한 경우에는, 회고적으로(retrospect) 법원들이 자신들이 한 일을 할 ‘내재적’ 권한(inherent power)을 언제나 가지고 있었다고 자주 말해질 것이고, 진정으로 그렇게 보일 수도 있다. 그러나 그 유일한 증거가 행해진 일의 성공뿐이라면, 이것은 경건한 허구(pious fiction)일 수 있다.

영국 법원들이 선례의 구속력(binding force)에 관한 규칙들을 조작한 것은, (p. 154) 아마도 이 마지막 방식으로, 권한들을 확보하여 행사하려는 성공적인 시도(successful bid)로서 서술되는 것이 가장 정직할 것이다. 여기서 권한(power)은 성공으로부터 사후적으로(ex post facto) 권위(authority)를 획득한다. 따라서 형사항소법원(Court of Criminal Appeal)이 *Rex* 대 *Taylor* 사건³에서 신민의 자유에 관한 사항들에 대해 자기 자신의 선례들에 구속되지 않는다고 판정할 권위를 가진다고 판시하기 전에는, 그 법원이 그러한 권위를 가지는지는

³[1950] 2 KB 368.

전적으로 열려 있는 것으로 보였을 수 있다. 그러나 그 판정은 내려졌고, 지금은 법으로서 따라지고 있다. 법원이 이런 방식으로 판정할 내재적 권한을 언제나 가지고 있었다는 진술은, 분명 상황을 실제보다 더 정돈되어 보이게 하는 방식일 뿐일 것이다. 여기, 바로 이러한 근본적인 것들의 가장자리에서는, 우리는 규칙 회의주의자를 환영해야 한다. 다만 그는 자신이 환영받는 곳이 가장자리라는 점을 잊지 않아야 하며, 법원들이 가장 근본적인 규칙들을 이렇게 눈에 띄게 발전시킬 수 있게 하는 것은 상당 부분 법의 광대한 중심 영역들에서 의심할 여지 없이 규칙-지배적인(rule-governed) 작용들을 해 온 데서 법원들이 모은 위신(prestige)이라는 사실을 우리에게 보지 못하게 해서는 안 된다.

제7장 주석

125쪽. 규칙의 예시적 전달(Communication of rules by examples). 이러한 용어로 선례(precedent)의 사용을 특징지은 설명으로는 Levi의 “An Introduction to Legal Reasoning” 제1절, *University of Chicago Law Review* 제15권(1948년)을 보라. Wittgenstein은 *Philosophical Investigations* (특히 제1부 제208-238절)에서 규칙을 가르치고 따르는 일에 관한 관념들(notions)에 대해 여러 중요한 통찰을 제시한다. Wittgenstein에 대한 논의는 Winch, *The Idea of a Social Science* 제24-33쪽, 91-93쪽 참조.

128쪽. 언어적으로 정식화된 규칙들의 개방적 직조(Open texture of verbally formulated rules). 개방적 직조(open texture)라는 관념에 대해서는 Waismann의 “Verifiability”, *Essays on Logic and Language* 제1권(Flew 편집), 제117-130쪽을 보라. 법적 추론과 관련한 논의로는 Dewey, “Logical Method and Law,” *Cornell Law Quarterly* 제10권(1924); Stone, *The Province and Function of Law*, 제6장; Hart, “Theory and Definition in Jurisprudence,” *Proceedings of the Aristotelian Society* 보충권 제29권(1955), 제258-264쪽; “Positivism and the Separation of Law and Morals,” *Harvard Law Review* 제71권(1958), 제606-612쪽 참조.

129쪽. 형식주의(formalism)와 개념주의(conceptualism). 법 문헌들에서 이 용어들과 거의 동의어로 사용되는 표현으로는 ‘기계적 또는 자동적 법리학(mechanical or automatic jurisprudence)’, ‘구상들의 법리학(jurisprudence of conceptions)’, ‘논리의 과도한 사용(excessive use of logic)’ 등이 있다. 이와 관련하여 Pound, “Mechanical Jurisprudence,” *Columbia Law Review* 제8권(1908); *Interpretations of Legal History*, 제6장 참조. 이러한 용어들로 정확히 어떤 결함 또는 폐해가 지칭되는지는 항상 명확하지 않다. 이에 관해서는 Jensen, *The Nature of Legal Argument*, 제1장, 그리고 Honoré의 서평, *Law Quarterly Review* 제74권(1958), 제296쪽; Hart, 위에 언급한 *Harvard Law Review* 제71권, 제608-612쪽을 참조.

131쪽. 법적 기준들과 구체적 규칙들(Legal standards and specific rules). 이러한 두 가지 법적 통제 형태의 성격과 상호 관계에 대한 가장 통찰력 있는 일반적 논의는 Dickinson, *Administrative Justice and the Supremacy of Law*, 제128-140쪽에 있다.

131쪽. 행정 규칙제정에 의해 구체화되는 법적 기준들(Legal standards implemented by administrative rule-making). 미국에서는 Interstate Commerce Commission, Federal Trade Commission 등 연방 규제기관들이 ‘공정 경쟁(fair competition)’, ‘공정하고

합리적인 요율(just and reasonable rates)’ 등의 광범위한 법적 기준들을 구체화하는 규칙들을 제정한다. (Schwartz, *An Introduction to American Administrative Law*, 제6-18 쪽, 33-37쪽 참조.) 영국에서도 이와 유사한 규칙제정 기능이 행정부에 의해 수행되지만, 일반적으로 미국에서 익숙한 이해관계자들에 대한 형식적 준사법적 청문(quasi-judicial hearing) 절차 없이 이루어진다. 예컨대, 1957년 *Factories Act* 제46조에 근거한 복지규정(Welfare Regulations), 같은 법 제60조에 의한 건축규정(Building Regulations)을 참조. 또한, 1947년 *Transport Act*에 따라 이의제기자들(objectors)의 의견을 청취한 후 ‘요금 체계(charges scheme)’를 확정할 수 있는 *Transport Tribunal*의 권한은 미국식 모델에 보다 근접해 있다.

132쪽. 주의 기준들(Standards of care). 주의의무(duty of care)의 구성요소들에 대한 통찰력 있는 분석으로는 Learned Hand 판사의 판결문 *US v. Carroll Towing Co.* (1947), 159 F 2nd 169, 173쪽을 보라. 일반적 기준들을 구체적 규칙들로 대체하는 바람직성에 대해서는 Holmes, *The Common Law*, 제3강, 제111-119쪽 참조. 이 견해에 대한 비판은 Dickinson, 앞의 책, 제146-150쪽에 제시되어 있다.

133쪽. 구체적 규칙들에 의한 통제(Control by specific rules). 유연한 기준들(flexible standards)보다는 엄격하고 고정된 규칙들(hard and fast rules)이 적절한 통제 형태가 되는 조건에 대해서는 Dickinson, 앞의 책, 제128-132쪽, 제145-150쪽을 보라.

134쪽. 선례와 법원의 입법 활동(Precedent and the legislative activity of Courts). 영국법에서의 선례(precedent in English law)의 현대적 일반 설명으로는 R. Cross, *Precedent in English Law* (1961)을 보라. 본문에서 언급된 ‘협소화 과정(narrowing process)’의 잘 알려진 예시는 *L. & S. W. Railway Co. v. Gomm* (1880), 20 Ch.D. 562로, 이는 *Tulk v. Moxhay* (1848), 2 Ph. 774에서의 법리를 좁혀 적용하였다.

136쪽. 규칙회의주의의 다양상들(Varieties of rule-scepticism). 이 주제에 대한 미국 법학의 논의는 하나의 논쟁(debate)으로 읽을 때 특히 유익하다. 예컨대 *Law and the Modern Mind* (특히 제1장 및 부록 2, “Notes on Rule Fetishism and Realism”)에서의 Frank, *The Bramble Bush*에서의 Llewellyn의 논증은 다음과 같은 저작들을 배경으로 고려할 수 있다: Dickinson, “Legal Rules: Their Function in the Process of Decision,” *University of Pennsylvania Law Review* 제79권(1931); “법 배후의 법(The Law behind the Law),” *Columbia Law Review* 제29권(1929); “The Problem of the Unprovided Case,” *Recueil d’Études sur les sources de droit en l’honneur de F. Geny*, 제11권 제5장; Kantorowicz, “Some Rationalism about Realism,” *Yale Law Review* 제43권(1934).

139쪽. 실망한 절대주의자로서의 회의주의자(The sceptic as a disappointed absolutist). Miller, "Rules and Exceptions," *International Journal of Ethics* 제66권(1956)을 보라.

140쪽. 규칙의 직관적 적용(Intuitive application of rules). Hutcheson, "The Judgement Intuitive"; "The Function of the 'Hunch' in Judicial Decision," *Cornell Law Quarterly* 제14권(1928)을 보라.

141쪽. '헌법은 판사들이 말하는 바 그대로이다(The constitution is what the judges say it is).' 이 표현은 미국의 Hughes 대법원장(Chief Justice Hughes)에게서 유래한 것으로 보이며, Hendel, *Charles Evan Hughes and the Supreme Court* (1951), 제11-12쪽 참조. 그러나 Hughes 자신의 저작인 *The Defence Court of the United States* (1966년판) 제37, 41쪽에서는 헌법 해석에 있어 개인의 정치적 견해로부터 독립된 판사들의 책무(duty)를 강조하고 있다.

149쪽. 의회 주권에 대한 대안적 분석(Alternative analyses of the sovereignty of Parliament). H. W. R. Wade, "The Basis of Legal Sovereignty," *Cambridge Law Journal* (1955)을 보라. 이 견해는 Marshall, *Parliamentary Sovereignty and the Commonwealth*, 제4장과 제5장에서 비판받고 있다.

149쪽. 의회 주권과 신의 전능성(Parliamentary sovereignty and divine omnipotence). Mackie, "Evil and Omnipotence," *Mind*, 1955년, 제211쪽 참조.

150쪽. 의회를 구속하는 것인가, 재규정하는 것인가(Binding or redefining Parliament). 이 구분에 관해서는 Friedmann, "Trethowan's Case, Parliamentary Sovereignty and the Limits of Legal Change," *Australian Law Journal* 제24권(1950); Cowen, "Legislature and Judiciary," *Modern Law Review* 제15권(1952) 및 제16권(1953); Dixon, "The Law and the Constitution," *Law Quarterly Review* 제51권(1935); Marshall, 앞의 책, 제4장을 보라.

151쪽. 1911년 및 1949년 의회법들(Parliament Acts 1911 and 1949). 이들 법률이 위임입법(delegated legislation)의 한 형식을 수권하는 것으로 해석하는 견해는 H. W. R. Wade, 위 저작 및 Marshall, 위 저작 제44-46쪽 참조.

152쪽. 1931년 웨스트민스터 제정법(Statute of Westminster), 제4조. 권위 있는 견해들의 무제는, 이 조항의 제정이 도미니언의 동의 없이 도미니언을 위해 입법할 권한의 불가역적 종결을 구성할 수는 없었다는 견해를 지지한다. *British Coal Corporation v. The King* (1935), AC 500; Wheare, *The Statute of Westminster and Dominion Status*, 제5

판, 제297-298쪽; Marshall, 위 저작 제146-147쪽 참조. 이에 반하여, “한 번 부여된 자유는 철회될 수 없다(Freedom once conferred cannot be revoked)” 는 견해는 남아프리카 법원에서 *Ndlwana v. Hofmeyr* (1937), AD 229, 제237쪽에서 표현된 바 있다.

제7장 제3판 주석

124-128쪽. 법의 개방적 직조(Open texture of law). 일반적인 논의로는 Avishai Margalit, “Open Texture” (1979), *Meaning and Use* 제3권 141쪽을 보라. 하트(Hart)가 ‘개방적 직조(open texture)’ 개념을 어떻게 사용하는지에 대해서는 Brian Bix, *Law, Language, and Legal Determinacy* (Oxford University Press, 1993), 제1장을 참조하라. 법의 불확정성(indeterminacy)의 다른 원천들에 대해서는 Kelsen, *Pure Theory of Law*, 제348-356쪽을 참조. 불확정성과 그에 따른 재량(discretion)에 대한 드워킨(Dworkin)의 비판은 *Taking Rights Seriously* 제31-39쪽, 제4장, 제13장과 *A Matter of Principle* (Harvard University Press, 1986), 제5장에서 볼 수 있다. 드워킨의 이러한 비판은 David Brink, “Legal Theory, Legal Interpretation and Judicial Review” (1988), *Philosophy & Public Affairs* 제17권 105쪽 및 Nicos Stavropoulos, “Hart’s Semantics” in Jules Coleman 편, *Hart’s Postscript* 중 특히 제88-98쪽에서 지지를 얻는다. 반면에 Andrei Marmor, *Interpretation and Legal Theory*, 제2판 (Hart Publishing, 2005), 제7장에서는 이 비판을 수용하지 않는다.

128-134쪽. 일반 규칙들과 특정 사례들(General rules and particular cases). 규칙 기반 결정(rule-based decision-making)의 본질에 대해서는 David Lyons, *Forms and Limits of Utilitarianism* (Oxford University Press, 1965), Frederick Schauer, *Playing By the Rules: A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life* (Oxford University Press, 1991), 특히 제5장, 그리고 Larry Alexander와 Emily Sherwin, *The Rule of Rules: Morality, Rules, and Dilemmas of Law* (Duke University Press, 2001), 제1장과 제2장을 참조하라.

128-129쪽. 전범적 사례들(Paradigm cases). 전범적 사례들이 수행하는 역할에 대한 하트의 이해를 옹호하는 논의로는 Timothy Endicott, *Vagueness in Law* (Oxford University Press, 2000), 제7장을 보라. 이에 반대하는 드워킨의 견해는 *Law’s Empire*, 제3장, 특히 제90-94쪽에 제시되어 있다. 이에 대한 응답으로는 Endicott, “Herbert Hart and the Semantic Sting” in Jules Coleman 편, *Hart’s Postscript* (Oxford University Press, 2001)을 보라.

129-130쪽. 형식주의(Formalism). ‘형식주의(formalism)’라는 용어는 다른 방식으로 사용된다. 관련 논의로는 Martin Stone, “Formalism” in Jules Coleman and Scott Shapiro 편, *The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law* (Oxford University Press, 2002)을 참조하라.

130-132쪽. 불확정성과 재량(Indeterminacy and discretion). 법은, 이해 가능한 법적 질문에 대해 하나의 유일한(unique) 답을 정당화하지 못할 때, 즉 법이 불완전할 때 불확정적(indeterminate)이다. 이는 어떤 법적 사례가 ‘어렵다(hard)’는 것과 동일하지 않다. 후자는 유일한 답이 존재하지만 그 답이 분명하지 않거나 이견의 대상이 되는 경우에도 참일 수 있다. 또한 이는 법이 실제로(인과적으로) 사법적 결정들을 결정짓는다는 견해와도 다르다. 법은 전적으로 확정적일 수 있지만 판사들이 그것을 알지 못하거나, 알고도 적용하지 않기로 결정할 수 있다. 법의 확정성(legal determinacy)은 결정의 예측가능성(decisional predictability)을 함의하지 않는다. (비교: Brian Leiter, “Legal Indeterminacy” (1995), *Legal Theory* 제1권 481쪽) 하트가 옹호하는 것은 법의 정당화적 불확정성(justificatory indeterminacy)이다. 하트의 테제에 대한 거부는 Ronald Dworkin, “No Right Answer?” in P. M. S. Hacker and Joseph Raz 편, *Law, Morality and Society*, 그리고 Ronald Dworkin, “On Gaps in the Law” in Paul Amselek and Neil MacCormick 편, *Controversies About Law’s Ontology* (Edinburgh University Press, 1991)에서 볼 수 있다. 이에 대한 옹호는 Joseph Raz, *The Authority of Law*, 제4장에서 찾을 수 있다.

131-133쪽. 규칙들과 가변적 기준들(Rules and variable standards). 이 지점에서 하트(Hart)는 규칙(rule)을 두어야 하는지 여부(whether)를 논의하는 것이 아니라, 다양한 상황에 어떤 종류(kind)의 규칙이 적절할지를 논의하고 있다. 미국의 법률가들은, 헨리 하트(Henry Hart, H. L. A. Hart와는 무관)와 앨버트 삭스(Albert Sacks)의 영향을 받아, 때때로 ‘규칙들(rules)’과 ‘기준들(standards)’을 구분하지만, H. L. A. Hart에게 기준들(standards)은 규칙들의 한 종류이다. 이 구분에 대해서는 Henry M. Hart and Albert Sacks, *The Legal Process: Basic Problems in the Making and Application of Law* (W. N. Eskridge, Jr. and P. P. Frickey 편집, Foundation Press, 1994) 139-141쪽, 그리고 Pierre J. Schlag, “Rules and Standards” (1985) *UCLA Law Review* 제33권 379쪽을 참조하라. 마찬가지로, 흔히 ‘원칙들(principles)’이라 불리는 것들도 하트의 규칙들에 관한 관념(idea of rules)에 포함되며, 그는 드워킨(Dworkin)이 *Taking Rights Seriously* 제22-28쪽에서 설정한 것과 같은 규칙과 원칙 간의 범주적 구분을 거부한다. 이에 대한 하트의 입장은 *Postscript* 제261-263쪽에 언급되어 있다. 관련 논의로는 Joseph

Raz, “Legal Principles and the Limits of Law” (1972) *Yale Law Journal* 제81권 823쪽, Larry Alexander and Ken Kress, “Against Legal Principles” (1997) *Iowa Law Review* 제82권 739쪽을 참조하라.

134-135쪽. 선례(Precedent). 이 주제에 관한 문헌은 매우 풍부하다. 참고문헌으로는 다음을 보라: A. W. B. Simpson, “The Common Law and Legal Theory” in A. W. B. Simpson 편, *Oxford Essays in Jurisprudence*; Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* 제110-123쪽; Neil MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory* (수정판, Oxford University Press, 1994); Laurence Goldstein 편, *Precedent in Law* (Oxford University Press, 1987); Stephen Perry, “Judicial Obligation, Precedent and the Common Law” (1987) *Oxford Journal of Legal Studies* 제7권 215쪽; Frederick Schauer, “Precedent” (1987) *Stanford Law Review* 제39권 571쪽; Susan Hurley, “Coherence, Hypothetical Cases, and Precedent” (1990) *Oxford Journal of Legal Studies* 제10권 221쪽; Larry Alexander, “Precedent” in Dennis Patterson 편, *A Companion to the Philosophy of Law and Legal Theory* (Blackwell, 1996); Neil Duxbury, *The Nature and Authority of Precedent* (Cambridge University Press, 2008).

136-141쪽. 규칙회의주의의 다양상들(Varieties of rule scepticism). 하트의 관련 에세이로는 “American Jurisprudence through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream” (*Essays in Jurisprudence and Philosophy*, 제4장)이 있다. 하트의 저작 이후 등장한 가장 저명한 규칙회의주의자(rule-sceptics)는 미국의 ‘비판법학(Critical Legal Studies, CLS)’ 운동의 법학자들이었다. 철학적으로는 덜 정교하지만 영향력 있는 논의로는 Roberto Unger, *The Critical Legal Studies Movement* (Harvard University Press, 1986), 특히 제1-14쪽, 그리고 Duncan Kennedy, *A Critique of Adjudication [fin de siècle]* (Harvard University Press, 1997)를 들 수 있다. 초기 CLS 문헌에 대한 비판적 논의는 Ken Kress, “Legal Indeterminacy” (1989) *California Law Review* 제77권 283쪽을 참조하라. 또한 John Finnis, “On the Critical Legal Studies Movement”, 그의 *Philosophy of Law* 제13장, Andrew Altman, *Critical Legal Studies: A Liberal Critique* (Princeton University Press, 1990)도 보라. Brian Leiter는 “Legal Realism and Legal Positivism Reconsidered”, 그의 *Naturalizing Jurisprudence* (Oxford University Press, 2007) 제2장에서 하트의 규칙회의주의의 다양상들을 다룬다.

VIII. 정의(Justice)와 도덕(Morality)

우리는 법을 사회 통제의 수단으로서 특징짓는 요소들을 해명하기 위해, 명령(order), 위협(threat), 복종(obedience), 습관들(habits), 일반성(generality)이라는 관념들만으로는 구성할 수 없는 요소들을 도입할 필요가 있음을 확인하였다. 법에 특징적인 것들 가운데 너무 많은 것이, 그것을 이러한 단순한 용어들로 설명하려는 노력에 의해 왜곡된다. 따라서 우리는 일반적 습관(general habit)이라는 관념과 사회적 규칙(social rule)이라는 관념을 구별하고, 규칙들이 행위의 지침적이고 비판적인 기준들로 사용된다는 점에서 드러나는 규칙들의 내부 측면(internal aspect)을 강조할 필요가 있었다. 이어서 우리는 규칙들 가운데, 의무의 일차 규칙들(primary rules of obligation)과 승인·변경·재판의 이차 규칙들(secondary rules of recognition, change, and adjudication)을 구별하였다. 이 책의 중심 주제는, 법의 독특한 작동들 가운데 매우 많은 것과 법적 사고의 틀을 구성하는 관념들 가운데 매우 많은 것이, 그 해명을 위해 이 두 유형의 규칙 가운데 하나 또는 양자에 대한 참조를 요구하므로, 이 둘의 결합은, ‘법(law)’이라는 단어가 올바르게 사용되는 모든 곳에서 그것들이 언제나 함께 발견되는 것은 아니라 하더라도, 법의 ‘본질(essence)’로 정당하게 간주될 수 있다는 것이다. 일차 규칙들과 이차 규칙들의 결합에 이러한 중심적 자리를 부여하는 우리의 정당화는, 그 결합이 거기서 사전의 일을 해낼 것이라는 데 있지 않고, 그것이 큰 설명력을 가진다는 데 있다.

이제 우리는 법의 ‘본질’(essence), ‘성격’(nature), 또는 ‘정의’(definition)에 대한 오래된 논의 속에서, 우리가 부적절하다고 판단한 단순 명령 이론(simple imperative theory)에 가장 자주 맞세워져 온 주장(claim)에 주목해야 한다. 이것은 법과 도덕 사이에는 어떤 의미에서 ‘필연적(necessary)’인 연결이 존재하며, 법 관념(notion of law)을 분석하거나 해명하려는 어떤 시도에서도 중심적인 것으로 취급될 자격이 있는 것은 바로 이 연결이라는 일반적 논지(contention)이다. 이러한 견해의 옹호자들은 단순 명령 이론에 대한 우리의 비판을 다투는데 관심이 없을 수도 있다. 그들은 그것이 유용한 진전이였다는 점, 그리고 일차 규칙들과 이차 규칙들의 결합이 위협에 의해 뒷받침된 명령들보다 법을

이해하기 위한 출발점으로서 기실 더 중요하다는 점을 인정할 수도 (p. 156) 있다. 그러나 그들의 논변은 이것으로 충분하지 않다는 것, 즉 이러한 요소들조차 부차적(subordinate) 중요성만을 가지며, 도덕과의 ‘필연적’ 관계가 명시되고 그 중심적 중요성이 이해되기 전까지는 법 이해를 그토록 오래 흐려 온 안개가 걷힐 수 없다는 것일 터이다. 이러한 관점에서 보면, 법의 의심스럽거나 다룰 수 있는 사례들은 단지 입법부, 강제 관할권을 가진 법원들, 중앙적으로 조직된 제재들을 결여했기 때문에 의심스러운 것으로 여겨져 온 원시 사회들의 법이나 국제법만은 아닐 것이다. 이 관점에서 훨씬 더 의심스러운 것은, 판사, 경찰, 입법자(juge, gendarme et législateur)의 완비된 구성요소들을 갖추고 있으면서도 정의(justice)나 도덕(morality)의 일정한 근본 요건들에 부합하지 못하는 국내 법체계들(municipal systems)이 법으로 취급될 자격(title)을 가지는가이다. 성 아우구스티누스(St. Augustine)의 말처럼¹, “정의 없는 국가란 확대된 도적 떼가 아니고 무엇인가?”

법과 도덕 사이에 필연적 연결이 존재한다는 주장은 여러 중요한 변형들을 가지며, 그 모두가 명료함으로 두드러지는 것은 아니다. 핵심 용어들인 ‘필연적’ (necessary)과 ‘도덕’ (morality)에는 가능한 해석들이 많이 있으며, 옹호자들이든 비판자들이든 이것들을 언제나 구별하여 따로 고려한 것은 아니다. 이 관점의 가장 명료한 형태는, 아마도 그것이 이 관점의 가장 극단적인 표현 형식이기 때문에, 토마스주의(Thomist tradition)의 자연법(Natural Law) 전통과 결부된 형태일 것이다. 이것은 이중의 논지(contention)를 포함한다. 첫째, 신적 기원을 가지더라도 계시(revelation)의 도움 없이 인간 이성애 의해 발견될 수 있는 참된 도덕 또는 정의의 일정한 원칙들이 존재한다는 것, 둘째, 이러한 원칙들과 충돌하는 인간이 만든 법들(man-made laws)은 유효한 법이 아니라는 것이다. 즉, “부정의한 법은 법이 아니다(Lex iniusta non est lex).” 이 일반적인 관점의 다른 변형들은 도덕 원칙들의 지위와 법과 도덕 사이 충돌의 귀결 모두에 대해 서로 다른 견해를 취한다. 어떤 이들은 도덕을 불변의 행위 원칙들이나 이성애 의해 발견 가능한 것으로 파악하지 않고, 행위에 대한 인간의 태도들의 표현, 곧 사회마다 또는 개인마다 달라질 수 있는 태도들의 표현으로 파악한다.

¹De Civitate Dei, IV, 4.

이 형태의 이론들은 대개, 법과 도덕의 가장 근본적인 요건들 사이의 충돌조차도 그 자체로는 어떤 규칙에서 법으로서의 지위를 (p. 157) 박탈하기에 충분하지 않다고 본다. 그들은 법과 도덕 사이의 ‘필연적’ 연결을 다른 방식으로 해석한다. 그들은 하나의 법체계가 존재하려면 법에 복종할 도덕적 의무에 대한, 반드시 보편적이지는 않지만 광범위하게 퍼진 인정이 있어야 한다고 주장한다. 비록 이 의무가 특정한 경우들에서는 도덕적으로 사악한 특정 법들에 복종하지 않을 더 강한 도덕적 의무에 의해 압도될 수 있다 하더라도 말이다.

법과 도덕 사이의 필연적 연결을 단언하는 이론들의 서로 다른 변형들을 완전히 평가하려면 우리는 도덕 철학(moral philosophy)의 깊은 곳까지 들어가야 할 것이다. 그러나 그보다 적은 작업으로도 사려 깊은 독자가 그러한 주장들의 진리와 중요성에 관하여 이유 있는 견해를 형성할 만큼은 제공될 수 있다. 이 목적을 위해 가장 필요한 것은, 우리가 이 장과 다음 장에서 검토할, 오래 얽혀 온 몇몇 쟁점들을 분리하고 식별하는 일이다. 이 쟁점들 가운데 첫째는 도덕(morality)의 일반 영역 안에서 정의(justice)라는 특정한 관념(idea)을 구별하는 일과, 그 관념이 법과 유달리 밀접한 연결을 가지게 하는 특수한 특징들에 관한 것이다. 둘째는 도덕 규칙들과 원칙들을 법규칙들뿐 아니라 다른 모든 형태의 사회 규칙 또는 행위 기준들로부터 구별해 주는 특징들에 관한 것이다. 이 두 쟁점이 이 장의 주제이며, 다음 장의 주제가 되는 셋째 쟁점은 법규칙들과 도덕이 관련되어 있다고 말할 수 있는 많은 서로 다른 의미들과 방식들에 관한 것이다.

1. 정의의 원칙들 (Principles of Justice)

법률가들이 법이나 그 집행을 칭찬하거나 비난할 때 가장 자주 사용하는 용어들은 ‘정의로운(just)’ 과 ‘부정의한(unjust)’ 이라는 말이며, 그들은 매우 자주 정의(justice)와 도덕(morality)이라는 관념들이 같은 범위를 가지는 것처럼 쓴다. 기실 법적 장치들(legal arrangements)에 대한 비판에서 정의가 가장 두드러진 자리를 가져야 할 아주 좋은 이유들이 있다. 그러나 정의가 도덕의 구별되는 한 부분(segment)이라는 점, 그리고 법들과 법들의 집행은 서로 다른 종류의

탁월성들(excellences)을 가지거나 결여할 수 있다는 점을 보는 것이 중요하다. 도덕 판단의 몇 가지 흔한 유형들에 관하여 아주 조금만 숙고해도 정의의 이러한 특수한 성격은 드러난다. 자기 아이에게 심한 잔혹행위를 한 사람은 흔히 도덕적으로 그른(wrong), 나쁜(bad), 심지어 사악한(wicked) 일을 했거나, 자기 아이에 대한 도덕적 의무(obligation) 또는 책무(duty)를 무시했다고 (p. 158) 판단될 것이다. 그러나 그의 행위를 부정의하다(unjust)고 비판하는 것은 이상할 것이다. 이는 ‘부정의한(unjust)’이라는 말의 비난력이 너무 약하기 때문이 아니라, 정의 또는 부정의의 용어들로 하는 도덕적 비판의 초점(point)이, 이 특정한 경우에 적절하고 ‘그른(wrong)’, ‘나쁜(bad)’, ‘사악한(wicked)’ 같은 말들로 표현되는 다른 유형의 일반적 도덕 비판과 보통 다르고 더 특징적이기 때문이다. ‘부정의한(unjust)’이라는 말은, 그 사람이 동일한 과오를 저지른 다른 아이들에게 내려진 벌보다 더 엄한 벌을 주기 위해 자기 아이들 가운데 하나를 자의적으로 골랐거나, 그 아이가 실제로 그른 행위자(wrongdoer)였는지를 확인하는 조치를 취하지 않고 어떤 과오(offence)에 대해 그 아이를 벌한 경우에만 적절해질 것이다. 마찬가지로 개인 행위에 대한 비판에서 법에 대한 비판으로 옮겨 갈 때, 우리는 부모가 자녀를 학교에 보내도록 요구하는 법에 대한 승인을 그것이 좋은 법(good law)이라고 말함으로써 표현할 수 있고, 정부 비판을 금지하는 법에 대한 불승인을 그것을 나쁜 법(bad law)이라고 부름으로써 표현할 수 있다. 그러한 비판들은 보통 ‘정의(justice)’와 ‘부정의(injustice)’의 용어들로 표현되지 않을 것이다. 반면 ‘정의로운(just)’은 부에 따라 과세 부담을 분배하는 법에 대한 승인을 표현하기에 적절한 말일 것이며, ‘부정의한(unjust)’은 유색인종이 대중교통 수단이나 공원을 사용하는 것을 금지하는 법에 대한 불승인을 표현하기에 적절할 것이다. 정의로운 것과 부정의한 것이 좋음과 나쁨, 또는 옳음과 그름보다 더 특징적인 도덕 비판의 형식들이라는 점은 다음 사실에서 분명하다. 우리는 어떤 법이 정의로웠기 때문에 좋았다거나, 부정의했기 때문에 나쁘다고 이해 가능하게 주장할 수 있지만, 그것이 좋기 때문에 정의로웠거나 나쁘기 때문에 부정의했다고는 말할 수 없다.

정의의 구별되는 특징들과 그것이 법과 가지는 특수한 연결은, 정의롭다(just)와 부정의하다(unjust)의 용어들로 이루어지는 비판들의 대부분이 거의

똑같이 ‘공정한(fair)’ 과 ‘불공정한(unfair)’ 이라는 말들로 전달될 수 있다는 점을 관찰하면 드러나기 시작한다. 공정성(fairness)은 분명 일반 도덕과 같은 범위를 가지지 않는다. 공정성에 대한 참조는 주로 사회생활의 두 상황에서 관련된다. 하나는 우리가 단일한 개인의 행위가 아니라 개인들의 부류들(classes)이 대우받는 방식에 관심을 가지는 경우, 곧 어떤 부담이나 혜택이 그들 사이에 분배되어야 하는 경우이다. 따라서 전형적으로 공정하거나 불공정한 것은 ‘몫(share)’ 이다. 둘째 상황은 어떤 손해(injury)가 발생했고 보상(compensation)이나 구제(redress)가 청구되는 경우이다. 이것들이 (p. 159) 정의나 공정성의 용어들로 평가가 이루어지는 유일한 맥락은 아니다. 우리는 분배들(distributions)이나 보상들(compensations)이 정의롭거나 공정하다고 말할 뿐 아니라, 판사(judge)가 정의롭거나 부정의하다고, 재판(trial)이 공정하거나 불공정하다고, 어떤 사람이 정의롭게 또는 부정의하게 유죄판결을 받았다고 말한다. 이것들은 정의 관념(notion of justice)의 파생적 적용들이며, 정의가 분배와 보상의 사안들에 일차적으로 적용된다는 점이 이해되면 설명될 수 있다.

정의라는 관념(idea of justice)의 이러한 다양한 적용들 안에 잠재해 있는 일반 원리는, 개인들이 서로에 대하여 일정한 상대적 평등 또는 불평등의 지위를 가질 자격이 있다는 것이다. 이것은 부담들이나 혜택들이 분배되어야 할 때 사회생활의 부침 속에서 존중되어야 할 것이며, 그것이 교란될 때 회복되어야 할 것이기도 하다. 따라서 정의는 전통적으로 균형(balance) 또는 비례(proportion)를 유지하거나 회복하는 것으로 사유되어 왔고, 그 선도적 격률은 흔히 ‘같은 사례들은 같게 취급하라(Treat like cases alike)’ 로 정식화된다. 다만 우리는 후자에 ‘그리고 다른 사례들은 다르게 취급하라(and treat different cases differently)’ 를 덧붙여야 한다. 그러므로 우리가 정의의 이름으로 유색인종에게 공공 공원의 사용을 금지하는 법에 항의할 때, 그러한 비판의 요점은 그 법이 나쁘다는 데 있다. 왜냐하면 그 법은 공공 편의시설의 혜택들을 사람들 사이에 분배하면서 모든 관련 측면에서 같은 사람들 사이를 차별하기 때문이다. 반대로 어떤 법이, 예컨대 과세에서 어떤 특수 부문으로부터 특권이나 면제를 철회하기 때문에 정의롭다고 칭찬받는다면, 그 지침이 되는 생각은 특권을 누리는 부류와 공동체의 나머지 사람들 사이에 그들에게 특별 대우를 받을 자격을 부여할 만한

그런 관련 차이가 없다는 것이다. 그러나 이러한 단순한 예들만으로도, ‘같은 사례들은 같게, 다른 사례들은 다르게 취급하라(Treat like cases alike and different cases differently)’가 정의라는 관념의 중심 요소이기는 하지만, 그 자체로는 불완전하며 보충되기 전에는 행위에 대한 어떤 확정적인 지침도 제공할 수 없다는 점을 보여주기에 충분하다. 이는 어떤 인간 집합도 어떤 측면들에서는 서로 닮고 다른 측면들에서는 서로 다르며, 어떤 닮음과 차이들이 관련되는지가 확정되기 전까지 ‘같은 사례들은 같게 취급하라’는 공허한 형식으로 남아 있어야 하기 때문이다. 그것을 채우려면, 당면한 목적들을 위해 언제 사례들이 같은 것으로 간주되어야 하는지, 그리고 어떤 차이들이 관련되는지를 알아야 한다. 이러한 추가 보충 없이는 우리는 법들이나 다른 사회적 장치들을 부정의하다고 비판할 수 없다. 법이 살해(homicide)를 금지하면서 (p. 160) 붉은 머리카락을 가진 살인자들을 다른 사람들과 같은 방식으로 취급하는 것은 부정의하지 않다. 기실 법이 그들을 다르게 취급한다면 부정의할 것이며, 이는 제정신인 사람들과 정신이상인 사람들을 다르게 취급하기를 거부한다면 부정의할 것이라는 점과 같다.

그러므로 정의라는 관념의 구조에는 일정한 복잡성이 있다. 우리는 그것이 두 부분으로 이루어진다고 말할 수 있다. 하나는 ‘같은 사례들은 같게 취급하라(Treat like cases alike)’라는 격률로 요약되는 일률적 또는 고정적 특징이고, 다른 하나는 어떤 주어진 목적에서 사례들이 언제 같거나 다른지를 결정하는 데 사용되는 이동적 또는 가변적 기준이다. 이 점에서 정의는 진짜인 것(genuine), 키가 큰 것(tall), 따뜻한 것(warm)에 대한 관념들(notions)과 같다. 이 관념들은 그것들이 적용되는 사물의 분류에 따라 달라지는 기준에 대한 암묵적 참조를 포함한다. 키 큰 아이가 키 작은 남자와 같은 키일 수 있고, 따뜻한 겨울이 추운 여름과 같은 온도일 수 있으며, 가짜 다이아몬드가 진짜 골동품일 수 있다. 그러나 정의는 이러한 관념들보다 훨씬 더 복잡하다. 정의 안에 포함된, 서로 다른 사례들 사이의 관련 닮음이라는 이동하는 기준은 그것이 적용되는 대상의 유형에 따라 달라질 뿐 아니라, 단일한 대상 유형과 관련해서도 종종 다툼에 열려 있을 수 있기 때문이다.

기실 어떤 경우들에서는, 법적 장치들을 정의롭거나 부정의하다고 비판하는데 관련되는 인간들 사이의 닮음들과 차이들이 매우 명백하다. 이는 특히 우리가

특정 사례들에서 법(law)의 정의 또는 부정의가 아니라 그 적용(application)의 정의 또는 부정의에 관심을 가질 때 그러하다. 여기서는 법을 집행하는 사람이 주목해야 하는 개인들 사이의 관련 다툼들과 차이들이 법 자체에 의해 결정된다. 살인에 관한 법이 정의롭게 적용된다고 말하는 것은, 그 법이 법이 금지한 일을 했다는 점에서 같은 모든 사람들에게, 그리고 오직 그러한 사람들에게만 불편부당하게 적용된다는 말이다. 어떤 편견이나 이해관계도 집행자를 그들을 ‘동등하게’ 취급하는 데서 벗어나게 하지 않았다. 이와 일관되게, ‘*audi alteram partem*’, 곧 ‘다른 쪽의 말을 들어라’, ‘누구도 자기 자신의 사건에서 판사가 되어서는 안 된다’와 같은 절차적 기준들은 정의의 요건들로 사유되며, 영국과 미국에서는 종종 자연적 정의(Natural Justice)의 원칙들로 지칭된다. 이는 그것들이 불편부당성(impartiality) 또는 객관성(objectivity)의 보증들이며, 법이 법 자체가 지목한(marked out) 관련 측면에서 같은 모든 사람들에게, 그리고 오직 그러한 사람들에게만 적용되도록 확보하기 위해 설계되어 있기 때문이다.

(p. 161) 정의의 이러한 측면과 규칙에 의해 진행된다는 바로 그 관념(notion) 사이의 연결은 명백히 매우 밀접하다. 기실, 서로 다른 사례들에 법을 정의롭게 적용한다는 것은, 서로 다른 사례들에서 적용되어야 하는 것이 편견, 이해관계, 변덕 없이 동일한 일반 규칙이라는 단언(assertion)을 진지하게 받아들이는 것일 뿐이라고 말할 수도 있다. 법 집행에서의 정의와 규칙이라는 바로 그 관념 사이의 이러한 밀접한 연결은 몇몇 유명한 사상가들을 정의를 법에의 부합(conformity to law)과 동일시하도록 유혹해 왔다. 그러나 ‘법(law)’에 어떤 특별히 넓은 의미가 부여되지 않는 한 이것은 분명 오류이다. 그러한 정의 설명은 정의의 이름으로 이루어지는 비판이 특정 사례들에서의 법 집행에 국한되지 않고, 법들 자체도 자주 정의롭거나 부정의한 것으로 비판된다는 사실을 설명하지 않은 채 남겨 두기 때문이다. 기실 유색인종의 공원 출입을 금지하는 부정의한 법이, 그 법을 위반한 데 실제로 유죄인 사람들만이, 그리고 그 경우에도 공정한 재판 뒤에야 그 법 아래에서 처벌되었다는 점에서 정의롭게 집행되었다고 인정하는 데에는 아무 부조리도 없다.

법 집행의 정의 또는 부정의에서 이러한 용어들로 법 자체를 비판하는 일로 넘어가면, 법 자체는 이제 그 법의 규칙들이 같은 사례들을 같게 취급하여

정의로울 수 있으려면 개인들 사이의 어떤 닮음들과 차이들을 법이 인정해야 하는지를 확정할 수 없다는 점이 분명하다. 따라서 여기에는 의심과 다툼의 여지가 많다. 일반적인 도덕적·정치적 전망의 근본적 차이들은, 법을 부정의한 것으로 비판하는 데 인간 존재의 어떤 특징들이 관련되는 것으로 받아들여져야 하는지에 관하여 화해 불가능한 차이와 의견 불일치를 낳을 수 있다. 예컨대 앞의 사례에서 우리가 유색인종의 공원 출입을 금지하는 법을 부정의하다고 낙인찍은 것은, 적어도 그러한 편의시설들의 분배에서는 피부색의 차이들이 관련성이 없다는 전제 위에서였다. 현대 세계에서는, 어떤 피부색이든 인간 존재들이 사고, 감정, 자기 통제의 능력을 가진다는 사실이 법이 주목해야 할 그들 사이의 핵심적 닮음들(*crucial resemblances*)을 구성한다는 점이 일반적으로, 비록 보편적으로는 아니지만, 받아들여질 것이다. 따라서 대부분의 문명국가들에서는 형사법(*criminal law*)이 자유를 제한할 뿐 아니라 여러 종류의 해악으로부터 보호를 제공하는 것으로 파악되고, 민사법(*civil law*)이 해악에 대한 (p. 162) 구제(*redress*)를 제공하는 것으로 파악되는 한, 그러한 부담들과 혜택들의 분배에서 피부색이나 종교적 신념 같은 특징들을 참조하여 사람들 사이를 차별한다면 양자가 모두 부정의할 것이라는 데 상당한 합의가 있다. 그리고 법이 이러한 잘 알려진 인간적 편견의 초점들(*foci*) 대신 키, 몸무게, 아름다움처럼 명백히 무관한 것들을 참조하여 차별한다면, 그것은 부정의할 뿐 아니라 우스꽝스러울 것이다. 국교회에 속한 살인자들이 사형에서 면제된다면, 귀족들만이 명예훼손으로 소를 제기할 수 있다면, 유색인에 대한 폭행이 백인에 대한 폭행보다 덜 엄하게 처벌된다면, 그 법들은 대부분의 현대 공동체들에서, 일응(*prima facie*) 인간 존재들은 같게 대우되어야 하며 이러한 특권들과 면제들은 아무런 관련 근거에도 기초하고 있지 않다는 전제 위에서 부정의한 것으로 단죄될 것이다.

기실 일응 인간 존재들이 같게 대우받을 자격이 있다는 원칙은 현대인 안에 매우 깊이 박혀 있어서, 법들이 피부색과 인종 같은 사안들을 참조하여 차별하는 곳에서도 거의 보편적으로 적어도 말뿐인 경의(*lip-service*)는 여전히 이 원칙에 널리 바쳐진다. 그러한 차별들이 공격받으면, 그것들은 흔히 차별받는 부류(*class*)가 일정한 본질적 인간 속성들을 결여하거나 아직 발달시키지 못했다는

단언(assertion)에 의해 방어된다. 또는 유감스럽지만 그들의 평등한 대우를 요구하는 정의의 요구들(demands of justice)은, 그러한 차별들이 이루어지지 않는다면 위태로워질 더 큰 가치로 여겨지는 어떤 것을 보존하기 위해 제쳐져야 한다고 말해질 수도 있다. 그러나 말뿐인 정의가 이제 일반적이라 하더라도, 차별과 불평등을 정당화하기 위해 이러한, 종종 진정성 없는 장치들에 의존하지 않고, 일응 인간 존재들이 함께 대우되어야 한다는 원칙을 공개적으로 거부하는 도덕(morality)을 상상하는 것은 분명 가능하다. 대신 인간 존재들은 자연적으로 그리고 바꿀 수 없게 일정한 부류들(classes)로 나뉘며, 그래서 어떤 이들은 자유롭기에 자연적으로 적합하고 다른 이들은 그들의 노예, 곧 아리스토텔레스의 표현대로 타인들의 살아 있는 도구(living instruments)가 되기에 자연적으로 적합하다고 생각될 수 있다. 여기에는 인간들 사이의 일응의 평등(prima-facie equality)이라는 감각이 부재할 것이다. 이 견해의 일부는 아리스토텔레스와 플라톤에게서 발견되지만, 거기서조차 노예제에 대한 완전한 방어는 노예화된 자들이 독립적 존재를 위한 능력을 결여했거나 좋은 삶(good life)의 어떤 이상을 실현할 능력에서 자유인들과 달랐음을 보여주는 일을 수반할 것이라는 암시가 강하게 존재한다.

(p. 163) 그러므로 관련 다툼들과 차이들의 기준들은 주어진 개인이나 사회의 근본적 도덕 전망에 따라 자주 달라질 수 있음이 분명하다. 그러한 경우 법의 정의 또는 부정의에 대한 평가들은 서로 다른 도덕에서 영감을 받은 반대 단언들(counter-assertions)에 부딪힐 수 있다. 그러나 때로는 문제된 법이 인정된 바와 같이 실현하도록 설계된 목적(object)을 고려하면 정의로운 법이 인정해야 할 다툼들과 차이들이 명료해질 수 있으며, 그때 그것들은 거의 다툼에 열려 있지 않을 수 있다. 어떤 법이 빈곤 구제를 마련한다면, ‘같은 사례들은 함께 취급되어야 한다(Like cases be treated alike)’는 원칙의 요구는 분명 구제 청구자들(claimants)의 필요(need)에 주목하는 일을 수반할 것이다. 유사한 필요의 기준은 과세 부담이 누진소득세에 의해 과세되는 개인들의 부에 맞추어 조정될 때 암묵적으로 인정된다. 때로 관련되는 것은 문제된 법의 행사가 관계될 수 있는 특정 기능에 대한 사람들의 능력들(capacities)이다. 아동들이나 정신 이상인 사람들을 선거권에서 배제하거나, 그들에게 유언장을 작성하거나 계약을

체결할 권한(power)을 주지 않는 법들은 정의로운 것으로 간주된다. 그러한 사람들은 제정신인 성인들이 가진 것으로 추정되는, 이러한 제도적 수단들을 이성적으로 사용할 능력을 결여하기 때문이다. 그러한 차별들은 명백히 관련되는 근거들 위에서 이루어지는 반면, 이 사안들에서 성별 사이의 차별이나 서로 다른 피부색의 사람들 사이의 차별은 그렇지 않다. 물론 여성이나 유색인들의 종속을 방어하면서, 여성이나 유색인들이 백인 남성의 이성적 사고와 결정 능력을 결여한다고 논변되어 왔다. 그러나 그렇게 논변하는 것은, 그러한 능력이 여성들이나 유색인들에게 결여되어 있다는 아무 증거도 없는 상황에서는 다시금 이 원칙에 말뿐인 경의를 바칠 뿐이기는 하지만, 그러한 법의 경우 특정 기능에 대한 동등한 능력이 정의의 기준이라는 점을 인정하는 것이다.

지금까지 우리는 개인들 사이에 부담들과 혜택들을 분배하는(distributing) 것으로 볼 수 있는 법들의 정의 또는 부정의를 고려하였다. 그 혜택들 가운데 일부는 빈민 구제나 식량 배급처럼 유형적(tangible)이고, 다른 것들은 형사법이 제공하는 신체적 해악으로부터의 보호, 유연능력 또는 계약체결능력에 관한 법들이 제공하는 제도적 수단들(facilities), 또는 투표권(right to vote)처럼 무형적(intangible)이다. 이 넓은 의미의 분배와 구별하여, 우리는 한 사람이 다른 사람에게 가한 손해(injury)에 대한 보상(compensation)을 구별해야 한다. 여기서 정의로운 것과 (p. 164) 정의의 중심 격률인 ‘같은 사례들은 같게, 다른 사례들은 다르게 취급하라(Treat like cases alike and different cases differently)’ 사이의 연결은 분명 덜 직접적이다. 그러나 그것은 추적할 수 없을 정도로 간접적인 것은 아니며 다음 방식으로 볼 수 있다. 불법행위(torts)나 민사상 손해(civil injuries)에 대해 한 사람이 다른 사람에게 보상하도록 마련하는 법들은 두 가지 서로 다른 이유로 부정의한 것으로 여겨질 수 있다. 한편으로 그것들은 불공정한 특권들이나 면제들을 정립할 수 있다. 귀족들만이 명예훼손으로 소를 제기할 수 있거나, 어떤 백인도 유색인에 대한 주거침입이나 폭행에 대해 책임지지 않는 경우가 그러할 것이다. 그러한 법들은 보상의 권리들과 책무들(rights and duties of compensation)의 공정한 분배 원칙들을 직접적으로 위반할 것이다. 그러나 그러한 법들은 전혀 다른 방식으로도 부정의할 수 있다. 불공정한 차별들은 만들지 않으면서도, 도덕적으로는 보상이 마땅한 것으로 여겨지는 경우임에도

한 사람이 다른 사람에게 가한 특정 유형의 손해에 대한 구제(remedy)를 전혀 마련하지 못할 수 있기 때문이다. 이 사안에서 법은 모두를 같게 취급하면서도 부정의할 수 있다.

그러한 법들의 흠(vice)은 그때 부당분배(maldistribution)가 아니라, 타인에게 가하는 것이 도덕적으로 그른 손해들(injuries)에 대한 보상을 모두에게 똑같이 거부하는 데 있을 것이다. 그러한 부정의한 구제 거부의 가장 조악한 사례는, 함부로 가해진 신체적 해악에 대해 아무도 손해배상(damages)을 받을 수 없는 체계일 것이다. 형사법이 그러한 폭행들을 형벌을 붙여 금지하더라도 이 부정의는 여전히 남을 것이라는 점은 주목할 만하다. 그토록 조악한 사례들은 거의 발견되지 않지만, 광고업자들이 종종 수익성이 있다고 여기는 사생활 침해들에 대해 영국법이 보상을 마련하지 못한 것은 자주 이러한 방식으로 비판되어 왔다. 그러나 도덕적으로 마땅한 것으로 여겨지는 곳에서 보상을 마련하지 못하는 것은, 도덕적으로 그른 것으로 여겨지는 어떤 행위에 의해 타인의 비용으로 ‘부당이득(unjust enrichment)’을 허용하는 불법행위법 또는 계약법의 기술적 사항들(technicalities)에 대한 부정의 비난의 핵심(gravamen)이기도 하다.

손해에 대한 보상의 정의와 부정의, 그리고 ‘같은 사례들은 같게, 다른 사례들은 다르게 취급하라(Treat like cases alike and different cases differently)’는 원칙 사이의 연결은, 법 바깥에 법이 관심을 가지는 자들이 일정한 종류의 해로운 행위를 서로 삼가도록 요구할 권리(right)를 가진다는 도덕적 확신(moral conviction)이 존재한다는 사실에 있다. 적어도 더 거친 (p. 165) 종류의 해악을 금지하는 그러한 상호적 권리들과 의무들의 구조는 모든 사회 집단의 도덕의 기초를 이루지만, 그 전부는 아니다. 그 효과는 자연의 불평등들을 상쇄하기 위해 개인들 사이에 도덕적이고, 어떤 의미에서는 인위적인 평등을 창출하는 것이다. 도덕 규범(moral code)이 한 사람이 다른 사람을 강탈하거나 그에게 폭력을 사용하는 것을, 우월한 힘이나 교활함이 그로 하여금 아무 처벌 없이 그렇게 할 수 있게 해 주더라도, 금지할 때, 강한 자와 교활한 자는 약한 자와 단순한 자와 같은 평면 위에 놓인다. 그들의 사례들은 도덕적으로 같아진다. 따라서 도덕을 무시하고 자기 힘을 이용하여 타인을 해하는 강한 사람은, 도덕이 확립한 이 균형 또는 평등의 질서를 뒤흔드는 것으로 파악된다. 그러면 정의는 이 도덕적

현상 유지 상태(moral status quo)가 가능한 한 그른 행위자(wrongdoer)에 의해 회복되어야 한다고 요구한다. 단순한 절도의 사례들에서는 이것은 단순히 가져간 물건을 돌려주는 일을 수반할 것이다. 그리고 다른 손해들에 대한 보상은 이 원초적 관념(notion)의 확장이다. 타인을 신체적으로 해한 사람은 의도적으로든 과실로든 자기 피해자로부터 무언가를 가져간 것으로 생각된다. 그리고 그가 문자 그대로 그렇게 한 것은 아니지만, 이 비유는 지나치게 억지스럽지 않다. 그는 자기 피해자의 비용으로 이익을 얻었기 때문이다. 비록 그것이 오직 그를 해하려는 자기 욕망을 충족시킨 것이거나 적절한 예방조치를 취할 책무(duty)에 자기 편의를 희생하지 않은 것일 뿐이라 해도 그렇다. 따라서 법들이 정의가 요구하는 곳에서 보상을 마련할 때, 그것들은 피해자와 그른 행위자가 평등의 기반 위에 있고 따라서 같은 자들인 도덕적 현상 유지 상태를, 교란 뒤에 회복하도록 마련함으로써 ‘같은 사례들은 같게 취급하라’는 원칙을 간접적으로 인정한다. 다시 말해, 이 사안들에서 개인들을 상호적 평등의 기반 위에 놓지 않는 도덕 전망도 상상 가능하다. 도덕 규범이 야만인들(Barbarians)에게 그리스인들(Greeks)을 폭행하는 것은 금지하지만, 그리스인들이 야만인들을 폭행하는 것은 허용할 수도 있다. 그러한 경우 야만인은 자신이 한 손해들에 대해 그리스인에게 보상할 도덕적 구속을 지는 것으로 생각될 수 있지만, 자신은 그러한 보상을 받을 자격이 없을 수 있다. 여기서 도덕 질서는 피해자와 그른 행위자가 다르게 취급되는 불평등의 질서일 것이다. 우리에게 혐오스러울 수 있는 그러한 전망에서라면, 법은 이 차이를 반영하고 다른 사례들을 다르게 취급할 때에만 정의로울 것이다.

정의에 대한 이 간략한 윤곽에서 우리는 정의의 더 단순한 적용들 가운데 일부만을 고려하였다. 정의로운 것으로 평가되는 법들에 귀속되는 특정한 탁월성의 형식을 보여주기 위해서였다. (p. 166) 이것은 법들이 가지거나 결여할 수 있는 다른 가치들과 구별될 뿐 아니라, 때로는 정의의 요구들이 다른 가치들과 충돌할 수도 있다. 이는 범죄가 만연해진 때 법원이 특정 범죄자에게 형을 선고 하면서, 다른 유사한 사례들에서 내려진 것보다 더 엄한 형을 내리고, 공공연히 이것을 ‘경고로서’ 행하는 경우에 발생할 수 있다. 여기에는 ‘같은 사례들은 같게 취급하라’는 원칙을 사회의 일반적 안전 또는 복지에 희생시키는 일이 있

다. 민사 사건들에서는, 법이 어떤 도덕적으로 그른 행위(moral wrong)에 대해 구제(remedy)를 마련하지 않을 때, 정의와 일반선(general good) 사이의 유사한 충돌이 후자에 유리하게 해소된다. 그러한 경우들에서 보상을 집행하는 일이 증명의 큰 난점들을 수반하거나, 법원들에 과도한 부담을 주거나, 기업 활동을 부당하게 방해할 수 있기 때문이다. 어떤 사회든, 도덕적으로 그른 행위가 행해진 경우에도 감당할 수 있는 법 집행의 양에는 한계가 있다. 반대로 법은 사회의 일반 복지의 이름으로, 한 사람이 다른 사람에게 손해를 입힌 경우, 도덕적으로 정의의 사안으로는 마땅하다고 생각되지 않을 곳에서도 보상을 강제할 수 있다. 이는 불법행위 책임이 엄격한 경우, 즉 해할 의도나 주의의무를 다하지 못한 것과 독립적인 경우에 해당한다고 자주 말해진다. 이러한 책임 형식은 때때로 ‘사회’의 이익상 우연히 손해를 입은 자들이 보상받아야 하며, 이를 하는 가장 쉬운 방법은 아무리 주의 깊게 통제되더라도 그러한 사고들을 낳는 활동을 하는 자들에게 부담을 지우는 것이라는 근거 위에서 방어된다. 그들은 보통 충분한 재정적 여력(deep pockets)과 보험에 가입할 기회를 가진다. 이러한 방어가 제시될 때 그 안에는 사회의 일반 복지에 대한 암묵적 호소가 있으며, 그것은 도덕적으로 수용 가능하고 때로는 심지어 ‘사회적 정의(social justice)’라고 불릴 수도 있지만, 두 개인 사이의 현상 유지 상태를 가능한 한 시정(redress)하는 데 단순히 관심을 가지는 일차적 정의 형식들과는 다르다.

정의의 관념들과 사회적 선 또는 복지의 관념들 사이의 중요한 접합점(juncture point)에 주목해야 한다. 모든 개인들에게 똑같이 받아들여지거나 그들의 복지를 증진하는 사회적 변화들이나 법들은 매우 드물다. 경찰 보호나 도로와 같은 가장 기본적인 필요들을 마련하는 법들만이 여기에 가까이 갈 뿐이다. 대부분의 경우 법은 다른 사람들이 선호하는 것을 박탈하는 대가로만 인구의 한 부류에게 혜택들을 제공한다. 빈자들을 위한 마련은 (p. 167) 다른 사람들의 재화에서만 이루어질 수 있다. 모두를 위한 의무 학교교육은 자기 자녀를 사적으로 교육하려는 사람들에게 자유의 상실을 의미할 뿐 아니라, 산업에서의 자본 투자나 노령연금 또는 무상 의료서비스를 줄이거나 희생시키는 대가로만 재정이 마련될 수 있다. 그러한 경쟁하는 대안들 사이에서 선택이 이루어졌을 때, 그것은 ‘공익(public good)’ 또는 ‘공동선(common good)’을

위한 것이었다는 근거 위에서 적절한 것으로 방어될 수 있다. 여러 대안들이 공동선에 기여하는 바를 측정하고 더 큰 것을 식별할 척도는 없어 보이므로, 이 문구들이 무엇을 의미하는지는 명확하지 않다. 그러나 공동체의 모든 부분들의 이익들에 대한 사전 고려 없이 이루어진 선택은 단지 당파적이고 부정의한 것으로 비판에 열려 있을 것이라는 점은 분명하다. 그러나 입법 전에 모두의 청구들(claims)이 불편부당하게 고려되었다면, 결과적으로 한 부분의 청구들이 다른 부분들의 청구들에 종속되었더라도, 그것은 이 비난(imputation)에서 벗어날 것이다.

기실 어떤 사람들은 서로 다른 부류들이나 이익들의 경쟁하는 청구들 사이의 선택이 ‘공동선을 위하여’ 이루어졌다는 주장(claim)이 사실상 의미할 수 있는 전부는, 모두의 청구들이 결정 전에 이렇게 불편부당하게 검토되었다는 것이라고 논변할 수도 있다. 이것이 참인지 아닌지와 무관하게, 이 의미에서의 정의가 공동선을 위한 것이라고 자처하는 어떤 입법적 선택이든 충족해야 할 적어도 하나의 필요조건이라는 점은 분명해 보인다. 여기서 우리는 우리가 논의한 단순한 형식들과 다른 분배적 정의(distributive justice)의 추가 측면을 가진다. 여기서 정의롭게 ‘분배되는’ 것은 그것을 청구하는 사람들의 부류 사이의 어떤 특정 혜택이 아니라, 서로 다른 혜택들에 대한 경쟁하는 청구들에 대한 불편부당한 주목(attention)과 고려(consideration)이기 때문이다.

2. 도덕적 의무(Moral Obligation)와 법적 의무(Legal Obligation)

정의(Justice)는 도덕의 한 부분을 구성하며, 주로 개인의 행위(conduct)가 아니라 개인들의 부류들(classes)이 대우받는 방식들에 관심을 가진다. 바로 이것이 정의에 법과 다른 공적 또는 사회적 제도들을 비판할 때 그 특수한 관련성(relevance)을 부여한다. 정의는 미덕들(virtues) 가운데 가장 공적이고 가장 법적인 것이다. 그러나 정의의 원칙들은 도덕이라는 관념(idea of morality)을 고갈시키지 않으며, 도덕적(p. 168) 근거들 위에서 이루어지는 법에 대한 모든 비판이 정의의 이름으로 이루어지는 것도 아니다. 법들은 단순히 도덕적으로 나쁜 것으로 비난될 수 있다. 그것들이 도덕이 개인들에게 하지 말라고 금지하는

특정 행위들을 사람들에게 하라고 요구하거나, 도덕적으로 의무적인 행위들을 삼가라고 요구하기 때문이다.

그러므로 도덕에 속하고 행위를 도덕적으로 의무적인 것으로 만드는, 개인들의 행위에 관한 원칙들(principles), 규칙들(rules), 기준들(standards)을 일반적인 용어들로 특징지을 필요가 있다. 여기서 두 가지 관련된 난점이 우리 앞에 놓인다. 첫째, ‘도덕(morality)’이라는 말과 ‘윤리(ethics)’처럼 그와 관련되거나 거의 동의어인 모든 다른 용어들은 상당한 정도의 모호성(vagueness) 또는 ‘개방적 직조(open texture)’의 영역을 가진다. 어떤 형태의 원칙이나 규칙은 어떤 이들에게는 도덕적인 것으로 분류되지만 다른 이들에게는 그렇지 않을 것이다. 둘째, 이 점에 대한 합의가 있고 일정한 규칙들 또는 원칙들이 도덕에 속한다는 점이 다툼 없이 받아들여지는 경우에도, 그것들의 지위(status) 또는 인간 지식과 경험의 나머지 부분과의 관계에 관해서는 여전히 큰 철학적 불일치가 있을 수 있다. 그것들은 인간에 의해 만들어진 것이 아니라 인간 지성에 의한 발견을 기다리는, 우주의 직물(fabric)의 일부를 구성하는 불변의 원칙들인가? 아니면 변화하는 인간 태도들, 선택들, 요구들, 또는 감정들의 표현인가? 이것들은 도덕철학의 두 극단을 조야하게 정식화한 것이다. 그 사이에는 도덕의 본성을 해명하려는 노력 속에서 철학자들이 발전시켜 온 많은 복잡하고 미묘한 변형들이 놓여 있다.

이하에서 우리는 이러한 철학적 난점들을 피하려 할 것이다. 우리는 뒤에서² ‘중요성(Importance)’, ‘의도적 변경으로부터의 면역성(Immunity from deliberate change)’, ‘도덕적 위반행위들의 자발적 성격(Voluntary character of moral offences)’, ‘도덕적 압력의 형식(The form of moral pressure)’이라는 표제들 아래, 가장 일반적으로 ‘도덕적’인 것으로 여겨지는 행위의 원칙들, 규칙들, 기준들에서 언제나 함께 발견되는 네 가지 주된 특징들을 식별할 것이다. 이 네 특징들은 그러한 기준들이 사회생활이나 개인들의 삶에서 수행하는 특징적이고 중요한 기능의 서로 다른 측면들을 반영한다. 이것만으로도 이 네 특징들을 가진 것이 무엇이든 별도의 고려를 위해, 무엇보다도 법과의 대비 및 비교를 위해, 따로 확정할 정당한 이유가 될 것이다. (p. 169) 더 나아가 도덕이

²아래 173쪽 이하.

이 네 특징들을 가진다는 주장은 그 지위(status) 또는 ‘근본적’ 성격에 관한 경쟁하는 철학 이론들 사이에서 중립적이다. 거의 모든 철학자들은 아니더라도 대부분은 이 네 특징들이 어떤 도덕 규칙이나 원칙에서도 필요하다는 점에는 동의할 것이다. 비록 도덕이 그것들을 가진다는 사실에 대해서는 매우 다른 해석이나 설명을 제시하겠지만 말이다. 기실 이 특징들이 필요하기는 하지만 오직 필요할 뿐이고, 더 엄격한 검사라면 도덕에서 배제될 일정한 행위 규칙들이나 원칙들로부터 도덕을 구별하기에는 충분하지 않다는 반론이 제기될 수 있다. 우리는 그러한 반론들이 근거하는 사실들을 언급하겠지만, ‘도덕(morality)’의 더 넓은 의미를 고수할 것이다. 우리의 정당화는 이것이 많은 용례와 부합한다는 점과, 이 넓은 의미에서 그 말이 지칭하는 것이 사회적·개인적 삶에서 중요하고 구별 가능한 기능을 수행한다는 점 모두에 있다.

우리는 먼저 주어진 사회의 ‘그(the) 도덕’ 또는 실제 사회 집단의 ‘수용된(accepted)’ 도덕이나 ‘관행적(conventional)’ 도덕으로 자주 지칭되는 사회 현상을 고려할 것이다. 이 문구들은 특정 사회 안에서 널리 공유되는 행위 기준들을 지칭하며, 개인의 삶을 지배할 수 있지만 그가 함께 사는 사람들 가운데 상당수와 공유하지는 않는 도덕 원칙들이나 도덕 이상들과 대비된다. 사회 집단의 공유되거나 수용된 도덕의 기본 요소는, 우리가 앞서 제V장에서 의무(obligation)의 일반 관념을 해명할 때 이미 서술했고 거기서 의무의 일차 규칙들(primary rules of obligation)이라고 부른 종류의 규칙들로 이루어진다. 이 규칙들은 그것들을 뒷받침하는 중대한 사회적 압력과, 그것들에 대한 준수(compliance)가 수반하는 개인적 이익 또는 경향성(inclination)의 상당한 희생이라는 두 점에서 다른 규칙들과 구별된다. 같은 장에서 우리는 또한 그러한 규칙들이 사회 통제의 유일한 수단이었던 단계의 사회를 그렸다. 우리는 그 단계에서는 더 발전한 사회들에서 법규칙들과 도덕 규칙들 사이에 이루어지는 명확한 구별에 상응하는 것이 아무것도 없을 수 있다는 점에 주목하였다. 어떤 규칙들은 주로 불복종에 대한 처벌의 위협들에 의해 유지되고, 다른 규칙들은 규칙들에 대한 추정된 (p. 170) 존중이나 죄책감 또는 후회의 감정들에 대한 호소에 의해 유지된다면, 이 구별의 어떤 발생 초기 형태가 존재할 수도 있다. 이 초기 단계가 지나고 전법적(pre-legal) 세계에서 법적 세계로의 걸음이 이

루어져, 사회 통제의 수단이 이제 승인, 재판, 변경의 규칙들을 포함하는 규칙 체계를 포함하게 되면, 법규칙들과 다른 규칙들 사이의 이 대비는 어떤 확정적인 것으로 굳어진다. 공식 체계(official system)를 통해 식별되는 의무의 일차 규칙들은 이제 공식적으로 인정된(officially recognized) 규칙들과 나란히 계속 존재하는 다른 규칙들로부터 구분된다. 사실 우리 공동체에서, 그리고 기실 이 단계에 도달한 모든 공동체에서, 법체계 바깥에 놓인 여러 유형의 사회 규칙과 기준들이 존재한다. 이들 가운데 일부만이 보통 도덕적인 것으로 생각되고 말해지지만, 어떤 법이론가들은 모든 비법적 규칙들을 지칭하기 위해 ‘도덕적(moral)’이라는 말을 사용해 왔다.

그러한 비법적 규칙들은 여러 서로 다른 방식으로 구별되고 분류될 수 있다. 어떤 것들은 매우 제한된 범위의 규칙들로서 특정 행위 영역(예: 복장)이나, 의도적으로 만들어진 간헐적 기회들만 있는 활동들(의례와 게임)에 관한 것이다. 어떤 규칙들은 사회 집단 일반에 적용되는 것으로 파악된다. 다른 규칙들은 그 안의 특수 하위집단들, 곧 일정한 특징들에 의해 구별되는 별개의 사회 부류로서의 하위집단들이나, 제한된 목적들을 위해 만나거나 결합하기로 한 그들 자신의 선택에 의해 구별되는 하위집단들에 적용된다. 어떤 규칙들은 합의에 힘입어 구속적인 것으로 여겨지고 자발적 탈퇴를 허용할 수 있다. 다른 규칙들은 합의나 다른 어떤 형태의 의도적 선택에도 기원을 두지 않는 것으로 생각된다. 어떤 규칙들은 위반될 때 해야 할 ‘옳은(right)’ 일에 대한 단언(assertion)이나 상기(reminder) 이상을 만나지 않을 수 있고(예: 예절 또는 올바른 말의 규칙들), 다른 규칙들은 중대한 비난이나 경멸, 또는 관련 결사체로부터의 더 길거나 짧은 배제를 만날 수 있다. 정확한 척도는 구성될 수 없겠지만, 이러한 서로 다른 유형의 규칙들에 귀속되는 상대적 중요성에 관한 구상(conception)은 그것들이 요구하는 사적 이익의 희생 정도와 부합(conformity)을 위한 사회적 압력의 무게 모두에 반영된다.

법체계를 발전시킨 모든 사회들에는 그 비법적 규칙들 가운데 최고의 중요성이 부여되고, 핵심적 차이들(crucial differences)에도 불구하고 그 사회의 법과 많은 유사성들을 가지는 것들이 있다. 법규칙들의 요구들을 표현하는 데 사용되는 ‘권리들(rights)’, ‘의무들(obligations)’, ‘책무들(duties)’의 어휘는 매우

자주 (p. 171) ‘도덕적(moral)’이라는 말을 덧붙여, 이러한 규칙들이 요구하는 행위들이나 자제들을 표현하는 데 사용된다. 모든 공동체들에는 법적 의무와 도덕적 의무 사이에 내용의 부분적 중첩이 있다. 다만 법규칙들의 요구들은 더 특정적이고 그 도덕적 대응물들보다 더 상세한 예외들로 둘러싸여 있다. 특징적으로, 도덕적 의무와 책무는 많은 법규칙들처럼, 의도적으로 선택된 경우들에서의 드물거나 간헐적인 활동들이 아니라 집단의 삶에서 끊임없이 반복되는 상황들에서 무엇이 행해져야 하거나 행해지지 말아야 하는지를 다룬다. 그러한 규칙들이 요구하는 것은 자제들(forbearances)이거나, 그 수행에 어떤 특수한 기술이나 지능도 요구되지 않는다는 의미에서 단순한 행위들이다. 도덕적 의무들은 대부분의 법적 의무들처럼 어떤 정상 성인에게도 가능한 능력 범위 안에 있다. 이러한 도덕 규칙들의 준수(compliance)는 법규칙들의 준수와 마찬가지로 당연한 것으로 받아들여진다. 그래서 위반은 중대한 비난을 불러오지만, 도덕적 의무에 대한 부합(conformity)은, 다시 법에 대한 복종처럼, 예외적인 양심성(conscientiousness), 인내(endurance), 또는 특별한 유혹에 대한 저항으로 표시될 때를 제외하면 칭찬의 대상이 아니다. 도덕적 의무들과 책무들에 대해서는 여러 분류들이 이루어질 수 있다. 일부는 사회 구성원 모두가 차지하지는 않는 비교적 구별되고 지속적인 기능들이나 역할들에 속한다. 아버지나 남편이 가족을 돌볼 책무들이 그러하다. 다른 한편으로는 모든 정상 성인들이 평생 동안 가진 것으로 파악되는 일반 의무들(예: 폭력을 삼갈 의무)과, 그러한 구성원이 타인들과 특수한 관계들에 들어감으로써 부담하게 될 수 있는 특수 의무들(예: 약속을 지키거나 받은 서비스를 되돌려 줄 의무)이 모두 있다.

이 가장 근본적인 종류의 도덕 규칙들에서 인정되는 의무들과 책무들은 사회마다 달라질 수 있고, 단일한 사회 안에서도 시기에 따라 달라질 수 있다. 그 가운데 일부는 집단의 건강이나 안전을 위해 요구된다고 여겨지는 것에 관한 상당히 잘못된 또는 심지어 미신적인 믿음들을 반영할 수 있다. 어떤 사회에서는 아내가 남편의 장례용 장작더미에 몸을 던지는 것이 그녀의 책무일 수 있고, 다른 사회에서는 자살이 공통 도덕(common morality)에 대한 위반(offence)일 수 있다. 도덕 규범들(moral codes) 사이에는 주어진 사회의 특수하지만 실제적인 필요들에서 생겨날 수도 있고, 미신이나 무지에서 생겨날 수도 있는 다양성이

있다. 그러나 법과 구별될 수 있는 단계에 이른 사회들의 사회적 도덕(social morality)은, 인간들과 그들이 사는 세계가 가장 친숙하고 명백한 특성들 가운데 일부를 유지하는 한, 어떤 사회의 생존에도 본질적인 사적 경향성 또는 이익의 희생을 요구하는 일정한 의무들과 책무들을 언제나 포함한다. 사회생활에 명백히 요구되는 그러한 규칙들 가운데에는 폭력의 자유로운 사용을 금지하거나 적어도 제한하는 규칙들, 타인들과의 거래에서 일정한 형식의 정직성과 진실성을 요구하는 규칙들, 유형물들의 파괴나 타인들로부터의 탈취를 금지하는 규칙들이 있다. 가까이 함께 사는 어떤 개인들의 집단 안에서 이러한 가장 기본적인 규칙들에 대한 부합(conformity)이 당연한 것으로 생각되지 않는다면, 우리는 그 집단을 사회로 서술하는 데 의심을 품을 것이며, 그것이 오래 지속될 수 없다는 점을 확신할 것이다.

그러므로 도덕적 및 법적 의무와 책무의 규칙들은, 그 공통 어휘가 우연이 아님을 보여주기에 충분한 일정한 두드러진 유사성들을 가진다. 이것들은 다음과 같이 요약될 수 있다. 그것들은 구속되는 개인의 동의와 독립적으로 구속적인 것으로 파악되고, 부합(conformity)을 위한 중대한 사회적 압력에 의해 뒷받침된다는 점에서 같다. 법적 의무들과 도덕적 의무들 모두의 준수(compliance)는 칭찬의 대상이 아니라 당연한 것으로 받아들여져야 하는 사회생활에 대한 최소한의 기여로 간주된다. 더 나아가 법과 도덕은 모두 특수한 활동들이나 경우들이 아니라 삶 전체에 걸쳐 끊임없이 반복되는 상황들에서 개인들의 행위를 규율하는 규칙들을 포함하며, 양자 모두 특정 사회의 실제적 또는 상상된 필요들에 특유한 많은 것을 포함할 수 있지만, 함께 살아가는 데 성공하려는 어떤 인간 집단에 의해서도 명백히 충족되어야 하는 요구들을 한다. 따라서 사람 또는 재산에 대한 폭력 금지의 일부 형식들과 정직성 및 진실성의 일부 요구들은 양자 모두에서 발견될 것이다. 그러나 이러한 유사성들에도 불구하고, 법과 도덕이 공유할 수 없는 일정한 특징들이 존재한다는 점은 많은 이들에게 명백해 보였다. 비록 법리학(jurisprudence)의 역사에서 이것들은 정식화하기 가장 어려운 것들이 드러났지만 말이다.

그 본질적 차이를 요약적으로 전달하려는 가장 유명한 시도는, 법규칙들은 ‘외부(external)’ 행위만을 요구하고 행위의 동기들, 의도들, 또는 다른 ‘내부

(internal)’ 수반물들에는 (p. 173) 무관심한 반면, 도덕은 어떤 특정한 외부 행위들도 요구하지 않고 오직 선한 의지(good will)나 적절한 의도들 또는 동기만을 요구한다고 단언하는 이론이다. 이것은 실제로, 올바르게 이해된 법규칙들과 도덕 규칙들은 결코 같은 내용을 가질 수 없다는 놀라운 단언에 이른다. 그리고 그것이 진리의 암시를 담고 있기는 하지만, 있는 그대로는 심각하게 오도적이다. 그것은 사실 도덕의 일정한 중요한 특징들, 특히 도덕적 비난과 법적 처벌 사이의 일정한 차이들로부터 나온 추론이지만, 잘못된 추론이다. 어떤 사람이 도덕 규칙들이 금지하는 일을 하거나 그것들이 요구하는 일을 하지 못한 경우, 그가 그것을 비의도적으로 그리고 모든 주의에도 불구하고 그렇게 했다는 사실은 도덕적 비난으로부터의 면책(excuse)이다. 반면 법체계나 관습은 규칙들을 비의도적으로 그리고 ‘과실(fault)’ 없이 위반한 자들도 처벌에 책임질 수 있게 하는 ‘엄격책임(strict liability)’ 규칙들을 가질 수 있다. 따라서 도덕에서 ‘엄격책임’이라는 관념(notion)이 이 영역의 어떤 것 못지않게 용어모순에 가까이 온다는 것은 기실 참이지만, 그것은 법체계에서 발견될 때 단지 비판에 열려 있을 수 있는 것이다. 그러나 이것은 도덕이 오직 선한 의도, 의지, 또는 동기만을 요구한다는 뜻은 아니다. 기실 그렇게 논변하는 것은, 뒤에서 보이듯이, 행위에 대한 면책(excuse)이라는 관념을 정당화(justification)라는 관념과 혼동하는 것이다.

그럼에도 불구하고 이 혼란된 논변 속에는 중요한 어떤 것이 희화화되어 있다. 법과 도덕(morals) 사이의 차이가 한쪽의 ‘내부성(internality)’ 과 다른 쪽의 ‘외부성(externality)’ 사이의 대비와 연결되어 있다는 막연한 감각은, 법과 도덕에 관한 사변(speculation)에서 너무 되풀이되는 주제이므로 전적으로 근거 없을 수는 없다. 그것을 폐기하기보다, 우리는 그것을 도덕을 법규칙들뿐 아니라 다른 형태의 사회 규칙들로부터도 집합적으로 구별해 주는 네 가지 주된 관련 특징들의 압축적 진술(compendious statement)로 다룰 것이다.

- (i) 중요성(Importance). 어떤 도덕 규칙이나 기준의 본질적 특징은 그것을 유지하는 것이 큰 중요성을 가지는 것으로 여겨진다는 데 있다고 말하는 것은 동어반복적이고 모호해 보일 수 있다. 그러나 이 특징은 어떤 사회 집단이나 개인의 도덕에 대한 충실한 설명에서도 생략될 수 없고, 더 정

밀하게 만들어질 수도 없다. 그것은 여러 방식으로 드러난다. 첫째, 도덕 기준들은 그것들이 제한하는 강한 정념들의 충동에 맞서, 그리고 상당한 개인적 이익을 희생하는 대가로 유지된다는 단순한 사실에서 드러난다. 둘째, 개별 사례들에서 부합(conformity)을 얻기 위해서뿐 아니라 도덕 기준들이 사회의 모든 사람에게 당연한 것으로 가르쳐지거나 전달되도록 확보하기 위해 행사되는 중대한 형식들의 사회적 압력에서 드러난다. 셋째, 도덕 기준들이 일반적으로 수용되지 않는다면 개인들의 삶에서 광범위하고 달갑지 않은 변화들이 발생할 것이라는 일반적 인정에서 드러난다. 도덕과 대조적으로, 품행(deportment), 예절(manners), 복장의 규칙들, 그리고 전부는 아니지만 일부 법규칙들은 중대한 중요성의 척도에서 비교적 낮은 자리를 차지한다. 그것들은 따르기에 성가실 수는 있지만 큰 희생을 요구하지 않는다. 부합을 얻기 위해 큰 압력이 행사되지 않으며, 그것들이 준수되지 않거나 변경되더라도 사회생활의 다른 영역들에서 큰 변경들이 뒤따르지 않을 것이다. 도덕 규칙들의 유지에 이렇게 귀속되는 중요성의 많은 부분은 매력적인 합리주의적 노선에서 아주 단순하게 설명될 수 있다. 그것들은 구속되는 사람의 사적 이익들의 희생을 요구하더라도, 그것들에 대한 준수(compliance)는 모두가 같이 공유하는 생명적 이익들을 확보한다. 그것은 사람들을 명백한 해악으로부터 직접 보호하거나, 전될 만하고 질서 있는 사회의 짜임(fabric)을 유지함으로써 그렇게 한다. 그러나 많은 사회적 도덕의 합리성이 명백한 해악들로부터의 보호로서 이렇게 방어될 수 있다 하더라도, 이러한 단순한 공리주의적 접근이 언제나 가능한 것은 아니다. 또한 가능한 곳에서도, 그것이 도덕에 따라 사는 사람들의 관점을 대표하는 것으로 받아들여져서는 안 된다. 결국 어떤 사회의 도덕에서든 가장 두드러진 부분은 성적 행위(sexual behaviour)에 관한 규칙들로 이루어지는데, 그 규칙들에 부여되는 중요성이 그것들이 금지하는 행위가 타인들에게 해롭다는 믿음과 연결되어 있다는 점은 결코 명확하지 않다. 또한 그러한 규칙들이 실제로 언제나 이러한 정당화를 가진다고 보일 수도 없다. 자기 도덕을 신적으로 명령된 것으로 보기를 그만둔 현대 사회에서도, 동성애에 대한 공통의 거부(veto)

와 같은 성적 행위의 도덕적 규율에 부여되는 중요성은 타인들에 대한 해악성 계산으로 설명되지 않는다. 성적 기능들과 감정들은 모두에게 그토록 중대한 사안이고 정서적 관심의 대상이어서, 그 표현의 수용된 또는 정상적인 형식들로부터의 이탈들은 쉽게 내재적 ‘수치(pudor)’ 또는 중요성을 띠게 된다. 그것들은 (p. 175) 사회적 해악성에 대한 확신 때문이 아니라, 단순히 ‘부자연스러운’ 것 또는 그 자체로 혐오스러운 것으로 혐오된다. 그러나 이런 종류의 강한 사회적 거부들(social vetoes)에 도덕이라는 명칭(title)을 부인하는 것은 부조리할 것이다. 기실 성적 도덕은 보통 사람들이 도덕을 무엇이라고 생각하는지에서 아마 가장 두드러진 측면일 것이다. 물론 사회가 자기 자신의 도덕을 이러한 ‘비공리주의적’ 방식으로 본다는 사실은, 그 규칙들의 유지가 쓸모없거나 큰 고통이라는 비용으로 구입된 것으로 판단되는 곳에서, 그 규칙들이 비판이나 비난에서 자유롭다는 뜻은 아니다.

우리가 보았듯이, 법규칙들은 같은 행위를 요구하거나 금지한다는 의미에서 도덕 규칙들과 대응할 수 있다. 그렇게 하는 법규칙들은 의심할 바 없이 그 도덕적 대응물들만큼 중요한 것으로 느껴진다. 그러나 중요성은 도덕의 지위에 본질적인 것과 달리 모든 법규칙의 지위에 본질적인 것은 아니다. 어떤 법규칙이 유지하기에 전혀 중요하지 않은 것으로 일반적으로 생각될 수 있고, 기실 그것이 폐지되어야 한다는 데 일반적 합의가 있을 수도 있다. 그러나 그것은 폐지될 때까지 법규칙으로 남는다. 반면 어떤 규칙을, 아무도 더 이상 중요하거나 유지할 가치가 있다고 생각하지 않는에도 어떤 사회의 도덕의 일부라고 생각하는 것은 부조리할 것이다. 오래된 관습들과 전통들은 기실 한때 도덕 규칙들의 지위를 가졌을 수 있지만, 이제 단지 옛 시절을 위해 유지되는 경우, 그것들의 준수와 위반에 부여되던 중요성과 함께 도덕의 일부로서의 지위도 증발한 것이다.

- (ii) 의도적 변경으로부터의 면역성(Immunity from deliberate change). 법 체계의 특징은 새로운 법규칙들이 의도적 제정(deliberate enactment)에 의해 도입될 수 있고, 오래된 규칙들이 변경되거나 폐지될 수 있다는 점이다. 비록 어떤 법들은 최고 입법부의 권능(competence)을 제한하는

성문헌법에 의해 변경으로부터 보호될 수 있다 하더라도 그렇다. 그와 대조적으로 도덕 규칙들이나 원칙들은 이런 방식으로 생겨나거나 변경되거나 제거될 수 없다. 그러나 이것이 ‘할 수 없다(cannot)’ 고 단언하는 것은, 인간이 기후를 바꿀 수 없다는 단언처럼 어떤 상정 가능한 사태가 실제로 그러하다는 점을 부정하는 것이 아니다. 오히려 이 단언은 다음 사실들을 지목한다. ‘1960년 1월 1일부터 이러저러한 일을 하는 것은 범죄가 될 것이다’ 또는 ‘1960년 1월 1일부터 이러저러한 일을 하는 것은 더 이상 불법이 아닐 것이다’ 라고 말하고, 제정되거나 폐지된 법들을 참조하여 그러한 진술들을 뒷받침하는 것은 완전히 말이 된다. 그와 대조적으로 ‘내일부터 (p. 176) 이러저러한 일을 하는 것은 더 이상 비도덕적이지 않을 것이다’ 또는 ‘지난 1월 1일에 이러저러한 일을 하는 것이 비도덕적이 되었다’ 와 같은 진술들과, 이것들을 의도적 제정에 대한 참조로 뒷받침하려는 시도들은 무의미하지 않다 하더라도 놀라운 역설일 것이다. 도덕이 개인들의 삶에서 수행하는 역할과, 도덕 규칙들, 원칙들, 기준들이 법들처럼 의도적 행위에 의해 창조되거나 변경될 수 있는 것들로 여겨지는 것은 양립하지 않기 때문이다. 행위 기준들(standards of conduct)은 인간의 *fiat*만으로 도덕적 지위를 부여받거나 박탈당할 수 없다. 반면 제정(enactment)과 폐지(repeal) 같은 개념들의 일상적 사용은 법의 경우에는 동일한 것이 참이 아님을 보여준다.

도덕 철학의 많은 부분은 도덕의 이 특징을 설명하고, 도덕이 의도적 인간 선택에 의해 만들어지는 것이 아니라 인정되어야 할 ‘거기 있는’ 어떤 것이라는 감각을 해명하는 데 바쳐져 있다. 그러나 그 사실 자체는, 그 설명과 구별되는 것으로서, 도덕 규칙들의 특이성이 아니다. 이것이 도덕의 이 특징이 극히 중요하더라도 그 자체만으로 도덕을 다른 모든 사회 규범 형식들로부터 구별하는 데 쓰일 수 없는 이유이다. 이 점에서는, 다른 점들에서는 그렇지 않지만, 모든 사회 전통이 도덕과 같기 때문이다. 전통 역시 인간의 *fiat*에 의한 제정이나 폐지가 불가능하다. 어쩌면 사실이 아닐지도 모르는 이야기, 곧 한 영국 신설 퍼블릭스쿨의 교장이 다음 학기 시작부터 상급생들이 일정한 복장을

입는 것이 그 학교의 전통이 될 것이라고 발표했다는 이야기는, 그 희극적 효과를 전적으로 전통이라는 관념(notion)과 의도적 제정 및 선택이라는 관념의 논리적 양립불가능성에 의존한다. 규칙들은 자라나고 실천되고 실천되기를 멈추고 쇠퇴함으로써 전통의 지위를 획득하고 상실한다. 그리고 이러한 느리고 비자발적인 과정들이 아닌 다른 방식으로 생겨나거나 제거된 규칙들은, 그로써 전통의 지위를 획득하거나 상실할 수 없다.

도덕과 전통이 법들처럼 입법적 제정에 의해 직접 변경될 수 없다는 사실은 다른 형태의 변화로부터의 면역성으로 오인되어서는 안 된다. 기실 도덕 규칙이나 전통은 의도적 선택이나 제정에 의해 폐지되거나 변경될 수 없지만, 법들의 제정이나 폐지는 어떤 도덕 기준이나 어떤 전통의 변화 또는 쇠퇴의 원인들 가운데 하나일 수 있다. 가이 포크스(Guy Fawkes) 밤의 기념행사와 같은 전통적 실천이 (p. 177) 법에 의해 금지되고 처벌된다면, 그 실천은 중단되고 전통은 사라질 수 있다. 반대로 법들이 일정한 부류들에게 군복무를 요구한다면, 이것은 궁극적으로 그들 사이에서 그 법보다 훨씬 오래 지속될 수 있는 전통을 발전시킬 수 있다. 마찬가지로 법적 제정물들(legal enactments)은 정직성과 인간성의 기준들을 세워 궁극적으로 현재의 도덕을 바꾸고 높일 수 있다. 반대로 도덕적으로 의무적이라고 여겨지는 실천들에 대한 법적 억압은 결국 그것들의 중요성 감각, 따라서 도덕으로서의 그것들의 지위를 잃게 할 수 있다. 그러나 매우 자주 법은 뿌리 깊은 도덕과의 그러한 싸움에서 패배하며, 도덕 규칙은 자신이 명하는 바를 금지하는 법들과 나란히 완전한 활력으로 계속된다.

법이 인과적 요소일 수 있는 전통과 도덕의 이러한 변화 방식들은 입법적 변경이나 폐지와 구별되어야 한다. 제정으로 인한 법적 지위의 획득이나 상실은, 제정된 제정법(enacted statute)의 ‘법적 효과(legal effect)’ 라고 기실 말해질 수 있지만, 그것은 제정법이 도덕과 전통에 나중에 미치는 효과(eventual effect)와 같은 우연적 인과 변화가 아니기 때문이다. 이 차이는 다음 사실에서 단순히 볼 수 있다. 명확하고 유효한 법적 제정물(legal enactment)이 도덕의 변화로 이어질지는 언제나 의심할 수 있지만, 명확하고 유효한 법적 제정물이 법을 변경했는지에 관해서는 유사한 의심이 품어질 수 없다.

도덕 또는 전통이라는 관념이 의도적 제정에 의한 변경이라는 관념과 양

립하지 않는다는 점은, 어떤 체계들에서 헌법의 제한 조항들이 일정한 법들에 부여하는 면역성과도 구별되어야 한다. 그러한 면역성은 법으로서 법의 지위에 필요한 요소가 아니다. 이 면역성은 헌법 개정에 의해 제거될 수 있기 때문이다. 입법적 변경으로부터의 그러한 법적 면역성과 달리, 유사한 변화 방식들에 대한 도덕 또는 전통의 무능력(incapacity)은 공동체마다 또는 시기마다 달라지는 어떤 것이 아니다. 그것은 이 용어들의 의미 속에 편입되어 있다. 법적 제정 물들이 법을 만들고 변경하듯 도덕을 만들고 변경할 권능(competence)을 가진 도덕 입법부라는 관념은 도덕이라는 전체 관념(notion)에 반한다. 국제법을 고려하게 될 때, 우리는 체계의 결함으로 여겨질 수 있는 입법부의 단순한 사실상(de facto) 부재와, 여기서 (p. 178) 강조한 것처럼 도덕 규칙들이나 기준들이 입법에 의해 만들어지거나 폐지될 수 있다는 관념 안에 잠재해 있는 근본적 비일관성을 구별하는 것이 중요하다는 점을 보게 될 것이다.

(iii) 도덕적 위반들의 자발적 성격(Voluntary character of moral offences).

도덕(morals)은 오로지 ‘내부(internal)’ 인 것에 관심을 가지는 반면 법은 오직 ‘외부(external)’ 행위에 관심을 가진다는 오래된 구상(conception)은, 이미 논의한 두 특징을 부분적으로 잘못 진술한 것이다. 그러나 그것은 가장 자주 도덕적 책임(moral responsibility)과 도덕적 비난(moral blame)의 일정한 두드러진 특징들에 대한 참조로 다루어진다. *ab extra*로 판단할 때 그 행위가 도덕 규칙들이나 원칙들을 위반한 어떤 사람이, 가능한 모든 예방조치에도 불구하고 자신이 그것을 비의도적으로 했다는 점을 입증하는 데 성공하면, 그는 도덕적 책임에서 면책(excused)되며, 이러한 상황에서 그를 비난하는 것 자체가 도덕적으로 문제 있는 것으로 여겨질 것이다. 도덕적 비난은 그가 할 수 있는 모든 것을 했기 때문에 배제된다. 어떤 발전된 법체계에서든 같은 점은 어느 정도 참이다. 형사책임에서 일반적인 *mens rea* 요건은, 부주의 없이, 알지 못한 채, 또는 법에 부합할 신체적·정신적 능력을 결여한 상황들에서 위반한 자들이 면책되도록 확보하기 위해 고안된 요소이기 때문이다. 이것이 그렇지 않다면, 적어도 중대한 처벌을 수반하는 중대한 범죄들의 경우에 법체계는

심각한 도덕적 비난에 열려 있을 것이다.

그럼에도 불구하고 모든 법체계들에서 그러한 면책 사유들의 인정은 많은 서로 다른 방식으로 제한된다. 심리적 사실들에 대한 증명의 실제적 또는 주장된 난점들은 법체계로 하여금 특정 개인들의 실제 정신 상태들이나 능력들을 조사하기를 거부하게 하고, 대신 ‘객관적 검사 기준들(objective tests)’을 사용하게 할 수 있다. 그 검사 기준들에 의해 위반행위 혐의를 받는 개인은 정상적이거나 ‘합리적인’ 사람이 가질 통제 능력 또는 예방조치를 취할 능력들을 가진 것으로 받아들여진다. 어떤 체계들은 ‘인지적(cognitive)’ 장애들과 구별되는 ‘의지적(volitional)’ 장애들(disabilities)을 고려하기를 거부할 수 있다. 그렇다면 그 체계들은 면책 사유들의 범위를 의도의 결여나 지식의 결함들에 한정한다. 다시 법체계는 일정한 유형들의 위반행위(offence)에 대해 엄격책임(strict liability)을 부과하고, 어쩌면 피고인이 정상적 근육 통제를 가져야 한다는 최소 요건만을 제외하고 책임을 *mens rea*와 전적으로 독립시킬 수 있다.

따라서 피고인이 (p. 179) 자신이 위반한 법을 지킬 수 없었음을 보였다고 해서 법적 책임이 반드시 배제되는 것은 아님이 분명하다. 그와 대조적으로 도덕에서 ‘나는 어쩔 수 없었다(I could not help it)’는 언제나 면책 사유(excuse)이며, 도덕적 의무는 이 의미에서 도덕적 ‘해야 한다(ought)’가 ‘할 수 있다(can)’를 함의하지 않는다면 지금의 그것과 전혀 달랐을 것이다. 그러나 ‘나는 어쩔 수 없었다’는 오직 면책 사유일 뿐(비록 좋은 면책 사유이기는 하지만)이며, 면책 사유를 정당화(justification)와 구별하는 것이 중요하다. 우리가 말했듯이, 도덕이 외부 행위를 요구하지 않는다는 주장은 이 두 관념의 혼동에 기초하기 때문이다. 선한 의도들이 도덕 규칙들이 금지하는 일을 하는 것에 대한 정당화라면, 모든 주의를 기울였음에도 우연히 타인을 죽인 사람의 행위에는 개탄할 것이 아무것도 없을 것이다. 우리는 그것을, 자기방어의 필요한 수단으로 요구될 때 어떤 사람이 타인을 죽이는 경우를 지금 바라보는 것처럼 바라보아야 할 것이다. 후자는 정당화된(justified). 그러한 상황에서 살해(killing)는 물론 살해에 대한 일반 금지의 예외이지만, 체계가 방지하는 데 관심을 가지지 않고 심지어 장려할 수도 있는 종류의 행위이기 때문이다. 어떤 사람이 비의도적으

로 위반했기 때문에 면책되는(excused) 경우, 그 밑에 있는 도덕적 구상은 이 행위가 법의 정책상 허용하거나 심지어 환영할 종류의 행위라는 것이 아니다. 그것은 특정 위반자의 정신 상태를 조사할 때, 그가 법의 요구들에 부합할 정상 능력을 결여했다는 점을 우리가 발견한다는 것이다. 따라서 도덕의 ‘내부성(internality)’의 이 측면은 도덕이 외부 행위의 통제 형식이 아니라는 뜻이 아니라, 도덕적 책임의 필요조건이 개인이 자기 행위에 대하여 일정한 유형의 통제를 가져야 한다는 것뿐이다. 도덕에서도 ‘그는 그른 일을 하지 않았다’와 ‘그는 자신이 한 일을 어쩔 수 없이 했다’ 사이에는 차이가 있다.

(iv) 도덕적 압력의 형식(The form of moral pressure). 도덕의 추가적인 구별 특징은 도덕을 뒷받침하기 위해 행사되는 도덕적 압력의 특징적 형식이다. 이 특징은 마지막 특징과 밀접히 관련되며, 그것처럼 도덕이 ‘내부’인 것에 관심을 가진다는 막연한 감각에 강하게 기여해 왔다. 도덕에 대한 이러한 해석으로 이끈 사실들은 다음과 같다. 누군가가 행위 규칙을 위반하려 할 때마다, 그를 단념시키기 위한 논변에서 오직 신체적 처벌이나 불쾌한 결과들의 위협들만 사용된다면, 그러한 (p. 180) 규칙을 그 사회의 도덕의 일부로 간주하는 것은 불가능할 것이다. 비록 이것이 그것을 그 사회의 법의 일부로 취급하는 데 대한 반대이유가 되지는 않겠지만 말이다. 기실 법적 압력의 전형적 형식은 그러한 위협들로 이루어진다고 말해도 좋을 것이다. 반면 도덕에서 전형적 압력 형식은, 규칙들을 그 자체로 중요한 것들로 존중한다는 점, 그리고 그 존중이 말을 듣는 자들에 의해 공유된다고 추정된다는 점에 호소하는 데 있다. 그러므로 도덕적 압력은 특징적으로, 비록 배타적으로는 아니지만, 위협들이나 두려움 또는 이익에 대한 호소들에 의해서가 아니라, 고려 중인 행위의 도덕적 성격과 도덕의 요구들을 상기시키는 것들에 의해 행사된다. ‘그것은 거짓말일 것이다’, ‘그것은 네 약속을 깨는 것일 것이다.’ 배경에는 기실 처벌에 대한 두려움의 ‘내부’ 도덕 유사물들이 있다. 항의들이 말을 듣는 자들 안에서 수치심이나 죄책감을 일깨울 것이라고 상정되기 때문이다. 그들은 자기 자신의 양심에 의해 ‘처벌’ 받을 수 있다. 물론 때로 그러한

고유하게 도덕적인 호소들은 신체적 처벌의 위협들이나 통상적 개인 이익에 대한 호소들과 함께 나타난다. 도덕 규범으로부터의 일탈들은 비교적 비공식적인 경멸의 표현들에서부터 사회관계의 단절 또는 배척(ostracism)에 이르는 여러 다른 형식들의 적대적 사회 반응을 만난다. 그러나 규칙들이 요구하는 바를 강조하여 상기시키는 것들, 양심에 대한 호소들, 죄책감과 후회의 작용에 대한 의존은 사회적 도덕을 뒷받침하는데 사용되는 압력의 특징적이고 가장 두드러진 형식들이다. 도덕 규칙들과 기준들이 바로 이러한 방식으로 뒷받침되어야 한다는 것은, 그것들이 유지되는 것이 지극히 그리고 명백히 중요하다고 받아들여진다는 점의 단순한 귀결이다. 이러한 방식으로 뒷받침되지 않는 기준들은 도덕적 의무에 고유한 사회적·개인적 삶에서의 자리를 가질 수 없을 것이다.

3. 도덕 이상(Moral Ideals)과 사회적 비판(Social Criticism)

도덕적 의무와 책무는 사회적 도덕(social morality)의 기반(bedrock)이지만, 그것들이 전부는 아니다. 그러나 다른 형식들을 검토하기 전에, 우리가 도덕적 의무를 특징지은 방식에 대한 한 반론을 고려할 것이다. 지난 절에서 우리가 그것을 다른 형식의 사회적 기준 또는 규칙과 구별하기 위해 사용한 네 가지 기준들(fourfold criteria), 곧 중요성, 의도적 변경으로부터의 면역성, 도덕적 위반행위들의 자발적 성격, 도덕적 압력의 특수한 형식은 어떤 의미에서 형식적(formal) (p. 181) 기준들이다. 그것들은 규칙들이나 기준들이 도덕적이기 위해 가져야 할 어떤 필연적 내용에도, 심지어 그것들이 사회생활에서 봉사해야 할 어떤 목적에도 직접 참조하지 않는다. 우리는 기실 모든 도덕 규범들(moral codes)에서 사람이나 사물에 대한 폭력 사용의 금지 형식, 그리고 진실성(truthfulness), 공정한 거래(fair dealing), 약속들에 대한 존중의 요구들이 발견될 것이라고 주장해 왔다. 인간 본성과 물리적 세계의 성격에 관한 몇 가지 아주 명백한 자명성들(truisms)만 인정한다면, 이러한 것들은 인간 존재들이 가까운 곳에서 계속 함께 살아가기 위해 실제로 필수적임을 볼 수 있다. 그러므로 그것들을 마련하는 규칙들이 어디에서나 우리가 서술한 도덕적 중요성과 지위를 부여받지 않는

다면 그것은 놀라운 일일 것이다. 그러한 규칙들이 요구하는(demand) 개인적 이익의 희생은 우리와 같은 세계에서 타인들과 살아가기 위해 지불되어야 하는 대가이고, 그것들이 제공하는(afford) 보호는 우리와 같은 존재들에게 타인들과 사는 것을 가치 있게 만드는 최소한이다. 이러한 단순한 사실들은, 다음 장에서 우리가 논변하듯이, 자연법(Natural Law) 교설들 안의 논박할 수 없는 진리의 핵심을 구성한다.

많은 도덕론자들(moralists)은 우리가 제시한 네 가지 기준을 넘어서는 추가 기준으로, 도덕과 인간의 필요들 및 이익들 사이의 이처럼 명백해 보이는 연결을 도덕의 정의 안으로 들여오고 싶어 할 것이다. 그들은 어떤 규칙도, 그것이 그 사회의 규칙인 그 사회에서 인간 이익들의 관점에서 이성적 비판을 견뎌 낼 수 있고, 그래서 그것들을 증진하는 것으로 보일 수 있을 때(어쩌면 어떤 공정하거나 평등한 방식으로)만 도덕의 일부로 인정되어야 한다고 규정할 것이다. 어떤 이들은 더 나아가, 그 규칙이 요구하는 자제들(forbearances)과 행위들의 혜택들이 특정 사회의 경계들을 넘어, 그러한 규칙들을 존중할 의지와 능력이 있는 모든 사람들에게 확장되지 않는 한, 어떤 행위 원칙이나 규칙도 도덕적인 것으로 인정하기를 거부할 수도 있다. 그러나 우리는 의도적으로 도덕에 대한 더 넓은 견해를 취하였다. 한 사회의 실제 실천에서 우리가 언급한 네 특징들을 보이는 모든 사회 규칙들과 기준들을 그 안에 포함시키기 위해서이다. 이들 가운데 일부는 추가로 제안된 이러한 검사 기준들에 비추어 비판을 견뎌 낼 것이고, 다른 것들은 그렇지 못하겠지만 비합리적이거나 계몽되지 않았거나 심지어 야만적인 것으로 비난받을 수 있다. 우리가 이렇게 한 것은 단지 (p. 182) ‘도덕적(moral)’이라는 말의 용례의 무게가 이 더 넓은 의미를 지지하기 때문만이 아니라, 이들을 배제하는 더 좁고 제한된 견해를 취하면, 그것에 따라 사는 사람들의 삶 안에서 동일한 방식으로 기능하는 사회 구조의 요소들을 매우 비현실적인 방식으로 나누도록 강제될 것이기 때문이다. 실제로 타인들을 해하지 않을 수 있는 행위에 대한 도덕적 금지들은, 실제로 해하는 행위에 대한 금지들과 정확히 같은 본능적 존중의 대상이 될 뿐 아니라, 더 합리적으로 방어 가능한 규칙들의 요구들과 함께 성격에 대한 사회적 평가들 안으로 들어가며, 그것들과 함께 개인들이 살 것으로 기대되고 기실 살고 있다고 상정되는 삶의

일반적으로 수용된 그림의 일부를 이룬다.

그러나 도덕이 사회 집단들의 실제 실천에서 인정되는 의무들(obligations)과 책무들(duties)보다 훨씬 많은 것을 포함한다는 점은 참이고 중요하다. 의무와 책무는 도덕의 기반일 뿐이며, 사회적 도덕의 기반일 뿐이기도 하다. 그리고 특정 사회들의 수용되고 공유된 도덕을 넘어 확장되는 도덕의 형식들이 있다. 여기서 도덕의 두 가지 추가 측면에 주목할 필요가 있다. 첫째, 특정 사회의 도덕 안에서도 의무부과적인 도덕적 의무들과 책무들의 구조 및 그것들을 규정하는 비교적 명확한 규칙들과 나란히, 일정한 도덕적 이상들(ideals)이 존재한다. 이것들의 실현은 책무처럼 당연한 것으로 받아들여지지 않고, 칭찬받을 만한 성취로 받아들여진다. 영웅(hero)과 성인(saint)은 자기 책무보다 더 많은 것(more)을 하는 사람들의 극단적 유형들이다. 그들이 하는 것은 의무나 책무처럼 그들에게 요구될 수 있는 어떤 것이 아니며, 그것을 하지 못하는 것은 그른(wrong) 것으로 여겨지거나 비난(censure)의 대상이 되지 않는다. 성인이나 영웅보다 더 소박한 척도에는, 용감함(bravery), 자선(charity), 선의(benevolence), 인내(patience), 절제(chastity)와 같이 일상생활에서 드러내는 도덕적 미덕들(moral virtues) 때문에 한 사회에서 칭찬받을 자격이 있는 것으로 인정되는 사람들이 있다. 그러한 사회적으로 인정된 이상들과 미덕들, 그리고 사회적 의무와 책무의 일차적 의무부과 형식들 사이의 연결은 상당히 명확하다. 많은 도덕적 미덕들은, 책무가 요구하는 제한된 범위를 넘어, 책무가 요구하는 종류의 타인들의 이익에 대한 관심 또는 개인적 이익의 희생을 계속 밀고 나갈 능력과 성향(disposition)으로 이루어진 성질들이다. 선의(benevolence)와 자선(charity)이 이것의 예이다. 절제(temperance), 인내(patience), 용감함(bravery), 양심성(conscientiousness) 같은 다른 도덕적 미덕들은 (p. 183) 어떤 의미에서는 보조적(ancillary)이다. 그것들은 특별한 유혹이나 위험에 직면하여 책무에 대한 예외적 헌신이나 실질적 도덕 이상들의 추구에서 드러나는 성격의 성질들이다.

도덕의 더 먼 범위들은 우리를, 서로 다른 방식으로, 특정 사회 집단들에서 인정되는 의무들과 이상들의 경계 너머로, 사회 자체에 대한 도덕적 비판에서 사용되는 원칙들과 이상들로 이끈다. 그러나 여기서도 도덕의 원초적 사회 형식과의 중요한 연결들은 남아 있다. 우리 자신의 사회나 다른 어떤 사회의

수용된 도덕을 검토하게 될 때, 우리가 비판할 많은 것을 발견할 가능성은 언제나 있다. 그것은 현재 이용 가능한 지식에 비추어 불필요하게 억압적이고, 잔혹하고, 미신적이고, 계몽되지 않은 것으로 보일 수 있다. 그것은 인간 자유를 위축시킬 수 있는데, 특히 종교의 논의와 실천에서 또는 인간 삶의 서로 다른 형식들에 대한 실험에서 그러할 수 있으며, 그로써 타인들에게 확보되는 혜택들이 무시할 만한 것에 그치는 경우에도 그렇다. 무엇보다도, 주어진 사회의 도덕은 해악으로부터의 보호들을 자기 구성원들에게만, 또는 심지어 일정한 부류들에게만 확장하여, 노예 또는 헬롯 계급을 그 주인들의 변덕에 내맡길 수 있다. 이러한 유형의 비판 속에는, 설령 그것이 거부될 수 있다 하더라도, 확실히 ‘도덕적’ 비판으로 인정될 것이며, 수용된 도덕을 포함하는 사회의 장치들(arrangements)이 두 형식적 조건, 곧 합리성(rationality)과 일반성(generality)을 충족해야 한다는 전제가 암묵적으로 들어 있다. 따라서 그러한 비판에는 첫째, 사회적 장치들이 잘못된 것으로 입증될 수 있는 믿음들에 기초해서는 안 된다는 점이, 둘째, 도덕이 그 요구하는 행위들과 자제들을 통해 특징적으로 제공하는 해악으로부터의 보호들은 그러한 제한들을 스스로 준수할 능력과 의지가 있는 모든 인간에게 적어도 확장되어야 한다는 점이 함의된다. 그러므로 자유(liberty), 우애(fraternity), 평등(equality), 행복 추구(the pursuit of happiness)와 같은 표어들에 담긴 사회에 대한 도덕적 비판은, 모든 실제 사회 도덕들에서 이미 인정된, 비록 어쩌면 부적절한 정도로만 인정된, 어떤 가치 또는 가치들의 결합의 이름으로, 또는 합리성과 일반성이라는 두 요구를 충족하도록 정제되고 확장된 그것들의 한 판본의 이름으로, 개혁을 요청한다는 사실에서 그 도덕적 성격을 끌어낸다.

물론 자유나 평등의 이름으로 이루어지는 수용된 도덕 또는 다른 사회적 장치들에 대한 비판이 그 자체로 (p. 184) 도덕적(moral) 비판으로 인정된다는 사실로부터, 다른 가치들의 이름으로 그것을 거부하는 것 또한 도덕적일 수 없다는 결론이 따라나오는 것은 아니다. 자유 제한에 대한 비난은, 자유를 사회적 또는 경제적 평등이나 안전에 희생하는 것 자체가 정당화되었다는 주장(claim)에 부딪힐 수 있다. 서로 다른 도덕적 가치들에 부여되는 무게나 강조의 그러한 차이들은 화해 불가능한 것으로 드러날 수 있다. 그것들은 사회에 대한

근본적으로 다른 이상적 구상들(conceptions)에 이를 수 있고, 대립하는 정당들의 도덕적 기초를 형성할 수 있다. 민주주의의 위대한 정당화들(justifications) 가운데 하나는 그러한 대안들 사이의 실험과 수정 가능한 선택을 허용한다는 점이다.

끝으로, 주어진 사회에서 일반적으로 인정되는 의무들과 이상들을 넘어서는 도덕의 모든 확장이 사회 비판의 형식을 취할 필요는 없다. 도덕에는 개인적 측면이 있다는 점을 기억하는 것이 중요하다. 이는 개인이, 타인들과 공유할 필요도 없고, 타인들에 대한 비판의 원천으로, 더구나 사회 전체에 대한 비판의 원천으로 간주할 필요도 없는 이상들을 인정하는 데서 드러난다. 삶들은 영웅적, 낭만적, 미적, 학문적 이상들의 추구에 대한 헌신에 의해, 또는 덜 유쾌하게는 육체의 고행(mortification of the flesh)에 대한 헌신에 의해 지배될 수 있다. 여기서도 우리가 도덕을 말한다면, 개인들이 이렇게 추구하는 가치들이 그들 자신의 사회의 도덕 안에서 인정되는 가치들 가운데 일부와 적어도 유비적이기 때문이라고 논변될 수 있다. 그러나 그 유비는 분명 내용의 유비가 아니라 형식과 기능의 유비이다. 그러한 이상들은 개인들의 삶에서 도덕이 사회에서 하는 것과 같은 역할을 하기 때문이다. 그것들은 최고로 중요한 것으로 평가되어, 그 추구가 다른 이익들이나 욕망들이 희생되어야 할 책무로 느껴진다. 전환(conversions)은 가능하지만 그러한 이상들이 의도적 선택에 의해 채택되거나 변경되거나 제거될 수 있다는 관념(notion)은 공상적(chimerical)이다. 끝으로 그러한 이상들로부터의 일탈들은 사회적 도덕이 일차적으로 호소하는 바로 그 양심, 죄책감, 후회에 의해 ‘처벌’ 된다.

제8장 주석

157쪽. 정의(Justice)는 도덕(morality)의 구별되는 한 부분이다. 아리스토텔레스는 『니코마코스 윤리학(Nicomachean Ethics)』 제5권 1-3장에서, 정의는 인간들 사이의 균형(balance)이나 비례(proportion)를 유지하거나 회복하는 것에 특수하게 관련된 것으로 설명한다. 정의의 관념(idea of justice)에 대한 현대의 가장 뛰어난 설명은 시즈윅(Sidgwick)의 『윤리학의 방법(The Method of Ethics)』 제6장, 페를만(Perelman)의 『정의에 대하여(De la Justice)』(1945), 그리고 이를 따른 로스(Ross)의 『법과 정의(On Law and Justice)』 제12장에 있다. 역사적으로 흥미로운 논의는 델 베키오(Del Vecchio)의 『정의(Justice)』에 있으며, 이는 하트(Hart)가 『철학(Philosophy)』 제28호(1953)에서 서평했다.

161쪽. 법 적용에서의 정의. 이 정의의 측면만을 정의 전체로 환원하려는 유혹은, 홉스(Hobbes)가 『리바이어던(Leviathan)』 제30장에서 “어떠한 법도 부정의할 수 없다(no law can be unjust)” 라고 말한 데 대한 설명일 수 있다. 오스틴(Austin)은 『법의 영역(The Province of Jurisprudence Determined)』 제6강 260쪽 각주에서 “‘정의롭다(just)’는 말은 상대적 의미를 가지며, 그것은 발화자가 비교 기준으로 가정하는 특정한 법에 대한 관계에서 말해진다” 고 보았다. 따라서 그에게 있어 법은 그것이 실정 도덕(positive morality)이나 신의 법(law of God)에 의해 판단된다면 도덕적으로 부정의할 수 있다. 오스틴은 홉스가 단지 법이 법적으로(legally) 부정의할 수 없다고 말한 것이라 보았다.

162쪽. 정의와 평등(Equality). ‘인간은 일응(prima facie) 같게 대우되어야 한다’는 원칙의 지위와 정의의 관념(idea of justice)과의 관계에 대한 유익한 논의로는, 벤(Benn)과 피터스(Peters)의 『사회 원칙과 민주 국가(Social Principles and the Democratic State)』 제5장 ‘정의와 평등(Justice and Equality)’, 롤스(Rawls)의 “공정으로서의 정의(Justice as Fairness)” (*Philosophical Review*, 1958), 라파엘(Raphael)의 “평등과 형평(Equality and Equity)” (*Philosophy*, 제21권, 1946), 그리고 “정의와 자유(Justice and Liberty)” (*Proceedings of the Aristotelian Society*, 제51권, 1951-2)가 있다.

162쪽. 아리스토텔레스의 노예제. 『정치학(Politics)』 제1권 제2장 3-22절 참조. 그는 어떤 이들은 ‘자연적으로(by nature)’ 노예가 아니며, 그들에게 노예제는 정의롭지도 유익하지도 않다고 보았다.

163쪽. 정의와 보상(compensation). 이는 아리스토텔레스에 의해 분배적 정의(distributive justice)와 명확히 구별되며, 위 저서 제5권 제4장에서 논의된다. 그는 정의

관념(idea of justice)의 모든 적용에서 유지되거나 회복되어야 할 ‘정의로운’ 비례가 있다는 통일 원칙을 강조하였다. 해설서로는 잭슨(H. Jackson)의 『니코마코스 윤리학 제5권』(1879) 참조.

164쪽. 사생활 침해에 대한 법적 보상. 사생활권(the right to privacy)을 법이 인정해야 하며, 보통법(common law)의 원칙들이 그 인정(recognition)을 요구한다는 논증은, 워런(Warren)과 브랜다이스(Brandeis)의 “사생활의 권리(The Right to Privacy)” (*Harvard Law Review*, 제4권, 1890)와 *Roberson v. Rochester Folding Box Co.* (1902, 171 NY 538) 사건에서의 그레이 판사(Gray J.)의 반대 의견에서 확인된다. 영국의 불법행위법(tort law)은 사생활 자체를 보호하지는 않지만, 미국에서는 이제 광범위하게 보호된다. 영국법에서는 *Tolley v. J. S. Fry and Sons Ltd.* (1931, AC 333) 참조.

166쪽. 개인 간 정의와 더 넓은 사회적 이익 간의 충돌. 불법행위법(tort)에서의 엄격책임(strict liability)과 대리책임(vicarious liability)에 대한 논의는 프로서(Prosser)의 『불법행위론(Torts)』 제10장 및 제11장, 프리드먼(Friedmann)의 『변화하는 사회 속의 법(Law in a Changing Society)』 제5장에서 다루어진다. 형사법에서 엄격책임의 정당화에 대해서는 글랜빌 윌리엄스(Glanville Williams)의 『형사법(The Criminal Law)』 제7장, 프리드먼 위 저서 제6장 참조.

166쪽. 정의와 ‘공동선(common good)’. 공동선 추구를 정의롭게 행위하는 것 또는 공동체의 모든 구성원의 이익에 대한 공정한 배려와 동일시하는 논의는, 벤과 피터스의 『사회 원칙과 민주 국가』 제13장에서 다루어진다. 이처럼 ‘공동선’을 정의와 동일시하는 입장은 보편적으로 수용되지는 않는다. 시즈윅의 『윤리학의 방법』 제3장 참조.

167쪽. 도덕적 의무(Moral Obligation). 사회적 도덕(social morality) 내의 의무들(obligations)과 책무들(duties)을 도덕적 이상들(moral ideals) 및 개인적 도덕(personal morality)과 구분해야 한다는 논의는, 엄슨(Urmson)의 “성인과 영웅(Saints and Heroes)” (*Essays on Moral Philosophy*, 멜든(Melden) 편), 화이트리(Whiteley)의 “도덕 정의하기(On Defining ‘Morality’)” (*Analysis*, 제20권, 1960), 스트로슨(Strawson)의 “사회 도덕과 개인 이상(Social Morality and Individual Ideal)” (*Philosophy*, 1961), 브래들리(Bradley)의 『윤리학 연구(Ethical Studies)』 제5장 및 제6장에서 확인된다.

169쪽. 사회 집단의 도덕. 오스틴(Austin)은 『법의 영역(The Province of Jurisprudence Determined)』에서 ‘실정 도덕(positive morality)’이라는 표현을 사용하여, 하나의 사회에서 실제로 관찰되는 도덕을 ‘신의 법(the law of God)’과 구분하였다. 후자는 오스틴에게 있어 실정 도덕과 실정법을 판단하는 궁극적 기준들(ultimate standards)이었다.

이는 사회적 도덕과 그것을 넘어서 이를 비판하는 도덕 원칙들 사이의 중요한 구별을 지목한다. 오스틴의 실정 도덕은 실정법 외의 모든 사회 규칙을 포함하며, 예절, 게임, 클럽, 국제법 등도 포함된다. 이러한 ‘도덕’이라는 용어의 넓은 사용은 형식과 사회적 기능의 너무 많은 중요한 구별들을 흐린다. 제10장 제4절 참조.

172쪽. 필수 규칙들(Essential Rules). 폭력 사용을 제한하고 재산(property)과 약속(promises)에 대한 존중을 요구하는 규칙들이 실정법과 사회적 도덕 모두의 기저에 있는 자연법(Natural Law)의 ‘최소한의 내용(minimum content)’을 형성한다는 논의는 제9장 제2절 참조.

172-173쪽. 법과 외부 행위. 본문에서 비판된, 법은 외부 행위를 요구하지만 도덕은 그렇지 않다는 견해는, 칸트(Kant)의 법적 법칙(juridical laws)과 윤리적 법칙(ethical laws) 사이의 구분에서 비롯되었다. 이에 대한 고전적 설명은 헤이스티(Hastie) 편 『칸트의 법철학(Kant's Philosophy of Law)』(1887) 서론 14쪽 및 20-24쪽 참조. 현대적 재진술은 칸토로비츠(Kantorowicz)의 『법의 정의(The Definition of Law)』 43-51쪽에 있으며, 이는 휴즈(Hughes)의 “법체계의 존재(The Existence of a Legal System)” (*New York University Law Review*, 제35권, 1960)에서 비판된다.

178쪽. mens rea와 객관적 기준들. 홀즈(Holmes)의 『보통법(The Common Law)』 제11장, 홀(Hall)의 『형법 원칙(Principles of Criminal Law)』 제5장 및 제6장, 하트(Hart)의 “법적 책임과 면책 사유들(Legal Responsibility and Excuses)” (*Determinism and Freedom*, 후크(Hook) 편) 참조.

179쪽. 정당화(Justification)와 면책 사유(Excuse). 살해(homicide)에 관한 법 이론에서 이 구분은 케니(Kenny)의 『형법 개요(Outlines of Criminal Law)』(24판) 109-116쪽 참조. 일반 도덕에서의 중요성은 오스틴(Austin)의 “면책 사유들을 위한 변론(A Plea for Excuses)” (*Proceedings of the Aristotelian Society*, 제57권, 1956-57), 하트의 “처벌의 원칙에 대한 서설(Prolegomenon to the Principles of Punishment)” (*PAS*, 제60권, 1959-60) 12쪽에서 논의됨. 유사한 구별은 벤담(Bentham)의 『법 일반론(Of Laws in General)』 121-122쪽의 ‘면제(exemption)’와 ‘면책(exculpation)’ 참조.

181쪽. 도덕, 인간의 필요, 이해관계. 어떤 규칙을 도덕 규칙(moral rule)이라고 부르는 기준은 그것이 영향을 받는 자들의 이해관계에 대한 이성적이고 공정한 고려(reasoned and impartial consideration)의 산물이라는 견해에 대해서는 벤과 피터스의 『사회 원칙과 민주 국가』 제2장 참조. 대조적으로 데블린(Devlin)의 『도덕의 집행(The Enforcement of Morals)』(1959) 참조.

제8장 제3판 주석

157-160쪽. 정의의 원칙들(Principles of Justice). 하트(Hart)에게서 중요한 영향을 받은 존 롤스(John Rawls)는 정의(Justice)의 사항적 범위(subject matter)를 『정의론(A Theory of Justice)』(개정판, 하버드대학출판부, 1999) 제1장에서, 특히 6-10쪽에서 다룬다. 정의의 원칙들, 특히 분배적 성격(distributive character)에 주목한 유용한 개관으로는 데이비드 밀러(David Miller)의 『사회정의(Social Justice)』(옥스퍼드대학출판부, 1976) 제1장이 있다.

159-160쪽. ‘같은 사례들은 같게 취급하라(Treat like cases alike)’. 하트가 이것이 일종의 정의라고 시사한 점은 논쟁의 대상이 되어 왔다. 이 논의는 데이비드 라이언스(David Lyons)의 “형식적 정의에 대하여(On Formal Justice)”(*Cornell Law Review*, 제58권, 1972, 833쪽), 매튜 크레이머(Matthew Kramer)의 “지속성으로서의 정의(Justice as Constancy)”(*Law and Philosophy*, 제16권, 1997, 561쪽), 존 가드너(John Gardner)의 『신념의 도약으로서의 법(Law as a Leap of Faith)』 제10장 “정의의 미덕과 법의 성격”에서 다루어진다. 드워킨(Dworkin)은 ‘같은 사례들을 같게 취급한다’는 원칙을 단순한 일관성(consistency)이 아니라 ‘통합성(integrity)’이라는 이상(ideal)과 연결시킨다. 그는 “통합성은 공동체의 공적 기준들(public standards)이, 가능한 한, 정의(Justice)와 공정성(Fairness)을 올바른 관계 속에 놓는 단일하고 정합적인 체계를 표현하도록 만들어지고 또한 그렇게 보일 것을 요구한다”고 말한다(*Law's Empire*, 219쪽). 이에 대한 회의적 입장은 드니즈 레옴(Denise Réaume)의 “통합성은 미덕인가? 드워킨의 법적 의무 이론(Is Integrity a Virtue? Dworkin's Theory of Legal Obligation)”(*University of Toronto Law Journal*, 제39권, 1989, 380쪽), 조셉 라즈(Joseph Raz)의 『공적 영역에서의 윤리(Ethics in the Public Domain)』 319-325쪽을 참조하라.

161-164쪽. 분배적 정의(Distributive Justice)와 보상적 정의(Compensatory Justice). 정의의 ‘형태들(forms)’에 대한 전통적 분류와 그들 사이의 관계는 명확하지 않다. 특히 분배적 정의와 교정적 정의(corrective justice)에 관한 논의는 줄스 콜먼(Jules Coleman)의 『위험과 잘못(Risks and Wrongs)』(개정판, 옥스퍼드대학출판부, 1992), 스티븐 페리(Stephen Perry)의 “교정적 정의와 분배적 정의 사이의 관계에 대하여(On the Relationship between Corrective and Distributive Justice)”(제러미 호더(Jeremy Horder) 편, 『옥스퍼드 법철학 논문집』 제4집, 2000), 존 피니스(John Finnis)의 『자연법과 자연권(Natural Law and Natural Rights)』 173-184쪽, 존 가드너의 “불법행위법은 무엇을 위한 것인가? 제1부: 교정적 정의의 위치”(*Law and Philosophy*, 제30권, 2011, 1쪽)를

참조하라.

166-167쪽. 정의와 다른 가치들. 존 롤스는 『정의론』(개정판) 3-4쪽에서 정의는 사회 제도들(social institutions)의 제1 미덕(first virtue)이라 주장한다. 이 견해는 존 가드너의 『신념의 도약으로서의 법』 제10장 “정의의 미덕과 법의 성격”, 제러미 월드론(Jeremy Waldron)의 “정의의 우위성(The Primacy of Justice)” (*Legal Theory*, 제9권, 2003, 269쪽)에서 다루어진다.

169-170쪽. 관행적 도덕(Conventional Morality). 하트는 ‘실정 도덕(positive morality)’ 과 ‘비판적 도덕(critical morality)’ 을 구별한다. 실정 도덕, 또는 관습적(customary) 도덕, 또는 관행적 도덕(conventional morality)은 특정 사회 집단에 의해 실제로 수용되고 있는 도덕이다. 반면, 비판적 도덕은 건전한, 또는 올바른 도덕(sound, or correct morality), 즉 그 사회가 수용해야 마땅한(ought to accept) 도덕이다. 이는 하트의 『법, 자유, 도덕(Law, Liberty, and Morality)』(스탠퍼드대학출판부, 1963) 17-24쪽에서 설명된다. 드워킨은, 사회적으로 수용된 모든 행위에 대한 태도들이 도덕으로 간주될 수는 없으며, 일부는 단지 혐오(hatreds), 공포(phobias) 등에 불과하다고 주장한다. 이는 『권리를 진지하게 다루기(Taking Rights Seriously)』 248-255쪽에서 논의된다. W. J. 왈루초우(W. J. Waluchow)는, 단순한 관행의 문제가 아니라 공동체의 제도들에 의해 전제되는 실정적 ‘공동체 헌법 도덕(community constitutional morality)’ 이 존재한다고 주장한다. 이는 그의 『판례법적 사법심사 이론(A Common Law Theory of Judicial Review: The Living Tree)』(케임브리지대학출판부, 2007)에서 전개된다.

183-184쪽. 사회에 대한 도덕적 비판(Moral Criticism of Society). 관련 논의는 패트릭 데블린(Patrick Devlin)의 『도덕의 집행(The Enforcement of Morals)』(옥스퍼드대학출판부, 1965), 하트의 『법, 자유, 도덕』, 드워킨의 『권리를 진지하게 다루기』 제10장, 로버트 P. 조지(Robert P. George)의 『도덕적 인간 만들기(Making Men Moral): 시민적 자유와 공적 도덕(Civil Liberties and Public Morality)』(옥스퍼드대학출판부, 1993) 제2장을 참조하라.

IX. 법들과 도덕규범들 (Laws and Morals)

1. 자연법과 법실증주의 (Natural Law and Legal Positivism)

법들과 도덕규범들 사이에는 여러 서로 다른 유형의 관계들이 있으며, 그 가운데 어떤 하나를 그들 사이의 관계로 따로 골라 연구하는 것은 유익하지 않다. 오히려 법들과 도덕규범들이 관련되어 있다는 단언이나 부정에 의해 의미될 수 있는 여러 서로 다른 것들을 구별하는 것이 중요하다. 때로 단언되는 것은, 거의 누구도 부인한 적 없는 일종의 연결이다. 그러나 그 논박 불가능한 존재가 더 의심스러운 어떤 연결의 징후(sign)로 잘못 받아들여지거나, 심지어 그것과 혼동될 수 있다. 예컨대, 법의 발전이 모든 시대와 장소에서 특정 사회 집단들의 관행적 도덕(conventional morality)과 이상들(ideals), 그리고 당시 수용된 도덕을 넘어서는 도덕적 지평을 가진 개인들이 제기한 계몽된 도덕적 비판의 형식들에 의해 실제로 깊이 영향을 받아 왔다는 점은 진지하게 다룰 수 없다. 그러나 이 진리를 부당하게 가져와 다른 명제의 근거로 삼을 수도 있다. 곧 법체계는 도덕이나 정의와 어떤 특정한 부합(specific conformity)을 반드시 드러내야 하거나, 그것에 복종할 도덕적 의무가 있다는 널리 퍼진 확신 위에 반드시 기초해야 한다는 명제이다. 또, 이 명제가 어떤 의미에서는 참일 수도 있다 하더라도, 법체계에서 사용되는 특정 법들의 법적 유효성 기준들이 명시적이지 않더라도 암묵적으로 도덕이나 정의에 대한 참조를 포함해야 한다는 점은 그로부터 따라 나오지 않는다.

이 밖에도 많은 다른 문제들이 법들과 도덕규범들의 관계들에 관한 것이라고 말해질 수 있다. 이 장에서는 그 가운데 두 가지만 논의할 것이다. 다만 두 문제 모두 다른 많은 문제들에 대한 일정한 고찰을 수반할 것이다. 첫 번째 문제는 자연법(Natural Law)과 법실증주의(Legal Positivism) 사이의 쟁점으로 여전히 해명적으로(illuminatingly) 묘사될 수 있는 문제이다. 비록 이 두 명칭 각각이 법들과 도덕규범들에 관한 서로 다른 논제들의 범위를 가리키는 데 사용되게 되었지만 말이다. 여기서 우리는 법실증주의를, 법들이 도덕의 일정한 요구들을 재현하거나 충족한다는 것이 어떠한 의미에서도 (p. 186) 필연적 진리는

아니라는 단순한 논지(contention)로 이해하겠다. 물론 실제로 법들이 그렇게 해 온 경우는 많다. 그러나 바로 이러한 견해를 취한 사람들이 도덕의 성격에 관해 침묵했거나 서로 매우 달랐기 때문에, 법실증주의가 거부되어 온 두 가지 매우 다른 형식을 검토할 필요가 있다. 그 가운데 하나는 자연법의 고전적 이론들에서 가장 분명하게 표현된다. 곧 인간 이성에 의한 발견을 기다리고 있는 인간 행위의 일정한 원칙들이 있고, 인간이 만든 법(man-made law)이 유효하려면 그것들에 부합해야 한다는 것이다. 다른 하나는 도덕에 관해 다른, 덜 합리주의적인 견해를 취하며, 법적 유효성이 도덕적 가치와 연결되는 방식들에 대해 다른 설명을 제시한다. 이 절과 다음 절에서는 이 가운데 첫 번째 것을 검토할 것이다.

플라톤(Plato)에서 오늘날에 이르기까지, 인간들이 행위해야 하는 방식들이 인간 이성에 의해 발견될 수 있다는 명제의 단언(assertion)과 또한 그 부정(denial)에 바쳐진 방대한 문헌 속에서, 한쪽 논쟁자들은 다른 쪽 논쟁자들에게 “이것을 볼 수 없다면 당신들은 눈먼 것이다” 라고 말하는 듯하고, 그 대답으로 “당신들은 꿈을 꾸고 있었다” 라는 말을 받을 뿐인 듯하다. 이는 옳은 행위의 참된 원칙들이 이성적으로 발견 가능하다는 주장이 보통 별개의 교설로 제시된 것이 아니라, 원래는 무생물적 자연과 생물적 자연을 포괄하는 자연에 대한 일반적 구상(conception)의 일부로 제시되었고 오랫동안 그 일부로 방어되었기 때문이다. 이 전망(outlook)은 여러 방식에서 현대 세속적 사유의 틀을 구성하는 자연에 대한 일반적 구상과 반정립적이다. 따라서 비판자들에게 자연법 이론은 현대 사유가 승리적으로 벗어난 깊고 오래된 혼란들에서 생겨난 것처럼 보였고, 그 옹호자들에게 비판자들은 더 심원한 진리들을 무시한 채 피상적 사소함들만 고집하는 것처럼 보였다.

따라서 많은 현대 비판자들은, 올바른 행위의 법들(laws of proper conduct)이 인간 이성에 의해 발견될 수 있다는 주장이 ‘법(law)’이라는 단어의 단순한 애매성에 기초해 있으며, 이 애매성이 드러나면 자연법은 치명타를 입는다고 생각해 왔다. 존 스튜어트 밀(John Stuart Mill)이 『법의 정신(Esprit des Lois)』 제1장에서, 별 같은 무생물들과 동물들이 ‘자기 자연의 법(law of their nature)’에 복종하는데 왜 인간은 그렇게 하지 않고 죄에 빠지는지를 순진하게 묻는

몬테스키외(Montesquieu)를 다룬 방식이 바로 이것이다. 밀은 이것이 (p. 187) 자연의 과정이나 반복적 일양성들을 정식화하는 법칙들과, 인간에게 특정한 방식으로 행위할 것을 요구하는 법들 사이의 오래된 혼동을 드러낸다고 보았다. 전자는 관찰과 추론에 의해 발견될 수 있고 ‘기술적(descriptive)’ 이라고 불릴 수 있으며, 과학자의 일은 바로 그것들을 이렇게 발견하는 것이다. 후자는 그렇게 확립될 수 없다. 그것들은 사실들의 진술이나 기술이 아니라, 인간들이 특정한 방식으로 행위해야 한다는 ‘처방들(prescriptions)’ 또는 요구들이기 때문이다. 따라서 몬테스키외의 질문에 대한 대답은 단순하다. 처방적 법들(prescriptive laws)은 위반될 수 있고, 그러면서도 법들로 남을 수 있다. 그것은 단지 인간 존재들이 하라는 대로 하지 않는다는 뜻일 뿐이기 때문이다. 그러나 과학에 의해 발견된 자연법칙들에 관하여, 그것들이 위반될 수 있다거나 위반될 수 없다고 말하는 것은 무의미하다. 별들이 자기들의 반복적으로 일양적인 운동을 기술한다고 표방하는 과학적 법칙들에 반하는 방식으로 움직인다면, 이 법칙들은 위반되는 것이 아니라 ‘법칙들’ 이라고 불릴 자격을 잃고 다시 정식화되어야 한다. ‘법’ 의 의미에서 보이는 이러한 차이들에는, ‘must’, ‘bound to’, ‘ought’, ‘should’ 같은 관련 어휘들에서 보이는 체계적 차이들이 대응한다. 그러므로 이 관점에서 보면 자연법에 대한 믿음은 매우 단순한 오류, 곧 법의 의미가 스며든 이러한 단어들이 가질 수 있는 매우 다른 의미들을 지각하지 못한 데로 환원된다. 이는 마치 그 믿음을 가진 사람이 “당신은 병역을 위해 신고해야 한다(You are bound to report for military service)” 와 “바람이 북쪽으로 돌면 얼 수밖에 없다(It is bound to freeze if the wind goes round to the north)” 에서 그러한 단어들의 매우 다른 의미를 지각하지 못한 것과 같다.

자연법을 가장 격렬하게 공격한 벤담(Bentham)과 밀(Mill) 같은 비판자들은, 이러한 구별되는 법의 의미들 사이에서 상대방들이 보인 혼동을, 자연의 관찰된 반복적 일양성들이 우주의 신적 통치자(Divine Governor)에 의해 처방되거나 포고되었다는 믿음의 잔존 탓으로 돌리는 경우가 많았다. 이러한 신정론적 관점에서는, 중력의 법칙과 십계명, 곧 인간을 위한 신의 법(God’s law for Man) 사이의 유일한 차이는 블랙스톤(Blackstone)이 단언했듯 비교적 사소한 것이었다. 창조된 것들 가운데 인간만이 이성과 자유의지를 부여받았고, 그래서

사물들과 달리 신적 처방들을 발견하고 그것들에 불복종할 수 있다는 점이 그것이다. 그러나 자연법은 항상 우주의 신적 통치자나 입법자에 대한 믿음과 결합되어 있었던 것은 아니며, 설령 그렇게 결합되어 있었던 곳에서도 그 특징적 교의들(tenets)이 논리적으로 그 믿음에 의존했던 것은 아니다. 자연법 안으로 들어오는 ‘자연적(natural)’이라는 단어의 관련 의미와, 처방적 법들과 기술적 법칙들 사이의 차이, 곧 현대인의 마음에는 너무나 명백하고 중요한 그 차이를 (p. 188) 최소화하는 자연법의 일반적 전망은 모두 그리스 사상에 뿌리를 두고 있으며, 이 목적에서는 그 그리스 사상은 꽤 세속적이었다. 기실 어떤 형태의 자연법 교설이 계속 재단언되는 것은 부분적으로, 그 호소력이 신적 권위와 인간적 권위 양자로부터 독립되어 있다는 사실 때문이고, 또 이제는 받아들일 사람이 거의 없을 용어법과 많은 형이상학에도 불구하고 그것이 도덕과 법을 이해하는 데 중요한 몇 가지 기초적 진리들(elementary truths)을 담고 있다는 사실 때문이다. 우리는 이것들을 그 형이상학적 배경에서 풀어내어 여기에서 더 단순한 용어들로 다시 진술하고자 한다.

현대 세속적 사유에서 무생물과 생물, 동물과 인간의 세계는 일정한 반복적 일양성을 지닌 연결들을 예시하는 되풀이되는 종류의 사건들과 변화들의 장면이다. 이 가운데 적어도 일부를 인간 존재들은 발견하여 자연법칙들(laws of nature)로 정식화하였다. 이 현대적 견해에서 자연을 이해한다는 것은, 자연의 어떤 부분에 이러한 반복적 일양성들에 대한 지식을 끌어다 적용하는 것이다. 물론 위대한 과학 이론들의 구조가 관찰 가능한 사실, 사건, 변화들을 어떤 단순한 방식으로 비추어 내는 것은 아니다. 기실 그러한 이론들의 큰 부분은 관찰 가능한 사실 안에 직접 대응물을 갖지 않는 추상적 수학 정식화들로 이루어지는 경우가 많다. 그것들이 관찰 가능한 사건들과 변화들에 연결되는 지점은, 이러한 추상 정식화들로부터 관찰 가능한 사건들을 실제로 참조하며, 그러한 사건들에 의해 확증되거나 반증될 수 있는 일반화들이 연역될 수 있다는 사실에 있다. 따라서 과학 이론이 자연에 대한 우리의 이해를 증진시킨다는 주장은 궁극적으로 무엇이 일어날지를 예측하는 그 이론의 능력에 의존하며, 이 능력은 반복적으로 일양적인 발생에 대한 일반화들에 기초한다. 중력의 법칙과 열역학 제2법칙은 현대 사유에서, 관찰 가능한 현상들의 반복적 일양성들에 관해 제공하는 정보

덕분에 자연법칙들이며 단순한 수학적 구성물 이상의 것이다.

자연법 교설은, 관찰 가능한 세계를 단지 그러한 반복적 일양성들의 장면으로 보지 않고 자연에 대한 지식을 단지 그것들에 대한 지식으로 보지도 않는다. 더 오래된 자연 구상의 일부이다. 오히려 이 더 오래된 전망에서는, 인간적인 것이든 생물적인 것이든 무생물적인 것이든 명명 가능한 모든 종류의 존재하는 사물이, 단지 자기 존재를 유지하려는 경향을 가지는 것으로만이 아니라, (p. 189) 그것에 고유한 선, 곧 그것에 적합한 목적(end)인 일정한 최적 상태를 향해 나아가는 것으로 파악된다.

이것은 자연이 그 자체 안에 사물들이 실현하는 탁월성의 수준들(levels of excellence)을 담고 있다는 목적론적 자연 구상(teleological conception of nature)이다. 어떤 주어진 종류의 사물이 그 고유하거나 적합한 목적에 이르기까지 나아가는 단계들은 반복적으로 일양적인 양상을 보이며, 그 사물의 특징적 변화, 작용, 또는 발전 양태를 기술하는 일반화들로 정식화될 수 있다. 그 정도까지 목적론적 자연관은 현대 사유와 중첩된다. 차이는 목적론적 관점에서는 사물들에게 닥치는 반복적으로 일양적인 사건들이 단지(merely) 반복적으로 일양적인 발생 양상으로만 생각되지 않고, 그것들이 실제로(do) 반복적으로 일양적인 발생 양상을 보이는지, 그것들이 일어나야 하는지(should), 또는 그것들이 일어나는 것이 좋은지(good)라는 질문들이 별개의 질문들로 간주되지 않는다는 데 있다. 오히려(‘우연(chance)’에 귀속되는 몇몇 드문 기형들을 제외하면) 일반적으로 일어나는 것은, 관련 사물의 적합한 목적 또는 목표를 향한 한 단계로 제시됨으로써 설명될 수 있을 뿐 아니라, 선택한 것 또는 일어나야 할 것으로 평가될 수도 있다. 따라서 한 사물의 발전 법칙들은 그것이 어떻게 마땅히 행위하거나 변화해야 하는지와 어떻게 실제로 반복적으로 일양적인 행태나 변화를 보이는지를 모두 보여주어야 한다.

자연에 관한 이러한 사고방식은 추상적으로 진술되면 낯설어 보인다. 그러나 우리가 오늘날에도 적어도 생물들에 관해서는 여전히 말하는 몇몇 방식들을 떠올리면 덜 기이하게 보일 수 있다. 목적론적 관점은 그 발전을 기술하는 일상적 방식들 속에 여전히 반영되어 있기 때문이다. 예컨대 도토리(acorn)의 경우, 참나무(oak)로 성장하는 것은 도토리들에게서 반복적으로 일양적인 성취로 나

타나는 것일 뿐 아니라, (역시 반복적으로 일양적인) 부패(decay)와 달리 성숙의 최적 상태로 구별된다. 이 최적 상태에 비추어 중간 단계들은 설명되고 좋거나 나쁜 것으로 판단되며, 그것의 여러 부분들의 ‘기능들(functions)’ 과 구조적 변화들이 식별된다. ‘완전한(full)’ 또는 ‘적합한(proper)’ 발전에 필요한 수분을 얻으려면 잎의 정상적 성장이 요구되며, 이를 공급하는 것이 잎의 ‘기능’ 이다. 그래서 우리는 이러한 성장을 ‘자연적으로 일어나야 할 것(ought naturally to occur)’ 으로 사고하고 말한다. 무생물들의 작용이나 운동의 경우, 그것들이 인간 존재들이 어떤 목적을 위해 설계한 인공물들이 아닌 한, 이러한 말하기 방식들은 훨씬 덜 그럴듯해 보인다. 돌이 땅에 떨어질 때 어떤 적합한 (p. 190) ‘목적(end)’ 을 실현하고 있거나, 말이 마구간으로 달려 돌아가듯 자기 ‘고유한 자리(proper place)’ 로 되돌아가고 있다는 관념은 이제 다소 우스꽝스럽다.

기실, 목적론적 자연관을 이해할 때의 난점 하나는, 그것이 반복적으로 일양적인 일어남에 대한 진술들과 일어나야 할 것에 대한 진술들 사이의 차이를 최소화하듯이, 현대 사유에서 그토록 중요한, 자기 자신의 목적을 가지고(with) 그것을 의식적으로 실현하려고 노력하는 인간 존재들과 다른 생물 또는 무생물 사이의 차이도 최소화한다는 점이다. 목적론적 세계관에서 인간은 다른 사물들처럼 그에게 설정된 특정한 최적 상태 또는 목적을 향해 나아가는 것으로 생각되며, 그가 다른 사물들과 달리 이것을 의식적으로 할 수 있다는 사실은 그와 나머지 자연 사이의 근본적 차이로 파악되지 않는다. 이러한 특정한 인간의 목적 또는 선은 부분적으로, 다른 생물들의 경우처럼, 생물학적 성숙과 발달된 신체적 능력들의 조건이다. 그러나 그것은 또한, 인간에게 특유한 요소로서, 사유와 행위에서 드러나는 정신과 품성의 발전 및 탁월성을 포함한다. 다른 사물들과 달리 인간은 추론과 성찰을 통해 이러한 정신과 품성의 탁월성을 달성하는 일이 무엇을 수반하는지를 발견하고 그것을 욕구할 수 있다. 그러나 그렇다 해도, 이 목적론적 견해에서는 이 최적 상태가 인간이 그것을 욕구하기 때문에 그의 선이나 목적이 되는 것이 아니다. 오히려 그것이 이미 그의 자연적 목적이기 때문에 그는 그것을 욕구한다.

또한, 이러한 목적론적 관점의 많은 부분은 우리가 인간 존재들을 사고하고 말하는 몇몇 방식들 속에 살아남아 있다. 그것은 우리가 어떤 것들을 충족시키는

것이 좋은(good) 인간의 필요들(needs)로 식별하고, 인간에게 행해지거나 인간이 겪는 어떤 것들을 해악(harm) 또는 손해(injury)로 식별하는 데 잠재해 있다. 따라서 일부 사람들이 죽고 싶어서 먹거나 쉬기를 거부할 수 있다는 것은 참이지만, 우리는 먹고 쉬는 것을 인간들의 반복적으로 일양적인 행위들이거나 그저 우연히 욕구하는 일들 이상의 것으로 생각한다. 음식과 휴식은, 어떤 사람들이 그것들이 필요할 때 그것들을 거부한다 하더라도, 인간의 필요들이다. 그러므로 우리는 모든 인간이 먹고 자는 것이 자연스럽다고 말할 뿐 아니라, 모든 인간은 때때로 먹고 쉬어야 한다거나, 이러한 일들을 하는 것은 자연적으로 좋다고도 말한다. 인간 행위에 대한 그러한 판단들에서 ‘자연적으로(naturally)’ 라는 말의 힘은, 그 판단들을 단순한 관행들이나 인간적 처방들을 반영하는 판단들(‘모자를 벗어야 한다’)과 구별하고, 그 내용이 (p. 191) 사유나 성찰에 의해 발견될 수 없는 판단들과 구별하며, 또한 특정 시점에 한 사람은 우연히 가지고 다른 사람은 가지지 않을 수도 있는 어떤 특정 목적을 달성하기 위해 요구되는 것을 단지 지목하는 판단들과도 구별하는 데 있다. 같은 전망은 신체 기관들의 기능들(functions)에 대한 우리의 구상과, 이것들과 단순한 인과적 속성들 사이에 우리가 굿는 선에도 나타난다. 우리는 피를 순환시키는 것이 심장의 기능이라고 말하지만, 죽음을 초래하는 것이 암성 종양(cancerous growth)의 기능이라고 말하지는 않는다.

인간 행위에 대한 일상적 사고 속에 여전히 살아 있는 목적론적 요소들을 예시하기 위해 고안된 이 투박한 사례들은, 인간이 다른 동물들과 공유하는 생물학적 사실이라는 낮은 영역에서 끌어온 것이다. 이 사고와 표현의 양식을 이해 가능하게 만드는 것은 전적으로 자명한 어떤 것이라고 정당하게 지적될 것이다. 그것은 인간 활동의 적합한 목적이 생존(survival)이라는 묵시적 가정(tacit assumption)이고, 이는 대부분의 인간이 대부분의 시간 동안 계속 존재하기를 바란다는 단순한 우연적 사실에 기초해 있다. 우리가 자연적으로 행하기에 좋은 것들이라고 말하는 행위들은 생존을 위해 요구되는 행위들이며, 인간의 필요, 해악, 그리고 신체 기관들이나 변화들의 기능(function)이라는 관념들도 같은 단순한 사실에 기초해 있다. 물론 여기서 멈춘다면 우리는 자연법의 매우 약화된 판본만을 가지게 될 것이다. 이 전망의 고전적 주창자들은 생존

(*perseverare in esse suo*)을 인간의 목적 또는 인간에게 좋은 것에 대한 훨씬 더 복잡하고 훨씬 더 다룰 여지가 큰 개념에서 단지 가장 낮은 층위로만 파악했기 때문이다. 아리스토텔레스는 그 안에 인간 지성의 사심 없는 함양(*disinterested cultivation*)을 포함시켰고, 아퀴나스는 신에 대한 앎을 포함시켰으며, 이 둘은 도전될 수 있고 실제로 도전되어 온 가치들을 대표한다. 그러나 홉스(Hobbes)와 흄(Hume)을 포함한 다른 사상가들은 기꺼이 눈높이를 낮추었다. 그들은 생존이라는 소박한 목적에서 자연법 용어법에 경험적 일리(*empirical good sense*)를 부여하는, 중심적이고 다룰 수 없는 요소를 보았다. “인간 본성은 어떤 수단으로도 개인들의 결합(*association*) 없이는 존속할 수 없다. 그리고 형평(*equity*)과 정의의 법들(*laws*)에 아무런 고려도 기울여지지 않는다면 그 결합은 결코 자리 잡을 수 없었을 것이다.”¹

이 단순한 생각은 실제로 법들과 도덕규범들 양자의 특징들과 매우 깊은 관련을 가지며, 인간의 목적 또는 인간에게 좋은 것이, 사실상 사람들이 깊이 의견불일치를 보일 수 있는 특정한 삶의 방식으로 나타나는 일반적 목적론적 전망의 더 다룰 수 있는 부분들로부터 풀어낼 수 있다. 더 나아가 우리는 생존을 언급하면서, 이것이 인간의 고유한 목표 또는 목적이기 때문에 인간이 필연적으로 욕구하는, 선행적으로 고정된 어떤 것이라는 관념을 현대인의 마음에는 지나치게 형이상학적인 것으로 버릴 수 있다. 대신 우리는, 일반적으로 인간들이 살기를 욕구한다는 것은 달리 그럴 수도 있었던 단순한 우연적 사실이며, 생존을 인간의 목표 또는 목적이라고 부를 때 우리가 의미하는 것은 인간들이 그것을 욕구한다는 것 이상이 아닐 수 있다고 볼 수 있다. 그러나 이렇게 상식적인 방식으로 생각하더라도, 생존은 여전히 인간 행위와 그것에 대한 우리의 사고에서 특수한 지위를 가지며, 이는 자연법의 정통적 정식화들에서 생존에 부여된 두드러짐과 필연성에 평행한다. 압도적 다수의 인간들이 끔찍한 비참함을 대가로 치르더라도 살기를 바란다는 점만이 아니라, 이것이 우리가 세계와 서로를 기술하는 데 쓰는 우리의 사고와 언어 전체 구조들 속에 반영되어 있기 때문이다. 우리는 살고자 하는 일반적 바람을 빼내면서도 위험과 안전, 해악과 이익, 필요와 기능, 질병과 치료 같은 개념들을 온전하게 남겨 둘 수 없다.

¹Hume, *Treatise of Human Nature*, m. ii, ‘Of Justice and Injustice’.

이것들은 목적으로 받아들여진 생존에 대해 그것들이 하는 기여를 참조하여 사물들을 동시에 기술하고 평가하는 방식들이기 때문이다.

그러나 이보다 더 단순하고 덜 철학적인 고려들이 있으며, 그것들은 인간의 법과 도덕규범들에 관한 논의와 더 직접적으로 관련되는 의미에서 생존을 하나의 목적으로 받아들이는 일이 필요함을 보여준다. 우리는 논의의 용어들에 의해 전제되는 것으로서 그것에 이미 묶여 있다. 우리의 관심사는 자살 클럽의 장치들이 아니라 계속 존재를 위한 사회적 장치들이기 때문이다. 우리는 이러한 사회적 장치들 가운데 이성에 의해 발견 가능한 자연법들(natural laws)로 유익하게 분류될 수 있는 것들이 있는지, 그리고 그것들이 인간의 법과 도덕에 대해 어떤 관계를 가지는지를 알고 싶다. 인간들이 어떻게 함께 살아야 하는지에 관한 이 질문이나 다른 어떤 질문을 제기하기 위해서는, 일반적으로 말해 그들의 목적이 사는 것이라고 가정해야 한다. 이 지점에서 논증은 단순하다. 인간 본성과 인간들이 살아가는 세계에 관한 몇몇 매우 명백한 일반화들, 기실 자명한 이치들(truisms)에 대한 성찰은, (p. 193) 이것들이 타당하게 유지되는 한, 어떤 사회 조직이 존속 가능하려면 반드시 담고 있어야 하는 일정한 행위 규칙들이 있음을 보여준다. 그러한 규칙들은 실제로, 사회 통제의 서로 다른 형식들로 구별되는 지점까지 발전한 모든 사회들의 법과 관행적 도덕 안에서 공통 요소를 이룬다. 그것들과 함께, 법과 도덕규범들 양자에는 특정 사회에 고유한 많은 것과 임의적이거나 단순한 선택의 문제로 보일 수 있는 많은 것이 발견된다. 인간 존재들, 그들의 자연적 환경, 그리고 목적들에 관한 기초적 진리들(elementary truths)에 기초를 둔, 보편적으로 인정된 이러한 행위 원칙들은 그 이름 아래 자주 제시되어 온 더 장대한, 그리고 더 다룰 수 있는 구성물들과 대비하여 자연법의 최소한의 내용(minimum content)으로 여겨질 수 있다. 다음 절에서는 이 소박하지만 중요한 최소한이 의존하는 인간 본성의 두드러진 특징들을 다섯 가지 자명한 이치들의 형식으로 검토할 것이다.

2. 자연법의 최소한의 내용 (The Minimum Content of Natural Law)

여기서 제시하는 단순한 자명한 이치들(truisms)과 그것들이 법 및 도덕규범들과 맺는 연결을 고찰할 때, 각 경우에 언급된 사실들이 생존이 하나의 목적으로 주어지면 법과 도덕규범들이 특정한 내용을 포함해야 하는 이유(reason)를 제공한다는 점을 주목하는 것이 중요하다. 논증의 일반 형식은 단순하다. 그러한 내용이 없다면 법들과 도덕규범들은 인간들이 서로 결합하면서 가지는 생존이라는 최소 목적을 증진할 수 없다는 것이다. 이 내용이 없으면, 있는 그대로의 인간들은 어떤 규칙들에도 자발적으로 복종할 이유를 갖지 않을 것이다. 또 규칙들에 복종하고 그것들을 유지하는 것이 자기 이익에 부합한다고 보는 사람들이 자발적으로 제공하는 최소한의 협력이 없다면, 자발적으로 부합하지 않을 다른 사람들에 대한 강제(coercion)는 불가능할 것이다. 이 접근에서 자연적 사실들과 법적·도덕적 규칙들의 내용 사이의 구별되게 합리적인 연결을 강조하는 것은 중요하다. 자연적 사실들과 법적 또는 도덕적 규칙들 사이의 전혀 다른 연결 형식들을 탐구하는 것도 가능하고 중요하기 때문이다. 예컨대 아직 젊은 과학자들인 심리학과 사회학은, 일정한 물리적·심리적·경제적 조건들이 충족되지 않으면, 예컨대 어린 아이들이 (p. 194) 가족 안에서 일정한 방식으로 먹여지고 양육되지 않으면, 어떤 법들의 체계나 도덕규범들의 규약도 확립될 수 없다는 점, 또는 특정한 유형에 부합하는 법들만 성공적으로 기능할 수 있다는 점을 발견할 수도 있고 이미 발견했을 수도 있다. 이러한 종류의 자연적 조건들과 규칙 체계들 사이의 연결들은 이유들(reasons)에 의해 매개되지 않는다. 그것들은 일정한 규칙들의 존재를, 그 규칙들을 자기 규칙으로 삼는 사람들의 의식적 목표들이나 목적에 관련시키지 않기 때문이다. 유아기에 일정한 방식으로 먹여지는 것이 어떤 인구 집단이 도덕 규약이나 법 규약을 발전시키거나 유지하는 데 필요한 조건 또는 심지어 원인(cause)임이 충분히 입증될 수 있다. 그러나 그것은 그들이 그렇게 하는 이유는 아니다. 이러한 인과적 연결들은 물론 목적들이나 의식적 목표들에 기초한 연결들과 충돌하지 않는다. 기실 그것들은 자연법이 자기 출발점들로 삼는 의식적 목표들이나 목적들을 인간 존재들이 왜 가지는지를 설명할 수도 있으므로, 후자보다 더 중요하거나 근본적인 것으로

여겨질 수 있다. 이러한 유형의 인과적 설명들은 자명한 이치들에 기초하지 않고, 의식적 목표들이나 목적들에 의해 매개되지도 않는다. 그것들은 다른 과학들과 마찬가지로 사회학이나 심리학이 관찰에, 그리고 가능한 경우 실험에, 기초한 일반화와 이론의 방법들로 확립해야 할 것이다. 따라서 그러한 연결들은 일정한 법적·도덕적 규칙들의 내용을 다음 자명한 이치들에서 진술되는 사실들에 관련시키는 연결들과는 다른 종류의 것이다.

(i) 인간의 취약성 (Human vulnerability) 법과 도덕의 공통 요구들은 대부분 제공되어야 할 적극적 봉사들이 아니라 자제들(forbearances)로 이루어지며, 이 자제들은 보통 금지들(prohibitions)이라는 부정적 형식으로 정식화된다. 그 가운데 사회생활에 가장 중요한 것은 살해하거나 신체적 해악을 가하는 데 폭력을 사용하는 일을 제한하는 규칙들이다. 그러한 규칙들의 기본적 성격은 하나의 질문으로 드러낼 수 있다. 이런 규칙들이 없다면 우리와 같은 존재들에게 다른 어떤 종류의 규칙들을 가진다는 데 무슨 의의가 있을 수 있겠는가? 이 수사적 질문의 힘은 인간들이 때때로 신체적 공격을 하는 경향이 있고, 보통은 신체적 공격에 취약하다는 사실에 기초해 있다. 그러나 이것은 자명한 이치(truism)이기는 하지만 필연적 진리는 아니다. 사태는 달랐을 수도 있고 언젠가는 달라질 수도 있기 때문이다. 신체 구조(외골격이나 등딱지를 포함)가 같은 종의 다른 구성원들의 공격에 사실상 면역이 되게 하는 동물 종들도 있고, 공격할 수 있게 하는 기관을 전혀 갖지 않은 동물들도 있다. 인간들이 (p. 195) 서로에 대한 취약성을 잃는다면, 법과 도덕규범들의 가장 특징적인 규정 가운데 하나인 살해하지 말라(Thou shalt not kill)에 대한 한 가지 명백한 이유도 사라질 것이다.

(ii) 근사적 동등성 (Approximate equality) 인간들은 신체적 힘, 민첩성, 그리고 훨씬 더 크게는 지적 능력에서 서로 다르다. 그럼에도 불구하고 법과 도덕의 서로 다른 형식들을 이해하는 데 매우 중대한 중요성을 가지는 사실은, 어떤 개인도 협력 없이 짧은 기간을 넘어 타인들을 지배하거나 제압할 수 있을 만큼 다른 이들보다 훨씬 더 강력하지는 않다는 점이다.

가장 강한 사람도 때로는 잠을 자야 하며, 잠든 동안에는 일시적으로 자기 우월성을 잃는다. 이 근사적 동등성의 사실은 다른 어떤 것보다도, 법적 의무와 도덕적 의무 양자의 기초인 상호 자제와 타협의 체계가 필요하다는 점을 분명하게 만든다. 그러한 자제들을 요구하는 규칙들을 가진 사회 생활은 때때로 성가시다. 그러나 이렇게 근사적으로 동등한 존재들에게 그것은 어쨌든 억제되지 않은 공격보다 덜 험악하고, 덜 야수적이며, 덜 짧다. 물론 이와 전적으로 양립하며 그와 동등하게 자명한 이치는, 그러한 자제 체계가 확립되면 언제나 그 보호 안에서 살면서 동시에 그 제약들(restrictions)을 깨뜨림으로써 그것을 이용하려는 사람들이 있을 것이라는 점이다. 이것은 기실 뒤에서 보이듯, 단순히 도덕적인 통제에서 조직화된 법적 통제 형식들로 나아가는 단계를 필연적인 것으로 만드는 자연적 사실들 가운데 하나이다. 또한 사태는 달랐을 수도 있다. 근사적으로 동등한 대신, 어떤 사람들이 다른 사람들보다 압도적으로 더 강하고 휴식 없이 지낼 수 있는 능력도 더 컸을 수 있다. 어떤 이들이 이런 점들에서 현재 평균보다 훨씬 높았거나, 대부분이 그보다 훨씬 낮았기 때문일 수 있다. 그러한 예외적 인간들은 공격으로 얻을 것이 많고 타인들과의 상호 자제나 타협에서 얻을 것은 적었을 수 있다. 그러나 근사적 동등성이라는 사실의 중대한 중요성을 보기 위해 소인들 사이의 거인이라는 공상에 의존할 필요는 없다. 그 중요성은 국가들 사이에 힘과 취약성에서 거대한 격차들이 존재하거나 존재했던 국제 생활의 사실들에 의해 더 잘 예시되기 때문이다. 나중에 보겠지만, 국제법의 단위들 사이의 이러한 불평등은 국제법에 국내법과 그토록 다른 성격을 부여하고, 그것이 조직화된 강제 체계로 작동할 수 있는 정도를 제한해 온 것들 가운데 하나이다. (p. 196)

- (iii) 제한된 이타성 (Limited altruism) 인간들은 서로를 절멸시키려는 바람에 지배되는 악마들이 아니며, 생존이라는 소박한 목적만 주어져도 법과 도덕규범들의 기본 규칙들이 필요하다는 입증, 인간들이 주로 이기적이고 동료들의 생존과 복지에 사심 없는 관심을 전혀 갖지 않는다는 거짓 견해와 동일시해서는 안 된다. 그러나 인간들이 악마들이 아니라면

천사들도 아니다. 그리고 인간들이 이 두 극단 사이의 중간이라는 사실은 상호 자제들의 체계를 필요하게도 하고 가능하게도 하는 것이다. 타인들을 해하려는 유혹을 전혀 받지 않는 천사들에게는 자제들을 요구하는 규칙들이 필요하지 않을 것이다. 자기 자신에게 드는 비용을 무모하게 무시하면서 파괴할 준비가 된 악마들에게는 그러한 규칙들이 불가능할 것이다. 사태가 현재 그러한 대로, 인간의 이타성은 범위가 제한되어 있고 간헐적이며, 공격 성향들은 통제되지 않으면 사회생활에 치명적일 만큼 충분히 빈번하다.

- (iv) 제한된 자원 (Limited resources) 인간 존재들이 음식, 의복, 거처를 필요로 한다는 것, 이것들이 손 가까이에 무한히 풍부하게 존재하지 않는다는 것, 그것들이 부족하며 자연에서 재배되거나 얻어져야 하거나 인간의 수고로 만들어져야 한다는 것은 단지 우연적 사실이다. 그러나 이 사실들만으로도 재산 제도의 어떤 최소 형식(반드시 개인 재산일 필요는 없지만)과 그것에 대한 존중을 요구하는 독특한 종류의 규칙은 필수적이 된다. 재산의 가장 단순한 형식들은 일반적으로 ‘소유자’ (owner) 이외의 사람들을 토지에 들어가거나 토지를 사용하는 것에서, 또는 물질적 사물들을 취하거나 사용하는 것에서 배제하는 규칙들에서 볼 수 있다. 작물이 자라려면 토지는 무차별적 출입으로부터 안전해야 하고, 식량은 그 재배 또는 포획과 소비 사이의 기간에 다른 사람들에게 빼앗기지 않도록 안전해야 한다. 모든 시대와 장소에서 삶 자체는 이러한 최소한의 자제들에 의존한다. 또한 이 점에서도 사태는 현재와 달랐을 수 있다. 인간 유기체가 식물들처럼 구성되어 공기에서 음식을 추출할 수 있었을 수도 있고, 인간에게 필요한 것이 경작 없이 무한히 풍부하게 자랐을 수도 있다.

지금까지 논의한 규칙들은, 그것들이 부과하는 의무들과 이러한 의무들의 귀속양상이 개인들에 의해 변경될 수 없다는 의미에서 정태적 규칙들(*static rules*)이다. 그러나 아주 작은 집단들을 제외한 모든 집단이 적절한 공급을 얻기 위해 발전시켜야 하는 노동 분업은, 개인들이 의무들을 창출하고 그 귀속양상을

변경할 수 있게 한다는 의미에서 (p. 197) 동태적인 규칙들(*dynamic rules*)에 대한 필요를 가져온다. 여기에는 인간들이 자기 생산물을 이전하거나, 교환하거나, 판매할 수 있게 하는 규칙들이 포함된다. 이러한 거래들은 재산의 가장 단순한 형식을 규정하는 최초의 권리들과 의무들의 귀속양상을 변경할 행위능력을 수반하기 때문이다. 똑같이 피할 수 없는 노동 분업과 항구적인 협력 필요 역시, 다른 형식들의 동태적 또는 의무-창출 규칙을 사회생활에서 필요하게 만드는 요인들이다. 이것들은 약속들을 의무의 원천(*source of obligation*)으로 인정하게 한다. 이 장치에 의해 개인들은 구두든 서면이든 말로써, 일정하게 규정된 방식들로 행위하지 못한 데 대해 스스로 비난이나 처벌의 책임을 질 수 있게 된다. 이타성이 무제한적이지 않은 곳에서는, 타인들의 미래 행위에 대한 최소한의 신뢰 형식을 창출하고 협력에 필요한 예측가능성을 확보하기 위해, 그러한 자기구속 작용들을 마련하는 항구적 절차가 요구된다. 이것은 교환되거나 공동으로 계획되는 것이 상호 서비스들인 곳, 또는 교환되거나 판매될 재화들이 동시에 또는 즉시 이용 가능하지 않은 곳에서 가장 명백하게 필요하다.

- (v) 제한된 이해력과 의지력 (*Limited understanding and strength of will*) 사람들, 재산, 약속을 존중하는 규칙들이 사회생활에서 필요하게 되는 사실들은 단순하며, 그 상호 이익들은 명백하다. 대부분의 인간들은 그것들을 볼 수 있고, 그러한 규칙들에 대한 부합이 요구하는 즉각적인 단기 이익들의 희생을 감수할 수 있다. 그들은 기실 다양한 동기들에서 복종할 수 있다. 어떤 이들은 그 희생들이 얻는 이익에 비추어 치를 만하다는 신중한 계산에서, 어떤 이들은 타인들의 복지에 대한 사심 없는 관심에서, 어떤 이들은 그 규칙들 자체를 존중할 가치가 있는 것으로 보고 그것들에 대한 헌신에서 자기 이상들을 찾기 때문에 복종할 수 있다. 다른 한편으로, 장기적 이익에 대한 이해도, 복종을 향한 이러한 서로 다른 동기들의 실효성이 의존하는 의지의 힘이나 선행도 모든 인간들에게 똑같이 공유되어 있지는 않다. 누구나 때로 자기 자신의 즉각적 이익을 선호하려는 유혹을 받으며, 이를 탐지하고 처벌하기 위한 특수 조직이 없다면 많은 이들이 그 유혹에 굴복할 것이다. 상호 자제의 이점들이 매우 명백하므로, (p. 198)

강제 체계에서 자발적으로 협력할 사람들의 수와 힘은 보통 악행자들(malefactors)의 그럴 법한 어떤 결합보다 클 것이다. 그럼에도 매우 작고 긴밀하게 결속된 사회들을 제외하면, 그때 그 체계의 이점들은 얻으려 하면서 그 의무들에는 복종하지 않으려 할 자들을 강제할 조직이 없다면, 제한들의 체계에 대한 복종은 어리석은 일일 것이다. 따라서 ‘제재들’(sanctions)은 복종의 통상적 동기로서 요구되는 것이 아니라, 자발적으로 복종하려는 사람들이 그렇지 않으려는 사람들에게 희생되지 않으리라는 보증(guarantee)으로 요구된다. 이것 없이 복종하는 것은 밀려나 무너질 위험을 감수하는 일일 것이다. 이러한 항구적 위험이 주어질 때, 이성이 요구하는 것은 강제적 체계 안에서의 자발적 협력이다.

인간들 사이의 근사적 동등성이라는 바로 그 자연적 사실이 조직화된 제재들의 실효성에서도 핵심적으로 중요하다는 점을 주목해야 한다. 어떤 인간들이 다른 인간들보다 엄청나게 더 강력해서 타인들의 자제에 의존하지 않는다면, 악행자들의 힘은 법과 질서의 지지자들의 힘을 넘어설 수 있다. 그러한 불평등들이 주어지면, 제재들의 사용은 성공할 수 없고 그것들이 억누르도록 고안된 위험들만큼이나 큰 위험들을 수반할 것이다. 이러한 상황에서는, 사회생활이 소수의 악행자들에게만 간헐적으로 힘이 사용되는 상호 자제들의 체계에 기초하는 대신, 약자들이 자신들이 얻어낼 수 있는 최선의 조건으로 강자들에게 복종하고 그들의 ‘보호’ 아래 사는 체계만이 존속 가능할 것이다. 이것은 자원의 희소성 때문에 서로 충돌하는 다수의 권력 중심들을 낳을 것이고, 각각은 자기 ‘강한 자(strong man)’를 중심으로 묶일 것이다. 이들은 간헐적으로 서로 전쟁을 벌일 수 있겠지만, 패배 위험이라는 결코 무시할 수 없는 자연적 제재가 불안한 평화를 보장할 수도 있다. 그때 ‘세력들(powers)’이 싸우기를 원치 않는 쟁점들을 규율하기 위한 일종의 규칙들이 수용될 수도 있다. 또한 우리는 근사적 동등성의 단순한 역학(logistics)과 그것의 법에 대한 중요성을 이해하기 위해 소인들과 거인들을 공상할 필요가 없다. 관련 단위들이 힘에서 엄청나게 달랐던 국제 장면은 충분한 예시를 제공한다. 수 세기 동안 국가들 사이의 격차들은 조직화된 제재들이 불가능한 체계를 낳았고, 법은 ‘중대한(vital)’ 쟁점들에

영향을 미치지 않는 사안들에 국한되었다. (p. 199) 원자무기가 모든 이들에게 이용 가능해질 때, 그것이 불균등한 힘의 균형을 얼마나 시정하고 국내 형사법을 더 가깝게 닮은 통제 형식들을 가져올지는 지켜봐야 한다.

우리가 논의한 단순한 자명한 이치들은 자연법 교설 안의 건전한 양식의 핵심을 드러낼 뿐만 아니라, 법과 도덕규범들을 이해하는 데 사활적으로 중요하다. 또한 그것들은 이 기본 형식들의 정의를 어떤 특정 내용이나 사회적 필요들에 대한 참조 없이 순수하게 형식적 용어들로 내리는 일이 왜 그토록 부적절한 것으로 드러났는지도 설명한다. 아마 이 전망이 법리학(jurisprudence)에 주는 주요 이익은, 법의 특징들에 대한 논의를 자주 흐리는 일정한 오도적 이분법들에서 벗어나게 해 준다는 점이다. 예컨대 모든 법체계가 반드시 제재들을 마련해야 하는가라는 전통적 질문은, 이 단순한 자연법 판본이 제시하는 사물들에 대한 시야를 확보할 때 새롭고 더 명료한 빛 속에 놓일 수 있다. 우리는 더 이상, 흔히 망라적인 것으로 받아들여지는 두 부적절한 대안 사이에서 선택할 필요가 없을 것이다. 한편으로 이것이 ‘법’ 또는 ‘법체계’ 라는 단어들의 ‘그(the)’ 의미에 의해 요구된다고 말하는 대안과, 다른 한편으로 대부분의 법체계들이 제재들을 마련한다는 것은 ‘단지 사실(just a fact)’ 이라고 말하는 대안이다. 이 대안들 가운데 어느 것도 만족스럽지 않다. 중앙적으로 조직된 제재들이 없는 체계들에 ‘법’ 이라는 단어를 사용하는 것을 금지하는 확립된 원칙들은 없으며, 그러한 제재들을 갖지 않는 어떤 체계에 ‘국제법’ 이라는 표현을 사용할 좋은 이유는 있다(강제되는 것은 아니지만). 다른 한편, 인간들이 구성되어 있는 그대로의 존재들에게 최소 목적들을 수행하려면, 국내 체계 안에서 제재들이 가져야 하는 자리를 구별할 필요가 있다. 자연적 사실들과 목적들의 배경이 주어지고, 이 배경이 국내 체계에서 제재들을 가능하고 필요하게 만든다면, 우리는 이것이 자연적 필연성(natural necessity)이라고 말할 수 있다. 그리고 유사한 어떤 문구는 사람들, 재산, 약속에 대한 최소한의 보호 형식들, 곧 마찬가지로 국내법의 필수불가결한 특징들의 지위를 전달하는 데에도 필요하다. 우리는 ‘법은 어떤 내용도 가질 수 있다’ 는 실증주의 테제에 바로 이러한 형식으로 답해야 한다. 법뿐만 아니라 많은 다른 사회 제도들을 적절하게 기술하기 위해서는, 정의들(definitions)과 통상적 사실 진술들 옆에 제3 범주의 진술들을 위한 자리가 남겨

져야 한다는 것은 어느 정도 중요한 진리이기 때문이다. (p. 200) 곧 그것들의 참이 인간 존재들과 그들이 살아가는 세계가 자신들이 가진 두드러진 특징들을 계속 유지한다는 데 의존하는 진술들이다.

3. 법적 유효성과 도덕적 가치

법과 도덕규범들 양자의 배후에 놓인 상호 자제들의 체계가 제공하는 보호들과 혜택들은, 서로 다른 사회들에서 매우 다른 범위의 사람들에게 확장될 수 있다. 대응하는 제약들(restrictions)을 수용할 의사가 있는 어떤 인간 부류에게도 이러한 기초적 보호들(elementary protections)을 부정하는 것은, 모든 현대 국가들이 적어도 말뿐인 경의(lip-service)를 바치는 도덕과 정의의 원칙들에 어긋난다는 점은 참이다. 그들이 공언하는 도덕 전망은 일반적으로, 적어도 이러한 근본 사항들에서는 인간 존재들이 같게 대우받을 자격이 있으며, 대우의 차이는 단지 타인들의 이익에 호소하는 것 이상의 정당화를 필요로 한다는 구상으로 배어 있다.

그러나 사회들의 법이나 수용된 도덕이 그 범위 안에 있는 모든 사람에게 자기의 최소 보호들과 혜택들을 확장할 필요는 없으며, 실제로 그렇게 하지 않은 경우도 많다는 점은 분명하다. 노예소유 사회들에서 지배 집단은 노예들이 사용될 단순한 물건들이 아니라 인간 존재들이라는 감각을 잃을 수 있고, 그러면 서로의 청구들과 이익들에 대해서는 도덕적으로 가장 민감하게 남아 있을 수 있다. 『허클베리 핀(Huckleberry Finn)』에서 증기선 보일러 폭발로 누군가 다쳤는지 질문을 받자 허크는 “아뇨, 캄둥이 하나가 죽었어요(No'm: killed a nigger)”라고 답했다. 셸리 이모의 말, “그럼 다행이네. 가끔은 사람이 다치기도 하니까(Well it's lucky because sometimes people do get hurt)”는 인간들 사이에서 자주 지배적이었던 하나의 전체 도덕을 압축한다. 그것이 지배하는 곳에서는, 허크가 대가를 치르며 알게 되었듯이, 지배 집단 구성원들 사이에서는 자연스러운 타인들에 대한 관심을 노예들에게 확장하는 일이 중대한 도덕적 위반행위(offence)로 여겨질 수 있으며, 도덕적 죄책의 모든 후속 귀결들을 가져올 수 있다. 나치 독일과 남아프리카 공화국은 시간상 우리에게 불쾌할 만큼

가까운 유사 사례들을 제공한다.

어떤 사회들의 법이 때때로 수용된 도덕보다 앞서 간 적이 있기는 하지만, 보통 법은 도덕을 따르며 노예의 살해조차 공적 자원의 낭비나, 그 노예가 재산으로 속한 주인에 대한 침해(offence)로만 간주될 수 있다. 노예제가 공식적으로 인정되지 않는 곳에서도, 인종, 피부색, (p. 201) 또는 신조를 근거로 한 차별들은 모든 인간이 타인들로부터 최소한의 보호를 받을 자격이 있다는 점을 인정하지 않는 법체계와 사회적 도덕을 산출할 수 있다.

인간 역사의 이러한 고통스러운 사실들은, 어떤 사회가 존속 가능하려면 그 구성원들 가운데 일부에게 상호 자제들의 체계를 제공해야 하지만, 유감스럽게도 그것을 모두에게 제공할 필요는 없다는 점을 보여주기에 충분하다. 우리가 이미 제재들의 필요성과 가능성을 논하면서 강조했듯이, 어떤 규칙 체계가 누군가에게 힘으로 부과되려면, 그것을 자발적으로 수용하는 충분한 수의 사람들이 있어야 한다. 그들의 자발적 협력이 없다면, 그렇게 권위(authority)를 창출하지 않는다면, 법과 정부의 강제 권력(coercive power)은 정립될 수 없다. 그러나 이렇게 권위의 기초 위에 정립된 강제 권력은 두 가지 주된 방식으로 사용될 수 있다. 그것은 규칙들의 보호를 받으면서도 이기적으로 그 규칙들을 깨뜨리는 악행자들에 대해서만 행사될 수 있다. 다른 한편 그것은 종속 집단(subject group)을 제압하고 영구적 열등성의 지위에 유지하는 데 사용될 수 있다. 그 집단의 크기는, 지배 집단이 이용할 수 있는 강제 수단, 결속, 규율과 종속 집단의 무력함 또는 조직할 수 없음에 따라 지배 집단에 비해 클 수도 작을 수도 있다. 이렇게 억압받는 사람들에게 그 체계 안에는 그들의 충성을 불러일으킬 것이 아무것도 없고 두려워할 것들만 있을 수 있다. 그들은 그 체계의 수익자들이 아니라 희생자들이다.

이 책의 앞선 장들에서 우리는 법체계의 존재가 언제나 두 측면을 제시하는 사회 현상이라는 사실을 강조했고, 그것에 대한 우리의 견해가 현실적이려면 그 두 측면 모두에 주의를 기울여야 한다고 했다. 그것은 규칙들의 자발적 수용에 관련된 태도들과 행위를 포함하며, 단순한 복종이나 묵인에 관련된 더 단순한 태도들과 행위도 포함한다.

따라서 법을 가진 사회는, 그 규칙들을 단지 불복종하면 공무담당자들의 손

에서 자신들에게 닥칠 일을 알려 주는 신뢰할 만한 예측들로만 보지 않고, 내부 관점에서 수용된 행위 기준들로 보는 사람들을 포함한다. 그러나 그것은 또한, 악행자들이거나 그 체계의 무력한 희생자들일 뿐이기 때문에 이러한 법적 기준들이 힘이나 힘의 위협에 의해 부과되어야 하는 사람들도 포함한다. 그들에게 규칙들은 가능한 처벌의 원천일 뿐이다. 이 두 구성요소 사이의 균형은 (p. 202) 많은 서로 다른 요인들에 의해 결정될 것이다. 그 체계가 공정하고, 그것이 복종을 요구하는 모든 사람들의 중대한 이익들을 진정으로 돌본다면, 그것은 대부분의 시간 동안 대부분의 사람들의 충성을 얻고 유지할 수 있으며 따라서 안정적일 것이다. 다른 한편, 그것은 지배 집단의 이익 속에서 운영되는 좁고 배타적인 체계일 수 있으며, 잠재적 격변의 위협과 함께 계속 더 억압적이고 불안정하게 만들어질 수 있다. 이 두 극단 사이에서 법에 대한 이러한 태도들의 다양한 결합들이 발견되며, 흔히 같은 개인 안에서도 그러하다.

이 사물들의 측면에 대한 성찰은 냉정한 진실 하나를 드러낸다. 의무의 일차 규칙들(primary rules of obligation)이 사회 통제의 유일한 수단인 단순한 사회 형식에서, 중앙적으로 조직된 입법부, 법원들, 공무담당자들, 제재들을 가진 법의 세계로 나아가는 단계는 일정한 대가를 치르고 실질적 이득들을 가져온다. 그 이득들은 변화에 대한 적응성, 확실성, 효율성이며, 이것들은 막대하다. 그 대가는 중앙적으로 조직된 권력이, 그 지지 없이도 될 수 있는 다수의 억압에 사용될 위험이다. 이는 의무의 일차 규칙들의 더 단순한 체제에서는 가능하지 않았던 방식이다. 이 위험이 현실화되었고 다시 그럴 수 있기 때문에, 우리가 자연법의 최소한의 내용으로 제시한 것을 넘어 법이 도덕규범들에 반드시 부합해야 하는 어떤 추가적 방식이 있다는 주장(claim)은 매우 신중한 검토를 필요로 한다. 그러한 단언들(assertions) 가운데 다수는 법과 도덕규범들 사이의 연결이 어떤 의미에서 필연적이라고 주장되는지를 명료하게 만들지 못하거나, 검토해보면 참이고 중요한 어떤 것을 의미하지만 그것을 법과 도덕규범들 사이의 필연적 연결로 제시하는 것은 대단히 혼란스럽다는 점이 드러난다. 우리는 이 주장의 여섯 형식을 검토하면서 이 장을 마칠 것이다.

(i) 권력과 권위 (Power and authority) 법체계는 인간에 대한 인간의 단순한

권력에 기초하지도 않고 기초할 수도 없으므로, 도덕적 의무의 감각이나 그 체계의 도덕적 가치에 대한 확신에 기초해야 한다고 자주 말해진다. 우리는 이 책의 앞선 장들에서, 위협으로 뒷받침된 명령들과 복종의 습관들은 법체계의 토대들과 법적 유효성이라는 관념을 이해하기에 부적절하다는 점을 스스로 강조했다. 이것들은 우리가 제VI장에서 길게 논변했듯이 그 해명을 위해 수용된 승인 규칙이라는 관념(notion)을 요구할 뿐 아니라, (p. 203) 이 장에서 보았듯이 강제 권력(coercive power)의 존재에 필요한 조건은 적어도 일부가 그 체계 안에서 자발적으로 협력하고 그 규칙들을 수용해야 한다는 점이다. 이런 의미에서는 법의 강제 권력이 그 수용된 권위를 전제한다는 말은 참이다. 그러나 ‘단지 권력에 기초한 법’과 ‘도덕적으로 구속적인 것으로 수용된 법’의 이분법은 망라적이지 않다. 많은 수의 사람들이 그들이 도덕적으로 구속적이라고 보지 않는 법들에 의해 강제될 수 있을 뿐 아니라, 그 체계를 자발적으로 수용하는 사람들조차 자신들이 그렇게 하도록 도덕적으로 구속되어 있다고 파악해야 하는 것도 아니다. 물론 그렇게 파악할 때 그 체계는 가장 안정적인 것이다. 사실 그들을 체계에 묶어 두는 것은 많은 서로 다른 고려들에 기초할 수 있다. 장기적 이익 계산, 타인들에 대한 사심 없는 관심, 반성 없는 상속되거나 전통적인 태도, 또는 단지 다른 사람들이 하는 대로 하려는 바람이 그것이다. 기실 그 체계의 권위를 수용하는 사람들이 자기 양심을 검토하고, 도덕적으로는 그것을 수용하지 말아야 한다고 결정하면서도 여러 이유로 계속 그것을 수용할 수 있다.

이러한 상식적 사항들(commonplaces)은 인간들이 인정하는 법적 의무와 도덕적 의무 양자를 표현하기 위해 동일한 어휘가 일반적으로 사용된다는 점 때문에 가려졌을 수 있다. 법체계의 권위를 수용하는 사람들은 그것을 내부 관점에서 바라보며, 그 요구들에 대한 자기 감각을 법과 도덕규범들 양자에 공통적인 규범적 언어로 표현된 내부 진술들로 나타낸다. “나는(너는) 해야 한다”, “나는(그는) 해야만 한다”, “나는(그들은) 의무를 가진다.” 그러나 그들은 그로써 법이 요구하는 일을 하는 것이 도덕적으로 옳다는 도덕적 판단을

받아들이게 되는 것은 아니다. 물론 더 말해지는 것이 없다면, 이런 방식으로 자기 또는 타인의 법적 의무들에 대해 말하는 사람은 누구든 그것들을 이행하는데 반대하는 도덕적 또는 다른 이유가 있다고 생각하지 않는다는 추정이 있다. 그러나 이것은 어떤 것이 도덕적으로 의무적인 것으로 수용되지 않는 한 법적으로 의무적인 것으로 인정될 수 없다는 점을 보여주지 않는다. 우리가 언급한 추정은, 화자가 그 이행에 반대하여 제기할 도덕적 또는 다른 확정적 이유들을 가지고 있다면, 법적 의무를 인정하거나 지적하는 일이 흔히 무의미할 것이라는 사실에 기초해 있다.

(ii) 도덕이 법에 미치는 영향 (The influence of morality on law) 모든 현대 국가의 법은 (p. 204) 수많은 지점에서 수용된 사회적 도덕과 더 넓은 도덕적 이상들 양자의 영향을 보여준다. 이러한 영향들은 입법을 통해 갑작스럽고 공공연하게 법 안으로 들어오거나, 사법 절차를 통해 조용하고 단편적으로 들어온다. 미국에서처럼 어떤 체계들에서는 법적 유효성의 궁극적 기준들이 정의의 원칙들이나 실체적 도덕 가치들(substantive moral values)을 명시적으로 편입한다. 영국에서처럼 최고 입법부의 권능에 형식적 제약들(restrictions)이 없는 다른 체계들에서도, 그 입법은 그럼에도 정의나 도덕에 마찬가지로 세심하게 부합할 수 있다. 법이 도덕을 비추는 추가 방식들은 무수하며, 아직 충분히 연구되지 않았다. 제정법들(statutes)은 단순한 법적 껍데기일 수 있고, 그 명시적 문언으로 도덕 원칙들의 도움을 받아 채워질 것을 요구할 수 있다. 집행 가능한 계약들의 범위는 도덕과 공정성의 구상들을 참조하여 제한될 수 있다. 민사 및 형사상 그른 행위들(wrongs) 양자에 대한 책임은 도덕적 책임에 관한 지배적 견해들에 맞추어 조정될 수 있다. 어떤 ‘실증주의자’도 이것들이 사실이라는 점이나, 법체계들의 안정성이 도덕규범들과의 그러한 대응 유형들에 부분적으로 의존한다는 점을 부정할 수 없다. 이것이 법과 도덕규범들의 필연적 연결이 의미하는 것이라면, 그 존재는 인정되어야 한다.

(iii) 해석 (Interpretation) 법들은 구체적 사례들에 적용하려면 해석을 필요로

한다. 그리고 사법 절차들의 성격을 흐리는 신화들이 현실주의적 연구에 의해 견히고 나면, 제VII장에서 보았듯 법의 개방적 직조가 어떤 이들이 입법적이라고 부르는 창조적 활동을 위한 광대한 장을 남긴다는 점은 명백하다. 제정법들이나 선례들을 해석할 때 판사들은 맹목적이고 자의적인 선택과, 사전에 확정된 의미를 가진 규칙들로부터의 ‘기계적’ 연역이라는 대안들에 갇혀 있지 않다. 매우 자주 그들의 선택은, 그들이 해석하는 규칙들의 목적이 합리적이라는 가정에 의해 이끌린다. 따라서 그 규칙들은 부정의를 낳거나 확립된 도덕 원칙들을 위반하도록 의도된 것이 아니다. 사법적 결정은, 특히 고도의 헌법적 중요성을 가진 사안들에서, 단순히 어떤 하나의 두드러진 도덕 원칙을 적용하는 것이 아니라 도덕 가치들 사이의 선택을 수반하는 경우가 많다. 법의 의미가 의문스러울 때 도덕이 언제나 제공할 명료한 답을 가지고 있다고 믿는 것은 어리석기 때문이다. 이 지점에서 판사들은 다시 자의적이지도 기계적이지도 않은 선택을 할 수 있고, 여기서 흔히 (p. 205) 특징적인 사법적 미덕들(judicial virtues)을 드러낸다. 법적 결정에 대한 이 미덕들의 특별한 적합성은 왜 어떤 이들이 그러한 사법 활동을 ‘입법적’ 이라고 부르기를 주저하는지를 설명한다. 이러한 미덕들은 대안들을 검토할 때의 불편부당성과 중립성, 영향을 받을 모든 사람들의 이익에 대한 고려, 그리고 어떤 수용 가능한 일반 원칙을 결정의 이유 있는 기초로 전개하려는 관심이다. 물론 그러한 원칙들의 복수성은 언제나 가능하기 때문에, 어떤 결정이 유일하게 옳바르다는 점이 논증적으로 입증될 수는 없다. 그러나 그것은 충분한 정보를 갖춘 불편부당한 선택의 이유 있는 산물(reasoned product)로 수용 가능하게 만들어질 수 있다. 이 모든 것 속에서 우리는 경쟁하는 이익들 사이에서 정의를 행하려는 노력의 특징인 ‘저울질’ 과 ‘균형 조정’ 을 본다.

결정들을 수용 가능하게 만드는 데서 ‘도덕적’ 이라고 부를 만한 이러한 요소들의 중요성을 부인할 사람은 거의 없을 것이다. 그리고 대부분의 체계들에서 해석을 지배하는 느슨하고 변화하는 전통 또는 해석 준칙들도 흔히 그것들을

희미하게 편입한다. 그러나 이러한 사실들이 법과 도덕규범들의 필연적 연결의 증거로 제출된다면, 우리는 같은 원칙들이 준수에서만이나 위반에서도 거의 그만큼 존중되어 왔다는 점을 기억해야 한다. 오스틴(Austin)부터 오늘날까지, 그러한 요소들이 결정을 이끌어야 한다는 상기는 대체로 사법적 법창출이 사회적 가치들에 눈멀거나, ‘자동적’ 이거나, 충분히 이유 제시되지 못했다고 본 비판자들에게서 나왔다.

(iv) 법에 대한 비판(The criticism of law) 때로 법과 도덕 사이에 필연적 연결이 있다는 주장(claim)은, 좋은 법체계는 앞 단락에서 이미 언급한 것과 같은 일정한 지점들에서 정의와 도덕의 요구들에 부합해야 한다는 단언(assertion) 이상의 것이 아닐 수 있다. 어떤 이들은 이것을 명백한 자명한 이치로 볼 수도 있다. 그러나 그것은 동어반복은 아니며, 실제로 법에 대한 비판에서는 적절한 도덕 기준들과 요구되는 부합의 지점들 양자에 관해 의견불일치가 있을 수 있다. 법이 좋으려면 부합해야 하는 그 도덕은, 설령 그것이 미신에 기초해 있거나 노예들 또는 종속 계급들로부터 그 혜택들과 보호를 거두어 간다 하더라도, 그 법이 속한 집단의 수용된 도덕을 의미하는가? 아니면 도덕은 사실의 문제들에 관한 합리적 믿음들에 기초해 있고 모든 인간 존재들을 동등한 고려와 존중을 받을 자격이 있는 것으로 수용한다는 의미에서 계몽된 기준들을 의미하는가?

(p. 206) 법체계가 자기 범위 안의 모든 인간 존재들을 일정한 기본적 보호들과 자유들에 대한 자격이 있는 것으로 취급해야 한다는 논지(contention)는, 이제 법에 대한 비판에서 명백한 관련성을 가지는 하나의 이상(ideal)에 대한 진술로 일반적으로 수용되고 있음은 의심할 여지가 없다. 실천이 그것에서 벗어나는 곳에서도 보통 이 이상에 대한 말뿐인 경의가 나온다. 모든 인간의 동등한 고려에 대한 권리라는 이 견해를 취하지 않는 도덕은 어떤 내적 모순, 독단주의, 또는 비합리성에 말려든다는 점이 철학에 의해 보여질 수 있을지도 모른다. 그렇다면 이러한 권리들을 인정하는 계몽된 도덕은 진정한 도덕으로서 특별한 신임 근거(credentials)를 가지며, 많은 가능한 도덕들 가운데 단지 하나가 아니다. 이것들은 여기서 검토될 수 없는 주장들(claims)이다. 그러나 설령

그것들이 인정되더라도, 그것들은 일차 규칙들과 이차 규칙들의 특징적 구조를 가진 국내 법체계들이 이러한 정의의 원칙들을 공공연히 무시하면서도 오래 존속해 왔다는 사실을 바꾸거나 흐려서는 안 된다. 혹 있다면, 사악한 규칙들이 법임을 부정함으로써 무엇을 얻을 수 있는지는 아래에서 검토한다.

(v) 법다움과 정의의 원칙들 (Principles of legality and justice) 일정한 지점들에서 도덕과 정의에 부합하는 좋은 법체계와 그렇지 않은 법체계 사이의 구별은 오류적이라고 말해질 수 있다. 인간 행위가 공적으로 공표되고 사법적으로 적용되는 일반 규칙들에 의해 통제될 때마다 정의의 최소한이 필연적으로 실현되기 때문이라는 것이다. 기실 우리는 정의라는 관념을 분석하면서 이미 지적했듯이,² 그 가장 단순한 형식(법의 적용에서의 정의)은 여러 서로 다른 사람들에게 적용될 것이, 편견, 이익, 또는 변덕에 의해 휘지 않은 동일한 일반 규칙이라는 관념(notion)을 진지하게 받아들이는 것 이상으로 이루어지지 않는다. 이러한 불편부당성(impartiality)이 영국과 미국 법률가들에게 ‘자연적 정의(Natural Justice)’의 원칙들로 알려진 절차적 기준들이 확보하도록 설계된 것이다. 따라서 가장 혐오스러운 법들도 정의롭게 적용될 수 있지만, 우리는 일반 법규칙을 적용한다는 기본 관념(bare notion) 안에서 적어도 정의의 싹을 가진다.

이 최소 정의 형식의 추가 양상들, 곧 충분히 ‘자연적’이라고 불릴 수도 있는 양상들은, 게임 규칙들이든 법이든 어떤 사회 통제 방법 안에 실제로 (p. 207) 무엇이 수반되는지를 살펴보면 드러난다. 그 방법은 주로 사람들의 부류들에게 전달되는 일반적 행위 기준들로 이루어지고, 그런 다음 그 사람들이 추가 공무담당 지시 없이 그 규칙들을 이해하고 그 규칙들에 부합할 것으로 기대되는 방법이다. 이런 종류의 사회 통제가 기능하려면 규칙들은 일정한 조건들을 충족해야 한다. 그것들은 이해 가능해야 하고, 대부분이 복종할 능력 범위 안에 있어야 하며, 일반적으로 소급적이어서는 안 된다. 물론 예외적으로는 그럴 수 있다. 이는 대부분의 경우 결국 규칙 위반으로 처벌받는 사람들이 복종할 능력과 기회를 가지고 있었을 것이라는 뜻이다. 명백히 규칙에 의한 통제의 이러한

²p. 160 above.

특징들은 법률가들이 법다움의 원칙들이라고 부르는 정의의 요구들과 긴밀히 관련된다. 기실 어떤 실증주의 비판자는 규칙에 의한 통제의 이러한 양상들 속에서 법과 도덕 사이의 필연적 연결에 해당하는 어떤 것을 보았고, 그것들을 ‘법의 내적 도덕(the inner morality of law)’ 이라고 부르자고 제안했다. 또, 이것이 법과 도덕의 필연적 연결이 의미하는 것이라면, 우리는 그것을 수용할 수 있다. 유감스럽게도 그것은 매우 큰 사악함과 양립 가능하다.

(vi) 법적 유효성과 법에 대한 저항 (Legal validity and resistance to law) 실증주의자로 분류되는 법이론가들이 자기 일반 전망을 아무리 부주의하게 정식화했더라도, 앞의 다섯 표제 아래 논의된 법과 도덕규범들 사이의 연결 형식들을 부정하는 데 관심을 둔 사람은 거의 없었을 것이다. 그렇다면 법실증주의의 큰 전투 구호들은 무엇에 관심을 두었는가? “법의 존재는 한 가지이고, 그 공과(merit or demerit)는 다른 것이다.”³ “국가의 법은 이상이 아니라 실제로 존재하는 어떤 것이다 … 그것은 있어야 할 것이 아니라 있는 것이다.”⁴ “법규범들은 어떤 종류의 내용도 가질 수 있다.”⁵

이 사상가들이 대체로 증진하고자 한 것은, 도덕적으로 사악하지만 적절한 형식으로 제정되었고, 의미가 명료하며, 한 체계의 인정된 모든 유효성 기준들을 충족한 특정 법들의 존재가 제기하는 이론적·도덕적 쟁점들을 정식화할 때의 명료성과 정직성이었다. 그들의 견해는, 그러한 법들을 생각할 때 이론가와, 그것들을 (p. 208) 적용하거나 그것들에 복종하도록 요구받은 불운한 공무원이나 또는 사인(private citizen) 모두에게, 그것들에 ‘법’ 또는 ‘유효한 것’ 이라는 명칭을 거부하라는 권유는 혼란만 줄 수 있다는 것이었다. 그들은 이러한 문제들에 직면하기 위해 더 단순하고 더 솔직한 수단들이 이용 가능하며, 그것들이 관련된 모든 지적·도덕적 고려를 훨씬 더 잘 초점에 놓을 것이라고 생각했다. 우리는 “이것은 법이다. 그러나 적용하거나 복종하기에는 너무 사악하다” 라고 말해야 한다.

³ Austin, *The Province of Jurisprudence Defined*, Lecture V, pp. 184–5.

⁴ Gray, *The Nature and Sources of the Law*, s. 213.

⁵ Kelsen, *General Theory of Law and State*, p. 113.

그 반대 견해는 혁명이나 큰 격변 뒤에 어떤 체계의 법원들이 이전 체계 아래에서 사인들이나 공무담당자들이 법적 형식으로 저지른 도덕적 사악함들에 대한 자기 태도를 고려해야 할 때 매력적으로 보이는 견해이다. 그들의 처벌은 사회적으로 바람직하다고 느껴질 수 있다. 그러나 그것을 확보하기 위해, 이전 체계의 법이 허용했거나 심지어 요구했던 것을 범죄로 만드는 노골적인 소급 입법에 의존하는 것은 어려울 수 있고, 그 자체가 도덕적으로 혐오스러울 수 있으며, 어쩌면 가능하지 않을 수도 있다. 이러한 상황에서는 법의 어휘 속에 잠재한 도덕적 함의들, 특히 자연법 이론이 실려 있는 *ius, recht, diritto, droit* 같은 단어들을 이용하는 것이 자연스러워 보일 수 있다. 그때 사악함을 명하거나 허용한 제정물들(enactments)은, 그것들이 제정된 체계가 자기 입법부의 입법 권능에 대한 어떤 제약(restriction)도 인정하지 않았다 하더라도, 유효한 것으로 인정되거나 법의 성질을 가진 것으로 인정되어서는 안 된다고 말하고 싶은 유혹이 생길 수 있다. 나치 지배와 그 패배의 사악함들이 남긴 심각한 사회 문제들에 대응하여, 지난 전쟁 뒤 독일에서 자연법 논증들이 부활한 것은 바로 이러한 형식에서였다. 이기적 목적을 위해 나치 체제 동안 통과된 괴물 같은 제정법들에 대한 위반행위들(offences) 때문에 타인들의 투옥을 초래한 밀고자들은 처벌되어야 하는가? 그러한 제정법들이 자연법을 위반했고 따라서 무효(void)여서, 그 제정법들을 위반했다는 이유로 피해자들이 투옥된 것은 사실상 불법이었고 이를 초래한 일 자체가 위반행위(offence)였다는 근거 위에서, 전후 독일의 법원들이 그들에게 유죄를 선고할 수 있었는가?⁶ 도덕적으로 사악한 규칙들은 법일 수 없다는 견해를 (p. 209) 수용하려는 사람들과 거부하려는 사람들 사이의 쟁점은 간단해 보이지만, 논쟁자들은 그 일반적 성격에 관해 자주 매우 불명료해 보인다. 우리가 여기서 다루는 것은 도덕적으로 사악한 규칙들을 적용하지 않고, 복종하지 않고, 타인들이 자기 방어에서 원용하도록 허용하지 않겠다는 도덕적 결정을 정식화하는 대안적 방식들이다. 그러나 이 쟁점은 언어적 쟁점으로 제시되면 잘못 제시된다. 논쟁의 어느 쪽도 “그렇습니다. 당신

⁶1949년 7월 27일 Oberlandesgericht Bamberg 판결, 5 *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 207 참조. 이 판결은 H. L. A. Hart, 「Legal Positivism and the Separation of Law and Morals」, 71 *Harvard L. Rev.* (1958), 598 및 L. Fuller, 「Positivism and Fidelity to Law」, 같은 곳, 630쪽에서 상세히 논의된다. 다만 아래 303-4쪽의 정정된 설명을 유의하라.

말이 맞습니다. 영어(또는 독일어)로 그런 종류의 논점을 표현하는 올바른 방식은 당신이 말한 대로 말하는 것입니다” 라는 말을 듣고 만족하지 않을 것이다. 따라서 실증주의자는, 법규칙이 복잡하기에 너무 사악하다고 단언하는 데 아무 모순이 없으며, 어떤 규칙이 복잡하기에 너무 사악하다는 명제로부터 그것이 유효한 법규칙이 아니라는 결론은 따라 나오지 않는다는 점을 보여주는 영어 용례의 무게를 지적할 수 있다. 그러나 그 반대자들은 이것이 사안을 정리한다고 여기지는 않을 것이다.

명백히 우리는 이 쟁점을 언어 사용의 적절성들에 관한 것으로 본다면 적절하게 다룰 수 없다. 실제로 걸려 있는 것은 사회생활에서 일반적으로 실효적인 규칙 체계에 속한 규칙들을 분류하는 더 넓은 개념 또는 방식과 더 좁은 개념 또는 방식의 비교상 이점(merit)이다. 우리가 이 개념들 사이에서 이유 있는 선택을 해야 한다면, 그것은 어느 하나가 우리의 이론적 탐구들을 보조하거나 우리의 도덕적 숙고들을 진전시키고 명료화하는 방식에서, 또는 양자 모두에서, 다른 하나보다 우월하기 때문이어야 한다.

이 두 경쟁하는 법 개념 가운데 더 넓은 개념은 더 좁은 개념을 포함한다. 더 넓은 개념을 채택하면, 이는 이론적 탐구에서 우리가 일차 규칙들과 이차 규칙들의 체계가 가진 형식적 검사 기준들에 의해 유효한 모든 규칙들을, 비록 그 일부가 한 사회 자신의 도덕이나 우리가 계몽된 또는 참된 도덕이라고 여길 수 있는 것에 위반된다 하더라도, ‘법’ 으로 묶어 함께 고찰하게 이끌 것이다. 더 좁은 개념을 채택하면 우리는 그러한 도덕에 거슬리는 규칙들을 ‘법’ 에서 배제할 것이다. 법을 사회 현상으로 이론적 또는 과학적으로 연구할 때 더 좁은 개념을 채택함으로써 얻는 것은 아무것도 없어 보인다. 그것은 어떤 규칙들이 법의 다른 모든 복잡한 특징들을 드러내더라도 그 규칙들을 배제하게 할 것이기 때문이다. 그러한 규칙들에 대한 연구를 다른 분과에 맡기자는 제안에서는 분명 혼란 말고는 아무것도 따라 나올 수 없으며, 어떤 역사학이나 다른 법 연구 형식도 그렇게 하는 것을 유익하다고 본 적은 확실히 없다. 더 넓은 법 개념을 채택하면, (p. 210) 우리는 도덕적으로 사악한 법들이 가진 어떤 특수한 특징들과 그것들에 대한 사회의 반응도 그 안에 수용하여 연구할 수 있다. 따라서 여기서 더 좁은 개념의 사용은 일차 규칙들과 이차 규칙들의 체계에서 보이는

사회 통제의 특수한 방법의 발전과 잠재력들을 모두 이해하려는 우리의 노력을 혼란스럽게 꼬갤 수밖에 없다. 그것의 사용에 대한 연구는 그것의 남용에 대한 연구를 포함한다.

그렇다면 도덕적 숙고에서 더 좁은 법 개념의 실천적 이점들은 무엇인가? 도덕적으로 사악한 요구들에 직면했을 때 “이것은 어떤 의미에서도 법이 아니다”라고 생각하는 것이 “이것은 법이지만 복종하거나 적용하기에는 너무 사악하다”라고 생각하는 것보다 어떤 방식으로 더 나은가? 이것이 사람들을 더 명석하게 하거나, 도덕이 요구할 때 더 기꺼이 불복종하게 할 것인가? 나치 체제가 남긴 문제들과 같은 문제들을 처리하는 더 나은 방식들로 이끌 것인가? 관념들이 영향력을 가진다는 점은 의심할 여지가 없다. 그러나 유효하지만 도덕적으로 사악한 법들을 위한 자리가 없는 더 좁은 법적 유효성 개념의 사용을 사람들에게 훈련하고 교육하려는 노력이, 조직화된 권력의 위협들 앞에서 악에 대한 저항을 굳건하게 만들거나, 복종이 요구될 때 도덕적으로 걸려 있는 것이 무엇인지 더 명료하게 깨닫게 할 것 같지는 않다. 인간 존재들이 일부로부터 충분한 협력을 얻어 타인들을 지배할 수 있는 한, 그들은 법의 형식들을 자기 도구들 가운데 하나로 사용할 것이다. 사악한 사람들은 사악한 규칙들을 제정할 것이고 다른 사람들은 그것들을 집행할 것이다. 공적 권력 남용에 맞서 사람들을 명석하게 만들기 위해 가장 필요한 것은, 어떤 것이 법적으로 유효한 것으로 인정되었다는 점이 복종의 문제에 확정적이지 않으며, 공식 체계가 아무리 큰 위엄이나 권위의 후광을 가진다 하더라도 그 요구들은 결국 도덕적 심사에 제출되어야 한다는 감각을 보존하는 것이다. 공식 체계 바깥에 어떤 것이 있고, 최종적으로 개인은 그것을 참조하여 자기 복종의 문제들을 해결해야 한다는 이 감각은, 법규칙들이 사악할 수 있다고 생각하는 데 익숙한 사람들 사이에서, 사악한 것은 어디서도 법의 지위를 가질 수 없다고 생각하는 사람들 사이에서보다 더 살아 있게 유지될 가능성이 분명히 크다.

그러나 “이것은 법이지만 사악하다”라고 생각하고 말할 수 있게 하는 더 넓은 법 개념을 선호할 더 강한 이유는, 사악한 규칙들에 법적 인정을 부여하지 않는 것이 그것들이 낳는 도덕적 쟁점들의 다양상(variety)을 심하게 과도 단순화할 수 있다는 점이다. 벤담과 오스틴처럼 법이 무엇인가와 법이 무엇이어야

하는가의 구별을 고집한 옛 저자들이 그렇게 한 것은, 부분적으로 사람들이 이것들을 구별해 두지 않으면 사회가 치를 비용을 계산하지 않은 채 법들이 유효하지 않고 복종되어서는 안 된다는 성급한 판단을 내릴 수 있다고 생각했기 때문이다. 그러나 그들이 꽤 과대평가했을지도 모르는 이러한 무정부의 위험 말고도 다른 형태의 과도 단순화가 있다. 우리가 관점을 좁혀 악한 규칙들에 복종하도록 요구받는 사람만을 생각한다면, 그가 그것의 도덕적 사악함을 보고 도덕이 요구하는 일을 하는 한, 그가 자기가 유효한 ‘법’ 규칙에 직면했다고 생각하는지 여부는 중요하지 않다고 볼 수 있다. 그러나 복종의 도덕적 질문(나는 이 악한 일을 해야 하는가?) 말고도 소크라테스의 처벌 수용(submission)의 질문, 곧 나는 불복종에 대한 처벌을 받아들여야 하는가 아니면 도망쳐야 하는가라는 질문이 있다. 전후 독일 법원들이 직면했던 질문, 곧 “당시 효력을 가진 악한 규칙들에 의해 허용되었을 때 악한 일을 한 사람들을 우리가 처벌해야 하는가?”라는 질문도 있다. 이러한 질문들은 매우 서로 다른 도덕과 정의의 문제들을 제기하며, 우리는 그것들을 서로 독립적으로 고려해야 한다. 그것들은 악한 법들을 어떤 목적에서도 유효한 것으로 인정하기를 일거에 거부함으로써 해결될 수 없다. 이것은 섬세하고 복잡한 도덕적 쟁점들을 다루는 너무 거친 방식이다.

법의 유효하지 않음(invalidity)을 그 부도덕성과 구별할 수 있게 하는 법 개념은 우리가 이 별개의 쟁점들의 복잡성과 다양성을 볼 수 있게 한다. 반면 사악한 규칙들에 법적 유효성을 부정하는 좁은 법 개념은 우리를 그것들에 눈멀게 할 수 있다. 이기적 목적을 위해 괴물 같은 법들 아래서 타인들의 처벌을 초래한 독일 밀고자들이 도덕이 금지한 일을 했다는 점은 인정될 수 있다. 그러나 도덕은 또한 국가가, 악을 행하면서도 당시 국가가 금지한 일을 한 사람들만 처벌해야 한다고 요구할 수도 있다. 이것이 *nulla poena sine lege*의 원칙이다. 이 원칙의 희생보다 더 큰 악이라고 여겨지는 어떤 것을 피하기 위해 이 원칙에 침해가 가해져야 한다면, 걸려 있는 쟁점들이 명료하게 식별되는 것이 사활적으로 중요하다. 소급 처벌의 사례가 그 당시 불법이었던 행위에 대한 (p. 212) 통상적 처벌 사례처럼 보이게 만들어서는 안 된다. 적어도 도덕적으로 사악한 규칙들이 여전히 법일 수 있다는 단순한 실증주의 교설에 대해서는, 극단적

상황에서 이루어져야 할 수도 있는 악들 사이의 선택을 위장하지 않는다는 점을 주장할 수 있다.

제9장 주석

185쪽. 자연법(Natural Law). 고전적·스콜라철학적·근대적 자연법 구상들과 ‘실증주의(positivism)’라는 표현의 다의성에 대한 방대한 주석 문헌이 존재하는 탓에, 자연법(Natural Law)이 법실증주의(Legal Positivism)와 대립할 때 정확히 어떤 쟁점이 걸려 있는지를 파악하기 어려울 때가 많다. 본문에서는 그 중 하나의 쟁점을 식별하려는 시도를 한다. 그러나 이 주제를 논의함에 있어 이차 문헌만을 읽는다면 얻을 수 있는 것은 극히 제한적이다. 자연법의 일차 문헌들에 나타난 어휘와 철학적 전제들을 직접적으로 이해하는 것이 필수적이다. 다음은 쉽게 접근 가능한 최소한의 자료들이다: 아리스토텔레스(Aristotle), 『자연학(Physics)』 제2권 제8장 (Ross 역, Oxford); 아퀴나스(Aquinas), 『신학대전(Summa Theologica)』 제1-2부, 문제 90-97 (D’Entrèves, 『아퀴나스: 선별된 정치적 저작』(Aquinas: Selected Political Writings), Oxford, 1948에 번역 수록); 그로티우스(Grotius), 『전쟁과 평화의 법(On the Law of War and Peace)』, 서론(Prolegomena) (The Classics of International Law, 제3권, Oxford, 1925 수록 번역본); 블랙스톤(Blackstone), 『주석(Commentaries)』, 서론 제2절.

185쪽. 법실증주의(Legal Positivism). 현대 영미권 문헌에서 ‘실증주의(positivism)’라는 표현은 다음과 같은 하나 혹은 그 이상의 논지를 지칭하는 데 사용된다: (1) 법들(laws)은 인간의 명령들(commands)이다; (2) 법과 도덕규범들, 또는 존재하는 법(law as it is)과 마땅히 그래야 할 법(law as it ought to be) 사이에는 필연적 연결이 없다; (3) 법 개념들의 의미를 분석하거나 연구하는 것은 역사적 탐구, 사회학적 탐구, 도덕규범들·사회적 목적·기능에 따른 비판적 평가와는 구별되는 (그러나 적대적인 것이 아닌) 중요한 연구 분야이다; (4) 법체계는 ‘폐쇄된 논리 체계(closed logical system)’이며, 올바른 결정들(correct decisions)은 오직 미리 정해진 법규로부터 논리적 방법만으로도 출될 수 있다; (5) 도덕판단은 사실 진술들(statements of fact)처럼 합리적 논변, 증거, 또는 입증을 통해 정립될 수 없다(윤리적 비인지주의, non-cognitivism in ethics). 벤담(Bentham)과 오스틴(Austin)은 (1), (2), (3)의 견해를 지지했으나 (4), (5)는 지지하지 않았다. 켈젠(Kelsen)은 (2), (3), (5)를 수용했으나 (1), (4)는 수용하지 않았다. 논지 (4)는 흔히 ‘분석법리학자들(analytical jurists)’에게 귀속되곤 하지만, 이는 타당한 근거 없이 이루어진 것이다. 대륙 유럽 문헌에서는 ‘실증주의(positivism)’라는 표현이 흔히 이성에 의해서만 발견 가능한 인간 행위의 어떤 원칙이나 규칙의 존재라는 주장에 대한 전면적 거부를 지칭하는 데 사용된다. ‘실증주의’ 개념의 다의성에 대한 아고(Ago)의 유익한 논의는 *American Journal of International Law* 제51권(1957) 참조.

186쪽. 밀(Mill)의 자연법 비판. 『자연(Nature), 종교의 효용성, 유신론』에 수록된 “자연(Nature)” 에세이 참조.

187쪽. 블랙스톤과 벤담의 자연법에 대한 견해. 블랙스톤, 위 인용(loc. cit.); 벤담, 『주석에 대한 논평(Comment on the Commentaries)』 제1-6절.

193쪽. 자연법의 최소한의 내용. 자연법의 이 경험주의적 버전은 홉스(Hobbes), 『리바이어던(Leviathan)』 제14·15장과 흄(Hume), 『인성론(Treatise of Human Nature)』 제3권 제2부, 특히 제2절 및 제4-7절에 근거한다.

200쪽. 『허클베리 핀(Huckleberry Finn)』. 마크 트웨인(Mark Twain)의 이 소설은 사회적 도덕이 개인의 공감(sympathy)이나 인도주의(humanitarianism)에 반할 경우 발생하는 도덕적 딜레마에 대한 심오한 탐구다. 모든 도덕을 인도주의와 동일시하는 경향에 대한 귀중한 교정이 된다.

200쪽. 노예제(Slavery). 아리스토텔레스에게 있어 노예는 ‘살아있는 도구’였다. (정치학(Politics) 제1권 제2-4장).

203쪽. 도덕이 법에 미치는 영향. 법의 발전(development)이 도덕에 의해 어떻게 영향을 받아왔는지를 다룬 유익한 연구들로는 에임스(Ames), “법과 도덕규범들(Law and Morals)”, *Harvard Law Review* 제22권(1908); 파운드(Pound), 『법과 도덕규범들(Law and Morals)』(1926); 굿하트(Goodhart), 『영국법과 도덕법(English Law and the Moral Law)』(1953) 등이 있다. 오스틴은 이와 같은 사실적 혹은 인과적 연관을 충분히 인식하고 있었다. 『법의 영역(The Province of Jurisprudence Determined)』 제5강, 162쪽 참조.

204쪽. 해석(Interpretation). 법 해석에서 도덕적 고려가 차지하는 위치에 대해서는 라몽(Lamont), 『가치판단(The Value Judgment)』 296-301쪽; 웨슬러(Wechsler), “헌법 해석의 중립 원칙을 향하여”, *Harvard Law Review* 제73권, 960쪽; 하트(Hart), 앞서 인용한 *HLR* 제71권, 606-615쪽 및 풀러(Fuller)의 비판, 동일호 661쪽 끝 부분(ad fin.) 참조. 오스틴의 ‘경쟁하는 유추(competing analogies)’ 사이에서 사법적 선택을 위해 열려 있는 영역을 인정한 부분과, 판사들이 자기 결정들(decisions)을 공리성의 기준에 맞추지 못했다는 비판은 『강의(The Lectures)』 제37·38강 참조.

205쪽. 법에 대한 비판과 모든 인간의 평등한 고려에 대한 권리. 이러한 권리가 단지 가능한 여러 도덕들 가운데 하나에 속하는 것이 아니라 진정한 도덕의 규정적 특징(defining feature)이라는 견해는 벤(Benn)과 피터스(Peters), 『사회 원칙과 민주국가

(Social Principles and the Democratic State)』 제2·5장, 그리고 바이어(Baier), 『도덕적 관점(The Moral Point of View)』 제8장을 참조.

206쪽. 법다움과 정의의 원칙(Principles of legality and justice). 법다움 원칙에 대해서는 홀(Hall), 『형법의 원칙(Principles of Criminal Law)』 제1장을, ‘법의 내적 도덕(the internal morality of law)’ 에 대해서는 풀러(Fuller), *Harvard Law Review* 제71권(1958), 644-648쪽 참조.

208쪽. 전후 독일에서의 자연법 이론의 부활. G. 라드브루흐(Radbruch)의 후기 견해, 하트(Hart), 그리고 이에 대한 풀러(Fuller)의 응답에 대한 논의는 모두 *HLR* 제71권(1958) 참조. 이 논의는 1949년 7월 바이에른주 고등법원(Oberlandsgericht Bamberg)의 판결을 중심으로 진행되었는데, 이 사건은 1934년 나치 법률 위반 혐의로 남편을 신고한 아내가 남편의 자유를 불법적으로(unlawfully) 박탈한 혐의로 유죄 판결을 받은 사건이다. 이 사건에 대한 설명은 *HLR* 제64권(1951) 1005쪽에 기술된 것으로, 해당 독일 법원이 1934년 법률을 유효하지 않은 것(invalid)으로 보았다는 전제에 따라 이루어진다. 그러나 이 설명의 정확성은 파페(Pappe)의 비판(“나치 시대의 사법판단의 유효성에 대하여”, *Modern Law Review* 제23권(1960))에 의해 최근에 도전받았다. 파페 박사의 비판은 근거가 있으며, 하트가 논한 사례는 엄밀히 말하면 가상의 것으로 간주되어야 한다. 파페 박사에 따르면(위 저서, 263쪽), 실제 사건에서 법원(Provincial Court of Appeal)은 법률이 자연법(Natural Law)을 위반한 경우 불법이 될(be unlawful) 수 있다는 이론적 가능성을 받아들이면서도, 쟁점이 된 나치 법률이 이를 위반했다고 보지는 않았다. 피고는 정보를 제공할 책무(duty)가 없음에도, 순전히 사적 동기에서 그렇게 했으며, 그러한 행위가 그 상황에서 ‘모든 품위 있는 인간들의 건전한 양심과 정의감에 반하는’ 짓임을 인식했음이 분명하다는 이유로 자유의 불법적 박탈(unlawful deprivation of liberty) 혐의로 유죄 판결을 받았다. 파페 박사가 유사 사건에 대한 독일 연방대법원의 판결을 세밀하게 분석한 내용(268쪽 끝 부분)도 반드시 참고할 필요가 있다.

제9장 제3판 주석

185-6쪽. 실증주의(Positivism)와 ‘분리가능성 테제(separability thesis)’. 하트는 “법들이 도덕의 특정 요구를 재현하거나 충족시키는 것이 필연적 진리인 것은 결코 아니다” 라고 말한다. (호즈 강연에서는 “법과 도덕규범들 사이에는 필연적 연결이 없다” 고 말한다: H. L. A. Hart, “Positivism and the Separation of Law and Morals”

(1957) *Harvard Law Review* 제71권 593쪽, 601쪽 주석 25 참조.) 이 분리가능성 테제(separability thesis)에는 난점이 있는데, 그 이유 중 하나는 하트 자신이 규칙들과 정의 사이의 연결(159-60쪽 주석 참조)과 최소한의 내용 테제(minimum content thesis)(193쪽 주석 참조)를 통해 두 가지 ‘필연적 연결’을 옹호하는 것처럼 보이기 때문이다. 이 난제를 정리하려는 다양한 시도로는 다음이 있다: John Gardner, 「Legal Positivism: 5½ Myths」, *Law as a Leap of Faith* 제2장; Matthew H. Kramer, 「On The Separability of Law and Morality」 (2004) *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 제17권 315쪽; James Morauta, 「Three Separation Theses」 (2004) *Law and Philosophy* 제23권 111쪽; Leslie Green, 「Positivism and the Inseparability of Law and Morals」 (2008) *New York University Law Review* 제83권 1035쪽.

185-93쪽. 고전적 자연법 이론(Classical theories of natural law). 하트가 묘사한 견해의 후손 격이나 신-토미즘적(신-아퀴나스주의적)(neothomist) 성향이 가미된 입장으로는 John Finnis의 『Natural Law and Natural Rights』, Mark C. Murphy의 『Natural Law in Jurisprudence and Politics』 (Cambridge University Press, 2006)이 있다. Nigel Simmonds의 『Law as a Moral Idea』 (Oxford University Press, 2007)와 비교할 것. 자연법과 실증주의의 관계들(relationships)에 대해서는 John Finnis, 「The Truth in Legal Positivism」, 『Philosophy of Law』 제7장 참조. 자연법적 도덕 이론, 법 해석 이론, 자연법 법리학 이론 간의 관계의 결여에 대해서는 Philip Soper, 「Some Confusions about Natural Law」 (1992) *Michigan Law Review* 제90권 2393쪽.

193-200쪽. ‘최소한의 내용’ 명제(The ‘minimum content’ thesis). 인간의 본성과 우리가 살아가는 세계를 고려할 때, 보편적으로 가치 있는 것들에 관한 최소한의 내용(minimum content)을 다루지 않는 규칙 체계는 어떤 경우에도 법체계(legal system)가 될 수 없다. 하트의 목록을 수정한 사례로는 Neil MacCormick, 『H. L. A. Hart』 92-99쪽, John Finnis, 『Natural Law and Natural Rights』 제4장 참조. 법의 필수적 내용에 대한 다른 접근은 Joseph Raz, 『Practical Reason and Norms』 162-170쪽 참조.

203쪽. 법과 도덕의 공유 어휘(The shared vocabulary of law and morality). ‘의무(obligation)’, ‘권리(right)’, ‘자유(liberty)’ 등의 용어들이 법과 도덕에서 공통적으로 사용되는 이유에 대한 다른 설명은 Joseph Raz, 『The Authority of Law』 제8장 참조. 이에 대한 하트의 응답은 『Essays on Bentham』 153-161쪽에 실려 있다.

203-4쪽. 도덕의 법 안으로의 편입(The incorporation of morality in law). 이 부분, 그리고 더 강조되는 후기(Postscript)에서 하트는 다음과 같이 말한다: “일부 법체

계에서는 … 법적 유효성(legal validity)의 궁극적 기준들(ultimate criteria)이 정의 원칙이나 실체적 도덕 가치들(substantive moral values)을 명시적으로 편입하고 있다.” 하트는 이를 ‘연성 실증주의(soft positivism)’라 부르지만, 현재는 일반적으로 ‘편입 명제(incorporation thesis)’ 또는 ‘포괄적 법실증주의(inclusive legal positivism)’라 불린다. 관련 문헌은 기술적으로 복잡할 수 있다. 훌륭한 개관으로는 K. E. Himma, 「Inclusive Legal Positivism」, Jules Coleman & Scott Shapiro 편, 『The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law』 수록. 하트의 입장에 대한 비판은 Joseph Raz, 『The Authority of Law』 제3장, 『Between Authority and Interpretation』 제7장 참조. 포괄적 실증주의를 발전시킨 논의로는 다음이 있다: Jules Coleman, 「Negative and Positive Positivism」 (1982) *Journal of Legal Studies* 제11권 139쪽; 『The Practice of Principle: In Defence of a Pragmatist Approach to Legal Theory』 (Oxford University Press, 2001) 제8장; W. J. Waluchow, 『Inclusive Legal Positivism』 (Oxford University Press, 1994). 드워킨(Dworkin)은 하트의 접근(Philip Soper와 David Lyons가 채택한 방식)을 『Taking Rights Seriously』 345-350쪽에서 비판하며, Coleman의 입장은 「Thirty Years On」 (2002) *Harvard Law Review* 제115권 1655쪽에서 비판한다.

206-7쪽. 법다움과 정의의 원칙(Principles of legality and justice). 론 풀러(Lon L. Fuller)의 논의가 영향력 있다: 『법의 도덕성(The Morality of Law)』 (개정판, Yale University Press, 1969) 46-91쪽; 하트의 서평 「Lon L. Fuller, ‘The Morality of Law’」는 『Essays in Jurisprudence and Philosophy』 제16장에 수록. 하트와 풀러 간 논쟁의 중요성에 대해서는 Peter Cane 편, 『The Hart-Fuller Debate: 50 Years On』 (Hart Publishing, 2010) 수록 논문들 참조. 법의 지배(rule of law)와 법의 본성 사이의 관계에 대해서는 Raz, 『The Authority of Law』 제11장 참조. 드워킨은 「Hart’s Postscript and the Character of Political Philosophy」 (2004) *Oxford Journal of Legal Studies* 제24권 1, 23-37쪽에서 ‘법다움(legality)’이라는 가치에 기초하여 자신의 이론을 재구성한다.

207-12쪽. 법적 유효성과 법 저항(Legal validity and resistance to law). 정의를 확보하려는 최소한의 시도조차 하지 않는 법은 유효하지 않다(invalid)는 라드브루흐(Gustav Radbruch)의 논제를 현대적으로 계승한 사례로는 Robert Alexy, 『The Argument from Injustice: A Reply to Legal Positivism』 (Bonnie L. Paulson & Stanley L. Paulson 번역, Oxford University Press, 2002). 법이 우리의 복종(obedience)에 대해 제기하는 도덕적 청구(claims)에 대해서는 다음 문헌 참조: Joseph Raz, 『The Authority of Law』 제12-15장; A. J. Simmons, 『Moral Principles and Political Obligations』 (Princeton University Press, 1979); Leslie Green, 『The Authority of the State』; W. A. Edmundson, 『Three

Anarchical Fallacies: An Essay on Political Authority』(Cambridge University Press, 1998).

208-12쪽. ‘광의의 법 개념(broad concept of law)’을 옹호하기. 여러 저자들은 실증주의적 법 개념이 “도덕적 숙고(moral deliberation)를 촉진하고 명확하게 할 수 있다”는 하트의 주장(claim)을 발전시킨다(209쪽). 하트는 이 주장을 자신의 분석의 건전성(soundness)을 입증하기 위한 필수 요소로 보지는 않으며, 부차적 고려이거나, 광의의 법 개념이 정치적으로 위험하다고 비판하는 사람들에 대한 응답으로 간주한다. 문헌에서는 법 개념(the concept of law)이 도덕적으로 바람직한 결과를 위해 조정되어야 한다는 주장과 법의 내용(the content of the law)이 도덕적으로 좋은 결과를 위해 조정되어야 한다는 주장 사이에 모호함이 존재한다 (예: 사법적 책무(judicial duty)를 오직 원천 기반 자료(source-based materials) 적용에 한정하려는 시도 등). 비교 자료: Neil MacCormick, 「도덕주의적 법 비판, 비도덕주의적 법 옹호(A Moralistic Case for A-Moralistic Law)」(1985) *Valparaiso Law Review* 제20권 1쪽; Thomas Campbell, 『윤리적 실증주의의 법이론(The Legal Theory of Ethical Positivism)』(Dartmouth, 1996); Jeremy Waldron, 「규범적(또는 윤리적) 실증주의」, Jules Coleman 편, 『Hart’s Postscript』; Liam Murphy, 「법 개념에 대한 정치적 물음」, 동일 저서 수록.

X. 국제법 (INTERNATIONAL LAW)

1. 의문의 원천들 (SOURCES OF DOUBT)

본서에서 그토록 중요한 자리를 부여받은 일차 규칙들과 이차 규칙들의 결합이라는 관념(idea)은, 법리학적 극단들 사이의 중간으로 간주될 수 있다. 법이론은 때로는 위협으로 뒷받침된 명령이라는 단순한 관념에서, 때로는 도덕(morality)이라는 복잡한 관념에서 법 이해의 열쇠를 찾으려 해왔다. 법은 이 둘 모두와 분명 많은 친연성과 연결을 가진다. 그러나 우리가 보았듯이, 이것들을 과장하고 법을 다른 사회통제 수단들과 구별하는 특수한 특징들을 흐릴 상존하는 위험이 있다. 우리가 중심적인 것으로 취한 관념의 미덕은, 법, 강제(coercion), 도덕 사이의 복수적 관계들을 그것들이 실제로 그러한 대로 보게 해 주고, 이것들이 있다면 어떤 의미에서 필연적인지를 새롭게 고려하게 해 준다는 데 있다.

일차 규칙들과 이차 규칙들의 결합이라는 관념이 이러한 미덕들을 가지고 있고, 또 이러한 특징적인 규칙 결합의 존재를 ‘법체계(legal system)’라는 표현 적용의 충분조건으로 다루는 것이 용례(usage)에 부합할 것임에도, 우리는 ‘법(law)’이라는 단어가 반드시 그 결합의 관점에서 정의되어야 한다고 주장하지 않았다. 우리가 ‘법’이나 ‘법적’ 같은 단어들의 사용을 이런 방식으로 식별하거나 규율해야 한다는 주장을 하지 않기 때문에, 이 책은 자연스럽게 이 표현들의 사용을 위한 하나의 규칙 또는 여러 규칙들을 제공할 것으로 기대될 수 있는 ‘법’의 정의가 아니라, 법 개념(concept)의 해명으로 제시된다. 이 목적에 부합하게, 우리는 지난 장에서 독일 사례들에서 제기된 주장(claim), 곧 어떤 규칙들이 현존하는 일차 및 이차 규칙 체계에 속하더라도 그 도덕적 사악함(moral iniquity) 때문에 유효한 법이라는 명칭(title)을 그 규칙들로부터 보류해야 한다는 주장을 검토하였다. 결국 우리는 이 주장을 거부하였다. 그러나 그렇게 한 것은 그러한 체계에 속하는 규칙들은 반드시 ‘법’이라고 불려야 한다는 견해와 그 주장이 충돌하기 때문도 아니고, 용례의 무게와 충돌하기 때문도 아니었다. (p. 214) 오히려 우리는 도덕적으로 사악한 것을 밀어냄으로써 유효한 법들의 부류를 좁히려는 시도를 비판하였다. 그 근거는 그렇게 하는 것이 이론적 탐

구나 도덕적 숙고 어느 쪽도 진전시키거나 명료하게 하지 못한다는 데 있었다. 이러한 목적들을 위해서는, 많은 용례와 부합하고 규칙들이 아무리 도덕적으로 사악하더라도 그것들을 법으로 간주할 수 있게 하는 더 넓은 개념이, 검토 결과 적절한 것으로 드러났다.

국제법(international law)은 우리에게 그 반대의 사례를 제시한다. 지난 150년의 용례와 부합하게 여기서 ‘법’이라는 표현을 사용하더라도, 국제 입법부, 강제관할권을 가진 법원들, 중앙적으로 조직된 제재들의 부재는 적어도 법이론가들의 마음속에 의구심들을 불러일으켜 왔다. 이러한 제도들의 부재는 국가들에 대한 규칙들이, 오직 의무의 일차 규칙들만으로 이루어진 단순한 사회구조의 형식과 닮아 있음을 뜻한다. 개인들의 사회에서 이런 형식을 발견할 때 우리는 그것을 발전된 법체계와 대조하는 데 익숙하다. 우리가 보이겠지만, 국제법은 입법부와 법원들을 마련하는 변경과 재판의 이차 규칙들을 결여할 뿐 아니라, 법의 ‘원천들(sources)’을 특정하고 그 규칙들의 식별을 위한 일반 기준들을 제공하는 통합적 승인 규칙도 결여한다고 기실 논변할 수 있다. 이러한 차이들은 기실 두드러지며, ‘국제법은 정말로 법인가?’라는 질문은 거의 제쳐 놓을 수 없다. 그러나 이 경우에도 우리는 많은 사람들이 느끼는 의문들을 기존 용례를 단순히 환기시키는 것으로 물리치지 않을 것이며, 일차 및 이차 규칙들의 결합이 ‘법체계’라는 표현을 올바르게 사용하기 위한 충분조건일 뿐 아니라 필요조건이기도 하다는 근거 위에서 그 의문들을 단순히 확증하지도 않을 것이다. 그 대신 우리는 느껴져 온 의문들의 상세한 성격을 탐구하고, 독일 사례에서처럼, ‘국제법’을 말하는 공통의 더 넓은 용례가 어떤 실천적 또는 이론적 목적을 방해할 개연성이 있는지를 물을 것이다.

우리가 국제법의 성격에 관한 이 문제에 단 하나의 장만을 할애하겠지만, 일부 저자들은 이 질문을 훨씬 더 짧게 처리할 것을 제안해 왔다. 그들에게는 ‘국제법은 정말로 법인가?’라는 질문이 오직 단어들의 의미에 관한 사소한 질문을 사물들의 본성에 관한 (p. 215) 중대한 질문으로 오인했기 때문에 생겨났거나 살아남은 것처럼 보였다. 곧 국제법을 국내법(municipal law)과 구별하는 사실들은 명료하고 잘 알려져 있으므로, 확정되어야 할 유일한 질문은 우리가 기존 관행을 준수할 것인지 아니면 그것에서 벗어날 것인지이며, 이것은 각자가

스스로 확정할 문제라는 것이다. 그러나 이 질문을 이렇게 짧게 처리하는 방식은 확실히 너무 짧다. 이론가들이 ‘법’이라는 단어를 국제법으로 확장하는데 주저하게 된 이유들 가운데, 같은 단어를 많은 서로 다른 것들에 적용하는 일을 무엇이 정당화하는가에 관한 지나치게 단순하고 기실 터무니없는(absurd) 견해가 어느 정도 역할을 한 것은 사실이다. 일반적인 분류 용어들의 확장을 통상적으로 인도하는 원칙 유형들의 다양성(variety)은 법리학에서 너무 자주 무시되어 왔다. 그럼에도 국제법에 관한 의문의 원천들은 단어 사용에 관한 이러한 잘못된 견해들보다 더 깊고 더 흥미롭다. 더욱이 이 질문을 짧게 처리하는 방식이 제시하는 두 대안, 곧 ‘기존 관행을 준수할 것인가, 아니면 그것에서 벗어날 것인가?’는 망라적이지 않다. 그 둘 외에도, 실제로 기존 용례를 인도해 온 원칙들을 명시하고 검토하는 대안이 있기 때문이다.

제안된 이 짧은 처리 방식은 우리가 고유명사를 다루고 있었다면 기실 적절했을 것이다. 누군가 ‘런던’이라 불리는 장소가 정말로 런던인지를 묻는다면, 우리가 할 수 있는 일은 그에게 관행(convention)을 환기시키고 그가 그것을 따르거나 취향에 맞는 다른 이름을 선택하도록 남겨 두는 것뿐이다. 그런 경우에 어떤 원칙에 따라 런던이 그렇게 불리게 되었는지, 또 이 원칙이 받아들일 만한 것인지를 묻는 것은 부조리할 것이다. 이것이 부조리한 이유는, 고유명사의 배분은 오직 임시적(*ad hoc*) 관행에만 기초하는 반면, 어떤 진지한 학문분야의 일반 용어들의 확장은, 그 원칙 또는 이론적 근거(rationale)가 무엇인지 분명하지 않을 수는 있어도, 결코 원칙이나 근거 없이 이루어지지 않기 때문이다. 현재 경우처럼 사실상 ‘우리는 그것이 법이라고 불린다는 것은 알지만, 그것이 정말 법인가?’라고 말하는 이들이 그 확장에 의문을 제기할 때, 요구되는 것은, 분명 흐릿하게나마, 그 원칙을 명시하고 그 자격 근거들(credentials)을 심사하라는 것이다.

우리는 국제법의 법적 성격에 관한 두 가지 주요한 의문의 원천들과, 그것들과 함께, 이론가들이 이러한 의문들에 대응하기 위해 취해 온 조치들을 검토할 것이다. (p. 216) 두 형태의 의문은 모두, 법이 무엇인가에 관한 명료하고 표준적인 사례로 간주되는 국내법과 국제법을 불리하게 비교하는 데서 생겨난다. 첫째 의문은 법을 근본적으로 위협으로 뒷받침된 명령들의 문제로 보는 구상

(conception)에 깊이 뿌리박고 있으며, 국제법의 규칙들(rules)의 성격을 국내법의 규칙들의 성격과 대조한다. 둘째 형태의 의문은, 국가들이 근본적으로 법적 의무의 수범자들(subjects)이 될 수 없다는 모호한 믿음에서 솟아나며, 국제법의 수범자들(subjects)의 성격을 국내법의 수범자들의 성격과 대조한다.

2. 의무들과 제재들 (OBLIGATIONS AND SANCTIONS)

우리가 검토할 의문들은 국제법 책들의 첫 장들에서 흔히 ‘국제법은 어떻게 구속력 있을 수 있는가?’ 라는 질문 형식으로 표현된다. 그러나 이렇게 즐겨 쓰이는 질문 형식에는 매우 혼란스러운 점이 있다. 그것을 다루기 전에 우리는 답이 결코 분명하지 않은 선행 질문에 직면해야 한다. 이 선행 질문은 이렇다. 법체계 전체에 관하여 그것이 ‘구속력 있다(binding)’ 고 말할 때 무엇을 뜻하는가? 한 체계의 특정 규칙이 특정 사람에게 구속력 있다고 하는 진술은 법률가들에게 익숙하고 의미상 상당히 명료하다. 우리는 그것을, 문제의 규칙이 유효한 규칙이며 그 규칙 아래에서 문제의 사람에게 어떤 의무(obligation) 또는 책무(duty)가 있다는 단언으로 바꾸어 말할 수 있다. 이 외에도 이 형식의 더 일반적인 진술들이 이루어지는 몇몇 상황들이 있다. 우리는 어떤 상황들에서 어느 법체계가 특정 사람에게 적용되는지 의문을 가질 수 있다. 그러한 의문들은 국제사법(conflict of laws)이나 공국제법(public international law)에서 생길 수 있다. 전자의 경우 우리는 특정 거래에 관하여 프랑스법과 영국법 중 어느 것이 특정 사람에게 구속력 있는지를 물을 수 있고, 후자의 경우 우리는 예컨대 적국이 점령한 벨기에의 주민들이 망명정부가 벨기에법이라고 주장한 것에 구속되었는지, 아니면 점령국의 명령들(ordinances)에 구속되었는지를 물을 수 있다. 그러나 이 두 경우 모두에서 질문들은 어떤 법체계, 곧 국내법이든 국제법이든 어떤 체계 내부에서(within) 생겨나고 그 체계의 규칙들이나 원칙들을 참조하여 확정되는 법문제들(questions of law)이다. 그것들은 규칙들의 일반적 성격을 문제 삼지 않고, 다만 주어진 상황에서 특정 사람들 또는 거래들에 대한 규칙들의 범위 또는 적용가능성(applicability)을 문제 삼는다. (p. 217) 분명히 ‘국제법은 구속력 있는가?’ 라는 질문과 그 동류 질문들인 ‘국제법은 어떻게

구속력 있을 수 있는가?’ 또는 ‘무엇이 국제법을 구속력 있게 만드는가?’ 는 다른 차원의 질문들이다. 그것들은 적용가능성이 아니라 국제법의 일반적 법적 지위에 관한 의문을 표현한다. 이 의문은 ‘이러한 규칙들이 언제라도 의미 있게 그리고 참되게 의무들을 발생시킨다고 말해질 수 있는가?’ 라는 형식으로 더 솔직하게 표현될 것이다. 책들의 논의들이 보여 주듯이, 이 점에 관한 의문의 한 원천은 단순히 그 체계에 중앙적으로 조직된 제재들이 부재한다는 것이다. 이것은 국내법과의 불리한 비교 지점 하나인데, 국내법의 규칙들은 의심할 여지 없이 ‘구속력 있는’ 것으로 그리고 법적 의무의 전형들로 간주된다. 이 단계에서 더 나아가는 논변은 단순하다. 이러한 이유로 국제법의 규칙들이 ‘구속력 있는’ 것이 아니라면, 그것들을 법으로 분류하는 일을 진지하게 받아들이는 것은 확실히 방어될 수 없다는 것이다. 일상 언어의 방식들이 아무리 관대하더라도, 이것은 간과하기에는 너무 큰 차이이다. 법의 본성에 관한 모든 사변(speculation)은, 법의 존재가 적어도 일정한 행위를 의무적인(obligatory) 것으로 만든다는 가정에서 출발한다.

이 논변을 검토하면서 우리는 국제체계의 사실들에 관한 모든 의문점을 그 논변에 유리하게 보아 줄 것이다. 우리는 국제연맹 규약 제16조도 유엔 헌장 제7장도 국내법의 제재들과 동일시될 수 있는 어떤 것도 국제법에 도입하지 않았다고 받아들일 것이다. 한국전쟁에도 불구하고, 또 수에즈 사건에서 어떤 교훈(moral)이 도출될 수 있더라도, 우리는 헌장의 법집행 규정들(provisions)은 그 사용이 중요할 때마다 거부권에 의해 마비될 개연성이 있으며, 단지 종이 위에만 존재한다고 말해야 한다고 상정할 것이다.

국제법은 조직화된 제재들이 결여되어 있기 때문에 구속력 있지 않다고 논변하는 것은, 법이 본질적으로 위협으로 뒷받침된 명령들의 문제라는 이론 속에 들어 있는 의무 분석을 목시적으로 받아들이는 것이다. 이 이론은, 우리가 보았듯이, ‘의무를 가진다’ 또는 ‘구속된다’ 를 ‘불복종에 대해 위협된 제재나 처벌을 받을 개연성이 있다’ 와 동일시한다. 그러나 우리가 논변했듯이, 이러한 동일시는 모든 법적 사고와 담론에서 (p. 218) 의무(obligation)와 책무(duty)의 관념들(ideas)이 수행하는 역할을 왜곡한다. 실효적인 조직화된 제재들이 있는 국내법에서조차, 우리는 제Ⅲ장에서 제시된 다양한 이유들 때문에, ‘나는(너는)

불복종 때문에 고통을 겪을 개연성이 있다' 라는 외부 예측 진술의 의미와, '나는 (너는) 이렇게 행위할 의무를 가진다' 라는 내부 규범 진술의 의미를 구별해야 한다. 후자는 특정 사람의 상황을 행위의 지도 기준들로 수용된 규칙들의 관점에서 평가한다. 모든 규칙들이 의무들 또는 책무들을 발생시키는 것은 아니라는 점은 참이다. 또한 그렇게 하는 규칙들이 일반적으로 사적 이익의 어느 정도 희생을 요구하고, 일반적으로 부합(conformity)하라는 진지한 요구들과 일탈들에 대한 집요한 비판에 의해 뒷받침된다는 점도 참이다. 그러나 우리가 예측적 분석과, 법을 본질적으로 위협으로 뒷받침된 명령으로 보는 그 모태 구상(parent conception)으로부터 벗어나고 나면, 의무라는 규범적 관념을 조직화된 제재들에 의해 뒷받침되는 규칙들로 제한할 좋은 이유는 없어 보인다.

그러나 우리는 그 논변의 또 다른 형태를 고려해야 한다. 그것은 위협된 제재들의 개연성으로 의무를 정의하는 데 묶여 있지 않기 때문에 더 그럴듯하다. 회의론자는, 우리가 스스로 강조했듯이, 국내체계 안에는 정당하게 필수적이라고 불리는 일정한 규정들(provisions)이 있다고 지적할 수 있다. 그 가운데에는 폭력의 자유로운 사용을 금지하는 의무의 일차 규칙들과, 이 규칙들 및 다른 규칙들에 대한 제재로서 힘(force)의 공식적 사용을 마련하는 규칙들이 있다. 그러한 규칙들과 그것들을 뒷받침하는 조직화된 제재들이 이 의미에서 국내법에 필수적이라면, 그것들은 국제법에도 똑같이 필수적이지 않은가? 그렇다는 주장은 이것이 '구속력 있는(binding)' 이나 '의무(obligation)' 같은 단어들의 바로 그 의미로부터 나온다고 고집하지 않고도 유지될 수 있다.

이 형태의 논변에 대한 답은, 국내법의 지속적인 심리적·물리적 배경을 이루는 인간 존재와 그 환경에 관한 그 기초적 진리들(elementary truths)에서 발견된다. 신체적 힘과 취약성에서 근사적으로 동등한 개인들의 사회에서 물리적 제재들은 필수적이면서도 가능하다. 그것들은 법의 제약들에 자발적으로 복종하려는 이들이, 그러한 제재들이 없다면 스스로는 법을 존중하지 않으면서 타인들의 법 존중에서 오는 이익을 거둬 악행자들(malefactors)의 단순한 희생자가 되지 않게 하기 위해 요구된다. 서로 가까운 곳에서 사는 개인들 사이에서는 (p. 219) 공개적 공격에 의하지 않더라도 속임수로 타인들에게 손해를 가할 기회들이 매우 크고, 빠져나갈 가망(chances)도 상당하므로, 가장 단순한 사회

형태들을 제외하면 단순한 자연적 억제요인들만으로는 법에 복종하기에는 너무 사악하거나, 너무 어리석거나, 너무 약한 이들을 제어하기에 적절할 수 없다. 그러나 같은 근사적 동등성의 사실과 제약 체계에 복종할 때의 분명한 이점들 때문에, 악행자들의 어떤 결합도 그 체계의 유지에 자발적으로 협력하려는 이들의 힘을 넘어서 개연성은 없다. 국내법의 배경을 이루는 이러한 상황들에서는, 제재들이 비교적 작은 위협으로 악행자들에게 성공적으로 사용될 수 있고, 그 제재들의 위협은 존재할 수 있는 자연적 억제요인들에 많은 것을 더할 것이다. 그러나 개인들에게 성립하는 단순한 자명한 이치들이 국가들에게는 성립하지 않고, 국제법의 사실적 배경이 국내법의 사실적 배경과 매우 다르기 때문에, 제재들에 대한 유사한 필수성도 없고(국제법이 그것들에 의해 뒷받침되는 것이 바람직할 수는 있더라도), 그것들을 안전하고 실효적으로 사용할 유사한 전망도 없다.

그 까닭은 국가들 사이의 침략이 개인들 사이의 침략과 매우 다르기 때문이다. 국가들 사이의 폭력 사용은 공적일 수밖에 없고, 국제 경찰력이 없더라도 그것이, 경찰력이 없는 경우의 살인이나 절도처럼, 침략자와 피해자 사이의 문제로 남으리라는 확실성은 거의 있을 수 없다. 전쟁을 개시하는 것은 최강대국에게조차 합리적 확신을 가지고 예측하기 드문 결과를 위해 많은 것을 위험에 거는 일이다. 다른 한편, 국가들의 불평등 때문에 국제질서 편에 선 이들의 결합된 힘이 침략의 유혹을 받는 세력들(powers)보다 우세할 개연성이 있다는 상시적 보장은 있을 수 없다. 따라서 제재들의 조직과 사용은 두려운 위험들을 수반할 수 있고, 그것들의 위협은 자연적 억제요인들에 거의 보태는 것이 없을 수 있다. 이렇게 매우 다른 사실의 배경에 맞서 국제법은 국내법과 다른 형식으로 발전해 왔다. 현대 국가의 인구 안에서 범죄의 조직화된 억압과 처벌이 없다면 폭력과 절도는 매시간 예상될 것이다. 그러나 국가들의 경우에는 참혹한 전쟁들 사이에 오랜 평화의 해들이 끼어들어 왔다. 이 평화의 해들은 전쟁의 위협과 이해관계 및 국가들의 상호 필요들을 고려할 때에만 (p. 220) 합리적으로 기대될 수 있다. 그러나 그것들은, 다른 것들 가운데 어느 중앙 기관에 의한 집행도 마련하지 않는다는 점에서 국내법의 규칙들과 다른 규칙들에 의해 규율할 가치가 있다. 그럼에도 이 규칙들이 요구하는 것은 의무적인(obligatory) 것으로 생각되고 말

해진다. 규칙들에 부합(conformity)하라는 일반적 압력이 있고, 청구들(claims)과 시인들(admissions)은 그것들에 근거하며, 그것들의 위반은 보상에 대한 집요한 요구들뿐 아니라 보복조치들과 대응조치들을 정당화하는 것으로 여겨진다. 규칙들이 무시될 때, 그것은 규칙들이 구속력 있지 않다는 근거 위에서 이루어지는 것이 아니다. 오히려 사실들을 감추려는 노력들이 이루어진다. 물론 그러한 규칙들은 국가들이 싸우려 하지 않는 쟁점들에 관한 한에서만 실효적이라고 말할 수 있다. 그럴 수 있으며, 그것은 그 체계의 중요성과 인류에 대한 가치에 불리하게 반영될 수 있다. 그러나 그럼에도 이만큼이라도 확보될 수 있다는 사실은, 조직화된 제재들이 국내법에 필수적이라는 점, 곧 국내법의 물리적·심리적 사실 배경에서의 그 필수성으로부터, 매우 다른 배경의 국제법은 그것들 없이는 어떤 의무도 부과하지 않고 ‘구속력 있지’ 않으며 따라서 ‘법’이라는 명칭을 받을 가치가 없다는 결론으로 가는 단순한 추론은 할 수 없음을 보여준다.

3. 의무와 국가들의 주권 (OBLIGATION AND THE SOVEREIGNTY OF STATES)

영국, 벨기에, 그리스, 소비에트 러시아는 국제법 아래에서 권리들과 의무들을 가지며, 따라서 그 수범자들(subjects)에 속한다. 그것들은 일반인은 독립적이라고 생각하고 법률가는 ‘주권적(sov​er​eign)’ 이라고 인정할 국가들의 임의적 사례들이다. 국제법의 의무적 성격에 관한 가장 지속적인 당혹의 원천들 가운데 하나는, 주권적인 국가가 국제법에 의해 ‘구속될(bound)’ 수도 있고 국제법 아래에서 의무를 가질 수도 있다는 사실을 받아들이거나 설명하는 데서 느껴진 어려움이었다. 이러한 형태의 회의론은 어떤 의미에서는 국제법이 제재들을 결여하기 때문에 구속력 있지 않다는 반론보다 더 극단적이다. 왜냐하면 그 반론은 언젠가 국제법이 제재 체계에 의해 강화된다면 대응될 수 있지만, 현재의 반론은 동시에 주권적이고 법의 적용을 받는(subject to law) 국가라는 구상 안에 존재한다고 말해지거나 느껴지는 근본적 비일관성에 기초하기 때문이다.

이 반론의 검토는, 주권이라는 관념(notion)을 (p. 221) 국가 안의(within) 입

법부나 다른 어떤 요소 또는 인격에 적용하는 것이 아니라 국가 자체에 적용하는 경우를 면밀히 살피는 일을 포함한다. 법리학에서 ‘주권적(sov^{er}ei^{gn})’이라는 단어가 나타날 때마다, 그것을 자기보다 낮은 자들 또는 수범자들(subjects)에 대하여 자신의 말이 법인 법 위의 인격이라는 관념(idea)과 결부시키는 경향이 있다. 우리는 이 책의 앞 장들에서 이 매혹적인 관념(notion)이 국내법체계의 구조에 얼마나 나쁜 안내자인지를 보았다. 그러나 그것은 국제법 이론에서는 훨씬 더 강력한 혼란의 원천이었다. 물론 국가를 이러한 방식으로, 마치 일종의 초인, 곧 본래 법에 매이지 않지만 그 수범자들에게는 법의 원천인 존재인 것처럼 생각하는 것은 가능하다. 16세기 이래 국가와 군주의 상징적 동일시(‘L’état c’est moi’)는 이러한 관념을 부추겼을 수 있고, 이 관념은 정치이론뿐 아니라 법이론의 많은 부분에 의심스러운 영감을 제공해 왔다. 그러나 국제법의 이해를 위해서는 이러한 연상들을 떨쳐 내는 것이 중요하다. ‘국가’라는 표현은 본래 또는 ‘본성상’ 법 바깥에 있는 어떤 인격이나 사물의 이름이 아니다. 그것은 두 사실들을 지칭하는 방식이다. 첫째, 한 영토에 거주하는 인구가 입법부, 법원들, 일차 규칙들이라는 특징적 구조를 가진 법체계가 마련한 질서 있는 정부 형식 아래에서 산다는 사실, 둘째, 그 정부가 모호하게 규정된 정도의 독립성을 누린다는 사실이다.

‘국가(state)’라는 단어가 분명 그 자체의 넓은 모호성 영역을 가지지만, 지금까지 말한 것으로 그 중심 의미를 드러내기에는 충분할 것이다. 다시 임의적 사례들을 들면, 영국이나 브라질, 미국이나 이탈리아 같은 국가들은 자기 국경 밖의 어떤 권위들이나 인격들에 의한 법적 통제와 사실적 통제 양자 모두로부터 매우 큰 정도의 독립성을 가지며, 국제법에서 ‘주권국가들’로 자리매겨질 것이다. 다른 한편, 미국의 주들처럼 연방연합의 구성원인 개별 주들은 여러 다른 방식으로 연방정부와 연방헌법의 권위와 통제에 종속된다. 그러나 이 연방 주들조차 보유하는 독립성은, 이를테면 ‘국가’라는 단어가 전혀 사용되지 않을 잉글랜드 카운티의 지위와 비교하면 크다. 카운티는 자기 구역을 위해 입법부의 기능들 일부를 수행하는 지방의회를 가질 수 있지만, 그 빈약한 권한들은 의회의 권한들에 (p. 222) 종속되며, 어떤 사소한 측면들을 제외하면 그 카운티의 구역은 나라의 나머지 부분과 같은 법들 및 정부의 적용을 받는다.

이 극단들 사이에는 질서 있는 정부를 가진 영토 단위들 사이의 종속성, 따라서 독립성의 많은 서로 다른 유형들과 정도들이 있다. 식민지, 보호령, 종주권관계(suzerainties), 신탁통치지역, 국가연합들은 이 관점에서 흥미로운 분류 문제들을 제시한다. 대부분의 경우 한 단위가 다른 단위에 종속되어 있다는 점은 법적 형식들로 표현되므로, 종속 단위의 영토 안에서 법인 것은 적어도 일정한 쟁점들에 관해서는 궁극적으로 다른 단위의 법제정 작용들(law-making operations)에 의존할 것이다.

그러나 어떤 경우에는 종속된 영토의 법체계가 그 종속성을 반영하지 않을 수 있다. 이는 그 영토가 단지 형식적으로 독립되어 있고 실제로는 꼭두각시들을 통해 외부에서 통치되기 때문일 수도 있고, 또는 종속된 영토가 내부 사무들에 대해서는 실질적 자율성을 가지지만 외부 사무들에 대해서는 그렇지 않으며, 외부 사무들에서 다른 나라에 대한 그 종속성이 그 국내법의 일부로 표현될 필요가 없기 때문일 수도 있다. 그러나 이러한 여러 방식으로 한 영토 단위가 다른 영토 단위에 종속되는 것이 그 독립성이 제한될 수 있는 유일한 형식은 아니다. 제한 요인은 그러한 다른 단위의 권력(power)이나 권위(authority)가 아니라, 서로 똑같이 독립적인 단위들에 영향을 미치는 국제적 권위일 수 있다. 국제적 권위의 많은 서로 다른 형식들과 그에 상응하는 국가 독립성의 많은 서로 다른 제한들을 상상할 수 있다. 그 가능성들에는, 많은 다른 것들 가운데, 모든 단위의 내부/외부 사무들을 규율할 법적으로 무제한적인 권한들(powers)을 가진, 영국 의회를 모델로 한 세계 입법부, 특정 사안들에 대해서만 법적 권능(legal competence)을 가지거나 구성 단위들의 특정 권리 보장에 의해 제한되는, 미국 의회를 모델로 한 연방 입법부, 법적 통제의 유일한 형식이 모두에게 적용가능한 것으로 일반적으로 수용된 규칙들로 이루어지는 체제, 마지막으로 인정되는 의무의 유일한 형식이 계약적 또는 자기부과적인 것이어서 국가의 독립성이 오직 자신의 행위에 의해서만 법적으로 제한되는 체제가 포함된다.

이러한 가능성들의 범위를 고려하는 것은 유익하다. 종속성과 독립성의 가능한 형식들과 (p. 223) 정도들이 많다는 점을 깨닫기만 해도, 국가들이 주권적이기 때문에 국제법의 적용을 받거나 국제법에 의해 구속될 수 '없다' 거나 어떤 특정 형식의 국제법에 의해서만 구속될 수 '있다' 는 주장(claim)에 답하는

한 걸음이 되기 때문이다. 여기서 ‘주권적’이라는 단어는 ‘독립적’이라는 말 이상을 뜻하지 않으며, 후자처럼 그 의미상 힘(force)이 부정적이다. 주권국가는 일정 유형들의 통제에 종속되지 않는 국가이고, 그 주권은 그 국가가 자율적인 행위 영역이다. 우리가 보았듯이, 국가라는 단어의 바로 그 의미가 어느 정도의 자율성을 불러들이지만, 이것이 무제한적이어야 ‘한다’거나 일정 유형들의 의무에 의해서만 제한될 수 ‘있다’는 논지(contention)는 기껏해야 국가들이 여타 모든 제약들로부터 자유로워야 한다는 주장(claim)의 단언이고, 최악의 경우에는 이유 없는 독단이다. 실제로 국가들 사이에 어떤 주어진 형식의 국제적 권위가 존재한다는 것을 우리가 발견한다면, 국가들의 주권은 그만큼 제한되며, 그것은 규칙들이 허용하는 바로 그 정도를 가진다. 따라서 어떤 국가들이 주권적인지, 그리고 그 주권의 범위가 무엇인지는 규칙들이 무엇인지 알 때에만 알 수 있다. 이는 영국인이나 미국인이 자유로운지 그리고 그의 자유의 범위가 무엇인지가 영국법이냐 미국법이 무엇인지 알 때에만 알 수 있는 것과 같다. 국제법의 규칙들은 많은 점에서 기실 모호하고 충돌하므로, 국가들에게 남겨진 독립성의 영역에 관한 의문은 국내법 아래 시민의 자유 범위에 관한 의문보다 훨씬 더 크다. 그럼에도 이러한 어려움들은, 국제법을 참조하지 않고 국가들에게 속한다고 가정된 절대적 주권으로부터 국제법의 일반적 성격을 연역하려는 선형적(a priori) 논변을 타당화하지 않는다.

주권 개념의 무비판적 사용이 국내법 이론과 국제법 이론 양쪽에 유사한 혼란을 퍼뜨려 왔고, 양쪽에서 유사한 교정을 요구한다는 점은 관찰할 가치가 있다. 그 영향 아래에서 우리는 모든 국내법체계에는 법적 제한들에 종속되지 않는 주권 입법자가 반드시 있어야 한다고 믿게 된다. 마찬가지로 우리는 국가들이 주권적이고 스스로에 의한 제한을 제외하고는 법적 제한을 받을 수 없기 때문에 국제법은 반드시 어떤 성격을 가져야 한다고 믿게 된다. 두 경우 모두, 법적으로 무제한적인 주권자가 필연적으로 존재한다는 믿음은 실제 (p. 224) 규칙들을 검토할 때에만 답할 수 있는 질문을 선취 판단한다. 국내법에 관한 질문은 이것이다. 이 체계에서 인정되는 최고 입법 권위(supreme legislative authority)의 범위는 무엇인가? 국제법에 관한 질문은 이것이다. 규칙들이 국가들에게 허용하는 최대 자율성 영역은 무엇인가?

따라서 현재의 반론에 대한 가장 단순한 답은, 그것이 질문들이 고려되어야 할 순서를 뒤집는다는 것이다. 국제법의 형식들이 무엇인지, 그리고 그것들이 단지 공허한 형식들인지 아닌지를 알기 전까지는 국가들이 어떤 주권을 가지는지 알 길이 없다. 많은 법리학적 논쟁은 이 원칙이 무시되었기 때문에 혼란스러워졌고, 이 원칙에 비추어 ‘의사주의(voluntarist)’ 이론들 또는 ‘자기제한(auto-limitation)’ 이론들로 알려진 국제법 이론들을 고려하는 것은 유익하다. 이러한 이론들은 국가들의 (절대적) 주권을 국제법의 구속력 있는 규칙들의 존재와 조화시키려 하면서, 모든 국제적 의무들을 약속에서 생겨나는 의무처럼 자기부과적인 것으로 다루었다. 그러한 이론들은 사실 국제법에서 정치학의 사회계약론들에 대응하는 것이다. 후자는, ‘자연적으로’ 자유롭고 독립적인 개인들이 그럼에도 국내법에 의해 구속된다는 사실들을, 법에 복종할 의무를 구속되는 이들이 서로, 그리고 몇몇 경우에는 자기 통치자들과 맺은 계약에서 생겨나는 의무로 다루어 설명하고자 했다. 우리는 여기서 이 이론을 문자 그대로 취할 때의 잘 알려진 반론들이나, 단지 해명적 유비로 취할 때의 그 가치에 대해서는 고려하지 않을 것이다. 그 대신 우리는 그 역사에서 의사주의 국제법 이론들에 반대하는 세 갈래 논변을 끌어낼 것이다.

첫째, 이러한 이론들은 국가들이 자기부과적 의무들에 의해서만 구속될 수 ‘있다’는 점이 어떻게 알려지는지, 또는 국제법의 실제 성격에 대한 어떤 검토보다 앞서 왜 그들의 주권에 관한 이러한 견해가 수용되어야 하는지를 전혀 설명하지 못한다. 그것을 뒷받침할 것이, 그것이 자주 반복되었다는 사실 외에 더 있는가? 둘째, 국가들이 그 주권 때문에 스스로에게 부과한 규칙들의 적용을 받거나 그 규칙들에 의해 구속될 수 있을 뿐임을 보이도록 설계된 논변에는 비일관적인 점이 있다. ‘자기제한’ 이론의 몇몇 매우 극단적인 형식들에서는 한 국가의 합의나 조약상 약정들이 그 국가가 제안하는 장래 행위에 관한 단순한 선언들로 취급되고, 이행하지 않음은 어떤 의무의 위반으로도 간주되지 않는다. (p. 225) 이것은 사실들과 매우 어긋나지만, 적어도 일관성이라는 이점(merit)을 가진다. 그것은 국가들의 절대적 주권이 어떤 종류의 의무와도 비일관적이어서, 의회처럼 국가도 자신을 구속할 수 없다는 단순한 이론이다. 그러나 국가가 약속, 합의 또는 조약에 의해 스스로에게 의무들을 부과할 수 있다는 덜 극단적인

전해는, 국가들이 이렇게 스스로에게 부과한 규칙들의 적용을 받거나 그 규칙들에 의해 구속될 수 있을 뿐이라는 이론과 비일관적이다. 말해진 것이든 쓰인 것이든 말들이 일정한 상황에서 약속, 합의 또는 조약으로 기능하여 의무들을 발생시키고 타인들이 청구할 수 있는 권리들을 부여하려면, 한 국가가 적절한 말들로 하겠다고 맡은 것은 무엇이든 하도록 구속된다고 규정하는 규칙들이 이미 존재해야 하기 때문이다. 자기부과적 의무라는 바로 그 관념(notion) 안에 전제되어 있는 그러한 규칙들은, 그것들에 복종해야 한다는 자기부과적 의무에서 그것들의 의무적 지위(obligatory status)를 도출할 수 없음이 분명하다.

주어진 국가가 해야 하도록 구속된 모든 특정 행위(action)가 이론상 약속에서 그 의무적 성격을 도출할 수 있다는 것은 참이다. 그럼에도 이는 약속 등이 의무들을 창설한다는 규칙이 어떤 약속과도 독립적으로 그 국가에 적용되는 경우에만 그럴 수 있다. 개인들로 이루어졌든 국가들로 이루어졌든 어떤 사회에서든, 약속, 합의 또는 조약의 말들이 의무들을 발생시키기 위해 필요하고 충분한 것은, 이를 마련하고 이러한 자기구속 작용들(self-binding operations)을 위한 절차를 특징하는 규칙들이, 보편적으로 그럴 필요는 없지만 일반적으로 인정되는 것이다. 그것들이 인정되는 곳에서는 이러한 절차들을 알고서 사용하는 개인이나 국가는, 구속되기를 선택하든 선택하지 않든 그 절차들에 의해 구속된다. 그러므로 사회적 의무의 이 가장 자발적인 형식조차, 그 규칙들에 의해 구속되는 당사자의 선택과 독립적으로 구속력 있는 몇몇 규칙들을 포함하며, 이는 국가들의 경우 그들의 주권이 그러한 모든 규칙들로부터의 자유를 요구한다는 상정과 비일관적이다.

셋째, 사실들이 있다. 우리는 방금 비판한 선험적 주장, 곧 국가들은 자기 부과적 의무들에 의해서만 구속될 수 ‘있다’는 주장과, 국가들이 다른 체계 아래에서는 다른 방식으로 구속될 수 있었다라든가 사실상 현행 국제법 규칙들 아래에서는 국가들을 위한 다른 어떤 의무 형식도 존재하지 않는다는 주장을 구별해야 한다. 물론 그 (p. 226) 체계가 이 완전히 합의적인(consensual) 형식의 것일 수도 있으며, 그 성격에 관한 이 견해의 단언들과 부인들은 법리학자들의 저술, 판사들의 의견, 심지어 국제법원들의 의견, 그리고 국가들의 선언들에서 발견된다. 오직 국가들의 실제 실천에 대한 냉정한 조사만이 이 견해가 옳은지

아닌지를 보여 줄 수 있다. 현대 국제법이 매우 큰 부분에서 조약법이라는 점은 참이며, 국가들의 사전 동의 없이도 국가들에게 구속력 있는 것으로 보이는 규칙들이 실제로는 동의에 기초해 있다는 것을 보이려는 정교한 시도들이 이루어져 왔다. 다만 이 동의는 오직 ‘묵시적으로(tacitly)’ 주어진 것이거나 ‘추론되어야’ 하는 것일 수 있다. 모두가 허구인 것은 아니지만, 국제적 의무의 형식들을 하나로 환원하려는 이 시도들 중 적어도 일부는, 우리가 보았듯이 국내법의 유사하지만 더 명백히 허위적인 단순화를 수행하도록 설계된 ‘묵시적 명령’이라는 관념(notion)과 같은 의심을 불러일으킨다.

모든 국제적 의무가 구속되는 당사자의 동의에서 생겨난다는 주장에 대한 상세한 검토는 여기서 수행할 수 없지만, 이 교설에 대한 두 가지 명료하고 중요한 예외들은 주목되어야 한다. 첫째는 신생국가의 경우이다. 1932년의 이라크와 1948년의 이스라엘처럼 새롭고 독립적인 국가가 존재로 출현할 때, 그 국가는 그중에서도 조약들에 구속력을 부여하는 규칙들을 포함한 국제법의 일반 의무들에 구속된다는 점은 결코 의문시된 적이 없다. 여기서 신생국가의 국제적 의무들을 ‘묵시적’ 또는 ‘추론된’ 동의에 기초시키려는 시도는 완전히 빈약해 보인다. 둘째는 국가가 영토를 획득하거나 어떤 다른 변화를 겪고, 그 변화가 이전에는 그 국가가 준수하거나 위반할 기회도 없었고 동의를 주거나 보류할 계기도 없었던 규칙들 아래에서 처음으로 의무들의 귀속양상(incidence)을 가져오는 경우이다. 이전에 바다에 접근할 수 없던 국가가 해양 영토를 획득한다면, 이것이 그 국가를 영해와 공해에 관한 국제법의 모든 규칙들의 수범자로 만들기에 충분하다는 점은 분명하다. 이 밖에도 주로 일반 조약이나 다자 조약들이 비당사자들에게 미치는 효과와 관련된 더 논쟁적인 사례들이 있다. 그러나 이 두 중요한 예외들만으로도, 모든 국제적 의무가 자기부과적이라는 일반 이론이 사실들에 대한 존중은 너무 적고 추상적 독단에 지나치게 이끌려 왔다는 의심은 정당화하기에 충분하다.

4. 국제법과 도덕 (INTERNATIONAL LAW AND MORALITY)

(p. 227) 제V장에서 우리는 의무의 일차 규칙들만으로 이루어진 단순한 사회구조 형식을 검토하였고, 가장 작고 가장 긴밀하게 결속되어 있으며 고립된 사회들을 제외하면 그것이 중대한 결함들을 겪는다는 점을 보았다. 그러한 체제는 정태적이어야 하고, 그 규칙들은 성장과 쇠퇴의 느린 과정들에 의해서만 변경된다. 규칙들의 식별은 불확실해야 하고, 특정 사례들에서 그 규칙들의 위반 사실을 확인하는 일과 위반자들에게 사회적 압력을 적용하는 일은 우발적이고, 시간을 낭비하며, 약할 수밖에 없다. 우리는 국내법에 특징적인 승인, 변경, 재판의 이차 규칙들을 이러한 서로 다른 결함들에 대한 서로 다르지만 관련된 치유책들(remedies)로 파악하는 것이 해명적임을 발견하였다. 국제법은 형식상 그러한 일차 규칙들의 체제를 닮아 있다. 그럼에도 그 흔히 정교한 규칙들의 내용은 원시 사회의 규칙들과 매우 다르고, 그 개념들, 방법들, 기법들 가운데 많은 것은 현대 국내법의 그것들과 같다. 법리학자들은 매우 자주 국제법과 국내법 사이의 이러한 형식적 차이들이 전자를 ‘도덕(morality)’으로 분류함으로써 가장 잘 표현될 수 있다고 생각해 왔다. 그러나 이런 방식으로 차이를 표시하는 것은 혼란을 불러들이는 것으로 보임이 분명하다.

때로는 국가들 사이의 관계들을 규율하는 규칙들이 오직 도덕 규칙들일 뿐이라는 고집이, 위협으로 뒷받침된 명령들로 환원될 수 없는 모든 사회구조 형식은 오직 ‘도덕’의 한 형식일 수밖에 없다는 오래된 독단주의에서 영감을 받는다. 물론 ‘도덕’이라는 단어를 이처럼 매우 포괄적인 방식으로 사용하는 것은 가능하다. 그렇게 사용되면 그것은 게임, 클럽, 예절의 규칙들, 헌법과 국제법의 기본 규정들(provisions), 그리고 잔혹함, 부정직, 거짓말의 공통된 금지처럼 우리가 통상 도덕적인 것들로 생각하는 규칙들과 원칙들이 함께 들어갈 개념적 폐지통을 제공한다. 이 절차에 대한 반론은, 이렇게 ‘도덕’으로 함께 분류된 것들 사이에는 형식과 사회적 기능 양쪽에서 너무 중요한 차이들이 있어서, 그토록 조악한 분류로는 생각할 수 있는 어떤 실천적 또는 이론적 목적도 봉사될 수 없다는 것이다. 이렇게 인위적으로 넓혀진 도덕의 범주 안에서는, 그것이 흐리는 오래된 구별들을 새로 다시 확정해야 할 것이다.

(p. 228) 국제법의 특수한 경우에는 그 규칙들을 ‘도덕’으로 분류하는 데 저항할 여러 서로 다른 이유들이 있다. 첫째는 국가들이 종종 부도덕한 행위에 대해 서로를 비난하거나, 국제 도덕의 기준에 부응했다는 이유로 자신들이나 타국들을 칭찬한다는 점이다. 국가들이 보일 수도 있고 보이지 못할 수도 있는 미덕들 가운데 하나가 국제법을 준수하는 것임은 의심할 여지가 없지만, 그것이 그 법이 도덕이라는 뜻은 아니다. 실제로 도덕의 관점에서 국가들의 행위를 평가하는 일은, 국제법 규칙들 아래에서 청구들, 요구들, 권리들과 의무들의 인정들을 정식화하는 일과 식별 가능하게 다르다. 제IX장에서 우리는 사회적 도덕의 규정적 특징들(defining characteristics)로 취해질 수 있는 일정한 특징들을 열거하였다. 그 가운데에는 도덕 규칙들이 일차적으로 뒷받침되는 도덕적 압력의 독특한 형식이 있었다. 이것은 두려움에 대한 호소나 보복의 위협이나 보상 요구로 이루어지지 않고, 말이 건네진 사람이 문제된 도덕 원칙을 일단 상기하게 되면 죄책감이나 수치심에 이끌려 그것을 존중하고 잘못을 바로잡게(make amends) 될 수 있으리라는 기대 속에서 이루어지는 양심에 대한 호소로 이루어진다.

국제법 아래에서의 청구들은 이러한 용어들로 표현되지 않는다. 물론 국내법에서처럼 그것들은 도덕적 호소와 결합될 수 있다. 국가들이 국제법의 다툼 있는 사안들에 관하여 서로에게 제시하는, 흔히 기술적인 논변들에서 우세한 것은 선례들, 조약들, 법리학 저술들에 대한 참조들이다. 흔히 도덕적 옳음이나 그름, 좋음이나 나쁨에 대한 언급은 전혀 이루어지지 않는다. 따라서 베이징 정부가 포모사에서 국민당 세력들을 추방할 국제법 아래의 권리를 가지고 있 다거나 가지고 있지 않다는 주장은, 이것이 공정한지, 정의로운지, 또는 도덕적으로 좋은 일인지 나쁜 일인지의 질문과 매우 다르며, 특징적으로 서로 다른 논변들에 의해 뒷받침된다. 의심할 여지 없이 국가들 사이의 관계들에는, 사적 생활에서 인정되는 예의와 공손의 기준들과 유비적인, 분명히 법인 것과 분명히 도덕인 것 사이의 중간지대들이 있다. 개인적 사용을 위한 물품을 무관세로 받을 수 있도록 외교사절에게 확대된 특권에서 예시되는 국제 예양(international comity)의 영역이 그러하다.

더 중요한 구별 근거는 다음과 같다. 국제법의 규칙들은 국내법의 규칙들

처럼 (p. 229) 흔히 도덕적으로 상당히 무관하다. 하나의 규칙은 그것이 다루는 주제들에 관하여 어떤 명료하고 고정된 규칙을 가지는 것이 편리하거나 필수적이기 때문에 존재할 수 있지, 그 특정 규칙에 어떤 도덕적 중요성이 부착되기 때문에 존재하는 것은 아닐 수 있다. 그것은 가능했던 많은 규칙들 중 하나일 수 있고, 그중 어느 하나라도 똑같이 잘 기능했을 수 있다. 따라서 국내적·국제적 법규칙들은 흔히 많은 구체적 세부사항을 담고, 도덕 규칙들이나 원칙들 안의 요소들로서는 이해될 수 없을 자의적 구분들을 낳는다. 사회적 도덕의 가능한 내용에 관하여 우리가 독단적이어서는 안 된다는 점은 참이다. 제IX장에서 보았듯이 한 사회 집단의 도덕은 현대 지식의 빛에서 보면 터무니없거나(absurd) 미신적인 것으로 보일 수 있는 많은 명령을 포함할 수 있다. 그러므로 우리와 매우 다른 일반적 믿음을 가진 사람들이 도로의 오른쪽이 아니라 왼쪽으로 운전하는데 도덕적 중요성을 부착하게 되거나, 두 명의 증인이 지켜본 약속을 여기면 도덕적 죄책감을 느끼지만 한 명이 지켜본 경우에는 그러한 죄책감을 느끼지 않게 된다고 상상하는 것은 어렵지만 가능하다. 그러한 낯선 도덕들이 가능하더라도, 도덕은 그것을 따르는 이들이 일반적으로 대안들보다 결코 더 선호할 만하지 않고 아무 내재적 중요성도 없다고 여기는 규칙들을 논리적으로 포함할 수 없다는 점은 여전히 참이다. 그러나 법은 도덕적으로 중요한 많은 것을 포함하기도 하지만, 바로 그러한 규칙들을 포함할 수 있고 실제로 포함한다. 따라서 도덕의 일부로 이해하기는 가장 어려운 자의적 구분들, 형식절차들(formalities), 고도로 구체적인 세부사항은 법의 자연스럽고 쉽게 이해되는 특징들이다. 도덕과 달리 법의 전형적 기능 가운데 하나는 확실성과 예측가능성을 극대화하고 청구들의 증명 또는 평가를 용이하게 하기 위해 바로 이러한 요소들을 도입하는 것이기 때문이다. 형식들과 세부사항에 대한 지나친 고려는 법으로 하여금 ‘형식주의’와 ‘법률주의’라는 비난을 얻게 했다. 그러나 이러한 악덕들이 법의 독특한 성질들 일부를 과장한 것임을 기억하는 것이 중요하다.

이 이유 때문에, 유효하게 작성된 유언장이 몇 명의 증인을 가져야 하는지를 도덕이 아니라 국내법체계가 말해 주기를 기대하듯이, 교전국 선박이 급유나 수리를 위해 (p. 230) 중립항에 머물 수 있는 날짜 수, 영해의 폭, 그것을 측정하는데 사용될 방법들과 같은 것들은 도덕이 아니라 국제법이 말해 주기를 기대한

다. 이 모든 것들은 법규칙들이 정하는 것이 필수적이고 바람직한 규정 사항들(provisions)이다. 그러나 그러한 규칙들이 몇몇 형식들 중 어느 것을 취해도 똑같이 괜찮을 수 있거나, 특정 목적들에 이르는 많은 가능한 수단들 가운데 하나로서만 중요하다는 감각이 유지되는 한, 그것들은 개인적 또는 사회적 삶에서 도덕에 특징적인 지위를 가지는 규칙들과 구별되어 남아 있다. 물론 국제법의 모든 규칙들이 이런 형식적이거나 자의적이거나 도덕적으로 중립적인 종류인 것은 아니다. 요점은 오직 법규칙들은 이런 종류일 수 있고 도덕 규칙들은 그럴 수 없다는 것이다.

국제법과 우리가 자연스럽게 도덕으로 생각하는 것 사이의 성격 차이에는 또 다른 측면이 있다. 일정한 실천들을 요구하거나 금지하는 법의 효과가 궁극적으로 한 집단의 도덕에 변화를 일으키는 것일 수는 있지만, 도덕 규칙들을 만들거나 폐지하는 입법부라는 관념(notion)은, 제VII장에서 보았듯이, 부조리한 것이다. 입법부는 자기 *fiat*에 의해 새 규칙을 도입하고 그것에 도덕 규칙의 지위를 부여할 수 없다. 같은 수단으로 한 규칙에 전통의 지위를 부여할 수 없는 것과 마찬가지로이다. 다만 왜 그러한지는 두 경우에서 같지 않을 수 있다. 따라서 도덕은 단지 입법부를 결여하거나 우연히 입법부를 가지지 않는 것이 아니다. 인간의 입법적 *fiat*에 의한 변경이라는 바로 그 관념이 도덕이라는 관념에 배치된다. 우리가 도덕을 인간 행위들, 입법적 행위들이든 그 밖의 행위들이든 그것들을 평가하는 궁극적 기준으로 파악하기 때문에 그러하다. 국제법과의 대조는 명료하다. 국제법의 본성이나 기능 안에는 그 규칙들이 입법적 변경의 대상이 될 수 있다는 관념과 유사하게 비일관적인 것이 없다. 입법부의 결여는 많은 이들이 언젠가 수선되어야 할 결함으로 생각하는 바로 그런 결여일 뿐이다.

끝으로 우리는 국제법 이론에서, 제IX장에서 비판된 논변, 곧 국내법의 특정 규칙들이 도덕과 충돌할 수 있더라도 체계 전체는 그 규칙들에 복종할 도덕적 의무가 있다는 일반적으로 확산된 확신에 기초해야 하며, 이것은 특별한 예외적 사례들에서만 압도될 수 있다는 논변과의 병행성을 주목해야 한다. 국제법의 ‘토대들(foundations)’에 관한 논의에서, (p. 231) 최종적으로 국제법의 규칙들은 그것들에 복종할 도덕적 의무가 있다는 국가들의 확신에 기초해야 한다고 자주 말해져 왔다. 그러나 이것이 국가들이 인정하는 의무들이 공적으로 조직

된 제재들에 의해 집행가능하지 않다는 것 이상을 뜻한다면, 그것을 받아들일 이유는 없어 보인다. 물론 한 국가가 국제법에 의해 요구되는 어떤 행위 과정을 도덕적으로 의무적인 것으로 여겼고 그 이유로 행위했다고 우리가 말하는 것을 확실히 정당화할 상황들을 생각할 수 있다. 예컨대 조약들에 대한 신뢰가 심하게 흔들리면 인류에게 명백한 해악이 따를 것이기 때문에, 또는 자신이 그 차례에 타인들에게 부담이 떨어졌을 때 과거에 이익을 얻었던 규약(code)의 성가신 부담들을 짊어지는 것이 공정할 뿐이라는 감각 때문에, 한 국가는 부담스러운 조약의 의무들을 계속 이행할 수 있다. 도덕적 확신에 관한 그러한 사안들에서 정확히 누구의 동기들, 생각들(thoughts), 감정들이 국가에 귀속되어야 하는지는 여기서 우리를 붙들어 둘 필요가 없는 질문이다.

그러나 그러한 도덕적 의무의 감각이 있을 수 있다 하더라도, 국제법의 존재 조건으로 그것이 왜 또는 어떤 의미에서 반드시 존재해야 하는지 보기는 어렵다. 국가들의 실천에서 일정한 규칙들이 일정한 희생을 대가로 하면서도 반복적으로 일양적인 존중을 받는다는 점, 그것들을 참조하여 청구들이 정식화된다는 점, 규칙들의 위반은 위반자를 중대한 비판에 노출시키고 보상 또는 보복에 대한 청구들을 정당화하는 것으로 여겨진다는 점은 분명하다. 이것들은 확실히 국가들 사이에 그들에게 의무들을 부과하는 규칙들이 존재한다는 진술을 뒷받침하는 데 요구되는 모든 요소들이다. 어떤 사회에서 ‘구속력 있는’ 규칙들이 존재한다는 입증은, 단순히 그것들이 그러한 것으로 생각되고, 말해지고, 기능한다는 것이다. ‘토대들’의 방식으로 무엇이 더 요구되며, 더 요구된다면 왜 그것은 도덕적 의무의 토대여야 하는가? 물론 압도적 다수가 규칙들을 수용하고 그것들의 유지에 자발적으로 협력하지 않는 한, 규칙들은 국가들 사이의 관계에서 존재하거나 기능할 수 없다는 것은 참이다. 또한 규칙들을 깨뜨리거나 깨뜨리겠다고 위협하는 이들에게 행사되는 압력은 흔히 비교적 약하고, 대체로 탈중심화되어 있거나 조직화되어 있지 않다는 점도 참이다. 그러나 훨씬 더 강하게 강제적인 국내법체계를 자발적으로 수용하는 개인들의 경우와 마찬가지로, 그러한 체계를 자발적으로 지지하는 동기들은 극도로 다양할 수 있다. 어떤 (p. 232) 형식의 법질서든 그것에 부합하는 것이 도덕적으로 의무적이라는 감각이 일반적으로 퍼져 있을 때 가장 건강할 수는 있다. 그럼에도 법에 대한 고수(adherence)

는 그것에 의해 동기부여되지 않을 수 있고, 장기적 이익의 계산이나 전통을 계속하려는 바람, 또는 타인들에 대한 사심 없는 관심에 의해 동기부여될 수 있다. 개인들 사이에서든 국가들 사이에서든, 이들 중 어느 하나를 법의 존재에 필요한 조건으로 식별할 좋은 이유는 없어 보인다.

5. 형식과 내용의 유비들 (ANALOGIES OF FORM AND CONTENT)

순진한 눈에는, 입법부, 강제관할권을 가진 법원들, 공적으로 조직된 제재들을 결여한 국제법의 형식적 구조가 국내법의 그것과 매우 달라 보인다. 그것은 우리가 말했듯이 내용에서는 전혀 아니지만 형식에서는 일차법 또는 관습법의 단순한 체제를 닮아 있다. 그러나 어떤 이론가들은 국제법이 ‘법’ 이라고 불릴 자격(title)을 회의론자에 맞서 방어하려는 초조함 속에서, 이러한 형식적 차이들을 최소화하고 국제법 안에서 입법이나 국내법의 다른 바람직한 형식적 특징들과 관련하여 발견될 수 있는 유비들을 과장하려는 유혹에 굴복하였다. 그래서 패전국이 영토를 양도하거나, 의무들을 부담하거나, 어떤 축소된 독립 형식을 받아들이는 조약으로 끝나는 전쟁은 본질적으로 입법적 행위라고 주장되어 왔다. 입법처럼 그것은 부과된 법적 변경이기 때문이다. 오늘날 이 유비에 감명받거나, 그것이 국제법도 국내법과 동등하게 ‘법’ 이라고 불릴 자격(title)을 가진다는 점을 보이는 데 도움이 된다고 생각할 사람은 거의 없을 것이다. 국내법과 국제법 사이의 두드러진 차이들 가운데 하나는, 전자는 보통 폭력으로 강취된 합의들의 유효성을 인정하지 않지만 후자는 인정한다는 점이기 때문이다.

‘법’ 이라고 불릴 자격(title)이 그것들에 달려 있다고 생각하는 이들은 여러 다른, 더 존중할 만한 유비들을 강조해 왔다. 국제사법재판소와 그 전신인 상설국제사법재판소의 판결들이 거의 모든 사례에서 당사자들에 의해 제대로 이행되어 왔다는 사실은, 국내법 법원들과 대조적으로 어떤 국가도 그 사전 동의 없이는 이러한 국제재판소들 앞에 세워질 수 없다는 사실을 그것이 어떻게든 상쇄하는 것처럼 자주 강조되어 왔다. 또한 국내법에서 제재로서 법적으로 규율되고 공적으로 집행되는 (p. 233) 힘의 사용과 ‘탈중심화된 제재들’, 곧

국제법 아래의 자기 권리들이 타국에 의해 침해되었다고 주장하는 국가가 전쟁이나 무력 보복에 의존하는 것 사이에서도 유비들이 발견되어 왔다. 어느 정도 유비가 있다는 것은 명백하다. 그러나 그 의미는, 국내법 법원은 ‘자력구제’의 옳음과 그름을 조사하고 그것에 그르게 의존한 일을 처벌할 강제관할권을 가지는 반면, 어떤 국제법원도 유사한 관할권을 가지지 않는다는 똑같이 명백한 사실에 비추어 평가되어야 한다.

이 의심스러운 유비들 중 일부는 국가들이 유엔 헌장 아래에서 부담한 의무들에 의해 훨씬 강화된 것으로 여겨질 수 있다. 그러나 여기서도, 그 강도에 대한 어떤 평가도, 종이 위에서는 훌륭한 헌장의 법집행 규정들(provisions)이 거부권 및 강대국들의 이념적 분열과 동맹들에 의해 마비되어 온 정도를 무시한다면 거의 가치가 없다. 때로 국내법의 법집행 규정들(provisions)도 총파업에 의해 마비될 수도 있다고 답해지지만, 이것은 거의 설득력 있지 않다. 국내법과 국제법 사이의 비교에서 우리는 사실상 존재하는 것에 관심을 가지며, 여기서 사실들은 부인할 수 없이 다르기 때문이다.

그러나 국제법과 국내법 사이에 제안된 하나의 형식적 유비는 여기서 어느 정도 검토할 가치가 있다. 켈젠과 많은 현대 이론가들은 국내법처럼 국제법도 ‘기초규범(basic norm)’, 또는 우리가 승인 규칙이라고 부른 것을 가지고 있고 기실 가져야만 한다고 고집한다. 체계의 다른 규칙들의 유효성은 그것을 참조하여 평가되며, 규칙들은 그것 덕분에 단일한 체계를 구성한다는 것이다. 반대 견해는 이러한 구조의 유비가 거짓이라는 것이다. 국제법은 단지 이러한 방식으로 통합되어 있지 않은, 분리된 의무의 일차 규칙들의 집합(set)으로 이루어져 있다는 것이다. 국제법은 국제법학자들의 통상 용어로, 조약들에 구속력을 부여하는 규칙이 그중 하나인 관습 규칙들의 집합이다. 그 과제에 착수한 이들이 국제법의 ‘기초규범’을 정식화하는 데 매우 큰 어려움을 발견했다는 것은 잘 알려져 있다. 이 지위의 후보들에는 *pacta sunt servanda* 원칙이 포함된다. 그러나 이것은, 그 용어를 아무리 넓게 해석하더라도 국제법 아래의 모든 (p. 234) 의무들이 ‘*pacta*’에서 생겨나는 것은 아니라는 사실과 양립하지 않는 것으로 보이기 때문에, 대부분의 이론가들에 의해 포기되었다. 그래서 그것은 덜 친숙한 어떤 것, 곧 이른바 ‘국가들은 자신들이 관습적으로 행위해

온 대로 행위해야 한다' 는 규칙으로 대체되었다.

우리는 국제법의 기초규범에 관한 이러한 공식화들과 다른 경쟁적 공식화들의 이점들(merits)을 논의하지 않을 것이다. 그 대신 우리는 국제법이 그러한 요소를 반드시 포함해야 한다는 가정을 문제 삼을 것이다. 여기서 물어야 할 첫 질문이자 어쩌면 마지막 질문은 이것이다. 왜 우리는 이러한 선험적 가정, 곧 그것은 바로 선험적 가정인데, 그것을 하고 그리하여 국제법 규칙들의 실제 성격을 선취 판단해야 하는가? 구성원들에게 의무들을 부과하는 규칙들을 '구속력 있는' 것으로 삼아 살아가는 사회가, 그러한 규칙들을 어떤 더 기초적인 규칙에 의해 통합되거나 그 규칙에서 유효성을 도출하는 것이 아니라 단순히 분리된 규칙들의 집합으로 여길 수 있다는 것은 확실히 상상 가능하다. 어쩌면 그런 경우가 자주 있었을 수도 있다. 규칙들의 단순한 존재가 그러한 기초규칙의 존재를 수반하지 않는다는 것은 분명하다. 대부분의 현대 사회에는 예절 규칙들이 있고, 우리는 그것들이 의무들을 부과한다고 생각하지 않지만 그러한 규칙들이 존재한다고 말할 수 있다. 그러나 우리는 분리된 규칙들의 유효성이 도출될 수 있는 예절의 기초규칙을 찾지 않을 것이며, 찾을 수도 없을 것이다. 그러한 규칙들은 체계를 형성하지 않고 단순한 집합을 형성한다. 물론 예절보다 더 중요한 사안들이 걸려 있는 곳에서 이러한 사회통제 형식의 불편들은 상당하다. 그것들은 이미 제V장에서 서술되었다. 그러나 규칙들이 실제로 행위 기준들로 수용되고, 의무적 규칙들에 특징적인 적절한 형식의 사회적 압력에 의해 뒷받침된다면, 그것들이 구속력 있는 규칙들임을 보이기 위해 더 요구되는 것은 없다. 비록 이 단순한 사회구조 형식에서는 국내법에서 우리가 가지는 것, 곧 체계의 어떤 궁극적 규칙을 참조하여 개별 규칙들의 유효성을 논증하는 방식을 가지지 못하더라도 그러하다.

물론 체계가 아니라 단순한 집합을 구성하는 규칙들에 대해서도 우리가 물을 수 있는 여러 질문들이 있다. 예컨대 우리는 그것들의 역사적 기원에 관한 질문들이나 규칙들의 성장을 촉진한 인과적 영향들에 관한 질문들을 물을 수 있다. 또한 우리는 그것들에 따라 살아가는 이들에게 그 규칙들이 가지는 가치, 그리고 그들이 자신들을 그 규칙들에 복종하도록 도덕적으로 구속된 것으로 여기는지 (p. 235) 아니면 어떤 다른 동기에서 복종하는지를 물을 수 있다. 그러

나 더 단순한 경우에는, 국내법이 그러하듯 기초규범 또는 이차적 승인 규칙에 의해 풍부해진 체계의 규칙들에 관하여 물을 수 있는 한 종류의 질문을 물을 수 없다. 더 단순한 경우 우리는 이렇게 물을 수 없다. ‘분리된 규칙들은 그 유효성 또는 “구속력(binding force)”을 체계의 어떤 궁극적 규정(provision)으로부터 도출하는가?’ 그러한 규정이 없고, 있을 필요도 없기 때문이다. 그러므로 기초규칙 또는 승인 규칙이 의무의 규칙들 또는 ‘구속력 있는’ 규칙들의 존재에 일반적으로 필요한 조건이라고 상정하는 것은 오류이다. 이것은 필수성이 아니라 사치이며, 그 구성원들이 분리된 규칙들을 하나씩 받아들이게 될 뿐 아니라 일반적 유효성 기준들에 의해 확정된 규칙들의 일반 부류들을 미리 수용하기로 결속되어 있는 발전된 사회체계들에서 발견된다. 더 단순한 사회 형식에서는 한 규칙이 규칙으로 수용되는지 아닌지를 기다려 보아야 한다. 기초적 승인 규칙을 가진 체계에서는 규칙이 실제로 만들어지기 전에, 그것이 승인 규칙의 요건들에 부합한다면 유효할 것이라고 말할 수 있다.

같은 요점은 다른 형식으로 제시될 수 있다. 그러한 승인 규칙이 분리된 규칙들의 단순한 집합에 추가될 때, 그것은 체계의 이점들과 식별의 용이성을 함께 가져올 뿐 아니라, 처음으로 진술의 새로운 형식을 가능하게 한다. 이것들은 규칙들의 유효성에 관한 내부 진술들이다. 우리는 이제 새로운 의미에서 ‘체계의 어떤 규정(provision)이 이 규칙을 구속력 있게 만드는가?’ 또는 켈젠의 언어로 ‘체계 안에서 그것의 유효성의 근거는 무엇인가?’ 라고 물을 수 있기 때문이다. 이 새로운 질문들에 대한 답들은 기초적 승인 규칙에 의해 제공된다. 그러나 더 단순한 구조에서 규칙들의 유효성이 어떤 더 기초적인 규칙을 참조하여 어떻게 논증될 수 없다고 하더라도, 이것은 규칙들이나 그 구속력 또는 유효성에 관하여 설명되지 않은 채 남겨지는 어떤 질문이 있다는 뜻이 아니다. 그러한 단순한 사회구조에서 규칙들이 왜 구속력 있는지에 관한 어떤 신비가 있고, 우리가 기초규칙을 찾을 수만 있다면 그것이 그 신비를 해소할 것이라는 말이 아니다. 단순한 구조의 규칙들은, 더 발전된 체계들의 기초규칙처럼, 수용되고 그러한 것으로 기능한다면 구속력 있다. 그러나 서로 다른 사회구조 형식들에 관한 이러한 단순한 진리들은, 이러한 바람직한 요소들이 사실상 발견되지 않는 곳에서 통일성과 (p. 236) 체계에 대한 완고한 탐색에 의해 쉽게 가려질 수 있다.

기실 기초규칙 없이 존재하는 가장 단순한 사회구조 형식들을 위해 기초 규칙을 만들어 내려고 기울이는 노력에는 우스꽝스러운 점이 있다. 그것은 마치 별거벗은 야만인이 정말로는 어떤 보이지 않는 종류의 현대적 의복을 입고 있어야 한다고 우리가 고집하는 것과 같다. 불행히도 여기에는 상존하는 혼동 가능성도 있다. 우리는 관련 사회, 개인들의 사회이든 국가들의 사회이든, 그것이 일정한 행위 기준들을 의무적 규칙들로 준수한다는 단순한 사실을 텅 빈 반복으로 말하는 어떤 것을 기초규칙으로 다루도록 설득될 수 있다. 국제법에 대해 제안되어 온 기묘한 기초규범, 곧 ‘국가들은 자신들이 관습적으로 행위해 온 대로 행위해야 한다’는 바로 이런 지위를 가지는 것이 분명하다. 그것은 일정한 규칙들을 수용하는 이들이 그 규칙들이 준수되어야 한다는 규칙도 준수해야 한다는 것 이상을 말하지 않기 때문이다. 이것은 규칙들의 집합이 국가들에 의해 구속력 있는 규칙들로 수용된다는 사실의 단순하고 무익한 중복일 뿐이다.

다시, 국제법은 기초규칙을 포함해야 한다는 가정으로부터 우리가 해방되고 나면, 직면해야 할 질문은 사실의 질문이다. 국가들 사이의 관계들에서 기능하는 규칙들의 실제 성격은 무엇인가? 관찰될 현상들에 관한 서로 다른 해석들은 물론 가능하다. 그러나 여기서 제출되는 견해는, 국제법의 규칙들에 대한 일반적 유효성 기준들을 제공하는 기초규칙은 없고, 실제로 작동하는 규칙들은 체계가 아니라 규칙들의 집합을 구성하며, 그 가운데 조약들의 구속력을 마련하는 규칙들이 있다는 것이다. 많은 중요한 사안들에서 국가들 사이의 관계들이 다자조약들에 의해 규율되고, 이것들이 당사자가 아닌 국가들도 구속할 수 있다고 때때로 논변되는 것은 사실이다. 이것이 일반적으로 인정된다면, 그러한 조약들은 사실상 입법적 제정물들이 될 것이고 국제법은 그 규칙들에 대한 독자적인 유효성 기준들을 가지게 될 것이다. 그때에는 체계의 실제 특징을 나타내고 규칙들의 집합이 사실상 국가들에 의해 준수된다는 사실의 공허한 재진술 이상이 될 기초적 승인 규칙이 정식화될 수 있을 것이다. 아마 국제법은 현재 이것 및 구조상 그것을 국내체계에 더 가까워지게 할 다른 형식들의 수용으로 향하는 이행 단계에 있을지도 모른다. 만일, (p. 237) 그리고 이 이행이 완료될 때에는, 현재로서는 빈약하고 심지어 기만적으로 보이는 형식적 유비들이 실질을 획득할 것이며, 국제법의 법적 ‘성질(quality)’에 관한 회의론자의

마지막 의문들은 그때 잠재워질 수 있다. 그 단계에 도달할 때까지 유비들은 분명 형식의 유비들이 아니라 기능과 내용의 유비들이다. 기능의 유비들은 우리가 국제법이 도덕과 다른 방식들을 성찰할 때 가장 명료하게 나타나며, 그 일부를 우리는 앞 절에서 검토하였다. 내용의 유비들은 국내법과 국제법 모두에 공통되고 법률가들의 기법을 한쪽에서 다른 쪽으로 자유롭게 이전 가능하게 만드는 원칙들, 개념들, 방법들의 범위에 있다. ‘국제법’이라는 표현의 발명자인 벤담은 그것이 국내법과 ‘충분히 유비적’이라고 말하는 것만으로 그 표현을 방어하였다.¹ 여기에 두 가지 언급을 덧붙일 가치가 있을 수 있다. 첫째, 그 유비는 형식의 유비가 아니라 내용의 유비라는 것, 둘째, 이 내용의 유비에서 국제법의 규칙들만큼 국내법에 가까운 다른 사회 규칙들은 없다는 것이다.

¹*Principles of Morals and Legislation*, XVII. 25, n. 1.

제10장 주석

214쪽. ‘국제법은 정말 법인가?’ — 이것이 단지 사실문제로 오인된 언어적 질문에 불과하다는 견해는 Glanville Williams, 앞서 인용, 22 *BYBIL* (1945)을 참조하라.

215쪽. 의문의 원천들(Sources of doubt). — 건설적인 일반적 개관으로는 A. H. Campbell, ‘International Law and the Student of Jurisprudence’ in 35 *Grotius Society Proceedings* (1950); Gihl, ‘The Legal Character and Sources of International Law’ in *Scandinavian Studies in Law* (1957)을 참조하라.

216쪽. ‘국제법은 어떻게 구속력 있을 수 있는가?’ — 이 질문(때로는 국제법의 구속력(binding force)의 문제로 지칭됨)은 Fischer Williams, *Chapters on Current International Law*, pp. 11–27; Brierly, *The Law of Nations*, 제5판 (1955), 제2장; *The Basis of Obligation in International Law* (1958), 제1장에서 제기된다. 또한 Fitzmaurice, ‘The Foundations of the Authority of International Law and the Problem of Enforcement’ in 19 *MLR* (1956)을 참조하라. 이 저자들은 규칙들의 체계가 구속력 있다(또는 구속력 있지 않다)는 단언의 의미를 명시적으로 논의하지 않는다.

217쪽. 국제법에서의 제재(Sanctions). — 국제연맹 규약(League of Nations Covenant) 제16조 하에서의 상황은 Fischer Williams, ‘Sanctions under the Covenant’ in 17 *BYBIL* (1936)을 참조하라. 유엔 헌장 제7장 하에서의 제재에 관해서는 Kelsen, ‘Sanctions in International Law under the Charter of U.N.’, 31 *Iowa LR* (1946), 그리고 Tucker, ‘The Interpretation of War under present International Law’, 4 *The International Law Quarterly* (1951)을 참조하라. 한국전쟁에 대해서는 Stone, *Legal Controls of International Conflict* (1954), 제9장, 담론 14(Discourse 14)를 참조하라. ‘평화를 위한 단결(유엔총회 결의)’ 이 유엔이 ‘마비되었다(paralyzed)’ 는 주장을 반박하는 것이라는 해석도 가능하다.

220쪽. 의무적인 것으로 생각되고 말해지는 국제법. — Jessup, *A Modern Law of Nations*, 제1장, 그리고 ‘The Reality of International Law’, 118 *Foreign Affairs* (1940)을 참조하라.

220쪽. 국가들의 주권(The Sovereignty of States). — ‘주권은 단지 국제 영역 중 법에 의해 국가들의 개별 행위에 남겨진 만큼에 부여된 이름일 뿐이다’ 라는 견해에 대한 명료한 설명은 Fischer Williams, 앞서 인용, pp. 10–11, 285–99, *Aspects of Modern International Law*, pp. 24–26, 그리고 Van Kleffens, ‘Sovereignty and International Law’, *Recueil des Cours* (1953), I, pp. 82–83을 참조하라.

221쪽. 국가(The State). — ‘국가(state)’라는 관념(notion)과 종속국가들(dependent states)의 유형에 대해서는 Brierly, *The Law of Nations*, 제4장을 참조하라.

224쪽. 의사주의(voluntarist) 및 자기제한(auto-limitation) 이론들. — 주요 저자들로 는 Jellinek, *Die Rechtliche Natur der Staatsverträge*; Triepel, ‘Les Rapports entre le droit interne et le droit internationale’, *Recueil des Cours* (1923)이 있다. 극단적인 견해는 Zorn, *Grundzüge des Völkerrechts*에 나타나며, 이에 대한 비판적 논의는 Gihl, 앞서 인용, *Scandinavian Studies in Law* (1957); Starke, *An Introduction to International Law*, 제 1장; Fischer Williams, *Chapters on Current International Law*, pp. 11-16을 참조하라.

224쪽. 의무(obligation)와 동의(consent). — 어떤 국제법 규칙도 한 국가의 사전 동의, 명시적이든 묵시적이든 그러한 동의 없이는 그 국가에 구속력 있지 않다는 견해는 영국 법원들에서 표현되었으며(*R. v. Keyn* 1876, 2 Ex. Div. 63, ‘The Franconia’ 사건 참조), 상설국제사법재판소에서도 표현되었다. 이에 관해서는 *The Lotus*, PCIJ Series A, No. 10을 참조하라.

226쪽. 신생국 및 해양영역을 획득한 국가들. — 이에 대해서는 Kelsen, *Principles of International Law*, pp. 312-13을 참조하라.

226쪽. 비당사자들(non-parties)에 대한 일반 국제조약들의 효과. — 이에 대해서는 Kelsen, 앞서 인용, pp. 345 ff.; Starke, 앞서 인용, 제1장; Brierly, 앞서 인용, 제7장, pp. 251-2를 참조하라.

227쪽. ‘도덕(morality)’이라는 용어의 포괄적 사용. — 이에 대해서는 Austin, *The Province* 제5강(Lecture V), pp. 125-9, 141-2에서 ‘실정 도덕(positive morality)’에 관한 논의를 참조하라.

230쪽. 국제법에 복종할 도덕적 의무(moral obligation). — 이것이 국제법의 ‘토대(the foundation)’라고 보는 견해는 Lauterpacht, Brierly의 *The Basis of Obligation in International Law* 서문(xviii), 그리고 Brierly, 같은 책 제1장을 참조하라.

232쪽. 힘에 의해 부과된 조약을 입법으로 보는 것. — 이에 대해서는 Scott, ‘The Legal Nature of International Law’, *American Journal of International Law* (1907), pp. 837, 862-4를 참조하라. 일반 조약들을 ‘국제 입법(international legislation)’이라고 부르는 통상적 서술에 대한 비판은 Jennings, ‘The Progressive Development of International Law and its Codification’, 24 *BYBIL* (1947), p. 303에서 확인할 수 있다.

233쪽. 탈중심화된 제재들(decentralized sanctions). — 이에 대해서는 Kelsen, 앞서

인용, p. 20; Tucker, 앞서 인용, *4 International Law Quarterly* (1951)을 참조하라.

233쪽. 국제법의 기초규범(basic norm). — 이를 *pacta sunt servanda*로 공식화한 논의는 Anzilotti, *Corso di diritto internazionale* (1923), p. 40을 참조하라. 이를 ‘국가들은 자신들이 관습적으로 행위해 온 대로 행위해야 한다’는 식으로 대체하려는 논의는 Kelsen, *General Theory*, p. 369, 그리고 *Principles of International Law*, p. 418을 참조하라. 이에 대한 중요한 비판적 논의는 Gihl, *International Legislation* (1937) 및 *Scandinavian Studies in Law* (1957), pp. 62 ff.에 있다. 국제법에 기초규범이 없다는 해석을 보다 충분히 전개한 논의로는 Ago, ‘Positive Law and International Law’, *51 American Journal of International Law* (1957), *Scienza giuridica e diritto internazionale* (1958)을 참조하라. Gihl은 국제사법재판소 규정 제38조에도 불구하고 국제법은 법의 형식적 원천들을 갖지 않는다고 결론짓는다. 국제법에 대해 하나의 ‘초기 가설(initial hypothesis)’을 정식화하려는 시도로서, 본문에서 제기된 것과 유사한 비판들에 열려 있는 것으로 보이는 견해는 Lauterpacht, *The Future of Law in the International Community*, pp. 420–3을 참조하라.

237쪽. 국제법과 국내법 사이의 내용의 유비(analogy of content). — 이에 대해서는 Campbell, 앞서 인용, *35 Grotius Society Proceedings* (1950), p. 121 *ad fin.*, 그리고 조약들, 영토취득, 시효, 임대, 위임통치, 지역권(servitudes) 등에 관한 규칙들을 논의한 Lauterpacht, *Private Law Sources and Analogies of International Law* (1927)을 참조하라.

제10장 제3판 주석

220–226쪽. 주권국가들과 국제법(Sovereign states and international law). 주권(sovereignty)과 국제법의 제약들(constraints)의 양립가능성에 관해서는 Timothy Endicott, 「The Logic of Freedom and Power」, Samantha Besson 및 John Tasioulas 편, *The Philosophy of International Law* (Oxford University Press, 2010)을 참조하라. 국가 주권(state sovereignty)과 법의 지배(rule of law) 간의 관계에 대해서는 Jeremy Waldron, 「The Rule of International Law」, (2006) *Harvard Journal of Law and Public Policy* 제 30권, 15쪽을 참조하라. 초국가적 권위(transnational authority)의 다양한 등장 형태들에 비추어 주권을 재해석하려는 시도들에 대해서는 Neil MacCormick, *Questioning Sovereignty*를 참조하라. 현대 세계에서 ‘주권적’ 국가들의 사실상의 권력(de facto power)에 대한 의문들에 대해서는 Saskia Sassen, *Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization* (Columbia University Press, 1996)을 참조하라.

227-232쪽. 국제법과 도덕 (International law and morality). 국제 영역에서 정의의 원칙들(principles of justice)의 적용에 대한 매우 영향력 있는 논의는 John Rawls, *The Law of Peoples* (Harvard University Press, 1999)을 참조하라. 또한 Allen Buchanan, *Justice, Legitimacy, and Self-Determination: Moral Foundations for International Law* (Oxford University Press, 2003)을 참조하라. 국가들이 오직 자국의 국익을 증진하기 위해서만 국제법을 준수하고(comply with), 또 준수해야 한다는 ‘현실주의(realist)’ 관점에 대해서는 Jack L. Goldsmith 및 Eric A. Posner, *The Limits of International Law* (Oxford University Press, 2005)를 참조하라.

232-237쪽. 형식과 내용의 유비들 (Analogies of form and content). Hart가 저술하던 시기에 비해 오늘날의 국제법은 더 체계화되었다는 시사에 대해서는 Samantha Besson 및 John Tasioulas가 편집한 *The Philosophy of International Law* 서문의 ‘Introduction’과 거기에서 인용된 원천들을 참조하라. 또한 Allen Buchanan 및 David Golove, 「Philosophy of International Law」 in Jules L. Coleman 및 Scott Shapiro 편, *The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law*를 참조하라.

후기 (POSTSCRIPT)

서론 (INTRODUCTORY)

(p. 238) 이 책이 처음 출판된 지 32년이 지났다. 그 이후 법리학(jurisprudence)과 철학은 훨씬 더 가까워졌고, 법이론(legal theory)이라는 주제는 이 나라와 미국 양쪽에서 크게 발전하였다. 학계의 법률가들과 철학자들 사이에서 이 책의 주요 교설들(doctrines)에 대한 비판자들이 그 교설들에 동조한 이들만큼이나 많았더라도, 나는 이 책이 이러한 발전을 자극하는 데 어느 정도 도움을 주었다고 생각하고 싶다. 어쨌든, 내가 원래 이 책을 영국 학부생 독자들을 염두에 두고 썼지만, 이 책은 훨씬 더 넓게 유통되었고 영어권 세계와 이 책의 번역본들이 나온 여러 나라에서 비판적 논평의 방대한 부차 문헌을 낳았다. 이 비판 문헌의 많은 부분은 법학 및 철학 저널의 논문들로 이루어져 있지만, 그 밖에도 이 책의 여러 교설들이 비판의 표적이자 비판자들 자신의 법이론 전개의 출발점으로 취급된 중요한 책들이 여럿 출판되었다.

나는 내 비판자들 가운데 몇몇, 특히 고 론 풀러 교수¹와 R. M. 드워킨 교수²를 향해 몇 발의 견제 사격을 가한 적은 있지만, 지금까지 그들 중 누구에게도 일반적이고 포괄적인 답변을 하지는 않았다. 나는 일부 비판자들이 (p. 239) 나와 달랐던 만큼이나 서로도 달랐던, 매우 유익한 계속 논쟁을 지켜보고 거기서 배우는 편을 선호했다. 그러나 이 후기에서는 드워킨이 *Taking Rights Seriously* (1977)와 *A Matter of Principle* (1985)에 수록된 여러 선구적 논문들 및 그의 책 *Law's Empire* (1986)³에서 제기한 광범위한 비판들 가운데 일부에 답하려고 한

¹그의 *The Morality of Law* (1964)에 대한 나의 서평을 보라, *Harvard Law Review* 제 78권 (1965) 1281면. 이 글은 *Essays in Jurisprudence and Philosophy* (1983)에도 재수록됨, 343면. [주: 대괄호로 표시된 각주는 편집자들이 추가한 것임.]

²나의 다음 글을 참조하라: “Law in the Perspective of Philosophy: 1776–1976”, *New York University Law Review* 제51권 (1976) 538면; “American Jurisprudence through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream”, *Georgia Law Review* 제11권 (1977) 969면; “Between Utility and Rights”, *Columbia Law Review* 제79권 (1979) 828면. 이들 모두 *Essays in Jurisprudence and Philosophy*에 재수록되어 있다. 또한, “Legal Duty and Obligation”, *Essays on Bentham* (1982)의 제6장, 그리고 R. Gavison 편, *Issues in Contemporary Legal Philosophy* (1987) 수록 “Comment” (35면)를 참조하라.

³이하에서는 각각 TRS, AMP, LE로 인용함.

다. 이 후기에서 나는 주로 드워킨의 비판들에 초점을 맞춘다. 그는 이 책의 거의 모든 독특한 테제들이 근본적으로 잘못되었다고 논변했을 뿐 아니라, 이 책에 암묵적으로 들어 있는 법이론의 전체 구상(conception)과 법이론이 무엇을 해야 하는지의 전체 구상을 문제 삼았기 때문이다. 이 책의 주요 주제들에 대한 드워킨의 논변들은 여러 해 동안 대체로 일관되었지만, 몇몇 논변들의 실질과 그것들이 표현되는 용어법 양쪽에는 중요한 변화들이 있었다. 그의 초기 논문들에서 두드러졌던 몇몇 비판들은, 명시적으로 철회되지는 않았지만, 그의 후기 작업에는 나타나지 않는다. 그러나 그러한 초기 비판들은 널리 통용되고 매우 영향력이 있으므로, 나는 그의 후기 비판들뿐 아니라 그것들에도 답하는 것이 적절하다고 생각했다. 이 후기의 첫째이자 더 긴 부분은 드워킨의 논변들을 다룬다. 그러나 둘째 부분에서는, 내 테제들 가운데 일부에 대한 나의 전개에 불명료함과 부정확성이 있을 뿐 아니라 어떤 지점들에서는 실제 비일관성과 모순도 있다는 여러 다른 비판자들의 주장들을 검토한다.⁴ 여기서 나는, 생각하고 싶지 않을 만큼 많은 경우에 내 비판자들이 옳았음을 인정해야 하며, 이 후기를 기회로 삼아 불명료한 것을 명료화하고 내가 원래 쓴 것 가운데 비일관적이거나 모순적인 곳을 수정하고자 한다.

1. 법이론의 본성 (THE NATURE OF LEGAL THEORY)

이 책에서 나의 목표는 일반적이면서도 기술적인(descriptive), 법이 무엇인가에 관한 이론을 제공하는 것이었다. 그것이 일반적이라는 것은, 그것이 어떤 특정 법체계나 법문화에 묶여 있지 않고, 규칙-지배적이고(rule-governed) 그 의미에서 ‘규범적(normative)’인 측면을 가진 복합적 사회·정치 제도로서의 법에 관하여 설명적이고 명료화하는 설명(account)을 제시하려 한다는 의미이다. 이 (p. 240) 제도는 서로 다른 문화와 서로 다른 시대의 많은 변이에도 불구하고 동일한 일반적 형식과 구조를 취해 왔지만, 명료화를 요구하는 많은 오해들과 흐리게 하는 신화들이 그 주변에 모여 있었다. 이 명료화 작업의 출발점은, 이 책 3쪽에서 내가 어느 교육받은 사람에게나 귀속시킨 근대적 국내법체계의 두드러

⁴[하트는 본 절에서 언급된 두 개 절 중 두 번째를 완성하지 못함. 편집자 주 참조.]

진 특징들에 관한 널리 퍼진 공통 지식이다. 나의 설명(account)은 도덕적으로 중립적이고 정당화적 목적들을 가지지 않는다는 점에서 기술적이다. 그것은 법에 관한 나의 일반적 설명에 나타나는 형식들과 구조들을 도덕적 근거 또는 다른 근거 위에서 정당화하거나 권장하려 하지 않는다. 다만 나는 이것들에 대한 명료한 이해가 법에 대한 어떤 유익한 도덕적 비판에도 중요한 예비 단계라고 생각한다.

이 기술적 기획을 수행하는 수단으로서, 내 책은 책무부와 규칙들(duty-imposing rules), 권한부여 규칙들(power-conferring rules), 승인 규칙들(rules of recognition), 변경 규칙들(rules of change), 규칙들의 수용(acceptance of rules), 내부 관점과 외부 관점(internal and external points of view), 내부 진술들과 외부 진술들(internal and external statements), 그리고 법적 유효성(legal validity) 같은 여러 개념들을 반복해서 사용한다. 이 개념들은 여러 법제도들과 법적 실천들이 해명적으로 분석될 수 있는 항들이 되는 요소들에 주의를 집중시키고, 이러한 제도들과 실천들에 관한 성찰이 촉발한 법의 일반적 본성에 관한 질문들에 대답들이 제시될 수 있게 한다. 여기에는 다음과 같은 질문들이 포함된다. 규칙들이란 무엇인가? 규칙들은 단순한 습관들이나 행위의 반복적 일양성들과 어떻게 다른가? 법규칙들에는 근본적으로 서로 다른 유형들이 있는가? 규칙들은 어떻게 관련될 수 있는가? 규칙들이 하나의 체계를 형성한다는 것은 무엇인가? 법규칙들과 그것들이 가진 권위는 한편으로 위협들과, 다른 한편으로 도덕적 요구사항들과 어떻게 관련되는가?⁵

이런 방식으로 기술적이면서 일반적인 것으로 구상된 법이론은, 드워킨이 법이론을, 또는 그가 자주 부르듯 ‘법리학(jurisprudence)’을, 부분적으로 평가적이고 정당화적이며 ‘특정 법문화에 향한(addressed to a particular legal culture)’ 것으로 보는 구상과 근본적으로 다른 기획이다.⁶ 그 법문화는 대개 이론가 자신의 법문화이고, 드워킨의 경우에는 영미법의 법문화이다. 이렇게 구상된 법이론의 중심 과제는 드워킨에 의해 ‘해석적(interpretive)’이라고 불

⁵H. L. A. Hart, “Comment”, 위의 Gavison 편, 주석 2, 35면.

⁶LE 102면.

리머⁷ 부분적으로 평가적이다. 왜냐하면 그것은 한 법체계의 확립된 법(settled law)과 법적 실천들에 가장 잘 ‘부합(fit)’ 하거나 그것들과 정합하는(cohere) 동시에 그것들에 대한 최선의 도덕적 정당화를 제공하는 (p. 241) 원칙들을 식별하는 데, 그리하여 법을 ‘그 최선의 빛 아래’ 보이는 데 있기 때문이다.⁸ 드워킨에게 이렇게 식별된 원칙들은 법에 관한 이론의 일부일 뿐 아니라 법 자체의 암시적 부분들이기도 하다. 그래서 그에게 “법리학은 재판(adjudication)의 일반적 부분이며, 법에 의한 어떤 결정(any decision at law)에나 붙는 침묵의 서곡”이다.⁹ 그의 초기 작업에서 그러한 원칙들은 단순히 “법에 관한 가장 건전한 이론(the soundest theory of law)”으로 지칭되었지만,¹⁰ 그의 최신 작업인 *Law's Empire*에서 그는 이러한 원칙들과 그것들에서 따라 나오는 특정 법명제들(propositions of law)을 ‘해석적 의미’에서의 법으로 특징짓는다. 그러한 해석이론이 해석해야 할 확립된 법적 실천들 또는 법의 전형들(paradigms)은 드워킨에 의해 ‘전해석적(preinterpretive)’이라고 불리며,¹¹ 이론가는 그러한 전해석적 자료들을 식별하는 데 어려움도 없고 수행해야 할 이론적 과제도 없는 것으로 여겨진다. 그것들은 특정 법체계들의 법률가들의 일반적 합의의 문제로 확립되어 있기 때문이다.¹²

나 자신의 법이론 구상과 드워킨의 법이론 구상처럼 그렇게 서로 다른 기획들 사이에 왜 중대한 충돌이 있어야 하는지, 또는 기실 있을 수 있는지는 분명하지 않다. 따라서 *Law's Empire*를 포함한 드워킨 작업의 많은 부분은, 법, 곧 ‘과거의 정치적 결정들’¹³이 강제를 정당화하는 방식에 관한 세 가지 서로 다른 설명들의 비교상 이점들을 정교하게 전개하는 데 바쳐져 있으며, 그로부터 그가 ‘관행주의(conventionalism)’, ‘법적 실용주의(legal pragmatism)’, ‘통합성으로서의 법(law as integrity)’이라고 부르는 세 가지 서로 다른 법이론 형식들이

⁷ LE 제3장.

⁸ LE 90면.

⁹ LE 90면.

¹⁰ TRS 66면.

¹¹ LE 65-66면.

¹² 그러나 드워킨은 그러한 전해석적 법(preinterpretive law)을 식별하는 일 자체가 해석을 수반할 수 있다고 경고한다. LE 66면 참조.

¹³ LE 93면.

나온다.¹⁴ 그가 이 세 유형의 이론에 관해 쓰는 모든 것은 평가적·정당화적 법리학에 대한 기여로서 큰 흥미와 중요성을 가진다. 나는, 이 책에서 제시된 것과 같은 실증주의적 법이론이 그러한 해석이론으로 해명적으로 재진술될 수 있다고 그가 주장하는 한을 제외하고, 이러한 해석적 관념들을 그가 전개한 것에 이의를 제기하려는 것이 아니다.¹⁵ 이 후자의 주장은 (p. 242) 내 견해로는 잘못되었으며, 아래에서 내 이론의 그러한 해석적 판본에 반대하는 이유들을 제시한다.

그러나 드워킨은 그의 책들에서 일반적이고 기술적인 법이론을 잘못 이끌린 것이거나, 기껏해야 단순히 쓸모없는 것으로 배제하는 듯하다. 그는 “유용한 법이론들”은 “역사적으로 발전하는 실천의 특정 단계에 대한 해석”이라고 말하며,¹⁶ 이전에는 “기술(description)과 평가(evaluation) 사이의 평면적 구별(flat distinction)”이 “법이론을 약화시켰다”고 썼다.¹⁷

나는 드워킨이 기술적 법이론, 또는 그가 자주 부르듯 ‘법리학’을 거부하는 정확한 이유들을 따라가기 어렵다. 그의 중심 반론은, 법이론은 하나의 법체계 안의 내부자 또는 참여자의 관점인 법에 대한 내부 관점(internal perspective)을 고려해야 하며, 참여자의 관점이 아니라 외부 관찰자의 관점을 가진 기술 이론으로는 이 내부 관점에 대한 적절한 설명이 제공될 수 없다는 것처럼 보인다.¹⁸ 그러나 내 책에서 예시된 기술적 법리학의 기획에는, 비참여자 외부 관찰자가 참여자들이 그러한 내부 관점에서 법을 바라보는 방식들을 기술하는 일을 배제하는 것이 사실상 전혀 없다. 그래서 나는 이 책에서 참여자들이 법을 자기 행위에 대한 지침들과 비판 기준들을 제공하는 것으로 수용함으로써 자신의

¹⁴LE 94면.

¹⁵그러나 일부 비평가들, 예컨대 Michael Moore는 “The Interpretive Turn in Modern Theory: A Turn for the Worse?”, *Stanford Law Review* 제41권 (1989) 871면에서 947-948면, 드워킨의 의미에서 법실천이 해석적이라는 점에는 동의하면서도, 법이론은 해석적일 수 없다고 주장한다.

¹⁶LE 102면. 또한, “우리에게 법의 일반 이론들은 우리 자신의 사법 실천에 대한 일반 해석들이다”라는 진술도 비교하라. LE 410면.

¹⁷AMP 148면. 또한, “‘법이론들은 사회적 실천에 대한 중립적 설명들로 ... 합당하게 이해될 수 없다’”는 진술도 비교하라. Ronald Dworkin, “A Reply by Ronald Dworkin”, Marshall Cohen 편, *Ronald Dworkin and Contemporary Jurisprudence* (1983), 이하 RDC로 인용, 247면 중 254면.

¹⁸[LE 13-14면 참조.]

내부 관점을 드러낸다고 상당히 길게 설명했다. 물론 기술적 법이론가는 그러한 자격으로는 참여자들이 이러한 방식으로 법을 수용하는 것을 스스로 공유하지 않는다. 그러나 그는 그러한 수용을 기술할 수 있고 또 기술해야 하며, 기실 나는 이 책에서 그렇게 하려고 시도하였다. 이 목적을 위해 기술적 법이론가는 내부 관점을 채택한다는 것이 무엇인지 이해해야 하고, 그러한 제한된 의미에서 그는 내부자의 자리에 자신을 둘 수 있어야 한다는 것은 참이다. 그러나 이것은 법을 수용하거나, 내부자의 내부 관점을 공유하거나 지지(endorse)하거나, 어떤 다른 방식으로든 자신의 기술적 입장을 포기하는 것이 아니다.

드워킨은 기술적 법리학에 대한 자신의 비판에서, 외부 관찰자가 참여자의 내부 관점을 이런 기술적 방식으로 고려할 수 있다는 (p. 243) 이 명백한 가능성을 배제하는 듯하다. 앞서 말했듯이 그는 법리학을 ‘재판(adjudication)의 일반적 부분’ 과 동일시하고, 이것은 법리학 또는 법이론 자체를 그 사법적 참여자들의 내부 관점에서 보인 한 체계의 법의 일부로 취급하는 것이기 때문이다. 그러나 기술적 법이론가는 법에 관한 내부자의 내부 관점을 채택하거나 공유하지 않고도 그것을 이해하고 기술할 수 있다. 설령 (닐 매코믹¹⁹과 많은 다른 비판자들이 논변했듯이) 행위 지침들과 비판 기준들을 제공하는 것으로 법을 수용하는 데서 드러나는 참여자의 내부 관점이, 법의 요구사항들에 부합할 도덕적 이유들이 있고 법의 강제 사용에 대한 도덕적 정당화가 있다는 믿음도 필연적으로 포함한다 하더라도, 이것 역시 도덕적으로 중립적인 기술적 법리학이 기록할 것이지 지지하거나 공유할 것은 아니다.

그러나 드워킨이 ‘해석적’ 이라고 부르는 부분적으로 평가적인 쟁점들이 법리학과 법이론의 유일하게 적절한 쟁점들이 아니며 일반적이고 기술적인 법리학에도 중요한 자리가 있다는 나의 주장에 대해, 그는 이것이 그렇다는 점을 인정하였다. 그리고 그는 ‘법리학은 재판의 일반적 부분’ 이라는 자신의 관찰들과 같은 것들이 한정될 필요가 있다고 설명하였다. 그가 이제 말하듯, 이것은 오직 ‘뜻의 문제(question of sense)에 관한 법리학에 대해서만 참’ 이기 때문이다.²⁰ 이것은 법이론의 유일하게 적절한 형식은 해석적이고 평가적인

¹⁹[*Legal Reasoning and Legal Theory* (1978), 63-64면 및 139-140면 참조.]

²⁰R. M. Dworkin, “Legal Theory and the Problem of Sense”, R. Gavison 편, *Issues*

것이라는 과도하고, 기실 드워킨 자신이 표현했듯 ‘제국주의적’인 주장으로 보였던 것에 대한 중요하고 환영할 만한 교정이다.

그러나 드워킨이 이제 자신의 겉보기에 제국주의적인 주장의 철회와 결부시킨 다음의 주의를 주는 말들(cautionary words)의 함의는 나에게 여전히 매우 당혹스럽다. “그러나 하트의 것과 같은 일반 이론들이 주로 논의해 온 쟁점들에서 그 [뜻의] 문제가 얼마나 널리 퍼져 있는지를 강조할 가치가 있다.”²¹ 이 주의의 관련성은 분명하지 않다. 내가 논의한 쟁점들(위 p. 240의 목록 참조)에는 (p. 244) 한편으로 강제적 위협들과, 다른 한편으로 도덕적 요구사항들과 법의 관계 같은 질문들이 포함된다. 드워킨의 주의의 요점은, 그러한 쟁점들을 논의할 때 기술적 법이론가조차 법명제들(propositions of law)의 뜻(sense) 또는 의미(meaning)에 관한 질문들에 직면해야 하며, 이 질문들은 해석적이고 부분적으로 평가적인 법이론에 의해서만 만족스럽게 답될 수 있다는 것처럼 보인다. 이것이 정말 사실이라면, 어떤 주어진 법명제의 뜻을 결정하기 위해 기술적 법이론가조차 “이 명제가 확립된 법에 가장 잘 부합하고 그것을 가장 잘 정당화하는 원칙들에서 따라 나오려면, 이 명제에는 어떤 의미가 배정되어야 하는가?”라는 해석적이고 평가적인 질문을 묻고 답해야 할 것이다. 그러나 내가 언급한 종류의 질문들에 대한 답을 찾는 일반적이고 기술적인 법이론가가 많은 서로 다른 법체계들에서 법명제들의 의미를 결정해야 한다는 것이 참이라 하더라도, 이것이 드워킨의 해석적이고 평가적인 질문을 묻는 일에 의해 결정되어야 한다는 견해를 받아들일 이유는 없어 보인다. 더구나 일반적이고 기술적인 법이론가가 고려해야 하는 모든 법체계들의 판사들과 법률가들 자신이 사실상 의미의 질문들을 이러한 해석적이고 부분적으로 평가적인 방식으로 확정한다고 하더라도, 이것은 그러한 법명제들의 의미에 관한 자기의 일반적 기술적 결론들을 기초 지을 하나의 사실로서 일반적 기술 이론가가 기록해야 할 일일 것이다. 이러한 결론들이 그렇게 기초 지어졌다는 이유로, 그 결론들 자체가 해석적이고 평가적이어야 하며, 그것들을 제시하면서 이론가가 기술의 과제에서 해석과 평가의 과제로 옮겨 갔다고 상정하는 것은 물론 중대한 오류일

in *Contemporary Legal Philosophy: The Influence of H. L. A. Hart* (1987), 19면.

²¹앞 인용과 동일.

것이다. 기술(description)은 기술되는 것이 평가(evaluation)일 때에도 여전히 기술일 수 있다.

2. 법실증주의의 본성 (THE NATURE OF LEGAL POSITIVISM)

(i) 의미론적 이론으로서의 실증주의 (Positivism as a Semantic Theory)

내 책은 드워킨에 의해 현대 법실증주의의 대표작으로 취급된다. 이 현대 법실증주의는 주로 벤담과 오스틴의 명령 이론들(imperative theories of law)과, 모든 법이 법적으로 무제한적인 주권적 입법 (p. 245) 인격 또는 기관으로부터 나온다는 그들의 구상을 거부한다는 점에서 그들 같은 초기 판본들과 구별된다. 드워킨은 나의 법실증주의 판본에서 서로 다르지만 관련된 많은 오류들을 발견한다. 이 오류들 가운데 가장 근본적인 것은, 법적 권리들과 법적 책무들(legal duties)을 서술하는 법명제들(propositions of law) 같은 것들의 참은 개인적 믿음들과 사회적 태도들에 관한 사실들을 포함한 명백한 역사적 사실에 관한 질문들에만 의존한다는 견해이다.²² 법명제들의 참이 의존하는 사실들은 드워킨이 ‘법의 근거들(grounds of law)’ 이라고 부르는 것을 구성하며,²³ 그에 따르면 실증주의자는 이것들이 판사들과 법률가들이 공유하는 언어 규칙들에 의해 고정되어 있다고 잘못 받아들인다. 이 언어 규칙들은 ‘law’ 라는 단어가 특정 체계의 특정 쟁점에 관한 ‘당해 법(the law)’ 이 무엇인지에 대한 진술들에 나타날 때와 ‘법(law)’, 곧 일반적 법이 무엇인지에 관한 진술들에 나타날 때 모두 그 단어의 사용, 따라서 의미를 지배한다고 한다.²⁴ 이러한 실증주의적 법관에 따르면, 법문제들(questions of law)에 관해 있을 수 있는 유일한 의견불일치들은 그러한 역사적 사실들의 존재 또는 부존재에 관한 것들이며, 무엇이 법의 ‘근거들’ 을 구성하는지에 관한 이론적 의견불일치나 논쟁은 있을 수 없게 된다.

드워킨은 법실증주의 비판의 많은 해명적 지면을, 무엇이 법의 근거들을 구성하는지에 관한 이론적 의견불일치가 실증주의자의 견해와 반대로 영미법

²²LE 6면 이하.

²³LE 4면.

²⁴LE 31면 이하.

실천들의 두드러진 특징임을 보이는 데 할애한다. 법률가들과 판사들이 공유하는 언어 규칙들에 의해 그것들이 논쟁의 여지 없이 고정되어 있다는 견해에 맞서, 드워킨은 그것들이 본질적으로 논쟁적이라고 주장한다. 그 가운데에는 역사적 사실들뿐 아니라 매우 자주 논쟁적인 도덕 판단들과 가치 판단들도 있기 때문이다.

드워킨은 나 같은 실증주의자들이 어떻게 이 근본적으로 잘못된 견해를 채택하게 되었는지에 관한 매우 다른 두 설명을 제시한다. 이 설명들 가운데 첫째에 따르면, 실증주의자들은 법의 근거들이 규칙들에 의해 논쟁의 여지 없이 고정되어 있지 않고 이론적 의견불일치를 허용하는 논쟁적 사안이라면, 'law'라는 단어가 서로 다른 사람들에게 서로 다른 것을 뜻하게(mean) 될 것이고, 그 단어를 사용하면서 그들은 같은 것에 관해 소통하는 것이 아니라 서로 빗나가 말하게 될 것이라고 믿는다. 이렇게 실증주의자에게 귀속된 믿음은 드워킨의 견해로는 전적으로 잘못된 것이며, 그는 (p. 246) 실증주의자가 그것에 기초한다고 상정되는 논쟁적 법의 근거들에 대한 논변을 '의미론적 독침(semantic sting)' ²⁵이라고 부른다. 그것이 'law'라는 단어의 의미에 관한 이론에 기초하기 때문이다. 그래서 그는 *Law's Empire*에서 이 '의미론적 독침'을 뽑아내고자 했다.

*Law's Empire*의 첫 장에서 나는 오스틴과 함께 의미론적 이론가로 분류되고, 그래서 'law'라는 단어의 의미에서 명백한-사실 실증주의적 법이론을 도출하며 의미론적 독침을 겪는 것으로 분류된다. 그러나 실제로 내 책이나 내가 쓴 다른 어떤 것에도 내 이론에 관한 그러한 설명을 뒷받침하는 것은 없다. 따라서 발전된 국내법체계들이 법원들이 적용해야 하는 법들의 식별 기준들을 특정하는 승인 규칙을 포함한다는 나의 교설은 틀릴 수 있지만, 나는 어디에서도 이 교설을 모든 법체계들 안에는 그러한 승인 규칙이 있어야 한다는 것이 'law'라는 단어의 의미의 일부라는 잘못된 관념에 기초시키지 않았고, 법의 근거들의 식별 기준들이 논쟁의 여지 없이 고정되어 있지 않다면 'law'가 서로 다른 사람들에게 서로 다른 것을 뜻하게 될 것이라는 훨씬 더 잘못된 관념에 기초시키지도 않았다.

기실 내게 귀속된 이 마지막 논변은 한 개념의 의미와 그 개념의 적용 기준들

²⁵LE 45면.

을 혼동한다. 나는 이것을 받아들이기는커녕 정의(justice)의 개념을 설명하면서 이 책 160쪽에서, 일정한 의미를 가진 개념의 적용 기준들이 달라질 수도 있고 논쟁적일 수도 있다는 사실에 명시적으로 주의를 환기했다. 이것을 명료하게 하기 위해 나는 사실상 드워킨의 후기 작업에서 그토록 두드러지게 나타나는 개념(concept)과 한 개념의 서로 다른 구상들(conceptions) 사이의 바로 그 구별을 그었다.²⁶

마지막으로 드워킨은 또한, 실증주의자가 자신의 법이론이 의미론적 이론이 아니라 복합적 사회현상으로서 일반적 법의 독특한 특징들에 관한 기술적 설명이라고 주장하는 것은, 의미론적 이론과의 대비를 제시하지만 그 대비는 공허하고 오도적이라고 고집한다. 그의 논변²⁷은, 사회현상으로서 법의 독특한 특징들 가운데 하나가 법률가들이 법명제들의 참을 논쟁하고 (p. 247) 이것을 그러한 명제들의 의미를 참조하여 ‘설명한다’는 것이므로, 그러한 기술적 법이론은 결국 의미론적이어야 한다는 것이다.²⁸ 이 논변은 내게는 ‘law’의 의미와 법명제들의 의미를 혼동하는 것으로 보인다. 법에 관한 의미론적 이론은, ‘law’라는 단어의 바로 그 의미가 법을 일정한 특정 기준들에 의존하게 만든다는 이론이라고 드워킨에 의해 말해진다. 그러나 법명제들은 전형적으로 ‘law’가 무엇인지가 아니라 당해 법(the law)이 무엇인지, 곧 어떤 체계의 법이 사람들에게 무엇을 하도록 허용하거나, 요구하거나, 권한을 부여하는지에 관한 진술들이다. 그러므로 그러한 법명제들의 의미가 정의들이나 진리조건들에 의해 결정된다 하더라도, 이것은 ‘law’라는 단어의 바로 그 의미가 법을 일정한 특정 기준들에 의존하게 만든다는 결론으로 이어지지 않는다. 그러한 경우가 되려면 한 체계의 승인 규칙이 제공하는 기준들과 그러한 규칙의 필요성이 ‘law’라는 단어의 의미에서 도출되어야 할 것이다. 그러나 내 작업에는 그러한 교설의 흔적이 전혀 없다.²⁹

²⁶이 구분에 대해서는 John Rawls, *A Theory of Justice* (1971), 5-6, 10면 참조. [Rawls는 정의 개념(concept of justice)과 정의의 구상들(conceptions of justice)을 구분하면서 “나는 H. L. A. Hart의 *The Concept of Law*... 155-159면을 따른다”고 명시함. *A Theory of Justice* 5면 각주 1 참조.]

²⁷LE 418-419면, 주석 29.

²⁸LE 31-33면 참조.

²⁹본서 209면 참조. 이곳에서 나는 그러한 교설을 명시적으로 거부하고 있다.

드워킨이 나의 법실증주의 형식을 잘못 제시하는 또 하나의 측면이 있다. 그는 나의 승인 규칙 교설을, 승인 규칙이 법의 식별을 위해 제공하는 기준들이 오직 역사적 사실들로만 이루어져야 한다고 요구하는 것으로, 그래서 ‘명백한-사실 실증주의(plain-fact positivism)’의 한 사례로 취급한다.³⁰ 그러나 승인 규칙이 제공하는 기준들에 관해 내가 든 주된 예들이, 드워킨이 ‘계보(pedigree)’라고 부른 사항들, 곧 법들이 법제도들에 의해 채택되거나 창설되는 방식에만 관련되고 그 내용에는 관련되지 않는 사항들인 것은 사실이지만,³¹ 나는 이 책(72쪽)과 앞선 논문 「실증주의와 법과 도덕의 분리(Positivism and the Separation of Law and Morals)」 양쪽에서, 미국에서처럼 어떤 법체계들에서는 법적 유효성의 궁극적 기준들이 계보뿐 아니라 정의 원칙들이나 실체적 도덕 가치들(substantive moral values)을 명시적으로 편입할 수도 있고, 이것들이 법적 헌법적 제약들의 내용을 형성할 수도 있다고 명시적으로 진술했다.³² *Law's Empire*에서 드워킨이 내게 ‘명백한-사실’ 실증주의를 귀속시키는 것은 내 이론의 이 측면을 무시하는 것이다. 그러므로 (p. 248) 그가 내게 귀속시키는 명백한-사실 실증주의의 ‘의미론적’ 판본은 분명 내 것이 아니며, 내 이론은 어떤 형식의 명백한-사실 실증주의도 아니다.

(ii) 해석적 이론으로서의 실증주의 (Positivism as an Interpretive Theory)

드워킨의 명백한-사실 실증주의에 대한 둘째 설명은 그것을 의미론적 이론이나 언어적 고려들에 기초한 것으로 다루지 않고, 그가 ‘관행주의(conventionalism)’라고 부르는 드워킨식 해석이론의 한 형식으로 재구성하려고 시도한다. 이 이론, 곧 드워킨이 결국 결함 있는 것으로 거부하는 이론에 따르면, 실증주의자는 법을 최선의 빛 아래 보이는 데 전념하는 해석 이론가라는 외양 아래에서, 법의 기준들을 명백한 사실들로 이루어진 것으로 제시한다. 다만 이 사실들은 의미론적 판본에서처럼 법의 어휘에 의해 고정되는 것이 아니라, 판사들과 법률가들이

³⁰[이 표현은 하트 자신의 것이며, LE에는 등장하지 않음.]

³¹TRS 17면.

³²*Harvard Law Review* 제71권 (1958) 598면. *Essays on Jurisprudence and Philosophy*에도 재수록. 특히 54-55면 참조.

공유하는 확신에 의해 논쟁의 여지 없이 고정된다. 이것은 법을 수범자들에게 큰 가치가 있는 어떤 것을 확보해 주는 것으로 보임으로써 법에 유리한 빛을 던진다. 곧 법적 강제와 계기들이 모두에게 이용 가능한 명백한 사실들에 의존하도록 만들어, 강제가 사용되기 전에 모두가 공정한 경고를 받을 수 있게 한다는 것이다. 드워킨은 이것을 ‘보호된 기대들의 이상(the ideal of protected expectations)’이라고 부르지만,³³ 그에게 그 이점들은 결국 그 여러 결함들을 능가하지 않는다.

그러나 관행주의로서의 실증주의에 관한 이 해석주의적 설명은 내 법이론의 그럴듯한 판본이나 재구성으로 제시될 수 없다. 두 가지 이유에서 그렇다. 첫째, 내가 이미 말했듯이 내 이론은 명백한-사실 실증주의 이론이 아니다. 법의 기준들 가운데 ‘명백한’ 사실들뿐 아니라 가치들도 인정하기 때문이다. 둘째, 그리고 더 중요하게, 드워킨의 해석적 법이론은 그 모든 형식에서 법과 법적 실천의 요점 또는 목적이 강제를 정당화하는 것이라는 전제에 기초해 있지만,³⁴ 법이 이것을 자신의 요점 또는 목적으로 가진다는 것은 결코 내 견해가 아니며 그런 적도 없다. 다른 실증주의 형식들처럼 내 이론은 법과 법적 실천들 그 자체의 요점 또는 목적을 식별한다고 주장하지 않는다. 그러므로 법의 목적이 강제 사용을 정당화하는 것이라는 드워킨의 견해, 내가 결코 공유하지 않는 그 견해를 뒷받침하는 것은 내 이론 안에 없다. (p. 249) 사실 나는 법 그 자체가 봉사하는 더 특정한 목적을, 인간 행위에 대한 지침들과 그러한 행위에 대한 비판 기준들을 제공하는 것 너머에서 찾는 것은 매우 헛되다고 생각한다. 물론 이것은 같은 일반적 목적들을 가진 다른 규칙들이나 원칙들로부터 법들을 구별하는 데에는 충분하지 않을 것이다. 법의 독특한 특징들은 그 기준들의 식별, 변경, 집행을 위해 이차 규칙들을 통해 마련하는 장치와, 다른 기준들에 대한 우선성(priority)을 내세우는 일반적 주장에 있다. 그러나 내 이론이 법적 강제와 계기들에 대한 사전 고지가 일반적으로 이용 가능하리라는 점을 보증함으로써 기대들을 보호하는 관행주의 형식의 명백한-사실 실증주의에 전적으로 결속되어 있다 하더라도, 이것은 오직 내가 이것을 법이 가진 특정한 도덕적

³³ LE 117면.

³⁴ [LE 93면.]

이점(moral merit)으로 본다는 것만을 보여 줄 뿐, 법 그 자체의 전체 목적이 이것을 제공하는 것임을 보여 주지는 않을 것이다. 법적 강제의 계기들은 주로 그 수범자들의 행위를 인도하는 법의 일차적 기능이 무너진 경우들이므로, 법적 강제는 물론 중요한 사안이지만 부차적 기능이다. 그것의 정당화는 법 그 자체의 요점 또는 목적으로 온당하게 취급될 수 없다.

법적 강제는 그것이 “관행적 이해들(conventional understandings)에 부합할 때”³⁵에만 정당화된다는 주장을 하는 관행주의적 해석이론으로 내 법이론을 재구성하려는 드워킨의 이유들은, 이 책 제V장 제3절의 ‘법의 요소들(Elements of Law)’에 관한 내 설명에 기초한다. 거기서 나는 승인, 변경, 재판의 이차 규칙들을, 오직 의무의 일차 규칙들만으로 이루어진 상상된 단순한 체제의 결함들에 대한 치유책들(remedies)로 제시한다. 이 결함들은 규칙들의 동일성에 관한 불확실성, 규칙들의 정태적 성질, 그리고 규칙들이 오직 분산된 사회적 압력에 의해서만 집행될 때의 시간낭비적 비효율성이다. 그러나 이러한 이차 규칙들을 그러한 결함들에 대한 치유책들로 제시하면서도, 나는 어디에서도 법적 강제가 이러한 규칙들에 부합할 때에만 정당화된다고 주장하지 않았고, 더더욱 그러한 정당화의 제공이 일반적 법의 요점 또는 목적이라고 주장하지 않았다. 기실 이차 규칙들에 관한 논의에서 내가 강제를 언급하는 유일한 대목은 규칙들의 집행을 (p. 250) 법원들이 운용하는 조직화된 제재들 대신 분산된 사회적 압력에 맡기는 일의 시간낭비적 비효율성에 관한 것이다. 그러나 분명 비효율성에 대한 치유책은 정당화가 아니다.

물론 의무의 일차 규칙들의 체제에 이차적 승인 규칙이 추가되면, 개인들이 강제의 계기들을 사전에 식별할 수 있게 하는 경우가 많으므로, 강제 사용에 대한 하나의 도덕적 반론을 배제한다는 의미에서 그 사용을 정당화하는 데 도움이 될 것이다. 그러나 승인 규칙이 가져올 법의 요구사항들에 관한 확실성과 사전 지식은 강제가 문제되는 경우에만 중요한 것이 아니다. 그것은 예컨대 유언장을 작성하거나 계약을 체결할 행위능력으로 나타나는 법적 권한들의 지성적 행사와, 일반적으로 사적·공적 삶의 지성적 계획에도 똑같이 핵심적이다. 그러므로 승인 규칙이 기여하는 강제의 정당화는 그 승인 규칙의 일반적 요점

³⁵LE 429면 주석 3.

또는 목적으로 제시될 수 없고, 더더구나 법 전체의 일반적 요점 또는 목적으로 제시될 수 없다. 내 이론에는 그것이 그럴 수 있다고 시사하는 것이 없다.

(iii) 연성 실증주의 (Soft Positivism)

드워킨은 내게 ‘명백한-사실 실증주의’ 교설을 귀속시키면서, 내 이론을 승인 규칙의 존재와 권위가 법원들에 의한 그 수용이라는 사실에 의존해야 한다고 요구하는 것으로는, 실제로 그렇듯이, 취급했을 뿐 아니라, 그 규칙이 제공하는 법적 유효성 기준들이 그가 ‘계보(pedigree)’ 사항들이라고 부르는, 법의 창설 또는 채택의 방식과 형식에 관한 특정한 종류의 명백한 사실로만 이루어져야 한다고 요구하는 것으로도, 실제로는 그렇지 않은데, 취급하였다. 이것은 이중으로 잘못되었다. 첫째, 그것은 승인 규칙이 법적 유효성 기준들로서 도덕 원칙들 또는 실체적 가치들(substantive values)에 대한 부합(conformity)을 편입할 수 있다는 나의 명시적 인정을 무시한다. 따라서 내 교설은 이른바 ‘연성 실증주의(soft positivism)’ 이지, 드워킨의 그 판본에서처럼 ‘명백한-사실’ 실증주의가 아니다. 둘째, 승인 규칙이 제공하는 명백한-사실 기준들이 오직 계보 사항들일 수밖에 없다고 시사하는 것은 내 책에 전혀 없다. 그것들은 대신 종교의 설립이나 투표권 제한에 관한 미국 헌법 제16 수정조항 또는 제19 수정조항처럼 입법 내용에 대한 실체적 제약들(substantive constraints)일 수 있다.

그러나 이 답변은 드워킨의 가장 기본적인 비판들에 답하지 못한다. (p. 251) 연성 실증주의의 어떤 형식을 채택한 다른 이론가들에게 답하면서,³⁶ 그는 그것이 타당하다면 내 이론에도 적용되어 여기서 답을 요구할 중요한 비판들을 제기했기 때문이다.

드워킨의 가장 근본적인 비판은, 법의 식별이 도덕 판단 또는 다른 가치 판단에 대한 부합이라는 논쟁적 사안들에 의존할 수 있도록 허용하는 연성 실증주의와, 논쟁적 도덕 논변들에 의존하지 않고 명백한 사실의 문제들로서 확실하게 식별될 수 있는 신뢰할 만한 공적 행위 기준들을 제공하는 데 법이 본질적으로 관련되어 있다는 일반 실증주의적 ‘그림(picture)’ 사이에 깊은 비

³⁶E. P. Soper와 J. L. Coleman에 대한 드워킨의 응답을 *RDCJ* 247면 이하, 252면 이하에서 볼 수 있음.

일관성이 있다는 것이다.³⁷ 연성 실증주의와 내 이론의 나머지 부분 사이의 그러한 비일관성을 입증하기 위해 드워킨은, 다른 결함들 가운데서도 상상된 전법적(pre-legal) 관습-유형 의무 일차 규칙 체제의 불확실성을 치유하는 것으로 승인 규칙을 설명한 내 설명을 인용할 것이다. 연성 실증주의에 관한 이 비판은 내게는 일관된 실증주의자가 법적 기준들의 한 집합에 귀속해야 한다고 보는 확실성의 정도와, 법적 유효성 기준들이 특정 도덕 원칙들이나 가치들에 대한 부합을 포함할 경우 생길 불확실성 양쪽 모두를 과장하는 것으로 보인다. 승인 규칙의 중요한 기능 하나가 법이 확인될 수 있는 확실성을 증진하는 것임은 물론 참이다. 승인 규칙이 법에 대해 도입한 검사 기준들이 어떤 사례들에서 논쟁적 쟁점들을 제기할 뿐 아니라 모든 사례 또는 대부분의 사례에서 그렇게 한다면, 그것은 이 기능을 수행하지 못할 것이다. 그러나 다른 가치들의 측면에서 어떤 대가를 치르더라도 모든 불확실성을 배제하는 것은 내가 승인 규칙을 위해 생각해 본 목표가 아니다. 이는, 승인 규칙 자체뿐 아니라 그것을 참조하여 식별되는 특정 법규칙들도 다룰 수 있는 불확실성의 ‘반음영(penumbra)’을 가질 수 있다는 내 명시적 진술에 의해서도, 내가 바랐듯이, 분명해진다.³⁸ 또한 법들이 그 의미에 관해 생길 수 있는 모든 가능한 질문들을 미리 확정할 수 있도록 틀 지어질 수 있다 하더라도, 그러한 법들을 채택하는 것은 법이 소중히 여겨야 할 다른 목적들과 자주 충돌할 것이라는 나의 일반 논변도 있다.³⁹ 예견되지 않은 사례의 구성이 알려지고 그 결정에서 걸린 쟁점들이 식별되어 합리적으로 확정될 수 있도록, 많은 법규칙들의 경우 일정한 불확실성의 여지는 (p. 252) 용인되어야 하며 기실 환영되어야 한다. 승인 규칙의 확실성-제공 기능을 최우선적이고 압도적인 것으로 취급할 때에만, 논쟁적일 수 있는 도덕 원칙들이나 가치들에 대한 부합을 법의 기준들 가운데 포함하는 연성 실증주의의 형식이 비일관적인 것으로 간주될 수 있을 것이다. 여기서 바탕에 있는 질문은, 법체계가 일반적으로 신뢰할 수 있고 사전에 식별 가능한 확정적 행위 지침들을 제공함으로써 탈중심화된 관습-유형 규칙 체제로부터 어떤 유의미한 진전을 이루려면, 어느

³⁷ RDCJ 248면.

³⁸ 본서 123면, 147-154면 참조.

³⁹ [본서 128면 참조.]

정도 또는 범위의 불확실성을 용인할 수 있는가에 관한 것이다.

나의 연성 실증주의 판본의 일관성에 대한 드워킨의 둘째 비판은 법의 확정성(determinacy)과 완전성(completeness)에 관한 서로 다르고 더 복잡한 쟁점들을 제기한다. 이 책에서 전개된 내 견해는, 승인 규칙이 제공하는 기준들에 의해 일반적 항들로 식별되는 법규칙들과 법원칙들이 내가 자주 ‘개방적 직조(open texture)’ 라고 부르는 것을 종종 가진다는 것이다. 그래서 주어진 규칙이 특정 사례에 적용되는지가 문제될 때, 법은 어느 쪽의 답도 확정하지 못하고 따라서 부분적으로 불확정적인 것으로 드러난다. 그러한 사례들은 단지 합리적이고 식견 있는 법률가들이 어느 답이 법적으로 올바른지에 관하여 의견불일치할 수 있다는 의미에서 논쟁적인 ‘어려운 사례들’ 일 뿐 아니라, 그러한 경우 법은 근본적으로 불완전하다. 그것은 그러한 사례들에서 쟁점이 된 질문들에 아무 답도 제공하지 않는다. 그것들은 법적으로 규율되지 않으며, 그러한 사례들에서 결정에 이르기 위해 법원들은 내가 ‘재량(discretion)’ 이라고 부르는 제한된 법창출 기능을 행사해야 한다. 드워킨은 법이 이런 방식으로 불완전할 수 있고 그러한 법창출 재량의 행사로 채워질 틈들을 남길 수 있다는 관념을 거부한다. 그는 이 견해가, 법적 권리 또는 법적 책무의 존재를 단언하는 법명제가 논쟁적일 수 있고 따라서 합리적이고 식견 있는 사람들이 의견을 달리할 수 있으며, 그들이 의견을 달리할 때 그것이 참인지 거짓인지를 확정적으로 논증할 방법이 자주 없다는 사실에서 나온 잘못된 추론이라고 생각한다. 그러한 추론이 잘못된 것은, 법명제가 이렇게 논쟁적일 때에도 그럼에도 그것을 참 또는 거짓으로 만드는 ‘사안의 사실들(facts of the matter)’ 이 있을 수 있고, (p. 253) 그 참이나 거짓을 논증할 수 없더라도 그것이 참이라는 논변들이 그것이 거짓이라는 논변들보다 더 나은 것으로 평가될 수 있으며, 그 반대도 가능하기 때문이다. 논쟁적인 법과 불완전하거나 불확정적인 법 사이의 이 구별은 드워킨의 해석이론에 상당히 중요하다. 그 이론에 따르면 법명제는 다른 전제명제들과 결합하여, 법체계의 제도적 역사에 가장 잘 부합하고 그것에 대한 최선의 도덕적 정당화도 제공하는 원칙들에서 따라 나올 때에만 참이기 때문이다. 그러므로 드워킨에게 어떤 법명제의 참은 궁극적으로 무엇이 가장 잘 정당화하는지에 관한 도덕 판단의 참에 의존하며, 그에게 도덕 판단들은 본질적으로 논쟁적이므로 모든 법명제들도

그러하다.

드워킨에게, 적용이 논쟁적인 도덕 판단을 포함하는 법적 유효성 기준이라는 관념은 이론적 어려움을 전혀 제시하지 않는다. 그의 견해에서는 그것이 여전히 이미 존재하는 법(pre-existing law)에 대한 진정한 검사 기준(test)일 수 있다. 그 논쟁적 성격은 그것을 참으로 만드는 사실들, 많은 경우 도덕적 사실들이 존재한다는 점과 완전히 양립 가능하기 때문이다.

그러나 법적 유효성 기준이 부분적으로 도덕적 검사 기준일 수 있음을 허용하는 연성 실증주의는, 드워킨의 주장에 따르면, 위 pp. 251-252에서 이미 논의한 것에 더해 둘째 비일관성에 연루된다. 그것은 법이 확실하게 식별 가능하다는 실증주의적 ‘그림’과 비일관적일 뿐 아니라, 법명제들의 ‘객관적 지위(objective standing)’⁴⁰를 도덕 판단들의 지위에 관한 어떤 논쟁적 철학 이론에 대한 결속으로부터도 독립시키려는, 그가 실증주의자들에게 귀속시키는 바람과도 비일관적이다. 도덕적 검사 기준이 이미 존재하는 법에 대한 검사 기준일 수 있으려면, 도덕 판단들이 참이 되는 객관적 도덕 사실들이 있어야 한다. 그러나 그러한 객관적 도덕 사실들이 있다는 것은 논쟁적 철학 이론이다. 그러한 사실들이 없다면, 도덕적 검사 기준을 적용하라는 말을 들은 판사는 이것을 오직, 법체계가 이에 부과하는 어떤 제약들에 종속하여, 도덕과 그 요구사항들에 관한 자신의 최선의 이해에 따라 법창출 재량을 행사하라는 요청으로만 취급할 수 있다.

나는 여전히 법이론이 도덕 판단들의 일반적 지위에 관한 (p. 254) 논쟁적 철학 이론들에 결속되는 것을 피해야 하며, 이 책에서 내가 그러하듯(p. 168), 그것들이 드워킨이 ‘객관적 지위’라고 부르는 것을 가지는지에 관한 일반 질문을 열어 두어야 한다고 생각한다. 이 철학적 질문에 대한 답이 무엇이든, 판사의 책무는 동일할 것이기 때문이다. 곧 그가 결정해야 할 수 있는 어떤 도덕적 쟁점들에 대해서도 자신이 할 수 있는 최선의 도덕 판단을 내리는 것이다. 사건들을 이렇게 결정하면서 판사가 도덕에 따라, 법이 부과하는 어떤 제약들에 종속하여, 법을 만들고 있는 것인지, 아니면 법에 대한 도덕적 검사 기준에 의해 드러나는 이미 존재하는 법이 무엇인지에 관한 자신의 도덕 판단에

⁴⁰RDCJ 250면.

의해 인도되는 것인지는 어떤 실천적 목적에서도 중요하지 않을 것이다. 물론, 내가 그래야 한다고 주장하듯이 법이론이 도덕 판단들의 객관적 지위 문제를 열어 둔다면, 연성 실증주의는 단순히 도덕 원칙들이나 가치들이 법적 유효성의 기준들 가운데 있을 수 있다는 이론으로 특징지어질 수 없다. 도덕 원칙들과 가치들이 객관적 지위를 가지는지가 열린 질문이라면, 그것들에 대한 부합을 현존 법(existing law)에 대한 검사 기준들 가운데 포함하려는 ‘연성 실증주의적’ 규정들이 그러한 효과를 가질 수 있는지, 아니면 오직 법원들에게 도덕에 따라 법을 만들라는 지시들을 구성할 수 있을 뿐인지도 열린 질문이어야 하기 때문이다.

몇몇 이론가들, 특히 라즈가 다음과 같이 본다는 점은 관찰되어야 한다. 도덕 판단들의 지위가 무엇이든, 법이 법원들에게 법이 무엇인지를 확정하는데 도덕 기준들을 적용하라고 요구할 때마다, 법은 그로써 법원들에게 재량을 부여하고, 새 법을 만들면서 자기들의 최선의 도덕 판단에 따라 그 재량을 사용하라고 지시한다. 법은 그로써 도덕을 이미 존재하는 법으로 전환하지 않는다.⁴¹

3. 규칙의 본성 (THE NATURE OF RULES)

(i) 규칙의 실천 이론 (The Practice Theory of Rules)

이 책의 여러 지점에서 나는 법의 내부 진술(internal statements)과 외부 진술(external statements) 사이의 구분, 그리고 법의 내부 측면(internal aspects)과 외부 측면(external aspects) 사이의 구분에 주의를 기울였다.

이러한 구분들과 그 중요성을 설명하기 위해 나는 (56-7쪽) (p. 255) 제정된 규칙들과 관습-유형 규칙들 양쪽을 포함하는 고도로 복잡한 법체계의 사례에서 출발하지 않고, 그보다 단순한 사례, 곧 크든 작든 어떤 사회 집단의 관습-유형 규칙들의 사례에서 출발했다. 내부/외부 구분은 이 사례에도 똑같이 적용되며, 나는 이러한 규칙들을 ‘사회적 규칙들(social rules)’ 이라고 부른다. 내가 그것들에 관해 제시한 설명은 ‘규칙의 실천 이론(the practice theory)’ 으로 알려지게

⁴¹J. Raz, “Dworkin: A New Link in the Chain”, *California Law Review* 제74권 (1986) 1103면, 1110면 및 1115-1116면.

되었는데, 그것은 한 집단의 사회적 규칙들을 사회적 실천의 한 형식에 의해 구성되는 것으로 취급하기 때문이다. 이 사회적 실천은 집단 구성원 대부분이 반복적으로 일양적인 따름을 보이는 행위 양식들과, 그러한 행위 양식들에 대한 독특한 규범적 태도, 곧 내가 ‘수용(acceptance)’ 이라고 부른 것을 함께 포함한다. 이 수용은 그러한 행위 양식들을 자신의 미래 행위의 지침들로, 그리고 부합(conformity)에 대한 요구들과 여러 형태의 압력을 정당화할 수 있는 비판 기준들로 삼으려는 개인들의 지속적 성향으로 이루어진다. 사회적 규칙들에 대한 외부 관점은 그 실천의 관찰자의 관점이고, 내부 관점은 그 실천의 참여자, 곧 규칙들을 행위의 지침들과 비판 기준들로 수용하는 참여자의 관점이다.

나의 사회적 규칙들의 실천 이론은 드워킨에 의해 광범위하게 비판되어 왔다. 앞서 말했듯이 그는 이와 유사하지만 실제로는 여러 점에서 매우 다른 구별, 곧 한 공동체의 사회적 규칙들에 대한 사회학자의 외부 기술과, 자신의 행위와 타인의 행위에 대한 평가와 비판을 위해 규칙들에 호소하는 참여자의 내부 관점 사이의 구별을 제시한다.⁴² 사회적 규칙들에 대한 나의 원래 설명에 관해 드워킨이 제기한 비판 가운데 일부는 분명 타당하며 법의 이해에도 중요하다. 이어서 나는 이제 필요하다고 보는 나의 원래 설명의 상당한 수정들을 지목한다.

- (i) 드워킨이 주장했듯이, 나의 설명은 한 집단의 관행적 규칙들에서 드러나는 관행(convention)의 합의와, 한 집단의 동시적 실천들에서 드러나는 독립적 확신(conviction)들의 합의 사이의 중요한 차이를 무시한다는 점에서 결함이 있다. 어떤 규칙들에 대한 집단의 일반적 부합(conformity)이 그 개별 구성원들이 그 규칙들을 수용하는 이유들의 일부라면, 그 규칙들은 관행적 사회 실천들이다. 이와 대조적으로 (p. 256) 한 집단의 공유 도덕과 같은 단지 동시적인 실천들은 관행이 아니라, 집단 구성원들이 특정 방식으로 행위할 동일하지만 독립적인 이유들을 가지고 대체로 그 이유들에 따라 행위한다는 사실에 의해 구성된다.

- (ii) 드워킨이 또한 옳게 주장했듯이, 나의 사회적 규칙 설명은 내가 이제

⁴²[LE 13-14면 참조.]

설명한 의미에서 관행적인 규칙들에만 적용 가능하다. 이것은 나의 실천 이론의 범위를 상당히 좁히며, 나는 이제 그것을 개인적 도덕이든 사회적 도덕이든 도덕에 대한 건전한 설명으로 보지 않는다. 그러나 그 이론은 일반적 사회 관습들, 곧 법적 효력을 가진 것으로 승인될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 관습들뿐 아니라, 승인 규칙을 포함한 일정한 중요한 법규칙들도 포함하는 관행적 사회적 규칙들에 대한 충실한 설명으로는 남아 있다. 승인 규칙은 사실상 법원들의 법-식별 및 법-적용 작용에서 수용되고 실천될 때에만 존재하는 사법적 관습 규칙의 한 형식이다. 이와 대조적으로 제정된 법규칙들은, 승인 규칙이 제공하는 기준들에 의해 유효한 법규칙들로 식별될 수 있지만, 그것들을 실천할 계기가 생기기 전에도 제정의 순간부터 법규칙들로 존재할 수 있으므로, 실천 이론은 그것들에는 적용되지 않는다.

드워킨의 규칙의 실천 이론에 대한 핵심 비판은, 그것이 사회적 규칙을 그 사회적 실천에 의해 구성되는 것으로 잘못 받아들이며, 그래서 그러한 규칙이 존재한다는 진술을 단지 그 규칙의 존재를 위한 실천-조건들이 충족되었다는 외부 사회학적 사실의 진술로 취급한다는 것이다.⁴³ 드워킨의 논변에 따르면 그러한 설명은 가장 단순한 관행적 규칙조차 가지는 규범적 성격을 설명할 수 없다. 그러한 규칙들은 책무들과 행위의 이유들을 확립하며, 그러한 규칙들이 행위 비판과 행위 요구의 뒷받침에서 통상 인용될 때에는 바로 이것들에 호소하기 때문이다. 규칙들의 이러한 이유-제공 및 책무-확립 특징이 그 독특한 규범적 성격을 구성하며, 그것은 규칙들의 존재가 실천 이론에 따르면 사회적 규칙의 존재를 구성하는 실천들과 태도들이 그러하듯이 단지 사실적 사태로 이루어질 수 없음을 보여 준다. 드워킨에 따르면, 이러한 독특한 특징들을 가진 규범적 규칙은 ‘일정한 규범적 사태’가 있을 때에만 존재할 수 있다.⁴⁴ (p. 257) 나는 인용된 이 말들이 답답할 만큼 모호하다고 본다. ‘교회 출석자들의 규칙’ (남성은 교회에서 머리를 드러내야 한다)의 예에 관한 논의에서,⁴⁵ 드워킨은

⁴³[TRS 48-58면 참조.]

⁴⁴TRS 51면.

⁴⁵[TRS 50-58면; 본서 124-125면 참조.]

규범적 사태로 규칙이 요구하는 것을 할 좋은 도덕적 근거들 또는 정당화의 존재를 뜻하는 듯하다. 그래서 그는 교회 출석자들이 교회에서 모자를 벗는 단순한 반복적으로 일양적인 실천은 그 규칙을 구성할 수 없지만, 불쾌감을 주는 방식들을 창출하고 교회에서 모자를 벗도록 요구하는 규칙을 위한 좋은 근거들인 기대들을 일으킴으로써 그 규칙을 정당화하는 데 도움을 줄 수 있다고 논변한다. 규범적 규칙의 단언을 보증하기 위해 요구되는 규범적 사태로 드워킨이 뜻하는 것이 이것이라면, 사회적 규칙의 존재 조건에 관한 그의 설명은 내게 지나치게 강해 보인다. 그것은 규칙들에 책무를 확립하거나 행위의 이유들을 제공하는 것으로 호소하는 참여자들이 규칙들에 부합할 좋은 도덕적 근거들 또는 정당화가 있다고 믿어야 할 뿐 아니라, 실제로 그러한 좋은 근거들이 있어야 한다고 요구하는 것처럼 보이기 때문이다. 분명 어떤 사회는 그 구성원들이 수용하지만 도덕적으로 사악한 규칙들, 예컨대 특정 피부색을 가진 사람들이 공원이나 해수욕장 같은 공공시설을 이용하는 것을 금지하는 규칙들을 가질 수 있다. 기실 사회적 규칙의 존재를 위한 일반 조건으로, 참여자들이 그 규칙에 부합할 좋은 도덕적 근거들이 있다고 믿어야 한다는 더 약한 조건조차도 지나치게 강하다. 어떤 규칙들은 단순히 전통에 대한 존중, 타인들과 동일시하려는 바람, 또는 사회가 개인들에게 무엇이 유리한지를 가장 잘 안다는 믿음에서 수용될 수 있기 때문이다. 이러한 태도들은 그 규칙들이 도덕적으로 문제 있다는 어느 정도 생생한 자각과 공존할 수 있다. 물론 관행적 규칙은 도덕적으로 건전하고 정당화될 수도 있으며 그렇게 믿어질 수도 있다. 그러나 관행적 규칙들을 자신의 행위 지침이나 비판 기준들로 수용한 사람들이 왜 그렇게 했는지가 문제될 때, 나는 제시될 수많은 답변들(이 책 203쪽, 232쪽 참조) 가운데 규칙들의 도덕적 정당화에 대한 믿음을 유일하게 가능하거나 충분한 답변으로 골라낼 이유가 없다고 본다.

마지막으로, 드워킨은 규칙의 실천 이론이 (p. 258) 관행적 규칙들로 제한 되더라도 폐기되어야 한다고 논변한다. 그것은 관행적 규칙의 범위가 논쟁적일 수 있고 따라서 의견불일치의 대상이 될 수 있다는 관념을 수용할 수 없기 때문이다.⁴⁶ 그는 반복적으로 일양적인 실천과 수용에 의해 구성되는 논쟁의 여지

⁴⁶[TRS 58면.]

없는 규칙들이 일부 있다는 점은 부정하지 않지만, 그렇게 구성되는 규칙들은 어떤 게임들의 규칙들처럼 상대적으로 중요하지 않은 사례들만 포함한다고 주장한다. 그러나 이 책에서는 법체계의 기본 승인 규칙처럼 중요하고도 거의 논쟁의 여지가 없는 규칙이 법원들이 그것을 자신들의 법-적용 및 법-집행 작용의 지침으로 수용하는 일양적 실천에 의해 구성되는 규칙으로 취급된다. 이에 맞서 드워킨은 어려운 사례들에서 어떤 주제에 관한 당해 법이 무엇인지에 관해 판사들 사이에 이론적 의견불일치가 자주 있으며, 이것들이 논쟁 없음과 일반적 수용의 외양이 환상임을 보여 준다고 주장한다. 물론 그러한 의견불일치들의 빈도와 중요성은 부정될 수 없다. 그러나 그것들의 존재에 호소하여 승인 규칙에 실천 이론이 적용될 수 없다고 논변하는 것은 그 규칙의 기능에 대한 오해에 기초한다. 그것은 승인 규칙이 특정 사례들의 법적 결과를 완전히 확정하도록 의도되어, 어떤 사례에서 생기는 어떤 법적 쟁점도 그 규칙이 제공하는 기준들이나 검사 기준들에 대한 단순한 호소만으로 해결될 수 있다고 가정한다. 그러나 이것은 오해이다. 그 규칙의 기능은 현대 법체계들에서 올바른 법적 결정들이 충족해야 하는 일반 조건들만을 확정하는 것이다. 그 규칙은 대개 드워킨이 계보 사항들이라고 부르는 유효성 기준들, 곧 법의 내용이 아니라 법들이 창설되거나 채택되는 방식과 형식에 관련되는 기준들을 제공함으로써 이 기능을 수행한다. 그러나 내가 말했듯이(250쪽), 승인 규칙은 그러한 계보 사항들에 더해 법들의 사실적 내용이 아니라 실체적 도덕 가치들(substantive moral values)이나 원칙들에 대한 그 부합과 관련되는 검사 기준들을 제공할 수도 있다. 물론 특정 사례들에서 판사들은 그러한 검사 기준들이 충족되는지 여부에 관해 의견불일치할 수 있고, 승인 규칙 안의 도덕적 검사 기준은 그러한 의견불일치를 해소하지 않을 것이다. 판사들은 특정 사례들에서 (p. 259) 그 검사 기준들이 무엇을 요구하는지에 관해서는 의견불일치하면서도, 그러한 검사 기준들의 관련성이 확립된 사법 실천에 의해 확정된 것이라는 데에는 동의할 수 있다. 이렇게 이해된 승인 규칙에는 규칙의 실천 이론이 온전히 적용 가능하다.

(ii) 규칙들과 원칙들 (Rules and Principles)

오랫동안 이 책에 대한 드워킨의 비판 가운데 가장 잘 알려진 것은, 이 책이 법을 오직 ‘전부-아니면-무(all-or-nothing)’ 규칙들로만 이루어진 것으로 잘못 제시하고, 법적 추론과 재판에서 중요하고 독특한 역할을 하는 다른 종류의 법적 기준, 곧 법적 원칙들을 무시한다는 것이었다. 내 작업에서 이 결함을 발견한 일부 비판자들은 그것을 다소 고립된 흠으로 보았고, 내가 법체계의 구성 요소들로 법규칙들과 함께 법원칙들을 포함하기만 하면 그것을 고칠 수 있으며, 책의 주요 논제들 가운데 어느 것도 포기하거나 중대하게 수정하지 않고도 그렇게 할 수 있다고 생각했다. 그러나 이 비판 노선을 처음 강하게 제기한 드워킨은, 법원칙들은 나의 법이론 안에 포함될 수 있지만 그 대가는 그 중심 교설들의 포기라고 주장해 왔다. 그에 따르면 내가 법이 부분적으로 원칙들로 이루어져 있음을 인정한다면, 나는 한 체계의 당해 법이 법원칙들의 실천에서 수용된 승인 규칙이 제공하는 기준들에 의해 식별된다는 주장도, 현존하는 명시적 법이 결정을 지시하지 못하는 경우 법원칙들이 진정한, 비록 간극적인, 법창출 권한 또는 재량을 행사한다는 주장도, 법과 도덕 사이에 중요한 필연적 또는 개념적 연결이 없다는 주장도 일관되게 유지할 수 없다. 이 교설들은 내 법이론의 중심일 뿐 아니라 현대 법실증주의의 핵심을 구성하는 것으로 자주 받아들여지므로, 그것들의 포기는 상당한 중대성을 가진 문제일 것이다.

이 응답의 이 절에서 나는 내가 법원칙들을 무시했다는 비판의 여러 측면들을 검토하고, 그 비판에서 타당한 것이 무엇이든 내 이론 전체에 중대한 귀결 없이 수용될 수 있음을 보이고자 한다. 그러나 나는 이제, 재판과 법적 추론이라는 주제에 관해, 특히 내 비판자들이 법원칙들이라고 부르는 것들로부터의 논변들에 관해 이 책에서 내가 너무 적게 말했다는 점을 기꺼이 인정한다. 원칙들이 이 책에서 지나가듯 다루어졌을 뿐이라는 점은 결함이라는 데 나는 이제 동의한다.

그러나 정확히 내가 무시했다고 고발되는 것은 무엇인가? (p. 260) 법원칙들은 무엇이며, 그것들은 법규칙들과 어떻게 다른가? 법률가들이 사용하는 ‘원칙들’은 흔히 방대한 이론적·실천적 고려사항들을 포함하며, 그 가운데

일부만이 드워킨이 제기하려 한 쟁점들과 관련된다. ‘원칙’이라는 표현을, 사건들을 결정하는 법원들의 행위를 포함한 행위 기준으로 제한해 받아들인다 하더라도, 규칙들과 그러한 원칙들 사이의 대비를 갖는 방식들은 서로 다를 수 있다. 그러나 내가 원칙들을 무시했다고 비난한 모든 비판자들은 적어도 두 특징이 그것들을 규칙들과 구별한다는 데 동의할 것이라고 생각한다. 첫째는 정도의 문제이다. 원칙들은 규칙들에 비해 넓고 일반적이며 비특정적이다. 흔히 다수의 구별되는 규칙들로 여겨질 것들이 하나의 원칙의 예증들 또는 실례들로 제시될 수 있다는 의미에서 그렇다. 둘째 특징은, 원칙들이 어떤 목적, 목표, 권리자격(entitlement) 또는 가치를 어느 정도 명시적으로 참조하기 때문에, 어떤 관점에서는 유지하거나 고수하는 것이 바람직한 것으로 간주되며, 따라서 그것들을 예증하는 규칙들의 설명 또는 이론적 근거(rationale)를 제공할 뿐 아니라 적어도 그 정당화에도 기여하는 것으로 간주된다는 점이다.

규칙들과 관련하여 원칙들이 수행하는 설명적·정당화적 역할을 설명하는, 넓이와 어떤 관점에서의 바람직성이라는 이 두 비교적 논쟁의 여지가 없는 특징들 외에도, 세 번째 구별 특징이 있다. 나 자신은 이것이 정도의 문제라고 생각하지만, 드워킨은 그것을 핵심적이라고 본다. 그에 따르면 규칙들은 그것들을 적용하는 사람들의 추론에서 ‘전부-아니면-무 방식’으로 기능한다. 즉 어떤 규칙이 유효하고 주어진 사례에 적용 가능하다면, 그것은 법적 결과 또는 귀결을 ‘필연화한다’, 곧 확정적으로 결정한다.⁴⁷ 그가 법규칙들의 예로 든 것들 가운데에는 유료도로에서 시속 60마일의 최고속도를 정하는 규칙이나, 유언장의 작성·증명·효력을 규율하는 제정법들, 예컨대 두 증인이 서명하지 않으면 유언장은 유효하지 않다는 제정법 규칙이 있다. 드워킨에 따르면 법원칙들은 그러한 전부-아니면-무 규칙들과 다르다. 그것들은 적용될 때 결정을 ‘필연화하지’ 않고, 결정 쪽을 가리키거나 (p. 261) 결정에 유리하게 작용하거나, 압도될 수 있지만 법원들이 어느 한 방향으로 기울게 하는 것으로 고려하는 이유를 진술하기 때문이다. 짧게 말해, 나는 원칙들의 이러한 특징을 그 ‘비확정적(non-conclusive)’ 성격이라고 부르겠다. 드워킨이 든 그러한 비확정적 원칙들의 예들 가운데에는 ‘법원들은 소비자와 공적 이익들이 공정하게 다루어지는지

⁴⁷[TRS 24면.]

보기 위해 [자동차] 구매 계약들을 면밀히 검토해야 한다' 는 것처럼 상대적으로 특정적인 것들도 있고,⁴⁸ '누구도 자신의 그른 행위로부터 이익을 얻어서는 안 된다' 는 것처럼 훨씬 넓은 범위를 가지는 것들도 있다.⁴⁹ 실제로 미국 헌법 제 1·5·14 수정조항의 규정들처럼 미국 연방의회의 권한들과 주 입법에 대한 가장 중요한 헌법적 제한들의 상당수는 비확정적 원칙들로 기능한다.⁵⁰ 드워킨에 따르면 법원칙들은 유효성의 차원이 아니라 무게의 차원을 가진다는 점에서 규칙들과 다르다.⁵¹ 그래서 더 큰 무게의 다른 원칙과 충돌하면 한 원칙은 압도되어 결정을 확정하지 못할 수 있지만, 그럼에도 온전하게 존속하여 다른 사례들에서 더 작은 무게의 다른 원칙과 경쟁할 때 이길 수도 있다. 반면 규칙들은 유효하거나 유효하지 않을 뿐 이 무게의 차원을 가지지 않는다. 그래서 처음 정식화된 규칙들이 충돌하면, 드워킨에 따르면 그 가운데 오직 하나만 유효할 수 있고, 다른 규칙과의 경쟁에서 진 규칙은 그 경쟁 규칙과 일관되도록 다시 정식화되어야 하며 따라서 주어진 사례에는 적용될 수 없게 된다.⁵²

나는 법원칙들과 법규칙들 사이의 이 날카로운 대비도, 유효한 규칙이 주어진 사례에 적용 가능하다면 원칙과 달리 항상 그 사례의 결과를 결정해야 한다는 견해도 받아들이 이유가 없다고 본다. 법체계가, 어떤 유효한 규칙은 그것이 적용 가능한 사례들에서 결과를 결정하지만, 더 중요하다고 판단되는 다른 규칙이 같은 사례에도 적용되는 경우에는 예외라고 승인하지 못할 이유는 없다. 따라서 주어진 사례에서 (p. 262) 더 중요한 규칙과의 경쟁에서 패배한 규칙은 원칙처럼, 다른 경쟁 규칙보다 더 중요하다고 판단되는 다른 사례들에서는 결과를 결정하기 위해 존속할 수 있다.⁵³

⁴⁸ TRS 24면. 다음 판례에서 인용함: *Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc.*, 32 NJ 358, 161 A.2d 69 (1960), 387면, 85면.

⁴⁹ TRS 25-26면.

⁵⁰ [드워킨은 TRS 27면에서 수정헌법 제1조가 규칙(rule)인지 원칙(principle)인지 논의함.]

⁵¹ [TRS 26면.]

⁵² TRS 24-27면.

⁵³ 이 중요한 지점은 Raz와 Waluchow가 강조했지만, 나는 이에 충분한 주의를 환기하지 못했다. J. Raz, "Legal Principles and the Limits of the Law", *Yale Law Journal* 제81권 (1972) 823면, 832-834면; W. J. Waluchow, "Herculean Positivism", *Oxford Journal of Legal Studies* 제5권 (1985) 187면, 189-192면 참조.

그러므로 드워킨에게 법은 전부-아니면-무 규칙들과 비확정적 원칙들 양쪽을 포함하며, 그는 이 차이를 정도의 문제로 보지 않는다. 그러나 나는 드워킨의 입장이 정합적일 수 있다고 생각하지 않는다. 그의 가장 이른 예들은 규칙들이 원칙들과 충돌할 수 있고, 어떤 원칙은 때로 규칙과의 경쟁에서 이기고 때로 질 것임을 함축한다. 그가 인용한 사례들에는 *Riggs v. Palmer*가 포함된다.⁵⁴ 그 사건에서 사람은 자신의 그른 행위로부터 이익을 얻도록 허용되어서는 안 된다는 원칙은, 유언의 효력을 지배하는 제정법 규칙들의 명확한 문언에도 불구하고, 살인자가 희생자의 유언에 따라 상속하는 것을 배제하는 것으로 판시되었다. 이것은 원칙이 규칙과의 경쟁에서 이기는 예이지만, 그러한 경쟁의 존재 자체가 규칙들이 전부-아니면-무 성격을 가지지 않음을 분명히 보여 준다. 규칙들은 자신보다 더 무거울 수 있는 원칙들과 그러한 충돌 속으로 들어갈 수 있기 때문이다. 우리가 그러한 사례들을 (드워킨이 때때로 시사하듯이) 규칙들과 원칙들 사이의 충돌이 아니라, 문제된 규칙을 설명하고 정당화하는 원칙과 다른 어떤 원칙 사이의 충돌로 서술하더라도, 전부-아니면-무 규칙들과 비확정적 원칙들 사이의 날카로운 대비는 사라진다. 이 견해에서는 어떤 규칙이 그 문언에 따르면 적용 가능한 사례에서 결과를 확정하지 못하는 것은 그 정당화 원칙이 다른 원칙에 의해 무게에서 압도되기 때문이다. (드워킨이 또한 시사하듯이) 우리가 어떤 원칙을 명확히 정식화된 법규칙에 대한 새로운 해석을 위한 이유를 제공하는 것으로 생각하는 경우에도 마찬가지이다.⁵⁵

법체계가 전부-아니면-무 규칙들과 비확정적 원칙들 양쪽으로 이루어진다는 주장 안의 이 비정합성은, 그 구별이 정도의 문제임을 인정하면 치유될 수 있다. (p. 263) 확실히, 적용 조건들의 충족이 몇몇 사례들, 곧 그 규정들이 더 중요하다고 판단되는 다른 규칙과 충돌할 수 있는 사례들을 제외하고는 법적 결과를 확정하기에 충분한 거의 확정적인 규칙들과, 단지 결정을 향해 가리키지만 매우 자주 그것을 확정하지 못할 수 있는 일반적으로 비확정적인 원칙들 사이에는 합리적 대비가 이루어질 수 있다.

나는 그러한 비확정적 원칙들로부터의 논변들이 재판과 법적 추론의 중요한

⁵⁴ 115 N.Y. 506, 22 N.E. 188 (1889); TRS 23면; LE 15면 이하 참조.

⁵⁵ [드워킨의 논의는 TRS 22-28면, LE 15-20면 참조.]

특징이며, 적절한 용어법으로 표시되어야 한다고 확실히 생각한다. 그것들의 중요성과 법적 추론에서의 역할을 보이고 예시한 점에서 드워킨에게는 큰 공이 있다. 그리고 내가 그것들의 비확정적 힘을 강조하지 않은 것은 분명 중대한 실수였다. 그러나 나는 ‘규칙’이라는 말을 사용하면서 법체계들이 오직 ‘전부-아니면-무’ 규칙들 또는 거의 확정적인 규칙들만 포함한다고 주장하려 의도하지 않았다. 나는 이 책 130-3쪽에서 내가 (아마도 썩 적절하지 않게) ‘가변적 법적 기준들’이라고 부른 것들, 곧 고려되어 다른 것들과 저울질되어야 할 요소들을 특정하는 기준들에 주의를 환기했을 뿐 아니라, 왜 어떤 행위 영역들은 ‘상당한 주의’와 같은 가변적 기준들이 아니라 드문 사례들을 제외하고 동일한 특정 행위들을 금지하거나 요구하는 거의 확정적인 규칙들에 의한 규율에 적합한지를 설명하려고도 했다(133-4쪽 참조). 그래서 우리는 살인과 절도에 반대하는 규칙들을 가지고 있는 것이지, 인간 생명과 재산에 대한 적절한 존중을 요구하는 원칙들만 가지고 있는 것이 아니다.

4. 원칙들과 승인 규칙 (PRINCIPLES AND THE RULE OF RECOGNITION)

계보와 해석 (Pedigree and Interpretation)

드워킨은 법원들의 실천에서 드러나는 승인 규칙이 제공하는 기준들에 의해 법 원칙들이 식별될 수 없으며, 원칙들은 법의 필수 요소들이므로 승인 규칙 교설은 폐기되어야 한다고 주장해 왔다. 그에 따르면 법원칙들은 오직 구성적 해석에 의해서만, 곧 한 법체계의 확립된 법 전체의 제도적 역사에 가장 잘 부합하고 그것을 가장 잘 정당화하는 유일한 원칙 집합의 구성원들로서만 식별될 수 있다. 물론 영국이든 미국이든 어떤 법원도 (p. 264) 당해 법을 식별하기 위해 그러한 체계-전체적 총체 기준을 명시적으로 채택한 적은 없으며, 드워킨은 자신의 신화적 이상 판사 ‘헤라클레스’와 구별되는 실제 인간 판사는 누구도 한 번에 자기 나라의 모든 법에 대한 해석을 구성하는 위업을 성취할 수 없다는 점을 인정한다. 그럼에도 그의 견해에서 법원들은 제한된 방식으로 ‘헤라클레스를 모방하려’ 하는 것으로 이해될 때 가장 잘 해명되며, 그는 자신들의 판결을

이렇게 바라보는 일이 ‘숨겨진 구조’를 드러내는 데 기여한다고 생각한다.⁵⁶

제한된 형식의 구성적 해석에 의해 원칙들이 식별되는 가장 유명한 예, 영국 법률가들에게 익숙한 예는 *Donoghue v. Stevenson* 사건에서 애킨 경이 이전에는 정식화되지 않았던 ‘이웃 원칙(neighbour principle)’을, 여러 상황에서 주의책무를 확립하는 다양한 개별 규칙들의 밑바탕에 놓인 원칙으로 정식화한 것이다.⁵⁷

나는 그러한 제한된 구성적 해석의 수행들에서 판사들이 헤라클레스의 총체적 체계-전체 접근을 모방하려 한다고 이해하는 것이 그럴듯하다고 보지 않는다. 그러나 여기서 나의 현재 비판은, 구성적 해석에 대한 몰두가 드워킨으로 하여금 많은 법원칙들이 그 지위를 확립된 법의 해석으로 기능하는 그 내용 덕분이 아니라, 그가 그 원칙들의 ‘계보’라고 부르는 것, 곧 인정된 권위 있는 원천에 의해 그것들이 창설되거나 채택된 방식 덕분에 얻는다는 사실을 무시하게 만들었다는 것이다. 이 몰두는 실제로 그를 이중의 오류로 이끌었다고 생각한다. 첫째는 법원칙들이 그 계보에 의해 식별될 수 없다는 믿음이고, 둘째는 승인 규칙이 오직 계보 기준들만 제공할 수 있다는 믿음이다. 이 두 믿음은 모두 잘못이다. 첫 번째 믿음이 잘못된 것은 원칙들의 비확정적 성격에도, 그 밖의 특징들에도, 그것들이 계보 기준들에 의해 식별되는 것을 배제하는 것은 전혀 없기 때문이다. 분명 성문헌법이나 헌법 수정조항 또는 제정법의 한 규정은 원칙들에 특징적인 비확정적 방식으로 작동하도록 의도된 것으로, 곧 어떤 다른 규칙이나 원칙이 대안적 결정을 위한 더 강한 이유들을 제시하는 사례들에서는 압도될 수 있는 결정 이유들을 제공하는 것으로 받아들여질 수 있다. 드워킨 자신도 의회가 표현의 자유를 제한해서는 안 된다고 규정하는 미국 헌법 제1 수정조항이 바로 그런 방식으로 (p. 265) 해석되어야 한다고 상정했다.⁵⁸ 또한 자기 자신의 그런 행위로부터 이익을 얻어서는 안 된다는 원칙 같은 커먼로의 몇몇 기본 원칙들을 포함한 일부 법원칙들은, 반대 방향을 가리키는 이유들에 의해 어떤 사례들에서는 압도될 수 있음에도 고려되어야 할 결정 이유들을

⁵⁶ LE 265면.

⁵⁷ [1932] A.C. 562.

⁵⁸ [TRS 27면 참조.]

제공하는 것으로, 여러 다른 사례 범위에서 법원들이 일관되게 원용해 왔다는 점에서 ‘계보’ 검사 기준에 의해 법으로 식별된다. 계보 기준들에 의해 식별되는 법원칙들의 이러한 예들 앞에서, 법의 일부로 원칙들을 포함하는 것이 승인 규칙 교설의 포기를 함축한다는 일반 논변은 성공할 수 없다. 사실 내가 아래에서 보이듯이, 그것들의 포함은 그 교설과 양립 가능할 뿐 아니라 실제로 그 교설의 수용을 요구한다. 승인 규칙이 제공하는 계보 기준들에 의해 적어도 일부 법원칙들이 법으로 ‘포착’ 되거나 식별될 수 있다는 점이 인정된다면, 그리고 분명 인정되어야 한다면, 드워킨의 비판은 더 겸손한 주장으로 축소되어야 한다. 곧 그렇게 포착될 수 없는 법원칙들이 많이 있는데, 그것들은 너무 많거나, 너무 일시적이거나, 변화나 수정에 너무 열려 있거나, 법체계의 제도적 역사와 실천들에 가장 잘 부합하고 그것들을 가장 잘 정당화하는 정합적 원칙 체계에 속한다는 검사 기준 이외의 어떤 검사 기준을 참조해서도 법원칙들로 식별될 수 있게 하는 특징을 가지지 않는다는 주장이다. 첫눈에 이 해석주의적 검사 기준은 승인 규칙이 제공하는 기준의 대안이 아니라, 몇몇 비판자들이 주장했듯이,⁵⁹ 원칙들을 그 계보가 아니라 그 내용에 의해 식별하는 그러한 기준의 복합적 ‘연성-실증주의적’ 형식일 뿐인 듯하다. 그러한 해석 기준을 포함하는 승인 규칙이, 위 251쪽 이하에서 논의한 이유들 때문에, 드워킨에 따르면 실증주의자가 원할 법 식별의 확실성 정도를 확보할 수 없다는 것은 사실이다. 그럼에도 해석적 검사 기준이 법-식별의 관행적 양식의 일부였음을 보이는 것은 여전히 (p. 266) 그것의 법적 지위에 대한 좋은 이론적 설명일 것이다. 그러므로 법의 일부로 원칙들을 인정하는 것과 승인 규칙 교설 사이에는 드워킨이 주장하는 그런 양립불가능성이 분명 없다.

앞의 두 단락의 논변은, 드워킨의 논지와 달리 원칙들을 법의 일부로 수용하는 것이 승인 규칙 교설과 양립 가능하다는 점을 보이기에 충분하다. 설령 드워킨의 해석적 검사 기준이 그가 주장하듯 원칙들을 식별하기에 유일하게 적절한 기준이라고 하더라도 그렇다. 그러나 사실 더 강한 결론이 보증된다. 곧

⁵⁹예: E. P. Soper, “Legal Theory and the Obligation of a Judge”, *RDCJ* 3면, 16면; J. Coleman, “Negative and Positive Positivism”, *RDCJ* 28면; D. Lyons, “Principles, Positivism and Legal Theory”, *Yale Law Journal* 제87권 (1977) 415면.

법원칙들이 그러한 기준에 의해 식별되려면 승인 규칙이 필요하다는 결론이다. 왜냐하면 드워킨의 해석적 검사 기준에 의해 드러날 어떤 법원칙을 식별하기 위한 출발점은, 그 원칙이 부합하고 정당화하는 데 도움을 주는 확립된 법의 어떤 특정 영역이기 때문이다. 그러므로 그 기준의 사용은 확립된 법의 식별을 전제하며, 그것이 가능하려면 법의 원천들과 그들 사이에 성립하는 우위와 종속의 관계들을 특징하는 승인 규칙이 필요하다. *Law's Empire*의 용어법으로 말하면, 밑바탕에 놓인 또는 암시적 법원칙들을 식별하는 해석 과제의 출발점들을 구성하는 법규칙들과 실천들은 ‘전해석적 법(preinterpretive law)’을 구성하며, 드워킨이 그것에 관해 말하는 많은 것은, 그것의 식별을 위해 이 책에서 서술된 것처럼 법의 권위 있는 원천들을 식별하는 승인 규칙과 매우 유사한 것이 필요하다는 견해를 지지하는 듯하다. 여기서 내 견해와 드워킨의 견해 사이의 주된 차이는, 내가 법의 원천들을 식별하기 위한 기준들에 관해 판사들 사이에서 발견되는 일반적 합의를 그러한 기준들을 제공하는 규칙들의 공유된 수용에 귀속시키는 반면, 드워킨은 규칙들이 아니라 같은 해석 공동체의 구성원들이 공유하는 ‘합의’,⁶⁰ ‘패러다임들’,⁶¹ ‘가정들’⁶²에 관해 말하기를 선호한다는 점이다. 물론 드워킨이 분명히 했듯이, 합의의 각 당사자가 일치하는 데 가지는 이유의 일부로 다른 이들의 일치가 들어 있지 않은 독립적 확신들의 합의와, 그것이 그러한 일부인 관행의 합의 사이에는 중요한 구별이 있다. 승인 규칙은 내 책에서 분명 (p. 267) 관행적 형식의 사법적 합의에 기초하는 것으로 취급된다. 그것이 그렇게 기초해 있다는 점은 적어도 영국법과 미국법에서는 아주 분명해 보인다. 영국 판사가 의회의 입법을, 또는 미국 판사가 헌법을, 다른 원천들에 대해 최고성을 갖는 법의 원천으로 취급하는 이유에는 분명 그의 사법 동료들이 그들의 선임자들이 그랬던 것처럼 이에 동의한다는 사실이 포함되기 때문이다. 기실 드워킨 자신도 입법 최고성 교설을 판사의 확신이 수행할 수 있는 역할을 제한하는 법적 역사의 낱것의 사실로 말하고,⁶³ ‘해석적 태도는 같은 해석 공동체의 구성원들이 “무엇이 실천의 일부로 간주되는가”에 관해

⁶⁰[LE 65-66면, 91-92면.]

⁶¹[LE 72-73면.]

⁶²[LE 47, 67면.]

⁶³[LE 401면.]

적어도 대략 동일한 가정들을 공유하지 않으면 존속할 수 없다' 고 진술한다.⁶⁴ 그러므로 나는 드워킨이 말하는 규칙들과 '가정들', '합의', '패러다임들' 사이에 어떤 차이들이 남아 있든, 법의 원천들에 대한 사법적 식별에 관한 그의 설명은 실질적으로 나의 설명과 같다고 결론짓는다.

그러나 나의 견해와 드워킨의 견해 사이에는 큰 이론적 차이들이 남아 있다. 드워킨은 법원칙들을 위한 자신의 해석적 검사 기준을, 어떤 법체계들에서 그 법원들의 수용에 의존하여 존재와 권위를 가지는 관행적 승인 규칙이 취하는 특정 형식으로 다루는 나의 처리를 분명 거부할 것이다. 그의 견해에서는 이것이 법을 최선의 도덕적 빛 아래 보이도록 설계된 '구성적' 해석의 기획, 곧 드워킨의 견해에서 법의 식별에 관여하는 기획을 완전히 잘못 제시하고 격하하는 것이기 때문이다. 그는 이러한 해석 양식을, 특정 법체계들의 판사들과 법률가들이 수용한 단순한 관행적 규칙이 요구하는 법-식별의 방법으로 구상하지 않는다. 대신 그는 그것을 법 이외에도 많은 사회사상과 사회적 실천의 중심 특징으로, 그리고 문학비평에서 이해되는 해석과 심지어 자연과학에서 이해되는 해석까지 포함하여 '모든 형식의 해석 사이의 깊은 연결' 을 보여 주는 것으로 제시한다.⁶⁵ 그러나 이 해석 기준이 단지 관행적 규칙이 요구하는 법-식별의 양식이 아니고 다른 분과들에서 이해되는 해석과 친연성 및 연결을 가진다 하더라도, 드워킨의 총체적 해석 기준이 (p. 268) 실제로 법원칙들을 식별하는 데 사용되는 법체계들이 있다면 그 체계들에서 그 기준이 관행적 승인 규칙에 의해 제공될 수 있음은 여전히 사실이다. 그러나 이 완전한 총체 기준이 사용되는 실제 법체계들은 없고, *Donoghue v. Stevenson* 같은 사례들에서 잠재적 법원칙들을 식별하기 위해 더 겸손한 구성적 해석 수행들이 이루어지는 영국법과 미국법 같은 체계들만 있을 뿐이다. 그러므로 고려되어야 할 유일한 질문은 그러한 수행들이 관행적 승인 규칙이 제공하는 기준의 적용으로 이해되어야 하는지, 아니면 다른 어떤 방식으로 이해되어야 하는지, 그리고 그렇다면 그것들의 법적 지위가 무엇인지이다.

⁶⁴ LE 67면.

⁶⁵ LE 53면.

5. 법과 도덕 (LAW AND MORALITY)

(i) 권리들과 책무들 (Rights and Duties)

이 책에서 나는, 법과 도덕 사이에는 서로 다른 많은 우연적 연결들이 있지만 법의 내용과 도덕 사이에는 필연적 개념적 연결들이 없으며, 따라서 도덕적으로 사악한 규정들도 법규칙들 또는 법원칙들로서 유효할 수 있다고 논변한다. 이러한 법과 도덕의 분리 형식의 한 측면은, 어떤 도덕적 정당화나 힘도 전혀 가지지 않는 법적 권리들과 책무들이 있을 수 있다는 점이다. 드워킨은 이 관념을 거부하고, 법적 권리들과 책무들의 존재에 관한 단언들에는 적어도 일응의 도덕적 근거들이 있어야 한다는 견해를 선호한다. 그래서 그는 ‘법적 권리들은 도덕적 권리들의 [한] 종으로 이해되어야 한다’ 는 관념을 자신의 법이론에서 ‘핵심적 (crucial)’⁶⁶ 요소로 여기며, 그에 반대되는 실증주의 교설은 도덕적 근거 또는 힘이 전혀 없는 법적 권리들과 책무들이 있을 수 있다는 것을 분석 이전에 그쳐야 하는 것으로 우리에게 주어지는 ‘법적 본질주의의 특이한 세계’⁶⁷에 속한다고 말한다. 일반 기술적 법리학이 법의 이해에 할 수 있는 기여의 종류를 이해하기 위해서는, 그의 일반 해석이론의 이점이 무엇이든, 법적 권리들과 책무들이 도덕적 힘이나 정당화를 결여할 수 있다는 교설에 대한 드워킨의 비판이 잘못되었음을 보는 것이 중요하다고 나는 생각한다. 그 이유는 다음과 같다. (p. 269) 법적 권리들과 책무들은 법이 그 강제적 자원들로 각각 개인의 자유를 보호하고 제한하거나, 개인들에게 법의 강제적 장치를 이용할 권한을 부여하거나 부인하는 지점이다. 그러므로 법들이 도덕적으로 좋은 나쁜든, 정의롭든 부정의하든, 권리들과 책무들은 법의 작용에서 인간들에게 최고로 중요한 초점들로서, 법들의 도덕적 이점들과 독립적으로 주목을 요구한다. 따라서 법적 권리들과 책무들의 진술들이 현실 세계에서 의미를 가질 수 있으려면 그 존재를 단언할 어떤 도덕적 근거가 있어야만 한다는 말은 참이 아니다.

⁶⁶RDCJ 260면.

⁶⁷RDCJ 259면.

(ii) 법의 식별 (The Identification of the Law)

이 책에서 전개된 법이론과 드워킨의 이론 사이에서 법과 도덕의 연결들에 관련된 가장 근본적인 차이는 법의 식별에 관한 것이다. 내 이론에 따르면 법의 존재와 내용은 법의 사회적 원천들, 예컨대 입법, 사법 결정들, 사회 관습들을 참조하여 식별될 수 있으며, 그렇게 식별된 법이 그 자체로 법의 식별을 위한 도덕적 기준들을 편입한 경우를 제외하면 도덕에 대한 참조 없이 그렇게 될 수 있다. 반면 드워킨의 해석이론에서는 어떤 주제에 관한 당해 법이 무엇인지 진술하는 모든 법명제가 필연적으로 도덕 판단을 포함한다. 그의 총체적 해석이론에 따르면 법명제들은 다른 전제명제들과 함께, 법의 사회적 원천들을 참조하여 식별된 한 체계의 확립된 법 전체에 가장 잘 부합하고 그것에 대한 최선의 도덕적 정당화를 제공하는 원칙들의 집합에서 따라 나올 때에만 참이기 때문이다. 그러므로 이 전체적 총체 해석이론은 이중 기능을 가진다. 그것은 법을 식별하는 데에도, 그 법에 대한 도덕적 정당화를 제공하는 데에도 쓰인다.

이것이 *Law's Empire*에서 ‘해석적’ 법과 ‘전해석적’ 법 사이의 구별을 도입하기 전 드워킨의 이론을 간략히 요약한 모습이었다. 법의 존재와 내용이 도덕에 대한 참조 없이 식별될 수 있다는 실증주의자의 이론에 대한 대안으로 고려할 때, 원래 상태의 드워킨 이론은 다음 비판에 취약했다. 사회적 원천들에 대한 참조로 식별된 법이 도덕적으로 사악한 곳에서는, (p. 270) 그것을 가장 잘 ‘정당화’ 하는 원칙들은 그 법에 부합하는 원칙들 가운데 가장 덜 사악한 것들일 수밖에 없다. 그러나 그러한 가장 덜 사악한 원칙들은 어떤 정당화하는 힘도 가질 수 없으며, 무엇이 법으로 간주될 수 있는지에 어떤 도덕적 한계나 제약도 구성할 수 없다. 그리고 그것들이 아무리 사악한 법체계에도 부합할 수밖에 없기 때문에, 그것들을 참조하여 법을 식별한다고 주장하는 이론은 도덕에 대한 어떤 참조도 없이 법이 식별될 수 있다는 실증주의 이론과 구별되지 않는다. 드워킨이 ‘배경 도덕(background morality)’ 이라고 부른 것의 기준상 도덕적으로 건전한 원칙들, 단지 법에 부합하는 원칙들 가운데 도덕적으로 가장 건전한 것이 아닌 원칙들은 기실 무엇이 법으로 간주될 수 있는지에 도덕적 한계나 제약을 제공할

수 있다.⁶⁸ 나는 그 명제에 어떤 식으로도 반대하지 않지만, 그것은 법이 도덕에 대한 참조 없이 식별될 수 있다는 나의 주장과 완전히 양립 가능하다.

드워킨은 후기에 해석적 법과 전해석적 법 사이의 구별을 도입하면서, 우리가 도덕적으로 수용 가능하다고 볼 수 있는 그 법들의 어떤 해석도 불가능할 정도로 사악한 법체계들이 있을 수 있음을 인정한다. 그러한 경우에는 그가 설명하듯이 ‘내부 회의주의’⁶⁹에 의지하여 그러한 체계들이 법임을 부정할 수 있다. 그러나 그러한 상황들을 서술하기 위한 우리의 자원들은 매우 유연하기 때문에, 우리는 대신 아무리 사악한 법체계들도 전해석적 의미에서는 법이라고 말할 수 있을 때 반드시 그 결론에 이르도록 구속되어 있지 않다.⁷⁰ 그러므로 우리는 가장 나쁜 나치 법들에 대해서조차 그것들이 법이 아니라고 말하도록 강제되지 않는다. 그 법들은 법창출의 형식들, 재판과 집행의 형식들과 같은 법의 많은 독특한 특징들을 도덕적으로 수용 가능한 체제들의 법들과 공유하면서, 오직 그 사악한 도덕적 내용에서만 그것들과 다를 수 있기 때문이다. 많은 맥락들과 많은 목적들에서는 그 도덕적 차이를 무시하고, 실증주의자와 함께 그러한 사악한 체계들이 법이라고 말할 충분한 이유들이 있을 수 있다. 이에 드워킨은 말하자면 자신의 해석적 관점에 대한 일반적 고수를 드러내는 단서, 곧 그러한 사악한 체계들은 오직 전해석적 의미에서만 법이라는 단서만을 덧붙일 것이다.

나는 우리 언어의 유연성에 대한 이 호소와 (p. 271) 이 지점에서 해석적 법과 전해석적 법 사이의 구별을 도입하는 일이 실증주의자의 논거를 약화하기보다 오히려 인정한다고 본다. 그것은, 그가 기술적 법리학에서는 법이 도덕에 대한 참조 없이 식별될 수 있다고 고집하지만, 확립된 법을 무엇이 가장 잘 정당화하는지에 관한 도덕 판단을 법의 식별이 항상 포함한다고 보는 정당화적 해석 법리학에서는 사정이 다르다는 메시지를 전달하는 것 이상의 일을 거의 하지 않기 때문이다. 물론 이 메시지는 실증주의자가 자신의 기술적 기획을 포기할 어떤 이유도 주지 않으며, 그렇게 하려는 의도도 없다. 그러나 이 메시지조차

⁶⁸[TRS 112, 128면, TRS 93면 참조.]

⁶⁹LE 78-79면.

⁷⁰[LE 103면.]

한정되어야 한다. 법이 너무 사악하여 ‘내부 회의주의’가 적절한 경우에는 법의 해석이 어떤 도덕 판단도 포함하지 않으며, 드워킨이 이해하는 해석은 포기되어야 하기 때문이다.⁷¹

드워킨이 자신의 해석이론에 가한 또 하나의 수정은 그의 법적 권리 설명에 중요한 관련을 가진다. 원래 제시된 그의 총체 이론에서는 법의 식별과 그 정당화가 모두 한 체계의 확립된 법 모두에 가장 잘 부합하고 그것을 가장 잘 정당화하는 유일한 원칙 집합에서 따라 나오는 것으로 취급되었다. 그러므로 그러한 원칙들은, 내가 말했듯이, 이중 기능을 가진다. 그러나 한 체계의 확립된 법이 너무 사악해서 그 법에 대한 전반적 정당화 해석이 불가능할 수 있으므로, 드워킨은 이 두 기능이 분리될 수 있고, 도덕에 대한 어떤 참조도 없이 식별되는 법원칙들만 남을 수 있다고 관찰했다. 그러나 그러한 법은 드워킨이 모든 법적 권리들이 가진다고 주장하는 일응의 도덕적 힘을 가지는 어떤 권리들도 확립할 수 없다. 그럼에도 드워킨이 나중에 인정했듯이, 그 체계가 너무 사악해서 법 전체에 대한 어떤 도덕적 또는 정당화적 해석도 불가능한 곳에서도, 개인들이 적어도 일응의 도덕적 힘을 가진 권리들을 가진다고 적절히 말해질 수 있는 상황들이 여전히 있을 수 있다.⁷² 그것은 그 체계가, 예컨대 계약의 형성과 집행에 관련된 법들처럼 그 체계의 일반적 사악함에 영향을 받지 않을 수 있는 법들을 포함하고, 개인들이 자기 삶을 계획하거나 재산 처분들을 할 때 그러한 법들에 의존했을 수 있는 경우일 것이다. 그러한 상황들에 대응하기 위해 드워킨은, (p. 272) 일응의 도덕적 힘을 가진 법적 권리들과 책무들이 법에 대한 일반 해석이론에서 흘러나와야 한다는 자신의 원래 관념을 한정하고, 그러한 상황들이 자신의 일반 이론과 독립하여 개인들에게 어떤 도덕적 힘을 가진 법적 권리들을 귀속시키기 위한 ‘특별한 이유들’을 구성한다고 인정한다.

⁷¹[LE 105면.]

⁷²[LE 105-106면.]

6. 사법적 재량 (JUDICIAL DISCRETION)⁷³

이 책의 법이론과 드워킨의 이론 사이의 가장 날카로운 직접 충돌은, 어떤 법 체계에도 언제나 법적으로 규율되지 않은 일정한 사례들이 있을 것이며, 그 사례들에서는 어떤 지점에 관해 어느 쪽의 결정도 법에 의해 지시되지 않고 따라서 법이 부분적으로 불확정적이거나 불완전하다는 나의 논지로부터 생긴다. 그러한 사례들에서 판사가 결정을 내려야 하고, 벤담이 한때 주장했듯이 관할권을 부인하거나 현존 법에 의해 규율되지 않은 쟁점들을 입법부에 회부하여 결정하게 하지 않는다면, 판사는 이미 존재하는 확립된 법을 단지 적용하는 것이 아니라 자기 재량을 행사하여 그 사례를 위한 법을 만들어야 한다. 그러므로 그러한 법적으로 마련되지 않았거나 규율되지 않은 사례들에서 판사는 새로운 법을 만들면서, 동시에 자신의 법창출 권한들을 부여하고 제약하는 확립된 법을 적용한다.

법이 부분적으로 불확정적이거나 불완전하고 판사가 제한된 법창출 재량을 행사하여 그 틈들을 메운다는 이 구상은, 드워킨에 의해 법과 사법 추론 양쪽에 대한 오도적 설명으로 거부된다. 그는 사실상 불완전한 것은 법이 아니라 실증주의자의 법 그림이며, 이 점은 사회적 원천들을 참조하여 식별되는 명시적 확립된 법 외에도 그 명시적 법에 가장 잘 부합하거나 정합하고 또한 그것에 대한 최선의 도덕적 정당화를 제공하는 원칙들인 암시적 법원칙들을 포함하는 법에 대한 자신의 ‘해석적’ 설명에서 드러난다고 주장한다. 이 해석적 견해에서는 법이 결코 불완전하거나 불확정적이지 않으므로, 판사는 결정을 내리기 위해 법 바깥으로 나가 법창출 권한을 행사할 계기를 결코 가지지 않는다. 따라서 (p. 273) 법의 사회적 원천들이 어떤 법적 쟁점에 관해 결정을 확정하지 못하는 ‘어려운 사례들’에서 법원들이 향해야 할 것은, 그 도덕적 차원들을 가진 그러한 암시적 원칙들이다.

법에 의해 부분적으로 규율되지 않은 채 남은 사례들을 규율하기 위해 내가 판사들에게 귀속시키는 법창출 권한들은 입법부의 권한들과 다르다는 점이 중요하다. 판사의 권한들은 입법부가 상당히 자유로울 수 있는 많은 제약들, 곧

⁷³[본 절의 도입 문단의 대체 버전은 미주(endnote)에 수록됨.]

그의 선택을 좁히는 제약들에 종속될 뿐 아니라, 특정한 당해 사례들을 처리하기 위해서만 행사되므로 대규모 개혁이나 새로운 법전들을 도입하는 데 사용될 수 없다. 그래서 그의 권한들은 많은 실체적 제약들(substantive constraints)에 종속될 뿐 아니라 간극적이다. 그럼에도 현존 법이 어떤 결정도 올바른 것으로 지시하지 못하는 지점들이 있을 것이며, 그런 경우들을 결정하기 위해 판사는 자신의 법창출 권한들을 행사해야 한다. 그러나 그는 이것을 자의적으로 해서는 안 된다. 곧 그는 언제나 자기 결정을 정당화하는 어떤 일반적 이유들을 가져야 하고, 자신의 믿음들과 가치들에 따라 결정함으로써 양심적 입법자가 하듯이 행위해야 한다. 그러나 그가 이 조건들을 충족한다면, 그는 법에 의해 지시되지 않고 유사한 어려운 사례들에 직면한 다른 판사들이 따른 것들과 다를 수 있는 결정 기준들이나 이유들을 따를 자격이 있다.

법에 의해 불완전하게 규율된 채 남은 사례들을 처리하기 위해 법원들이 그러한 제한된 재량적 권한을 행사한다는 나의 설명에 맞서, 드워킨은 세 가지 주요 비판을 제기한다. 첫째는 이 설명이 사법 절차와 ‘어려운 사례들’에서 법원들이 하는 일에 대한 거짓 기술이라는 것이다.⁷⁴ 이를 보이기 위해 드워킨은 판사들과 법률가들이 판사의 과제를 서술할 때 사용하는 언어와 사법적 의사결정의 현상학에 호소한다. 사건들을 결정하는 판사들과 자신들에게 유리하게 결정하라고 그들을 촉구하는 법률가들은, 새로운 사례들에서조차 판사가 법을 ‘만든다’고 말하지 않는다는 것이다. 그러한 사례들 가운데 가장 어려운 것들에서조차 판사는, 실증주의자가 시사하듯이, 결정 과정에 완전히 다른 두 단계가 있다는 자각을 드러내지 않는 경우가 많다. 곧 판사가 먼저 현존 법이 어느 쪽의 결정도 지시하지 못한다고 발견하는 단계와, 그 다음 현존 법에서 돌아서서 무엇이 최선인지에 관한 자신의 관념에 따라 당사자들을 위해 처음부터 그리고 사후적으로 법을 만드는 단계 말이다. (p. 274) 대신 법률가들은 판사가 언제나 현존 법을 발견하고 집행하는 데 관여하는 것처럼 판사에게 말하고, 판사는 법이 모든 사례에 대한 해법이 판사의 발명이 아니라 발견을 기다리는, 빈틈없는 권리자격들의 체계인 것처럼 말한다.

사법 절차의 익숙한 수사가 발전된 법체계에는 법적으로 규율되지 않은

⁷⁴[TRS 81면; LE 37-39면 비교.]

사례들이 없다는 관념을 복돋는다는 데에는 의심의 여지가 없다. 그러나 이것은 얼마나 진지하게 받아들여져야 하는가? 물론 입법자와 판사의 구별을 극화하고, 판사는 현존 법이 명확할 때 그러하듯 언제나 자신이 만들거나 빚어내지 않는 법의 단순한 ‘입’ 이라고 주장하는 오랜 유럽 전통과 권력분립 교설이 있다. 그러나 법정에서 사건들을 결정할 때 판사들과 법률가들이 사용하는 의례적 언어와, 사법 절차에 관한 그들의 더 성찰적인 일반 진술들을 구별하는 것이 중요하다. 미국의 올리버 웬델 홈스와 카도조, 영국의 맥밀런 경이나 래드클리프 경 또는 리드 경과 같은 격의 판사들, 그리고 학계와 실무계 양쪽의 수많은 다른 법률가들은, 법에 의해 불완전하게 규율된 채 남은 사례들이 있어서 판사에게 피할 수 없는, 비록 ‘간극적’ 인, 법창출 과제가 있으며, 법에 관한 한 많은 사례들이 어느 쪽으로든 결정될 수 있다고 주장해 왔다.

하나의 주요한 고려사항은 판사들이 때로 법을 만들면서 동시에 적용한다는 주장에 대한 저항을 설명하는 데 도움을 주며, 사법적 법창출을 입법부의 법창출과 구별하는 주요 특징들도 해명한다. 그것은 규율되지 않은 사례들을 결정할 때 법원들이, 자신들이 만드는 새로운 법이 비록 새로운 법이기는 하지만 이미 현존 법에 발판을 가진 것으로 인정된 원칙들이나 밀받침 이유들과 부합하도록 보장하기 위해 유비에 따라 진행하는 데 전형적으로 부여하는 중요성이다. 특정 제정법들이나 선례들이 불확정적인 것으로 드러나거나 명시적 법이 침묵할 때, 판사들이 단지 법서들을 밀쳐 두고 법으로부터 더 이상의 지침 없이 입법하기 시작하지 않는 것은 사실이다. 그러한 사례들을 결정하면서 그들은 매우 자주 현존 법의 상당한 관련 영역이 예증하거나 증진하는 것으로 이해될 수 있고 당해 어려운 사례에 대한 확정적 답을 향해 가리키는 어떤 일반 원칙이나 일반적 목표 또는 목적을 인용한다. (p. 275) 이것은 기실 드워킨 재판 이론의 매우 두드러진 특징인 ‘구성적 해석’ 의 바로 그 핵심이다. 그러나 이 절차는 사법적 법창출의 순간을 분명 유예하지만, 제거하지는 않는다. 어떤 어려운 사례에서도 경쟁하는 유비들을 뒷받침하는 서로 다른 원칙들이 나타날 수 있고, 판사는 법에 의해 자신에게 이미 규정된 우선성의 질서가 아니라 양심적 입법자처럼 무엇이 최선인지에 관한 자신의 감각에 의존하여 그들 사이에서 선택해야 하는 경우가 많기 때문이다. 그러한 모든 사례들에 대해, 경쟁하는 저차-질서 원칙들에 상대적

무게나 우선성을 배정하는 고차-질서 원칙들의 어떤 유일한 집합이 현존 법 안에서 언제나 발견될 수 있을 때에만, 사법적 법창출의 순간은 단순히 유예되는데 그치지 않고 제거될 것이다.

드워킨의 나의 사법 재량 설명에 대한 다른 비판들은 그것을 기술적으로 거짓이라고 비난하는 것이 아니라, 비민주적이고 부정의한 법창출 형식을 지지한다고 비난한다.⁷⁵ 판사들은 보통 선출되지 않으며, 민주주의에서는 오직 선출된 국민의 대표자들만 법창출 권한들을 가져야 한다고 주장된다. 이 비판에는 많은 답변들이 있다. 법이 규율하지 못한 분쟁들을 처리하기 위해 판사들에게 법창출 권한들이 맡겨져야 한다는 것은, 입법부에 회부하는 것 같은 대안적 규율 방법들의 불편을 피하기 위해 치러야 할 필수적 대가로 여겨질 수 있다. 그리고 판사들이 이 권한들의 행사에서 제약되어 법전들이나 광범위한 개혁들을 형성할 수 없고 특정 사례들이 던지는 특정 쟁점들을 처리하기 위한 규칙들만 만들 수 있다면, 그 대가는 작아 보일 수 있다. 둘째, 제한된 입법 권한들을 행정부에 위임하는 것은 현대 민주주의들의 익숙한 특징이며, 그러한 위임이 사법부에 이루어진다고 해서 민주주의에 더 큰 위협으로 보이지는 않는다. 두 위임 형식 모두에서 선출된 입법부는 보통 잔여적 통제권을 가지며, 받아들일 수 없다고 보는 어떤 종속된 법들도 폐지하거나 수정할 수 있다. 미국에서처럼 입법부의 권한들이 성문헌법에 의해 제한되고 법원들이 광범위한 심사 권한들을 가지는 경우, 민주적으로 선출된 입법부가 어떤 사법적 입법 하나를 뒤집을 수 없음을 알게 될 수 있다는 것은 사실이다. 그러면 (p. 276) 궁극적 민주적 통제는 헌법 수정이라는 번거로운 장치를 통해서만 확보될 수 있다. 그것이 정부에 대한 법적 제약들을 위해 치러야 하는 대가이다.

드워킨은 사법적 법창출이 부정의하며, 물론 보통 부정의한 것으로 여겨지는 소급적 또는 사후적 법창출의 한 형식으로 그것을 비난한다는 추가 고발을 한다. 그러나 소급적 법창출을 부정의한 것으로 보는 이유는, 행위할 때 자기 행위의 법적 귀결들이 그 행위 당시 확립되어 있던 알려진 법의 상태에 의해 결정될 것이라는 가정에 의존했던 사람들의 정당한 기대들을 그것이 좌절시키기 때문이다. 하지만 이 반론은, 분명히 확립된 법에 대한 법원의 소급적 변경이나

⁷⁵[TRS 84-85면.]

번복에 대해서는 힘을 가질 수 있다 하더라도, 어려운 사례들에서는 전혀 관련 없어 보인다. 그것들은 법이 불완전하게 규율한 채 남겨 둔 사례들이고, 기대들을 정당화할 명확히 확립된 알려진 법의 상태가 없는 경우들이기 때문이다.

후기 주석

272쪽. [이 절의 대체 시작문이 여기에 포함되어 있으며, 폐기되지 않음.]

드워킨(Dworkin)은 오랜 시간에 걸친 재판(adjudication)에 관한 저술 전반에서, 법원들이 현존 법에 의해 불완전하게 규율된 채 남은 사례들을 결정할 법창출 권한(law-creating power)이라는 의미의 재량(discretion)을 가진다는 것을 부인하는 입장을 한결같이 견지해 왔다. 기실 그는, 사소한 예외를 제외하면 그러한 사례들은 존재하지 않으며, 유명하게 말했듯이 어떤 사례에서 생기는 어떤 법적 쟁점에 관해 당해 법이 무엇인지에 대한 의미 있는 질문에는 언제나 단 하나의 ‘정답(right answer)’이 있다고 논변해 왔다.⁷⁶

그러나 이러한 불변하는 듯한 교설의 외양에도 불구하고, 드워킨이 후기에 해석적 관념들(interpretive ideas)을 자신의 법이론에 도입하고 모든 법명제들(propositions of law)이 그가 이 표현에 부여한 특수한 의미에서 ‘해석적’이라고 주장한 것은, 라즈가 처음 분명히 했듯이,⁷⁷ 법원들이 실제로 법창출 재량을 가지며 자주 행사한다는 점을 인정하게 함으로써 이 입장의 실질을 나의 입장에 매우 가까이 가져왔다. 논변해 볼 수 있듯이, 해석적 관념들이 그의 이론에 도입되기 전에는, 드워킨의 강한 의미의 사법 재량 부정과 항상 정답이 있다는 그의 주장이 사건들을 결정하는 판사의 역할은 현존 법을 분별해 내고 집행하는 것이라는 관념과 결합되어 있었기 때문에, 우리의 각 재판 설명 사이에는 큰 차이가 있는 듯했다. 그러나 물론 법원들이 사건들을 결정하면서 법창출 재량을 자주 행사한다는 나의 주장과 매우 날카롭게 충돌했던 이 초기 구상은 더 이상 이 절에서 전혀 등장하지 않는다.

[섹션 6의 대체 시작문의 텍스트는 여기에서 끝난다.]

⁷⁶[그의 글 ‘No Right Answer?’ in P. M. S. Hacker and J. Raz (eds.), *Law, Morality and Society* (1977), pp. 58–84. 개정 후 재수록: ‘Is There Really No Right Answer in Hard Cases?’ AMP, 제5장 참조.]

⁷⁷[J. Raz, ‘Dworkin: A New Link in the Chain’, 74 *California Law Review*, 1103 (1986), pp. 1110, 1115–16 참조.]

후기 제3판 주석

이것은 아마도 어떤 후기(postscript)에 관해 책 한 권 전체가 나온 유일한 사례일 것이다:

Jules Coleman 역음, *Hart's Postscript*. 수록된 에세이들은 후기(postscript)뿐만 아니라 하트의 법이론 전반을 이해하는 데 매우 유익하다. 또한, Ronald Dworkin, "Hart's Postscript and the Character of Political Philosophy" (*Oxford Journal of Legal Studies* 제 24권, 2004년, 1면)을 참조하라.